

스터디파이터 감정평가사 민법 문제집

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
민법
문제집

제1판

민법 문제집 목차

PART 01 민법 총칙

제1장 서 론

기본문제	2
실전문제	11

제2장 권리의 주체(自然人)

기본문제	30
실전문제	44

제3장 권리의 주체(法人)

기본문제	63
실전문제	75

제4장 권리의 객체(물건)

기본문제	93
실전문제	99

제5장 법률행위

기본문제	106, 136, 170, 200, 226
실전문제	118, 148, 178, 210, 231

제6장 기간과 소멸시효

기본문제	243
실전문제	253

PART 02 물권법

제1장 서론

기본문제	274
실전문제	278

제2장 물권변동

기본문제	285
실전문제	299

제3장 점유권

기본문제	322
실전문제	328

제4장 소유권

기본문제	341
실전문제	360

제5장 용익물권

기본문제	404
실전문제	415

제6장 담보물권

기본문제	451
실전문제	471

01

CONTENT

민법총칙

서론

1

기본문제

01

민법의 법원(法源)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 조약은 국회의 비준을 얻더라도 법원(法源)이 될 수 없다.
- ② 관습법의 확인과 적용은 법원이 직권으로 하는 것이 원칙이나, 당사자가 이를 주장·증명할 수도 있다.
- ③ 상행위와 관련된 법률관계에서는 상관습법이 민법보다 우선하여 적용된다.
- ④ 관습법이 헌법에 위반될 때에는 법원(法院)이 그 효력을 부인할 수 있다.
- ⑤ 관습이 관습법이 되기 위해서는 사회의 법적 확신과 인식에 의해 법적 규범으로 승인·강행되어야 한다.

해설

- ① 민법 제1조에서 말하는 법률은 민법전뿐만 아니라 명령·조례·대법원규칙·조약·자치법규 등을 포함한 실질적 의미의 법률을 의미하므로 조약도 민법의 법원(法源)이 된다.
- ② 법령과 같은 효력을 갖는 관습법은 당사자의 주장·증명을 기다림이 없이 법원이 직권으로 이를 확정하여야 하나, 법원이 이를 알 수 없는 경우 결국은 당사자가 이를 주장·증명할 필요가 있다(대법원 1983.6.14. 80다3231).
- ③ 「상법」 제1조에서는 상관습법은 「상법」에 대하여는 보충적 효력을 갖지만 「민법」에 대하여는 우선적 효력을 갖는 것으로 규정하고 있다.
- ④ 관습법은 법원(法源)으로서 법령에 저촉되지 아니하는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이고, 또 사회의 거듭된 관행으로 생성한 어떤 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기에 이르렀다고 하기 위하여는 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다(대법원 2005.07.21. 2002다1178 전원합의체).
- ⑤ 신의성실의 원칙은 권리행사와 의무이행의 행위준칙을 정하고, 권리남용의 원칙은 권리행사로 인정할 수 없는 행위의 한계를 정하고 있다고 보는 것이 일반적이다. 정답: ①

02

민법의 법원(法源)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 대통령의 긴급명령이 민사에 관한 것이면 민법의 법원이 될 수 있다.
- ② 국제조약이나 일반적으로 승인된 국제법규는 민사에 관한 것이라도 민법의 법원이 될 수 없다.

- ③ 대법원규칙은 민사에 관한 것이라도 민법의 법원이 될 수 없다.
- ④ 헌법재판소의 결정은 민사에 관한 것이라도 민법의 법원이 될 수 없다.
- ⑤ 관습법도 민법의 법원이며, 판례가 인정한 관습법상의 권리로 분묘기지권, 관습상의 법정 지상권, 온천권을 들 수 있다.

해설

- ①②③④ 민사에 관한 것이면 실질적 의미의 법률(민법전, 민사특별법, 민법부속법령, 명령·대법원 규칙·조약·자치법규·헌법재판소 결정 등)은 민법의 법원이 된다.
- ⑤ 온천권은 관습법상의 물건이라 볼 수 없다(대법원 1970.5.26., 69다1239). 정답: ①

03 관습법과 사실인 관습에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사회의 거듭된 관행이 관습법으로 승인되었다면, 그것이 적용될 시점에 전체 법질서와 부합하지 않더라도 효력이 인정된다.
- ② 상행위와 관련된 법률관계에서는 민법이 상관습법에 우선한다.
- ③ 관습법은 당사자의 주장·증명이 없으면 법원이 직권으로 이를 확정 할 수 없다.
- ④ 사실인 관습이 강행규정에 관한 것이더라도, 강행규정에서 관습에 따르도록 위임한 경우라면 그 관습에 대하여 법적 효력을 부여할 수 있다.
- ⑤ 물건은 관습법에 의하여 창설될 수 없다.

해설

- ④ 사실인 관습은 사적 자치가 인정되는 분야 즉 그 분야의 제정법이 주로 임의규정일 경우에는 법률행위의 해석기준으로서 또는 의사를 보충하는 기능으로서 이를 재판의 자료로 할 수 있을 것 이나 이 이외의 즉 그 분야의 제정법이 주로 강행규정일 경우에는 그 강행규정 자체에 결함이 있거나 강행규정 스스로가 관습에 따르도록 위임한 경우 등 이외에는 법적 효력을 부여할 수 없다(대법원 1983.06.14. 80다3231). 따라서 사실인 관습이 강행규정에 관한 것이더라도, 강행규정에서 관습에 따르도록 위임한 경우라면 그 관습에 대하여 법적 효력을 부여할 수 있다.
- ①③ 관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이른 것을 말하고, 그러한 관습법은 법원(法源)으로서 법령에 저촉되지 아니하는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이고, 또 사회의 거듭된 관행으로 생성한 어떤 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기에 이르렀다고 하기 위하여는 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다(대법원 2005.07.21. 2002다1178 전원합의체).
- ② [상법 제1조] 상사(商事)에 관하여 본법(상법)에 규정이 없으면 상관습법에 의하고, 상관습법이 없으면 민법에 의한다.
- ⑤ [민법 제185조] 물건은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다. 정답: ④

민법
규정

- ㉠ 조건의 성취, 불성취 의제규정(제150조)
- ㉡ 채권자자체의 규정(제400조 이하)
- ㉢ 계약체결상의 과실규정(제535조)
- ㉣ 불공정한 법률행위에 관한 규정(제104조)
- ㉤ 이행보조자의 고의·과실에 의한 채무자의 책임 등(제391조)
- ㉥ 동시이행의 항변권(제536조)
- ㉦ 위험부담(제537조)
- ㉧ 상린관계(제215조 이하)

따라서 ④의 경우는 신의성실의 원칙과는 무관하다. 정답: ④

06 신의성실의 원칙에 대한 판례의 내용 중 옳지 않은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 민법상 신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자는 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 아니 된다는 추상적 규범이다.
- ② 신의성실의 원칙에 반한다거나 권리남용에 해당한다는 사실은 당사자가 주장하여야 하므로 법원에서 직권으로 판단해서는 안 된다.
- ③ 자기소유의 대저상에 자신의 친딸에게 건물을 신축하도록 승낙한 자가 그 건물이 친딸의 채권자에 의한 경매신청에 따라 경락되자 경락인에 대하여 그 철거를 구하는 것은 신의성실의 원칙에 어긋난다.
- ④ 자신이 연대보증하여야 할 것을 타인에게 부탁하여 그 타인이 대신 연대보증인이 된 경우, 자신이 그 연대보증채무를 변제하고서 그 타인에 대하여 구상권을 행사하는 것은 신의칙에 반한다.
- ⑤ 토지소유자가 그 점유자에 대하여 부당이득반환청구권을 장기간 적극적으로 행사하지 아니하였다는 사정만으로는 부당이득반환청구권이 이른바 실효의 원칙에 따라 소멸하였다고 볼 수 없다.

해설

- ② 신의성실의 원칙에 반하는 것 또는 권리남용은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다(대법원 1995.12.22. 94다42129).
- ③ 대법원 1991.6.11. 91다9299
- ④ 대법원 2000.5.12. 99다38293
- ⑤ 대법원 2002.1.8. 2001다60019 정답: ②

07 신의칙에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 친권자인 모가 미성년자인 자의 법정대리인으로서 자의 유일한 재산을 아무런 대가도 받지 않고 증여하였고 상대방이 그 사실을 알고 있었던 경우, 그 증여행위는 친권의 남용에 의한 것이므로 그 효과는 자에게 미치지 않는다.
- ② 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 그 권리행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 공여하였거나, 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다.
- ③ 채권자가 채권을 담보하기 위하여 제3자의 부동산을 채무자에게 명의신탁을 하게 한 다음, 이 부동산에 대하여 강제집행을 하는 것은 신의성실의 원칙에 반한다.
- ④ 시효완성을 하지 않기로 한 약정에 위반된 시효주장에 대하여 판례는 시효완성을 알았는지를 문제 삼지 않고 시효주장을 배척하였다.
- ⑤ 스스로 강행법규 위반행위를 하고는 바로 그 이유로 자신의 행위가 무효라고 주장하는 것은 신의칙상 허용되지 않는다.

해설

- ⑤ 강행법규를 위반한 자 스스로가 그 약정의 무효를 주장함이 신의칙에 위반되는 권리의 행사라는 이유로 그 주장을 배척한다면, 이는 오히려 강행법규에 의하여 배제하려는 결과를 실현시키는 셈이 되어 입법취지를 완전히 몰각하게 되므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 이와 같은 주장은 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 볼 수 없다(대법원 1999.3.23. 99다4405).
- ① 대법원 1997.1.24. 96다43928
- ② 신의성실의 원칙의 의미와 신의성실의 원칙의 위반을 이유로 권리행사를 부정하기 위한 요건으로 지문과 같이 판시하고 있다(대법원 1991.12.10. 91다3802 참조).
- ③ 대법원 1981.7.7. 80다2064
- ④ 대법원 1998.5.22. 96다24101 정답: ⑤

08 권리남용금지의 원칙에 관하여 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① '시카네'라는 것은 타인을 해(害)할 의사만으로 행사하는 것을 말한다.
- ② 권리남용으로 인정되기 위해서는 주관적 요건과 객관적 요건을 필요로 한다.
- ③ 권리의 행사가 신의성실의 원칙에 위반하는 경우에는 권리남용이 된다.
- ④ 권리남용금지는 당사자 사이의 법적 특별관계가 있는 경우에 한하여 성립한다.
- ⑤ 권리남용의 금지는 점차 그 적용범위를 확대해 나가고 있는 것이 현대법의 경향이다.

◎ 권리남용금지의 원칙

의의	㉠ 외형상은 권리의 행사와 같이 보이지만, 구체적·실질적으로 볼 때에는 권리의 사회성·공공성에 반하여 권리의 행사로써 시인될 수 없는 행위를 말한다. ㉡ [민법 제2조 제2항] “권리는 남용하지 못한다.”라고 규정함으로써 신의칙과 함께 권리의 사회성·공공성을 강조하고 있다.
연혁	로마법 : “자기의 권리를 행사하는 자는 누구도 해하지 않는다”라고 함으로써 권리의 절대성을 인정하였다. → 독일에서는 시카네(타인을 해할 목적만으로써 하는 권리의 행사) 금지규정을 둠으로써 권리자유의 원칙을 수정하였다. = 권리남용의 요건으로서 행위자에게 주관적 가해의사가 있어야 한다는 것
요건	㉠ 권리의 행사가 있을 것 ㉡ 권리의 행사가 사회성·공공성에 반할 것 ㉢ 가해목적이 존재할 것(주관적 요건으로서 반드시 요하는 것은 아님 : 객관적 표준설)
남용 효과	㉠ 청구권 행사가 남용 → 법이 조력하지 않음(주장배척) ㉡ 형성권 행사가 남용 → 효과의 발생부정 ㉢ 친권의 행사가 남용 → 친권상실신고

④ 신의성실의 원칙은 당사자 사이의 법적 특별관계(계약관계)가 있는 경우에 주로 적용되지만 권리 남용금지의 원칙은 그러하지 않다. 정답: ④

09 다음 권리 중 분류의 관점이 다른 것은?

- ① 가족권 ② 청구권 ③ 사원권
④ 인격권 ⑤ 재산권

해설

◎ 권리의 내용상 분류

권 리	내 용	예
인격권	권리의 주체와 분리할 수 없는 인격적 권리의 향수를 내용으로 하는 권리	성명권, 명예권, 정조권, 자유권, 신체권, 생명권
재산권	경제적 이익을 내용으로 하는 권리로서 양도성과 상속성을 가지는 권리	물권, 채권, 지식재산권
신분권	친족권과 상속권이 이에 해당	친권, 부양청구권(친족권) 재산상속권(상속권)
사원권	단체의 구성원이 그 지위에 기하여 단체에 대하여 가지는 권리	의결권, 업무집행권(공익권) 이익배당청구권(자익권)

①③④⑤는 권리의 내용상의 분류에 해당하고, ②의 청구권은 권리의 작용에 의한 분류에 해당한다.

정답: ②

10 형성권이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 진정상속인의 상속회복청구권
- ② 임차인의 부속물매수청구권
- ③ 매수인의 대금감액청구권
- ④ 지상권자의 지상물매수청구권
- ⑤ 전세권설정자의 전세권소멸청구권

해설

※ 청구권이라 불리우나 실질이 형성권인 권리

- ㉠ 지상권자의 지상물매수청구권(제283조 제2항)
- ㉡ 전세권자의 부속물매수청구권(제318조 제2항)
- ㉢ 임차인의 부속물매수청구권(제642조~제647조)
- ㉣ 지상권설정자의 지상권소멸청구권(제287조)
- ㉤ 전세권설정자의 전세권소멸청구권(제311조)
- ㉥ 지료증감청구권(제286조)

- ㉦ 매매대금감액청구권(제572조)

- ㉧ 공유물분할청구권(제268조) 등

그러나 부동산공사 수급인의 저당권설정청구권(제666조), 상속회복청구권(제999조) 등은 순수한 청구권이다. 정답: ①

11 다음 중 형성권이 아닌 것은?

- ① 무권대리행위에 대한 추인권
- ② 착오에 의한 의사표시의 취소권
- ③ 채무불이행에 기한 계약 해제권
- ④ 매수인의 매도인에 대한 등기청구권
- ⑤ 미성년자의 법정대리인의 동의권

해설

- ④ 매수인의 매도인에 대한 등기청구권은 '청구권'이다. 정답: ④

12 다음 중 권리의 분류가 잘못된 것은?

- ① 주택임차인이 주택을 이용할 수 있는 권리는 지배권이다.
- ② 채권이 상계적상에 있는 경우 상계할 수 있는 권리는 형성권이다.
- ③ 전세권자가 전세권설정계약에 반하여 목적물을 사용한 경우 전세권설정자가 전세권의 소멸을 청구할 수 있는 권리는 형성권이다.
- ④ 유치권자가 점유한 물건에 관한 채권을 변제 받을 때까지 그 물건을 유치할 수 있는 권리는 지배권이다.
- ⑤ 매도인의 물건의 인도가 있을 때까지 대금의 지급을 거절할 수 있는 권리는 항변권이다.

해설

- ① 임차권이란 임차인이 목적물을 사용·수익할 수 있는 권리인 채권이다.
- ② 상계권(제492조)은 채무자가 채권자에 대하여 동종의 채권을 가지는 경우에 채무자의 일방적 의사표시에 의하여 그 채권과 채무가 대등액에 한하여 소멸하는 효과를 가져오는 형성권이다.
- ③ 전세권소멸청구권은 청구권이라는 용어를 쓰지만 실질은 형성권인 경우이다(제311조).
- ④ 지배권은 타인의 협력을 필요로 하지 않고 일정한 객체를 직접 지배할 수 있는 권리로서, 물건·지식재산권·인격권·친권·후견권 등이 이에 속한다.
- ⑤ 항변권이란 청구권의 행사에 대해 일정한 사유에 의하여 그 급부를 거절할 수 있는 권리로서 이에에는 연기적 항변권과 영구적 항변권이 있다. 동시이행항변권은 청구권의 행사를 일시적으로 저지할 수 있는 연기적 항변권이라 할 수 있다. 정답: ①

13 다음 중 형성권인 것은?

- ① 부동산공사 수급인의 저당권설정청구권
- ② 저당권설정자의 저당물보충청구권
- ③ 미성년자의 법률행위의 취소권
- ④ 점유자의 유익비상환청구권
- ⑤ 점유취득시효 완성자의 등기청구권

해설

- ③ 취소권은 형성권이며, 나머지 지문들은 모두 청구권에 해당한다. 정답: ③

14 권리의 내용 및 효력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 채권 상호 간에는 먼저 성립한 채권이 항상 우선한다.
- ② 채권과 물건 상호 간에는 항상 채권이 우선한다.
- ③ 물건 상호 간에는 권리자 평등의 원칙이 적용된다.
- ④ 조건부 법률행위에서 발생하는 권리는 기대권의 성질을 갖는다.
- ⑤ 소유권과 제한물권 사이에서는 소유권의 성질상 소유권이 우선한다.

해설

- ④ 조건부 권리와 기한부 권리는 기대권(희망권)에 해당한다.
- ① 채권 상호 간에는 채권자평등의 원칙이 적용된다.
- ② 물건과 채권이 충돌하는 경우에는 성립순위와 관계없이 물건이 우선함이 원칙이다.
- ③⑤ 물건 간의 충돌인 경우 제한물권은 항상 소유권에 우선하나, 제한물권 상호 간에 있어서는 원칙적으로 먼저 성립한 권리가 후에 성립한 권리에 우선한다. 정답: ④

15 민법의 효력이 미치는 범위에 관하여 틀린 것은?

- ① 법률불소급의 원칙은 법학에 있어서의 일반적 원칙이기는 하지만 민법은 원칙적으로 소급 효를 인정하고 있다.
- ② 민법은 모든 한국인에게 적용되는 것이 아니라, 한국인이더라도 외국에 거주하면 그 효력이 미치지 않는 것이 원칙이다.
- ③ 우리 민법은 1960년 1월 1일부터 시행되었다.
- ④ 민법은 대한민국의 영토 내에 있는 외국인에게도 적용되는 것이 원칙이다.
- ⑤ 민법은 성별·종교·사회적 신분 등의 구별에 의하여 그 적용이 제한되지 않는 것이 원칙이다.

해설

◎ 민법의 효력

時	[민법부칙 제2조] “본법은 특별한 규정이 있는 경우 외에는 본법시행일 전의 사항에 대하여도 적용한다.”고 하여 법률불소급의 원칙의 예외를 인정하고 있다. 그러나 기득권존중의 이상에 입각하여 “그러나 이미 구법에 의하여 생긴 효력에 영향을 미치지 아니한다.”라고 규정함으로써 실질적으로는 불소급의 원칙을 채택하고 있다.
人	㉠ 모든 한국국적을 가지는 자에게 적용된다(속인주의 효과). ㉡ 한국영토 내의 모든 내외국인에게 적용된다(속지주의 효과).
장 소	민법은 대한민국 영토 전체에 적용됨이 원칙이다.

- ② 민법은 모든 한국인에게 적용되므로 한국인이 외국에 거주하더라도 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 속인주의로 표현된다. 정답: ②

01 민법의 법원(法源)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ㉠ 헌법에 의해 체결 · 공포된 민사에 관한 조약은 민법의 법원이 되지 않는다.
㉡ 관습법이 되기 위해서는 사회구성원의 법적 확신이 필요하다.
㉢ 관습법은 법령에 저촉되지 않는 한 법칙으로서의 효력이 있다.

- (1) ㄱ
- (2) L
- (3) ㄱ, C
- (4) L, C
- (5) ㄱ, L, C

해설

- ㉠ 헌법에 의해 체결 · 공포된 민사에 관한 조약도 민법의 법원이다.
㉡ 타당한 기술이다. 정답: ㉠

02 민법의 법원(法源)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 민법 제1조에서 민법의 법원으로 규정한 '민사에 관한 법률'은 민법전만을 의미한다.
- ② 민법 제1조에서 민법의 법원으로 규정한 '관습법'에는 사실인 관습이 포함된다.
- ③ 대법원이 정한「공탁규칙」은 민법의 법원이 될 수 없다.
- ④ 헌법에 의하여 체결 · 공포된 국제조약은 그것이 민사에 관한 것이더라도 민법의 법원이 될 수 없다.
- ⑤ 미등기무허가 건물의 양수인에게는 소유권에 준하는 관습법상의 물건이 인정되지 않는다.

해설

- ⑤ 미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경료받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996.06.14. 94다53006).
- ①③④ 민법 제1조에서 말하는 법률은 민법전문만 아니라 명령·조례·대법원규칙·조약·자치법규 등을 포함한 실질적 의미의 법률을 의미하므로 조약도 민법의 법원(法源)이 된다.
- ② 민법 제1조에서 민법의 법원으로 규정한 '관습법'에는 사실인 관습은 포함되지 않는다. 정답: ⑤

03

관습법과 사실인 관습에 관한 설명 중 맞는 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 관습법은 사실인 관습과 구별되지만, 양자 모두 법률행위의 당사자의 의사를 보충함에 그치는 점에서는 동일하다.
- ② 종종 구성원의 자격은 성년 남자로 한정된다는 관습법으로서의 법적 확신은 종전대로 유지되고 있다.
- ③ 명인방법, 동산의 양도담보 등은 사실인 관습에 해당되므로 그 존재는 당사자가 주장·증명하여야 한다.
- ④ 민법에 규정된 내용과 다른 관습이 있는 경우에 그 관습이 우선적으로 적용되는 경우도 있다.
- ⑤ 관습법으로 인정되기 위해서는 사회의 거듭된 관행으로 생성된 사회생활규범으로서 그 내용이 민법상의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하지 않는 내용이라면 충분하고, 「헌법」상의 정당성과 합리성까지 고려할 필요는 없다.

해설

④ 사실인 관습은 임의법규에 우선하여 법률행위의 해석기준이 된다(제106조).

- ① 관습법은 법원으로서의 기능을 하고, 사실인 관습은 당사자의 의사를 보충하는 기능을 한다. 따라서 관습법이 당사자의 의사를 보충하는 기능을 하는 것은 아니다.
- ② 최근의 전원합의체 판결은 '종중원'의 지위에 대하여 그 태도를 변경하여, 종종 구성원의 자격은 성년 남자로 한정된다는 종래의 관습법의 효력을 부인하였다(대법원 2005.7.21. 2002다1178 전합).
- ③ 관습법에 해당되므로 법원이 직권으로 조사할 사항이다.
- ⑤ 사회의 거듭된 관행으로 생성한 어떤 사회생활규범이 법적 규범으로 승인되기에 이르렀다고 하기 위해서는 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 한다. 정답: ④

04

관습법과 사실인 관습에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 관습법은 성문법에 대하여 보충적 효력을 갖는다.
- ② 공동선조와 성과 본을 같이하는 미성년자인 후손은 종종 구성원이 될 수 없다.
- ③ 관습법이 성립한 후 사회구성원들이 그러한 관행의 법적 구속력에 더 이상 법적 확신을 갖지 않게 된 경우, 그 관습법은 법적 규범으로서의 효력이 없다.
- ④ 사실인 관습은 법령으로서의 효력이 없고, 법률행위 당사자의 의사를 보충함에 그친다.
- ⑤ 미등기 무허가건물의 매수인은 그 소유권이전등기를 마치지 않아도 소유권에 준하는 관습상의 물권을 취득한다.

해설

- ⑤ 미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경로받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996.06.14. 94다53006). 정답: ⑤

05

다음 중 사실인 관습에 관한 설명으로 타당하지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사실인 관습은 사적 자치가 인정되는 분야에서는 법률행위의 해석기준으로서 또는 의사를 보충하는 기능으로서 이를 재판의 자료로 할 수 있다.
- ② 사실인 관습은 제정법이 주로 강행규정일 경우에도 그 강행규정 자체에 결함이 있거나 강행규정 스스로가 관습에 따르도록 위임한 경우 이외에는 법적 효력을 부여할 수 없다.
- ③ 사실인 관습은 당사자의 주장·증명을 요하지 않고 법원이 직권으로 확정하여야 한다.
- ④ 사실인 관습이 강행규정에 반하는 경우에는 당사자의 의사가 명확치 않은 때에도 해석의 표준이 될 수 없다.
- ⑤ 사실인 관습은 사적자치가 인정되는 분야에서 당사자의 의사가 분명하지 않은 경우에 임의 법규에 우선하여 당사자의 의사를 보충한다는 데 의미가 있다.

해설

- ③ 법령과 같은 효력을 갖는 관습법은 당사자의 주장 증명을 기다림이 없이 법원이 직권으로 이를 확정하여야 하고, 사실인 관습은 그 존재를 당사자가 주장·증명하여야 하나, 관습은 그 존부 자체도 명확하지 않을 뿐만 아니라 그 관습이 사회의 법적 확신이나 법적 인식에 의하여 법적 규범으로까지 승인되었는지의 여부를 가리기는 더욱 어려운 일이므로, 법원이 이를 알 수 없는 경우 결국은 당사자가 이를 주장·증명할 필요가 있다(대법원 1983.6.14. 80다3231).
- ①② 사실인 관습은 사적 자치가 인정되는 분야, 즉 그 분야의 제정법이 주로 임의규정일 경우에는 법률행위의 해석기준으로서 또는 의사를 보충하는 기능으로서 이를 재판의 자료로 할 수 있을 것이나 이 이외의, 즉 그 분야의 제정법이 주로 강행규정일 경우에는 그 강행규정 자체에 결함이 있거나 강행규정 스스로가 관습에 따르도록 위임한 경우 등 이외에는 법적 효력을 부여할 수 없다(대법원 1983.6.14. 80다3231).
- ④ 법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 관습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 관습에 의한다(제106조).
- ⑤ 사실인 관습은 임의법규에 우선하여 법률행위의 해석기준이 된다(제106조). 정답: ③

06

다음 중 관습법에 관한 설명 중 가장 타당하지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 토지 또는 건물이 동일한 소유자에게 속하였다가 건물 또는 토지가 매매 기타의 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 된 때에 그 건물을 철거한다는 조건이 없는 이상 건물소유자는 토지소유자에 대하여 그 건물을 위한 법정지상권을 취득하는 것이 관습이다.
- ② 타인의 토지에 합법적으로 분묘를 설치한 자는 그 토지 위에 지상권에 유사한 일종의 물권을 취득하는 것이 관습이다.
- ③ 관습법과 사실인 관습은 구별되고, 관습법은 법령에 저촉되지 않는 범위 내에서 보충적으로 적용된다.
- ④ 관습법이나 사실인 관습은 당사자의 주장·증명을 기다리지 않고 법원이 직권으로 이를 확정하여야 한다.
- ⑤ 종중의 목적과 본질에 비추어 볼 때 공동선조와 성과 본을 같이 하는 후손은 성별의 구별 없이 성년이 되면 당연히 그 구성원이 된다고 보는 것이 조리에 합당하고, 종중 구성원의 자격을 성년 남자만으로 제한하는 종래의 관습법은 이제 더 이상 법적 효력을 가질 수 없다.

해설

- ④ 법령과 같은 효력을 갖는 관습법은 당사자의 주장 증명을 기다림이 없이 법원이 직권으로 이를 확정하여야 하고 사실인 관습은 그 존재를 당사자가 주장 증명하여야 함이 원칙이다(대법원 1983.6.14. 80다3231).
- ① 토지 또는 건물이 동일한 소유자에게 속하였다가 건물 또는 토지가 매매 기타의 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 된 때에 그 건물을 철거 한다는 조건이 없는 이상 건물 소유자는 토지 소유자에 대하여 그 건물을 위한 관습상의 법정지상권을 취득한다(대법원 1984.9.11, 83다카 2245).
- ⑤ 종중은 공동선조의 분묘수호와 봉제사 및 종원 상호간의 친목을 목적으로 형성되는 종족단체로서 공동선조의 사망과 동시에 그 후손에 의하여 자연발생적으로 성립하는 것임에도, 공동선조의 후손 중 성년 남자만을 종중의 구성원으로 하고 여성은 종중의 구성원이 될 수 없다는 종래의 관습은, 공동선조의 분묘수호와 봉제사 등 종중의 활동에 참여할 기회를 출생에서 비롯되는 성별만에 의하여 생래적으로 부여하거나 원천적으로 박탈하는 것으로서, 위와 같이 변화된 우리의 전체 법질서에 부합하지 아니하여 정당성과 합리성이 있다고 할 수 없으므로, 종중 구성원의 자격을 성년 남자만으로 제한하는 종래의 관습법은 이제 더 이상 법적 효력을 가질 수 없게 되었다(대법원 전합 2005.07.21. 2002다1178). 정답: ④

07 관습법과 사실인 관습에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 관습법이 되기 위해서는 사회구성원의 법적 확신이 필요하다.
- ② 사실인 관습은 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행에 지나지 않으므로 법률행위 당사자의 의사를 보충하는 수단이 될 수 없다.
- ③ 여성은 종중의 구성원이 될 자격이 없다는 종래의 관습에 법적 효력은 인정되지 않는다.
- ④ 온천에 관한 권리는 관습법상 권리가 아니다.
- ⑤ 관습법의 존부는, 법원이 알 수 없는 경우를 제외하고는, 당사자의 주장·증명을 기다리지 않고 법원이 직권으로 이를 확정하여야 한다.

해설

- ② 관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이른 것을 말하고, 사실인 관습은 사회의 관행에 의하여 발생한 사회생활규범인 점에서 관습법과 같으나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인된 정도에 이르지 않은 것을 말하는 바, 관습법은 바로 법원으로서 법령과 같은 효력을 갖는 관습으로서 법령에 저촉되지 않는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이며, 이에 반하여 사실인 관습은 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행으로서 법률행위의 당사자의 의사를 보충함에 그치는 것이다(대법원 1983.06.14. 80다3231). 따라서 사실인 관습은 법률행위의 해석기준이 된다(제106조).

정답: ②

08 법원(法源)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사회생활규범이 관습법으로 승인되었다면 그것을 적용하여야 할 시점에서의 전체 법질서에 부합하지 않아도, 그 관습법은 법적 규범으로서의 효력이 인정된다.
- ② 법원은 관습법의 존부를 알 수 없는 경우를 제외하고 당사자의 주장·증명이 없어도 관습법을 직권으로 확정하여야 한다.
- ③ 관습법은 법령과 같은 효력을 가지는 것으로서 법령에 저촉되지 않는 한 법칙으로서의 효력이 있다.
- ④ 물건은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다.
- ⑤ 강행규정 자체에 결함이 있거나 강행규정 자체가 관습에 따르도록 위임한 경우에는 사실상 관습에 법적 효력을 부여할 수 있다.

해설

- ① 관습법은 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다(대법원 2005.07.21. 2002다1178 전원합의체). 정답: ①

09 신의성실의 원칙에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법원은 당사자의 주장이 있을 경우에만 신의칙의 위반 여부를 판단할 수 있다.
- ② 분양회사는 아파트단지 인근에 쓰레기 매립장이 건설될 예정이라는 사실을 알았더라도 이를 수분양자에게 고지할 신의칙상 의무를 부담하지 않는다.
- ③ 지방자치단체로부터 매수한 토지가 공공공지에 편입되어 매수인이 주관적으로 의도한 건축이 불가능하게 되었다면 매매계약을 해제할 만한 사정변경에 해당한다.
- ④ 소멸시효 완성 전에 채무자가 채권자에게 시효중단조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였고 채권자도 이를 신뢰하였다면 채무자는 소멸시효의 완성을 주장할 수 없다.
- ⑤ 근로자가 장기간 무단결근을 이유로 해고된 후 공탁된 퇴직금을 조건 없이 수령하였다고 하더라도 8개월이 지나서 해고무효의 확인을 구하는 것은 신의칙에 반하지 않는다.

해설

- ④ 채무자가 시효완성 전에 채권자의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 하거나 그러한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 한 경우에는 채무자가 소멸시효의 완성을 주장하는 것이 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용으로서 허용될 수 없다(대법원 1999.12.7. 98다42929).
- ① 신의성실의 원칙은 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 판단할 수 있다.
- ② 아파트 분양자는 아파트 단지 인근에 쓰레기 매립장이 건설예정인 사실을 분양계약자에게 고지할 신의칙상 의무를 부담한다(대법원 2006.10.12. 2004다48515).
- ③ 지방자치단체로부터 매수한 토지가 공공공지에 편입되어 매수인이 의도한 건축이 불가능하게 되었다면 이는 매매계약을 해제할 만한 사정변경에 해당하지 않고, 매매계약을 그대로 유지하는 것이 신의칙에 반한다고 볼 수도 없다(대법원 2007.3.29. 2004다31302).
- ⑤ 근로자가 해고통지를 받은 후 동종업체에 취업하여 종전회사에서와 같은 액수의 월급을 받고 있으며 종전회사로부터 퇴직금까지 수령하였다면 해고처분을 유효한 것으로 인정하였다고 봄이 상당하고 그 후 8개월이 지난 뒤에 해고무효확인청구소송 등을 제기한 것은 금반언의 원칙에 위배되어 위법하다(대법원 1991.5.28., 91다9275). 정답: ④

- ㉠ 대항력 있는 주택임차권을 가진 甲이 임대인 乙의 부탁으로 그 주택에 관하여 저장권을 취득하려는 丙에게 임차권이 없다는 각서를 써 주었다. 그 후 丙이 경매절차에서 그 주택을 매수하여 甲에게 그 인도를 청구한 경우, 甲은 丙에게 임차권의 대항력을 주장할 수 있다.
- ㉡ 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정의 변경이 발생하였고, 그러한 사정의 변경이 해제권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것으로서 계약내용 대로의 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우, 사정변경으로 인한 계약해제가 인정될 수 있다.
- ㉢ 甲이 자신의 토지에 불법으로 건물을 소유하고 있는 乙을 상대로 건물철거를 청구하는 것이 권리남용에 해당하더라도, 甲은 특별한 사정이 없는 한 乙에 대하여 임료 상당의 부당이득반환을 청구할 수 있다.
- ㉣ 회사의 이사로 재직하면서 회사의 확정채무를 보증한 자는 이사직을 사임한 후에 사정변경을 이유로 그 보증계약을 해지할 수 있다.
- ㉤ 상속인 중의 1인이 피상속인의 생존 시에 상속을 포기하기로 피상속인과 약정하였으나 상속개시 후에 법정절차에 따라 상속포기를 하지 아니하였다면, 상속개시 후에 자신의 상속권을 주장하는 것은 정당한 권리행사로 볼 수 있다.

① ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢

④ ㉠, ㉢, ㉤

⑤ ㉡, ㉢, ㉤

해설

- ㉠ (X) 근저당권자가 담보로 제공된 건물에 대한 담보가치를 조사할 당시 대항력을 갖춘 임차인이 그 임대차사실을 부인하고 임차보증금에 대한 권리주장을 잃겠다는 내용의 확인서를 작성해 준 경우, 그 후 그 건물에 대한 경매절차에서 이를 반복하여 대항력 있는 임대차의 존재를 주장함과 아울러 근저당권자보다 우선적 지위를 가지는 확정일자부 임차인임을 주장하여 그 임차보증금반환채권에 대한 배당요구를 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 금반언 및 신의칙에 위반되어 허용될 수 없다(대법원 1997.6.27, 97다12211).
- ㉡ (O) 이른바 사정변경으로 인한 계약해제는, 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정의 변경이 발생하였고 그러한 사정의 변경이 해제권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것으로서, 계약내용대로의 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에 계약준수 원칙의 예외로서 인정되는 것이다(대법원 2007.3.29, 2004다31302).
- ㉢ (O) 권원 없이 타인의 토지를 불법점유하고 있는 지상물소유자를 상대로 한 토지소유자의 지상물 철거청구 및 대지인도청구가 권리의 남용으로 인정되어 청구기각판결을 받았다고 하여 그 토지소유권이 상실되는 것은 아닐 뿐만 아니라 지상물소유자에게 그 토지를 무상으로 사용·수익할 수 있는 권원이 생기는 것도 아니므로, 토지소유자는 지상물소유자에 대하여 임료 상당의 부당이득 반환청구(제741조)나 불법점유로 인한 손해배상청구(제750조)를 할 수 있다.
- ㉣ (X) 사정변경을 이유로 보증계약을 해지할 수 있는 것은 포괄근보증과 같이 채무액이 불확정적이고 계속적인 거래로 인한 채무에 대하여 보증한 경우에 한하고, 회사의 이사로 재직하면서 보증 당시 그 채무가 특정되어 있는 확정채무에 대하여 보증을 한 후 이사직을 사임하였다 하더라도 사정변경을 이유로 보증계약을 해지할 수 없는 것이 원칙이다(대법원 2006.7.27, 2004다30675).
- ㉤ (O) 상속인 중의 1인이 피상속인의 생존시에 피상속인에 대하여 상속을 포기하기로 약정하였다고 하더라도, 상속개시 후 민법이 정하는 절차와 방식에 따라 상속포기를 하지 아니한 이상, 상속개시 후에 자신의 상속권을 주장하는 것은 정당한 권리행사로서 권리남용에 해당하거나 또는 신의칙에 반하는 권리의 행사라고 할 수 없다(대법원 1998.7.24., 98다9021). 정답: ⑤

11 다음 중 신의성실의 원칙에 관하여 판례의 태도와 다른 것은?

- ① 신의성실의 원칙에 반하는 것 또는 권리남용은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다.
- ② 회사의 이사로 재직하면서 확정채무를 보증한 자는 이사직을 사임한 후에 사정변경을 이유로 보증계약을 해지할 수 없다.
- ③ 스스로 강행법규 위반행위를 하고 바로 그 이유로 자신의 행위가 무효라고 주장하는 것은 신의칙상 허용되지 않는다.
- ④ 권리남용이 성립하기 위해서는 주관적으로는 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있고 객관적으로는 그 권리 행사가 사회질서에 위반할 수 있어야 한다.
- ⑤ 이러한 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보이는 사정에 의하여 추인할 수 있다.

해설

③ 증권거래법 위반사례(대법원 1999.3.23. 99다4405)와 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 위반사례(대법원 1995.2.28. 94다51789)에서 판례는 '강행법규에 위반하는 약정의 일방 당사자가 그 약정이 강행법규에 위반된다는 것을 이유로 무효임을 주장하는 경우에, 신의칙에 위배되는 권리행사라는 이유로 그 주장을 배척한다면 강행법규로 금지하려 했던 것이 실현되는 셈이 되어 입법취지를 몰각하게 된다'는 사유를 들어 신의칙 위반이 아니라는 입장이다.

- ① 대법원 1989.9.29. 88다카17181
- ② 대법원 1999.1.15. 98다46082
- ④ 대법원 1986.7.22. 85다카2307
- ⑤ 대법원 1998.6.26. 97다4282 정답: ③

12 다음은 신의성실의 원칙에 관한 판례의 태도이다. 이 판례와 입장이 다른 것은?

- ① 상속인이 피상속인의 생존시에 피상속인에 대하여 상속을 포기하기로 약정하였다가 상속개시 후에 자신의 상속권을 주장하는 것은 신의칙에 반하지 않는다.
- ② 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 그 권리행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 공여하였거나, 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의 관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다.
- ③ 무권대리인이 본인의 지위를 상속한 후 본인의 지위에서 추인거절권을 행사하는 것은 신의칙상 허용되지 않는다.
- ④ 일조방해의 정도가 사회통념상 일반적으로 인용되는 수인한도를 넘어서는 경우에는 그 건축행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 불법행위를 구성한다고 하면서 객관적 요건만으로 권리남용을 인정한 판례도 있다
- ⑤ 증권거래법의 위반에 의하여 무효인 수익보증약정을 고객과 체결한 투자신탁회사가 그 약정의 무효를 주장하는 것은 신의칙에 반한다.

해설

- ⑤ 강행법규에 위반하여 무효인 수익보장약정이 투자신탁회사가 먼저 고객에게 제의를 함으로써 체결된 것이라고 하더라도, 이러한 경우에 강행법규를 위반한 투자신탁회사 스스로가 그 약정의 무효를 주장함이 신의칙에 위반되는 권리의 행사라는 이유로 그 주장을 배척한다면, 이는 오히려 강행법규에 의하여 배제하려는 결과를 실현시키는 셈이 되어 입법취지를 완전히 몰각하게 되므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 주장이 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 할 수 없다(대법원 1999.3.23. 99다4405).
- ① 대법원 1998.7.24. 98다9021
 ② 대법원 2001.5.15. 99다53490
 ③ 대법원 1994.9.27. 94다20617
 ④ 대법원 2001.26.26. 2000다44928 정답: ⑤

13 신의칙에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ㉠ 법원은 당사자의 주장이 없으면 직권으로 신의칙 위반 여부를 판단할 수 없다.
 ㉡ 무권대리인이 무권대리행위 후 단독으로 본인의 지위를 상속한 경우, 본인의 지위에서 그 무권대리행위의 추인을 거절하는 것은 신의칙에 반한다.
 ㉢ 부동산거래에서 신의칙상 고지의무의 대상은 직접적인 법령의 규정뿐만 아니라 계약상, 관습상 또는 조리상의 일반원칙에 의해서도 인정될 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉠ 신의성실의 원칙에 반하는 것 또는 권리남용은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다(대법원 1998.08.21. 97다37821).
- ㉡ 무권대리인이 본인의 지위를 상속받아 승계한 경우, 상속인의 지위에서 추인을 거절하여 무효를 주장하는 것은 금반언의 원칙이나 신의칙에 반한다(대법원 1994.09.27. 94다20617).
- ㉢ 부동산 거래에 있어 거래 상대방이 일정한 사정에 관한 고지를 받았더라면 그 거래를 하지 않았을 것이م 경험칙상 명백한 경우에는 신의성실의 원칙상 사전에 상대방에게 그와 같은 사정을 고지할 의무가 있으며, 그와 같은 고지의무의 대상이 되는 것은 직접적인 법령의 규정뿐 아니라 널리 계약상, 관습상 또는 조리상의 일반원칙에 의하여도 인정될 수 있고, 일단 고지의무의 대상이 되는 사실이라고 판단되는 경우 이미 알고 있는 자에 대하여는 고지할 의무가 별도로 인정될 여지는 없다(대법원 2007.06.01. 2005다5812). 정답: ④

14 다음 중 신의성실의 원칙 및 권리남용에 대한 판례의 태도로 타당하지 않은 것은?

- ① 계속적 보증계약에서 보증기간이 정하여졌다 하더라도 회사 퇴사와 같은 중대한 사정변경이 있는 경우에는 보증인에게 해지권을 인정한다.
- ② 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 그 권리행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 공여하였거나, 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 상태에 이르러야 한다.
- ③ 은행에게 보증금 없이 임차하고 있다고 말하고 은행에게 확인서를 써준 임차인이 건물에 대항력을 갖춘 경우 경락인(매수인)인 은행에게 보증금의 반환을 내세워 그 건물의 명도를 거부하는 것은 금반언의 원칙에 위배된다.
- ④ 사직원을 제출한 후 12년이 지난 뒤, 동일한 처지에 있던 다른 자가 해고무효확인소송을 제기하여 대법원의 확정판결을 받은 후 2년 6개월 남짓하여 제기한 해고무효소송은 실효의 원칙에 의거하여 허용되지 않는다.
- ⑤ 매매계약이 체결된 후에 9년이 지나고 그 시가가 올랐다면 그것만으로 그 매매계약을 해제할 만한 사정변경이 있었다고 볼 수 있다.

해설

- ⑤ 판례는 매매계약이 체결된 후에 9년이 지나고 그 시가가 올랐을지라도 계약을 해제할 만한 사정변경이 있었다고 볼 수 없다고 한다(대법원 1991.2.26. 90다19664).
- ① 근보증의 경우 회사의 퇴사는 보증인의 신분·지위의 현저한 변화로서 사정변경에 의한 해지권이 인정되는 경우라 할 수 있다(대법원 1990.2.27. 89다카1381).
- ② 대법원 1988.9.29. 87다카279
- ③ 임대인인 갑이 을에게 임차하여 준 자기 소유의 건물을 담보로 제공하고 은행융자를 받음에 있어 임차인인 을이 위 건물의 담보가치를 높게 평가하기 위하여 은행직원에게 임료없이 무상으로 거주하고 있다고 허위내용의 확인서를 작성하여 주었다면 경락인(매수인)에 대하여 명도를 거부하는 것은 특단의 사정이 없는 한 금반언의 원칙에 반한다(대법원 1987.12.8. 87다카1733).
- ④ 고용관계의 존부를 둘러싼 노동분쟁에서는 실효의 원칙이 다른 법률관계에서 보다 더욱 적극적으로 적용되어야 할 필요가 있는데, 다른 직원의 의원면직처분이 무효라는 사실의 승소판결로부터 2년 4개월이 경과한 시점에서 무효를 주장하는 것은 실효의 원칙에 비추어 허용될 수 없다(대법원 1992.1.21. 91다30118). 정답: ⑤

15 신의성실의 원칙에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ㉠ 회사의 이사가 회사의 확정채무를 보증한 경우에는 그 직을 사임하더라도 사정변경을 이유로 그 보증계약을 해지할 수 없다.
- ㉡ 소멸시효 완성 전에 채무자가 시효중단을 현저히 곤란하게 하여 채권자가 아무런 조치를 취할 수 없었던 경우, 그 채무자가 시효완성을 주장하는 것은 신의칙 상 허용되지 않는다.
- ㉢ 강행법규를 위반한 자가 스스로 강행법규 위반을 이유로 약정의 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반한다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉠ 이사로 재직 중 채무액과 변제기가 특정되어 있는 회사의 확정채무에 대하여 보증을 한 후 이사 직을 사임한 자는 사정변경을 이유로 그 계약을 해지할 수 없다(대법원 1996.2.9. 95다27431).
- ㉡ 채무자가 시효완성 전에 채권자의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 하였거나, 그러한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였거나, 객관적으로 채권자가 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었거나, 또는 일단 시효완성 후에 채무자가 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 권리자가 그와 같이 신뢰하게 하였거나,중략..... 채무자가 소멸시효의 완성을 주장하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용으로서 허용될 수 없다(대법원 2016.9.30. 2016다218713).
- ㉢ 강행법규를 위반한 자가 스스로 강행법규 위반을 이유로 약정의 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 할 수 없다(대법원 1999.3.23. 99다4405).

정답: ③

16 신의성실의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 신의성실의 원칙은 채권관계뿐만 아니라 물권관계나 가족관계에서도 적용된다.
- ② 신의성실의 원칙은 구체적 내용이 정하여져 있지 않은 일반조항으로서 그 내용은 재판에 의하여 형성된다.
- ③ 신의성실의 원칙은 강행법규의 성질을 가지므로 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 판단할 수 있다.
- ④ 강행법규 위반사실을 알면서 그러한 계약을 체결한 당사자가 후에 그 행위가 강행법규 위반으로 무효라고 주장하는 것은 신의칙에 위반된다.
- ⑤ 신의성실의 원칙에 위배됨을 이유로 권리행사를 부정하기 위해서는 법률관계의 당사자가 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다.

해설

- ④ 강행법규를 위반한 자가 스스로 강행법규 위반을 이유로 약정의 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 할 수 없다(대법원 1999.3.23. 99다4405). 정답: ④

17 사정변경의 원칙에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 민법에는 사정변경의 원칙에 입각한 일반규정과 개별규정이 있다.
- ② 계약당사자가 일방의 책임 있는 사유로 인해 현저한 사정변경이 초래된 경우, 그 당사자는 사정변경을 이유로 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 사정변경으로 인한 계약해제에 있어서 사정이라 함은 계약의 기초가 되었던 객관적인 사정 및 당사자의 주관적 또는 개인적인 사정을 포함하는 것이다.
- ④ 이사로 재직 중 채무액과 변제기가 특정되어 있는 회사의 확정채무에 대하여 보증을 한 후 이사직을 사임한 자는 사정변경을 이유로 그 계약을 해지할 수 있다.
- ⑤ 현저하게 변경된 사정이 계약 성립 당시에 당사자가 예견할 수 있었던 것이라면 그 당사자는 계약을 해제할 수 없다.

해설

- ⑤ 사정변경을 계약 성립 당시에 당사자가 예견할 수 있었던 것이라면 그 당사자는 계약을 해제할 수 없다.
- ① 민법에는 사정변경의 원칙에 입각한 일반적인 규정은 없으며, 지상권의 지료증감청구(제286조), 전세금증감청구(제312조의2), 불안의 항변(제536조 제2항), 재산상태악화에 의한 증여계약의 해제(제557조), 임차물의 일부멸실과 차임감액청구(제627조), 차임증감청구(제628조) 등의 개별 규정이 있다.
- ② 계약당사자가 일방의 책임 있는 사유로 인해 현저한 사정변경이 초래된 경우, 그 당사자는 사정변경을 이유로 계약을 해제할 수 없다.
- ③ 사정변경으로 인한 계약해제에 있어서 사정이라 함은 계약의 기초가 되었던 객관적인 사정을 말하는 것이지, 당사자의 주관적 또는 개인적인 사정을 의미하지 않는다.
- ④ 이사로 재직 중 채무액과 변제기가 특정되어 있는 회사의 확정채무에 대하여 보증을 한 후 이사직을 사임한 자는 사정변경을 이유로 그 계약을 해지할 수 없다(대법원 1996.2.9., 95다27431).

정답: ⑤

18 신의성실의 원칙과 권리남용 금지원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 강행법규 위반임을 알면서 계약을 체결한 후 이를 이유로 계약의 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반한다.
- ② 실효의 원칙을 적용하기 위해서는 의무자인 상대방이 더 이상 권리가 그 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿을 만한 정당한 사유가 있어야 한다.
- ③ 채무자가 채권자의 시효중단을 현저히 곤란하게 하여 채권자가 시효중단을 주장할 수 없는 경우, 채무자가 시효의 완성을 주장하는 것은 신의칙상 허용되지 않는다.
- ④ 법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 법정지상권까지 양도받기로 한 자에 대하여 대지소유자가 그 소유권에 기하여 건물철거를 청구하는 것은 허용되지 않는다.
- ⑤ 권리남용의 해당 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 판단할 수 있다.

해설

- ① 강행법규인 국토이용관리법(現 국토의계획및이용에관한법률) 규정을 위반하였을 경우에 있어서 위반한 자 스스로가 무효를 주장함이 신의성실의 원칙에 위배되는 권리의 행사라는 이유로서 이를 배척한다면 투기거래계약의 효력발생을 금지하려는 국토이용관리법의 입법취지를 완전히 몰각시키는 결과가 되므로, 거래당사자 사이의 약정내용과 취득목적대로 관할관청에 토지거래허가신청을 하였을 경우에 그 신청이 국토이용관리법 소정의 허가기준에 적합하여 허가를 받을 수 있었으나 다른 급박한 사정으로 이러한 절차를 회피하였다고 볼만한 특단의 사정이 엿보이지 아니하는 한, 그러한 주장이 신의성실의 원칙에 반한다고는 할 수 없다(대법원 1993.12.24. 93다44319,93다44326). 정답: ①

19 형성권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 채권자취소권은 반드시 재판상으로만 행사해야 하는 형성권이다.
② 계약의 해제권은 형성권이 아니다.
③ 형성권의 행사로 법률관계를 변경시킬 수 있다.
④ 민법전에 청구권으로 표기된 권리 중에는 그 본질이 형성권인 것도 있다.
⑤ 건물소유목적의 토지임대차기간이 만료된 경우, 임차인이 행사하는 임대차계약의 갱신청구권은 형성권이 아니다.

해설

- ② 형성권이란 권리자의 일방적 의사표시에 의하여 법률관계를 변동케 하는 권리를 말하며 해제권은 형성권에 해당한다.
④ 명칭은 청구권이나 실질이 형성권인 것으로는 다음과 같은 것이 있다.
㉠ 지상권자의 지상물매수청구권(제283조 제2항)
㉡ 전세권자의 부속물매수청구권(제318조 제2항)
㉢ 임차인의 부속물매수청구권(제642조~제647조)
㉣ 지상권설정자의 지상권소멸청구권(제287조)
㉤ 전세권설정자의 전세권소멸청구권(제311조)
㉥ 지료증감청구권(제286조)
㉦ 매매대금감액청구권(제572조)
㉧ 공유물분할청구권(제268조) 등
⑤ 건물소유목적의 토지임대차기간이 만료된 경우, 임차인이 행사하는 임대차계약의 갱신청구권은 임대인이 갱신을 거절할 수 있기 때문에 청구권에 해당한다(제643조). 정답: ②

20 신의성실의 원칙 내지 그 파생원칙의 적용에 관한 판례의 입장과 다른 것은?

- ① 근로자가 아무런 이의 없이 퇴직금을 수령하고 의원면직일로부터 5년이 경과하였다고 하더라도 사직원의 작성과 제출이 자신의 형(兄)에 의하여 이루어졌다면 의원면직의 무효를 주장할 수 있다.
② 매매계약 체결 후 9년이 지났고 시가가 올랐다는 사정만으로 계약을 해제할 만한 사정변경이 있다고 볼 수 없고, 매수인의 소유권이전등기청구가 신의칙에 위배된다고 할 수 없다.

- ③ 병원은 입원하여 치료를 받는 환자의 휴대폰 등의 도난 방지에 필요한 적절한 조치를 강구해 줄 신의칙상의 보호의무를 부담한다.
- ④ 법률행위가 법령에 위반되어 무효임을 알면서 그 법률행위를 한 사람은 특별한 사정이 없는 한 강행법규의 위반을 이유로 무효를 주장할 수 있다.
- ⑤ 사용자와 근로자 사이의 근로자의 지위의 존부를 둘러싼 노동분쟁은, 사용자의 입장에서는 물론 근로자의 입장에서도 신속히 해결되는 것이 바람직하므로 실효의 원칙이 다른 법률 관계에 있어서보다 더욱 적극적으로 적용되어야 할 필요가 있다.

해설

- ① 징계면직처분에 불복하던 근로자가 이의 없이 퇴직금을 수령하고 다른 생업에 종사하다 징계면직 일로부터 2년 10개월 후에 제기한 해고무효확인청구는 신의칙 및 실효의 원칙에 위배되어 허용될 수 없다(대법원 1996.11.26, 95다49004).
- ② 대법원 1991.2.26, 90다19664
- ③ 환자가 병원에 입원하여 치료를 받는 경우에 있어서, 병원은 진료뿐만 아니라 환자에 대한 숙식의 제공을 비롯하여 간호, 보호 등 입원에 따른 포괄적 채무를 지는 것인 만큼, 병원은 병실로의 출입자를 통제·감독하든가 그것이 불가능하다면 최소한 입원환자에게 휴대폰을 안전하게 보관할 수 있는 시정장치가 있는 사물함을 제공하는 등으로 입원환자의 휴대폰 등의 도난을 방지함에 필요한 적절한 조치를 강구하여 줄 신의칙상의 보호의무가 있다고 할 것이고, 이를 소홀히 하여 입원환자와는 아무런 관련이 없는 자가 입원환자의 병실에 무단출입하여 입원환자의 휴대폰 등을 절취하였다면 병원은 그로 인한 손해배상책임을 면하지 못한다(대법원 2003.4.11, 2002다63275).
- ④ 특별한 사정이 없는 한, 법령에 위반되어 무효임을 알고서도 그 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 무효를 주장한다 하여 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반하거나 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다(대법원 2003.8.22, 2003다19961).
- ⑤ 대법원 1992.1.21. 91다30118 정답: ①

21 신의성실의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ① 채권자가 유효하게 성립한 계약에 따른 급부의 이행을 청구하는 때에 법원이 급부의 일부를 감축하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.
- ② 아파트 분양자는 아파트단지 인근에 공동묘지가 조성되어 있는 사실을 분양계약자에게 고지할 신의칙상의 의무를 부담한다.
- ③ 경제상황의 변동으로 당사자에게 손해가 생기더라도 합리적인 사람의 입장에서 사정변경을 예견할 수 있었다면 사정변경을 이유로 계약을 해제할 수 없다.
- ④ 법령에 위반되어 무효임을 알면서도 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 그 무효를 주장하는 것은 신의칙에 반한다.
- ⑤ 취득시효완성 사실을 모르고 해당 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 약속한 후, 이에 반하여 취득시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다.

해설

- ④ 특별한 사정이 없는 한, 법령에 위반되어 무효임을 알고서도 그 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 무효를 주장한다 하여 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반하거나 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다(대법원 2003.8.22., 2003다19961). 정답: ④

22 신의성실의 원칙(신의칙)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 후 법정대리인의 동의 없음으로 그 계약을 취소하는 것은 신의칙에 반하지 않는다.
- ② 채권자가 채권을 확보하기 위하여 제3자의 부동산을 채무자에게 명의신탁하도록 한 다음 그 부동산에 대해 강제집행을 하는 것은 신의칙에 반한다.
- ③ 회사의 이사로 재직하면서 회사의 확정채무를 보증한 자는 이사직을 사임한 후에 사정변경을 이유로 그 보증계약을 해지할 수 있다.
- ④ 신의성실의 원칙에 반하거나 권리남용이 되는 경우에는 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 이를 판단할 수 있다.
- ⑤ 징계면직처분에 불복하던 근로자가 이의 없이 퇴직금을 수령하고 다른 생업에 종사하다 징계면직 일로부터 5년 후에 제기한 해고무효확인청구는 신의칙 및 실효의 원칙에 위배되어 허용될 수 없다.

해설

- ③ 사정변경의 원칙의 적용에 있어서, 판례는 계속적 채권관계, 특히 계속적 보증관계에서는 일관되게 사정변경의 원칙을 인정하고 있으나 일반 확정채무에 대한 보증에 대하여는 그 적용을 부정함이 원칙이다. 즉 판례는 회사의 이사가 '채무액과 변제기가 특정되어 있는 회사 채무'에 대하여 보증계약을 체결한 경우에는 계속적 보증이나 포괄근보증의 경우와는 달리 이사직 사임이라는 사정변경을 이유로 보증인인 이사가 일방적으로 보증계약을 해지할 수 없다(대법원 2006.7.4., 2004다30675)고 한다. 정답: ③

23 권리남용에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 권리가 법령에 위반되어 무효임을 알면서도 법률행위를 한 후 강행법규 위반을 이유로 그 법률행위의 무효를 주장한다면 원칙적으로 권리남용에 해당된다.
- ② 권리의 권리행사에 대하여 상대방이 권리남용을 주장하지 않는다면 법원은 이를 직권으로 판단할 수 없다.
- ③ 당사자간의 합의로 권리남용금지 원칙의 적용을 배제하기로 하는 특약은 허용하지 않는다.
- ④ 채무자가 소멸시효에 기한 항변권을 행사하는 경우에는 권리남용금지 원칙의 지배를 받지 않는다.
- ⑤ 권리남용을 이유로 권리 그 자체가 박탈되는 경우는 없다.

해설

- ③ 권리남용금지의 원칙을 규정한 민법 제2조 제2항은 강행규정으로서 당사자의 특약으로 배제할 수 없다.
- ① 이미 설명된 바와 같이, 권리자가 법령에 위반되어 무효임을 알면서도 법률행위를 한 후 강행 법규 위반을 이유로 그 법률행위의 무효를 주장하는 것은 권리남용금지의 원칙이나 신의칙위반에 해당하지 않는다.
- ② 권리자의 권리행사가 권리남용인지 여부는 법원의 직권조사사항이다.
- ④ 채무자가 소멸시효에 기한 항변권을 행사하는 경우에는 신의성실의 원칙 내지 권리남용금지 원칙의 지배를 받는 경우가 있다. 취득시효완성 '후'에 그 사실을 '모르고' 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 하였다 하더라도 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다(대법원 1998.5.22. 96다24101).
- ⑤ 권리남용금지의 원칙은 권리의 행사를 제한하는 원칙일 뿐 권리 자체를 박탈하기 위한 제도는 아니나, 친권의 상실 내지 제한(제924조)과 같이 명문의 규정이 있으면 권리가 박탈될 수도 있다.
- 정답: ③

24 권리남용금지의 원칙에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ㉠ 채무자가 소멸시효완성 전에 채권자의 권리행사를 현저하게 곤란하게 하여 시효가 완성된 경우, 채무자가 시효의 완성을 주장하는 것은 권리 남용이 된다.
- ㉡ 권리남용은 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다.
- ㉢ 거래당사자가 유치권을 자신의 이익을 위하여 고의적으로 작출하여 유치권의 우선순위 담보권으로서의 지위를 부당하게 이용함으로써 신의성실의 원칙에 반한다고 평가되는 경우에는 유치권의 남용이 된다.
- ㉣ 권리남용으로 인정되는 경우, 남용의 구체적 효과는 권리의 종류와 남용의 결과에 관계 없이 권리의 박탈이라는 점에서는 동일하다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

해설

- ㉠ 채무자가 시효완성 전에 채권자의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 하였거나, 그러한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였거나, 객관적으로 채권자가 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었거나, 또는 일단 시효완성 후에 채무자가 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 권리자가 그와 같이 신뢰하게 하였거나,중략..... 채무자가 소멸시효의 완성을 주장하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용으로서 허용될 수 없다(대법원 2016.9.30. 2016다218713).
- ㉡ 신의성실의 원칙에 반하는 것 또는 권리남용은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다(대법원 1995.12.22. 94다42129).
- ㉢ 채무자 소유의 목적물에 이미 저당권 기타 담보물권이 설정되어 있는데 채권자가 자기 채권의 우선적 만족을 위하여 채무자와 의도적으로 유치권의 성립요건을 충족하는 내용의 거래를 하고 목적물을 점유함으로써 유치권이 성립한 경우, 유치권을 저당권자 등에게 주장하는 것은 허용될 수 없다(대법원 2011.12.22. 2011다84298).

- ㉔ 권리의 종류에 따라 남용의 효과는 다르다. 예컨대 청구권행사가 남용이 되면 주장이 배척되고, 형성권행사가 남용이 되면 효과발생이 부정된다. 정답: ④

25

신의성실의 원칙에 관한 기술 중 옳은 것(○)과 옳지 않은 것(×)을 바르게 표시한 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ㉑ 계약 성립 후 현저한 사정의 변경이 발생하였고, 그러한 사정의 변경이 해제권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것으로서, 계약 내용대로의 구속을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에 사정의 변경으로 인한 계약해제가 인정되는데, 여기의 사정에는 상대방에게 알려진 일방당사자의 주관적 사정도 포함된다.
- ㉒ 동생 소유의 아파트에 거주하고 있는 채무자 甲이 그 아파트를 담보로 저축은행 乙로부터 대출을 받으면서 乙에게 자신은 임차인이 아니고 위 아파트에 관하여 일체의 권리를 주장하지 않겠다는 확인서를 작성하여 준 경우, 甲이 그 후 대항력을 갖춘 임차인임을 내세워 위 아파트를 경매절차에서 매수한 乙의 인도명령을 다투는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.
- ㉓ 적절한 위임사무처리에 관하여 약정된 보수액이 부당하게 과다하여 신의칙에 반하는 경우, 그러한 약정 전부가 무효이고 적정보수를 초과하는 부분만 무효로 되는 것은 아니다.

- ① ㉑(○), ㉒(○), ㉓(○)
 ② ㉑(○), ㉒(○), ㉓(×)
 ③ ㉑(○), ㉒(×), ㉓(○)
 ④ ㉑(○), ㉒(×), ㉓(×)
 ⑤ ㉑(×), ㉒(○), ㉓(×)

해설

- ㉑ (X) 이른바 사정변경으로 인한 계약해제는, 계약성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정의 변경이 발생하였고 그러한 사정의 변경이 해제권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것으로서, 계약내용대로의 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에 계약준수 원칙의 예외로서 인정되는 것이고, 여기에서 말하는 사정이라 함은 계약의 기초가 되었던 객관적인 사정으로서, 일방당사자의 주관적 또는 개인적인 사정을 의미하는 것은 아니다.
- ㉒ (○) 근저당권자가 담보로 제공된 건물에 대한 담보가치를 조사할 당시 대항력을 갖춘 임차인이 그 임대차 사실을 부인하고 임차보증금에 대한 권리주장을 않겠다는 내용의 확인서를 작성해 준 경우, 그 후 그 건물에 대한 경매절차에서 이를 반복하여 대항력 있는 임대차의 존재를 주장함과 아울러 근저당권자보다 우선적 지위를 가지는 확정일자부 임차인임을 주장하여 그 임차보증금반환채권에 대한 배당요구를 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 금반언 및 신의칙에 위배되어 허용될 수 없다(대법원 1997.6.27. 97다12211).
- ㉓ (X) 그 약정된 보수액이 부당하게 과다하여 신의성실의 원칙이나 형평의 원칙에 반하는 특별한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 상당하다고 인정되는 범위 내의 보수액만을 청구할 수 있다고 할 것이다(대법원 2006.6.15. 2004다59393). 정답: ⑤

28 권리의 충돌과 경합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 전세목적물이 전세권자의 고의로 멸실된 경우에 소유자인 전세권설정자는 전세권자에게 채무 불이행에 기한 손해배상청구권과 불법행위에 기한 손해배상청구권을 가지며, 양자는 청구권 경합의 관계에 있다.
- ② 하나의 생활사실이 여러 개의 법규의 요건을 충족하여 동일한 목적을 가지는 여러 개의 권리가 발생하는 경우는 권리의 경합이다.
- ③ 공무원의 직무상 불법행위책임에 대하여 국가배상법과 민법의 규정이 경합하는 경우 전자만이 적용된다.
- ④ 임대차가 종료하면 임대인인 소유자는 임차인에게 소유권에 기하여 목적물의 반환을 청구할 수 있을 뿐이다.
- ⑤ 토지에 대하여 지상권과 임차권이 충돌하는 경우 권리 성립의 선후에 관계없이 지상권이 우선한다.

해설

- ④ 임대차가 종료하면 임대인인 소유자는 임차인에게 소유자의 지위에서 소유권에 기하여 목적물의 반환을 청구할 수도 있고, 임대인의 지위에서 임대차종료를 원인으로 임대차에 기한 목적물의 반환을 청구할 수도 있다.
- ③ 공무원의 직무상 불법행위책임에 대하여 국가배상법과 민법의 규정이 경합하는 경우 전자만이 적용되는데 이를 법규의 경합(특별법우선의 원칙)이라고 한다. 정답: ④

29 형성권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 형성권의 효력 발생에는 상대방의 동의나 승낙을 요하지 않는다.
- ② 형성권의 행사는 단독행위이므로 조건은 붙일 수 없음이 원칙이나, 계약의 정지조건부 해제는 인정된다.
- ③ 공유물분할청구권은 형성권이다.
- ④ 형성권은 반드시 재판상 행사해야 한다.
- ⑤ 취소할 수 있는 법률행위의 취소권의 존속기간은 제척기간이다.

해설

- ④ 형성권은 권리자의 일방적 의사표시에 의하여 행사하는 것과 반드시 재판에 의하여 행사하여야 하는 것이 있다. 전자에는 동의권, 철회권, 상계권, 추인권, 해지권, 해제권, 취소권, 매매의 일방 예약완결권 등이 있고, 후자에는 채권자취소권(제406조), 친생부인권(제846조), 입양취소권(제884조), 재판상 이혼권(840조) 등이 있다. 정답: ④

- ① 저당권-취소권-동의권
- ② 상계권-준물권-예약완결권
- ③ 해제권-취소권-지상물매수청구권
- ④ 추인권-해지권-물권적 청구권
- ⑤ 해지권-부양청구권-부속물매수청구권

해설

- ③ 해제권과 취소권은 권리자의 일방적 의사표시에 의하여 행사하는 형성권이고, 지상물매수청구권은 청구권이라 불리우나 그 실질이 형성권에 해당하는 권리이다. 정답: ③

권리의 주체(자연인)

1

기본문제

01

다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 권리능력에 관한 규정은 예외 없이 강행규정이다.
- ② 민사소송의 당사자가 될 수 있는 지위가 당사자능력이다.
- ③ 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있는 능력이 행위능력이다.
- ④ 자기행위의 결과와 의미를 판별할 수 있는 능력이 책임능력이다.
- ⑤ 민법에는 의사능력에 관한 명문규정이 없다.

해설

각종 능력의 비교

종 류	의 의	흠결의 효과
권리능력	권리나 의무의 주체가 될 수 있는 추상적·확일적 능력	법률행위 불성립(무효)
의사능력	사물을 판단하고 행위의 의미나 결과를 예측할 수 있는 구체적·개별적 능력	법률행위 무효(유아·정신병자 등)
행위능력	단독으로 유효한 법률행위를 행할 수 있는 추상적·확일적 능력	법률행위 취소(미성년자·피한정후견인·피성년후견인)
불법행위능력	행위의 책임을 변식할 수 있는 구체적·개별적 능력	불법행위 책임 없음

④는 책임능력이 아니라 의사능력이다. 정답: ④

02

민법상 권리능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자연인의 권리능력은 사망으로만 소멸한다.
- ② 자연인의 권리능력은 다른 사람에게 양도하거나 포기할 수 없다.
- ③ 자연인은 생존한 동안 성별, 연령, 직업을 묻지 않고 평등하게 권리능력을 갖는다.
- ④ 자연인은 출생으로 권리능력을 취득하지만 예외적으로 태아가 살아서 출생하지 못한 경우에도 권리능력을 가지는 경우가 있다.
- ⑤ 법인의 권리능력은 법인의 성질, 법률의 규정, 정관으로 정한 목적의 범위에 의해 제한된다.

해설

④ 태아의 개별적 보호주의에 다른 권리능력은 태아가 살아서 출생한다는 것을 전제로 인정되는 것이므로, 태아가 사산(유산)된 경우에는 권리능력을 인정할 여지가 없다. 정답: ④

03 권리능력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법인의 권리능력은 정관에 명시된 목적 자체에 국한된다.
- ② 제3자의 불법행위로 태아가 사산된 경우에는 모(母)가 태아의 손해배상청구권을 상속한다.
- ③ 동시사망의 추정은 사실상의 추정이 아니라 법률상의 추정이다.
- ④ 증여에 관하여는 태아의 수증능력이 인정되지 아니하나, 그 법정대리인에 의한 수증행위는 가능하다.
- ⑤ 권리능력은 사망신고에 의해 상실된다.

해설

- ③ 사실상의 추정이란 어느 사실로부터 다른 사실을 경험칙에 의하여 추인하는 것을 말하고, 법률상의 추정이란 어느 사실로부터 다른 사실을 경험칙에 의하여 추인하는 사실상의 추정과는 달리 법률에 의하여 추인하는 것으로 규정된 것을 말한다. 사실상의 추정에서의 경험칙이 법규화 된 것이라고 할 수 있다. 따라서 동시사망의 추정은 사실상의 추정이 아니라 법률상의 추정에 해당한다.
- ① 법인의 권리능력은 법인의 설립근거가 된 법률과 정관상의 목적에 의하여 제한되나 그 목적 범위 내의 행위라 함은 법률이나 정관에 명시된 목적 자체에 국한되는 것이 아니라 그 목적을 수행하는 데 있어 직접, 간접으로 필요한 행위는 모두 포함되는 것이다(대법원 2001.9.21. 2000그98).
- ② 태아가 모체와 같이 사망하여 출생의 기회를 가지지 못한 이상, 불법행위로 인한 손해배상청구권을 논할 여지가 없다(대법원 1976.09.14. 76다1365).
- ④ 생전행위로서의 '증여'에 대해서는 태아에게 권리능력이 인정되지 아니한다.
- ⑤ 출생신고나 사망신고는 보고적 신고에 해당하며, 권리능력의 취득이나 상실과는 무관하다.

정답: ③

04 다음 기술 중 부당한 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 행위능력자 중에 의사능력이 없는 자도 있고, 제한능력자 중에 의사능력이 있는 자도 있다.
- ② 법정대리인이 미성년자에 대하여 어떤 종류의 영업을 허락한 경우에, 그 범위 내에서는 법정대리인이 미성년자를 대리할 수 없다.
- ③ 자기 행위의 결과를 정상적으로 인식할 수 없는 심각한 정신질환자라 하더라도 권리능력은 있다.
- ④ 미성년자도 타인의 대리인으로서 그 본인의 부동산의 매매계약을 체결할 수 있다.
- ⑤ 법정대리인이 미성년자에게 준 영업허락의 취소는 실질적으로 철회를 의미하며, 제한능력자 보호의 정신에 따라 이 취소는 미성년자와 거래한 모든 제3자에게 대항할 수 있다.

해설

- ⑤ 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다(제8조 제2항 단서).
- ① 의사능력의 유무는 구체적인 행위에 대하여 개별적으로 판단되는 반면, 행위능력의 유무는 제한능력자 보호의 차원에서 획일적으로 판단된다.
- ② 미성년자가 법정대리인으로부터 허락을 얻은 특정영업에 관하여는 성년자와 동일한 행위능력이 있다(제8조 제1항).
- ④ 대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다(제117조). 정답: ⑤

05 다음 태아를 이미 출생한 것으로 보아 보호하지 않는 경우는 어느 것인가?

- ① 부모가 타인의 불법행위로 인하여 사망한 경우의 손해배상청구권
- ② 대습상속
- ③ 재산상속에 있어서의 상속순위
- ④ 태아가 유증을 받는 경우
- ⑤ 채무불이행으로 인한 손해배상청구권

해설

- ㉠ 태아의 개별적 보호주의에 의한 보호내용(권리능력이 인정되는 경우)
 - ㉡ 불법행위로 인한 손해배상청구권(제762조)
 - ㉢ 父의 생명침해로 인한 子 자신이 위자료를 청구하는 경우를 말하며, 父의 생명침해로 인한 재산적 손해는 일단 父에게 손해배상청구권이 발생하고 그것이 상속인(태아)에게 상속된다는 것이 판례의 태도이다.
 - ㉣ 태아 자신이 입은 불법행위로 인한 손해에 대하여 배상청구를 하는 경우이다.
 - ㉤ 재산상속(제1000조)
 - ㉥ 유류분권(제1112조)
 - ㉦ 대습상속(제1001조)
 - ㉧ 유증(제1064조)
 - ㉨ 인지(제858조) : 부의 태아에 대한 인지(認知)는 인정되나 태아의 부에 대한 인지청구권은 부정된다는 것이 다수설과 판례의 태도이다.
 - ㉩ 사인증여(제562조)
 - ㉪ 긍정설(다수설) : 제562조에서 유증의 규정을 준용하고 있다는 것에 근거를 둔다.
 - ㉫ 부정설(판례) : 논거로서 첫째, 법률행위의 성질상 유증은 단독행위이고 사인증여는 계약이라는 것이다. 둘째, 현행법상 태아의 법정대리인제도가 인정되지 않는다. 셋째, 유증으로서도 보호를 받음에도 사인증여에까지 확대하는 것은 무리가 따른다는 것이다. 정답: ㉤

06 자연인의 권리능력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 태아는 불법행위에 기한 손해배상의 청구권에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.
- ② 실종선고를 받은 자는 그 재판이 확정된 때에 사망한 것으로 본다.
- ③ 태아는 모든 법률관계에서 자연인과 동일한 권리능력을 갖는다.
- ④ 출생한 자는 가족관계등록부에 등록되는 것을 정지조건으로 출생시 소급하여 권리능력을 취득한다.
- ⑤ 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 간주한다.

해설

- ① 제762조
- ② 실종선고를 받은 자는 실종기간이 만료한 때(보통실종은 5년, 특별실종은 1년)에 사망한 것으로 본다(제28조).
- ③ 우리 민법은 태아의 경우 모든 법률관계가 아니라 개별적 법률관계에서만 출생한 것으로 보는 입법주의인 개별적 보호주의를 취하고 있다.
- ④ 출생한 자는 가족관계등록부에 등록하는 것과 상관없이 산모로부터 전무노출시 권리능력을 취득한다.
- ⑤ 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다(제30조). 정답: ①

07 권리능력에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우 동시에 사망한 것으로 추정한다.
- ② 임신부에 위법한 약물 투여로 인하여 장애를 갖고 태어난 자는 이로 인한 손해배상청구권을 갖는다.
- ③ 출생의 가족관계등록부의 기재는 출생의 증거자료가 될 뿐이고 출생을 창설하는 효력을 갖는 것은 아니다.
- ④ 외국인이라도 한국사람의 명의로 한국선박의 소유권을 취득할 수 있다.
- ⑤ 출생신고에 의하여 권리능력을 취득하는 것은 아니다.

해설

- ① 동시사망의 추정(제30조)
- ② 태아에게 인정되는 불법행위로 인한 손해배상청구권을 말한다.
- ③ 출생신고는 창설적 신고가 아닌 보고적 신고이다.
- ④ 외국인에게는 한국선박과 항공기의 소유권 및 도선사가 되는 권리는 인정되지 않는다. 정답: ④

08 제한능력자의 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 피성년후견인이 속임수로서 법정대리인의 동의가 있는 것으로 계약 상대방을 믿게 한 경우에는 그 계약을 취소할 수 없다.
- ② 의사무능력자는 성년후견개시 심판 없이도 피성년후견인으로서 보호된다.
- ③ 미성년자가 단순히 자기가 성년자라고 말하여 계약 상대방을 믿게 한 경우에는 그 계약을 취소할 수 있다.
- ④ 제한능력자의 법률행위가 취소된 경우, 제한능력자가 악의이면 그는 받은 이익 전부를 반환하여야 한다.
- ⑤ 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 시가보다 저렴한 가격으로 컴퓨터를 매수한 경우, 법정대리인은 이를 취소할 수 없다.

해설

- ③ 속임수(사술)의 정도에 대하여 판례는 적극적 속임수(동의를 위조 등)만이 속임수에 해당한다고 한다. 따라서 미성년자가 단순히 자기가 성년자라고 말하여 계약 상대방을 믿게 한 경우에는 소극적 속임수에 불과하므로 그 계약을 취소할 수 있다. 정답: ③

09 사망과 관련된 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 실종선고를 받은 사람의 공법상의 권리는 소멸하지 않는다.
- ② 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다.
- ③ 자연인은 실종선고로 권리능력을 상실하는 것은 아니다.
- ④ 동시사망추정에 대한 반증이 없어 동시에 사망한 것으로 인정된 자 사이에도 상속이 이루어진다.
- ⑤ 탑승한 항공기가 2012년 2월 15일에 추락하여 생사불명된 자가 2016년 3월 5일에 실종선고를 받았다면, 2013년 2월 15일 24시에 사망한 것으로 본다.

해설

- ① 실종선고는 실종자의 종래의 주소를 중심으로 한 사법적 법률관계에 대해서만 사망으로 간주된다.
- ② 제30조
- ③ 실종선고는 실종자의 권리능력 자체를 박탈하는 제도가 아니다. 자연인의 유일한 권리능력 상실 사유는 심폐정지에 의한 사망뿐이다.
- ④ 동시사망의 당사자 사이에서는 상속이 발생하지 않는다.
- ⑤ 항공기 추락은 특별실종이므로 실종기간은 1년이다. 따라서 2013년 2월 15일 24시에 사망 간주된다. 정답: ④

10 만 18세의 미혼인 자가 법정대리인의 동의 없이 단독으로 할 수 있는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- | | |
|------------------|-----------------|
| ㉠ 유언 | ㉡ 대리행위 |
| ㉢ 경제적으로 유리한 매매 | ㉣ 근로기준법상 임금의 청구 |
| ㉤ 증여받기로 한 계약의 해제 | |

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ① ㉠, ㉡, ㉢ | ② ㉠, ㉡, ㉣ | ③ ㉠, ㉢, ㉤ |
| ④ ㉡, ㉣, ㉤ | ⑤ ㉢, ㉣, ㉤ | |

해설

- ① 유언의 경우 만 17세에 달한 미성년자는 단독으로 유효하게 유언을 할 수 있다(제1061조).
- ② 대리행위의 경우 대리인은 행위능력자임을 요하지 않으므로 미성년자는 타인의 대리인이 될 수 있다(제117조).
- ③ 근로기준법상의 근로계약과 그에 따른 임금의 청구도 미성년자가 단독으로 할 수 있다(「근로기준법」 제67조, 제68조). 정답: ②

- 11 미성년자의 법적 지위와 보호에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)
- ① 미성년자는 법정대리인의 동의가 없는 한 단독으로 유효하게 채무변제를 수령할 수 없다.
 - ② 법정대리인이 사용목적을 정하여 처분을 허락한 재산에 대하여 미성년자는 그 목적과 다른 용도로 유효하게 처분할 수 있다.
 - ③ 미성년자가 상대방에 대하여 속임수로서 능력자로 믿게 한 경우 취소권이 배제되는데 이 경우 미성년자는 단순히 능력자라고 칭한 정도가 아니라 적극적으로 사기수단을 사용하여야 하며 이에 대한 증명은 상대방이 부담한다.
 - ④ 미성년임을 이유로 법률행위를 취소한 경우 미성년자는 선의·악의에 관계없이 현존이익한도에서 반환하면 되는데 현존이익이 금전인 경우 특별한 사정이 없는 한 현존하는 것으로 추정된다.
 - ⑤ 미성년을 이유로 취소한 경우 미성년자의 거래상대방은 그 목적물을 제3자에게 처분하여 제3자가 선의취득의 요건을 구비하더라도 미성년자는 목적물의 반환을 청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 제3자에게 선의취득 또는 취득시효의 권리취득이 인정되는 경우에는 그에 의하여 권리를 취득한다.
정답: ⑤

12 제한능력자의 상대방 보호에 특유한 제도가 아닌 것은?

- ① 상대방의 철회권
- ② 상대방의 최고권(확답촉구권)
- ③ 상대방의 거절권
- ④ 법정추인제도
- ⑤ 제한능력자가 속임수(사술)를 쓴 경우의 취소권 배제

해설

㉠ 제한능력자의 상대방보호

모든 취소권자의 상대방보호제도	제한능력자의 상대방보호에 특유한 제도
추인 법정추인 취소권의 단기소멸	최고권 철회권 거절권 속임수로 인한 취소권 배제

- ④의 법정추인제도는 모든 취소권자의 상대방보호에 공통된 제도이다. 정답: ④

13 다음 중 미성년자가 단독으로 할 수 있는 것은?

- ① 16세 미성년자의 유언행위 ② 허락받은 영업에 관한 행위
- ③ 부담부 증여를 받는 행위 ④ 채무변제의 수령
- ⑤ 경제적으로 유리한 매매계약의 체결

해설

- ② 영업의 허락이 있으면, 미성년자는 영업 자체 외에营业을 하는데 직접·간접으로 필요한 모든 행위 (점포임대차, 점원고용, 자금차입 등)를 할 수 있으며, 그 영업에 관하여는 법정대리인의 동의권과 대리권이 소멸한다. 정답: ②

14 18세인 A는 유흥비를 마련하기 위해 자기 소유의 승용차를 B에게 넘기는 매매계약을 단독으로 체결하였다. 다음 설명 중 바르게 된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 계약체결 당시 A가 자신을 능력자라고 칭한 경우, 판례에 의하면 그것만으로도 속임수가 인정되므로 A의 법정대리인이 A와 B 사이의 계약을 취소할 수 없다.
- ② A는 계약체결 후에 제한능력자인 상태에서 단독으로 유효하게 B와의 계약을 취소할 수 있다.
- ③ 계약체결 후에 A가 미성년자임을 알게 된 B가 자신의 의사표시를 철회하는 경우 A가 아직 미성년자인 경우라면 A를 상대로 철회할 수 없다.
- ④ 미성년자의 법정대리인이 매매계약을 취소할 때, A가 매매대금으로 받은 금전 중 일부를 유흥비로 낭비했어도 상대방인 B가 선의라면 받은 이익의 전부를 반환할 책임이 있다.
- ⑤ B가 A의 법정대리인에게 최고(확답을 촉구)하는 경우 상당한 기간 내에 확답을 받지 못하면 추인한 것으로 본다.

해설

- ② 제한능력자는 능력자가 되기 전에도 자신이 행한 행위를 취소할 수 있다.
- ① 미성년자가 단순히 자신을 능력자라고 칭하는 정도는 속임수에 해당하지 않는다는 것이 판례의 태도이다. 따라서 A는 B와의 계약을 취소할 수 있다.
- ③ 계약 당시에 선의였던 상대방은 제한능력자 측의 추인이 있기 전에는 철회할 수 있다. 그리고 철회의 의사표시는 제한능력자에게 직접 할 수 있다.
- ④ 제한능력자의 상대방에 대한 부당이득반환의 범위는 현존이익의 한도이다.
- ⑤ '상당기간'이 아니라 '1월 이상의 유예기간'을 정하여 최고하여야 한다. 정답: ②

15 제한능력자에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 피성년후견인이 성년후견인의 동의를 얻어 한 법률행위는 취소할 수 없다.
- ② 격지자 甲 乙간에 甲의 청약에 대해 乙이 승낙의 통지를 발신한 후 도달 전에 甲이 성년후견심판을 받은 경우, 甲은 그 청약을 취소할 수 없다.
- ③ 미성년자 甲이 그 소유의 노트북을 법정대리인의 동의 없이 선의·무과실의 乙에게 매각하고 인도한 경우, 甲의 법정대리인이 그 계약을 취소해도 乙은 그 노트북의 소유권을 취득한다.
- ④ 미성년자가 매매계약을 체결한 후 성년에 달해 대금을 수령한 경우라도 이 계약을 추인한 것으로 볼 수 없다.
- ⑤ 제한능력자의 법률행위의 취소는 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다.

해설

- ② 격지자 사이의 승낙의 통지는 발신주의를 취하므로 乙이 승낙의 통지를 발신한 때 이미 계약이 성립된 것으로 본다. 따라서 유효한 계약의 성립이 되므로 타당한 기술이다.
- ① 피성년후견인의 법정대리인에게는 동의권이 없으므로 피성년후견인이 설사 성년후견인의 동의를 얻어 법률행위를 하였더라도 취소사유가 된다. 즉 성년후견인에게는 원칙적으로 동의권이 없다.
- ③ 제한능력자의 상대방이 선의·무과실이라 하더라도 선의취득이 인정되지는 않는다.
- ④ 법정추인으로 본다.
- ⑤ 제한능력자의 법률행위의 취소는 선의의 제3자에게도 대항할 수 있는 절대적 취소이다. 정답: ②

16 2023. 6. 3. 15세인 甲이 친권자 乙의 동의 및 처분허락 없이 본인 소유의 자전거를 丙에게 30만 원에 매도하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲은 乙의 동의 없이 매매계약을 취소할 수 있다.
- ② 2023. 7. 14. 甲이 乙의 동의 없이 丙에 대한 대금채권을 丁에게 양도한 후 丙에게 양도 사실을 통지하였다면, 甲은 매매계약을 취소할 수 없다.
- ③ 甲과 丙이 제한능력자에 관한 규정의 적용을 배제하기로 약정하였더라도 乙은 매매계약을 취소할 수 있다.
- ④ 丙이 乙에게 1개월 이상의 기간을 정하여 매매계약에 대한 추인 여부의 응답을 촉구한 경우, 乙이 그 기간 내에 응답을 발송하지 아니하면 이를 추인한 것으로 본다.
- ⑤ 丙이 계약체결 당시 甲이 미성년자라는 사실을 알았다면, 丙은 乙의 추인 전이라도 자신의 의사표시를 철회할 수 없다.

해설

- ② 취소할 수 있는 법률행위로 취득한 권리(대금채권)의 양도는 법정추인사유에 해당하나, 법정추인으로 인정되기 위해서는 '추인'으로서의 요건을 갖추어야 한다. 정답: ②

17 주소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 주민등록지는 반증이 없는 한 주소로 추정된다.
- ② 주소를 정하거나 변경함에 있어서 정주의 의사가 필요한 것은 아니다.
- ③ 주소는 동시에 두 곳 이상 둘 수 있다.
- ④ 가주소는 특정 거래관계에 관하여 주소로서의 기능을 갖는다.
- ⑤ 주소는 변제 장소를 정하는 표준이 될 수 없다.

해설

◎ 주소와 비슷한 개념

거 소	㉠ 다소간 계속하여 거주하는 장소로 장소와의 밀접도가 주소만 못한 곳이다. ㉡ 주소를 알 수 없을 때와 국내에 주소가 없는 자에 대해서는 거소를 주소로 본다.
현재지	㉠ 장소와의 밀접도가 거소보다 못한 곳이다. ㉡ 민법상의 거소는 현재지를 포함하는 것으로 해석한다.
가주소	㉠ 어떤 거래에 관하여 당사자가 일정한 장소를 정하여 주소로 정한 때, 그 장소를 말한다. ㉡ 가주소는 그 거래관계에 있어서는 주소로서의 효과를 가진다.
주민등록지	㉠ 주민등록법에 의하여 등록한 곳을 의미한다. ㉡ 주민등록지는 공법상의 개념이며 민법상의 주소와는 다르다.

⑤ 민법상 주소는 변제 장소를 정하는 표준이 된다(제467조). 정답: ⑤

18 다음은 주소와 관련한 민법의 내용이다. 틀린 것은?

- ① 생활의 근거되는 곳을 주소로 한다.
- ② 주소는 동시에 두 곳 이상 있을 수 있다.
- ③ 주소를 알 수 없으면 거소를 주소로 본다.
- ④ 국내에 주소 없는 자에 대하여는 국내에 있는 거소를 주소로 본다.
- ⑤ 가주소를 정한 때에는 모든 법률행위에 관하여 이를 주소로 본다.

해설

◎ 입법주의

형식주의	형식적인 표준에 따라 획일적으로 주소를 결정
실질주의	생활의 실질관계를 중시하여 구체적으로 결정(제18조 제1항)
의사주의	생활의 근거라는 객관적 사실 외에 정주의 의사까지 필요하다는 주의
객관주의	정주의 사실만으로 주소를 결정(명문규정은 없으나 통설)
단수주의	주소를 한 곳밖에 인정하지 않는 주의
복수주의	주소는 동시에 두 곳 이상 둘 수 있다는 주의(제18조 제2항)

⑤ 어느 행위에 있어서 가주소를 정한 때에는 그 행위에 관하여는 이를 주소로 본다(제21조).

① 제18조 제1항, ② 제18조 제2항, ③ 제19조, ④ 제20조 정답: ⑤

19 부재자재산관리제도에 관한 다음 설명 가운데 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부재자가 사전에 재산관리인을 정해 둔 이상 법원은 재산관리인을 선임할 수 없다.
- ② 법원에 의해 선임된 재산관리인은 일종의 법정대리인이다.
- ③ 법원에 의해 선임된 재산관리인이 법원의 허가 없이 처분행위를 한 경우 그 처분행위는 무효이다.
- ④ 재산관리인의 처분행위에 대한 법원의 허가는 과거의 처분에 대한 추인을 위해서도 할 수 있다.
- ⑤ 법원은 자신이 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다.

해설

- ① 부재자가 직접 재산관리인을 정한 경우에는 법원이 개입하지 않는 것이 원칙이나 본인의 부재중에 관리인의 권한이 소멸하거나 부재자의 생사가 불명(不明)하게 된 경우에는 이해관계인이나 감사의 청구에 의해 재산관리인을 개임할 수 있다. 정답: ①

20 부재와 실종에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전쟁으로 인한 특별실종기간은 3년이다.
- ② 법원은 법원이 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 보수를 지급할 수 없다.
- ③ 법원이 선임한 재산관리인은 그 부재자의 사망이 확인되면 선임결정이 취소되지 않더라도 관리인으로서의 권한이 소멸된다.
- ④ 법원이 선임한 재산관리인이 법원의 허가 없이 부재자 소유의 부동산을 매각한 후에 법원의 허가를 얻었다면, 그 처분행위는 추인한 것으로 된다.
- ⑤ 실종선고를 받은 자의 직계존속은 선순위 상속인이 있더라도 상속인으로서 실종선고의 취소를 청구할 수 있다.

해설

- ④ 부재자 재산관리인에 의한 부재자 소유의 부동산 매매행위에 대한 법원의 허가결정은 그 허가를 받은 재산에 대한 장래의 처분행위뿐만 아니라 과거의 처분행위(기왕의 매매)에 대한 추인으로도 할 수 있다(대법원 2000.12.26. 99다19278).
- ① 전쟁으로 인한 특별실종기간은 1년이다.
- ② 법원은 법원이 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 보수를 지급할 수 있다.
- ③ 법원이 선임한 부재자의 재산관리인은 그 부재자의 사망이 확인된 후라 하더라도 그 선임결정이 취소되지 않는 한 그 관리인으로서의 권한이 소멸되는 것은 아니다(대법원 1971.03.23. 71다189).
- ⑤ 부재자의 제1순위 재산상속인이 있는 경우에 제2순위의 재산상속인은 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다(대법원 1980.09.08. 80스27). 정답: ④

21

부재와 실종에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법원에 의해 부재자의 재산관리인이 선임되면 그때부터 부재자는 사망한 것으로 본다.
- ② 실종선고가 내려지면 실종기간 만료시 사망한 것으로 본다.
- ③ 추락한 항공기에 있었던 자의 생사가 항공기의 추락 후 1년간 분명하지 않은 경우 실종 선고를 청구할 수 있다.
- ④ 원칙적으로 실종선고의 취소에는 소급효가 있다.
- ⑤ 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력은 실종선고의 취소에 의해 영향을 받지 않는다.

해설

- ① 실종선고를 받은 부재자는 실종기간이 만료한 때(보통실종은 5년, 특별실종은 1년)에 사망한 것으로 본다(제28조). 부재자의 재산관리제도는 부재자가 돌아올 것으로 보고 그의 재산을 관리하는 1단계 제도이며 부재자의 사망과는 관계가 없다.
- ② 실종선고가 내려지면 실종기간 만료시 사망한 것으로 본다.
- ③ 실종선고의 청구는 해당 실종기간이 만료된 후에 청구하여야 하는 것으로 법문(法文)상 해석한다. 따라서 항공기 실종의 경우 항공기 추락 1년 후 실종선고를 청구할 수 있다(제27조 제2항).
- ⑤ 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제29조 제1항).

정답: ①

22

실종선고에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 실종선고를 받은 자는 재산법적 관계에서 뿐만 아니라 가족법적 관계에서도 사망한 것으로 간주된다.
- ② 제1순위의 상속인이 있는 경우에 제2순위의 상속인은 실종선고를 청구할 수 없다.
- ③ 실종선고에 의한 사망의 효과는 실종선고시에 발생한다.
- ④ 실종선고의 요건이 갖추어진 경우 법원은 반드시 실종선고를 하여야 한다.
- ⑤ 실종선고를 받은 자는 생존하고 있는 한 권리능력을 상실하지는 않는다.

해설

- ③ 실종선고가 내려지면 실종기간 만료시에 사망한 것으로 본다.
- ① 실종선고는 실종자의 종래의 주소를 중심으로 하는 사법적 법률관계만을 종료케 하는 것으로서 재산법적 관계와 가족법적 관계를 불문한다.
- ② 민법 제27조의 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 부재자의 법률상 사망으로 인하여 직접적으로 신분상 또는 경제상의 권리를 취득하거나 의무를 면하게 되는 사람만을 뜻하므로 부재자의 자매로서 제2순위 상속인에 불과한 자는 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다(대법원 1986.1.10. 86스20).
- ④ 실종선고는 필연적 선고이다(제27조 제1항).
- ⑤ 사망한 것으로 본다는 것은 실종선고는 실종자의 종래의 주소를 중심으로 하는 사법적 법률관계만을 종료케 하는 것이지, 권리능력은 오직 사망에 의하여서만 상실된다. 정답: ③

23 실종선고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 추락한 항공기 중에 있던 자의 실종기간은 항공기가 추락한 때부터 기산한다.
- ② 생사가 불명한 자의 제1순위의 상속인이 있는 경우에 제2순위의 상속인은 실종선고를 청구할 수 없다.
- ③ 실종선고로 인한 사망의 효과를 바로잡기 위해서는 반드시 실종선고를 취소하여야 한다.
- ④ 실종선고가 취소되더라도 '실종기간 만료 후 그 취소 전'에 선의로 한 법률행위에는 영향을 미치지 않는다.
- ⑤ 실종선고를 직접 원인으로 하여 재산을 취득한 자가 선의라면 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환하면 된다.

해설

- ④ 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다(제29조 제2항). 여기서 선의란 실종선고가 사실과 다르다는 사실을 알지 못함을 의미한다. 정답: ④

24 甲은 유람선에 乙과 함께 승선하였는데 선박이 2021년 4월 1일에 침몰하였고, 그 후 甲이 생사불명인 상태에서 2023년 5월 1일에 실종선고를 받았다. 이 경우 甲의 사망일은?

- ① 2021. 4. 1 ② 2022. 4. 1 ③ 2023. 4. 1
- ④ 2023. 3. 31 ⑤ 2023. 5. 1

해설

- ② 실종선고가 있으면 선고를 받은 자는 실종선고 만료시에 사망한 것으로 간주되므로(제28조), 실종기간 만료시까지는 실종자가 생존한 것으로 추정된다. 따라서 특별실종기간 1년을 계산하면 2022년 4월 1일 오후 12시(24시)가 된다. 정답: ②

25 실종선고에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 실종선고를 받은 자가 살아서 돌아온 경우에 그 자가 형성한 새로운 법률관계는 실종선고의 취소가 없더라도 유효하다.
- ② 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인에는 사실상의 이해관계인은 포함되지 않는다.
- ③ 실종선고가 확정되기 전이라도 실종기간이 만료된 실종자는 소송상 당사자능력을 상실한다.
- ④ 실종선고의 취소는 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ 甲에 대한 실종선고로 선의의 자(子)인 乙이 1천만 원을 상속받아 자신의 노력으로 이 돈을 3천만 원으로 증식하였는데, 그 후 실종선고가 취소되면 乙은 1천만 원을 반환하면 된다.

해설

㉠ 실종의 효과

- ㉡ 실종기간 만료시에 사망한 것으로 간주한다.
- ㉢ 실종선고가 취소되지 않는 한 반증으로 선고의 효과를 다투지 못한다.
- ㉣ 실종자의 종래의 주소를 중심으로 하는 사법적 법률관계만을 종료케 한다.
- ㉤ 생환 후의 법률관계나 신주소지에서의 법률관계에는 선고의 효과가 미치지 않는다.
- ㉥ 공법관계에는 선고의 효과가 미치지 않는다.
- ③ 실종선고제도는 권리능력 자체를 박탈하는 제도가 아님을 주의하여야 한다. 따라서 선고가 있기 전에는 소송상 당사자능력을 상실하지 않는다. 정답: ③

26

甲 생명보험회사는 乙의 실종선고로 인하여 보험수익자로 지정된 乙의 처 丙에게 보험금을 지급하였는데 후일 乙이 생환하여 자신에게 내려진 실종선고를 취소한 경우, 甲 생명보험회사는 이미 丙에게 지급된 보험금의 반환을 주장할 수 있을 것인가에 관한 다음 기술 중 맞는 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙의 선의, 악의를 불문하고 원칙적으로 반환을 청구할 수 있다.
- ② 사망과 달리 그 반환을 청구할 수 없다.
- ③ 丙이 선의인 경우에만 반환을 청구할 수 없다.
- ④ 丙이 악의인 경우에만 현존이익의 범위 안에서 청구할 수 있다.
- ⑤ 丙이 선의인 경우에도 받은 이익의 범위 안에서 청구할 수 있다.

해설

- ① 실종선고로 직접 재산을 취득한 자가 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환하여야 하고, 악의인 경우에는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하고, 손해가 있으면 그것을 배상하여야 한다. 정답: ①

27

16세인 미성년자가 단독으로 유효하게 할 수 없는 법률행위는?

- ① 유언행위
- ② 대리행위
- ③ 의무만을 면하는 행위
- ④ 권리만을 얻는 행위
- ⑤ 법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산의 처분행위

해설

- ① 만17세에 달한 자는 단독으로 유언을 할 수 있다(1061조). 정답: ①

- 28 甲은 취소할 수 없는 법률행위의 범위를 정함이 없이 성년후견개시심판을 받았다. 그 후 甲은 법정대리인 乙의 동의서를 위조하는 방법으로 乙의 동의가 있는 것처럼 믿게 하여 자기 소유 건물을 丙에게 매각하는 계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉠ 乙은 丙을 상대로 계약을 취소할 수 있다.
 ㉡ 丙은 甲을 상대로 계약의 추인여부에 대한 확답을 촉구할 수 있다.
 ㉢ 계약 당시 甲이 제한능력자임을 丙이 알았더라도 그 추인이 있기 전까지 丙은 乙을 상대로 자기의 의사표시를 철회할 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉡ 제한능력자는 최고(확답촉구)의 상대방이 될 수 없다.
 ㉢ 선의의 상대방은 철회권을 행사할 수 있으나 악의의 상대방에게는 인정되지 않는다. 정답: ④

01 甲남과 乙녀는 법률상 부부인데 乙은 태아 A를 임신 중이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① A가 살아서 태어났다면 출생신고와 상관없이 권리능력을 취득한다.
- ② 甲의 동생 丙이 태아인 A를 대리한 甲과의 계약으로 자신의 아파트를 A에게 증여하는 것은 불가능하다.
- ③ 甲이 丁의 음주운전차량에 치어 사망한 경우, 그 당시 태아인 A는 이후에 출생하였다고 하더라도 丁에 대해 위자료청구권을 행사하지 못한다.
- ④ 의사 戊가 乙을 진료하던 중에 약물을 잘못 투여하여 태아인 A가 사산되었다면 A에게 戊에 대한 손해배상청구권이 인정되지 않는다.
- ⑤ 甲의 동생 丙은 태아인 A에게 자신의 아파트를 유증할 수 있다.

해설

③ 甲이 丁의 음주운전차량에 치어 사망한 경우, 그 당시 태아인 A는 이후에 출생함을 전제로 가해자 丁에 대해 불법행위로 인한 손해배상청구권(위자료청구권)을 행사할 수 있다. 정답: ③

02 태아의 권리능력에 관한 아래 설명 중 맞는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 직계존속의 생명침해에 대해 태아는 위자료를 청구할 수 있다.
- ㉡ 태아는 대습상속에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.
- ㉢ 판례는 사인증여의 경우에 있어서 태아의 수증능력을 인정한다.
- ㉣ 판례가 취하는 정지조건설에 의하면 태아의 보호를 위한 법정대리인을 인정할 수 있다.
- ㉤ 현행 민법상 父는 태아를 인지할 수 있지만, 태아에게는 부(父)에 대한 인지청구권이 없다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉡, ㉤
- ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉢, ㉤
- ⑤ ㉠, ㉣, ㉤

해설

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ 태아는 불법행위로 인한 손해배상청구권에 대하여 이미 출생한 것으로 본다.
- ㉡ 대습상속에 대하여도 태아는 이미 출생한 것으로 본다.
- ㉤ 태아의 부(父)에 대한 인지청구권은 인정되지 않는다. 정답: ②

03 해외지사에서 장기간 파견근무를 하게 된 甲은 사촌동생 乙에게 자신 소유의 X건물에 대한 관리·처분을 위임하였다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙이 X건물을 매각함에 있어 甲에게 경제적으로 불리한 계약이라도 법원의 허가를 받을 필요는 없다.
- ② 乙의 권한이 甲의 부재중에 소멸한 경우, 가정법원은 甲의 추정상속인의 청구가 있으면 재산관리에 필요한 처분을 명해야 한다.
- ③ 甲의 생사가 불명하여 법원이 乙을 甲의 재산관리인으로 유임한 경우, 乙은 법원의 허가 없이 X건물을 매각할 수 있다.
- ④ 甲이 사망하더라도 乙은 甲의 상속인 등이 X건물에 대한 관리업무를 할 수 있을 때까지 그 사무의 처리를 계속하여야 한다.
- ⑤ 甲의 생사가 불명하여 법원이 새로 선임한 재산관리인은 재산관리를 위하여 지출한 필요비와 그 이자를 법원에 청구할 수 있다.

해설

- ③ 甲의 생사가 불명하여 법원이 乙을 甲의 재산관리인으로 유임한 경우, 乙은 법정대리인이므로 매각 행위와 같은 처분행위를 하는 경우에는 가정법원의 허가를 받아야 하고, 이에 위반한 처분행위는 무효가 된다. 정답: ③

04 권리주체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 의사능력은 자신의 행위의 의미와 결과를 합리적으로 판단할 수 있는 정신적 능력으로 구체적인 법률행위와 관련하여 개별적으로 판단되어야 한다.
- ② 어떤 법률행위가 일상적인 의미만으로 알기 어려운 특별한 법률적 의미나 효과를 가진 경우, 이를 이해할 수 있을 때 의사능력이 인정된다.
- ③ 현행 민법은 태아의 권리능력에 관하여 일반적 보호주의를 취한다.
- ④ 태아의 상태에서는 법정대리인이 있을 수 없고, 법정대리인에 의한 수증행위도 할 수 없다.
- ⑤ 피상속인과 그의 직계비속 또는 형제자매가 동시에 사망한 것으로 추정되는 경우에도 대습 상속이 인정된다.

해설

- ③ 우리 민법은 개별적 보호주의에 따라 태아의 권리능력을 인정하고 있다. 정답: ③

05

미성년자인 甲은 행위능력자 乙과 자기소유의 자전거를 매도하는 계약을 체결하였고, 乙은 그 후 甲이 미성년자라는 사실을 알게 되었다. 甲에게는 친권자 丙이 있으며 甲은 여전히 미성년자이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 乙은 丙에게 매매계약의 추인여부를 최고할 수 있다.
- ② 乙의 최고에 대해서 유예기간 내에 丙이 확답을 발하지 않으면 추인을 거절한 것으로 본다.
- ③ 乙은 丙의 추인이 있기 전까지 丙뿐만 아니라 甲에 대해서도 매수의 의사표시를 철회할 수 있다.
- ④ 甲은 단독으로 매매계약을 추인할 수 없다.
- ⑤ 甲이 속임수로 丙의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우, 甲은 매매계약을 취소하지 못한다.

해설

- ② 미성년자인 甲소유의 자전거를 매수하는 계약을 체결한 행위능력자인 상대방 乙은 친권자인 법정 대리인 丙에게 1월 이상의 기간을 정하여 최고할 수 있고 유예기간 내에 丙이 확답을 발하지 않으면 추인한 것으로 본다(제15조 제2항).
- ① 상대방 乙은 제한능력자인 미성년자인 甲에게는 추인할 수 없지만 친권자인 丙에게 매매계약의 추인여부를 최고할 수 있다.
- ③ 상대방 乙은 친권자 丙의 추인이 있기 전까지 친권자 丙뿐만 아니라 미성년자인 甲에 대해서도 매수의 의사표시를 철회할 수 있다(제16조 제3항).
- ④ 미성년자 甲은 여전히 미성년 상태에 있으므로 취소원인 종료 후가 아니면 단독으로 매매계약을 추인할 수 없고 친권자의 동의를 얻거나 성년이 된 후에 추인할 수 있다.
- ⑤ 미성년자 甲이 속임수로 친권자 丙의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우, 甲은 매매계약을 취소하지 못한다(제17조 제2항). 정답: ②

06

미성년자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 1995. 3. 30. 오후 9시에 출생한 자는 2014. 3. 29. 오후 12시에 성년자로 된다.
- ② 법정대리인이 미성년자에게 특정한 영업을 허락한 경우에 미성년자는 그 영업에 관하여 성년자와 동일한 행위능력을 가진다.
- ③ 미성년자가 부담 없는 증여를 받는 행위는 법정대리인의 동의를 요하지 않는다.
- ④ 미성년자가 월 소득범위 내에서 소규모의 일상적인 신용구매계약을 체결하였더라도 스스로 얻은 소득에 대해 법정대리인의 묵시적 처분허락이 있었다고 볼 수는 없다.
- ⑤ 미성년자는 자신의 노무제공에 대한 임금의 청구를 독자적으로 할 수 있다.

해설

- ④ 미성년자가 월 소득범위 내에서 신용구매계약을 체결한 사안에서, 스스로 얻고 있던 소득에 대하여는 법정대리인의 묵시적 처분허락이 있었다고 보아 위 신용구매계약은 처분허락을 받은 재산범위 내의 처분행위에 해당한다(대법원 2007.11.16. 2005다71659). 정답: ④

07 미성년자 甲의 행위에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲이 매매계약을 체결한 후 그 후 성년이 되어 대금을 수령하면 甲은 이 계약을 추인했다고 볼 수 있다.
- ② 甲이 대학생활을 시작하면서 원룸에서 법정대리인의 동의를 얻지 않고 전기, 수도의 공급 계약을 체결한 경우 甲은 이 계약을 취소할 수 있다.
- ③ 甲의 법정대리인이 甲이 매매계약을 체결한 것을 알고 있으면서 3년간 취소권을 행사하지 않는 경우 甲의 취소권은 소멸한다.
- ④ 甲이 乙로부터 그 소유의 토지의 매각을 위임받고 乙의 대리인으로서 丙과 매매계약을 체결하였지만 그 후 乙과의 관계에서 위임계약을 취소한 경우 대리권이 소급적으로 소멸 하더라도 乙, 丙간의 계약은 효력을 잃지 않는다.
- ⑤ 甲이 그 소유 동산을 법정대리인의 동의를 얻지 않고 선의·무과실인 乙에게 매각하여 인도한 경우 甲의 법정대리인이 그 계약을 취소하면 乙은 그 동산의 소유권을 취득할 수 없다.

해설

② 사실적 계약관계에는 제한능력자제도가 적용되지 않는다.

① 제145조

③ 제146조(취소권의 단기소멸) 참조 정답: ②

08 제한능력자에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉠ 만18세의 미성년자가 자기의 월 근로소득 범위 내에서 신용구매계약을 체결한 경우, 그 신용구매계약은 처분허락을 받은 재산범위 내의 처분행위에 해당한다.
- ㉡ 한정후견인의 동의가 필요한 법률행위를 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 하였을 때에는 그것이 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위가 아닌 경우 그 법률행위를 취소할 수 있다.
- ㉢ 제한능력자가 아직 능력자가 되지 못한 경우에도 그 상대방은 그에게 1개월 이상의 기간을 정하여 추인 여부의 확답을 촉구할 수 있다.
- ㉣ 제한능력자와 계약을 맺은 선의의 상대방은 추인이 있기 전까지 의사표시를 거절할 수 있다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢

④ ㉡, ㉣

⑤ ㉢, ㉣

해설

틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

㉢ 제한능력자가 아직 능력자가 되지 못한 경우에는 최고(확답촉구)의 상대방이 될 수 없다.

㉣ 제한능력자와 계약을 맺은 선의의 상대방은 추인이 있기 전까지 의사표시를 철회할 수 있다.

정답: ①

09

성년후견 및 한정후견제도에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있으나, 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수도 있다.
- ② 지방자치단체의 장은 가정법원에 성년후견개시, 성년후견종료, 한정후견개시 및 한정후견종료의 심판을 모두 청구할 수 있다.
- ③ 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 피성년후견인의 법률행위는 성년후견인이 취소할 수 없다.
- ④ 가정법원은 성년후견개시의 경우와는 달리 한정후견개시의 심판을 할 때에는 본인의 의사를 고려하지 않을 수도 있다.
- ⑤ 가정법원은 성년후견개시의 원인이 소멸된 경우 본인의 청구에 의하여 성년후견종료의 심판을 할 수도 있다.

해설

- ④ 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다(제9조 제2항). 한정후견개시의 경우에 제9조 제2항을 준용한다(제12조 제2항). 따라서 가정법원은 성년후견개시의 경우 뿐만 아니라 한정후견개시의 심판을 할 때에도 본인의 의사를 고려하여야 한다. 정답: ④

10

제한능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 성년후견인은 여러 명을 둘 수 있다.
- ② 가정법원은 본인의 청구에 의하여 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 변경할 수 있다.
- ③ 가정법원이 피성년후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 성년후견의 종료 심판을 하여야 한다.
- ④ 한정후견의 개시를 청구한 사건에서 의사의 감정 결과 성년후견 개시의 요건을 충족하고 있다면 법원은 본인의 의사를 고려하지 않고 성년후견을 개시할 수 있다.
- ⑤ 특정후견의 심판이 있는 후에 피특정후견인이 특정후견인의 동의 없이 재산상의 법률행위를 하더라도 이는 취소의 대상이 되지 않는다.

해설

- ④ 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다(제9조 제2항). 정답: ④

11

성년인 甲은 질병으로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 상태이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ① 甲은 스스로 한정후견개시의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 가정법원은 甲에 대한 한정후견개시의 심판을 할 때 甲의 의사를 고려해야 한다.
- ③ 甲의 배우자가 甲에 대한 성년후견개시의 심판을 청구한 경우에도 가정법원은 필요하다면 한정후견개시의 심판을 할 수 있다.

- ④ 가정법원은 甲에 대한 한정후견개시의 심판을 할 때 취소할 수 없는 甲의 법률행위의 범위를 정할 수 있다.
- ⑤ 甲에 대한 한정후견개시의 심판이 있은 후 한정후견개시의 원인이 소멸된 경우, 甲은 한정후견종료의 심판을 청구할 수 있다.

해설

- ④ 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다(제10조 제2항). 그러나 ④의 지문은 규정된 바 없으며, 가정법원은 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 있다(제13조 제1항)고 규정하고 있다. 정답: ④

12 성년후견개시의 심판과 피성년후견인의 행위능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다.
- ② 성년후견의 개시 또는 종료를 위한 심판은 본인도 청구할 수 있다.
- ③ 가정법원은 피성년후견인이 성년후견인의 동의를 받아야 하는 법률행위의 범위를 정할 수 있다.
- ④ 피성년후견인이 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위를 한 경우, 성년후견인은 이를 취소할 수 없다.
- ⑤ 가정법원은 일정한 자의 청구가 있는 경우, 가정법원이 취소할 수 없는 것으로 정한 피성년후견인의 법률행위의 범위를 변경할 수 있다.

해설

- ③ 한정후견인에게는 동의권이 있으나 성년후견인에게는 동의권이 없다. 물론 대리권과 취소권이 인정됨은 당연하다. 정답: ③

13 제한능력자에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 2000년 2월 21일 23시에 출생한 자는 2019년 2월 20일 오전 0시부터 민법상 성년으로 된다.
- ② 피성년후견인이 속임수로서 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에는 그 행위를 취소할 수 없다.
- ③ 제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있으나, 상대방이 그 단독행위 당시에 제한능력자임을 알았을 경우에는 거절할 수 없다.
- ④ 혼인한 미성년자라도 협의상 이혼을 할 경우에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다.
- ⑤ 가정법원이 피성년후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 성년후견의 종료 심판을 한다.

- ㉔ 가정법원이 피한정후견인 또는 피특정후견인에 대하여 성년후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 한정후견 또는 특정후견의 종료 심판을 하고, 피성년후견인 또는 피특정후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 성년후견 또는 특정후견의 종료 심판을 한다(제14조의3).
- ㉕ 2000년 2월 21일 23시에 출생한 자는 2019년 2월 20일 24시에 민법상 성년이 된다.
- ㉖ 피성년후견인이 속임수로서 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에도 취소권은 소멸하지 않는다. 성년후견인에게는 동의권이 없기 때문이다.
- ㉗ 제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있으며, 이 때 상대방의 거절권은 악의인 경우에도 인정된다.
- ㉘ 혼인한 미성년자는 성년으로 의제되므로 협의상 이혼을 하는 경우에도 법정대리인의 동의를 요하지 않는다. 정답: ㉔

14

만 15세의 미성년자 甲은 친권자 丙의 동의를 얻어 자신의 소유인 X 토지를 乙에게 매도하는 경우, 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 丙의 동의는 명시적으로 뿐만 아니라 묵시적으로도 가능하다.
- ㉡ 丙이 동의를 할 때에는 친족회의 동의를 필요로 한다.
- ㉢ 丙의 동의는 甲의 법률행위 이전에 하여야 하고 이후에 하는 동의는 효력이 없다.
- ㉣ 甲이 丙의 동의가 있는 것처럼 보이기 위하여 소극적인 사술을 쓴 것만으로도 취소권이 배제된다.
- ㉤ X 토지가 甲 명의의 매매계약서에 근거하여 乙에게 소유권이전등기가 경료되었다면, 丙의 동의 여부와 관계없이 적법한 등기로 추정된다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㅅ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㅁ, ㅁ

해설

※ 옳은 것을 기술했다면 다음과 같다.

- ㉠ 법정대리인의 동의는 명시적으로 뿐만 아니라 묵시적으로도 가능하다.
- ㉡ 등기절차의 적법추정을 기술하고 있다. 즉 전등기명의인이 미성년자라 하더라도 일단 상대방에게 이전등기가 경료되었다면 적법한 절차를 거친 것으로 추정된다. 정답: ㉡

15

제한능력자의 상대방을 보호하기 위한 제도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 최고의 상대방은 최고를 수령할 능력과 최소나 추인을 할 수 있는 능력이 있어야 한다.
- ② 미성년자가 사술로써 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에는 그 행위를 취소하지 못한다.
- ③ 제한능력자의 단독행위에 대한 거절은 상대방이 의사표시를 수령할 당시에 선의 또는 악의였는지를 불문하고 인정된다.

- ④ 상대방은 제한능력자 측에서 추인하기 전까지 그의 의사표시를 철회할 수 있지만, 제한능력자에 대하여는 능력자로 된 경우에만 철회의 의사표시를 할 수 있다.
- ⑤ 최고를 받은 자가 유예기간 내에 추인 또는 취소의 응답을 하면 각각 그에 따른 효과가 생기며, 최고의 효과는 유예기간 내에 응답을 발하지 않은 경우에 발생한다.

해설

- ④ 거절권과 철회권은 제한능력자에게도 행사할 수 있다(제16조 제3항).
- ③ 철회권과는 달리 악의의 상대방도 거절권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 제15조

정답: ④

16 제한능력자와 거래한 상대방을 보호하기 위한 제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 미성년자와 부동산매매계약을 체결한 자가 미성년자의 친권자에게 1개월 이상의 기간을 정하여 그 취소할 수 있는 행위에 대한 추인 여부의 응답을 촉구하였으나 친권자가 그 기간 내에 응답을 발송하지 않은 때에는 추인을 거절한 것으로 본다.
- ② 미성년자와 계약을 체결한 상대방이 미성년자의 취소권을 배제하기 위하여 “미성년자가 속임수를 썼다”고 주장하는 경우, 취소권의 배제를 주장하는 자에게 그 증명책임이 있다.
- ③ 제한능력자와 거래한 상대방이 법률행위 당시 제한능력자임을 알고 있었을 경우, 상대방은 응답촉구권을 행사할 수 있다.
- ④ 철회나 거절의 의사표시는 제한능력자에 대하여도 할 수 있다.
- ⑤ 매매 당시 미성년자가 상대방에게 성년자로 군대에 갔다 왔다고 말한 사실이 있었다고 해서 민법 제17조의 속임수를 쓴 경우에 해당되지 않는다.

해설

- ① 제한능력자가 아직 능력이 되지 못한 경우에는 그의 법정대리인에게 1개월 이상의 기간을 정하여 그 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지 여부의 응답을 촉구할 수 있고, 법정대리인이 그 정한 기간 내에 응답을 발송하지 아니한 경우에는 그 행위를 추인한 것으로 본다(제15조 제2항).

정답: ①

17 제한능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2021' 감정평가사]

- ① 가정법원은 한정후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하지 않아도 된다.
- ② 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있으나, 성년후견인의 청구에 의하여 이를 변경할 수 있다.
- ③ 성년후견인은 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 않은 피성년후견인의 법률행위를 취소할 수 없다.
- ④ 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다.
- ⑤ 피성년후견인이 성년후견인의 동의를 얻어 재산상의 법률행위를 한 경우에도 성년후견인은 이를 취소할 수 있다.

해설

- ① 가정법원은 한정후견개시 또는 성년후견개시의 심판을 할 때에는 본인의 의사를 고려하여야 한다.

정답: ①

18 제한능력제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피성년후견인이 행한 모든 재산법상의 법률행위는 언제든지 취소할 수 있다.
- ② 가정법원은 한정후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다.
- ③ 가정법원은 특정후견의 심판을 할 때 본인의 의사에 반하여 할 수 없다.
- ④ 가정법원이 피한정후견인에 대해 성년후견개시의 심판을 하는 경우, 종전의 한정후견의 종료심판을 한다.
- ⑤ 가정법원은 청구권자의 청구가 없는 한, 성년후견개시의 심판을 직권으로 할 수 없다.

해설

- ① 피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다(제10조 제1항). 그러나 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위는 성년후견인이 취소할 수 없다(제10조 제4항).

답: ①

19 금년 19세인 대학생 A는 유흥비를 마련하기 위하여 부모의 동의없이 타고 다니던 자동차를 중고 자동차상 B에게 500만 원에 팔기로 하고, 계약금조로 100만 원을 수령한 후, 이 중 50만 원은 유흥비로 탕진하고, 50만 원으로는 친구에게 빌린 돈을 갚았다. 이 경우 다음 중 틀린 것은? (견해의 대립시 판례에 의함)

- ① A가 미성년인 상태에서도 부모의 동의없이 위 매매계약을 유효하게 취소할 수 있다.
- ② 이 때 A는 B에게 채무변제에 사용한 50만 원만 반환하면 된다.
- ③ 매매계약 당시 A가 단순히 나이를 속였다면, A나 A의 부모는 위 매매계약을 취소할 수 없다.
- ④ B는 위 매매계약 당시 A가 제한능력자임을 알았다면, 자기의 의사표시를 철회할 수 없다.
- ⑤ B가 A측에 대하여 최고권을 가지지만 A가 아직 미성년이라면 그는 최고의 상대방이 될 수 없다.

해설

- ③ 소극적 속임수(예: 단순히 능력자라고 칭하는 정도)는 사술(속임수)에 해당하지 않는다고 보는 것이 판례의 태도이므로 취소할 수 있다(대법원 1971.12.24. 71다2045). 정답: ③

20 미성년자 A는 자기 재산인 토지(시가 1억)를 B에게 6,000만 원에 매매계약을 체결하고 계약금과 중도금을 합하여 3,000만 원을 수령하여 1,000만 원은 생활비에 충당하고 2,000만 원은 낭비하였다. 다음 예문에서 가장 타당한 것을 선택하면? (견해의 대립시 판례에 의함)

- ① 미성년자가 사술을 쓴 경우에는 법정대리인은 취소할 수 있다.
- ② 위의 계약이 법정대리인의 동의를 받지 아니하였고 B가 계약 당시 미성년자임을 안 경우에는 매매계약에 대한 추인 여부의 확답을 최고할 수 없다.

- ③ 법정대리인의 동의를 받지 않아 계약이 취소된 경우 미성년자 측에서는 3,000만 원을 반환하여야 한다.
- ④ 미성년자 측에서 공박·경솔·무경험에 의한 무효를 주장할 수 없다.
- ⑤ 미성년자 측에서 계약을 취소한 경우 제3자의 선의·악의를 불문하고 제3자에 대하여 반환청구를 할 수 있다.

해설

- ⑤ 제한능력자의 취소는 절대적이다. 즉, 선의의 제3자에게도 대항할 수 있다.
- ① 제한능력자가 사술을 쓴 경우에는 취소권은 배제된다(제17조 제1항).
- ② 제한능력자임을 안 경우에도 상대방은 최고권을 행사할 수 있다.
- ③ 제한능력자는 받은 이익의 현존하는 한도 내에서 상환할 책임이 있다(제141조 단서).
- ④ 제104조(불공정한 법률행위)의 요건이 충족되는 경우에는 폭리행위를 이유로 무효를 주장할 수 있다. 정답: ⑤

21 미성년자 甲과 그의 유일한 법정대리인인 乙에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 甲이 그 소유 물건에 대한 매매계약을 체결한 후에 미성년인 상태에서 매매대금의 이행을 청구하여 대금을 모두 지급받았다면 乙은 그 매매계약을 취소할 수 없다.
- ② 乙이 甲에게 특정한 영업에 관한 허락을 한 경우에도 乙은 그 영업에 관하여 여전히 甲을 대리할 수 있다.
- ③ 甲이 乙의 동의 없이 타인의 적법한 대리인으로서 법률행위를 했더라도 乙은 甲의 제한능력을 이유로 그 법률행위를 취소할 수 있다.
- ④ 甲이 乙의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 이후에 乙의 동의 없음을 이유로 그 계약을 취소하는 것은 신의칙에 반한다.
- ⑤ 乙이 재산의 범위를 정하여 甲에게 처분을 허락한 경우, 甲이 그에 관한 법률행위를 하기 전에는 乙은 그 허락을 취소할 수 있다.

해설

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 취소권자가 상대방의 이행을 수령한 경우에도 추인(법정추인)으로 볼 수 있으나, 미성년인 상태에서는 인정될 수 없다.
- ② 법정대리인이 특정영업을 허락한 경우에는 그 한도내에서는 대리권이 제한된다.
- ③ 미성년자도 타인의 대리인이 될 수 있다.
- ④ 甲이 乙의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 이후에 乙은 그 계약을 취소할 수 있다. 다만, 미성년자가 월 소득범위 내에서 신용구매계약을 체결한 경우에는, 스스로 얻고 있던 소득에 대하여는 법정대리인의 묵시적 처분허락이 있었다고 보아 위 신용구매계약은 처분허락을 받은 재산범위 내의 처분행위에 해당한다(대법원 2007.11.16. 2005다71659). 정답: ⑤

22

법원이 부재자 甲의 재산관리인으로 乙을 선임하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲의 재산을 乙이 임의로 처분한 후 법원이 이를 허가하였다면, 乙의 처분행위는 유효한 것으로 된다.
- ② 甲이 사망한 것으로 확인되면 乙의 권한은 즉시 소멸한다.
- ③ 법원은 甲의 재산으로 乙에게 상당한 보수를 지급할 수 있다.
- ④ 甲의 재산을 乙이 법원의 허가를 받아 처분한 후 그 허가결정이 취소되더라도 乙의 처분 행위에는 영향이 없다.
- ⑤ 乙은 법원의 허가가 없더라도 甲의 재산을 그 용도에 따라 제3자에게 임대하고 임대료를 청구할 수 있다.

해설

- ②④ 법원에 의하여 부재자 재산관리인의 선임결정이 있었던 이상, 가령 부재자가 그 이전에 사망하였음이 밝혀졌다 하여도 법에 정한 절차에 따라서 위 선임결정이 취소되지 않는 한 이미 선임된 부재자 재산관리인의 권한은 당연히 소멸되지 아니하며 위 선임결정이 취소된 경우에도 그 취소의 효력은 장래에 향하여서만 생기는 것이다(대법원 1970.7.28, 70다741). 따라서 부재자 甲이 사망한 것으로 확인되더라도 재산관리인 乙의 권한은 선임결정이 취소되지 않는 한 소멸되지 않는다.
- ① 부재자 재산관리인에 의한 부재자 소유의 부동산 매매행위에 대한 법원의 허가결정은 그 허가를 받은 재산에 대한 장래의 처분행위뿐만 아니라 기왕의 매매를 추인하는 방법으로도 할 수 있다(대법원 2000.12.26, 99다19278).
- ③ 제26조 제2항
- ⑤ 재산관리인 乙은 법원의 허가가 없더라도 이용행위나 개량행위를 할 수 있다. 정답: ②

23

부재자의 재산관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 부재자로부터 재산처분권한을 수여받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어 법원의 허가를 받을 필요가 없다.
- ② 부재자가 재산관리인을 정하지 않은 경우, 부재자의 채권자는 재산관리에 필요한 처분을 명할 것을 법원에 청구할 수 있다.
- ③ 법원이 선임한 재산관리인은 법원의 허가 없이 부재자의 재산에 대한 차임을 청구할 수 있다.
- ④ 재산관리인의 처분행위에 대한 법원의 허가는 이미 행한 처분행위를 추인하는 방법으로 할 수 있다.
- ⑤ 부재자가 사망한 사실이 확인되면 부재자 재산관리인 선임결정이 취소되지 않더라도 관리인의 권한은 당연히 소멸한다.

해설

- ⑤ 법원이 선임한 부재자의 재산관리인은 그 부재자의 사망이 확인된 후라 하더라도 그 선임결정이 취소되지 않는 한 그 관리인으로서의 권한이 소멸되는 것은 아니다(대법원 1971.03.23. 71다189). 정답: ⑤

24 부재자가 위임계약을 통하여 자신의 재산관리인을 선임하였으나 그의 생사가 불분명해진 경우에 관한 설명 중 맞는 내용은?

- ① 부재자가 재산관리인을 선임해 두었으므로, 법원은 부재자의 재산관리에 관하여 개입할 수 없다.
- ② 부재자의 생사가 분명하지 않게 되었으므로 법원은 재산관리인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 재산관리인을 개입할 수 있다.
- ③ 가정법원이 직권으로 재산관리인을 개입할 수 있다.
- ④ 법원의 감독이 개시되면 그때부터 재산관리인의 지위는 법정대리인으로 바뀌게 된다.
- ⑤ 부재자의 생사불명에 의하여 재산관리에 관한 위임계약은 당연히 종료되고, 부재자가 재산관리인을 정하지 아니한 경우와 동일한 방법에 의하여 재산관리가 진행된다.

해설

- ② 부재자란 종래의 주소나 거소를 떠나서 당분간 돌아올 가망성이 없어서 그의 재산이 관리되지 못하고 있는 상태에 있는 자인데, 부재자가 재산관리인을 정한 경우에 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에는 법원은 예외적으로 재산관리인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 재산관리인을 개입할 수 있다(제23조). 정답: ②

25 다음 중 미성년자 甲의 친권자 乙과 거래당사자 丙이 법정에서 제시한 근거를 가지고 판단할 경우, 乙이 승소하기 어려운 경우는? (견해의 대립이 있을 경우 판례에 의함)

- ① 乙은 甲과 丙의 부동산 매매계약에 대해 취소한다고 주장한다. 이에 대해 丙은 10일의 기간을 정하여 최고를 하였는데도 乙이 확답을 하지 않았다는 점을 증명하였다.
- ② 乙은 甲이 丙에게 행한 부동산의 증여계약에 대해 취소한다고 주장한다. 이에 대해 丙은 甲에게 최고를 하였는데도 확답을 하지 않았다는 점을 증명하였다.
- ③ 乙은 甲이 丙과 한 부동산매매계약에 대해 추인한다고 주장한다. 이에 대해 丙은 그 전에 甲에게 계약을 철회하였음을 증명하였다.
- ④ 乙은 丙이 이미 철회의 의사표시를 한 甲과 丙의 부동산매매계약에 대해 추인하기를 주장 하면서, 계약 당시 丙이 甲이 미성년자임을 알았음을 증명하였다.
- ⑤ 乙은 甲이 丙과 한 부동산매매계약에 대해 취소한다고 주장한다. 이에 대해 丙은 甲이 계약 당시 아무 말도 하지 않았음을 증명하였다.

해설

- ③ 제한능력자 측의 추인과 상대방의 철회는 무엇이 먼저 행사되었는가에 따라 그 효력이 좌우된다. 따라서 상대방이 이미 철회하였으므로 친권자 乙의 추인은 효력이 없다. 乙이 승소하기 어려운 경우로써 타당한 예문이다.
- ① 제한능력자와 거래한 상대방의 최고는 1월 이상의 유예기간을 정하여 행하여야 한다(제15조).
- ② 상대방의 최고는 법정대리인 또는 제한능력자이었던 본인에게 행사하여야 한다. 따라서 여전히 미성년자 상태인 甲에게 행한 최고는 인정될 수 없다(제15조).
- ④ 상대방이 철회권을 행사하기 위해서는 계약 당시 선의일 것을 요한다(제16조).
- ⑤ 미성년자가 계약 당시 자신이 제한능력자임을 고지하지 않은 것만으로는 취소권이 배제되지 아니한다(제17조). 정답: ③

26

실종선고에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 실종선고를 하여야 한다.
- ② 부재자의 1순위 상속인이 따로 있는 경우 제2순위 내지 3순위 상속인은 특별한 사정이 없는 한 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다.
- ③ 실종선고가 취소되지 않는 한 반증을 들어 실종선고의 효과를 다룰 수 없고, 오직 실종선고를 취소하여야만 사망의 효과를 뒤집을 수 있다.
- ④ 가족관계등록부에 이미 사망한 것으로 기재되어 있는 자에 대하여도 특단의 사정이 없는 한 실종선고를 할 수 없다.
- ⑤ 실종기간의 만료 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력은 실종선고의 취소에 의해 영향을 받지 않는다.

해설

⑤ 제29조【실종선고의 취소】

실종자의 생존한 사실 또는 전조의 규정과 상이한 때에 사망한 사실의 증명이 있으면 법원은 본인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 실종선고를 취소하여야 한다. 그러나 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에 영향을 미치지 아니한다. 정답: ⑤

27

甲은 한라산 관광에 나섰다가 악천후를 만나 행방불명이 되었다. 이 경우의 법률관계에 관하여 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 甲에게 처 乙과 아들 丙이 있었다더라도, 갑의 동생 戊도 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 있다.
- ② 부재자 재산관리인의 선임결정이 있었던 이상 부재자가 사망한 것이 사실이라 하더라도 그 결정이 취소되지 않는 한 관리인의 권한이 당연히 소멸되는 것은 아니다.
- ③ 실종기간 만료 후 실종선고 전에 乙이 丁과 재혼하였는데, 甲이 살아서 돌아왔다면, 甲은 乙과 丁의 혼인을 취소할 수 있다.
- ④ 가족관계등록부상 이미 사망한 것으로 기재되어 있는 자는 그 사망기재의 추정력을 뒤집을 수 있는 자료가 없는 한 그 생사가 불분명한 자라고 볼 수 없어 실종선고를 할 수 없다.
- ⑤ 甲의 실종선고로 인하여 선의인 乙과 丙이 10억을 상속받았는데, 丙은 자기의 상속분 전부를 도박에 탕진한 반면, 乙은 생활비로 1억 원을 사용하고 나머지는 예금하여 둔 경우에 甲이 살아서 돌아와 실종선고가 취소되었다면 甲은 乙로부터 6억 원을 반환 받을 수 있다.

해설

- ① 부재자의 형제자매로서 제2순위 상속인에 불과한 자는 부재자에 대한 실종선고의 여부에 따라 상속지분에 차이가 생긴다고 하더라도 이는 부재자의 사망 간주시기에 따른 간접적인 영향에 불과하고 부재자의 실종선고 자체를 원인으로 한 직접적인 결과는 아니므로 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다(대결 1986.10.10. 자86스20).
- ② 대법원 1967.2.21. 66다2352

- ③ 실종기간만료 후 실종선고 전의 혼인이므로 실종선고 취소로 당연히 전혼이 부활하여 후혼은 중혼이 되어 취소할 수 있게 된다(제818조).
- ④ 대법원 1997.11.27. 97스4
- ⑤ 을과 병은 공동상속인으로서 상속액은 을은 6억 원(3/5의 상속분), 병은 4억 원(2/5의 상속분)이다. 실종선고 취소에서 선의인 상속인은 그 받은 이익이 현존하는 한도 내에서 반환하여야 한다. 예금과 생활비 사용은 이익이 현존한다고 볼 수 있으나, 도박에 탕진한 것은 현존한다고 볼 수 없다. 따라서 갑은 을에게만 6억 원의 반환을 청구할 수 있다. 정답: ①

28 실종선고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2021' 감정평가사]

- ① 가족관계등록부상 이미 사망으로 기재되어 있는 자에 대해서는 원칙적으로 실종선고를 할 수 없다.
- ② 실종선고를 받아 사망으로 간주된 자는 실종선고가 취소되지 않는 한 반증을 통해 그 효력을 번복할 수 없다.
- ③ 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력은 실종선고의 취소에 의해 영향을 받지 않는다.
- ④ 실종선고의 취소에는 공시최고를 요하지 않는다.
- ⑤ 실종자를 당사자로 한 판결이 확정된 후에 실종선고가 확정되어 그 사망간주의 시점이 소 제기 전으로 소급하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 판결은 당사자능력이 없는 사람을 상대로 한 판결로서 무효가 된다.

해설

- ⑤ 실종선고의 효력이 발생하기 전에는 실종기간이 만료된 실종자라 하여도 소송상 당사자능력을 상실하는 것은 아니므로 실종선고 확정 전에는 실종기간이 만료된 실종자를 상대로 하여 제기된 소도 적법하고, 실종자를 당사자로 하여 선고된 판결도 유효하다. 따라서 실종자를 당사자로 한 판결이 확정된 후에 실종선고가 확정되어 그 사망간주의 시점이 소 제기 전으로 소급하는 경우에도 위 판결 자체가 소급하여 당사자능력이 없는 사망한 사람을 상대로 한 판결로서 무효가 된다고는 볼 수 없다(대법원 1992. 7. 14, 92다2455). 정답: ⑤

29 부재자의 재산관리와 실종선고에 관한 다음 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

- ㉠ 법원에 의해 선임된 재산관리인은 언제든지 사임할 수 있다.
- ㉡ 부재자가 재산관리인을 선임한 경우, 그의 생사가 불분명한 경우에도 개임을 청구할 수는 없다.
- ㉢ 부재자재산의 보존등기에 소요된 비용은 법원의 허가를 얻어 손해배상을 청구할 수 있다.
- ㉣ 실종선고의 경우 본인의 생존 기타의 반증을 들어 선고의 효과를 다투지 못한다.
- ㉤ 실종선고가 취소되면 실종선고에 기한 법률관계는 소급적으로 무효가 된다.
- ㉥ 실종선고에 의해 사망으로 간주되는 시기는 실종기간이 만료한 때이므로, 실종기간 만료 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 경우에는 실종선고취소의 효과를 받지 않는다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉢, ㉣

- ② ㉠, ㉢, ㉡, ㉢
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

- ③ ㉠, ㉢, ㉡

해설

- ㉠ 법원에 의하여 선임된 재산관리인은 언제든지 사임할 수 있고 법원도 언제든지 개임할 수 있다 (가사소송규칙 제42조).
㉡ 부재자의 생사가 불분명한 경우에는 이해관계인 등의 청구에 의해 관리인을 개임할 수 있다(제23조).
㉢ 관리인은 재산관리를 위하여 지출한 필요비와 그 이자 및 과실없이 받은 손해배상을 청구할 수 있으며 이 때 법원의 허가는 요하지 아니한다(제24조 제4항).
㉣ 간주주의를 취하는 결과 반증이 제기되더라도 법원의 취소절차를 거쳐야 한다.
㉤ 실종선고의 취소는 소급효가 있다.
㉥ '실종기간 만료 후 취소 전'이 아니라 '실종선고 후 취소 전'이다. 정답: ①

30 부재자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법원이 선임한 재산관리인이 부재자의 재산에 대해 보존행위를 함에는 법원의 허가를 얻어야 한다.
② 부재자가 재산관리인을 선임하였으나 부재자의 생사가 분명하지 않은 경우, 법원은 청구권자의 청구에 의하여 재산관리인을 개임할 수 있다.
③ 재산관리인의 처분행위에 대한 법원의 허가는 장래의 처분행위뿐만 아니라 과거의 처분행위에 대한 추인을 위해서도 할 수 있다.
④ 법원이 선임한 재산관리인이 부재자의 사망을 확인했더라도 법원에 의해 선임결정이 취소되지 않는 한 재산관리인은 계속하여 권한을 행사할 수 있다.
⑤ 재산관리인은 보수청구권을 가지며, 재산관리로 인하여 과실 없이 입은 손해에 대해 배상을 청구할 수 있다.

해설

- ① 법원이 선임한 재산관리인의 경우 부재자의 재산에 대한 관리행위(보존·이용·개량행위)는 법원의 허가를 요하지 않으며(제118조), 다만 처분행위(매각·담보설정행위)는 법원의 허가를 받아야 하며 또한 부재자를 위한 경우에 가능하다(대법원 1997.03.22. 76다1437). 정답: ①

31 부재와 실종에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 부재자재산관리인의 권한초과행위에 대한 법원의 허가는 과거의 처분행위를 추인하는 방법으로 할 수 없다.
② 법원은 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다.
③ 후순위 상속인도 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인에 포함된다.
④ 동일인에 대하여 2차례의 실종선고가 내려져 있는 경우, 뒤에 내려진 실종선고를 기초로 상속관계가 인정된다.

- ⑤ 실종선고를 받은 자가 실종기간 동안 생존했던 사실이 확인된 경우, 실종선고의 취소 없이도 이미 개시된 상속은 부정된다.

해설

- ② 법원은 그 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다(제26조 제2항).
- ① 부재자 재산관리인에 의한 부재자 소유의 부동산 매매행위에 대한 법원의 허가결정은 그 허가를 받은 재산에 대한 장래의 처분행위뿐만 아니라 과거의 처분행위(기왕의 매매)에 대한 추인으로도 할 수 있다(대법원 2000.12.26. 99다19278).
- ③④ 부재자의 제1순위 재산상속인이 있는 경우에 제2순위의 재산상속인은 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다(대법원 1980.09.08. 80스27).
- ⑤ 실종선고에 의한 사망의 효과를 반복하려면 반증으로서는 안 되고, 그 선고의 취소가 있어야 한다(대법원 1995.2.17. 94다52751). 정답: ②

32

실종선고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 실종선고 취소의 청구를 받은 가정법원은 공시최고의 절차를 거칠 필요가 없다.
- ② 실종선고가 확정되면 실종선고를 받은 자는 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다.
- ③ 실종선고가 취소되더라도 실종기간 만료 후 실종선고 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.
- ④ 실종선고의 취소가 있는 경우, 실종선고를 직접원인으로 하여 재산을 취득한 자는 선의이면 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있다.
- ⑤ 부재자의 1순위 상속인이 있는 경우에 4순위의 상속인에 불과한 자는 특별한 사정이 없는 한 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다.

해설

- ③ 실종선고가 취소되더라도 '실종선고 후 그 취소 전'에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. 선의란 실종선고가 사실과 다르다는 사실을 알지 못하는 것을 말한다. 정답: ③

33

실종선고에 관한 다음 기술 중 맞는 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 실종선고의 청구권자와 실종선고 취소의 청구권자는 동일하다.
- ② 실종선고가 있으면 선거권 등 공법상의 권리는 소멸한다.
- ③ 실종선고를 직접원인으로 하여 재산을 취득한 자가 실종선고취소의 결과 이익을 반환해야 할 경우, 그 반환범위는 이득자의 선·악에 관계없이 그 받은 이익이 현존하는 한도로 충분하다.
- ④ 실종선고에 의한 사망의 효력을 부정하는 데는 선고취소의 청구를 가정법원에 하는 외에 개개의 소송에서 반증을 하면 이를 반복할 수 있다.
- ⑤ 실종선고의 취소에는 소급효가 있지만, 실종선고 후 취소 전에 실종선고에 의한 재산취득자의 재산에 대하여 시효취득에 의하여 권리를 취득한 자는 실종선고가 취소되어도 그 재산의 반환의무는 없다.

해설

- ⑤ 실종선고의 취소시에는 원상회복을 원칙으로 하나, 재산취득자에게 취득시효(제245조), 선의취득(제249조) 등의 다른 권리취득의 요건이 구비된 때에는 그 한도에서는 실종선고의 취소의 효과를 받지 않는다.
- ① 실종선고의 청구권자는 이해관계인이나 검사이나, 실종선고 취소의 청구권자는 본인·이해관계인 또는 검사이다.
- ② 실종선고는 실종자의 종래의 주소를 중심으로 하는 사법상의 법률관계만을 종료시키는 것이며 권리능력을 중국적으로 박탈하는 제도가 아니다. 그러므로 새로운 곳에서의 법률관계 내지 공법상의 법률관계(선거권의 유·무, 범죄의 성립여부 등)에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
- ③ 제29조【실종선고의 취소】
 - ② 실종선고의 취소가 있을 때에 실종의 선고를 직접원인으로 하여 재산을 취득한 자가 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고 악의인 경우에는 그 받은 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다.
- ④ 실종선고가 있는 이상 실종자가 생존하여 있다가 실종선고에 의하여 의제되는 시기와 다른 시기에 사망하였다는 것이 증명된다 할지라도 이에 의하여 사망의 효과가 반복되는 것이 아니고 반드시 실종선고의 취소가 있어야 한다. 정답: ⑤

34 실종선고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 선박침몰로 인한 실종기간은 1년이고, 그 기간은 선박이 침몰한 때부터 기산한다.
- ② 실종선고가 취소되지 않는 한, 실종선고의 효과가 반증을 통하여 반복되는 것은 아니다.
- ③ 법원이 실종선고 및 그 취소를 할 때에는 반드시 공시최고의 절차를 거쳐야 한다.
- ④ 실종선고를 받은 자는 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다.
- ⑤ 실종선고에 의한 사망의 효과는 실종자의 종래의 주소나 거소를 중심으로 하는 사법적 법률관계에 국한된다.

해설

- ③ 실종선고 절차와는 달리 실종선고 취소절차에서는 '공시최고'를 요하지 않는다. 정답: ③

35 부재자의 재산관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 부재자가 스스로 위임한 재산관리인에게 재산처분권까지 준 경우에도 그 재산관리인은 재산처분에 법원의 허가를 얻어야 한다.
- ② 재산관리인의 권한초과행위에 대한 법원의 허가결정은 기왕의 처분행위를 추인하는 방법으로 할 수 있다.
- ③ 재산관리인이 소송절차를 진행하던 중 부재자에 대한 실종선고가 확정되면 그 재산관리인의 지위도 종료한다.
- ④ 생사불명의 부재자를 위하여 법원이 선임한 재산관리인은 그가 부재자의 사망을 확인한 때에도 선임결정이 취소되지 않으면 계속 권한을 행사할 수 있다.
- ⑤ 생사불명의 부재자에 대하여 실종이 선고되더라도 법원이 선임한 재산관리인의 처분행위에 근거한 등기는 그 선임결정이 취소되지 않으면 적법하게 마친 것으로 추정된다.

해설

- ① 부재자가 스스로 위임한 재산관리인에게 재산처분권까지 준 경우에는 원칙적으로 법원은 개입하지 않는다. 다만 본인의 부재중에 관리인의 권한이 소멸하거나 부재자의 생사가 불명하게 된 경우에는 가정법원은 재산관리인·이해관계인·검사의 청구에 의해 관리인을 개입하거나 감독을 행할 수 있다. 정답: ①

36 부재와 실종에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부재자는 성질상 자연인에 한한다.
 ② 법원은 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다.
 ③ 외국에 장기 체류하는 자가 국내에 있는 재산을 관리하고 있으면 그는 부재자에 해당하지 않는다.
 ④ 부재자에 대한 실종선고 이전에 법원이 선임한 부재자의 재산관리인이 선임결정취소 전에 한 처분행위에 기하여 경료된 등기는 적법한 것으로 추정된다.
 ⑤ 피상속인의 사망 후에 그의 아들에 대한 실종선고가 있었으나 피상속인의 사망 이전에 실종기간이 만료된 경우, 그 아들은 상속인이 될 수 있다.

해설

- ⑤ 피상속인의 사망 이전에 아들에 대한 실종기간이 만료되었다면, 아들은 상속인의 지위에 서지 못한다. 정답: ⑤

37 어머니 乙과 언니 丙을 두고 있는 미혼의 甲은 가출한 후 생사불명의 상태가 되었다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙은 甲의 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다.
 ② 乙은 甲이 가출한 날부터 3년이 지나면 甲에 대한 실종선고를 청구할 수 있다.
 ③ 실종선고 후에 甲의 생존사실이 확인되면, 실종선고의 취소가 없더라도 상속은 즉시 그 효력을 상실한다.
 ④ 실종선고가 취소된 경우, 실종선고를 직접원인으로 재산을 취득한 자는 현존이익에 대해서도 반환의무가 없다.
 ⑤ 甲이 생환하여 실종선고가 취소되더라도 乙이 실종기간 만료 후 실종선고 전에 선의로 한 甲의 재산에 대한 처분행위는 유효하다.

해설

- ① 민법 제27조의 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 부재자의 법률상 사망으로 인하여 직접적으로 신분상 또는 경제상의 권리를 취득하거나 의무를 면하게 되는 사람만을 뜻한다. 따라서 부재자의 제1순위 재산상속인(직계존속, 어머니)이 있는 경우에 후순위의 상속인(형제자매, 언니)은 이해관계인에 포함되지 않으므로 실종선고를 청구할 수 없다(대법원 1986.10.10, 86스20 등).
 ② 보통실종기간은 5년이다(제27조 제1항).

- ③ 실종선고로서 사망이 간주된다. 따라서 반증으로는 번복될 수 없고 반드시 실종선고의 취소 절차에 의하여 취소되어야 한다.
- ④ 실종선고의 취소가 있으면 실종의 선고를 직접원인으로 하여 재산을 취득한 자가 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고 악의인 경우에는 그 받은 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다(제29조 제2항).
- ⑤ 실종선고 후 취소 전에 선의로 한 행위에는 영향을 미치지 아니한다(제29조 제1항). 정답: ①

38 甲(乙의 父)·乙(본인)·丙(乙의 妻)·丁(乙의 子)·戊(丁의 妻)가 있는 가정에서 乙과 丁이 여행 중 비행기 추락사고로 사망하였다. 사망의 전후를 가릴 수 없는 경우 乙의 재산에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 乙과 丁이 동시에 사망한 것으로 추정되므로, 丁에게는 상속이 일어나지 않은 것으로 되어 丙이 단독 상속인이 된다.
- ② 乙과 丁이 동시에 사망한 것으로 추정되므로, 丙과 戊는 공동상속인이 된다.
- ③ 乙과 丁은 동시에 사망한 것으로 추정되지만, 丁이 乙보다 먼저 사망한 사실이 증명되면 甲과 丙이 공동으로 상속인이 된다.
- ④ 乙과 丁은 동시에 사망한 것으로 추정되지만, 乙이 丁보다 먼저 사망한 사실이 증명되면 戊가 단독 상속인이 된다.
- ⑤ 乙과 丁이 동시에 사망한 것으로 추정되지만, 乙과 丁의 사망시기의 전후를 증명할 수 있다면, 甲이 공동상속인으로 되는 경우가 있다.

해설

- ② 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정되어, 추정되는 당사자 사이에는 상속의 문제가 발생하지 아니하나 丁에게는 그의 처 戊가 있으므로 대습상속의 결과 丙과 戊는 공동상속인이 된다. 정답: ②

39 부재와 실종에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부재자로부터 재산처분권을 위임받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어서 법원의 허가를 받을 필요가 없다.
- ② 제1순위 상속인이 있는 경우에 제2순위 상속인은 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인이 될 수 없다.
- ③ 부재자 재산관리인의 재산처분행위를 허가하는 법원의 결정은 기왕의 처분행위를 추인하는 방법으로도 할 수 있다.
- ④ 실종선고를 받은 자가 실종기간 동안 생존하였다는 사실이 밝혀진 경우, 실종선고의 취소 없이도 이미 개시된 상속을 부정할 수 있다.
- ⑤ 피상속인의 사망 후 그 상속인에 대한 실종선고가 이루어졌으나 실종기간 만료시점이 피상속인의 사망 이전인 경우, 실종선고된 자는 상속인이 될 수 없다.

해설

- ④ 우리민법은 실종선고에 관하여 간주주의를 취하는 결과, 실종선고가 사실과 다르다는 것만으로는 선고의 효과가 번복되지 아니한다. 따라서 별도의 법원의 취소절차가 있어야 선고의 결과를 부정할 수 있다. 정답: ④

권리의 주체(법인)

1

기본문제

제3장
기본문제

01 민법상 법인의 정관에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 재단법인의 기본재산이 경매절차에 의하여 매각된 경우, 주무관청의 허가가 없는 한 매수인은 소유권을 취득할 수 없다.
- ② 사원총회의 결의에 의한 정관해석은 구성원인 사원들이나 법원을 구속한다.
- ③ 사단법인의 정관은 이를 작성한 사원 이외에 그 후에 가입한 사원은 구속하지 않는다.
- ④ 법인의 정관 변경은 주무관청의 허가를 얻지 않더라도 효력이 발생한다.
- ⑤ 정관에 기재된 이사의 대표권 제한을 등기하지 않아도, 법인은 대표권 제한에 대해 알았던 제3자에게 대항할 수 있다.

해설

- ① 사회복지법인이 기본재산을 매도하기 위하여는 보건복지부장관의 허가를 받아야 하고, 이는 경매 절차에 의한 매각의 경우에도 마찬가지인 바, 사회복지법인의 기본재산에 대하여 실시된 부동산 경매절차에서 최고가매수신고인이 그 부동산 취득에 관하여 보건복지부장관의 허가를 얻지 못하였다면 경매법원은 그에 대한 매각을 불허하여야 한다(대법원 2007.6.18. 2005마1193).
- ②③ 사단법인의 정관은 이를 작성한 사원뿐만 아니라 그 후에 가입한 사원이나 사단법인의 기관 등도 구속하는 점에 비추어보면 그 법적 성질은 계약이 아니라 자치법규로 보는 것이 타당하므로, 이는 어디까지나 객관적인 기준에 따라 그 규범적인 의미 내용을 확정하는 법규해석의 방법으로 해석되어야 하는 것이지, 작성자의 주관이나 해석 당시의 사원의 다수결에 의한 방법으로 자의적으로 해석될 수는 없다. 따라서 어느 시점의 사단법인의 사원들이 정관의 규범적인 의미 내용과 다른 해석을 사원총회의 결의라는 방법으로 표명하였다 하더라도 그 결의에 의한 해석은 그 사단법인의 구성원인 사원들이나 법원을 구속하는 효력이 없다(대법원 2000.11.24. 99다12437).
- ④ 법인의 정관 변경은 주무관청의 허가를 받아야 그 효력이 발생한다.
- ⑤ 법인의 정관에 대표권제한에 관한 규정이 있으나, 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 제3자가 선의나 악의냐에 관계없이 대항할 수 없다(대법원 1992.02.14. 91다24564). 정답: ①

02 사단과 조합의 차이에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 구성원 상호간의 관계를 정하는 것은 사단에서는 정관이지만, 조합에서는 계약이다.
- ② 사단 자체는 구성원으로부터 독립한 단체적 조직이지만, 조합은 그렇지 않다.
- ③ 대외적 거래의 주체는 사단에 있어서는 단체구성원이고, 조합에 있어서는 조합 자체이다.
- ④ 사단의 업무집행자는 보통 구성원의 총회에서 선임되나, 조합에 있어서는 계약에 의하여 고정적으로 특정한 구성원이 된다.
- ⑤ 사단에 있어서 구성원의 가입·탈퇴는 비교적 자유로이 인정되지만, 조합에 있어서는 일반적으로 인정되지 않는다.

해설

◎ 사단과 조합의 비교

사항	사단	조합
설립	주무관청의 허가와 설립등기	구성원의 계약(법인격 없음)
내부규제	정 관	계 약
구성원의 수	다수(2인 이상)	소 수
조직	계속적 조직체	독립된 조직체가 아님
가입·탈퇴	비교적 자유로움	자유롭지 못함
단체성	단체성이 강함	구성원의 개성이 강함
존속기간	장기간	단기간
대외적 거래주체	단체 자체	단체 구성원
업무집행	대표(이사)	업무집행사원
재산소유 형태	단독소유	합 유
책임	유한책임	무한책임

③의 경우에는 반대로 표현되어 있다. 정답: ③

03 민법상 법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사단법인의 사원의 지위는 정관에 의해 양도될 수 있다.
- ② 부동산의 생전처분으로 재단법인을 설립하는 경우, 법인의 성립 외에 부동산에 대한 등기가 있어야 법인은 제3자에 대한 관계에서 소유권을 취득한다.
- ③ 재단법인 설립시 출연자가 출연재산의 소유명의만을 재단법인에 귀속시키고 실질적 소유권은 자신에게 유보하는 부관을 붙여서 이를 기본재산으로 출연하는 것도 가능하다.
- ④ 재단법인의 목적을 달성할 수 없는 때에는 설립자나 이사는 주무관청의 허가를 얻어 설립의 취지를 참작하여 그 목적 기타 정관의 규정을 변경할 수 있다.
- ⑤ 법인의 이사가 수인인 경우에는 정관에 다른 규정이 없으면 법인의 사무집행은 이사의 과반수로써 결정한다.

해설

- ③ 재단법인의 기본재산은 재단법인의 실체를 이루는 것이므로, 재단법인 설립을 위한 기본재산의 출연행위에 관하여 그 재산출연자가 소유명의만을 재단법인에 귀속시키고 실질적 소유권은 출연자에게 유보하는 등의 부관을 붙여서 출연하는 것은 재단법인 설립의 취지에 어긋나는 것이어서 관할 관청은 이러한 부관이 붙은 출연재산을 기본재산으로 하는 재단법인의 설립을 허가할 수 없다 (대법원 2011.2.10. 2006다65774). 정답: ③

04 권리능력 없는 사단에 관하여 틀린 것은?

- ① 내부관계에 관해서는 정관에 달리 규정이 없는 한 사단법인에 관한 규정을 적용한다.
- ② 대표기관이 그 권한 내에서 한 행위에 의하여 직접 사단재산에 변동이 생긴다. 또한 대표기관의 직무상의 불법행위에 대해서는 기관부담자 뿐만 아니라 사단재산으로써 배상책임을 진다.
- ③ 재산귀속관계에 관하여는 각 사원은 지분을 가지고 총회를 통하여 그 관리에 참가할 수 있다.
- ④ 업무집행기관은 총사원의 수임자로서 모든 업무이행에 관하여 선량한 관리자의 주의의무를 부담한다.
- ⑤ 예금채권에 관해서는 대표자의 성명에 '사단대표자'라는 표시를 하여 실질적으로 사단채권인 것을 표시하는 방법이 관행으로 되어 있다.

해설

- ③ 권리능력 없는 사단의 재산소유형태인 총유는 공유나 합유와 달리 지분이 존재하지 않는다.

정답: ③

05 법인 아닌 사단에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 법인 아닌 사단이 되기 위하여 대표자의 성명, 총회의 운영 기타 사단으로서 중요한 점이 규칙(정관)에 의하여 확정되어 있을 필요는 없다.
- ② 종중, 교회, 동, 리는 모두 법인 아닌 사단이다.
- ③ 종중에 대하여 부동산에 관한 취득시효완성으로 인한 소유권취득을 인정할 수 있다.
- ④ 법인 아닌 사단도 그 대표자가 정하여져 있으면 소송상의 당사자가 될 수 있다.
- ⑤ 법인 아닌 사단 명의로 등기를 할 수 있다.

해설

- ① 권리능력 없는 사단으로 인정되기 위해서는 대표자와 총회가 있어야 하며 사단의 중요한 사항은 정관이나 규칙으로 규정되어야 한다. 다만 종중에 대하여 판례는 반드시 특정한 명칭의 사용 및 서면화된 종중규약이 있어야 하거나 종중의 대표자가 계속하여 선임되어 있는 등 조직을 갖추어야 하는 것은 아니다(대법원 2005.7.21. 2002다1178).
- ② 판례가 인정한 권리능력 없는 사단으로는 종중, 교회, 동, 리, 집합건물의 관리단, 채권청산위원회, 친목계, 어촌계 등이 있다.
- ③ 문중 또는 종중과 같이 법인 아닌 사단 또는 재단도 취득시효완성으로 인한 소유권을 취득할 수 있다(대법원 1970.2.10. 69다2013).
- ④ 민사소송법 제52조
- ⑤ 부동산 등기법 제26조 정답: ①

06 법인과 관련된 다음의 설명 중 가장 잘못된 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 따름)

- ① 권리능력 없는 사단의 재산소유형태는 총유이며 이는 단체주의적 성격이 가장 강한 공동 소유형태이기 때문에 그 처분을 위해서는 사원 전원의 동의가 있어야 한다.
- ② 권리능력 없는 사단이라고 하더라도 대표자가 있는 경우에는 단체의 명의로 등기할 수 있고 소송상의 당사자가 될 수 있다.
- ③ 법인의 불법행위가 성립하는 경우에 대표기관인 개인은 법인과 연대하여 손해배상책임을 지게 되는데 이 경우 양자의 책임은 부진정 연대채무로 해석된다.
- ④ 재단법인에 대한 출연재산으로서의 부동산은 법인설립시에 귀속되지만 제3자에게 대항하기 위해서는 등기해야 한다.
- ⑤ 청산종결등기가 종료된 후에도 청산사무가 종결되지 않은 경우에는 청산법인으로 계속 존속한다.

해설

- ① 총유물의 관리 및 처분은 정관의 규정이 없는 경우에는 사원총회의 결의에 의한다(제276조). 처분에 전원의 동의를 요하는 것은 합유이다(제272조).
- ② 부동산등기법 제26조, 민사소송법 제52조
- ③ 법인의 불법행위가 성립하기 위하여는 제750조의 일반불법행위의 요건이 충족되어야 하며, 법인

의 불법행위가 성립하는 경우에도 대표기관은 그 자신의 손해배상책임을 면하지 못한다(제35조 제1항 후단). 따라서 피해자는 법인과 대표기관 개인에 대해 선택적으로 손해배상을 청구할 수 있고, 이 양자의 채무는 부진정 연대채무로 해석된다. 이와 관련해 대표기관성, 직무관련성, 대표권의 남용, 대표기관의 불법행위 등이 거론된다.

④ 대법원[전합] 1979.12.11. 78다481

⑤ 대법원 1980.4.8. 79다2036 정답: ①

07 다음 중 사단법인의 정관의 필요적 기재사항이 아닌 것은?

- ① 자산에 관한 규정
- ② 사원자격의 취득·상실에 관한 사항
- ③ 존립시기와 해산사유를 정한 경우 그 시기와 사유
- ④ 출자의 방법
- ⑤ 이사의 임면에 관한 규정

해설

제40조 【사단법인의 정관】

사단법인의 설립자는 다음 각 호의 사항을 기재한 정관을 작성하여 기명날인하여야 한다.

1. 목적
 2. 명칭
 3. 사무소의 소재지
 4. 자산에 관한 규정
 5. 이사의 임면에 관한 규정
 6. 사원자격의 득실에 관한 규정
 7. 존립시기나 해산사유를 정하는 때에는 그 시기 또는 사유
- ④ 출자의 방법은 설립등기에 기재할 사항이다. 정답: ④

08 사단법인과 재단법인의 차이에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 사단법인의 설립에는 반드시 서면에 의한 정관작성이 필요하나, 재단법인의 설립에는 이는 요구되지 않고 대신 재산의 출연이 반드시 필요하다.
- ② 사단법인에는 사원총회가 필수적 기관이나 재단법인에는 사원총회가 존재치 않는다.
- ③ 양자는 모두 성립에 있어서 주무관청의 허가가 필요하다.
- ④ 사단법인의 설립에는 2인 이상의 설립자가 필요하나, 재단법인의 설립에는 설립자가 1인이 라도 가능하다.
- ⑤ 사단법인은 자주적으로 정관을 변경할 수 있으나 재단법인의 정관변경에는 제한이 있다.

해설

◎ 사단법인과 재단법인의 비교

사 항	사단법인	재단법인
설립행위	㉠ 2인 이상의 설립자의 정관작성(제 40조) ㉡ 설립행위는 합동행위	㉠ 재산의 출연과 정관작성 ㉡ 1인에 의한 설립행위는 상대방 없는 단독행위
구 성 원	2인 이상의 사원	일정한 목적에 바쳐진 재산
의사결정	㉠ 사원총회에 의해 결정 ㉡ 자율적 법인	㉠ 설립자의 의도가 반영된 정관에서 정한 목적에 따라 변경 ㉡ 타율적 법인
기 관	이사, 감사, 사원총회	이사, 감사
정관변경	총사원의 3분의 2 이상의 동의	원칙적으로 변경 불가
해산사유	▪ 공동해산사유 ㉠ 존립기간의 만료 ㉡ 목적의 달성 또는 불능 ㉢ 파 산 ㉣ 설립허가의 취소 ㉤ 정관에서 정한 해산사유의 발생	
	▪ 사단법인의 특유한 사유 ㉠ 사원이 없게 된 때 ㉡ 총회의 해산결의(임의해산 : 총사원의 4분의 3 이상의 동의)	

정답: ①

09 재단법인에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- 재단법인의 설립자는 일정한 재산을 출연하고 요구되는 사항을 기재한 정관을 작성하면 되고, 기명날인은 요하지 않는다.
- 재단법인의 설립자가 그 명칭, 사무소 소재지 등을 정하지 않고 사망한 때에는 이해관계인이나 감사의 청구에 의하여 주무관청이 정한다.
- 재단법인의 목적달성을 위해서도 정관에 변경방법이 정해져 있지 아니하면 명칭 또는 사무소의 소재지를 변경할 수 없다.
- 재단법인의 목적을 달성할 수 없는 경우에는 설립자는 법원의 허가를 얻어 그 목적 기타 정관의 규정을 변경할 수 있다.
- 생전처분으로 재단법인을 설립한 때에는 증여에 관한 규정을 준용한다.

해설

⑤ 제47조 제1항

- 재단법인의 설립자는 일정한 재산을 출연하고 요구되는 사항을 기재한 정관을 작성하여 기명날인하여야 한다(제43조).

- ② 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 법원이 정한다(제44조).
 ③ 재단법인의 목적달성 또는 그 재산의 보전을 위하여 적당한 때에는 법인의 본질과는 거리가 먼 명칭이나 사무소의 소재지 등은 비록 정관에 변경방법이 규정되어 있지 않더라도 변경할 수 있다(제45조 제2항).
 ④ 정관의 변경방법이 정관에 규정되어 있지 않더라도 재단법인의 목적을 달성할 수 없는 때에는 설립자나 이사는 주무관청의 허가를 얻어 설립의 취지를 참작하여 그 목적 기타 정관의 규정을 변경할 수 있다(제46조). 정답: ⑤

10 다음 중 법인의 불법행위가 성립하기 위한 요건으로서 타당하지 않은 것은?

- ① 일반불법행위의 요건을 갖추어야 한다.
 ② 법인의 대표자가 그 직무에 관하여 행한 불법행위라야 한다.
 ③ 법인은 대표자의 선임·감독에 과실 없음을 증명하면 그 책임을 면한다.
 ④ 법인과 함께 대표자 개인도 책임을 진다.
 ⑤ 법인은 불법행위를 한 대표자에게 구상할 수 있다.

해설

(1) 법인의 불법행위의 성립요건

대표기관의 행위	㉠ 이사, 직무대행자, 임시이사, 특별대리인, 청산인의 행위일 것 ㉡ 사원총회, 감사, 대리인, 지배인은 대표기관이 아님.
대표기관의 직무에 관한 행위	외형상 직무행위로 볼 수 있는 행위와 직무행위와 사회통념상 견련성을 가지는 행위도 포함
불법행위의 요건 구비	㉠ 대표기관이 책임능력을 가질 것 ㉡ 고의 또는 과실이 있을 것 ㉢ 가해행위가 위법성을 가질 것 ㉣ 피해자가 손해를 입었을 것 ㉤ 가해행위와 손해 사이에 인과관계가 있을 것

(2) 불법행위의 효과(제35조 제1항)

법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.

- ㉠ 피해자는 그가 받은 손해의 충분한 전보를 받을 때까지 법인이나 대표기관에 대하여 선택적으로 배상청구를 할 수 있다(부진정연대채무).

- ㉡ 법인이 배상한 경우에는 기관개인에 대하여 구상권을 행사(선관주의의무 위반을 이유로)할 수 있다.

정답: ③

11 비영리 사단법인의 재산귀속형태는?

- ① 사원들의 총유 ② 사단법인의 단독소유 ③ 사원들의 합유
 ④ 사원들의 공유 ⑤ 대표이사의 단독소유

해설

- ② 비영리 사단법인의 재산소유형태는 사단법인의 단독소유이다. 그러나 권리능력 없는 사단의 재산 소유형태는 사원들의 총유이다. 정답: ②

12

법인에 관한 다음 설명 중 틀린 것으로만 연결된 것은?

- ㉠ 사단법인에는 반드시 이사를 두어야 하나 재단법인에서는 임의기관이다.
- ㉡ 정관에 기재되지 아니한 이사의 대표권 제한은 무효이다.
- ㉢ 이사는 법인의 업무에 관하여 연대하여 법인을 대표한다.
- ㉣ 법인의 직무행위에 해당하는지 여부는 행위의 외형을 기준으로 판단한다.
- ㉤ 법인의 대표에는 표현대리에 관한 규정은 적용되지 않는다.
- ㉥ 법인의 권리능력 발생시기는 설립등기시이다.
- ㉦ 아파트입주자대표회의나 지역단체도 권리능력 없는 사단이라 함이 판례이다.
- ㉧ 권리능력 없는 재단의 재산도 총유적으로 귀속한다.

① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

② ㉠, ㉢, ㉤, ㉦

③ ㉡, ㉢, ㉤, ㉥

④ ㉠, ㉢, ㉤, ㉧

⑤ ㉢, ㉣, ㉤, ㉦

해설

- ㉠ 이사는 사단법인과 재단법인에 공통된 필수기관이다.
- ㉡ 이사는 법인을 대표함에 있어 각자대표를 원칙으로 한다.
- ㉢ 외형설이 통설이다.
- ㉣ 법인의 대표행위의 형식에 대하여는 대리의 규정을 준용한다.
- ㉤ 권리능력 없는 재단의 재산소유형태는 재단의 단독소유이다. 정답: ④

13

법인에 있어서 임시이사와 특별대리인에 관한 기술로서 틀린 것은?

- ① 특별대리인은 법인과 이사의 이익이 상반되는 사항에 관하여 선임한다.
- ② 임시이사는 이사가 없거나 결원이 있는 경우에 그로 인하여 손해가 생길 염려가 있을 때에 선임한다.
- ③ 양자는 모두 법인의 기관이다.
- ④ 양자는 모두 사원총회에서 선임한다.
- ⑤ 정식이사가 선임되면 임시이사의 권한은 당연히 소멸하고, 특별대리인의 권한은 당해 사항에 한정된다.

해설

㉠ 임시이사와 특별대리인

구 분	선임하여야 할 경우	선임기관	법적 성질
임시이사	이사가 없거나 결원이 된 때	법 원	임시적 대표기관
특별대리인	법인과 이사의 이익이 상반될 때	법 원	임시적 대표기관

정답: ④

14

법인의 기관에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ㉠ 법인의 정관에 이사의 해임사유에 관한 규정이 있는 경우, 법인으로서의 이사의 중대한 의무위반 등의 특별한 사정이 없는 이상 정관에서 정하지 아니한 사유로 이사를 해임할 수 없다.
- ㉡ 이사와 감사의 성명·주소는 등기사항이다.
- ㉢ 법인과 이사의 이익이 상반되는 경우, 법원이 선임한 특별대리인은 그 사항에 대하여 법인을 대표한다.
- ㉣ 이사의 대표권 제한이 정관에 기재된 경우, 이를 등기하지 않아도 악의의 제3자에게 대항할 수 있다.

- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣ ③ ㉠, ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

해설

- ㉠㉢ 타당한 기술이다.
 ㉡ 감사의 성명·주소는 등기사항이 아니다.
 ㉣ 법인의 정관에 대표권제한에 관한 규정이 있으나, 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 제3자가 선의나 악의냐에 관계없이 대항할 수 없다(대법원 1992.02.14. 91다24564). 정답: ①

15

법인의 해산사유 중 옳지 않은 것은?

- ① 법인의 목적달성 또는 달성불능이 확정되었을 때
- ② 법인의 설립허가가 취소되었을 때
- ③ 법인의 채무가 초과한 때
- ④ 사단법인은 총사원의 3/4 이상의 동의를 얻어 결의를 하였을 때
- ⑤ 존립기간이 만료한 때

해설

- ③ 법인의 채무가 초과된 때에는 이사는 지체없이 파산신청을 하여야 하고, 파산에 의하여 해산이 된다. 따라서 채무초과로써 곧 해산사유가 되는 것은 아니다.

㉠ 법인의 해산사유

공동해산사유	㉠ 존립기간의 만료 ㉡ 목적의 달성 또는 불능 ㉢ 파 산 ㉣ 설립허가의 취소 ㉤ 정관에서 정한 해산사유의 발생
사단법인의 특유한 사유	㉠ 사원이 없게 된 경우 ㉡ 총회의 해산결의(임의해산 : 총사원의 3/4 이상의 동의)

정답: ③

16 청산법인에 관한 다음 기술 중 타당한 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법인은 설립등기에 의하여 성립하기 때문에 청산종결등기에 의하여 당연히 소멸한다.
- ② 청산종결등기가 종료되었더라도 청산사무가 종료하지 않은 경우에는 청산법인으로 존속한다.
- ③ 설립 중의 법인을 권리능력 없는 단체라 할 수 있으므로 청산종결등기가 종료되었어도 권리능력 없는 단체로 존속하는 경우가 있다.
- ④ 청산법인의 청산사무는 특별대리인이 행한다.
- ⑤ 청산법인은 청산의 목적범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다.

해설

- ② 청산종결의 등기가 종료되었더라도 청산사무가 종료되지 아니한 때에는 청산법인으로서 존속한다는 것이 판례의 입장이다(대법원 1980.4.8. 79다2036).
- ④ 청산법인의 청산사무는 청산인이 행한다.
- ⑤ 해산한 법인은 청산의 목적범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다(제81조). 정답: ②

17 법인의 기관에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 비영리 사단법인의 사원총회는 정관의 규정에 의하더라도 이를 두지 않거나 폐지할 수 없다.
- ② 주식회사의 이사회는 상설의 필요기관이나 민법상 법인의 이사회는 그렇지 않다.
- ③ 직무대행자는 이사의 선임행위가 흠이 있는 것이어서 이해관계인의 신청으로 법원이 가처분으로 선임하는 임시적 기관이다.
- ④ 임시이사는 법인과 이사의 이익이 상반되는 사항에 대하여 이해관계인 또는 감사의 청구로 법원이 선임하는 임시적 기관이다.
- ⑤ 민법상 법인의 감사는 임의기관이다.

해설

- ④ 법인과 이사의 이익상반행위시 법원에 의하여 선임된 자는 특별대리인이며, 임시이사는 이사가 없거나 결원이 있는 경우에 이로 인하여 손해가 생길 염려가 있는 때에는 법원에 의하여 선임된 자이다. 정답: ④

18 비영리 사단법인의 기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 정관에 이사의 대표권 제한에 관한 규정이 있으면 등기되어 있지 않더라도 법인은 악의의 제3자에 대하여는 대항할 수 있다.
- ② 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 한다.
- ③ 법인이 해산한 경우, 정관 또는 총회의 결의로 달리 정한 바가 없으면 파산의 경우를 제외하고는 이사가 청산인이 된다.
- ④ 감사는 법인의 재산상황에 관하여 부정이 있음을 발견한 때에는 이를 총회 또는 주무관청에 보고하여야 한다.
- ⑤ 정관에 다른 규정이 없는 경우, 임의해산은 총사원의 4분의 3 이상, 정관변경은 총사원의 3분의 2 이상의 동의를 요한다.

해설

- ① 이사의 대표권은 정관으로 제한할 수 있다(제59조 제1항 단서). 따라서 대표권제한은 정관에 기재되어야 그 효력이 있다. 다만, 이를 등기하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다(제60조). 여기서 제3자의 범위에 관하여 학설은 대립하나, 선의자와 악의자를 모두 포함한다는 것이 판례의 입장이다.

[관련판례] 법인의 정관에 법인대표권의 제한에 관한 규정이 있으나 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면, 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 선의나 악의자에 관계없이 제3자에 대하여 대항할 수 없다(대법원 1992.2.14, 91다24564).

- ② 제61조
③ 제82조
④ 제67조
⑤ 임의해산은 제78조, 정관변경은 제42조가 적용된다. 정답: ①

19 다음 중 틀린 것은?

- ① 재단법인의 정관을 변경하기 위하여 정관에서 정관의 변경방법을 정하고 있는 경우에 주무관청의 허가를 받아야 하는데, 이 허가의 법적 성질을 판례는 인가로 본다.
② 특정한 양로원의 노인들을 돌보기 위하여 설립된 재단법인은 그 양로원의 노인들이 모두 사망하더라도 그것이 해산사유에 해당하지 않는다.
③ 정관 또는 사원총회의 결의로 달리 정한 바가 없는 경우 해산 당시의 이사가 청산인으로 되는 것이 원칙이다.
④ 청산에 관한 규정은 강행규정이다.
⑤ 채권신고기간 내에 신고하지 않은 채권자는 청산절차에서 완전히 배제된다.

해설

- ⑤ 청산기간 내에는 변제기에 이르지 않은 채권에 대해서도 변제할 수 있으며, 청산인이 알고 있는 채권자는 그 신고가 없더라도 변제하여야 한다.
① 재단법인의 정관변경은 주무관청의 허가를 얻어야 그 효력이 발생한다(제45조 제3항). 따라서 이때의 허가는 그 법적 성질을 효력요건으로서의 인가이다.
② 사원이 없게 된 경우에 사단법인의 경우에는 소멸사유가 되나, 재단법인은 그러하지 않다.
③ 통상의 경우에는 해산 당시의 이사가 청산인이 된다.
④ 청산에 관한 규정은 제3자와의 이해관계에 중대한 영향을 미치므로 강행규정이다. 정답: ⑤

20 법인의 불법행위책임에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 법인이 불법행위책임을 지게 되는 대표기관의 행위에는 이사나 임시이사 뿐만 아니라 청산인이나 특별대리인도 포함된다.
② 법인의 사원이더라도 법인의 위법한 행위로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.
③ 권리능력 없는 사단이 행한 불법행위에 대해서도 법인의 불법행위책임에 관한 규정이 적용될 수 있다.

- ④ 피해자는 법인이나 실제 가해행위를 한 대표기관 개인에 대해서 선택적으로 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 대표기관의 행위가 법인의 목적범위를 벗어난 경우에는 그 사항의 의결에 찬성한 사원, 이사 및 기타 대표자는 공동불법행위가 성립할 때에 한해서 연대하여 배상할 책임을 진다.

해설

- ⑤ 법인의 불법행위가 성립하지 아니하는 경우에는 제750조에 의해 그 대표기관만이 손해배상책임을 지는 것이 원칙이지만, 공동불법행위에 대한 제760조에 대한 특칙으로 공동불법행위가 성립하지 아니하는 경우에도 피해자보호를 위해 그 사항의 의결에 찬성한 사원, 이사 및 기타 대표자는 연대하여 배상할 책임을 진다. 정답: ⑤

21 다음 중 '문화'에 관계된 사단법인의 청산절차에 관한 감독기관은?

- ① 교육부장관과 문화체육관광부장관
- ② 주된 사업인 교육에 관한 주무부장관인 교육부장관
- ③ 허가신청서류를 먼저 제출한 문화체육관광부장관
- ④ 법원
- ⑤ 문화체육관광부장관 및 교육부장관과 법원

해설

- ④ 법인의 해산과 청산사무를 감독하는 기관은 법원이다. 정답: ④

22 민법상 법인의 정관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사단법인의 정관변경은 법원의 허가를 얻지 않으면 그 효력이 없다.
- ② 사단법인에서 이사의 대표권에 대한 제한은 정관에 기재되지 않더라도 효력이 있다.
- ③ 재단법인 설립자는 정관에 그 존립시기나 해산사유를 기재하고 기명날인하여야 한다.
- ④ 재단법인 설립자가 이사의 임면방법을 정하지 아니하고 사망한 경우, 이해관계인의 청구에 의하여 주무관청이 이를 정한다.
- ⑤ 재단법인의 재산보전을 위하여 적당한 때에는 정관에 변경방법이 없더라도 명칭 또는 사무소의 소재지를 변경할 수 있다.

해설

- ⑤ 재단법인은 원칙적으로 정관변경이 불가하나 목적달성이나 재산의 보전을 위하여 명칭 또는 사무소 소재지의 변경이 가능하다(제45조 제2항). 정답: ⑤

01 재단법인에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 재단법인의 설립을 위한 출연의 의사표시는 착오를 이유로 취소할 수 없다.
- ② 재단법인에게도 상속 및 유증을 받을 권리능력이 있다.
- ③ 주무관청의 허가는 성질이 주무관청의 자유재량이므로 그 허가 여부에 대해 다툴 수 없다.
- ④ 재단법인이 권리능력을 취득하는 시기는 설립자가 정관을 작성하여 등기소에 제출한 때이다.
- ⑤ 변경방법을 정한 재단법인의 정관에 좇아 변경된 정관은 주무관청의 허가를 받지 않더라도 효력이 있다.

해설

- ③ 주무관청의 허가는 성질이 주무관청의 자유재량이므로 그 허가 여부에 대해 다툴 수 없다는 것이 판례이다.
- ① 재단법인 설립을 위하여 서면에 의한 증여(출연)를 한 경우, 출연자가 착오에 기한 의사표시를 이유로 출연의 의사표시를 취소할 수 있다.
- ② 성질상 자연인에게만 인정되는 것(상속 등)은 법인에게 인정될 수 없다.
- ④ 법인이 권리능력을 취득하는 시기는 서류를 등기소에 제출한 때가 아니라 설립등기를 한 때이다(제33조).
- ⑤ 정관의 변경은 주무관청의 허가를 얻지 아니하면 그 효력이 없다(제42조). 정답: ③

02 민법상 법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 사단법인의 설립행위는 상대방 없는 단독행위이며, 요식행위이다.
- ㉡ 사단법인 정관에 대해 사원총회의 결의로 그 규범적인 의미 내용을 확정된 경우에 그 결의는 사원이나 법원을 구속하는 효력이 있다.
- ㉢ 재단법인 설립자가 부동산을 출연하고 법인설립등기를 마쳤으나 그 부동산이 법인명의로 등기되기 전에 설립자가 이를 제3자에게 처분하고 이전등기를 해주었다면 법인은 제3자에게 그 부동산의 소유권을 주장할 수 없다.
- ㉣ 사단법인 사원의 지위는 양도하거나 상속할 수 없다는 「민법」의 규정은 임의규정이다.
- ㉤ 법인의 대표기관인 이사, 감사, 청산인이 그 직무에 관하여 타인에게 손해를 입힌 경우, 법인이 그 손해를 배상할 책임이 있다.

① ㉠, ㉡, ㉢

② ㉠, ㉡, ㉤

③ ㉠, ㉢, ㉤

④ ㉡, ㉢, ㉣

⑤ ㉢, ㉣, ㉤

해설

- ㉠ 사단법인의 설립행위는 합동행위이며, 요식행위이다.
- ㉡ 사단법인 정관에 대해 사원총회의 결의로 그 규범적인 의미 내용을 확정된 경우에 그 결의는 사원이나 법원을 구속하는 효력이 없다.

판례는 정관은 이를 작성한 사원, 작성 후에 가입한 사원, 기관 등을 구속하는 자치법규이며(대법원 2000.11.24. 99다12437). 따라서 그 해석도 객관적 기준에 따른 법규해석의 방법에 의해야 하고 '사원총회의 결의'의 형태로 행해진 정관의 해석은 구속력이 발생하지 않는다고 판시하였다.

㉔ 감사는 법인의 대표기관이 아니다. 정답: ㉔

03 민법상 법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사단법인의 정관에 다른 규정이 없는 한, 그 정관은 총사원 3분의 2 이상의 동의가 있는 때에 한하여 이를 변경할 수 있다.
- ② 법인은 법률의 규정에 의함이 아니면 성립하지 못한다.
- ③ 법인의 목적 범위 외의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다.
- ④ 사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없고, 이는 정관으로 달리 정할 수 없다.
- ⑤ 이사가 수인(數人)인 경우에 법인의 사무집행은 정관에 다른 규정이 없는 한 이사의 과반수로써 결정한다.

해설

④ 사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없다고 규정한 민법 제56조의 규정은 강행규정이 아니므로, 정관으로 달리 정할 수 있다. 정답: ④

04 민법상 법인의 정관에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2023' 감정평가사]

- ① 감사의 임면에 관한 사항은 정관의 필요적 기재사항이다.
- ② 정관의 임의적 기재사항은 정관에 기재되더라도 정관의 변경절차 없이 변경할 수 있다.
- ③ 정관변경의 의결정족수가 충족되면 주무관청의 허가가 없어도 정관변경의 효력이 생긴다.
- ④ 재단법인이 기본재산을 편입하는 행위는 주무관청의 허가를 받지 않아도 유효하다.
- ⑤ 재단법인의 기본재산에 관한 저당권 설정행위는 특별한 사정이 없는 한 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다.

해설

⑤ 민법상 재단법인의 기본재산에 관한 저당권 설정행위는 특별한 사정이 없는 한 정관의 기재사항을 변경하여야 하는 경우에 해당하지 않으므로, 그에 관하여는 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다 (대법원 2018. 7. 20.자 2017마1565).

① 이사와 달리 감사의 임면에 관한 사항은 정관의 필요적 기재사항이 아니다.

② 정관의 임의적 기재사항이 정관에 기재되면 정관의 변경절차를 거쳐 변경하여야 한다.

③ 정관변경의 의결정족수 충족과 주무관청의 허가를 받아야 정관변경의 효력이 생긴다.

④ 재단법인이 기본재산을 편입하는 행위도 자산의 변경을 초래하므로 주무관청의 허가를 받아야 한다.

정답: ⑤

05 甲이 A재단법인 설립을 위해 X부동산을 출연하고 후에 A재단법인은 설립등기를 하여 법인설립을 완료하였으나 그 부동산에 대해 A법인 명의로 이전등기를 하지 않은 채 사망하였고, 甲의 상속인 乙은 甲의 X부동산을 丙에게 매도하고 이전등기를 해 주었다. 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲의 A재단법인에 대한 정관작성은 상대방 없는 단독행위이다.
- ② 甲과 A재단법인의 관계에서 X부동산은 A재단법인으로 이전등기시에 A재단법인의 소유로 된다.
- ③ A재단법인과 丙 사이에서는 X부동산의 소유권은 A법인 앞으로 이전등기가 되어야 A법인은 丙에게 대항할 수 있다.
- ④ 丙은 유효하게 소유권을 취득한다.
- ⑤ A재단법인은 乙에게 채무불이행으로 인한 손해배상을 청구할 수 있다.

해설

② 출연재산이 부동산인 경우에도 출연자와 법인 사이에는 이전등기 없이도 법인의 성립(설립등기)과 동시에 법인에게 귀속하지만, 법인이 제3자에게 이로써 대항하려면 이전등기를 요한다는 것이 판례이다. 정답: ②

06 민법상 사단법인의 정관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 사원총회의 결의에 의한 정관해석은 사원들이나 법원을 구속하는 효력이 없다.
- ② 정관의 변경은 주무관청의 허가를 얻지 않으면 그 효력이 없다.
- ③ 사원의 지위를 상속할 수 있도록 한 정관의 규정은 유효하다.
- ④ 사단법인의 정관은 총사원 3분의 2 이상의 동의가 있는 때에 한하여 이를 변경할 수 있는 것이 원칙이다.
- ⑤ 결의권평등의 원칙을 변경하는 정관의 규정은 효력이 없다.

해설

⑤ 각 사원의 결의권은 평등으로 한다. 그러나 정관에 다른 규정이 있는 때에는 적용하지 아니한다(제73조 제1항, 제3항).

① 사단법인 정관의 해석은 객관적 기준에 따른 법규해석의 방법에 의해야 하고 사원총회의 결의의 형태로 행해진 정관의 해석은 구속력이 발생하지 않는다(대법원 2000.11.24, 99다12437).

② 제42조 제2항

③ 사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없다고 규정한 민법 제56조의 규정은 강행규정이라고 할 수 없으므로, 정관으로 이를 인정하고 있을 때에는 양도, 상속이 허용된다(대법원 1997.9.26, 95다6205).

④ 사단법인의 정관은 총사원 3분의 2 이상의 동의가 있는 때에 한하여 이를 변경할 수 있다. 그러나 정수에 관하여 정관에 다른 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다(제42조 제1항). 정답: ⑤

재단법인에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 법인의 대표자가 법인의 채무를 부담하는 계약을 할 때, 주무관청의 인가를 받도록 정관에 규정되어 있다면 이는 법인의 권리능력을 제한하는 것이다.
- ㉡ 법인이 기본재산을 감소시키는 경우에는 주무관청의 허가를 받아야 하지만, 기본재산을 증가시키는 경우에는 주무관청의 허가가 필요치 않다.
- ㉢ 유언으로 재단법인을 설립하기 위해 지명채권을 출연하는 경우, 그 채권이 법인에 귀속하는 시기는 유언의 효력이 발생한 때, 즉 출연자가 사망한 때이다.
- ㉣ 법인설립을 위한 출연행위는 상대방이 있는 단독행위이다.
- ㉤ 유언으로 재단법인을 설립하기 위해 특정부동산을 출연하는 경우, 제3자에 대한 관계에서 그 부동산이 법인에 귀속하는 시기는 법인명의로 등기를 마친 때이다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉣

④ ㉡, ㉤

⑤ ㉢, ㉤

해설

- ㉠ 법인의 대표자가 법인의 채무를 부담하는 계약을 할 때, 주무관청의 인가를 받도록 정관에 규정되어 있다면 이는 이사의 대표권 제한이지, 법인의 권리능력을 제한하기 위한 것이 아니다.
- ㉡ 재산법인의 기본재산에 관한 사항은 정관의 기재사항으로서 기본재산의 변경은 정관의 변경을 초래하기 때문에 주무부장관의 허가를 받아야 하고, 따라서 기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무관청의 허가가 있어야만 유효하다(대법원 1982.9.28, 82다카499).
- ㉢ 유언으로 재단법인을 설립하는 때에는 출연재산은 유언의 효력이 발생한 때로부터 법인에 귀속한 것으로 간주되므로 유언으로 재단법인을 설립하기 위해 지명채권을 출연하는 경우, 그 채권이 법인에 귀속하는 시기는 유언의 효력이 발생한 때, 즉 출연자가 사망한 때이다(제48조 제2항).
- ㉣ 재단법인 설립을 위한 출연행위는 상대방이 없는 단독행위이다.
- ㉤ 유언으로 재단법인을 설립하기 위해 특정부동산을 출연하는 경우 즉, 출연자와 법인과의 사이에는 이전등기 없이도 출연부동산은 법인성립(설립등기)과 동시에 법인에게 귀속하지만, 법인이 제3자에게 이로써 대항하려면 제186조의 일반원칙에 따라 이전등기를 요한다(대법원 1979.12.11, 78다481·78다482 전합). 정답: ⑤

사단법인의 사원총회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사원총회에는 대외적인 대표권이나 대내적인 업무집행권이 없다.
- ② 각 사원은 평등한 결의권을 가지며, 정관으로도 달리 정할 수 없다.
- ③ 정관에 다른 규정이 없는 한, 총사원의 5분의 1 이상이 회의의 목적사항을 제시하여 총회 소집을 청구한 경우에 이사는 임시총회를 소집하여야 한다.
- ④ 총회는, 정관에 규정이 있으면, 소집 통지에 기재한 목적사항 이외에 대해서도 결의할 수 있다.
- ⑤ 정관에 다른 규정이 없는 한, 정관변경을 위해서는 총사원의 3분의 2 이상의 동의를 있어야 한다.

해설

- ② 각 사원은 원칙적으로 평등한 결의권을 가지며(제73조 제1항), 이러한 결의권 평등의 원칙은 사원의 고유권을 박탈하지 않는 범위 내에서 정관으로 변경할 수 있다. 아울러 법인과 어느 사원과의 관계(㉠) 법인과 사원과의 매매계약)에 대하여 의결하는 때에는 그 사원은 결의권이 없다.

정답: ②

09 법인의 이사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 임시이사는 법인의 대표기관으로서 사원총회를 소집할 권한이 있다.
 ② 이사가 여러 명인 경우, 정관에 달리 정한 바가 없으면 이사는 법인사무에 관하여 각자 법인을 대표한다.
 ③ 이사가 없거나 결원이 있어 손해가 생길 염려가 있는 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 임시이사를 선임하여야 한다.
 ④ 이사는 법인에 대한 일방적인 의사표시로 사임할 수 없고, 이사회 결의나 관할관청의 승인이 있어야 한다.
 ⑤ 이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있는데, 이때 대리인은 법인의 대리인이다.

해설

- ④ 이사는 법인에 대한 일방적인 의사표시로 사임할 수 있고, 사임의 의사표시는 수령권한 있는 기관에 도달함으로써 바로 효력이 생기는 것이며 그 효력발생을 위하여 이사회 결의나 관할관청의 승인이 있어야 하는 것은 아니다(대법원 2003.1.10., 2001다1171). 정답: ④

10 법인의 이사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 사임하지 않은 다른 이사들로써 정상적인 법인활동이 가능하면 사임한 이사에게 직무를 계속 행사하게 할 필요는 없다.
 ② 법인 대표자의 유임 내지 중임을 금지하는 규약이 없는 이상, 임기만료 후에 대표자가 개임이 없었다면 그 대표자를 묵시적으로 다시 대표자로 선임하였다고 해석된다.
 ③ 정관에 다른 규정이 없는 한, 이사의 사임의 의사표시는 법인에 대한 일방적인 의사표시와 법인의 승낙이 있어야만 효력이 발생한다.
 ④ 이사의 퇴임은 등기 후가 아니면 제3자에게 대항할 수 없다.
 ⑤ 이사가 사임의 의사표시를 한 경우, 사임의 효력이 발생하기 전에 사임의 의사표시를 철회할 수 있다.

해설

- ③ 이사는 법인에 대한 일방적인 사임의 의사표시에 의하여 법률관계를 종료시킬 수 있고, 그 의사표시는 수령권한 있는 기관에 도달함으로써 바로 효력을 발생하는 것이며, 그 효력발생을 위하여 이사회 결의나 관할관청의 승인이 있어야 하는 것은 아니다(대법원 2003.1.10., 2001다1171).
 ④ 이사의 대표권에 대한 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다(제60조). 정답: ③

11

법인의 기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 정관에 다른 규정이 없는 한, 사원총회의 결의사항은 총회를 소집할 때 미리 적법하게 통지한 사항에 한한다.
- ② 이사 사임의 의사표시가 법인의 대표자에게 도달한 후에는, 특별한 사정이 없으면, 그 의사 표시를 철회할 수 없다.
- ③ 사원총회 소집권자가 총회 구성원들에게 총회 개최의 연기를 통지할 때에는 총회의 소집과 동일한 방식에 의할 필요가 없다.
- ④ 정관이나 사원총회의 결의로 금지하지 않는 한, 이사는 타인으로 하여금 법인의 제반 사무 처리를 포괄적으로 대리하게 할 수 있다.
- ⑤ 사원총회의 결의는 법률 또는 정관에 다른 규정이 없으면 사원 과반수의 출석과 출석사원의 결의권의 과반수로써 한다.

해설

- ④ 비법인사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법 규정 가운데 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 하는데, 민법 제62조에 비추어 보면 비법인사단의 대표자는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있을 뿐 비법인사단의 제반 업무처리를 포괄적으로 위임할 수는 없으므로 비법인사단 대표자가 행한 타인에 대한 업무의 포괄적 위임과 그에 따른 포괄적 수임인의 대행행위는 민법 제62조를 위반한 것이어서 비법인사단에 대하여 그 효력이 미치지 않는다(대법원 2011.04.28. 2008다15438). 정답: ④

12

법인의 정관변경에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 재단법인의 기본재산을 처분하려면 주무관청의 허가가 필요하나, 새로이 기본재산으로 편입하는 경우에는 주무관청의 허가를 요하지 않는다.
- ② 사단법인의 정관은 정관에 다른 규정이 있더라도 출석의원 3분의 2 이상의 동의가 있으면 주무관청의 허가를 받아 변경할 수 있다.
- ③ 사원자격의 득실변경에 관한 정관의 기재사항이 적법한 절차를 거쳐서 변경된 경우에는 구성원이 다르더라도 그 변경 전후의 사단법인은 동일성을 유지하면서 존속한다.
- ④ 재단법인의 명칭은 정관의 기재사항이므로 주무관청의 허가를 받더라도 변경할 수 없다.
- ⑤ 사단법인의 정관은 사단법인의 동일성을 해하거나 그 본질에 반하는 경우에도 총사원의 동의가 있으면 변경할 수 있다.

해설

- ③ 타당한 기술이다.
- ① 기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무부장관의 허가가 있어야만 유효하다(대법원 1982.9.28. 82다카499).
 - ② 사단법인의 정관은 총의원 3분의 2 이상의 동의가 있는 때에 한하여 이를 변경할 수 있다. 그러나 정수에 관하여 정관에 다른 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다(제42조).
 - ④ 정관에서 정관변경의 방법을 정하지 않은 경우에도 목적달성 또는 재산보전을 위하여 적당한 때에는 명칭 또는 사무소의 소재지를 변경할 수 있다(제45조 제2항).
 - ⑤ 비영리법인을 영리법인으로 하는 것과 같이 사단법인의 동일성을 해하거나 그 본질에 반하는 경우에는 총사원의 동의가 있어도 변경할 수 없다. 정답: ③

13 법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2021' 감정평가사]

- ① 사단법인 이사의 대표권 제한은 이를 등기하지 않으면 약의 제3자에게도 대항하지 못한다.
- ② 재단법인의 정관변경은 그 변경방법을 정관에서 정한 때에도 주무관청의 허가를 얻지 않으면 그 효력이 없다.
- ③ 재단법인의 기본재산에 관한 근저당권 설정행위는 특별한 사정이 없는 한 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다.
- ④ 재단법인의 기본재산 변경 시, 그로 인하여 기본재산이 새로이 편입되는 경우에는 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다.
- ⑤ 법인에 대한 청산종결등기가 경료된 경우에도 청산사무가 종결되지 않는 한 그 범위 내에서 청산법인으로서 존속한다.

해설

- ④ 기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무부장관의 허가가 있어야만 유효하다(대법원 1982.9.28., 82다카499). 정답: ④

14 비법인사단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2023' 감정평가사]

- ① 비법인사단의 대표자는 자신의 업무를 타인에게 포괄적으로 위임할 수 있다.
- ② 정관이나 규약에 달리 정함이 없는 한, 사원총회의 결의를 거치지 않은 총유물의 관리행위는 무효이다.
- ③ 고유한 의미의 종중은 종중원의 신분이나 지위를 박탈할 수 없고, 종중원도 종중을 탈퇴할 수 없다.
- ④ 고유한 의미의 종중은 자연발생적 종족단체이므로 특별한 조직행위나 성문의 규약을 필요로 하지 않는다.
- ⑤ 비법인사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.

해설

- ① 비법인사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법 규정 가운데 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 하는데, 민법 제62조에 비추어 보면 비법인사단의 대표자는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있을 뿐 비법인사단의 제반 업무처리를 포괄적으로 위임할 수는 없다(대법원 2011.04.28. 2008다15438).

정답: ①

15

2023년 5월 A학교법인 대표이사 甲은 건물신축공사를 한다는 명목으로 乙로부터 1억 원을 차용하고, 그 담보로 대표이사 甲의 명의로 당좌수표를 교부하였다. 그런데 구 사립학교법 규정에 의하면 학교법인이 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때에는 관할청의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있으나, 사실 甲 개인의 사리(私利)를 도모할 목적이었으므로 관할청의 허가를 받지 않은 것이었다. 그 후 차용금을 변제하지 않자 乙은 당좌수표를 지급 제시하였으나 무거래를 이유로 지급이 거절되었다. 다음 설명 중 틀린 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲의 1억 원 차용행위는 직무관련성이 인정된다.
- ② 구 사립학교법 규정에 위반하여 감독청의 허가없이 乙로부터 금원을 차용한 경우라 하더라도 그 차용행위는 A학교법인에 대하여 효력이 있다.
- ③ 甲이 그 업무집행에 관하여 타인에게 손해를 가한 경우이므로 학교법인 A는 손해배상책임을 진다.
- ④ 乙이 甲의 행위가 감독청의 허가없이 하는 것이라는 사정을 미리 알고 있었다 하더라도 불법행위로 인한 손해배상책임을 A학교법인에 물을 수 있다.
- ⑤ 위 ②의 경우, 甲은 그 자신의 손해배상책임을 면하지 못한다.

해설

- ①②③⑤ 설문의 경우 A법인의 불법행위가 성립한다. 법인의 대표기관이 그 직무에 관하여 타인에게 손해를 가한 경우에 법인의 불법행위가 성립하는데, 설문에서처럼 학교법인의 대표이사가 신축건물공사를 위해 금원을 차입하는 행위는 외형상 직무행위의 범위에 들어간다고 볼 수 있고, 또 A법인의 대표이사 甲의 사립학교법 위반의 위법행위로 금전소비대차계약이 무효가 됨에 따라 乙에게 손해가 발생하였기 때문이다. 따라서 乙은 A법인에 대해서는 법인의 불법행위책임을, 대표이사 甲에 대해서는 그 자신의 불법행위책임을 물을 수 있고, 양자는 부진정연대채무의 관계에 있다.
- ④ 한편, 법인의 대표기관이 그 직무에 관하여 한 행위는 설사 그것이 법인을 위한 것이 아니라 자기 또는 제3자의 이익을 위해 한 경우, 즉 '대표권을 남용'한 경우에도 법인의 행위로 되는 데에 지장이 없다. 문제는 상대방이 그러한 대표권의 남용사실을 안 경우의 그 효력 여하이다. 이 문제에 관해, 판례는 제107조(진의 아닌 의사표시) 제1항 단서를 유추적용하여 그 상대방이 그러한 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 법인에게 그 효과를 물을 수 없는 것으로 판단하고 있다 (대법원 1988.8.9. 86다카1858). 정답: ④

16

법인의 불법행위책임에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 외형상 직무행위로 인정되는 대표자의 권한 남용행위에 대해서도 법인의 불법행위책임이 인정될 수 있다.
- ② 등기된 대표자의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 경우에만 법인의 불법행위책임이 성립할 수 있다.
- ③ 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 중대한 과실로 알지 못한 경우, 법인의 불법행위책임이 인정된다.
- ④ 대표권 없는 이사가 그 직무와 관련하여 타인에게 손해를 가한 경우, 법인의 불법행위책임이 성립한다.
- ⑤ 법인의 불법행위책임이 성립하는 경우 그 대표기관은 손해배상책임이 없다.

해설

- ① 행위의 외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리(私利)를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다(대법원 2004.02.27. 2003다15280).
- ② '법인의 대표자'에는 그 명칭이나 직위 여하, 또는 대표자로 등기되었는지 여부를 불문하고 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하여 법인의 사무를 집행하는 사람을 포함한다(대법원 2011.04.28. 2008다15438).
- ③ 법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나(악의) 또는 중대한 과실로 인하여(중과실) 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다(대법원 2004.03.26. 2003다34045).
- ④ 민법 제35조에서 말하는 '이사 기타 대표자'는 법인의 대표기관을 의미하는 것이고 대표권 없는 이사는 법인의 기관이기는 하지만 대표기관은 아니기 때문에 그 행위로 인하여 법인의 불법행위는 성립하지 않는다(대법원 2005.12.23. 2003다30159).
- ⑤ 피해자는 그가 받은 손해의 충분한 전보(填補)를 받을 때까지 법인이나 대표기관에 대하여 동시에 또는 선택적으로 손해배상청구를 할 수 있다(부진정연대채무). 그러므로 대표기관도 당연히 손해배상책임을 면하지 못한다. 정답: ①

17

민법 제35조(법인의 불법행위능력)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ① 대표권이 없는 이사의 행위로 인하여는 법인의 불법행위가 성립하지 않는다.
- ② 법인의 불법행위능력은 사단법인뿐만 아니라 재단법인에 대하여도 적용된다.
- ③ 민법 제35조 제1항의 규정은 법인 아닌 사단에 유추적용된다.
- ④ 대표자의 행위가 법령의 규정에 위배된 것이라도 외관상, 객관적으로 직무에 관한 행위라고 인정될 수 있는 것이라면 민법 제35조 제1항의 직무에 관한 행위에 해당한다.
- ⑤ 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자가 알았던 경우에도 법인의 불법행위책임을 인정된다.

해설

- ⑤ 법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나(악의) 또는 중대한 과실로 인하여(중과실) 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다(대법원 2004.03.26. 2003다34045). 정답: ⑤

18 권리능력 없는 사단에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 권리능력 없는 사단의 사원의 권리와 의무는 사원의 지위를 취득·상실함에 따라 취득·상실된다.
- ② 종중의 법적 성격이 권리능력 없는 사단인 이상 어떤 종중이 종중으로서 존재하려면 사단의 실체를 갖추어야 하므로 종중규약이나 대표자가 없는 종중은 종중유사의 단체일지언정 고유의미의 종중은 아니다.
- ③ 권리능력 없는 사단도 사회적으로 독립한 존재이므로 명예권, 성명권, 재산권을 향유할 수 있다.
- ④ 하나의 교회가 2개의 교회로 분열된 경우, 특별한 사정이 없으면 교회의 법률적 성질이 권리능력 없는 사단이므로 종전의 교회재산은 잔존교인들의 총유이다.
- ⑤ 소집절차에 하자가 있어 그 효력을 인정할 수 없는 종중총회의 결의라도 후에 적법하게 소집된 종중총회에서 이를 추인하면 처음부터 유효하다.

해설

- ② 종중이란 공동선조의 후손 중 성년 이상의 남녀를 종원으로 하여 구성되는 종족의 자연발생적 집단으로서, 그 성립을 위하여 특별한 조직행위를 필요로 하는 것이 아니다. 다만, 그 목적인 공동선조의 분묘수호, 제사봉행, 종원 상호간의 친목을 규율하기 위하여 규약을 정하는 경우가 있고 또 대외적인 행위를 할 때에는 대표자를 정할 필요가 있기는 하나, 반드시 특정한 명칭의 사용 및 서면화된 종중규약이 있어야 하거나 종중의 대표자가 계속하여 선임되어 있는 등의 조직을 갖추어야 하는 것은 아니다(대법원 1995.11.14. 95다610, 대법원 2005.7.21. 2002다1178).

정답: ②

19 비법인사단 및 재단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 비법인사단의 대표자가 총유물의 관리·처분과 무관한 대외적 거래행위에 관하여 사원총회의 결의를 거치도록 한 정관 규정에 위반하여 그러한 거래행위를 한 경우, 상대방이 그와 같은 대표권 제한 사실을 알 수 없었다면 그 거래행위는 유효하다.
- ② 규약에 달리 정한 바가 없으면, 종중이 그 명의로 총유재산에 대한 보존행위로서 소송을 하기 위해서 종중총회의 결의를 거쳐야 하는 것은 아니다.
- ③ 비법인사단에 대하여는 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 사단법인에 관한 민법규정을 유추 적용한다.
- ④ 매매계약에 의하여 부담하고 있는 채무의 존재를 인식하고 있다는 뜻을 표시함에 불과한 소멸시효 중단사유로서의 승인은 총유물의 관리·처분행위라고 볼 수 없다.
- ⑤ 비법인재단의 경우에도 대표자가 있는 때에는 재단명의로 그 재단에 속하는 부동산의 등기를 할 수 있다.

해설

- ② 총유물의 보존에 있어서는 공유물의 보존에 관한 민법 제265조의 규정이 적용될 수 없고, 민법 제276조 제1항의 규정에 따른 사원총회의 결의를 거치거나 정관이 정하는 바에 따른 절차를 거쳐야 하므로, 법인 아닌 사단인 교회가 총유재산에 대한 보존행위로서 소송을 하는 경우에도 교인 총회의 결의를 거치거나 정관이 정하는 바에 따른 절차를 거쳐야 한다(대법원 2014.02.13. 2012다11229). 따라서 종중의 경우에도 종중총회의 결의를 거쳐야 한다. 정답: ②

- ① 비법인사단은 부동산소유권에 관하여 등기의무자가 될 수 없다.
- ② 비법인사단의 해산에 따른 청산절차에는 사단법인의 청산인에 관한 민법 규정을 유추 적용할 수 있다.
- ③ 비법인사단의 대표자가 행한 타인에 대한 업무의 포괄적 위임과 그에 따른 포괄적 수임인의 대행행위는 비법인사단에 대하여 그 효력이 있다.
- ④ 비법인사단의 채무는 구성원의 지분비율에 따라 귀속한다.
- ⑤ 이사의 결원으로 인하여 손해가 생길 염려가 있더라도 이해관계인은 법원에 임시이사의 선임을 청구할 수 없다.

해설

- ② 비법인사단에 대하여는 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 사단법인에 관한 민법규정을 유추 적용한다. 따라서 비법인사단의 해산에 따른 청산절차도 사단법인의 청산에 관한 민법 규정을 유추 적용할 수 있다.
- ① 비법인사단이나 재단의 경우에도 대표자가 있는 때에는 그 사단 또는 재단명의로 부동산의 등기를 할 수 있고 등기관리자나 등기의무자가 될 수 있다.
- ③ 법인격 없는 사단의 경우에도 대표자는 법인의 경우와 마찬가지로 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하도록 할 수는 있으나 그 제반 업무처리를 포괄적으로 위임할 수는 없다.
- ④ 비법인사단의 재산소유형태는 총유이며 채무도 총유적으로 귀속한다. 즉 지분이 없으므로 사단재산에 대한 유한책임을 진다.
- ⑤ 이사가 없거나 결원이 있는 경우에 이로 인하여 손해가 생길 염려 있는 때에는 법원은 이해관계인이나 감사의 청구에 의하여 임시이사를 선임하여야 한다(제63조). 정답: ②

- ① 법인격 없는 사단의 경우에도 대표자는 법인의 경우와 마찬가지로 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하도록 할 수는 있으나 그 제반 업무처리를 포괄적으로 위임할 수는 없다.
- ② 부동산을 출연재산으로 하는 유언에 따른 재단법인 설립에서 그 재산이 법인 명의로 등기되기 이전에 유언자의 상속인으로부터 선의의 제3자가 권리를 이전 받았을 경우, 법인은 그 제3자에 대하여 등기이전 또는 말소를 주장할 수는 없다.
- ③ 일반적으로는 취소권이 인정되는 착오의 사정이 있더라도 증여를 내용으로 하는 재단법인 설립행위의 경우 출연자는 그 의사표시를 취소할 수 없다.
- ④ 법인의 대표자가 법인의 채무를 부담하는 계약을 체결하는 경우 일정한 절차를 거치도록 하는 제한을 정관에는 규정해 두었으나 등기해 두지 않았다면 제3자가 정관의 대표권 제한규정에 관해 선의인지 악의인지를 묻지 않고 법인은 이를 주장할 수 없다.
- ⑤ 법인설립에는 목적의 비영리성, 설립행위, 주무관청의 허가, 설립등기의 요건을 갖추어야 한다.

해설

- ③ 재단법인 설립을 위하여 서면에 의한 재산을 출연한 경우에도 출연자는 착오를 이유로 출연의 의사표시를 취소할 수 있다는 것이 판례의 태도이다(대법원 1999.7.9. 98다9045). 정답: ③

22

비법인사단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 비법인사단이 타인간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물의 관리, 처분행위라고 볼 수 없다.
- ② 사단법인의 하부조직이 스스로 단체로서의 실체를 갖추고 독자적인 활동을 하고 있다면, 사단법인과는 별개의 독립된 비법인사단으로 볼 수 있다.
- ③ 비법인사단의 구성원은 총유재산에 대한 보존행위로서 각자 소를 제기할 수 있다.
- ④ 비법인사단이 해산하였다도 청산사무가 완료될 때까지는 청산의 목적범위 내에서 권리·의무의 주체가 된다.
- ⑤ 사단법인에 관한 민법규정 중 법인격을 전제로 한 규정을 제외하고는 비법인사단에도 유추 적용된다.

해설

- ③ 총유물의 보존에 있어서는 공유물의 보존에 관한 민법 제265조의 규정이 적용될 수 없고, 민법 제276조 제1항의 규정에 따른 사원총회의 결의를 거치거나 정관이 정하는 바에 따른 절차를 거쳐야 하므로, 법인 아닌 사단인 교회가 총유재산에 대한 보존행위로서 소송을 하는 경우에도 교인 총회의 결의를 거치거나 정관이 정하는 바에 따른 절차를 거쳐야 한다(대법원 2014.02.13. 2012다11229). 정답: ③

23

법인의 불법행위능력에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 법인에 대한 손해배상책임의 원인이 대표기관의 고의적인 불법행위라고 하더라도 피해자에게 그 불법행위 내지 손해발생에 과실이 있다면 법원은 과실상계의 법리에 좇아 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 있어 이를 참작하여야 한다.
- ② 법인이 대표자의 선임과 감독에 과실 없음을 증명한 때에는 법인의 불법행위(제35조)가 성립하지 않는다.
- ③ 대표기관의 행위가 직무집행에 관한 것이라는 점에 대하여 상대방은 선의이고 중과실이 없어야 한다.
- ④ 법인의 불법행위능력에 관한 규정은 법인 아닌 사단에도 유추적용된다.
- ⑤ 대표기관인 이사가 특정의 법률행위에 대해 대리인을 선임한 경우, 그 대리인의 불법행위에 대해서는 제35조의 불법행위책임이 성립되지 않는다.

해설

- ② 법인은 무과실책임을 부담한다.
 ① 대법원 1997.12.8. 86다1170
 ③ 대법원 2003.7.25. 2002다27088
 ④ 법인의 불법행위능력에 관한 규정은 법인 아닌 사단에도 유추적용된다.
 ⑤ 법인이 불법행위책임을 지는 것은 이사, 임시이사, 특별대리인, 청산인, 직무대행자 등 대표기관의 행위에 한하고 이사의 임의대리인 등의 경우에는 사용자책임이 성립할 수는 있어도 법인자체의 불법행위로 되지는 않는다. 정답: ②

24 법인의 불법행위능력에 관하여 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 이사 기타 대표자의 행위이어야 하는 바, 이 때 이사는 특정사무를 대리하는 대리인을 선임할 수 있는데 이러한 이사의 대리인은 대표자의 행위로 볼 수 없다.
- ② 직무행위라 함은 행위의 외형상 기관의 직무수행이라고 볼 수 있는 행위 및 직무행위와 사회통념상 견련성을 가지는 행위이어야 한다.
- ③ 노동조합의 집행기관이라 할 수 있는 조합간부들이 불법행위를 기획, 지시, 지도하는 등으로 주도한 경우라도 노동조합은 헌법에 의하여 보장된 노동자의 단체이므로 법인의 불법행위 책임을 규정한 민법 제35조 제1항을 유추적용하여 노동조합에게 그 책임을 묻지는 못한다.
- ④ 법인의 대표기관이 자신의 개인적 이익을 꾀할 목적으로 권한을 남용해서 부정한 대표행위를 한 경우에도 법인의 불법행위책임을 인정한다.
- ⑤ 위 ④의 경우 그 논거로 판례는 그 행위의 상대방이 대표이사의 진의를 알았거나 알 수 있었을 때에는 회사에 대하여 무효라고 판시하면서 제107조 제1항 단서를 그 이유로 들고 있다.

해설

- ③ 노동조합의 간부들이 불법 쟁의행위를 기획, 지시, 지도하는 등으로 주도한 경우에 이와 같은 간부들의 행위는 조합의 집행기관으로서의 행위라 할 것이므로 이러한 경우 민법 제35조 제1항의 유추적용에 의하여 노동조합은 그 불법 쟁의행위로 인하여 사용자가 입은 손해를 배상할 책임이 있고, 한편 조합간부들의 행위는 일면에 있어서는 노동조합 단체로서의 행위라고 할 수 있는 외에 개인의 행위라는 측면도 아울러 지니고 있고, 일반적으로 쟁의행위가 개개 근로자의 노무정지를 조직하고 집단화하여 이루어지는 집단적 투쟁행위라는 그 본질적 특징을 고려하여 볼 때 노동조합의 책임 외에 불법 쟁의행위를 기획, 지시, 지도하는 등으로 주도한 조합의 간부들 개인에 대하여도 책임을 지우는 것이 상당하다(대법원 1994.3.25. 93다32828).
- ① 대표기관에는 이사, 이사직무대행자, 임시이사(제63조), 특별대리인(제64조), 청산인(제82, 제83조)이 포함되며 이사의 대리인은 법인이 사용자책임(제756조)을 부담하며, 법인의 불법행위책임(제35조)은 인정되지 않는다.
- ② 대법원 1990.3.23. 89다카555
- ④ 대법원 1978.3.14. 78다132
- ⑤ 대법원 1997.8.29. 97다18059 정답: ③

25 민법 제35조에 의한 법인의 불법행위책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법령상 대표권 없는 이사의 행위에 대해서는 법인의 책임이 성립하지 않는다.
- ② 대표자로 등기되지 않았으나 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하는 자의 직무수행에 대해서도 법인의 책임이 성립할 수 있다.
- ③ 대표자 개인의 이익을 도모하기 위한 것이었더라도 외형상 객관적으로 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이면, 법인의 책임이 성립할 수 있다.
- ④ 대표기관의 고의적인 불법행위가 있으면 피해자에게 그 불법행위 내지 손해발생에 과실이 있더라도, 과실상계는 허용되지 않는다.

- ⑤ 법인이 피해자에게 손해를 배상하면, 법인은 그 직무를 수행한 대표기관에 대해 선량한 관리자의 주의무 위반을 이유로 구상권을 행사할 수 있다.

해설

- ④ 법인에 대한 손해배상책임의 원인이 대표기관의 고의적인 불법행위라고 하더라도, 피해자에게도 손해발생에 과실이 있다면 법원은 과실상계의 법리에 따라 이를 참작하여야 한다(대법원 1987.12.08. 86다카1170). 정답: ④

26

甲사단법인의 대표이사 乙이 외관상 그 직무에 관한 행위로 丙에게 불법행위를 한 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 감정평가사]

- ① 乙의 불법행위로 인해 甲이 丙에 대해 손해배상책임을 지는 경우에도 乙은 丙에 대한 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.
- ② 甲의 손해배상책임 원인이 乙의 고의적인 불법행위인 경우에는 丙에게 과실이 있더라도 과실상계의 법리가 적용될 수 없다.
- ③ 丙이 乙의 행위가 실제로는 직무에 관한 행위에 해당하지 않는다는 사실을 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우에는 甲에게 손해배상책임을 물을 수 없다.
- ④ 甲의 사원 丁이 乙의 불법행위에 가담한 경우, 丁도 乙과 연대하여 丙에 대하여 손해배상책임을 진다.
- ⑤ 甲이 비법인사단인 경우라 하더라도 甲은 乙의 불법행위로 인한 丙의 손해를 배상할 책임이 있다.

해설

- ② 법인에 대한 손해배상책임의 원인이 대표기관의 고의적인 불법행위라고 하더라도, 피해자에게도 손해발생에 과실이 있다면 법원은 과실상계의 법리에 따라 이를 참작하여야 한다(대법원 1987.12.08. 86다카1170). 정답: ②

27

민법의 사단법인에 관한 다음의 규정 중 권리능력 없는 사단에는 적용될 수 없는 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 제60조【이사의 대표권에 대한 제한의 대항요건】 이사의 대표권에 대한 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다.
- ② 제62조【이사의 대리인 선임】 이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있다.
- ③ 제63조【임시이사의 선임】 이사가 없거나 결원이 있는 경우에 이로 인하여 손해가 생길 염려가 있는 때에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 임시이사를 선임하여야 한다.
- ④ 제75조【총회의 결의방법】① 총회의 결의는 본법 또는 정관에 다른 규정이 없으면 사원 과 반수의 출석과 출석사원의 결의권의 과반수로써 한다.

- ⑤ 제82조【청산인】 법인이 해산한 때에는 파산의 경우를 제하고는 이사가 청산인이 된다. 그러나 정관 또는 총회의 결의로 달리 정한 바가 있으면 그에 의한다.

해설

- ① 비법인사단의 경우에는 대표자의 대표권 제한에 관하여 등기할 방법이 없어 민법 제60조의 규정을 준용할 수 없다는 것이 판례이다. 정답: ①

28 법인의 불법행위능력에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법인의 불법행위능력에 관한 규정은 법인 아닌 사단에 유추적용되지 않는다.
 ② 법인이 대표자의 선임과 감독에 과실 없음을 증명한 때에는 법인의 불법행위(「민법」 제35조)가 성립하지 않는다.
 ③ 대표기관이 법인의 목적범위 외의 행위로 타인에게 손해를 가한 경우, 사원이 단순히 그 사항의 의결에 찬성하였다고 하여 책임을 지는 것은 아니다.
 ④ 법인 아닌 사단의 대표자의 행위가 직무에 해당하지 아니함을 피해자가 중대한 과실로 알지 못한 경우에는 법인 아닌 사단에 대하여 손해배상책임을 물을 수 없다.
 ⑤ 법인의 불법행위가 성립하는 경우, 피해자는 법인에 대하여 불법행위책임을 물을 수 있을 뿐 가해자인 이사에 대하여 그 책임을 물을 수는 없다.

해설

- ④ 법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다(대법원 2004.3.26, 2003다34045).
 ① 비법인사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법 규정 가운데서 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 한다(대법원 1996.9.6, 94다18522). 따라서 법인의 불법행위능력에 관한 규정은 비법인사단에 유추적용된다.
 ② 법인은 무과실책임을 부담한다.
 ③ 법인의 목적범위 외의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다(제35조 제2항).
 ⑤ 가해자인 이사로도 법인과 함께 연대하여 그 책임을 진다(부진정전대채무, 제35조 제1항 단서)

정답: ④

29 다음 중 재단법인의 정관변경에 관한 설명으로 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 정관에서 그 변경방법을 정하지 않은 때에도 재단법인의 목적달성 또는 그 재산보전을 위하여 적당한 때에는 명칭 또는 사무소의 소재지를 변경할 수 있다.
 ② 재단법인의 목적을 달성할 수 없는 때에는 설립자나 이사는 주무관청의 허가를 얻어 설립 취지를 참작하여 그 목적 기타 정관의 규정을 변경할 수 있다.
 ③ 정관변경에 대한 주무관청의 허가의 법적 성질은 일반적 금지의 해제로 보는 것이 판례의 태도이다.

- ④ 기본재산이 증가하거나 감소하는 경우 주무관청의 허가가 있어야 유효하다.
- ⑤ 재단법인의 기본재산의 처분은 정관변경행위이므로 주무관청의 허가를 받지 아니하면 그 효력이 없다.

해설

- ③ 정관변경에 대한 주무관청의 허가의 법적 성질은 일반적 금지의 해제로 보기보다는 법률행위의 보충으로 보는 인가적 성질을 띠는 것이 판례의 태도이다(대법원 1996.5.16, 95누4810 전합).
정답: ③

30

비법인사단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사단법인의 하부조직이라도 스스로 단체로서의 실체를 갖추고 독자적인 활동을 하고 있다면 그 사단법인과는 별개의 독립된 비법인사단으로 볼 수 있다.
- ② 정관 기타 규약에 다른 정함이 없는 한, 사원총회의 결의를 거치지 않은 총유물의 관리 행위는 무효이다.
- ③ 비법인사단의 대표자의 행위가 외관상 · 객관적으로 직무에 관한 행위로 인정될 수 있으면, 그의 행위가 직무에 관한 것이 아님을 피해자가 중대한 과실로 알지 못한 경우에도 비법인사단에게 손해배상책임을 물을 수 있다.
- ④ 소집절차에 하자가 있어 그 효력을 인정할 수 없는 중중총회의 결의라도 후에 적법하게 소집된 중중총회에서 이를 추인하면 처음부터 유효로 된다.
- ⑤ 재건축조합의 총회에서는 정관에 다른 정함이 없는 한 소집 1주간 전에 통지된 그 회의의 목적 사항에 관하여만 결의할 수 있다.

해설

- ③ 법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다(대법원 2004.3.26, 2003다34045). 비법인사단의 경우에도 마찬가지이다. 정답: ③

31

정관이 있는 비법인사단에 유추적용할 수 없는 규정은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 이사의 대표권에 대한 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다는 민법 제60조
- ② 법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다는 민법 제34조
- ③ 법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다는 민법 제35조 제1항
- ④ 사단법인의 사무는 정관으로 이사 또는 기타 임원에게 위임한 사항 외에는 총회의 결의에 의하여야 한다는 민법 제68조
- ⑤ 이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있다는 민법 제62조

해설

- ① 비법인사단의 경우에는 대표자의 대표권 제한에 관하여 등기할 방법이 없어 민법 제60조의 규정을 준용할 수 없다. 정답: ①

32

법인의 불법행위책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 대표자는 그 명칭이나 직위는 문제되지 않으며, 대표자로 등기되지 않은 자도 이에 포함될 수 있다.
② 대표자의 행위가 직무에 관한 것이 아님을 피해자가 안 경우, 법인은 책임을 지지 않는다.
③ 외형상 대표자의 직무행위로 인정되어도 그것이 대표자 개인의 사리를 도모하기 위한 것이면, 직무에 관한 행위에 해당하지 않는다.
④ 법인의 책임이 성립하는 경우 특별한 사정이 없는 한, 사원이 그 사항의 총회의결에 찬성했다는 사실만으로 법인과 연대책임을 부담하지는 않는다.
⑤ 법인책임이 대표자의 고의적인 불법행위로 인한 경우에도 피해자에게 과실이 있다면, 법원은 이를 참작하여야 한다.

제3장
실전문제

해설

- ③ 행위의 외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리(私利)를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다. 정답: ③

33

민법상 법인의 기관에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 이사의 변경등기는 대항요건이 아니라 효력발생요건이다.
② 이사가 수인인 경우, 특별한 사정이 없는 한 법인의 사무에 관하여 이사는 공동으로 법인을 대표한다.
③ 사단법인의 정관 변경에 관한 사원총회의 권한은 정관에 의해 박탈할 수 있다.
④ 이사회에서 법인과 어느 이사와의 관계사항을 의결하는 경우, 그 이사는 의사정족수 산정의 기초가 되는 이사의 수에 포함된다.
⑤ 법인의 대표권 제한에 관한 사항이 등기되지 않았더라도 법인은 대표권 제한에 대해 악의인 제3자에게 대항할 수 있다.

해설

- ④ 민법상 법인의 이사회에서 법인과 어느 이사와의 관계사항을 의결하는 경우에는 그 이사는 의결권이 없다. 이 때 의결권이 없다는 의미는 이해관계 있는 이사는 이사회에서 의결권을 행사할 수는 없으나 의사정족수 산정의 기초가 되는 이사의 수에는 포함되고, 다만 결의 성립에 필요한 출석이사에는 산입되지 아니한다(대법원 2009. 4. 9. 2008다1521).
① 이사의 변경등기는 효력요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건이다.
② 이사가 수인인 경우, 특별한 사정이 없는 한 법인의 사무에 관하여 이사는 각자 법인을 대표한다.
③ 사단법인의 정관 변경에 관한 사원총회의 권한은 정관에 의해서도 박탈할 수 없다.
⑤ 대표권의 제한이 등기되어 있지 않더라도 악의의 제3자에게는 대항할 수 있다는 견해(다수설)가 있으나, 판례는 제3자의 선의·악의를 불문하고 대항할 수 없다고 한다. 정답: ④

34 민법상 법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 감정평가사]

- ① 재단법인의 정관변경은 그 정관에서 정한 방법에 따른 경우에도 주무관청의 허가를 얻지 않으면 효력이 없다.
- ② 사단법인과 어느 사원과의 관계사항을 의결하는 경우에는 원칙적으로 그 사원은 결의권이 없다.
- ③ 사단법인의 사원자격의 득실에 관한 규정은 정관의 필요적 기재사항이다.
- ④ 민법상 법인의 청산절차에 관한 규정에 반하는 합의에 의한 잔여재산처분행위는 특별한 사정이 없는 한 무효이다.
- ⑤ 청산 중 법인의 청산인은 채권신고기간 내에는 채권자에 대하여 변제할 수 없으므로 법인은 그 기간 동안 지연배상 책임을 면한다.

해설

- ⑤ 청산인은 채권신고기간 내에는 채권자에 대하여 변제하지 못한다. 그러나 법인은 채권자에 대한 지연손해배상의 의무를 면하지 못한다(제90조). 정답: ⑤

35 甲사단법인이 3인의 이사 (乙, 丙, 丁) 를 두고 있는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 감정평가사]

- ① 乙, 丙, 丁은 甲의 사무에 관하여 원칙적으로 각자 甲을 대표한다.
- ② 甲의 대내적 사무집행은 정관에 다른 규정이 없으면 乙, 丙, 丁의 과반수로써 결정한다.
- ③ 甲의 정관에 乙의 대표권 제한에 관한 규정이 있더라도 이를 등기하지 않으면 그와 같은 정관의 규정에 대해 악의인 제3자에 대해서도 대항할 수 없다.
- ④ 丙이 제3자에게 甲의 제반 사무를 포괄 위임한 경우, 그에 따른 제3자의 사무대행행위는 원칙적으로 甲에게 효력이 없다.
- ⑤ 甲의 토지를 丁이 매수하기로 한 경우, 이 사항에 관하여 丁은 대표권이 없으므로 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 임시이사를 선임하여야 한다.

해설

- ⑤ 법인과 이사의 이익이 상반하는 사항에 관하여는 이사는 대표권이 없다. 이 경우에는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 특별대리인을 선임하여야 한다(제64조). 정답: ⑤

권리의 객체

1

기본문제

제4장
기본문제

01 물건에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 특정물과 불특정물의 구별은 당사자의 의사에 의한 주관적인 구별이다.
- ② 정당한 이익이 있는 범위 내의 온천수는 토지의 구성부분으로 토지소유권의 범위에 속한다.
- ③ 독립된 건물로 인정되기 위해서는 최소한 기둥과 지붕 그리고 주벽이 갖추어지면 된다.
- ④ 입목에 관한 법률에 의하여 등기된 입목은 소유권의 객체가 될 수 있을 뿐이다.
- ⑤ 자연석을 조각하여 제작한 석불은 임야와 독립하여 소유권의 대상이 된다.

해설

- ④ 수목은 토지의 정착물로서 독립하여 물권의 객체가 되지 못한다. 그러나 「입목에 관한 법률」에 의하여 등기된 수목의 집단은 독립하여 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있다(동법 제3조 제1항).
- ① 물건은 당사자의 의사 여부(구체적·주관적 구별)에 따라 특정물과 불특정물로 나누어지는데, 특정물은 당사자가 동종의 다른 것으로 바꾸는 것을 허용하지 않는 물건을 말하며, 불특정물은 당사자가 동종의 다른 것으로 바꾸는 것이 허용되는 물건을 말하는데 대체물이라도 당사자가 특정시킨 경우에는 특정물이 된다.
- ② 온천수는 토지소유권과 독립되는 물건으로 볼 수 없고 토지의 구성부분이다. 정답: ④

02 다음 설명 중 옳바른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 무체물이라도 관리가능한 자연력의 경우에는 민법상 물건이 될 수 있다.
- ② 주물 위에 저당권이 설정된 경우 저당권설정 후에 부속한 종물에는 그 저당권의 효력이 생기지 않는다.
- ③ 권원 없이 타인의 토지를 경작한 농작물의 경우 명인방법을 갖추지 않았다면 그 농작물의 소유권은 토지소유자에게 귀속된다.
- ④ 미분리의 천연과실은 토지의 일부이므로 어떤 경우에도 독립된 물건이 될 수 없다.
- ⑤ 물건의 임대차로 받은 사용료, 노동의 대가로서의 임금도 과실에 포함된다.

해설

- ① 무체물 가운데에서는 관리가능한 자연력만이 물건이 될 수 있다.
- ② 저당권설정 전후를 불문하고 저당목적물 위에 부속된 부합물·종물에도 저당권의 효력이 미친다.
- ③ 타인의 토지에 권원 없이 경작한 농작물이 성숙한 경우에는 명인방법을 갖추지 않아도 경작자의 소유가 된다는 것이 판례의 태도이다.

- ④ 입목등기를 갖추지 않은 수목의 집단, 개개의 수목, 미분리의 과실 등은 원칙적으로 종속정착물과 같이 취급되나, 거래상의 관행에 따라 토지에 정착한 상태에서 명인방법이라는 공시방법을 갖추어 독립정착물과 동일하게 취급되어 부동산이 된다.
- ⑤ 노동의 대가, 주식의 배당금이나 특허권의 사용료 등은 과실이 될 수 없다. 정답: ①

03 동산에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 관리할 수 있는 전기
㉡ 지중(地中)에 있는 지하수
㉢ 강제통용력을 상실한 주화(禱貨)
㉣ 토지에 정착된 다리(橋)

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

해설

② ㉠㉢은 동산, ㉡㉣은 부동산에 해당한다. 정답: ②

04 물건에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 저당권의 효력은 저당목적물의 종물에도 미친다.
㉡ 집합물에 대해서도 양도담보권을 설정할 수 있다.
㉢ 무주(無主)의 부동산에도 선점이 인정된다.
㉣ 하천·공원은 공용물이다.
㉤ 1필의 토지의 일부에 대하여는 저당권을 설정할 수 없다.

- ① ㉠, ㉢ ② ㉢, ㉣ ③ ㉡, ㉤
④ ㉠, ㉡, ㉤ ⑤ ㉡, ㉣, ㉤

해설

- ㉠ ○ 주물 위에 저당권이 설정된 경우 그 저당권의 효력은 저당권설정 당시에 이미 존재하던 종물 뿐 아니라 그 설정 후에 부속된 종물에 대하여도 미친다(제358조).
- ㉡ ○ 집합물도 예외적으로 양도담보의 객체가 될 수 있다.
- ㉢ × 무주의 부동산은 국유이다.
- ㉣ × 하천과 공원은 공공용물이다. 공용물은 관공서의 건물·국공립학교의 건물과 같이 국가·공공 단체가 소유하고 공공목적으로 사용되는 물건을 말한다.
- ㉤ ○ 1필의 토지의 일부에 대한 저당권은 설정할 수 없다. 다만, 용익물권은 부동산의 일부에도 설정될 수 있다. 정답: ④

05 과실(果實)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉠ 물건의 사용대가로 받은 물건도 법정과실이다.
- ㉡ 국립공원의 입장료는 토지의 사용대가로서 민법상 과실에 해당한다.
- ㉢ 천연과실은 그 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에게 속한다.
- ㉣ 법정과실은 수취할 권리의 존속기간일수의 비율로 취득한다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉣
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉢, ㉣
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

해설

- ④ ㉡ 국립공원의 입장료는 토지의 사용대가라는 민법상 과실이 아니라 수익자 부담의 원칙에 따라 국립공원의 유지·관리비용의 일부를 국립공원 입장객에게 부담시키고자 하는 것이어서 토지의 소유권이나 그에 기한 과실수취권과는 아무런 관련이 없다(대법원 2001.12.28. 2000다27749).
- ㉠, ㉢, ㉣은 모두 타당한 기술이다. 정답: ④

06 종물의 요건으로서 틀린 것은?

- ① 종물은 주물의 상용에 공여하는 것이어야 한다.
- ② 종물이 되기 위하여는 특정한 주물에 부속한다고 인정되는 정도의 장소적 관계가 있을 것이 필요하다.
- ③ 주물과 종물은 다같이 독립적인 물건이어야 한다.
- ④ 주물과 종물은 동일한 소유자에 속할 것을 요한다.
- ⑤ 동산만이 종물이 될 수 있다.

해설

㉠ 주물과 종물

주 물	다른 물건을 보조적으로 사용함이 없이 독립적으로 경제적 가치를 가지는 물건을 말한다.
종물의 요건	㉠ 주물의 상용에 공할 것 ㉡ 독립한 물건일 것 ㉢ 부동산, 동산 모두에 인정 ㉣ 주물, 종물 모두 동일한 소유자에게 속할 것 ㉤ 장소적으로 밀접한 위치에 있을 것
효 과	종물은 주물의 처분에 따른다(임의규정).

정답: ⑤

07 주물과 종물에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 주물의 소유자나 이용자의 상용에 공여되고 있다면 주물 자체의 효용과 직접 관계되지 않는 물건도 종물이 된다.
- ② 주물과 종물 사이에는 밀접한 장소적 관련성이 있어야 한다.
- ③ 종물은 독립한 물건이어야 하며 동산이든 부동산이든 관계없다.
- ④ 횡집으로 사용할 점포건물에 붙여서 횡감용 생선을 보관하기 위하여 신축한 수족관 건물은 점포건물의 종물이다.
- ⑤ 건물에 인접한 대지의 지하에 매설된 정화조는 건물의 구성부분이지 종물은 아니다.

해설

- ① 종물은 주물의 상용에 이바지해야 한다. 따라서 주물의 소유자나 이용자의 상용에 공여되는 경우에는 종물로 볼 수 없다. 예컨대 배와 노, 자물통과 열쇠, 새와 새장, 주택과 광, 안채와 사랑채는 주물·종물의 관계에 있다. 그러나 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건은 종물이 아니다. 예컨대, 식기·침구·난로·텔레비전·책상 등은 주택의 종물이 아니다. 정답: ①

08 물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ① 토지의 정착물은 부동산이다.
- ② 일정한 토지가 지적공부에 1필의 토지로 등록된 경우, 그 토지의 지적 및 경계는 일응 그 등록으로써 확정된다.
- ③ 건물의 경계는 사회통념상 독립한 건물로 인정되는 건물 사이의 현실적 경계에 의하여 특정된다.
- ④ 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건이라도 주물 소유자의 사용에 공여되고 있으면 종물에 해당한다.
- ⑤ 특별한 사정이 없는 한 법정과실은 수취할 권리의 존속기간일수의 비율로 취득한다.

해설

- ④ 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건은 종물이 아니다. 정답: ④

09 다음 중 판례의 태도가 잘못 소개된 것은?

- ① 종물이 타인의 소유라 하더라도 그 타인의 권리를 해하지 아니하는 범위에서 제100조가 적용된다.
- ② '종물은 주물의 상용에 공한다'란 의미는 사회통념상 계속하여 주물의 효용을 완성시키는 작용을 한다고 인정되는 종류의 물건이고 또 특정의 주물에 부속된다고 인정될 만한 장소적 관계에 있어야 한다.
- ③ 종물은 주물의 처분에 따른다는 내용의 제100조 제2항 규정은 임의규정이므로 합의에 따라 달리 정할 수 있다.

- ④ 저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다는 제358조 본문의 규정은 저당부동산에 관한 종된 권리로까지 유추적용될 수 없기 때문에, 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물을 목적으로 하는 지상권에는 미치지 않는다.
- ⑤ 헛집으로 사용되는 건물에 신축한 수족관은 종물이다.

해설

- ④ 저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다는 제358조 본문을 유추하여 보면 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미치게 되므로, 건물에 대한 저당권이 실행되어 경락인이 그 건물의 소유권을 취득하였다면 경락 후 건물을 철거한다는 등의 매각조건에서 경매되었다는 등 특별한 사정이 없는 한, 경락인은 건물 소유를 위한 지상권도 제187조의 규정에 따라 등기 없이 당연히 취득하게 되고, 한편 이 경우에 경락인이 건물을 제3자에게 양도한 때에는, 특별한 사정이 없는 한 제100조 제2항의 유추적용에 의하여 건물과 함께 종된 권리인 지상권도 양도하기로 한 것으로 본다(대법원 1996.4.26. 95다52864).

- ① 대법원 2002.2.5. 2000다38527
 ② 대법원 1956.5.24. 4288민상526
 ③ 대법원 1978.12.26. 78다2028
 ⑤ 헛집으로 사용할 점포 건물에 거의 붙여서 헛감용 생선을 보관하기 위하여, 즉 위 점포건물의 상용에 공하기 위하여 신축한 수족관 건물은 위 점포 건물의 종물이다(대법원 1993.3.12. 92도3234).

정답: ④

10 다음 판례의 설명 중 틀린 것은?

- ① 판례는 미분리의 천연과실과 수목의 집단은 토지의 일부이지만 명인방법을 갖춘 경우에는 독립한 권리의 객체가 된다고 한다.
- ② 판례는 권원 없이 경작한 농작물에 대한 소유권은 경작한 사람에게 있다고 한다.
- ③ 판례는 종물은 특정의 주물에 종속된다고 볼 만한 장소적 관계가 존재하여야 한다고 한다.
- ④ 판례는 민법 제358조 본문의 규정은(저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 종물에 미친다) 종된 권리에도 적용된다고 하여 종물이론을 유추적용한다.
- ⑤ 판례는 건물의 개수를 판단함에 있어서는 물리적 구조와 같은 객관적 사정에 의해서 판단하여야 하며, 당사자의 의사를 판단의 기준으로 삼아서는 아니 된다고 한다.

해설

- ⑤ 객관적 사정 외에도 건축한 자의 의사와 같은 주관적 사정도 고려하여야 한다는 것이 판례의 태도이다. 정답: ⑤

11

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 분묘에 매장된 조상의 유골은 민법이 정하는 제사용 재산인 분묘와 함께 그 제사주재자에게 승계된다.
- ② 농작물을 권원 없이 타인의 토지에서 경작하고 그 농작물이 성숙하여 독립한 물건이 되었으면 그에 대한 소유권은 경작자에게 있다.
- ③ 입목에 관한 법률에 의한 입목은 토지와 독립한 동산으로 본다.
- ④ 지상권은 1필의 토지의 일부에도 설정될 수 있다.
- ⑤ 건물은 토지와 독립한 별개의 부동산이다.

해설

- ③ 토지에 부착된 수목의 집단으로서 그 소유자가 '입목에 관한 법률'에 의하여 소유권보존등기를 한 것을 입목이라 하며, 이 입목은 독립의 부동산으로 취급된다. 정답: ③

01 물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법률상 공시방법이 인정되지 않은 집합물이라도 특정성이 있으면 이를 양도담보의 목적으로 할 수 있다.
- ② 법정과실은 원칙적으로 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다.
- ③ 수목에 달려있는 미분리의 과실에 대해 명인방법을 갖추면 그 과실은 독립한 물건으로 거래의 목적으로 할 수 있다.
- ④ 천연과실은 다른 특약이 있더라도 그 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에게 속한다.
- ⑤ 권원 없이 타인의 토지에서 경작한 농작물도 성숙하여 독립한 물건으로 인정되면 그 소유권은 명인방법을 갖추 필요 없이 경작자에게 있다.

해설

- ④ 과실의 귀속에 관한 민법의 규정은 임의규정이다. 정답: ④

02 다음 판례의 설명 중 틀린 것은?

- ① 미분리의 천연과실과 수목의 집단은 토지의 일부이지만 명인방법을 갖춘 경우에는 독립한 권리의 객체가 된다고 한다.
- ② 종물은 특정의 주물에 종속된다고 볼 만한 장소적 관계가 존재하여야 한다고 한다.
- ③ 권원없이 경작한 농작물에 대한 소유권은 경작한 사람에게 있다고 한다.
- ④ 집합물에 대하여 양도담보권설정계약이 맺어지면 그 집합물을 구성하는 개개의 물건이 변동하거나 변형되더라도 한개의 물건으로서의 동일성을 잃지 않는 것으로 본다.
- ⑤ 경매법원이 기존건물의 종물이라거나 부합된 부속건물이라고 볼 수 없는 건물에 대하여 경락 허가를 한 경우에 그 독립된 건물에 대한 경락도 유효하므로 경락인은 소유권을 취득한다.

해설

- ⑤ 대법원 1988.2.23. 87다카600
 ① 입목에 관한 법률에 따라 등기된 입목이나 명인방법을 갖춘 수목의 경우에는 독립하여 거래의 객체가 되므로 토지 평가에 포함되지 아니한다(대법원 1998.10.28. 98마1817).
 ② 대법원 1978.12.26. 78다2028
 ③ 대법원 1979.8.28. 79다784
 ④ 대법원 1990.12.26. 88다카20224 정답: ⑤

03

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 1동의 건물의 일부도 독립성이 인정되면 하나의 부동산이 될 수 있다.
- ② 부동산의 일부를 전세권의 객체로 할 수 있다.
- ③ 입목에 관한 법률에 의해 등기한 수목의 집단은 저당권의 객체가 될 수 없다.
- ④ 독립된 부동산으로서의 건물이라고 하기 위하여는 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽(主壁)을 갖추어야 한다.
- ⑤ 타인의 토지 위에 권원없이 경작한 농작물이 성숙하였다면 그 소유권은 경작자에게 귀속된다.

해설

③ 입목법에 의하여 등기한 수목의 집단은 독립하여 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있다(입목에 관한 법률 제3조). 정답: ③

04

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 토지의 개수는 지적공부상 토지의 필수에 의한다.
- ② 사람은 유언으로 본인의 시신을 병원에 연구용으로 기증할 수 있으나, 제사를 주재하는 자에게 법적 구속을 받는 것은 아니다.
- ③ 집합물은 이를 하나의 물건으로 인정하는 법률의 특별규정이 있는 경우에 한하여 하나의 물건으로 취급한다.
- ④ 법정과실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득함이 원칙이다.
- ⑤ 유체물이어도 배타적 관리가능성이 없으면 물건으로 보지 않는다.

해설

- ③ 집합물은 공장 및 광업재단저당법과 같은 특별법상 하나의 물건으로 취급해야 할 사회적·경제적 필요성이 있고, 적당한 공시방법이 갖추어진 경우에는 예외적으로 하나의 물건이 된다. 또한 집합물이 관습법상 양도담보의 객체가 되는 경우가 있다.
- ② 피상속인이 생전행위 또는 유언으로 자신의 유체·유골을 처분하거나 매장장소를 지정한 경우에, 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하지 않는 이상 그 의사는 존중되어야 하고 이는 제사주재자로서도 마찬가지이지만, 피상속인의 의사를 존중해야 하는 의무는 도의적인 것에 그치고, 제사주재자가 무조건 이에 구속되어야 하는 법률적 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다(대법원 2008.11.20. 2007다27670 전합).
- ④ 법정과실은 수취할 권리의 존속기간일수의 비율로 취득한다(제102조 제2항). 정답: ③

05

주물과 종물에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 독립한 부동산은 종물이 될 수 없다.
- ② 주물을 처분할 때 당사자의 특약으로 종물만을 별도로 처분할 수도 있다.
- ③ 주물 위에 설정된 저당권의 효력은, 법률의 규정 또는 다른 약정이 없으면, 설정 후의 종물에까지 미치지 않는다.

- ④ 구분건물의 전유부분에 대한 가압류 결정의 효력은 특별한 사정이 없는 한 그 대지권에 미치지 않는다.
- ⑤ 권리 상호간에는 주물과 종물의 법리가 적용되지 않는다.

해설

- ② ‘종물은 주물의 처분에 따른다(제100조 제2항)’는 규정은 임의규정이다. 따라서 당사자의 특약으로 달리 약정할 수 있다.
- ① 주물과 종물 모두 부동산이든 동산이든 불문한다.
- ③ 주물 위에 저당권이 설정된 경우에는 그 저당권의 효력은 저당권설정 전후를 불문하고 종물에도 그 효력이 미친다(제358조 참조).
- ④ 구분건물의 전유부분에 대한 소유권보존등기만 경료되고 대지지분에 대한 등기가 경료되기 전에 전유부분만에 대해 내려진 가압류결정의 효력은, 대지사용권의 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 종물 내지 종된 권리인 그 대지권에까지 미친다(대법원 2006.10.26. 2006다29020).
- ⑤ 종물이론은 권리 상호간과 물건과 권리 간에도 준용될 수 있다. 정답: ②

06 물건에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산은 언제나 종물이 될 수 없다.
- ② 주물 자체의 효용과 직접적인 관계가 없는 물건도 종물이 될 수 있다.
- ③ 물건의 용법에 의하여 수취하는 산출물은 법정과실에 해당한다.
- ④ 천연과실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득함이 원칙이다.
- ⑤ 건물의 개수는 공부상의 등록뿐만 아니라 거래관념에 따라 제반사정을 참작하여 결정한다.

해설

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 주물과 종물 모두 부동산이든 동산이든 불문한다.
- ② 종물은 주물의 구성부분이 아니고, 주물의 경제적 효용을 돕기 위하여 주물에 부속된 물건이므로 독립한 물건이어야 한다.
- ③ 천연과실이란 물건의 용법에 따라 산출되는 산출물을 말한다(제101조 제1항).
- ④ 법정과실은 이를 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다(제102조 제2항). 정답: ⑤

07 주물과 종물에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 어떤 물건이 주물의 소유자나 이용자의 상용에 공여되고 있다면 주물의 효용과 직접 관계 없어도 종물이다.
- ② 주유소의 지하에 매설된 유류저장탱크는 주유소의 종물이다.
- ③ 종물은 주물의 처분에 따라야 하므로 종물만의 처분을 당사자가 임의로 정할 수는 없다.
- ④ 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다.
- ⑤ 법률의 규정 또는 다른 약정이 없으면 주물에 설정된 저당권은 저당권설정 이후의 종물에 그 효력이 미치지 않는다.

해설

- ④ 저당권의 효력이 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다는 민법 제358조 본문을 유추하여 보면, 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다. 따라서 건물에 대한 저당권이 실행되어 경락인이 그 건물의 소유권을 취득하였다면, 경락 후 건물을 철거한다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 경락인은 건물소유를 위한 지상권도 등기 없이 당연히 취득하게 되고, 경락인이 건물을 제3자에게 양도한 때에는, 특별한 사정이 없는 한 건물과 함께 종된 권리인 지상권도 양도한 것으로 본다(대법원 1996.04.26. 95다52864).
- ① 어느 건물이 주된 건물의 종물이기 위해서는 주물의 상용에 이바지되어야 하는 관계가 있어야 하는 바, 여기에서 주물의 상용에 이바지한다 함은 주물 그 자체의 경제적 효용을 다하게 하는 것을 말하는 것이며, 주물이 소유자나 이용자의 상용에 공여되고 있더라도 주물 그 자체의 효용과는 직접 관계없는 물건은 종물이 아니다(대법원 1994.06.10. 94다11606).
- ② 주유소의 지하에 매설된 유류저장탱크를 토지로부터 분리하는데 과다한 비용이 들고 이를 분리하여 발굴할 경우 그 경제적 가치가 현저히 감소할 것이 분명하다는 이유로, 그 유류저장탱크는 토지에 부합된 것으로 본다. 따라서 종물이 아니다(대법원 1995.06.29. 94다6345).
- ③ '종물은 주물의 처분에 따른다(제100조 제2항)'는 규정은 임의규정이다. 따라서 당사자의 특약으로 달리 약정할 수 있다.
- ⑤ 주물 위에 저당권이 설정된 경우에는 그 저당권의 효력은 저당권설정 전후를 불문하고 종물에도 그 효력이 미친다(제358조 참조). 정답: ④

08 물건에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 완공된 신축 건물이라도 보존등기 전에는 소유권이 인정되지 않는다.
- ② 1필의 토지 일부에는 지상권을 설정할 수 없다.
- ③ 등기된 입목의 소유자는 입목을 토지와 분리하여 양도할 수 있고 이를 저당권의 목적으로 할 수 있다.
- ④ 권한 없이 타인의 토지에 농작물을 심은 경우, 수확기에 이른 농작물의 소유권은 토지 소유자에게 귀속된다.
- ⑤ 주유소의 주유기는 주유소 건물에 부합되어 종물로 볼 수 없다.

해설

- ③ 등기된 수목의 집단은 독립하여 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있다(입목에 관한 법률 제3조).
- ① 신축건물의 소유권의 취득은 등기를 요하지 아니한다.
- ② 용익물권은 1필의 일부위에도 설정될 수 있다.
- ④ 권한 없이 타인의 토지에 경작·재배한 경우에 명인방법을 갖추 필요 없이 성숙한 농작물의 소유권은 언제나 그 경작자에 있다(대법원 1978.3.14. 77다2396).
- ⑤ 주유소의 주유기는 계속해서 주유소 건물 자체의 경제적 효용을 다하게 하는 작용을 하고 있으므로 주유소건물의 상용에 공하기 위하여 부속시킨 종물이다(대법원 1995.06.29. 94다6345).

정답: ③

09 다음 중 원칙적으로 원물로부터 산출된 천연과실의 소유권을 가질 수 있는 자는? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 원물에 비용을 지출하여 원물소유자로부터 비용을 상환 받을 때까지 적법하게 원물을 유치하고 있는 자
- ㉡ 저당권을 실행하기 위하여 원물의 경매를 신청한 저당권자
- ㉢ 원물을 매도하였으나 인도하기 전의 매도인
- ㉣ 원물인 토지의 지상권을 가지는 자
- ㉤ 원물을 임차인에게 임대한 임대인

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉠, ㉣
 ④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉣, ㉤

해설

- ㉠, ㉡ 유치권자와 질권자는 원칙적으로 수취권자가 될 수 없으나 예외적으로 담보물에서 파생되는 과실로서 변제에 총당할 수 있다. 그리고 저당권의 효력도 목적물의 과실에는 원칙적으로 미치지 아니하나 압류 후에는 그 효력이 미친다. 따라서 설문의 ㉠과 ㉡은 원칙에 따라 판단하면 수취권자가 될 수 없다.
 ㉤ 원물을 임차인에게 임대한 경우 임차인에게 과실수취권이 있다. 정답: ④

10 주물과 종물, 원물과 과실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 종물은 독립된 물건이어야 하지만 반드시 동산에 국한되지는 않는다.
- ② 주유소와 주유기는 주물·종물관계에 있다.
- ③ 백화점 건물과 그 지하층에 설치된 전화교환설비는 주물·종물관계에 있다.
- ④ 매매목적물이 매도인의 이행지체로 인도되지 않고 있고 그에 따라 매수인이 대금을 완제하지 않고 있다면, 특별한 사정이 없는 한 과실은 매수인에게 귀속한다.
- ⑤ 종물은 주물의 처분에 따른다는 민법규정은 임의규정이다.

해설

- ④ 매매목적물이 매도인의 이행지체로 인도되지 않고 있더라도 매수인이 대금을 지급하지 않고 있다면, 특별한 사정이 없는 한 과실은 매도인에게 귀속한다. 정답: ④

11 권리의 객체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 주물과 종물의 법리는 물건 상호간에 적용되고, 권리 상호간에는 적용되지 않는다.
- ② 천연과실은 그 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에게 속한다.
- ③ 독립된 부동산으로서의 건물이라고 하기 위하여는 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 갖추어져야 한다.

- ④ 종물은 주물의 처분에 따른다는 민법규정은 임의규정이다.
- ⑤ 명인방법을 갖춘 수목의 경우에는 토지와 독립한 거래의 객체가 된다.

해설

① 종물이론은 권리와 권리, 물건과 권리 간에도 준용될 수 있다. 정답: ①

12 부동산에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 우리 민법상 건물은 토지와 별개의 부동산이며, 이로 인해 법정지상권제도가 존재한다.
- ② 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 토지와는 별개의 부동산이지만 소유권 이외의 다른 물권의 객체가 되지는 못한다.
- ③ 1년생 농작물은 비록 권원 없이 타인의 토지에서 경작된 경우에도 경작자가 소유권을 갖지만 최소한 명인방법은 갖추어야 한다.
- ④ 경매대상인 토지를 평가함에 있어서 등기된 입목은 그 평가에 포함되지 않는다.
- ⑤ 건물의 개수는 건물의 물리적 구조뿐만 아니라 거래관념을 고려하여 결정하여야 한다.

해설

③ 토지에 경작·재배하고 있는 농산물은 토지의 일부이다. 다만, 정당한 권원에 의하여 타인의 토지에서 경작·재배한 농작물은 토지에 부합하지 않고 토지와는 독립된 물건으로 다루어진다(제256조 단서). 그런데 판례는 아무런 권원 없이 타인의 토지에 경작·재배한 경우에 명인방법을 갖추 필요 없이 성숙한 농작물의 소유권은 언제나 그 경작자에 있다고 한다(대법원 1978.3.14. 77다2396).

정답: ③

13 과실을 수취할 수 있는 자를 모두 고른 것은?

- ㉠ 질물의 과실에 대한 질권자
- ㉡ 유치물의 과실에 대한 유치권자
- ㉢ 점유물의 과실에 대한 선의의 점유자
- ㉤ 토지전세권에서 토지의 과실에 대한 전세권설정자

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉢, ㉤
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

해설

㉤ 토지의 과실에 대하여는 전세권자에게 과실수취권이 있다. 정답: ③

14 물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 주물의 구성부분은 종물이 될 수 없다.
- ② 1필의 토지의 일부는 분필절차를 거치지 않는 한 용익물권의 객체가 될 수 없다.
- ③ 국립공원의 입장료는 법정과실이 아니다.
- ④ 주물과 장소적 밀접성이 인정되더라도 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건은 종물이 아니다.
- ⑤ 저당권 설정행위에 “저당권의 효력이 종물에 미치지 않는다”는 약정이 있는 경우, 이를 등기하지 않으면 그 약정으로써 제3자에게 대항할 수 없다.

해설

- ② 용익물권은 1필의 토지 일부 위에도 설정될 수 있다.
- ①④ 종물은 주물의 구성부분이 아니고, 주물의 경제적 효용을 돕기 위하여 주물에 부속된 물건이므로 독립한 물건이어야 한다.
- ③ 국립공원의 입장료는 토지의 사용대가라는 민법상 과실이 아니라 수익자 부담의 원칙에 따라 국립공원의 유지·관리비용의 일부를 국립공원 입장객에게 부담시키고자 하는 것이어서 토지의 소유권이나 그에 기한 과실수취권과는 아무런 관련이 없다(대법원 2001. 12.28. 2000다27749).
- ⑤ 타당한 기술이다. 정답: ②

15 물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 주물 소유자의 사용에 공여되는 물건이라도 주물 자체의 효용과 직접 관계가 없으면 종물이 아니다.
- ② 「입목에 관한 법률」에 의하여 소유권보존등기를 한 수목의 집단은 저당권의 객체가 된다.
- ③ 종물과 주물의 관계에 관한 법리는 권리 상호간에도 적용될 수 있다.
- ④ 분필절차를 거치지 않은 1필의 토지의 일부에 대해서도 저당권을 설정할 수 있다.
- ⑤ 저당권의 효력은 저당부동산의 종물에 미치므로 경매를 통하여 저당부동산의 소유권을 취득한 자는 특별한 사정이 없는 한 종물의 소유권을 취득한다.

해설

- ④ 저당권은 1필의 토지 일부 또는 1동 건물의 일부위에는 설정할 수 없다. 정답: ④

16 물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 주물에 대한 압류의 효력은 특별한 사정이 없는 한 종물에는 미치지 않는다.
- ② 사람의 유골은 매장 · 관리의 대상이 될 수 있는 유체물이다.
- ③ 전기 기타 관리할 수 있는 자연력은 물건이다.
- ④ 법정과실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득함이 원칙이다.
- ⑤ 주물만 처분하고 종물은 처분하지 않기로 하는 특약은 유효하다.

해설

- ① 종물은 주물의 처분에 따른다(제100조 제2항). 따라서 주물에 대한 압류의 효력은 특별한 사정이 없는 한 종물에도 미친다. 정답: ①

법률행위

제1절 법률행위 일반론

1 기본문제

01 권리의 원시취득 사유에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- | | |
|---------------|------------------|
| ㉠ 무주물인 동산의 선점 | ㉡ 피상속인 사망에 의한 상속 |
| ㉢ 회사의 합병 | ㉣ 시효취득 |
| ㉤ 건물의 신축 | |

- | | |
|-----------|-----------|
| ① ㉠, ㉡ | ② ㉡, ㉢ |
| ③ ㉢, ㉣ | ④ ㉡, ㉢, ㉣ |
| ⑤ ㉢, ㉣, ㉤ | |

해설

◎ 권리변동의 모습

(1) 권리의 발생

- ㉠ 원시취득(절대적 발생) : 선점, 습득, 시효취득 등
- ㉡ 승계취득(상대적 발생)
 - └ ㉢ 이전적 승계 : 매매, 교환 등에 의한 승계
 - └ ㉣ 설정적 승계 : 지상권설정, 저당권설정 등
 - └ ㉤ 특정승계 : 매매, 교환, 증여 등에 의한 승계
 - └ ㉥ 포괄승계 : 상속, 포괄유증, 회사의 합병 등

(2) 권리의 변경

- ㉠ 성질적 변경 : 물건의 인도를 목적으로 하는 채권이 손해배상채권으로 변하는 것
- ㉡ 수량적 변경 : 제한물권의 설정이나 소멸
- ㉢ 작용의 변경 : 저당권의 순위의 변경

(3) 권리의 소멸

- ㉠ 절대적 소멸 : 목적물의 멸실에 의한 권리의 소멸
- ㉡ 상대적 소멸 : 권리주체의 변경
- ㉢ 피상속인 사망에 의한 상속과 ㉣ 회사의 합병은 원시취득이 아닌 타인의 권리를 기초로 하여 권리를 취득하는 승계취득으로서 포괄승계에 해당한다. 정답: ②

02 법률사실에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사무관리는 순수사실행위이다.
- ② 채무자의 의사는 관념적 용태이다.
- ③ 채무자의 승인은 의사의 통지이다.
- ④ 채권양도의 통지는 관념의 통지이다.
- ⑤ 정당한 대리인이라는 신뢰는 의사적 용태이다.

해설

◎ 법률사실의 체계

용 태	외 부 적 용 태	적 법 행 위	의 사 표 시			청약, 승낙, 추인, 동의 등
			준 법 률 행 위	표 현 위	의사의 통지	각종의 최고나 거절
					관념의 통지	사원총회소집의 통지, 대리권수여의 통지, 채무의 승인, 공탁의 통지, 채권양도의 통지, 승낙연착의 통지, 채무의 승인 등
					감정의 표시	망은행위에 대한 용서, 이혼사유에 대한 용서 등
			비표현 행 위	순수사실행위	매장물발견, 가공, 주소의 설정 등	
				혼합사실행위	유실물습득, 선점, 물건의 인도, 부부의 동거, 사무관리 등	
		위 법 위	불 법 행 위		불법행위	
			채무불이행		이행지체, 이행불능, 불완전이행 등	

정답: ④

제5장
기본문제

03 다음은 단독행위에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 시효이익의 포기는 상대방 있는 단독행위이다.
- ② 채무면제는 단독행위인 준물권행위이다.
- ③ 타인의 권리·의무의 변동을 목적으로 하지 않는 단독행위도 있다.
- ④ 자기의 소유물이 아닌 물건에 관하여도 의무부담행위인 매매계약을 유효하게 체결할 수 있다.
- ⑤ 단독행위에 대해서는 어떠한 경우에도 조건 또는 기한을 붙일 수 없다.

해설

- ⑤ 단독행위에는 원칙적으로 조건 등을 붙일 수 없다. 그러나 상대방의 동의를 얻거나 상대방을 유리하게 하는 경우에는 예외적으로 조건을 붙일 수 있다. 그러므로 채무의 면제, 유증의 경우에는 조건을 붙일 수 있다.
- ① 소유권 및 점유권의 포기는 상대방 없는 단독행위이고, 제한물권의 포기는 그 포기에 의하여 직접이익을 얻는 자(보통은 소유자)에 대하여 하여야 하는 상대방 있는 단독행위이다. 유언이나 재단법인의 설립행위, 권리의 포기는 상대방 없는 단독행위에 속한다.
- ③ 상대방의 권리·의무의 변동을 목적으로 하지 않는 단독행위도 있을 수 있는데 상대방 없는 단독행위 등을 들 수 있다. 정답: ⑤

04

법률행위의 분류와 그에 해당하는 예가 올바르게 연결된 것은?

- ① 상대방 없는 단독행위 - 유언 ② 상대방 있는 단독행위 - 증여
- ③ 불요식행위 - 법인 설립 ④ 준물권행위 - 저당권 설정
- ⑤ 물권행위 - 매매

해설

- ① 유언은 유언자의 사망시에 효력이 생기고 어떤 특정의 상대방에게 유언의 의사표시가 도달되어야 효력이 생기는 것은 아니므로 상대방 없는 단독행위이다.
 ②③ 증여는 계약이며, 법인 설립은 정관을 서면으로 작성하여야 하는 요식행위이다.
 ④⑤ 저당권 설정은 물권행위이며, 매매는 의무부담행위이다.

◎ 법률행위의 기본적 분류

표 준	세 분	내 용	예
의 사 표 시	단독행위	상대방 있는 단독행위	동의, 철회, 채무면제, 상계, 추인, 해지, 해제, 취소 등
		상대방 없는 단독행위	권리의 포기, 재단법인의 설립행위, 유언 등
	계 약	매매, 교환, 임대차, 사용대차, 증여, 소비대차, 위임, 도급, 화해, 조합, 현상광고 등과 물권의 설정계약, 가족법상의 신분계약	
	합동행위	사단법인의 설립행위	
법 률 효 과	채권행위	채권을 발생시키며 이행의 문제를 남김(원인, 약속 : 14종의 계약)	
	물권행위	물권변동이 일어나며 더 이상의 이행의 문제는 없음(결과, 이행 : 소유권이전, 전세권설정 등).	
	준물권행위	물권 이외의 권리의 종국적 변동을 일으키고 이행의 문제는 없음(채권양도, 채무면제 등).	

정답: ①

다음 연결 중 틀린 것은?

- ① 단독행위 - 유증 ② 요식행위 - 사단법인설립행위
③ 계약 - 사인증여 ④ 합동행위 - 재단법인설립행위
⑤ 무상행위 - 사용대차

해설

◎ 법률행위의 기타의 분류

요식행위	사단법인·재단법인 설립행위, 유언, 혼인, 입양, 어음·수표행위
사후행위	사인증여·유언 등
무상행위	증여·사용대차 등
보조행위	동의·추인·대리권수여행위 등
종된행위	저당권설정계약은 채권계약에 종된 행위, 보증계약은 주채권계약에 종된 행위, 부부재산계약은 혼인에 종된 행위
무인행위	어음행위·수표행위
비출연행위	소유권의 포기, 대리권의 수여행위

④의 재단법인의 설립행위는 상대방 없는 단독행위이다. 정답: ④

상대방 없는 단독행위에 해당하는 것은?

[2022' 공인중개사]

- ① 착오로 인한 계약의 취소
- ② 무권대리로 체결된 계약에 대한 본인의 추인
- ③ 미성년자의 법률행위에 대한 법정대리인의 동의
- ④ 손자에 대한 부동산의 유증
- ⑤ 이행불능으로 인한 계약의 해제

해설

④ 유증은 상대방 없는 단독행위이다. 정답: ④

07

- ### ① 공유지분의 포기

- ## ② 무권대리행위의 추인

- ### ③ 상계의 의사표시

- ④ 취득시효 이익의 포기

- ## ⑤ 재단법인의 설립행위

해설

⑤④ 재단법인의 설립행위는 상대방 없는 단독행위이다. 정답: ⑤

08

- ### ① 대리행위에 있어서의 대리권의 존재

- ② 유언에 있어서의 유언자의 사망

- ③ 기한부 법률행위에 있어서의 기한의 도래

- ④ 요물계약(要物契約)에 있어서의 물건의 인도

- ⑤ 조건부 법률행위에 있어서의 조건의 성취

해설

◎ 법률행위의 성립·효력요건

구 분	성 립 요 건	효 력 요 건
일 반 요 건	당사자	권리능력, 의사능력, 행위능력을 가질 것
	목 적	가능, 적법, 사회적 타당성, 확정할 수 있을 것
	의사표시	의사와 표시가 일치하고 의사표시에 하자가 없을 것
특 별 요 건	• 법인 : 정관작성 • 혼인 : 신고 • 유언 : 증서의 작성 • 요물계약 : 물건의 인도	• 대리 : 대리권의 존재 • 조건 : 조건의 성취 • 기한 : 기한의 도래 • 유언 : 유언자의 사망

정답: ④

09

- ① 효력규정인 강행법규에 위반하는 법률행위는 무효이다.

- ② 법률행위의 일부가 무효인 경우에는 원칙적으로 그 전부를 무효로 한다.

- ③ 법률행위의 목적은 법률행위시에 반드시 확정되어 있을 필요는 없다.

- ④ 법률행위의 목적이 물리적으로 가능하더라도 사회통념상 실현할 수 없으면 무효이다.

- ⑤ 법률행위의 목적이 성립 당시에는 가능하였지만 그 이행 전에 불가능하게 된 경우, 그 법률행위는 무효가 된다.

해설

⑤ 법률행위의 목적이 성립 당시에는 가능하였지만 그 이행 전에 불가능하게 된 경우는 후발적 불능으로서 법률행위는 유효하다. 정답: ⑤

10 강행법규라고 볼 수 없는 것은?

- ① 권리능력·행위능력·법인제도 등에 관한 규정
- ② 소멸시효에 관한 규정
- ③ 친족상속편에서 볼 수 있는 가족관계질서의 유지에 관한 규정
- ④ 물건편에서 볼 수 있는 사회일반의 이해에 직접 중요한 영향을 미치는 규정
- ⑤ 법정·천연과실의 귀속에 관한 규정

해설

⑤ 과실의 귀속을 정한 규정(제102조 제1항)은 임의규정에 해당한다. 정답: ⑤

11 법률행위의 목적에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 법률행위의 목적은 있어도 법률행위의 목적물은 존재하지 않는 경우가 있다.
- ② 법률행위의 목적은 법률행위시에 확정되거나 확정할 수 있어야 한다.
- ③ 법률행위 목적의 가능·불능의 판단은 그 시대의 사회관념에 의하여 결정된다.
- ④ 법률행위의 목적의 일부가 불능인 때에는 원칙적으로 그 부분만 불능으로 한다.
- ⑤ 법률행위의 목적이 임의법규에 위반되더라도 그 법률행위는 유효하다.

해설

④ 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다(제137조).

정답: ④

12 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하여 무효인 약정에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 영리를 목적으로 윤락행위를 하도록 권유·유인·알선 또는 강요하는 자가 영업상 관계 있는 윤락행위를 한 자에 대하여 선불금을 지급하기로 하는 약정
- ㉡ 부정행위를 용서받은 대가로 처에게 부동산을 양도하되 부부관계가 유지되는 동안에는 처가 임의로 처분할 수 없다는 제한을 붙인 약정
- ㉢ 불륜관계를 단절하면서 그 동안의 희생을 배상하고 장래 생활대책을 마련해 준다는 뜻에서 금원을 지급하기로 하는 약정
- ㉣ 해외파견된 근로자가 귀국일로부터 일정기간 소속회사에 근무하여야 한다는 사규나 약정
- ㉤ 공무원의 직무에 관하여 청탁하고 그 보수로 돈을 지급할 것을 내용으로 한 약정

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉣

④ ㉢, ㉤

⑤ ㉡, ㉤

해설

- ㉠ 선량한 풍속 사회질서에 위반하여 무효이다(제103조).
- ㉡ 부정행위를 용서받는 대가로 손해배상을 함과 아울러 가정에 충실하겠다는 서약의 취지에서 처에게 부동산을 양도하되, 부부관계가 유지되는 동안에는 처가 임의로 처분할 수 없다는 제한을 붙인 약정은 유효하다(대법원 1992.10.27, 92므204·92므211).
- ㉢ 첩 계약은 처의 동의 유무와 관계없이 무효이다(대법원 1967.10.6, 67다1134). 다만, 불륜관계의 지속을 위해서가 아닌, 첩의 생계유지비 및 출생한 자녀양육비를 지급하기로 하는 계약 또는 불륜관계의 단절을 목적으로 한 금전지급약정은 유효하다(대법원 1980.6.24, 80다458).
- ㉣ 해외에 파견된 근로자가 귀국 후 3년간 근무해야 하고 이를 위반시 해외파견에 소요된 경비를 배상해야 한다는 내규는 유효하다(대법원 1982.6.22, 82다카90).
- ㉤ 정의관념에 반하는 행위로서 무효이다. 정답: ㉡

13

甲의 건물을 乙에게 양도할 것을 합의하고 乙이 소유권이전등기를 받기 전에 甲은 사정을 아는 丙에게 이중양도하고 등기를 하여 주었다. 이 경우의 법률관계에 대한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 甲과 丙의 매매는 이중매매이므로 예외없이 무효가 된다.
- ㉡ 부동산물권의 변동은 합의와 등기가 갖추어져야 하므로 원칙적으로 丙만이 소유권을 취득한다.
- ㉢ 양도합의에 의하여 乙이 건물소유권을 취득하지만 등기 없이는 제3자에게 대항할 수 없어 丙이 결국 소유권을 취득한다.
- ㉣ 甲과 乙 사이의 합의로 건물의 소유권이 이미 乙에게 이전되어서 甲이 소유권을 丙에게 이전하는 것은 원칙적으로 불가능하다.
- ㉤ 丙이 甲의 배임 또는 횡령행위에 적극 가담하지 않더라도 이중양도행위는 무효가 된다.

해설

- ㉡ 丙의 이중매매행위가 사회질서에 반하지 않는 한 무효가 아니며, 따라서 甲과 丙의 이중매매행위는 유효하며, 소유권이전등기를 한 이상 丙이 소유자이다. 이중매매는 원칙적으로 유효하며 제2의 법률행위는 매매에 국한하지 않는다.
- ㉠⑤ 이중매매가 제103조에 위배되기 위해서는 丙이 적극적으로 甲의 배임행위에 가담하였어야 한다.
- ㉢④ 형식주의의 법제 하에서는 원칙상 등기하지 않은 乙이 건물의 소유권을 취득할 수는 없다.

정답: ㉡

14 부동산 이중매매에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2021' 공인중개사]

- ① 반사회적 법률행위에 해당하는 제2매매계약에 기초하여 제2매수인으로부터 그 부동산을 매수하여 등기한 선의의 제3자는 제2매매계약의 유효를 주장할 수 있다.
- ② 제2매수인이 이중매매사실을 알았다는 사정만으로 제2매매계약을 반사회적 법률행위에 해당한다고 볼 수 없다.
- ③ 특별한 사정이 없는 한, 먼저 등기한 매수인이 목적 부동산의 소유권을 취득한다.
- ④ 반사회적 법률행위에 해당하는 이중매매의 경우, 제1매수인은 제2매수인에 대하여 직접 소유권이전등기말소를 청구할 수 없다.
- ⑤ 부동산 이중매매의 법리는 이중으로 부동산임대차계약이 체결되는 경우에도 적용될 수 있다.

해설

- ① 부동산의 이중매매가 반사회적 법률행위에 해당하는 경우에 이중매매계약은 절대적으로 무효이므로, 당해 부동산을 제2매수인으로부터 다시 취득한 제3자는 설사 제2매수인이 당해 부동산의 소유권을 유효하게 취득한 것으로 믿었더라도 이중매매계약이 유효하다고 주장할 수 없다. 정답: ①

15 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부담 없는 증여계약은 불공정한 법률행위에 해당하는지의 여부를 논의할 수 있는 성질의 것이 아니다.
- ② 불공정한 법률행위로 무효를 주장하기 위해서는 공박·경솔·무경험이라는 요건을 모두 갖추어야 한다.
- ③ 공박·경솔·무경험의 증명책임은 무효를 주장하는 자의 상대방에게 있다.
- ④ 불공정한 법률행위로서 무효가 된 경우에는 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용될 수 없다.
- ⑤ 불공정한 법률행위는 폭리행위자가 상대방의 공박·경솔·무경험과 같은 사정을 알면서 그것을 이용하려는 의사를 요하지 않는다.

해설

- ① '증여계약'과 같이 아무런 대가 관계없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위(무상계약)는 그 공정성 여부를 논의할 수 있는 성질의 법률행위가 아니다(대법원 2002.2.11, 99다56833).
- ② 공박·경솔·무경험은 모두 구비하여야 하는 것이 아니고 이 중 어느 하나만 갖추면 된다(대법원 1998.3.13, 97다51506).
- ③ 불공정한 법률행위임을 이유로 무효를 주장하는 자는 스스로 객관적 요건과 주관적 요건의 존재를 모두 주장·증명하여야 한다.
- ④ 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용되어 당사자 쌍방이 위와 같은 무효를 알았더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립할 수 있다(대법원 2011.04.28. 선고 2010다106702).
- ⑤ 불공정한 법률행위가 성립하려면 폭리행위, 즉 폭리행위자가 상대방의 공박·경솔·무경험과 같은 사정을 알면서 그것을 이용하려는 의사가 필요하다. 정답: ①

16 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2021' 변리사]

- ① 불공정한 법률행위에도 무효행위 전환의 법리가 적용될 수 있다.
- ② 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에도 추인하면 유효로 된다.
- ③ 불공정한 법률행위에 관한 규정은 부담 없는 증여의 경우에도 적용된다.
- ④ 경매에서 경매부동산의 매각대금이 시가에 비하여 현저히 저렴한 경우, 불공정한 법률행위에 해당하여 무효이다.
- ⑤ 법률행위가 현저하게 공정을 잃은 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 법률행위는 공박·경솔·무경험으로 인해 이루어진 것으로 추정된다.

해설

- ① 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용될 수 있다(대법원 2011.04.28. 선고 2010다106702).
- ② 불공정한 법률행위는 절대적 무효에 해당하여 추인이 인정되지 않는다.
- ③ '증여계약'과 같이 아무런 대가 관계없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위(무상계약)는 그 공정성 여부를 논의할 수 있는 성질의 법률행위가 아니다(대법원 2002.2.11. 99다56833). 즉 불공정한 법률행위에 관한 규정은 적용되지 않는다.
- ④ 경매에 있어서는 불공정한 법률행위 또는 채무자에게 불리한 약정에 관한 것으로서 효력이 없다는 민법 제104조, 제608조는 적용될 여지가 없다(대법원 1980.3.21. 80마77).
- ⑤ 불공정한 법률행위임을 이유로 무효를 주장하는 자는 스스로 객관적 요건과 주관적 요건의 존재를 모두 주장·증명하여야 한다. 정답: ①

17 불공정한 법률행위에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 기부행위와 같이 대가 없는 행위에 대해서는 적용되지 않는다.
- ② 무경험이란 어느 특정영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 의미한다.
- ③ 폭리자에게 폭리행위의 악의가 없었다면 불공정한 법률행위는 성립하지 않는다.
- ④ 채권포기행위와 같은 단독행위에는 적용되지 않는다.
- ⑤ 법률행위의 무효를 주장하는 자가 필요한 요건사실을 주장·증명하여야 한다.

해설

- ④ 단독행위에도 제104조는 적용이 있다. 즉, 가정부인이 공박상태와 경험부족으로 남편이 구속된 상태에서 구속된 남편을 석방구제하기 위하여 남편의 대리인으로서 남편의 채권을 포기하는 행위를 한 행위는 불공정한 법률행위에 해당한다(대법원 1975.5.13., 75다92). 정답: ④

18 다음 불공정한 법률행위에 관한 판례 중 틀린 것은?

- ① 민법 제104조의 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 당사자 일방의 공박·경솔·무경험은 모두 구비하여야 하는 요건이 아니고 그 중 어느 하나만 갖추어져도 충분하다.
- ② 기부행위와 같이 아무런 대가관계 없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위는 그 공정성 여부를 논의할 수 있는 성질의 법률행위가 아니다.
- ③ 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 있는 경우에는 그것이 곧 당사자의 공박·경솔 또는 무경험에 기인하는 것으로 추정된다.
- ④ 판례는 외상매출채권의 포기와 같은 단독행위에도 민법 제104조가 적용될 수 있다는 입장이다.
- ⑤ 불공정한 법률행위는 약자적 지위에 있는 자가 공박·경솔 또는 무경험의 상태에 있어야 하며, 또한 상대방에게 위와 같은 피해 당사자측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사가 필요하다는 것이 판례의 입장이다.

해설

- ③ 법률행위가 현저하게 공정을 잃었다고 하여 곧 그것이 공박, 경솔하게 이루어진 것으로 추정되지 아니하므로 본조의 불공정한 법률행위의 법리가 적용되려면 그 주장하는 측에서 공박·경솔 또는 무경험으로 인하였음을 증명하여야 한다(대법원 1993.10.12. 93다19924).
- ② 대법원 1993.3.23. 92다52238
- ④ 사회적 경험이 부족한 가정부인이 경제적, 정신적 공박 상태 하에서 구속된 자기남편을 석방, 구제하는 데에는 위 수표의 회수가 필요할 것이라는 일념에서 회사에 대한 물품잔대금 채권이 얼마 인지조차 확실치 모르면서 보관 중이던 남편의 인감을 이용하여 남편을 대리하여 위임장과 포기서를 작성하여 준 채권포기행위는 거래관계에 있어서 현저하게 균형을 잃은 행위로서 사회적 정의에 반하는 불공정한 불법행위로 보는 것이 상당하다(대법원 1975.5.13. 75다92). 정답: ③

19 매도인 甲과 매수인 乙은 경기도 양평 소재 A토지를 매매의 목적으로 삼았다. A토지에 관하여 매매 목적물로 한다는 쌍방 당사자의 합의가 있었기 때문이다. 그러나 그 목적물의 지번 등에 관하여 착오를 일으켜 계약서상에는 A토지와 인접한 B토지를 매매목적물로 표시, 매매계약을 체결하였다. 그 후 乙은 B토지에 관하여 소유권이전등기를 경료하고, 이를 다시 丙에게 처분하여 등기까지 경료케 하였다. 다음 중 타당한 설명은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 의사의 합치가 없으므로 매매계약은 성립할 수 없다.
- ② 매매계약은 계약서상에 표시된 B토지에 관하여 성립한다.
- ③ 丙은 선의인 한 민법 제109조 제2항에 의거 유효하게 소유권을 취득한다.
- ④ B토지에 관한 乙의 이전등기는 무효이므로 丙은 소유권을 취득할 수 없다.
- ⑤ 丙은 공신의 원칙에 의거, 선의인 한 유효하게 소유권을 취득한다.

해설

- ①② 부동산의 매매계약에 있어 쌍방 당사자가 모두 특정의 A토지를 계약의 목적으로 삼았으나 그 목적물의 지번 등에 관하여 착오를 일으켜 계약을 체결함에 있어서는 계약서상 그 목적물을 A토지와는 별개인 B토지로 표시하였다 하더라도, A토지에 관하여 이를 매매의 목적으로 한다는 쌍방 당사자의 의사합치가 있는 이상 위 매매 계약은 A토지에 관하여 성립한 것으로 보아야 할 것이고(이른바 오표시무해의 원칙), B토지에 관하여 매매계약이 체결된 것으로 보아서는 아니 될 것이며, 만일 B토지에 관하여 위 매매계약을 원인으로 하여 매수인 명의로 소유권이전등기가 경료되었다면 이는 원인없이 경료된 것으로서 무효이다(대법원 1993.10.26. 93다2629,2636). A토지에 관하여는 매매계약은 성립하였으나 등기가 없으므로 물건변동이 일어나지 않고, B토지에 관하여는 그 등기가 원인없이 행해져서 무효이므로 물건변동이 일어나지 않는다. 따라서 丙은 소유권을 취득하지 못한다.
- ③ 매매계약은 자연적 해석의 결과, A토지에 관하여 성립하였으므로 착오의 문제는 발생하지 않는다.
- ⑤ 부동산의 경우에는 공신의 원칙이 적용되지 않는다. 정답: ④

20 법률행위해석의 기준 순서로 정당한 것은?

- ① 목적 - 관습 - 임의법규 - 조리
- ② 의도 - 임의법규 - 조리 - 관습
- ③ 강행법규 - 임의법규 - 관습 - 조리
- ④ 강행법규 - 임의법규 - 관습법 - 조리
- ⑤ 목적 - 관습법 - 임의법규 - 조리

해설

- ① 법률행위의 해석은 법률행위의 목적 내지 내용을 명확하게 하는 것으로 당사자가 의도하는 목적, 사실인 관습, 임의법규, 조리(신의성실의 원칙)를 그 해석기준으로 한다(제106조). 정답: ①

21 법률행위의 해석에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법률행위의 해석은 문구에 구애받지 않고 어디까지나 당사자가 그 표시행위에 부여한 내심적 의사에 따라야 한다.
- ② 당사자가 모두 X토지를 매매하기로 합의하였으나 그 지번을 착각하여 계약서에 Y토지로 표시한 경우 Y토지에 대한 매매계약이 성립한다.
- ③ 매매계약서상의 “계약사항에 대한 이의가 생겼을 때에는 매도인의 해석에 따른다”는 조항은 법원의 법률행위 해석권을 구속하지 않는다.
- ④ 당사자의 의사가 명확한 경우에도 사실인 관습이 우선하여 법률행위 내용을 확정하는 기준이 된다.
- ⑤ 관습법은 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행으로서 법률행위 당사자의 의사를 보충함에 그친다.

해설

- ① 법률행위의 해석이란 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 서면에 사용된 문구에 구애받을 것은 아니지만 어디까지나 당사자의 내심적 의사의 여하에 관계없이 그 서면의 기재 내용에 의하여 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 합리적으로 해석하여야 하는 것이다(대법원 1994.3.25. 93다32668).
- ② 당사자가 모두 X토지를 매매하기로 합의하였으나 그 지번을 착각하여 계약서에 Y토지로 표시한 경우 오표시무해의 원칙에 따라 Y토지가 아닌 X토지에 대해 매매계약이 성립한다.
- ④ 당사자의 의사(목적)가 명확한 경우 당사자 의사가 사실인 관습에 우선하여 법률행위 내용을 확정하는 기준이 된다.
- ⑤ 관습법이 아닌 사실인 관습이 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행으로서 법률행위 당사자의 의사를 보충함에 그친다. 정답: ③

01 물건의 승계취득에 해당하는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 무주물 선점에 의한 소유권 취득 ② 상속에 의한 소유권 취득
- ③ 환지처분에 의한 국가의 소유권 취득 ④ 건물 신축에 의한 소유권 취득
- ⑤ 공용징수에 의한 토지 소유권 취득

해설

② 상속에 의한 소유권 취득은 승계취득 중 포괄승계에 해당한다. 정답: ②

02 법률행위가 아닌 것은?

- ① 지상권 설정의 합의 ② 대리권의 수여
- ③ 사단법인의 설립행위 ④ 동산의 가공
- ⑤ 의사표시의 취소

해설

- ④ 가공은 순수사실행위에 해당한다
- ① 지상권설정 합의는 물건계약으로서 법률행위이다.
 - ② 대리권의 수여는 상대방 있는 단독행위이다.
 - ③ 사단법인의 설립행위는 합동행위이다.
 - ⑤ 취소는 상대방 있는 단독행위이다. 정답: ④

03 상대방 없는 단독행위인 것은?

- ① 소유권의 포기 ② 해제
- ③ 동의 ④ 추인
- ⑤ 채무면제

해설

- ① 소유권의 포기는 상대방 없는 단독행위에 해당한다.
- ②③④⑤ 상대방 있는 단독행위에 해당한다. 정답: ①

06

법률행위의 목적에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법률행위의 목적이 법률행위 당시에 구체적으로 확정되어야 그 법률행위는 유효하다.
- ② 법률행위의 일부가 무효인 경우에는 원칙적으로 그 일부만 무효이다.
- ③ 도박채무가 선량한 풍속에 반하여 무효라면 도박 채무에 대하여 양도담보 명목으로 이전해 준 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ④ 부동산 이중매매가 반사회질서 법률행위에 해당하여 무효가 되더라도 제2매수인으로부터 다시 취득한 선의의 제3자에 대해서는 이중매매의 무효를 주장할 수 없다.
- ⑤ 법률행위의 성립 당시 그 목적이 물리적으로 가능하더라도 사회통념상 실현할 수 없으면 그 법률행위는 무효이다.

해설

- ⑤ 법률행위의 성립 당시 그 목적이 물리적으로 가능하더라도 사회통념상 실현할 수 없으면 그 법률행위는 무효이다. 즉 목적의 가능과 불능의 기준은 사회통념으로 판단한다.
 - ① 법률행위의 목적이 법률행위 당시에 구체적으로 확정되어 있지 않아도 확정가능한 것이면 그 법률행위는 유효하다.
 - ② 법률행위의 일부가 무효인 경우에는 원칙적으로 전부를 무효로 한다.
 - ③ 도박채무가 선량한 풍속에 반하여 무효라면 도박 채무에 대하여 양도담보명목으로 이전해 준 소유권이전등기는 불법원인급여(제746조)에 해당하여 그 말소를 청구하지 못한다.
 - ④ 부동산 이중매매가 반사회질서 법률행위에 해당하여 무효가 되는 경우, 그 무효는 절대적 무효이므로, 제2매수인으로부터 다시 취득한 선의의 제3자에 대해서도 이중매매의 무효를 주장할 수 있다.
- 정답: ⑤

07

사회질서에 반하는 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 어떠한 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 약속은 무효이다.
- ② 법정에 나와 증언할 것을 조건으로 대가를 지급하기로 약정한 경우, 그 대가의 내용이 통상적으로 용인될 수 있는 수준을 초과하면 그 약정은 무효가 된다.
- ③ 이중매매임을 알고 부동산을 매수한 것만으로 제2매매가 사회질서에 반하여 무효인 것은 아니다.
- ④ 양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 실제로 거래한 가액보다 낮은 금액을 매매대금으로 기재한 경우에 그 매매계약은 무효이다.
- ⑤ 반사회질서의 법률행위는 당사자가 그 무효임을 알고 추진하여도 새로운 법률행위를 한 효과가 생길 수 없다.

해설

- ④ 양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 실제로 거래한 가액을 매매대금으로 기재하지 아니하고 그보다 낮은 금액을 매매대금으로 기재하였다 하여, 그것만으로 그 매매계약이 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 볼 수 없다(대법원 2007.06.14. 2007다3285). 정답: ④

甲이 X 부동산을 乙에게 매도하기로 약정하고, 계약금 및 중도금을 수령한 뒤 이를 다시 丙에게 매도하고 丙에게 먼저 소유권이전등기를 마쳐주었다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 乙은 이행불능을 이유로 한 계약해제권을 행사할 수 있다.
- ② 乙이 甲에 대하여 채무불이행으로 인한 손해배상청구권과 아울러 불법행위로 인한 손해배상청구권을 취득한 경우, 乙은 그 중 어느 쪽의 손해배상청구권이라도 선택적으로 행사할 수 있다.
- ③ 丙이 甲의 이중매매에 적극 가담한 것으로 인정되는 경우, 乙은 甲을 대위함이 없이 직접 丙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ④ 乙이 甲에 대한 소유권이전등기청구권의 보전을 위하여 甲과 丙 사이의 매매계약에 대하여 채권자취소권을 행사하는 것은 허용되지 않는다.
- ⑤ 만약 丁이 丙 명의의 소유권이전등기를 신뢰하여 丙으로부터 X를 매수하여 소유권이전등기를 마쳤더라도, 甲과 丙 사이의 매매계약이 사회질서에 반하여 무효인 것으로 인정되면, 丁은 선의의 제3자임을 증명하더라도 보호받을 수 없다.

해설

- ③ 매도인의 매수인에 대한 배임행위에 가담하여 증여를 받아 이를 원인으로 소유권이전등기를 경료한 수증자에 대하여 매수인은 매도인을 대위하여 위 등기의 말소를 청구할 수는 있으나 직접 청구할 수는 없다는 것은 형식주의 아래서의 등기청구권의 성질에 비추어 당연하다(대법원 1983.4.26. 83다카57).
- ① 제1매수인은 이행불능의 효과로서 계약 해제와 손해배상을 청구할 수도 있고, 계약 해제 없이 손해배상만을 청구할 수도 있다.
- ② 채무불이행책임과 불법행위책임은 요건과 효과를 달리하는 별개의 제도이므로, 두 개의 손해배상청구권이 경합하여 발생한다고 보는 것이 옳으며, 채권자로 하여금 선택하여 행사할 수 있게 하는 것이 피해자를 두텁게 보호할 수 있다는 점에서 타당하다.
- ④ 채권자취소권은 특정물에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 행사하는 것은 허용되지 않으므로, 부동산의 제1양수인은 소유권이전등기청구권 보전을 위하여 양도인과 제3자 사이에서 이루어진 이중양도행위에 대하여 채권자취소권을 행사할 수는 없다(대법원 1999.4.27, 98다56690).
- ⑤ 부동산의 이중매매가 반사회적 법률행위에 해당하는 경우에는 이중매매계약은 절대적으로 무효이므로, 당해 부동산을 제2매수인으로부터 다시 취득한 제3자는 설사 제2매수인이 당해 부동산의 소유권을 유효하게 취득한 것으로 믿었더라도 이중매매계약이 유효하다고 주장할 수 없다(대법원 1996.10.25. 96다29151). 정답: ③

다음은 법률행위의 적법성과 사회적 타당성에 관한 설명들이다. 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 신의칙상 모순행위금지원칙의 적용범위는 강행법규에 의하여 제한되며, 따라서 강행법규에 위반하는 약정을 한 뒤에 그 약정의 당사자가 강행법규에 위반한다는 이유로 그 무효를 주장하는 것도 허용된다.
- ② 타인으로부터 신탁받은 재산을 횡령한다는 사정을 알면서 그 수탁자로부터 이를 아주 싸게 매수하여 폭리를 취득한 경우 반사회성이 있다.
- ③ 불공정한 법률행위로 무효인 경우에는 법정추인의 규정이 적용될 여지가 없으나 상대방 (폭리행위의 피해자)의 의사에 따른 추인은 가능하다.
- ④ 매도인의 대리인이 매매한 경우에 그 매매가 불공정한 법률행위인가를 판단함에 있어서 경솔·무경험은 대리인을 기준으로 판단하여야 하고, 공박 상태가 있었는지의 여부는 매도인의 입장에서 판단해야 한다.
- ⑤ 제104조의 적용대상으로는 유상계약뿐만 아니라 채권포기행위도 포함되나 기부행위와 같은 무상행위는 적용되지 않는다.

해설

- ③ 불공정한 법률행위는 선의의 제3자에 대해서도 무효를 주장할 수 있는 절대적 무효로서, 추인에 의하여 그 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다(대법원 1994.6.24. 94다10900).
- ① 강행법규에 위반하여 무효인 수익보장약정이 투자신탁회사가 먼저 고객에게 제의를 함으로써 체결된 것이라고 하더라도, 이러한 경우에 강행법규를 위반한 투자신탁회사 스스로가 그 약정의 무효를 주장함이 신의칙에 위반되는 권리의 행사라는 이유로 그 주장을 배척한다면, 이는 오히려 강행법규에 의하여 배제하려는 결과를 실현시키는 셈이 되어 입법취지를 완전히 몰각하게 되므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 주장이 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 할 수 없다(대법원 1999.3.23. 99다4405).
- ④ 원칙적으로 공박은 본인을 표준으로, 경솔·무경험은 대리인을 표준으로 판단한다(대법원 1993.10.12. 93다19924).
- ⑤ 민법 제104조가 규정하는 현저히 공정을 잃은 법률행위라 함은 자기의 급부에 비하여 현저하게 균형을 잃은 반대급부를 하게 하여 부당한 재산적 이익을 얻는 행위를 의미하는 것이므로, 기부행위와 같이 아무런 대가관계 없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위는 그 공정성 여부를 논의할 수 있는 성질의 법률행위가 아니다(대법원 2002.2.11. 99다56833).

정답: ③

10 사회질서에 반하는 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 반사회적 행위로 조성된 비자금을 은닉하기 위하여 임치한 행위는 사회질서에 반하는 법률 행위이므로 임치인이 그 반환을 청구할 수 없다.
- ② 전통사찰의 주지직을 거액의 금품을 대가로 양도하기로 하는 약정이 있음을 알고도 이를 묵인 혹은 방조한 상태에서 한 종교법인의 주지임명행위는 사회질서에 반하는 법률행위로 서 무효이다.
- ③ 대리인이 사회질서에 반하여 이중매수를 한 경우, 본인이 그러한 사정을 몰랐거나 반사회성을 야기한 것이 아니라면 그 대리행위는 유효하다.
- ④ 처의 동의를 얻어 다른 여성과 성관계를 포함하는 원조교제계약을 한 경우, 그 계약에 따른 대가(代價)가 적당하다면 그 계약은 유효하다.
- ⑤ 정당한 대가를 지급하고 목적물을 매수하였다면, 특별한 사정이 없는 한, 비록 그 후 목적물이 범죄행위로 취득된 것을 알게 되었다더라도 소유권이전등기를 구하는 것이 사회질서에 반하는 법률행위라고 단정할 수 없다.

해설

- ② 전통사찰의 주지직을 거액의 금품을 대가로 양도하기로 하는 약정이 있음을 알고도 이를 묵인 혹은 방조한 상태에서 한 종교법인의 주지임명행위는 사회질서에 반하는 법률행위에 해당되지 않는다(대법원 2001.2.9. 99다38613).
- ③ 대리인이 사회질서에 반하여 이중매수를 한 경우, 본인이 그러한 사정을 몰랐거나 반사회성을 야기한 것이 아니라 하더라도 대리행위는 원칙적으로 대리인을 기준으로 하므로 그 대리행위는 무효이다(제116조).
- ④ 첩계약은 처의 동의 유무와 관계없이 무효이다(대법원 1967.10.6. 67다1134).
- ⑤ 매매계약체결 당시에 정당한 대가를 지급하고 목적물을 매수하는 계약을 체결하였다면, 비록 그 후 목적물이 범죄행위로 취득된 것을 알게 되었다고 하더라도, 계약의 이행을 구하는 것 자체가 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 것으로 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 그러한 사유만으로 당초의 매매계약에 기하여 목적물에 대한 소유권이전등기를 구하는 것이 제103조의 공서양속에 반하는 행위라고 단정할 수 없다(대법원 2001.11.9., 2001다44987). 정답: ⑤

11 법률행위의 목적에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 도박채무의 이행으로써 토지를 양도하는 계약은 반사회적 법률행위로서 무효이다.
- ② 법률행위의 목적의 불능은 확정적이어야 하고, 실현가능성이 있는 일시적 불능은 이에 해당하지 않는다.
- ③ 사찰이 그 존립에 필요불가결한 재산인 임야를 증여하는 계약은 무효이다.
- ④ 부첩관계를 유지하는 계약은 본처의 사전 동의가 있어도 반사회적 법률행위이다.
- ⑤ 법률행위의 동기가 사회질서에 반한다는 사실을 법률행위시에 상대방이 알았더라도, 그 상대방과 법률행위를 한 선의의 제3자는 그 법률행위의 유효를 주장할 수 있다.

해설

- ⑤ 동기의 불법에 대하여는 “민법 제103조에 의하여 무효로 되는 반사회질서행위는 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함한다(대법원 1984.12.11. 84다1402).”라고 하여 표시설에 입각한 태도를 취하고 있으며, 이러한 무효는 절대적 무효로써 선의의 제3자에게도 대항할 수 있다. 정답: ⑤

12 사회질서에 반하는 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 오로지 보험사고를 가장하여 보험금을 취득할 목적으로 체결한 생명보험계약은 무효이다.
- ② 비자금을 소극적으로 은닉하기 위하여 임치한 것은 사회질서에 반하는 법률행위로 볼 수 없다.
- ③ 부채관계를 청산하면서 희생의 배상 내지 장래 생활대책 마련의 의미로 금원을 지급하기로 한 약정은 공서양속에 반하지 않는다.
- ④ 반사회적 법률행위에 의한 무효를 가지고 선의의 제3자에게는 대항할 수 없다.
- ⑤ 형사사건에 관한 변호사 성공보수 약정은 재판의 결과를 금전적 대가와 결부시키는 것으로서 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있다.

해설

- ④ 반사회적 법률행위에 의한 무효는 절대적 무효로서 그 무효를 가지고 선의의 제3자에게도 대항할 수 있다.
- ⑤ 형사사건에 관하여 체결된 성공보수약정이 가져오는 여러 가지 사회적 폐단과 부작용 등을 고려하면, 구속영장청구 기각, 보석 석방, 집행유예나 무죄 판결 등과 같이 의뢰인에게 유리한 결과를 얻어내기 위한 변호사의 변론활동이나 직무수행 그 자체는 정당하다 하더라도, 형사사건에서의 성공보수약정은 수사·재판의 결과를 금전적인 대가와 결부시킴으로써, 기본적 인권의 옹호와 사회 정의의 실현을 사명으로 하는 변호사 직무의 공공성을 저해하고, 의뢰인과 일반 국민의 사법제도에 대한 신뢰를 현저히 떨어뜨릴 위험이 있으므로, 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있다.

다만 선량한 풍속 기타 사회질서는 부단히 변천하는 가치관념으로서 어느 법률행위가 이에 위반되어 민법 제103조에 의하여 무효인지는 법률행위가 이루어진 때를 기준으로 판단하여야 하고, 또한 그 법률행위가 유효로 인정될 경우의 부작용, 거래자유 보장 및 규제의 필요성, 사회적 비난의 정도, 당사자 사이의 이익균형 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 한다.

그런데 그동안 대법원은 수임한 사건 종류나 특성에 관한 구별 없이 성공보수약정이 원칙적으로 유효하다는 입장을 취해 왔고, 대한변호사협회도 1983년에 제정한 '변호사보수기준에 관한 규칙'에서 형사사건의 수임료를 착수금과 성공보수금으로 나누어 규정하였으며, 위 규칙이 폐지된 후에 권고양식으로 만들어 제공한 형사사건의 수임약정서에도 성과보수에 관한 규정을 마련하여 놓고 있었다. 이에 따라 변호사나 의뢰인은 형사사건에서의 성공보수약정이 안고 있는 문제점 내지 그 문제점이 약정의 효력에 미칠 수 있는 영향을 제대로 인식하지 못한 것이 현실이고, 그 결과 당사자 사이에 당연히 지급되어야 할 정상적인 보수까지도 성공보수의 방식으로 약정하는 경우가 많았던 것으로 보인다.

이러한 사정들을 종합하여 보면, 종래 이루어진 보수약정의 경우에는 보수약정이 성공보수라는 명목으로 되어 있다는 이유만으로 민법 제103조에 의하여 무효라고 단정하기는 어렵다. 그러나 대법원이 이 판결을 통하여 형사사건에 관한 성공보수약정이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있음을 명확히 밝혔음에도 불구하고 향후에도 성공보수약정이 체결된다면 이는 민법 제103조에 의하여 무효로 보아야 한다(대법원 2015.07.23. 2015다200111 전원합의체).

정답: ④

13 사회질서에 반하는 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부첩(夫妻)관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 사회질서에 반하여 무효이다.
- ② 어떠한 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 각서를 써 주었더라도 그와 같은 의사표시는 공서양속에 위반되어 무효이다.
- ③ 법률행위가 사회질서에 위반되었는지의 여부는 법률행위의 효력발생시점을 기준으로 판단해야 한다.
- ④ 강제집행을 면할 목적으로 허위의 근저당권설정등기를 하는 행위는 사회질서에 반하는 것으로 볼 수 없다.
- ⑤ 소송에서 증언하는 대가로 통상적으로 용인될 수 있는 수준을 넘는 급부를 제공하기로 하는 약정은 사회질서에 반하는 것으로 무효이다.

해설

- ③ 어느 법률행위가 사회질서에 반하는지 여부는 원칙적으로 법률행위 당시를 기준으로 판단하여야 한다. 판례도, 매매계약체결 당시에 정당한 대가를 지급하고 목적물을 매수하는 계약을 체결하였다면, 비록 그 후 목적물이 범죄행위로 취득된 것을 알게 되었다고 하더라도, 계약의 이행을 구하는 것 자체가 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 것으로 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 그러한 사유만으로 당초의 매매계약에 기하여 목적물에 대한 소유권이전등기를 구하는 것이 제 103조의 공서양속에 반하는 행위라고 단정할 수 없다(대법원 2001. 11. 9. 2001다44987)고 한다.

정답: ③

14 반사회적 법률행위로 무효가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 취득시효가 완성된 부동산의 소유자가 취득시효완성 사실을 알고 소유권이전등기 의무를 회피할 목적으로 아들과 공모하여 그 부동산을 아들에게 증여하는 행위
- ② 도박채무의 변제를 위하여 부동산의 처분을 위임받은 채권자가 그 부동산을 이러한 사정을 모르는 제3자에게 매도하는 행위
- ③ 증인이 증언을 조건으로 소송의 일방 당사자로부터 통상적으로 용인될 수 있는 수준을 넘어서는 대가를 받기로 약정하는 행위
- ④ 종중재산이 적법하게 명의신탁된 경우, 제3자가 명의수탁자의 명의신탁자에 대한 배임행위에 적극 가담하여 명의수탁자로부터 부동산을 매수하는 행위
- ⑤ 보험계약자가 다수의 보험계약을 통하여 보험금을 부정취득할 목적으로 보험계약을 체결하는 행위

해설

- ② 도박채무 부담행위 및 그 변제약정이 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되어 무효라 하더라도, 부동산 처분에 관한 대리권을 도박 채권자에게 수여한 행위 부분까지 무효라고 볼 수는 없으므로, 위와 같은 사정을 알지 못하는 거래 상대방인 제3자가 도박 채무자부터 그 대리인인 도박 채권자를 통하여 위 부동산을 매수한 행위까지 무효가 된다고 할 수는 없다(대법원 1995.7.14. 94다40147).
- ③ 증언하여 주는 대가로 용인될 수 있는 정도를 초과하는 급부를 제공받기로 한 것이라 인정된다면 이는 반사회질서적인 금전적 대가가 결부된 경우로서 제103조 소정의 반사회질서행위에 해당하여 무효이다(대법원 1999.4.13., 98다52483). 정답: ②

15 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부담 없는 증여계약에는 불공정한 법률행위가 성립할 여지가 없다.
- ② 피해자의 공박은 경제적인 공박 상태만을 의미하는 것은 아니다.
- ③ 경매부동산의 매각대금이 그 시가에 비하여 현저히 저렴한 경우, 경매가 적법한 절차에 의해 이루어졌어도 경매는 무효이다.
- ④ 불공정한 법률행위에 의해 급부가 이행된 경우, 피해자는 폭리자에게 급부를 부당이득으로 반환할 의무가 없다.
- ⑤ 불공정한 법률행위가 성립하기 위해서는 폭리자가 피해자에게 공박·경솔 또는 무경험의 사정이 있음을 알고서 이를 이용하려는 의사가 필요하다.

해설

- ③ 경매에 있어서는 불공정한 법률행위 또는 채무자에게 불리한 약정에 관한 것으로서 효력이 없다는 민법 제104조, 제608조는 적용될 여지가 없다(대법원 1980.3.21, 80마77).
- ① 증여계약과 같이 아무런 대가 관계없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위(무상계약)는 그 공정성 여부를 논의할 수 있는 성질의 법률행위가 아니다(대법원 2002.2.11, 99다56833).
- ② 공박이란 경제적·정신적·심리적 원인에 기인할 수도 있다.
- ④ 불공정한 법률행위로 무효인 경우에는 가해자에게만 불법이 있으므로, 피해자는 급부를 부당이득으로 반환청구할 수 있다(제746조 단서).
- ⑤ 폭리자의 악의적 의사가 있어야 한다. 정답: ③

16 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 어업권 소멸로 인한 손실보상금의 분배에 관하여 어촌계 총회의 결의가 현저하게 불공정한 경우, 폭리행위가 될 수 있다.
- ② 매매계약이 불공정한 법률행위에 해당하는 경우, 특별한 사정이 없는 한, 불이익을 입게 되는 당사자가 그 불공정성을 이유로 제소를 하지 못하게 하는 부제소합의는 무효이다.
- ③ 매매계약에서 의사표시를 한 자가 공박상태에 있었다라도 상대방이 그와 같은 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사가 없으면 그 계약은 불공정한 법률행위가 되지 않는다.
- ④ 불공정한 법률행위를 이유로 무효를 주장하는 자는 피해자의 공박, 경솔과 무경험을 모두 증명해야 한다.
- ⑤ 불공정한 법률행위로서 무효인 법률행위는 추인에 의해서 유효로 될 수 없다.

해설

- ④ 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해당사자의 공박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 공박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인

궁박, 경술, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분하다(대법원 2002.10.22. 2002다38927).

- ① 법인 아닌 어촌계가 취득한 어업권은 어촌계의 총유이고, 그 어업권의 소멸로 인한 보상금도 어촌계의 총유에 속하므로 총유물인 손실보상금의 처분은 원칙적으로 계원총회의 결의에 의하여 결정되어야 할 것이지만, 어업권의 소멸로 인한 손실보상금은 어업권의 소멸로 손실을 입은 어촌계원들에게 공평하고 적정하게 분배되어야 할 것이므로, 어업권의 소멸로 인한 손실보상금의 분배에 관한 어촌계 총회의 결의 내용이 각 계원의 어업권 행사 내용, 어업 의존도, 계원이 보유하고 있는 어업 장비나 멸실된 어업 시설 등의 제반 사정을 참작한 손실의 정도에 비추어 볼 때 현저하게 불공정한 경우에는 그 결의는 무효이다(대법원 2003.06.27. 2002다68034).
- ② 매매계약과 같은 쌍무계약이 급부와 반대급부의 불균형으로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효라고 한다면, 그 계약으로 인하여 불이익을 입는 당사자로 하여금 위와 같은 불공정성을 소송 등 사법적 구제수단을 통하여 주장하지 못하도록 하는 부제소 합의 역시 다른 특별한 사정이 없는 한 무효이다(대법원 2011.04.28. 2010다106702).
- ③ 불공정한 법률행위가 성립하기 위하여는 법률행위의 당사자 일방이 궁박, 경술 또는 무경험의 상태에 있고, 상대방이 이러한 사정을 알고서 이를 이용하려는 의사가 있어야 한다(대법원 1993.10.12. 93다19924).
- ⑤ 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 추인에 의하여 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다(대법원 1994.06.24. 94다10900). 정답: ④

17 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 경매에 의한 재산권의 이전에는 불공정한 법률행위의 법리가 적용되지 않는다.
- ② 대가관계 없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 법률행위도 불공정한 법률행위로 무효가 될 수 있다.
- ③ 대리행위의 경우 경술과 무경험은 대리인을 기준으로 판단하지만, 궁박은 본인을 기준으로 판단한다.
- ④ 궁박은 경제적 것만 한정되지 않으며, 정신적 또는 신체적 원인에 기인하는 것도 포함한다.
- ⑤ 불공정한 법률행위가 성립되기 위한 요건은 무효를 주장하는 자가 증명해야 한다.

해설

- ② 불공정한 법률행위에 해당하기 위하여는 급부와 반대급부의 사이에 현저히 균형을 잃을 것이 요구되므로 증여와 같이 상대방에 의한 대가적 의미의 재산관계의 출연이 없이 당사자 일방의 급부만 있는 경우에는 급부와 반대급부 사이의 불균형의 문제는 발생하지 않는다(대법원 1993.07.16. 92다41528). 정답: ②

18 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 매도인이 불공정한 법률행위를 이유로 계약의 무효를 주장하는 경우, 매도인은 매매가격의 현저한 불균형을 증명하면 족하고, 매도인의 경솔 등의 여부는 매수인이 증명하여야 한다.
- ② 불공정한 법률행위가 대리인에 의하여 이루어진 경우, 공박·경솔은 본인을 기준으로 하고 무경험은 대리인을 기준으로 판단한다.
- ③ 불공정한 법률행위가 성립하기 위해서는 폭리자에게 피해 당사자의 공박·경솔 또는 무경험에 대한 인식과 이를 이용하려는 의사가 있어야 한다.
- ④ 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에도 당사자가 그 무효임을 알고 추진한 때에는 새로운 법률행위로 본다.
- ⑤ 불공정한 법률행위에 있어서 급부와 반대급부 사이의 현저한 불균형이 있으면 이는 당사자의 공박·경솔 또는 무경험에 의한 것으로 추정된다.

해설

- ③ 불공정한 법률행위가 성립하기 위하여는 법률행위의 당사자 일방이 공박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있고, 상대방이 이러한 사정을 알고서 이를 이용하려는 의사가 있어야 한다(대법원 1993.10.12. 93다19924).
- ① 폭리행위가 성립하기 위한 주관적 요건(공박, 경솔, 무경험)과 객관적 요건(급부와 반대급부의 현저한 불균형)은 피해자가 증명하여야 한다.
- ② 대리인에 의하여 법률행위가 이루어진 경우 그 법률행위가 민법 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경솔과 무경험은 대리인을 기준으로 하여 판단하고, 공박은 본인의 입장에서 판단하여야 한다(대법원 2002.10.22. 2002다38927).
- ④ 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 추인에 의하여 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다(대법원 1994.06.24. 94다10900).
- ⑤ 불공정한 법률행위를 주장하는 자는 스스로 공박, 경솔, 무경험으로 인하였음을 증명하여야 하고, 그 법률행위가 현저하게 공정을 잃었다 하여 곧 그것이 경솔하게 이루어졌다고 추정하거나 공박한 사정이 인정되는 것이 아니다(대법원 1969.07.08. 69다594). 정답: ③

19 다음 민법규정 중 임의규정으로 이해되고 있는 것은?

- ① 제28조(실종선고의 효과) : 실종선고를 받은 자는 전조의 기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다.
- ② 제159조(기간의 만료점) : 기간을 일, 주, 월 또는 년으로 정한 때에는 기간 말일의 종료로 기간이 만료한다.
- ③ 제3조(권리능력의 존속기간) : 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.
- ④ 제4조(성년기) : 만 19세로 성년이 된다.
- ⑤ 제184조 제1항(시효이익의 포기 기타) : 소멸시효의 이익은 미리 포기하지 못한다.

해설

- ② 민법의 기간계산에 관한 규정은 널리 공법관계에도 적용되는 규정이나 임의규정에 해당한다.

정답: ②

20 반사회적 법률행위로서 무효가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 도박으로 인한 채무의 변제를 위하여 토지를 양도하는 계약을 체결한 경우
- ② 법률행위의 성립과정에서 강박이라는 불법적 방법이 사용된 것에 불과한 경우
- ③ 혼인 외의 성관계를 유지하기 위하여 증여계약을 체결한 경우
- ④ 소송에서 사실대로 증언해 줄 것을 조건으로 통상적 수준을 현저하게 넘는 대가를 지급하기로 약정한 경우
- ⑤ 부동산의 제2매수인이 매도인의 배임행위를 적극 종용하여 이중매매를 한 경우

해설

② 강박에 의한 법률행위가 하자 있는 의사표시로서 취소되는 것에 그치지 않고, 나아가 무효로 되기 위하여는 강박의 정도가 단순한 불법적 해악의 고지로 상대방으로 하여금 공포를 느끼도록 하는 정도가 아니고, 의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어져 단지 법률행위의 외형만이 만들어진 것에 불과한 정도이어야 한다(대법원 2003.05.13. 2002다73708). 정답: ②

21 甲과 乙은 X토지를 매매목적물로 하기로 약정하였으나 X토지의 지번에 관하여 착오를 일으켜서 계약서상 목적물로 Y토지의 지번을 표시하고 Y토지에 대해서 乙명의로 소유권이전등기가 경료되었다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲과 乙 간에는 Y토지에 대하여 매매계약이 존재한다.
- ② 乙은 甲에 대하여 X토지에 대한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 甲은 착오를 이유로 X토지에 대한 매매계약을 취소할 수 있다.
- ④ 甲은 乙에 대하여 Y토지에 대한 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 없다.
- ⑤ 만일 丙이 선의로 乙로부터 Y토지에 대하여 소유권이전등기를 경료받았다면 丙은 Y토지의 소유권을 취득한다.

해설

본 사례는 자연적 해석과 관련한 오표시무해의 원칙에 대한 것이다. 오표시무해의 원칙이란 표의자가 의사표시를 잘못 하였더라도 그 잘못된 표시의 진정한 의미를 인식할 수 있거나 명백한 때에는 표의자에게 해가 되지 않는다는 것이다. 따라서 착오의 문제는 발생하지 않는다. 이에 대한 판례는 다음과 같다. 부동산의 매매계약에 있어 쌍방당사자가 모두 특정의 X토지를 계약의 목적물로 삼았으나 그 목적물의 지번 등에 관하여 착오를 일으켜 계약을 체결함에 있어서는 계약서상 그 목적물을 X토지와는 별개인 Y토지로 표시하였다 하여도 X토지에 관하여 이를 매매의 목적으로 한다는 쌍방당사자의 의사합치가 있는 이상 위 매매계약은 X토지에 관하여 성립한 것으로 보아야 할 것이고 Y토지에 관하여 매매계약이 체결된 것으로 보아서는 안 될 것이며, 만일 Y토지에 관하여 위 매매계약을 원인으로 하여 매수인 명의로 소유권이전등기가 경료되었다면 이는 원인 없이 경료된 것으로서 무효이다(대법원 1993.10.26. 93다2629·93다2636). 판례의 입장에 따르면 아래와 같다.

- ① 甲과 乙 간에는 X토지에 대하여 매매계약이 유효하게 성립된 것이다.
- ③ 甲은 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 없다.
- ④ 甲은 乙에 대하여 Y토지에 대한 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙로부터 선의의 丙이 Y토지에 대한 소유권이전등기를 경료받았다 하더라도, 부동산에 대한 공신의 원칙을 우리나라는 인정하고 있지 않으므로, 丙은 소유권을 취득할 수 없다. 정답: ②

22

법률행위의 해석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 오표시무해(誤表示無害)의 원칙은 법률행위 해석 중 자연적 해석에 따른 것이다.
- ② 비전형의 혼합계약을 해석함에에는 사용된 문언의 내용에 의하여 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 있는 그대로 확정하는 것이 필요하다.
- ③ 당사자가 특정 토지를 계약 목적으로 합의하였으나 그 지번의 표시에 관한 착오로 인하여 계약서에 그 토지와 다른 토지로 표시한 경우, 계약서에 표시된 토지에 대하여 계약이 성립한다.
- ④ 사실인 관습은 당사자의 주장에 구애됨이 없이 법원이 스스로 직권에 의하여 판단할 수 있다.
- ⑤ 계약을 체결한 자가 타인의 이름으로 법률행위를 한 경우, 계약당사자의 확정에 관한 행위자와 상대방의 의사가 일치하면 그 일치한 의사대로 행위자 또는 명의인을 계약의 당사자로 확정해야 한다.

해설

- ③ 부동산의 매매계약에 있어 쌍방당사자가 모두 특정의 X토지를 계약의 목적으로 삼았으나 그 목적물의 지번 등에 관하여 착오를 일으켜 계약을 체결함에 있어서는 계약서상 그 목적물을 X토지와는 별개인 Y토지로 표시하였다 하여도 X토지에 관하여 이를 매매의 목적으로 한다는 쌍방당사자의 의사합치가 있는 이상 위 매매계약은 X토지에 관하여 성립한 것으로 보아야 할 것이고 Y토지에 관하여 매매계약이 체결된 것으로 보아서는 안 될 것이며, 만일 Y토지에 관하여 위 매매계약을 원인으로 하여 매수인 명의로 소유권이전등기가 경료되었다면 이는 원인 없이 경료된 것으로서 무효이다(대법원 1993.10.26., 93다2629·93다2636). 정답: ③

23

법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 어떠한 의사표시가 진의 아닌 의사표시로서 무효라고 주장하는 자는 그에 대한 증명책임을 진다.
- ② 불공정한 법률행위에 해당하는지는 법률행위가 이루어진 시점을 기준으로 약속된 급부와 반대급부 사이의 객관적 가치를 비교 평가하여 판단해야 한다.
- ③ 대리인에 의한 법률행위가 불공정한 법률행위에 해당하는지 판단함에 있어서 공박은 대리인을 기준으로 한다.
- ④ 부동산 매매계약에 있어 쌍방 당사자가 모두 X토지를 계약의 목적으로 삼았으나 그 목적물의 지번 등에 관하여 둘 다 착오를 일으켜 계약서에는 Y토지로 표시한 경우, 매수인은 X토지에 대해 이전등기를 청구할 수 있다.
- ⑤ 특별한 사정이 없는 한, 착오를 이유로 법률행위를 취소하려면 표의자에게 중대한 과실이 없어야 한다.

해설

- ③ 대리인에 의하여 법률행위가 이루어진 경우 그 법률행위가 민법 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경솔과 무경험은 대리인을 기준으로 하여 판단하고, 공박은 본인의 입장에서 판단하여야 한다(대법원 2002.10.22. 2002다38927). 정답: ③

24 반사회질서 또는 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부채관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 그 조건뿐만 아니라 그 계약 자체도 무효이다.
- ② 감정평가사를 통해 공무원에게 직무상 부정한 청탁을 하게 하고 그 대가로 상당한 금품을 교부하기로 한 약정은 무효이다.
- ③ 불공정한 법률행위가 되기 위해서는 피해자의 공박, 경술, 무경험 중 어느 하나만 있으면 되고 그 모두가 있어야 할 필요는 없다.
- ④ 계약이 불공정한 법률행위에 해당하여 무효라 하더라도 특별한 사정이 없는 한 그 계약에 관한 부채소합의는 유효하다.
- ⑤ 법률행위의 내용이 반사회적인 것은 아니지만 반사회적 조건이 붙어 반사회적인 성질을 띠게 되면 그 법률행위는 무효이다.

해설

- ④ 매매계약과 같은 쌍무계약이 급부와 반대급부의 불균형으로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효라고 한다면, 그 계약으로 인하여 불이익을 입는 당사자로 하여금 위와 같은 불공정성을 소송 등 사법적 구제수단을 통하여 주장하지 못하도록 하는 부채소합의 역시 다른 특별한 사정이 없는 한 무효이다(대법원 2011.04.28. 2010다106702). 정답: ④

25 법률행위의 해석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 계약의 해석은 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적 의미를 명백하게 확정하는 것이다.
- ② 계약의 당사자가 누구인지는 그 계약에 관여한 당사자의 의사해석의 문제이다.
- ③ 진의 아닌 의사표시에 있어서 진의는 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 의미한다.
- ④ 계약의 해석을 통하여 보충되는 당사자의 의사는 당사자의 주관적 의사가 아니라 거래관행이나 신의칙 등에 의하여 객관적으로 추인되는 의사를 의미한다.
- ⑤ 타인 명의로 계약을 체결하는 경우 계약을 체결한 자와 상대방의 의사가 일치한다면 그 일치된 의사대로 당사자를 확정하면 된다.

해설

- ③ 진의 아닌 의사표시에 있어서의 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음속에서 바라지는 아니하였다고 하더라도 당시의 상황에서는 그것이 최선이라고 판단하여 그 의사표시를 하였을 경우에는 이를 내심의 효과의사가 결여된 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없다(대법원 2015.08.27. 2015다211630). 정답: ③

26 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 성립요건인 공박, 경솔, 무경험은 그 중 하나만 갖추어도 충분하다.
- ② 공박은 경제적 원인 외에 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있다.
- ③ 대리인에 의하여 행해진 법률행위에서 불공정한 법률행위가 문제되는 경우, 경솔이나 무경험은 대리인을 기준으로 판단한다.
- ④ 무경험은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로, 어느 특정영역이 아니라 거래 일반에 대한 경험부족을 말한다.
- ⑤ 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 인하여 불공정한 법률행위에 해당하는 경우, 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용될 수 없다.

해설

- ⑤ 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용되어 당사자 쌍방이 위와 같은 무효를 알았더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립할 수 있다(대법원 2011.04.28. 선고 2010다106702). 정답: ⑤

27 법률행위의 목적에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? [2023' 감정평가사]

- ㉠ 甲이 乙에게 매도한 건물이 계약체결 후 甲의 방화로 전소하여 乙에게 이전할 수 없게 된 경우, 甲의 손해배상책임이 문제될 수 있다.
- ㉡ 甲이 乙에게 매도한 토지가 계약체결 후 재결수용으로 인하여 乙에게 이전할 수 없게 된 경우, 위험부담이 문제될 수 있다.
- ㉢ 甲이 乙에게 매도하기로 한 건물이 계약체결 전에 지진으로 전파(全破)된 경우, 계약체결상의 과실책임이 문제될 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉠ 후발적 불능 중 이행불능
 ㉡ 후발적 불능 중 위험부담의 문제
 ㉢ 원시적 불능으로서 당연무효 정답: ⑤

28

반사회적 법률행위로서 무효가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 변호사가 민사소송의 승소대가로 성공보수를 받기로 한 약정
- ② 도박자금에 제공할 목적으로 금전을 대여하는 행위
- ③ 수증자가 부동산 매도인의 배임행위에 적극 가담하여 체결한 부동산 증여계약
- ④ 마약대금채무의 변제로서 토지를 양도하기로 한 계약
- ⑤ 처음부터 보험사고를 가장하여 오로지 보험금을 취득할 목적으로 체결한 생명보험계약

해설

- ① 형사사건에 관한 성공보수약정은 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 민법 제103조에 의하여 무효로 보아야 한다(대법원 2015.07.23. 2015다200111 전원합의체)는 판례가 있으나 민사 사건은 그러하지 아니하다. 정답: ①

제5장
실전문제

29

반사회질서의 법률행위로서 무효가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 반사회질서적인 조건이 붙은 법률행위
- ② 상대방에게 표시된 동기가 반사회질서적인 법률행위
- ③ 부첩(夫妻) 관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약
- ④ 오로지 보험사고를 가장하여 보험금을 취득할 목적으로 체결한 생명보험계약
- ⑤ 주택매매계약에서 양도소득세를 면탈할 목적으로 소유권이전등기를 일정기간 후에 이전받기로 한 특약

해설

- ⑤ 양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 실제로 거래한 가액을 매매대금으로 기재하지 아니하고 그보다 낮은 금액을 매매대금으로 기재하였다 하여, 그것만으로 그 매매계약이 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 볼 수 없다(대법원 2007.06.14. 2007다3285). 정답: ⑤

30

다음 중 무효인 법률행위는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 공인중개사]

- ① 개업공인중개사가 임대인으로서 직접 중개의뢰인과 체결한 주택임대차계약
- ② 공인중개사 자격이 없는 자가 우연히 1회성으로 행한 중개행위에 대한 적절한 수준의 수수료 약정
- ③ 민사사건에서 변호사와 의뢰인 사이에 체결된 적절한 수준의 성공보수약정
- ④ 매도인이 실수로 상가지역을 그보다 가격이 비싼 상업 지역이라 칭하였고, 부동산 거래의 경험이 없는 매수인이 이를 믿고서 실제 가격보다 2배 높은 대금을 지급한 매매계약
- ⑤ 보험계약자가 오로지 보험사고를 가장하여 보험금을 취득할 목적으로 선의의 보험자와 체결한 생명보험계약

해설

- ⑤ 반사회적 법률행위로서 무효이다. 정답: ⑤

31

반사회적 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ㉠ 어느 법률행위가 사회질서에 반하는지 여부는 특별한 사정이 없는 한 법률행위 당시를 기준으로 판단해야 한다.
- ㉡ 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권을 설정하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 반사회적 법률행위라고 볼 수 없다.
- ㉢ 대리인이 매도인의 배임행위에 적극 가담하여 이루어진 부동산의 이중매매의 경우, 본인인 매수인이 그러한 사정을 몰랐다면 반사회적 법률행위가 되지 않는다.
- ㉣ 법률행위의 성립과정에서 단지 강박이라는 불법적 방법이 사용된 것에 불과한 때에는 반사회적 법률행위로 볼 수 없다.
- ㉤ 반사회적 법률행위임을 이유로 하는 무효는 선의의 제3자에 게 대항할 수 있다.

해설

- ㉢ 대리인이 사회질서에 반하여 이중매수를 한 경우, 본인이 그러한 사정을 몰랐거나 반사회성을 야기한 것이 아니라 하더라도 대리행위는 원칙적으로 대리인을 기준으로 하므로 그 대리행위는 무효이다(제116조). 정답: ㉢

32

반사회적 법률행위에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ㉠ 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위
- ㉡ 오로지 보험사고를 가장하여 보험금을 취득할 목적으로 생명보험계약을 체결하는 행위
- ㉢ 매도인의 배임행위에 제2매수인이 적극 가담하여 행해진 부동산이중매매
- ㉣ 도박자금에 제공할 목적으로 금전을 대차하는 행위

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

해설

- ㉠ 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권을 설정하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 반사회적 법률행위라고 볼 수 없다.
㉡㉢㉣은 모두 반사회적 법률행위에 해당한다. 정답: ①

33 법률행위의 효력에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2020' 공인중개사]

- ① 무효행위 전환에 관한 규정은 불공정한 법률행위에 적용될 수 있다.
- ② 경매에는 불공정한 법률행위에 관한 규정이 적용되지 않는다.
- ③ 강제집행을 면할 목적으로 허위의 근저당권을 설정하는 행위는 반사회질서의 법률행위로 무효이다.
- ④ 상대방에게 표시되거나 알려진 법률행위의 동기가 반사회적인 경우, 그 법률행위는 무효이다.
- ⑤ 소송에서 증언할 것을 조건으로 통상 용인되는 수준을 넘는 대가를 지급하기로 하는 약정은 무효이다.

해설

- ③ 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권을 설정하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 반사회적 법률행위라고 볼 수 없다. 정답: ③

34 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 급부와 반대급부 사이의 현저한 불균형은 그 무효를 주장하는 자가 증명해야 한다.
- ② 무경험은 어느 특정 영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 의미한다.
- ③ 대리인에 의한 법률행위의 경우, 공박 상태에 있었는지 여부는 본인을 기준으로 판단한다.
- ④ 불공정한 법률행위로서 무효인 경우, 원칙적으로 추인에 의하여 유효로 될 수 없다.
- ⑤ 경매절차에서 매각대금이 시가보다 현저히 저렴한 경우, 그 경매는 불공정한 법률행위로서 무효이다.

해설

- ⑤ 불공정한 법률행위는 경매 등 법률행위에 의하지 않은 재산권의 이전에는 적용되지 않는다.

정답: ⑤

1 기본문제

01 진의 아닌 의사표시의 요건이 아닌 것은?

- ① 일정한 효과를 노리는 의사표시가 있을 것
- ② 진의와 표시가 부합하지 않을 것
- ③ 표의자가 진의와 표시의 불일치를 알고 있을 것
- ④ 진의와 불일치한 표시를 한 이유나 동기는 어떤 것이든 묻지 않는다.
- ⑤ 반드시 상대방 있는 의사표시일 것

해설

◎ 비진의의사표시[심리유보, 단독허위표시](제107조)

의 의	표의자가 내심의 의사와 표시가 일치하지 않는다는 것을 알면서 하는 의사표시이다.
요 건	㉠ 의사표시의 존재 ㉡ 진의와 표시가 불일치 ㉢ 진의와 표시의 불일치를 표의자가 인식하고 있어야 한다. ㉣ 비진의의사표시를 한 이유나 동기는 불문한다.
효 과	▪ 원칙 : 의사표시의 효력에 영향을 미치지 않는다(=유효). ▪ 예외 : 상대방이 진의 아님을 알았거나, 알 수 있었을 때에는 무효이다(상대방의 악의 또는 과실은 표의자가 증명).
제3자 관계	무효로써 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다.
적용범위	㉠ 상대방 없는 의사표시에도 적용된다(언제나 유효). ㉡ 가족법상의 신분행위에는 적용되지 않는다.

정답: ⑤

02 물의를 일으킨 사립대학교 조교수 甲이 사직원이 수리되지 않을 것이라고 믿고, 사태수습을 위하여 형식상 이사장 앞으로 사직원을 제출하였다. 그러나 이사회에서 본인의 의사이니 하는 수 없다고 하여 사직원을 수리하였다. 다음 설명 중 가장 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲의 착오로 인한 의사표시이므로 甲은 취소할 수 있다.
- ② 진의가 의식적으로 흠결되어 있으므로 무효이다.
- ③ 표의자가 진의 아님을 알고 한 것이므로 항상 유효이다.
- ④ 원칙적으로 유효이나 이사회에서 그 진의를 알았으면 무효이다.
- ⑤ 원칙적으로 유효이나 이사회에서 그 진의를 알았거나 알 수 있었으면 무효이다.

해설

- ⑤ 물의를 일으킨 사립대학교 조교수가 사직원이 수리되지 않을 것이라고 믿고 사태수습을 위하여 형식상 이사장 앞으로 사직원을 제출하였던바 의외로 이사회에서 '본인의 의사이니 하는 수 없다'고 하여 사직원이 수리된 경우 위 조교수의 사직원이 설사 진의에 이르지 아니한 비진의 의사표시라 하더라도 학교법인이나 그 이사회에서 그러한 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우가 아니라면 그 의사표시에 따라 효력을 발생하는 것이다(대법원 1980.10.14. 79다2168). 정답: ⑤

03 가장매매의 법률효과에 관하여 옳은 것은?

- ① 당사자 사이에서는 유효하다.
 ② 당사자 사이는 물론 제3자에 대하여도 항상 무효이다.
 ③ 당사자 사이는 무효이나, 제3자에 대하여는 유효이다.
 ④ 제3자에 대하여는 선의·악의를 묻지 아니하고, 허위표시의 무효를 가지고 대항할 수 없다.
 ⑤ 제3자가 당사자에 대하여 무효를 주장하는 것은 무방하다.

제5장
기본문제

해설

◎ 통정허위표시[허위표시, 가장매매](제108조)

의 의	상대방과 통정하여 하는 진의 아닌 의사표시를 말한다.
요 건	㉠ 의사표시 존재 ㉡ 표시와 진의의 불일치 ㉢ 표의자가 불일치를 인식 ㉣ 상대방과의 사이에 통정이 있어야 한다.
효 과	당사자 사이에는 언제나 무효이다.
제3자 관계	㉠ 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다. ㉡ 선의의 제3자로부터 악의의 전득자에게 양도되었을 때에도 대항하지 못한다. ㉢ 제3자가 당사자에게 무효를 주장하는 것은 무방하다. ㉣ 증명책임은 제3자가 악의라는 사실(무효)을 주장하는 자에게 있다. ㉤ 허위표시는 당사자 간에는 철회할 수 있으나 선의의 제3자에게는 대항할 수 없다.
적용범위	㉠ 상대방 없는 단독행위는 적용의 여지가 없다. ㉡ 가족법상의 신분행위에는 적용되지 않는다.

정답: ⑤

민법 제108조 제2항의 통정허위표시에서의 '제3자'에 속하지 않는 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 가장매매에 기한 부동산매수인으로부터 그 부동산을 다시 사고 소유권이전등기를 받은 사람
- ㉡ 가장양수인으로부터 저당권을 설정 받은 자
- ㉢ 가장양수인으로부터 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가등기를 경료 받은 자
- ㉣ 허위로 체결된 제3자를 위한 계약의 수익자
- ㉤ 가장매매의 목적물을 압류한 그 매수인의 금전채권자

해설

㉣ 민법 제108조 제2항의 '제3자'란 당사자와 그의 포괄승계인 이외에 허위표시행위를 기초로 별개의 법률원인에 의하여 새로운 법률상의 이해관계를 맺은 자를 말한다. 따라서 제3자를 위한 계약에서의 수익자는 이에 해당하지 않는다.

(1) 제3자에 해당하는 자

- ㉠ 가장매매의 매수인으로부터 가등기를 취득한 자, 저당권을 설정 받은 자, 목적물의 임대차계약을 체결한 자
- ㉡ 가장저당권설정행위에 기한 저당권의 실행으로 경락 받은 자
- ㉢ 가장매매에 기한 대금채권의 양수인
- ㉣ 가장소비대차에 기한 채권의 양수인
- ㉤ 허위표시에 의한 채권을 가압류한 자
- ㉥ 가장매매의 매수인에 대한 압류채권자
- ㉦ 가장전세권설정에 기한 전세권저당권자
- ㉧ 파산자와는 독립한 지위에서 파산채권자 전체의 공동의 이익을 위하여 직무를 행하게 된 파산관재인

(2) 제3자에 해당하지 않는 자

- ㉠ 가장매매에 기한 손해배상청구권의 양수인
- ㉡ 채권의 가장양도에 있어서의 채무자
- ㉢ 주식을 가장양도하여 양수인 앞으로 명의개서한 경우의 그 주식회사
- ㉣ 가장매매의 매수인으로부터 그 지위를 상속받은 자
- ㉤ 저당권을 가장포기한 경우의 후순위저당권자
- ㉥ 제3자를 위한 계약에서의 제3자(수익자)
- ㉦ 채권의 가장 양수인으로부터 '추심'을 위하여 채권을 양수한 자 정답: ㉣

05 통정허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 기초로 하여 '새로운 법률상 이해관계를 맺은 제3자'에 해당하지 않는 자는? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2021' 감정평가사]

- ① 가장전세권에 관하여 저당권을 취득한 자
- ② 가장소비대차에 기한 대여금채권을 양수한 자
- ③ 가장저당권 설정행위에 기한 저당권의 실행에 의하여 목적부동산을 경락받은 자
- ④ 가장의 채권양도 후 채무가 변제되지 않고 있는 동안 채권양도가 허위임이 밝혀진 경우에 있어서의 채무자
- ⑤ 가장소비대차의 대주(貸主)가 파산한 경우, 파산자와는 독립한 지위에서 파산채권자 전체의 공동의 이익을 위하여 직무를 행하게 된 파산관재인

해설

④ 채권의 가장양도에 있어서의 채무자는 제108조 제2항의 '제3자'에 해당하지 아니한다. 정답: ④

06 통정허위표시를 기초로 새로운 법률상 이해관계를 맺은 제3자에 해당하지 않는 자는? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2020' 공인중개사]

- ① 가장채권을 가압류한 자
- ② 가장전세권에 저당권을 취득한 자
- ③ 채권의 가장양도에서 변제 전 채무자
- ④ 파산선고를 받은 가장채권자의 파산관재인
- ⑤ 가장채무를 보증하고 그 보증채무를 이행한 보증인

해설

③ 채권의 가장양도에 있어서의 채무자는 제108조 제2항의 '제3자'에 해당하지 아니한다. 정답: ③

07 비진의 의사표시의 요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 의사표시가 존재하여야 한다.
- ② 표의자의 진의와 표시가 일치하지 않아야 한다.
- ③ 표의자가 진의와 표시의 불일치를 알지 못하여야 한다.
- ④ 표의자가 의사표시를 하는 이유나 동기는 묻지 않는다.
- ⑤ 여기서 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말한다.

해설

- ③ 비진의 의사표시란 표의자가 자신의 의사(진의)와 표시가 불일치하는 것을 알면서 하는 의사표시를 말한다.
- ⑤ 비진의표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지, 표의자가 진정으로 마음속으로 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니다(대법원 1993.7.16., 92 다41528). 정답: ③

08

다음은 허위표시에 관한 설명이다. 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표의자의 의사를 단지 상대방이 알고 있는 경우에도 허위표시에 해당한다.
- ② 허위표시의 당사자 사이에서는 원칙적으로 유효하다.
- ③ 허위표시에 의하여 이루어지는 법률행위를 가장행위(假裝行爲)라 하고, 가장행위 속에 숨겨져 있는 법률행위를 은닉행위라고 한다. 가장행위는 언제나 무효이나, 은닉행위는 개별요건을 구비한 경우 유효하다.
- ④ 당사자 사이에서 허위표시에 기해 이행을 한 경우에는 이는 불법원인급여에 해당하므로 당사자 간에는 부당이득반환을 청구할 수 없다.
- ⑤ 허위표시는 무효에 해당하므로 당사자 사이에 철회도 허용되지 않는다.

해설

- ① 허위표시는 상대방과의 통정이 필요하다. 따라서 단지 상대방이 표의자의 의사를 알고 있는 것(악의)만으로는 부족하다. 이러한 경우에는 진의 아닌 의사표시에 해당한다.
- ② 허위표시는 당사자 사이에서는 언제나 무효이다.
- ④ 허위표시의 무효는 제103조 위반의 반사회질서행위는 아니므로 불법원인급여에서의 불법이 아니다. 따라서 당사자 간에는 부당이득반환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 당사자 사이에 철회가 허용된다. 정답: ③

09

착오에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표의자의 중대한 과실로 착오가 있는 때에는 표의자는 착오를 이유로 그 의사표시를 취소하지 못한다.
- ② 부동산 매매에 있어서 시가에 관한 착오는 일반적으로 중요부분에 관한 착오라고 할 수 없다.
- ③ 착오에 의하여 출연한 재단법인의 설립자는 착오를 이유로 출연의 의사표시를 취소할 수 있다.
- ④ 동기의 착오가 상대방에 의하여 유발된 경우에 동기의 표시여부와 무관하게 의사표시를 취소할 수 있다.
- ⑤ 매도인이 매매계약을 적법하게 해제하였다면 매수인은 그 해제로 인한 불이익을 피하기 위하여 더 이상 착오를 이유로 그 매매계약을 취소할 수 없다.

해설

- ⑤ 매도인이 매수인의 중도금 미지급을 이유로 매매계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인으로서의 착오를 이유로 하여 취소권을 행사하여 매매계약 전체를 무효로 돌릴 수 있다(대법원 1991.8.27., 91다11308). 정답: ⑤

12

착오로 인한 의사표시에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 착오가 표의자의 경과실로 생긴 때에도 표의자는 착오를 이유로 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ② 임차인이 목적물을 임대인의 소유인 것으로 착각하여 임차한 경우, 특별한 사정이 없는 한 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있다고 할 수 없다.
- ③ 시가(時價)에 관한 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 있음이 원칙이다.
- ④ 착오를 이유로 의사표시가 취소된 경우, 이로 인해 상대방에게 손해가 발생한 때에도 불법행위가 성립하지 않는다.
- ⑤ 토지의 현황·경계에 관한 착오는 법률행위 내용의 중요부분의 착오에 해당할 수 있다.

해설

- ③ 시가보다 저렴한 가격으로 양도계약을 체결한 것이라 하더라도 그것은 의사결정의 동기의 착오는 될 수 있을지언정 법률행위의 중요부분의 착오가 있는 경우로는 볼 수 없다(대법원 1984.4.10, 81다239).
- ① 의사표시가 착오에 해당하고 중요부분에 해당한다 하더라도, 표의자에게 중과실이 있으면 취소할 수 없다(제109조 제1항 단서). 따라서 표의자에게 경과실만 있는 경우에는 취소할 수 있다.
- ② 타인소유의 부동산을 임대한 것이 임대차계약을 해지할 사유는 될 수 없고 목적물이 반드시 임대인의 소유일 것을 특히 계약의 내용으로 삼은 경우라야 착오를 이유로 임차인이 임대차계약을 취소할 수 있다(대법원 1975.1.28, 74다2069).
- ④ 전문건설공제조합의 계약보증서 발급에 과실이 있는 경우, 과실로 착오에 빠져 보증계약을 발급한 것이나 그 착오를 이유로 보증계약을 취소한 것이 불법행위를 구성하지 않는다(대법원 1997.8.22, 97다13023).
- ⑤ 토지의 현황·경계에 관한 착오는 매매계약의 중요한 부분에 대한 착오이다(대법원 1974.4.23., 74다54). 정답: ③

13

의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 진의가 아님을 상대방이 알 수 있었던 비진의표시는 무효이다.
- ② 표의자가 과실없이 상대방을 알지 못한 경우, 의사표시는 민사소송법 공시송달의 규정에 의해 송달할 수 있다.
- ③ 대리행위에서 착오가 있는지의 여부는 본인을 기준으로 판단하는 것이 원칙이다.
- ④ 제3자의 사기에 의한 의사표시에 표의자의 상대방이 그 사실을 알 수 있었다면 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ⑤ 통정허위표시로 계약을 체결한 자는 선의로 그 계약에 기한 채권을 가압류한 자에게 그 무효로 대항할 수 없다.

해설

- ① 진의가 아님을 상대방이 알았거나 알 수 있었던 비진의표시는 무효이다(제107조 제1항).
- ② 표의자가 과실없이 상대방을 알지 못하거나 상대방의 소재를 알지 못하는 경우에는 의사표시는 민사소송법 공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다(제113조).
- ③ 대리행위에 착오가 있는 경우 대리행위는 원칙적으로 대리인을 표준으로 하므로 대리인을 기준으로 판단하는 것이 원칙이다. 즉, 법률행위를 하는 자는 대리인이므로 의사의 흠결(비진의표시·허위표시·착오)·사기·강박 또는 어떤 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받아야 할 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준으로 하여 결정한다(제116조 제1항).
- ④ 상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 행한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있다(제110조 제2항).
- ⑤ 통정허위표시로 계약을 체결한 자는 선의로 그 계약에 기한 채권을 가압류한 자에게 그 무효로 대항할 수 없다. 선의의 제3자에 해당하기 때문이다. 정답: ③

- ① 사기와 의사표시 사이에 인과관계가 없어도 사기를 이유로 의사표시를 취소할 수 있다.
- ② 제3자의 기망행위에 의하여 신원보증서류에 서명날인한다는 착각에 빠진 상태로 연대보증 계약서에 서명날인한 경우, 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 없다.
- ③ 의사표시 상대방의 사기에 의하여 법률행위의 중요부분에 착오가 생긴 때에는 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 없다.
- ④ 고지·설명 의무가 있는 경우 소극적으로 진실을 숨기는 것만으로는 기망행위가 될 수 없다.
- ⑤ 제3자의 사기로 목적물을 헐값에 매도한 경우, 매수인이 제3자의 사기를 알 수 없었던 때에는 매도인은 그 의사표시를 취소할 수 없다.

해설

- ⑤ 상대방 있는 의사표시에서 상대방이 제3자의 사기나 강박을 알았거나 또는 알 수 있었을 때에 한하여 취소할 수 있다(제110조 제2항). 여기서의 선의·악의·과실의 유무는 의사표시 당시를 기준으로 한다. 따라서 매수인이 제3자의 사기를 알 수 없었던 때에는 매도인은 그 의사표시를 취소할 수 없다.
- ① 기망행위와 착오 및 의사표시 사이에 인과관계가 있어야 한다. 인과관계는 피기망자의 주관적인 것으로 족하다. 다만, 착오는 내심적 효과의사를 결정하는 동기에 관한 것으로 충분하다.
- ② 기망행위에 의해 서면 내용을 착각하고 서명날인을 한 경우에는 착오취소만 가능하다. 사기에 의한 의사표시란 타인의 기망행위로 말미암아 착오에 빠지게 된 결과 어떠한 의사표시를 하게 되는 경우이므로 거기에는 의사와 표시의 불일치가 있을 수 없고, 단지 의사의 형성과정 즉 의사표시의 동기에 착오가 있는 것에 불과하며, 이 점에서 고유한 의미의 착오에 의한 의사표시와 구분되는 데, 신원보증서류에 서명날인한다는 착각에 빠진 상태로 연대보증의 서면에 서명날인한 경우, 결국 위와 같은 행위는 강박상 기명날인의 착오(또는 서명의 착오), 즉 어떤 사람이 자신의 의사와 다른 법률효과를 발생시키는 내용의 서면에, 그것을 읽지 않거나 올바르게 이해하지 못한 채 기명날인을 하는 이른바 표시상의 착오에 해당하므로, 비록 위와 같은 착오가 제3자의 기망행위에 의하여 일어난 것이라 하더라도 그에 관하여는 사기에 의한 의사표시에 관한 법리, 특히 상대방이 그러한 제3자의 기망행위 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우가 아닌 한 의사표시자가 취소권을 행사할 수 없다는 「민법」 제110조 제2항의 규정을 적용할 것이 아니라, 착오에 의한 의사표시에 관한 법리만을 적용하여 취소권 행사의 가부를 가려야 한다(대법원 2005.5.27, 2004다43824).
- ③ 상대방의 사기에 의하여 법률행위의 중요부분에 착오가 생긴 때에는 사기를 이유로 취소할 수도 있고, 착오를 이유로도 취소할 수 있다(사기와 착오의 경합). 상대방의 기망에 의해 착오가 유발된 경우 사기취소와 착오취소는 경합가능하다(대법원 1969.6.24, 68다1749).
- ④ 기망행위란 적극적으로 허위의 사실을 날조하는 것뿐만 아니라 소극적으로 진실한 사실을 숨기는 것과 단순한 침묵도 기망행위가 될 수 있다. 임차권 양도에 관한 임대인의 동의 여부 및 임대차 재계약 여부에 대한 설명 없이 임차권을 양도한 것은 기망행위에 해당한다(대법원 1996.6.14., 94다41003). 정답: ⑤

15 사기 또는 강박에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부정행위에 대한 고소·고발도 강박행위가 될 수 있다.
- ② 사기에 의한 의사표시가 성립하기 위해서는 기망행위가 위법하여야 한다.
- ③ 중요한 구체적 사실을 신의성실의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위 고지한 상품 선전 행위는 기망행위가 될 수 있다.
- ④ 특별한 사정이 없는 한 교환계약의 당사자가 자기 소유 목적물의 시가를 묵비하더라도 기망행위가 되지 않는다.
- ⑤ 제3자의 사기·강박에 의하여 상대방 있는 의사표시를 한 자는 상대방이 그 사실을 알았던 때에 한하여 취소할 수 있다.

해설

- ⑤ 제3자의 사기·강박에 의하여 상대방 있는 의사표시를 한 자는 상대방이 그 사실을 알았던 때에 한하여 취소할 수 있는 게 아니라 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 취소할 수 있다(제110조 제2항). 정답: ⑤

16 사기에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 사기를 이유로 법률행위를 취소하면 그 법률행위는 소급하여 무효로 된다.
- ② 상대방의 대리인의 사기로 의사표시를 한 경우, 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었는지의 여부에 관계없이 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ③ 사기에 의한 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못하는데 이 경우 제3자는 스스로 자기가 선의임을 증명하여야 한다.
- ④ 부작위나 침묵도 경우에 따라서는 기망행위가 될 수 있다.
- ⑤ 기망행위는 불법행위를 이유로 한 손해배상청구권을 발생시킬 수도 있다.

해설

- ③ 제3자는 선의로 추정되므로 악의에 대한 증명책임은 무효나 취소를 주장하는 자에게 있다(대법원 2006.3.10. 2002다1321).
- ② 상대방의 대리인은 제3자에 해당하지 않고 상대방과 동일한 자이므로 상대방과의 계약에 있어서 그 상대방의 대리인으로부터 기망을 당했다면, 상대방이 그 사기 사실을 알았는지 여부와 관계없이 취소할 수 있다(대법원 1999.2.23. 98다60828).
- ④ 침묵도 부작위에 의한 기망행위가 된다. 예컨대, 침수차량임을 숨기는 것, 무허가건물이라는 것, 토지가 도시계획선에 걸려 있다는 것을 침묵하는 것은 사기에 해당한다(대법원 1971.5.24. 70다 2878).
- ⑤ 사기·강박이 불법행위의 요건을 갖춘 때에는 취소와 아울러 불법행위에 기한 손해배상청구권을 행사할 수 있지만 불법행위를 이유로 손해배상을 청구하기 위하여 반드시 그 의사표시를 취소하여야 하는 것은 아니다(대법원 1999.3.10., 97다55829). 정답: ③

17 甲은 고층아파트를 짓기 위해 乙 소유의 토지를 매입하기로 하는 계약을 체결하고 계약금을 주었으나, 그 부동산은 법령상의 제한으로 고층아파트를 건축할 수 없는 토지였다. 한편 甲·乙 간의 계약서에 이 토지의 용도가 '주택건설용지'로 기재된 사실은 있지만 어떤 규모나 형태의 주택을 건설할지에 대한 언급은 없으며, 乙은 甲의 구체적인 건축계획을 모르는 상황이다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲·乙 간의 매매계약은 유효하다.
- ② 甲·乙 간의 매매계약은 원시적 불능에 해당하여 무효이다.
- ③ 甲은 표시상의 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다.
- ④ 甲은 사기에 의한 계약이라는 이유로 매매계약을 취소할 수 있다.
- ⑤ 甲이 중도금과 잔금을 지급하지 않았다고 하여 乙이 매매계약을 해제할 수는 없다.

해설

- ① 토지를 매수하였으나 관계법령상의 제한으로 건물을 짓지 못하는 경우 판례는 이는 단순한 동기의 착오에 지나지 않으므로 계약을 취소할 수 없다고 판시하고 있다. 따라서 토지매매계약은 유효하다 (대법원 1984.10.23., 83다카1187). 정답: ①

18 채무자가 보증인을 기망하여 보증계약을 체결한 경우, 그 계약에 관한 보증인의 주장 중 맞는 것은?

- ① 채무자에게 착오를 이유로 하여 취소를 주장할 수 있다.
- ② 채무자에게 기망사실을 이유로 하여 취소를 주장할 수 있다.
- ③ 채권자가 기망사실을 알았을 때 취소할 수 있다.
- ④ 채권자에게 기망사실을 이유로 하여 취소를 주장할 수 있다.
- ⑤ 보증계약은 유효하여 취소할 수 없다.

해설

- ③ 보증계약은 채권자와 보증인이 체결하고, 채무자는 그에 대하여 제3자에 해당하므로 제3자인 채무자가 사기·강박을 행한 경우에는 상대방(채권자)이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 취소할 수 있다. 정답: ③

19 의사표시에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 착오를 이유로 법률행위를 취소하기 위해서는 상대방이 표의자의 착오를 알았거나 알 수 있었어야 한다.
- ② 강박의 정도가 심하여 표의자의 의사결정의 자유가 완전히 박탈된 상태에서 한 의사표시는 무효이다.
- ③ 통정허위표시의 무효로 대항할 수 없는 제3자에게는 허위표시를 한 당사자의 상속인도 포함된다.
- ④ 각서에 서명 날인할 것을 강력히 요구하였다는 것만으로도 강박이 될 수 있다.
- ⑤ 사기나 강박에 의한 의사표시는 의사와 표시의 불일치가 있는 것이다.

해설

- ② 상대방 또는 제3자의 강박에 의하여 의사결정의 자유가 완전히 박탈된 상태에서 이루어진 의사표시는 효과의사에 대응하는 내심의 의사가 결여된 것이므로 무효이다.
- ① 착오를 이유로 법률행위를 취소하기 위해서는 상대방이 표의자의 착오를 알았거나 알 수 있었을 필요가 없다. 즉, 착오취소 요건을 갖추면 표의자는 법률행위를 취소할 수 있다(제109조)
- ③ 통정허위표시의 무효로 대항할 수 없는 제3자는 허위표시의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자를 말하므로 허위표시를 한 당사자의 상속인은 제3자에 포함되지 않는다(대법원 1982.5.25, 80다1403).
- ④ 각서에 서명 날인할 것을 강력히 요구하였다는 것만으로는 강박이 되지 않는다는 것이 판례이다.
- ⑤ 사기나 강박에 의한 의사표시는 표의자의 의사와 표시는 일치하지만 의사의 형성과정에 하자(사기·강박)가 있는 것을 말한다. 정답: ②

20 다음 중 의사표시에 있어서의 도달주의의 예외인 발신주의에 해당하지 않는 것은?

- ① 제한능력자의 상대방의 최고에 대한 법정대리인의 확답
- ② 격지자 계약에 있어서 승낙
- ③ 사원총회 소집의 통지
- ④ 무권대리인의 상대방의 최고에 대한 본인의 확답
- ⑤ 대화자 계약에 있어서 승낙

해설

- ⑤ 민법은 상대방 있는 의사표시에 대하여 원칙적으로 도달주의의 입장을 취하고 있다. 다만, 특별한 경우에는 예외적으로 발신주의를 취하고 있다.
- ㉠ 민법상 발신주의 적용의 예
- ㉡ 제한능력자의 상대방의 최고에 대한 법정대리인 등의 확답(제15조)
- ㉢ 제3자와 채무자와의 계약으로 인한 채무인수의 경우에 채무자의 승낙의 최고에 대한 채권자의 승낙(제455조)
- ㉣ 사원총회 소집의 통지(제71조)
- ㉤ 무권대리인의 상대방의 최고에 대한 본인의 확답(제131조)
- ㉥ 격지자 사이에서의 계약의 승낙의 통지(제531조) 정답: ⑤

21 의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에 도달한 때로부터 그 효력이 생긴다.
- ② 표의자가 의사표시를 발한 후 행위능력을 상실하더라도 그 의사표시의 효력에 영향을 미치지 않는다.
- ③ 의사표시의 발신자는 도달 후에도 상대방의 이행착수 전에는 그 의사표시를 철회할 수 있다.
- ④ 격자지간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다.
- ⑤ 상대방이 의사표시를 수령할 때 상대방이 제한능력자인 경우 표의자는 그 의사표시로서 상대방에게 대항하지 못한다.

해설

- ③ 의사표시는 발신 후 도달하기 전에는 그 의사표시를 철회할 수 있지만 의사표시가 도달한 후에는 상대방이 요지하기 전이라도 이를 철회할 수 없다. 정답: ③

22 甲이 의사표시를 발송했는데 그 의사표시가 도달하기 전에 상대방 乙이 행위능력을 상실하였다. 이 경우 맞는 설명은?

- ① 甲은 의사표시의 도달을 주장할 수 있다.
- ② 이 경우 의사표시는 자동적으로 철회된다.
- ③ 乙은 의사표시의 도달을 주장할 수 없다.
- ④ 甲은 乙의 법정대리인이 그 도달을 안 후에는 그 의사표시의 효력을 주장할 수 있다.
- ⑤ 甲과 乙 모두 의사표시의 도달을 주장할 수 있다.

해설

- ①⑤ 의사표시를 제한능력자가 수령한 경우에는 표의자는 도달을 주장하지 못한다.
 ②③ 제한능력자가 의사표시의 도달을 주장하는 것은 무방하다.
 ④ 타당한 기술이다. 정답: ④

01

진의 아닌 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 남편을 안심시키려는 고객의 요청에 따라 증권회사 직원이 증권투자로 인한 고객의 손해에 대하여 책임을 지겠다는 내용의 각서를 고객에게 작성하여 주었다면, 이는 진의 아닌 의사표시로서 무효이다.
- ② 공무원이 사직의 의사표시를 하여 의원면직처분이 된 경우, 내심의 의사가 사직할 뜻이 아니었더라도 그 면직처분은 유효하다.
- ③ 진의 아닌 의사표시에서 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 뜻하는 것이 아니고, 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것이다.
- ④ 진의 아닌 의사표시 규정은 대리인이 배임적 대리행위를 한 경우에 유추적용될 수 있다.
- ⑤ 진의 아닌 의사표시라는 이유로 무효를 주장하는 경우, 증명책임은 무효를 주장하는 자에게 있다.

해설

- ③ 비진의 의사표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니라고 할 것이므로, 비록 재산을 강제로 빼긴다는 것이 표의자의 본심으로 잠재되어 있었다 하여도 표의자가 강박에 의하여서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 것이라고 할 수는 없다(대법원 2002.12.27., 2000다47361). 정답: ③

02

진의 아닌 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 사인의 공법행위에는 진의 아닌 의사표시의 무효에 관한 규정이 적용되지 않는다.
- ② 진의 아닌 의사표시로서 무효가 되는 경우에 그 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.
- ③ 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 바라지는 않았더라도, 당시 상황에서는 그것을 최선이라고 판단하여 의사표시를 하였다면, 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없다.
- ④ 재산을 강제로 빼앗긴다는 것이 표의자의 본심에 잠재되어 있었다 하여도 표의자가 강박에 의하여 증여의 의사표시를 한 이상, 그 의사표시는 진의 아닌 의사표시라고 할 수 없다.
- ⑤ 진의 아닌 의사표시에서 진의는 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 말한다.

해설

- ③④⑤ 비진의 의사표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니라고 할 것이므로, 비록 재산을 강제로 빼앗긴다는 것이 표의자의 본심으로 잠재되어 있었다 하여도 표의자가 강박에 의하여서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 것이라고 할 수는 없다(대법원 2002.12.27., 2000다47361).
- ① 공법상의 의사표시에는 제107조의 적용이 없다. 판례는 이른바 1980년의 공직자속정계획의 일환으로 일괄사표의 제출과 선별수리의 형식으로 '공무원'에 대한 의원면직처분이 이루어진 사안에 관하여 비진의표시에 관한 제107조는 사인의 공법행위에 적용되지 않는다는 이유로 그 의원면직처분을 당연무효라고 할 수 없다고 한다(대법원 2001.8.24., 99두9971).
- ② 진의 아닌 의사표시로서 무효가 되는 경우에 그 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다(제107조 제1항 단서). 정답: ⑤

03 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 통정허위표시에서 파산관재인은 제3자에 해당하지 않는다.
- ② 통정허위표시에서 제3자가 보호받기 위해서는 선의이면 되고 그 과실 유무는 묻지 않는다.
- ③ 상대방에 의해 유발된 동기의 착오는 동기가 표시되지 않았더라도 법률행위 내용의 중요부분의 착오가 될 수 있다.
- ④ 통정허위표시는 제3자 유무와 상관없이 당사자 사이에서는 무효이다.
- ⑤ 사기에 의한 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

해설

- ① 채무자(파산자)가 가장채권의 보유 중에 파산선고된 경우의 파산관재인은 제3자에 해당한다.

정답: ①

04 다음은 허위표시에 관한 설명이다. 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표의자의 의사를 단지 상대방이 알고 있는 경우에도 허위표시에 해당한다.
- ② 허위표시의 당사자 사이에서는 원칙적으로 유효하다.
- ③ 허위표시에 의하여 이루어지는 법률행위를 가장행위(假裝行爲)라 하고, 가장행위 속에 숨겨져 있는 법률행위를 은닉행위라고 한다. 가장행위는 언제나 무효이나, 은닉행위는 개별요건을 구비한 경우 유효하다.
- ④ 당사자 사이에서 허위표시에 기해 이행을 한 경우에는 이는 불법원인급여에 해당하므로 당사자 간에는 부당이득반환을 청구할 수 없다.
- ⑤ 허위표시는 무효에 해당하므로 당사자 사이에 철회도 허용되지 않는다.

해설

- ① 허위표시는 상대방과의 통정이 필요하므로 단지 상대방이 표의자의 의사를 알고 있는 것(악의)만으로는 진의 아닌 의사표시에 해당한다.
- ② 허위표시는 당사자 사이에서는 언제나 무효이다.
- ④ 허위표시의 무효는 제103조 위반의 반사회질서행위는 아니므로 불법원인급여에서의 불법이 아니다. 따라서 당사자 간에는 부당이득반환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 당사자 사이에 철회가 허용된다. 정답: ③

07 통정허위표시에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 통정허위표시란 상대방과 통정하여서 하는 진의 아닌 거짓의 의사표시를 말한다.
- ② 선의의 제3자에게는 통정허위표시의 무효를 주장할 수 없지만, 이때 제3자가 무과실이어야 할 필요는 없다.
- ③ 채무자의 법률행위가 통정허위표시인 경우에는 채권자취소권의 대상이 될 수 없다.
- ④ 실제로 어음상의 권리를 취득하게 할 의사 없이 단지 채권자들에 의한 채권의 추심이나 강제집행을 피하기 위한 약속어음발행행위는 통정허위표시가 된다.
- ⑤ 기존 채권을 우선변제받기 위하여 그 채권을 임대차 보증금으로 하고 주택임대차로서의 대항력을 취득한 것처럼 외관을 만들었을 뿐 실제 주택을 사용·수익할 목적을 갖지 아니한 주택임대차계약은 통정허위표시에 해당한다.

해설

- ③ 통정허위표시도 채권자취소권의 대상이 될 수 있다는 것이 판례의 입장이다. 정답: ③

08 허위표시에 관한 다음 기술 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 파산자가 상대방과 통정한 허위의 의사표시에 의해 성립한 가장채권을 보유하고 있다가 파산이 선고된 경우, 파산관재인은 그 허위표시에 따라 외형상 형성된 법률관계를 기초로 새로운 법률상 이해관계를 가지게 된 제108조 제2항의 제3자에 해당한다.
- ② 강제집행을 면할 목적으로 타인과 합의하여 그의 명의로 소유권이전등기를 한 경우에는 허위표시로서 처리되며 따로 불법원인급여 규정(제746조)의 적용은 없다.
- ③ 통정허위표시에 의한 매수인으로부터 부동산의 권리를 취득한 제3자는 선의로 추정되므로 제3자가 악의라는 사실의 주장·증명책임은 그 무효를 주장하는 자에게 있다.
- ④ 선의의 제3자로부터 전득한 자가 악의인 경우에는 허위표시의 무효로써 그에게 대항할 수 있다.
- ⑤ 허위표시는 사해행위의 취소의 대상이 될 수 있다.

해설

- ④ 허위표시는 무효이지만 이로써 선의의 제3자에게 대항하지 못하는데, 선의의 제3자로부터 전득한 자가 악의이더라도 그는 이미 선의의 제3자의 권리를 승계하였으므로 그는 유효하게 권리를 취득한다.
- ① 대법원 2003.6.2. 2002다48214
 ② 대법원 1994.4.15. 93다61307
 ③ 판례는 제3자는 특별한 사정이 없는 한 선의로 추정되므로, 따라서 허위표시를 한 부동산 양도인이 제3자에 대하여 소유권을 주장하려면 그 제3자가 악의임을 증명하여야 한다고 한다.
 ⑤ 대법원 1988.4.28. 87다카1380 정답: ④

- ① 甲과 乙이 내부적으로는 증여의 의사를 가지고 계약을 체결하였으나 매매계약의 형식을 빌린 경우, 증여계약의 효력이 발생할 수 있다.
- ② 통정한 허위표시에 의하여 형성된 법률관계로 생긴 채권을 가압류한 채권자가 있는 경우, 그 가압류채권자가 선의라 하더라도, 그에게 허위표시의 무효를 가지고 대항할 수 있다.
- ③ 선의의 제3자에게는 허위표시의 무효를 주장할 수 없지만, 이때 제3자가 무과실이어야 할 필요는 없다.
- ④ 가장매매의 매도인은 매수인의 상속인이 그 허위표시에 대하여 선의라 하더라도, 그에게 허위표시의 무효를 가지고 대항할 수 있다.
- ⑤ 토지거래허가 구역 내 토지거래계약이 허위표시에 의하여 이루어진 경우, 거래당사자는 거래허가 신청 전(前)단계에서 허위표시임을 주장하여 거래허가 신청협력에 대한 거절의사를 명백히 함으로써 계약을 확정적으로 무효화시키고, 자신의 거래허가절차에 협력할 의무를 면할 수 있다.

해설

- ② 통정허위표시의 무효를 대항할 수 없는 제3자인 허위표시의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서 허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 토대로 새로운 법률원인으로써 이해관계를 갖게 된 자를 말한다.
- ① 증여의 의사는 은닉행위에 해당하되, 은닉행위는 다른 행위를 할 의사가 있으므로 보통의 허위표시로 취급할 것이 아니라, 그 감추어진 행위로서의 요건을 갖추었느냐에 따라 그 효력을 결정하면 된다.
- ③ 제108조 제2항은 선의의 제3자에게 무과실을 요구하지 않으므로 선의만으로도 충분하다고 한다.
- ④ 매수인의 상속인은 매수인의 포괄승계인으로서 제3자에 해당하지 않으므로 대항할 수 있게 된다.
- ⑤ 구 국토이용관리법상 규제구역 내에 속하는 토지거래에 관하여 관할 도지사로부터 거래허가를 받지 아니한 거래계약은 처음부터 위 허가를 배제하거나 잠탈하는 내용의 계약이 아닌 한 허가를 받기까지는 유동적 무효의 상태에 있고 거래당사자는 거래허가를 받기 위하여 서로 협력할 의무가 있으나, 그 토지거래가 계약 당사자의 표시와 불일치한 의사(비진의표시, 허위표시 또는 착오) 또는 사기, 강박과 같은 하자 있는 의사에 의하여 이루어진 경우에는, 이들 사유에 의하여 그 거래의 무효 또는 취소를 주장할 수 있는 당사자는 그러한 거래허가를 신청하기 전 단계에서 이러한 사유를 주장하여 거래허가신청 협력에 대한 거절의사를 일방적으로 명백히 함으로써 그 계약을 확정적으로 무효화시키고 자신의 거래허가절차에 협력할 의무를 면할 수 있다(대법원 1997.11.14. 97다36118). 정답: ②

- ① 교환계약의 당사자가 자기 소유 목적물의 시가를 묵비하였다면 특별한 사정이 없는 한, 위법한 기망행위가 성립한다.
- ② 강박에 의해 자유로운 의사결정의 여지가 완전히 박탈되어 그 외형만 있는 법률행위라고 하더라도 이를 무효라고 할 수는 없다.
- ③ 토지거래허가를 받지 않아 유동적 무효 상태에 있는 법률행위라도 사기에 의한 의사표시의 요건이 충족된 경우 시가를 이유로 취소할 수 있다.
- ④ 대리인의 기망행위로 계약을 체결한 상대방은 본인이 대리인의 기망행위에 대해 선의 · 무과실이면 계약을 취소할 수 없다.
- ⑤ 강박행위의 목적이 정당한 경우에는 비록 그 수단이 부당하다고 하더라도 위법성이 인정될 여지가 없다.

해설

③ 대법원 1997.11.14. 97다36118

- ① 일방 당사자가 자기가 소유하는 목적물의 시가를 묵비하여 상대방에게 고지하지 아니하거나 혹은 허위로 시가보다 높은 가액을 시가라고 고지하였다 하더라도 이는 상대방의 의사결정에 불법적인 간섭을 한 것이라고 볼 수 없다. 즉 위법성 있는 기망행위라고 볼 수 없다(대법원 2002.09.04. 2000다54406).
- ② 강박에 의한 법률행위가 하자 있는 의사표시로서 취소되는 것에 그치지 않고, 나아가 무효로 되기 위하여는 강박의 정도가 단순한 불법적 해약의 고지로 상대방으로 하여금 공포를 느끼도록 하는 정도가 아니고, 의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어져 단지 법률행위의 외형만이 만들어진 것에 불과한 정도이어야 한다(대법원 2003.05.13. 2002다73708).
- ④ 대리인의 기망행위는 곧 본인의 기망행위로 본다. 따라서 상대방은 본인에 대하여 계약을 취소할 수 있다.
- ⑤ 강박행위가 위법하다고 하기 위하여는, 강박행위 당시의 거래관념과 제반 사정에 비추어 해약의 고지로써 추구하는 이익이 정당하지 아니하거나 강박의 수단으로 상대방에게 고지하는 해약의 내용이 법질서에 위배된 경우 또는 어떤 해약의 고지가 거래관념상 그 해약의 고지로써 추구하는 이익의 달성을 위한 수단으로 부적당한 경우 등에 해당하여야 한다(대법원 2000.03.23. 99다64049). 정답: ③

13 착오로 인한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 매도인의 하자담보책임이 성립하더라도 착오를 이유로 한 매수인의 취소권은 배제되지 않는다.
- ② 계약 당시를 기준으로 하여 장래의 미필적 사실의 발생에 대한 기대나 예상이 빗나간 경우, 착오취소는 인정되지 않는다.
- ③ 동기의 착오는 동기가 표시되어 해석상 법률행위의 내용으로 된 경우에 한해서만 유일하게 고려된다.
- ④ 매매계약에서 매수인이 목적물의 시가에 관해 착오를 하였더라도 이는 원칙적으로 중요 부분의 착오에 해당하지 않는다.
- ⑤ 상대방이 표의자의 착오를 알면서 이용하였다면 표의자의 착오에 중대한 과실이 있더라도 착오취소가 인정된다.

해설

- ③ 동기를 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시한 경우에는 착오를 이유로 취소할 수 있다. 그러나, 표의자의 착오가 상대방에 의해 제공되었거나 유발된 경우에는, 동기의 표시여부를 묻지 않고 제109조를 적용하여 취소할 수 있다는 것이 판례의 태도이다. 정답: ③

14 민법 제109조의 착오에 의한 의사표시와 관련한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 중대한 과실이란 표의자의 직업, 행위의 종류, 목적 등에 비추어 보통 요구되는 주의를 현저히 결여하는 것을 의미한다.
- ② 매도인이 매매계약을 적법하게 해제한 경우에도 매수인은 이와 별도로 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다.
- ③ 부동산중개업자가 다른 점포를 매매목적물로 잘못 소개하여 매수인이 매매목적물에 관하여 착오를 일으킨 경우에는 매수인에게도 중대한 과실을 인정한다.
- ④ 공장을 경영하는 자가 공장이 협소하여 새로운 공장을 설립할 목적으로 토지를 매수하면서 토지상에 공장을 건축할 수 있는지 여부를 관할관청에 알아보지 않았다면 이는 중대한 과실에 해당한다.
- ⑤ 착오로 인하여 표의자가 경제적 불이익을 입은 것이 아니라면, 이를 법률행위 내용의 중요 부분의 착오라고 할 수 없다.

해설

- ③ 부동산중개업자가 다른 점포를 매매목적물로 잘못 소개하여 매수인이 매매목적물에 관하여 착오를 일으킨 경우, 매수인에게는 중대한 과실이 없다는 것이 판례의 태도이다(1997.11.28, 97다32772·97다32789). 정답: ③

15 착오에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 대리인에 의한 법률행위에서 착오의 유무는 대리인을 표준으로 판단한다.
- ② 착오의 존재 여부는 의사표시 당시를 기준으로 판단한다.
- ③ 착오에 의한 취소의 의사표시는 반드시 명시적이어야 하는 것은 아니고, 취소자가 그 착오를 이유로 자신의 법률행위의 효력을 처음부터 배제하려고 한다는 의사가 드러나면 충분하다.
- ④ 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 경우, 상대방이 표의자의 착오를 알고 이를 이용하였더라도, 표의자는 의사표시를 취소할 수 없다.
- ⑤ 착오를 이유로 법률행위를 취소한 표의자가 상대방에게 불법행위책임을 지는 것은 아니다.

해설

- ④ 민법 제109조 제1항 단서는 의사표시의 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 그 의사표시를 취소하지 못한다고 규정하고 있는데, 위 단서 규정은 표의자의 상대방의 이익을 보호하기 위한 것이므로, 상대방이 표의자의 착오를 알고 이를 이용한 경우에는 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 것이라고 하더라도 표의자는 의사표시를 취소할 수 있다(대법원 2014.11.27. 2013다49794). 정답: ④

16 착오로 인한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 채무자의 동일성에 관한 물상보증인의 착오는 법률행위 내용의 중요부분에 관한 착오에 해당하지 않는다.
- ② 착오로 의사표시를 취소한 자는 이로 인하여 상대방에 대해 불법행위책임을 지지 않는다.
- ③ 착오로 인하여 표의자가 경제적인 불이익을 입은 것이 아니라면 착오를 이유로 취소할 수 없다.
- ④ 특별한 사정이 없는 한 목적물의 시가에 관한 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 없다.
- ⑤ 동기의 착오가 상대방에 의해 유발된 경우 동기가 표시되지 않더라도 의사표시의 취소 사유인 착오에 해당할 수 있다.

해설

- ① 갑이 채무자란이 백지로 된 근저당권설정계약을 제시받고 그 채무자가 올인 것으로 알고 근저당권설정으로 서명날인을 하였는데 그 후 채무자가 병으로 되어 근저당권설정등기가 경료된 경우, 갑은 그 소유의 부동산에 관하여 근저당권설정계약상의 채무자를 병이 아닌 을로 오인한 나머지 근저당설정의 의사표시를 한 것이고, 이와 같은 채무자의 동일성에 관한 착오는 법률행위 내용의 중요부분에 관한 착오에 해당한다(대법원 1995.12.22. 95다37087). 정답: ①

17 착오(錯誤)로 인한 의사표시에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있더라도 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.
- ② 매도인이 매수인의 중도금 지급채무불이행을 이유로 매매계약을 적법하게 해제하면 위 매매계약은 소급적으로 그 효력을 상실하므로 그 후 매수인이 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 없다.
- ③ 부동산 매매에서 시가에 관한 착오는 원칙적으로 동기의 착오에 불과할 뿐 법률행위의 중요부분의 착오에 해당한다고 할 수 없다.
- ④ 동기의 착오를 이유로 법률행위를 취소할 수 있게 되는 요건으로서의 중요부분의 착오는, 표의자가 그 동기를 당해 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시하고 의사표시의 해석상 법률행위의 내용으로 되어 있다고 인정되면 충분하고, 당사자들 사이에 별도로 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의까지 이루어질 필요는 없다.
- ⑤ 화해계약은 화해당사자의 자격 또는 화해의 목적인 분쟁 이외의 사항에 착오가 있는 때가 아닌 한 착오를 이유로 하여 취소하지 못한다.

해설

- ② 매도인이 매수인의 중도금 지급채무 불이행을 이유로 매매계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인 으로서는 상대방이 한 계약해제의 효과로서 발생하는 손해배상책임을 지거나 매매계약에 따른 계약금의 반환을 받을 수 없는 불이익을 면하기 위하여 착오를 이유로 한 취소권을 행사하여 매매 계약 전체를 무효로 돌리게 할 수 있다.

① 제109조 제1항.

- ③ 부동산 매매에서 시가에 관한 착오는 그 부동산을 매매하려는 의사를 결정하는 데서 '동기의 착오'에 불과할 뿐, 법률행위의 중요부분에 관한 착오라고 할 수 없다. 시가는 변동할 뿐만 아니라, 거래목적물의 평가는 거래상의 일반적인 위험으로서 표의자가 그에 따른 위험을 상대방에게 전가 해서는 안 되기 때문이다.

④ 대법원 2000. 5. 12, 2000다12259.

⑤ 대법원 2005. 8. 19, 2004다53173. 정답: ②

18 착오에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 착오를 이유로 취소할 수 없다.
- ② 소취하 등 소송행위에도 민법상 사기 또는 착오로 인한 취소규정이 적용된다.
- ③ 계약당사자 쌍방이 계약의 기초가 되는 사항에 관하여 같은 내용으로 착오하여 그 사항에 관하여 약정하지 않은 경우 그 착오가 없었다면 약정하였을 내용으로 당사자의 의사를 보충할 수 있다.
- ④ 착오를 이유로 취소한 자는 이로 인하여 상대방에게 손해가 발생했더라도 불법행위책임을 부담하지 않는다.
- ⑤ 장래 도시계획이 변경되어 호텔의신축허가를 받을 수 있을 것이라고 스스로 생각하여 토지의 매매계약을 체결했으나 그 후 예상대로 되지 않은 경우 착오를 이유로 취소할 수 없다.

해설

- ② 공법상의 행위·소송행위에 대하여는 제109조가 적용되지 않는다. 정답: ②

19 착오에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 동기의 착오를 이유로 계약을 취소하기 위해서는 그 동기가 상대방에게 표시되고 의사표시 내용의 중요부분으로 인정될 수 있어야 한다.
- ② 특별한 사정이 없는 한 매매목적물의 시가는 의사표시 내용의 중요부분에 해당하므로 시가에 대한 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다.
- ③ 착오를 이유로 계약이 취소됨으로써 상대방이 손해를 입었더라도 상대방은 착오자에 대하여 불법행위를 원인으로 그 배상을 청구할 수는 없다.
- ④ 착오가 상대방의 기망에 의하여 유발된 경우에는 사기를 이유로 계약을 취소할 수 있다.
- ⑤ 상대방에 의하여 유발된 동기의 착오가 법률행위의 중요부분에 해당하는 경우에는 계약을 취소할 수 있다.

해설

- ② 부동산 매매에 있어서 시가에 관한 착오는 부동산을 매매하려는 의사를 결정함에 있어 동기의 착오에 불과할 뿐 법률행위의 중요부분에 관한 착오라고 할 수 없다(대법원 1992.10.23. 92다 29337). 정답: ②

20 甲은 丙(乙과는 아무런 관계없는 자임)의 기망행위로 자기소유 건물을 乙에게 매도하고 소유권이전등기를 경료하였다. 그 후 乙은 그 건물을 丁에게 전매하여 소유권을 이전한 경우에 대한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙이 기망사실을 알 수 있었다면 甲은 법률행위를 취소할 수 있다.
- ② 甲이 법률행위를 취소한 경우에도, 丁이 선의인 경우에는 건물에 대한 소유권을 취득할 수 있다.
- ③ 甲이 취소의 의사표시를 하면 甲과 乙의 매매계약은 무효가 되고 甲은 乙에게 부당이득 반환을 청구할 수 있다.
- ④ 甲이 丙에 대하여 불법행위를 이유로 손해배상을 청구하기 위해서는 반드시 乙과의 매매계약을 취소하여야 한다.
- ⑤ 甲이 사기사실을 안 후 乙로부터 매매대금을 수령한 경우에는 甲과 乙의 법률행위는 확정적으로 유효로 된다.

해설

- ④ 제3자의 사기행위로 인하여 피해자가 주택건설사와 사이에 주택에 관한 분양계약을 체결하였다고 하더라도 제3자의 사기행위 자체가 불법행위를 구성하는 이상, 피해자가 제3자를 상대로 손해배상청구를 하기 위하여 반드시 그 분양계약을 취소할 필요는 없다(대법원 1999.3.10., 97다55829).

정답: ④

사기나 강박에 의한 의사표시에 관한 설명 중 가장 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 법률행위가 사기에 의한 것으로서 취소되는 경우에 그 법률행위가 동시에 불법행위를 구성하는 때에는 취소의 효과로 생기는 부당이득반환청구권과 불법행위로 인한 손해배상청구권은 경합하여 병존하는 것이므로, 채권자는 어느 것이라도 선택하여 행사할 수 있지만 중첩적으로 행사할 수는 없다.
- ② 기망행위로 인하여 법률행위의 중요부분에 관하여 착오를 일으킨 경우뿐만 아니라 법률행위의 내용으로 표시되지 아니한 의사결정의 동기에 관하여 착오를 일으킨 경우에도 표의자는 그 법률행위를 사기에 의한 의사표시로서 취소할 수 있다.
- ③ 민법상 법률행위에 관한 규정은 민사소송법상의 소송행위에는 특별한 규정 기타 특별한 사정이 없는 한 적용이 없는 것이므로 소송행위가 강박에 의하여 이루어진 것임을 이유로 취소할 수는 없다.
- ④ 강박에 의한 법률행위가 하자 있는 의사표시로서 취소되는 것에 그치지 않고 나아가 무효로 되기 위하여는, 강박의 정도가 단순한 불법적 해악의 고지로 상대방으로 하여금 공포를 느끼도록 하는 정도가 아니고, 의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어져 단지 법률행위의 외형만이 만들어진 것에 불과한 정도이어야 한다.
- ⑤ 제3자에 의한 사기행위로 계약을 체결한 경우, 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 계약을 취소할 수 있으나, 그 취소를 하지 않고 제3자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상청구를 할 수는 없다.

해설

- ⑤ 제3자의 사기행위로 인하여 피해자가 주택건설사와 사이에 주택에 관한 분양계약을 체결하였다고 하더라도 제3자의 사기행위 자체가 불법행위를 구성하는 이상, 제3자로서는 그 불법행위로 인하여 피해자가 입은 손해를 배상할 책임을 부담하는 것이므로, 피해자가 제3자를 상대로 손해배상청구를 하기 위하여 반드시 그 분양계약을 취소할 필요는 없다.
- ① 법률행위가 사기에 의한 것으로서 취소되는 경우에 그 법률행위가 동시에 불법행위를 구성하는 때에는 취소의 효과로 생기는 부당이득반환청구권과 불법행위로 인한 손해배상청구권은 경합하여 병존하는 것이므로, 채권자는 어느 것이라도 선택하여 행사할 수 있지만 중첩적으로 행사할 수는 없다.
- ② 기망행위로 인하여 법률행위의 중요부분에 관하여 착오를 일으킨 경우뿐만 아니라 법률행위의 내용으로 표시되지 아니한 의사결정의 동기에 관하여 착오를 일으킨 경우에도 표의자는 그 법률행위를 사기에 의한 의사표시로서 취소할 수 있다.
- ③ 민법상의 법률행위에 관한 규정은 민사소송법상의 소송행위에는 특별한 규정 기타 특별한 사정이 없는 한 적용이 없는 것이므로, 소송행위가 강박에 의하여 이루어진 것임을 이유로 취소할 수는 없다. 마찬가지로 사기 또는 착오를 원인으로 하여 소취하 등 소송행위를 취소할 수 없다.
- ④ 강박에 의한 법률행위가 하자 있는 의사표시로서 취소되는 것에 그치지 않고 나아가 무효로 되기 위하여는, 강박의 정도가 단순한 불법적 해악의 고지로 상대방으로 하여금 공포를 느끼도록 하는 정도가 아니고, 의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어져 단지 법률행위의 외형만이 만들어진 것에 불과한 정도이어야 한다.

정답: ⑤

22

사기에 의한 의사표시의 성립요건에 관하여 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표의자를 기망하여 착오에 빠지게 하려는 고의와 그 착오에 기해 표의자로 하여금 의사표시를 하게 하려는 이종의 고의가 있어야 한다.
- ② 표의자를 기망하는 행위가 있어야 하는데, 단순한 침묵이나 의견의 진술 등도 기망행위에 해당할 수 있다.
- ③ 기망행위로 인하여 표의자가 법률행위의 중요부분에 착오를 일으켜 의사표시를 하였어야 한다.
- ④ 제3자가 사기를 행한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 표의자는 의사표시를 취소할 수 있다.
- ⑤ 표의자는 사기에 의한 의사표시의 취소와 동시에 불법행위에 기한 손해배청구권도 행사할 수 있다.

해설

- ③ 기망행위로 인하여 법률행위의 중요부분에 관하여 착오를 일으킨 경우뿐만 아니라 법률행위의 내용으로 표시되지 아니한 의사결정의 단순한 동기에 관하여 착오를 일으킨 경우에도 표의자는 그 법률행위를 사기에 의한 의사표시로서 취소할 수 있다.
- ② 침묵이나 은폐 등의 소극적 기망도 기망에 해당된다는 것이 다수설의 태도이다. 정답: ③

23

착오에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 대리인이 의사표시를 한 경우, 착오의 유무는 본인을 표준으로 판단하여야 한다.
- ② 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 표의자는 특별한 사정이 없는 한 그 의사표시를 취소할 수 없다.
- ③ 착오로 인하여 표의자가 경제적인 불이익을 입지 않았다면 법률행위 내용의 중요부분의 착오라 할 수 없다.
- ④ 상대방이 표의자의 진의에 동의한 경우, 표의자는 착오를 이유로 그 의사표시를 취소할 수 없다.
- ⑤ 착오를 이유로 의사표시를 취소하는 자는 착오가 없었더라면 의사표시를 하지 않았을 것이라는 점을 증명하여야 한다.

해설

- ① 의사표시의 효력이 의사의 흠결, 사기, 강박 또는 어떤 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준으로 하여 결정한다(제116조 제1항). 정답: ①

24 의사표시에 관한 다음 기술 중 맞는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 상대방이 정당한 이유없이 의사표시의 수령을 거절한 때에도 의사표시의 효력이 발생한다.
- ㉡ 허위표시가 곧 반사회적 행위는 아니다. 따라서 甲은 乙에게 반환청구 할 수 있다.
- ㉢ 허위표시에 관한 제108조는 상대방 있는 단독행위에 적용된다. 상대방 없는 단독행위에는 적용되지 않는다.
- ㉣ 매도인의 대리인이 매수인에게 사기를 행한 경우 매도인이 그 사실을 안 경우에 한하여 매수인이 매매계약을 취소할 수 있다.
- ㉤ 증여세를 면하기 위하여 부자(父子) 사이에 매매의 형식을 빌리는 경우 증여 그 자체도 통정허위표시로서 무효이다.

① ㉡, ㉢, ㉣

② ㉡, ㉢

③ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

④ ㉠, ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

해설

- ㉠ 매도인의 대리인이 매수인에게 사기를 행한 경우 언제든지 매수인이 매매계약을 취소할 수 있다.
- ㉡ 증여세를 면하기 위하여 부자(父子) 사이에 매매의 형식을 빌리는 경우 증여 그 자체는 은닉행위로서 유효로 본다. 정답: ④

25 의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상대방 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 효력이 발생하는 것이 원칙이다.
- ② 의사표시의 상대방이 의사표시를 받은 때에 제한능력자인 경우에는 그 상대방의 법정대리인이 의사표시가 도달한 사실을 안 후라도 표의자는 그 의사표시로서 대항할 수 없다.
- ③ 표의자가 의사표시의 통지를 발송한 후에 사망한 경우, 그 의사표시의 효력에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 내용증명우편이나 등기로 발송된 우편물은 반송 등의 특별한 사정이 없는 한 그 무렵 수취인에게 배달된 것으로 본다.
- ⑤ 표의자가 과실 없이 상대방을 알지 못하거나 상대방의 소재를 알지 못하는 경우, 의사표시는 민사소송법의 공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다.

해설

- ② 의사표시를 제한능력자가 수령한 때에는 상대방(표의자)은 도달을 주장하지 못한다. 그러나 법정대리인이 의사표시의 도달을 인식한 때에는 표의자는 도달을 주장할 수 있다. 정답: ②

26

하자 있는 의사표시의 효과에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 강박의 정도가 극심하여 표의자의 의사결정의 자유가 완전히 박탈되는 정도에 이른 경우라면 의사표시는 무효이다.
- ② 상대방 있는 의사표시에서 제3자가 사기나 강박을 한 때에는 표의자는 그 의사표시의 상대방이 제3자에 의한 사기나 강박의 사실을 알았거나 또는 알 수 있었을 경우에 한하여 취소할 수 있다.
- ③ 상대방의 사기나 강박으로 의사표시를 한 때에도 표의자가 취소하지 않는 한 그것이 범죄가 되어 형사 처분을 받아도 하자 있는 의사표시는 유효하다.
- ④ 제3자에 의한 사기나 강박에 의하여 상대방 없는 의사표시를 행한 경우에는 표의자는 언제나 취소할 수 있다.
- ⑤ 제3자의 선의는 추정되지 않으므로 표의자가 취소권을 행사하면 제3자는 자신의 선의를 증명하여야 한다.

해설

- ⑤ 제3자는 특별한 사정이 없는 한 선의로 추정되므로 하자 있는 의사표시를 한 자가 제3자에 대하여 의사표시의 취소권을 행사하려면 제3자가 악의임을 증명하여야 한다(대법원 1970.9.29. 70다466).
- ② 제110조 제2항 정답: ⑤

27

甲은 乙을 강박하여 乙 소유의 X 토지를 무상으로 자신에게 증여하도록 강요하였다. 이에 乙은 자신의 재산을 甲에게 강제로 빼앗긴다는 인식을 하였지만 그래도 어쩔 수 없다고 생각하면서 X 토지를 무상으로 증여하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙의 증여의 의사표시는 비진의 의사표시에 해당한다.
- ② 甲의 불법적인 해악의 고지로 말미암아 乙이 공포심을 느꼈다면 그것이 乙의 의사결정에 큰 영향을 주지 않았더라도 乙의 증여행위는 무효가 된다.
- ③ 불공정한 법률행위를 이유로 乙의 증여행위를 무효로 할 수 없다.
- ④ 乙은 강박에 의한 의사표시를 이유로 증여행위를 취소할 수 없다.
- ⑤ 乙의 증여의 의사표시는 통정허위표시에 해당하여 무효이다.

해설

- ③ 불공정한 법률행위에 해당하기 위하여는 급부와 반대급부의 사이에 현저히 균형을 잃을 것이 요구되므로 증여와 같이 상대방에 의한 대가적 의미의 재산관계의 출연이 없이 당사자 일방의 급부만 있는 경우에는 급부와 반대급부 사이의 불균형의 문제는 발생하지 않는다(대법원 1993.07.16. 92다41528).
- ①②④⑤ 비진의의사표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음 속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로, 비록 재산을 강제로 빼앗긴다는 것이 표의자의 본심으로 잠재되어 있었다 하여도 표의자가 강박에 의하여서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 비진의의사표시라고 할 수 없다(대법원 1993.07.16. 92다41528). 정답: ③

28 甲은 乙의 대리인인 丙의 말에 속아 丙과의 사이에 매매계약을 체결하였다. 물론 丙은 乙의 명의로 계약을 체결하였다. 이 경우에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲은 언제나 丙과의 계약을 취소할 수 있다.
- ② 甲은 丙의 사기사실을 乙이 안 경우에만 계약을 취소할 수 있다.
- ③ 甲은 丙의 사기사실을 乙이 알았거나 알 수 있었을 경우에만 계약을 취소할 수 있다.
- ④ 甲은 乙의 동의가 없는 한 계약을 취소할 수 없다.
- ⑤ 甲은 어떤 경우에도 계약을 취소할 수 없다.

해설

- ① 대리인 쪽에서 사기·강박을 한 경우에는 제116조가 적용되는 것이 아니지만, 대리인은 제110조 제2항의 제3자에서 배제하여 본인의 知·不知를 불문하고 취소할 수 있다는 것이 다수설이다. 판례도 이러한 취지에서 상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있으나, 상대방의 대리인 등 상대방과 동일시할 수 있는 자의 사기나 강박은 제3자의 사기·강박에 해당하지 아니한다는 입장이다(대법원 1999.2.23. 98다60828). 정답: ①

29 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 착오에 의한 의사표시의 취소권은 형성권이다.
- ② 복대리에 대해서는 표현대리가 성립되지 않는다.
- ③ 대리인을 통한 계약체결시 의사표시의 하자 여부는 대리인을 표준으로 결정한다.
- ④ 대리인이 다수인 때에는 특별한 사정이 없는 한 각자가 본인을 대리한다.
- ⑤ 취소권자가 상대방으로부터 담보를 제공받은 경우 법정추인이 된다.

해설

- ② 대리인이 대리권소멸 후 직접 상대방과 사이에 대리행위를 하는 경우는 물론 대리인이 대리권소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 상대방과 사이에 대리행위를 하도록 한 경우에도, 상대방이 대리권소멸 사실을 알지 못하여 복대리인에게 적법한 대리권이 있는 것으로 믿었고 그와 같이 믿은 데 과실이 없다면 제129조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다(대법원 1998.05.29. 97다55317). 정답: ②

30

상대방 있는 의사표시의 효력발생시기에 관한 민법의 일반원칙에 대한 다음 기술 중 바른 것은 어느 것인가?

- ㉠ 표의자가 발신 후 사망한 경우에는 의사표시는 취소할 수 있다.
- ㉡ 상대방 자신에게 전달될 필요는 없고 친족·동거인 등에게 전달되면 그것으로써 족하다.
- ㉢ 의사표시가 도달할 당시 상대방은 여행 중이고 가족이 수령한 경우는 상대방인 본인이 돌아와야 의사표시가 효력을 발생한다.
- ㉣ 표의자가 발신 후 제한능력자가 된 경우에는 법정대리인이 추인해야 의사표시가 효력을 발생한다.
- ㉤ 의사표시는 상대방이 알아야 되는 것이므로 상대방이 표의자의 말을 듣지 않으려고 귀를 막고 있으면 도달되지 않는다.

해설

- ㉡ 도달이란 의사표시가 객관적으로 보아 상대방이 요지할 수 있는 상태에 이른 것을 말한다. 따라서 상대방과 동거하는 친족이나 고용인에게 전달된 경우에도 도달로 볼 수 있으며, 상대방이 수령을 거절하거나 수령을 지연시키는 경우라 하더라도 정당한 사유가 없는 한 도달로 볼 수 있다는 것이 통설의 입장이다.
- ㉤ 도달이란 상대방의 지배권 내에 들어가서 사회통념상 객관적으로 요지할 수 있는 상태를 의미하므로 수령자 몰래 수령자의 호주머니 속에 넣어버린 경우는 도달이라 할 수 없고, 설사 귀를 막는다 하더라도 도달은 있는 것이다. 정답: ㉡

31

의사표시에 관한 다음 기술 중 맞는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 진의 아닌 의사표시는 상대방 없는 의사표시에는 그 적용이 없다.
- ㉡ 증여세를 면탈하기 위하여 매매의 형식을 빌리는 경우 증여도 허위표시로서 무효이다.
- ㉢ 매도인의 대리인이 매수인에게 사기를 행한 경우에는 매도인이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 매수인이 매매계약을 취소할 수 있다.
- ㉣ 상대방이 의사표시의 수령을 거절한 때에는 그 효력이 생기지 않는다.
- ㉤ 격지자사이의 계약의 성립과 사원총회소집의 통지에 관하여는 발신주의를 취한다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉤ ② ㉡, ㉤ ③ ㉠
- ④ ㉢, ㉤ ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

해설

- ㉠ 비진의 의사표시는 상대방 없는 단독행위에도 적용된다.
- ㉡ 은닉행위는 다른 행위를 할 의사가 있기 때문에 보통의 허위표시로 다룰 것이 아니라, 그 감추어진 행위로서의 요건이 갖추어져 있느냐의 여부에 따라 그 효력이 결정된다.
- ㉢ 대리인이 사기를 행한 경우에는 상대방은 본인에 대하여 본인의 악의·과실을 묻지 않고 취소권을 행사할 수 있다.
- ㉣ 상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에 도달한 때로부터 그 효력이 생긴다. 정답: ③

32 의사표시에 있어서 증명책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 통정허위표시에서 제3자의 악의는 그 허위표시의 무효를 주장하는 자가 증명하여야 한다.
- ② 사기에 의한 의사표시에서 제3자의 악의는 취소를 주장하는 자가 증명하여야 한다.
- ③ 진의 아닌 의사표시에서 상대방이 진의 아님을 알았거나 과실로 이를 알지 못하였다는 것은 의사표시의 무효를 주장하는 자가 증명하여야 한다.
- ④ 상대방에게 도달하여야 효력이 있는 의사표시를 보통우편의 방법으로 하였다면, 송달의 효력을 주장하는 자가 그 도달을 증명하여야 한다.
- ⑤ 착오로 인한 의사표시에서 착오가 법률행위 내용의 중요부분에 관한 것이라는 점과 중대한 과실이 없었다는 점은 표의자가 증명하여야 한다.

해설

⑤ 착오자에게 중대한 과실이 있다는 점에 대한 증명책임은 착오자의 상대방이 부담한다. 정답: ⑤

33 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 의사표시자가 그 통지를 발송한 후 사망하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 않는다.
- ② 통정허위표시의 무효로 대항할 수 없는 제3자는 허위표시의 당사자와 그의 포괄승계인 이외의 자로서 허위표시행위를 기초로 하여 새로운 이해관계를 맺은 자를 말한다.
- ③ 진의 아닌 의사표시에 있어서의 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니다.
- ④ 통정한 허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계로 생긴 채권을 가압류한 자는 통정허위표시의 무효로 대항할 수 없는 제3자에 해당한다.
- ⑤ 제3자가 통정허위표시의 무효에 대항하기 위해서는 선의·무과실이어야 한다.

해설

⑤ 허위표시의 무효를 가지고 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다(제108조 제2항). 제3자는 선의의 기간 하면 되고 무과실까지는 요구되지 않는다. 정답: ⑤

34 의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 보통우편으로 발송된 우편물은 상당기간 내에 도달한 것으로 추정된다.
- ② 격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다.
- ③ 표의자가 의사표시를 발송한 후 사망하더라도 그 효력에 영향이 없다.
- ④ 의사표시가 도달된 후에는 표의자의 상대방이 이를 요지(了知)하기 전이라도 표의자는 이를 철회하지 못한다.
- ⑤ 의사표시의 효력발생을 위해 표의자의 상대방이 그 의사표시의 내용을 알 것까지 요구되지는 않는다.

해설

① 내용증명우편이나 등기우편과는 달리, 보통우편의 방법으로 발송되었다는 사실만으로는 그 우편물이 상당한 기간 내에 도달하였다고 추정할 수 없고, 송달의 효력을 주장하는 측에서 증거에 의하여 이를 입증하여야 한다(대법원 2009.12.10. 2007두20140). 정답: ①

35

의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 수령무능력자에게 의사표시를 한 경우 표의자는 의사표시의 도달을 주장할 수 없으나, 제한능력자 측에서는 도달을 주장할 수 있다.
- ② 상대방 있는 의사표시는 원칙적으로 그 의사표시는 상대방에게 도달한 때부터 효력이 발생한다.
- ③ 의사표시가 도달하였다면, 의사표시의 발신 후 표의자가 사망하더라도 의사표시의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
- ④ 격지자 간의 계약은 승낙의 의사표시를 발송한 때에 성립한다.
- ⑤ 민법상 의사표시의 효력발생시기에 관한 규정은 강행규정이다.

해설

- ⑤ 민법상 의사표시의 효력발생시기에 관한 규정은 임의규정이다.
- ① 제112조
- ② 제111조 제1항
- ③ 제111조 제2항
- ④ 제531조 정답: ⑤

36

의사표시의 효력발생시기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 무권대리인의 상대방이 상당한 기간을 정하여 본인에게 추인 여부를 최고한 경우, 본인이 그 기간 내에 확답을 발하지 않으면 추인을 거절한 것으로 본다.
- ② 공시송달을 함에 있어서 표의자는 상대방을 알지 못하거나 그 소재를 알지 못하는 데 과실이 없어야 한다.
- ③ 미성년자에 대한 의사표시의 도달을 법정대리인이 안 후에는 표의자가 의사표시의 도달을 주장할 수 있다.
- ④ 보통우편의 방법으로 의사표시가 발송된 경우에는 그 의사표시가 상당한 기간 내에 도달한 것으로 추정된다.
- ⑤ 승낙의 의사표시를 발송한 후 승낙자가 사망하더라도 승낙의 효력에는 영향을 미치지 않는다.

해설

- ④ 보통우편으로 발송된 때에는 비록 반송된 사실이 없다 하더라도 우편제도상 당연히 도달된 것으로 추정되지 않는다는 것이 판례의 태도이다. 정답: ④

37 진의 아닌 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사인의 공법행위에는 적용되지 않으므로 공무원의 사직 의사가 외부에 표시된 이상 그 의사는 표시된 대로 효력을 발생한다.
- ② 진의는 특정한 내용의 의사표시를 하려는 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니다.
- ③ 표의자가 강박에 의하여 어쩔 수 없이 증여의 의사표시를 하였다면 이는 비진의표시에 해당하지 않는다.
- ④ 표의자가 비진의표시임을 이유로 의사표시의 무효를 주장하는 경우, 비진의표시에 해당한다는 사실은 표의자가 증명해야 한다.
- ⑤ 표의자가 비진의표시임을 이유로 의사표시의 무효를 주장하는 경우, 상대방이 자신의 선의·무과실을 증명해야 한다.

해설

- ⑤ 표의자가 비진의표시임을 이유로 의사표시의 무효를 주장하는 경우, 표의자가 상대방의 악의 또는 과실을 증명해야 한다. 정답: ⑤

38 착오로 인한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 제3자의 기망으로 표시상의 착오가 발생한 경우, 표의자는 사기를 이유로 의사표시를 취소할 수 있다.
- ② 착오로 인하여 표의자가 경제적인 불이익을 입지 않았다면, 법률행위 내용의 중요부분의 착오라고 할 수 없다.
- ③ 표의자의 착오를 알고 상대방이 이를 이용한 경우에는 착오가 표의자의 중대한 과실로 발생하여도 취소할 수 있다.
- ④ 당사자의 합의로 착오로 인한 의사표시의 취소에 관한 민법 제109조 제1항의 적용을 배제할 수 있다.
- ⑤ 동기의 착오를 이유로 의사표시를 취소할 때 그 동기를 의사표시의 내용으로 하는 당사자의 합의까지는 필요 없다.

해설

- ① 사기에 의한 의사표시란 타인의 기망행위로 말미암아 착오에 빠지게 된 결과 어떠한 의사표시를 하게 되는 경우이므로 거기에는 의사와 표시의 불일치가 있을 수 없고, 단지 의사의 형성과정 즉 의사표시의 동기에 착오가 있는 것에 불과하며, 이 점에서 고유한 의미의 착오에 의한 의사표시와 구분되는데, 신원보증서류에 서명날인한다는 착각에 빠진 상태로 연대보증의 서면에 서명날인한 경우, 결국 위와 같은 행위는 강학상 기망날인의 착오(또는 서명의 착오), 즉 어떤 사람이 자신의 의사와 다른 법률효과를 발생시키는 내용의 서면에, 그것을 읽지 않거나 올바르게 이해하지 못한 채 기명날인을 하는 이른바 표시상의 착오에 해당하므로, 비록 위와 같은 착오가 제3자의 기망행위에 의하여 일어난 것이라 하더라도 그에 관하여는 사기에 의한 의사표시에 관한 법리, 특히 상대방이 그러한 제3자의 기망행위 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우가 아닌 한 의사표시자가 취소권을 행사할 수 없다는 민법 제110조 제2항의 규정을 적용할 것이 아니라, 착오에 의한 의사표시에 관한 법리만을 적용하여 취소권 행사의 가부를 가려야 한다(대법원 2005.05.27. 2004다43824). 정답: ①

39

사기 · 강박에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 상대방의 기망행위로 의사결정의 동기에 관하여 착오를 일으켜 법률행위를 한 경우, 사기를 이유로 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ② 상대방이 불법적인 해약의 고지 없이 각서에 서명날인할 것을 강력히 요구하는 것만으로는 강박이 되지 않는다.
- ③ 부작위에 의한 기망행위로도 사기에 의한 의사표시가 성립할 수 있다.
- ④ 제3자에 의한 사기행위로 계약을 체결한 경우, 표의자는 먼저 그 계약을 취소하여야 제3자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 매수인이 매도인을 기망하여 부동산을 매수한 후 제3자에게 저당권을 설정해 준 경우, 특별한 사정이 없는 한 제3자는 매수인의 기망사실에 대하여 선의로 추정된다.

해설

- ④ 제3자에 의한 사기행위로 계약을 체결한 경우, 표의자는 그 계약을 취소하지 않고도 제3자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 1998.03.10. 97다55829). 정답: ④

40

의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 의사표시의 발신 후 표의자가 사망하였다면, 그 의사표시는 상대방에게 도달하더라도 무효이다.
- ② 의사표시의 효력발생시기에 관해 도달주의를 규정하고 있는 민법 제111조는 임의규정이다.
- ③ 상대방이 정당한 사유 없이 의사표시의 수령을 거절하더라도 상대방이 그 의사표시의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 있다면 그 의사표시는 효력이 있다.
- ④ 재단법인 설립행위의 효력발생을 위해서는 의사표시의 도달이 요구되지 않는다.
- ⑤ 미성년자는 그 행위능력이 제한되고 있는 범위에서 수령무능력자이다.

해설

- ① 표의자가 그 통지를 발신한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항). 정답: ①

41 상대방 있는 의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 의사표시의 도달은 표의자의 상대방이 이를 현실적으로 수령하거나 그 통지의 내용을 알았을 것을 요한다.
- ② 제한능력자는 원칙적으로 의사표시의 수령 무능력자이다.
- ③ 보통우편의 방법으로 발송된 의사표시는 상당기간 내에 도달하였다고 추정된다.
- ④ 표의자가 의사표시를 발송한 후 사망한 경우, 그 의사표시는 효력을 잃는다.
- ⑤ 표의자가 과실로 상대방을 알지 못하는 경우에는 민사소송법 공시송달 규정에 의하여 의사표시의 효력을 발생시킬 수 있다.

해설

- ② 민법상 모든 제한능력자는 의사표시의 수령능력이 없다(제112조).
- ① 의사표시는 상대방에게 도달됨으로써 효력을 발생하는 것이고, 여기서 도달이라 함은 사회관념상 상대방이 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 있다고 인정되는 상태를 의미하므로, 상대방이 이를 현실적으로 수령하였다거나 그 통지의 내용을 알았을 것까지는 필요로 하지 않는다(대법원 1997.11.25. 97다31281).
- ③ 내용증명우편이나 등기우편과는 달리, 보통우편의 방법으로 발송되었다는 사실만으로는 그 우편물이 상당한 기간 내에 도달하였다고 추정할 수 없다(대법원 2009.12.10. 2007두20140).
- ④ 표의자가 그 통지를 발신한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항).
- ⑤ 상대방 또는 상대방의 주소를 모르는 데 대하여 표의자의 과실이 없었어야 한다. 정답: ②

42 의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 도달주의의 원칙은 채권양도의 통지와 같은 준법률행위에도 유추적용될 수 있다.
- ② 의사표시의 부도달 또는 연착으로 인한 불이익은 특별한 사정이 없는 한 표의자가 이를 부담한다.
- ③ 의사표시자가 그 통지를 발송한 후 제한능력자가 되었다면 특별한 사정이 없는 한 그 의사표시는 취소할 수 있다.
- ④ 수령무능력자에게 의사표시를 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 표의자는 그 의사표시로써 수령무능력자에게 대항할 수 없다.
- ⑤ 상대방이 정당한 사유 없이 의사표시 통지의 수령을 거절한 경우, 상대방이 그 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 있는 때에 의사표시의 효력이 생기는 것으로 보아야 한다.

해설

- ③ 표의자가 그 통지를 발신한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항). 유효하다. 정답: ③

1

기본문제

01

대리가 허용되는 것은?

- ① 약혼
- ② 채무의 승인
- ③ 무주물선점
- ④ 불법행위
- ⑤ 유언

해설

- ①⑤ 가족법상의 신분행위는 원칙적으로 대리가 허용되지 않는다. 다만, 예외적으로 부양청구권의 행사, 상속회복청구권, 재산분할청구권과 같이 가족법상의 행위이더라도 재산행위로서의 성질도 아울러 가지는 행위에 관하여는 대리가 허용된다.
- ③④ 사실행위나 불법행위도 대리가 인정되지 않는다. 정답: ②

02

대리권의 범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 매매계약의 체결과 이행에 관하여 포괄적으로 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 상대방에 대하여 약정된 매매대금지급기일을 연기하여 줄 권한도 가진다.
- ② 매매계약을 체결할 권한이 있는 대리인은 특별한 사정이 없는 한 그 잔대금을 수령할 권한도 있다.
- ③ 일반적으로 인감증명서만을 교부하는 행위는 대리권수여행위로 보지 않는다.
- ④ 계약체결의 대리권을 가진 대리인은 그 계약을 해제할 권한도 당연히 가진다.
- ⑤ 대여금의 수령권한만을 위임받은 대리인이 대여금채무의 일부를 면제하기 위해서는 본인의 특별수권이 필요하다.

해설

- ④ 본인을 대리하여 금전소비대차계약을 체결한 대리인에게 그 계약관계를 해제할 권한까지는 없다 (대법원 1993.1.15, 92다39365).
- ①② 대법원 1992.4.14, 91다43107
- ③ 인감증명서만을 교부한 경우에는 대리권 수여 표시하였다고 볼 수 없다(대법원 1978.10.10, 78다 75).
- ⑤ 대여금의 수령권한만을 위임받은 대리인은 대여금채무의 일부를 면제할 수 있는 대리권한이 포함되지 않기 때문이다. 정답: ④

03 자기계약과 쌍방대리에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 대리인은 부동산 매매계약에 따른 소유권이전등기를 신청함에 있어서 쌍방대리를 할 수 있다.
- ㉡ 부동산입찰 절차에서 동일물건에 관하여 동일인이 이해관계가 다른 2인 이상의 대리인이 된 경우, 그 대리인이 한 입찰행위는 유효하다.
- ㉢ 대리인이 계약을 체결함에 있어서 본인이 미리 자기계약을 허락한 경우에는 그 계약은 유효하다.
- ㉣ 친권자가 본인의 지위와 법정대리인으로서의 지위에서 자기의 부동산을 미성년인 자(子)에게 증여하는 자기계약은 무효이다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉣

④ ㉡, ㉣

⑤ ㉢, ㉣

해설

- ㉠ 부동산입찰 절차에서 동일물건에 관하여 동일인이 이해관계가 다른 2인 이상의 대리인이 된 경우, 그 대리인이 한 입찰행위는 쌍방대리 금지에 해당하므로 무효하다.
- ㉡ 친권자가 본인의 지위와 법정대리인으로서의 지위에서 자기의 부동산을 미성년인 자(子)에게 증여하는 자기계약은 미성년자인 자(子)에게 유리하므로 유효하다. 정답: ②

04 대리권을 가지고 있는 대리인이 본인의 이익을 위해서가 아니라 자기 또는 제3자만의 이익을 꾀하기 위하여 대리행위를 한 경우의 효과에 대한 판례의 입장으로 옳은 것은?

- ① 무권대리로서 언제나 무효가 된다.
- ② 유권대리로서 언제나 본인이 책임을 부담한다.
- ③ 권한을 넘은 표현대리로서 본인이 책임을 부담한다.
- ④ 본인이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 본인이 책임을 부담한다.
- ⑤ 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 본인은 책임을 부담하지 않는다.

해설

진의 아닌 의사표시가 대리인에 의하여 이루어지고 그 대리인의 진의가 본인의 이익이나 의사에 반하여 자기 또는 제3자의 이익을 위한 배임적인 것이었다더라도 일단 대리의사는 존재하므로 대리행위로서 유효하지만, 다만 그 상대방이 대리인의 배임적 의도를 알았거나 알 수 있었을 경우에는 「민법」 제107조 제1항 단서의 유추해석상 그 대리인의 행위에 대하여 본인은 아무런 책임을 지지 않는다고 보아야 하고, 그 상대방이 대리인의 표시의사가 진의 아님을 알았거나 알 수 있었는가의 여부는 표의자인 대리인과 상대방 사이에 있었던 의사표시 형성 과정과 그 내용 및 그로 인하여 나타나는 효과 등을 객관적인 사정에 따라 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2001.1.19., 2000다20694). 정답: ⑤

05

대리행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 대리인이 법률행위를 하면서 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 경우, 그 행위는 언제나 자기를 위한 것으로 본다.
- ② 대리인은 본인과 사이에서 대리인과 상대방의 지위를 언제나 동시에 가질 수 없다.
- ③ 대리행위의 하자로 인해 취소권이 발생한 경우, 그 취소권은 대리인에게 귀속된다.
- ④ 임의대리인이 본인의 지시에 좇아 대리행위를 한 경우, 본인은 자기가 알고 있는 사정에 관하여 대리인의 부지(不知)를 주장하지 못한다.
- ⑤ 자기계약과 쌍방대리의 금지규정에 위반하여 대리행위를 한 경우 그 대리행위는 무효이다.

해설

- ① 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 때에는 그 의사표시는 자기를 위한 것으로 본다. 그러나 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알 수 있었을 때에는 대리행위로서 효력이 발생한다(제115조).
- ② 대리인에게 예외적으로 자기계약이 허용되는 경우(제124조)에는 대리인은 본인과 사이에서 대리인과 상대방의 지위를 동시에 가질 수 있다.
- ③ 대리행위의 하자로 인해 취소권이 발생한 경우, 그 취소권은 법률효과의 귀속주체인 본인에게 귀속된다.
- ⑤ 자기계약과 쌍방대리의 금지규정에 위반하여 대리행위를 한 경우 그 대리행위는 무효가 아니라 무권대리가 된다. 따라서 본인의 추인에 따라 유효될 여지가 있다. 정답: ④

06

대리권의 제한에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 대리인이 수인이더라도 각자대리가 원칙이지만, 친권의 행사에 있어서는 공동으로 대리하여야 한다.
- ② 공동대리의 제한이 있는 경우에도 수동대리에 있어서는 통설적 견해는 각 대리인이 단독으로 수령할 수 있는 것으로 해석한다.
- ③ 자기계약 또는 쌍방대리는 본인이 이를 허락한 경우에는 그 대리행위는 유효하다.
- ④ 채무의 이행의 경우에는 자기계약 또는 쌍방대리가 허용된다.
- ⑤ 친권자의 재산을 자에게 증여함에 있어 친권자가 수증자로서의 자의 지위를 대리하는 것은 자기계약이므로 자의 허락이 있어야 그 대리행위가 유효한 것이 된다.

해설

- ⑤의 경우 이해상반행위에 해당하지 않으므로 친권자가 자의 지위를 대리하는 자기계약은 유효하다는 것이 판례의 태도이다(대법원 1981.10.13. 81다649). 정답: ⑤

다음 중 대리권의 소멸사유가 아닌 것은?

- ① 본인의 사망 ② 대리인의 파산
③ 본인의 성년후견개시 ④ 대리인의 사망
⑤ 대리인의 성년후견개시

해설

◎ 대리권의 소멸

공통소멸사유	㉠ 본인의 사망 ㉡ 대리인의 사망 ㉢ 대리인의 성년후견개시 ㉣ 대리인의 파산
임의대리의 특유한 소멸사유	㉠ 수권행위의 철회 ㉡ 원인된 법률관계의 종료
법정대리의 특유한 소멸사유	개개의 법률의 규정

정답: ③

08 복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법정대리인이 부득이한 사유로 복대리인을 선임한 경우 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임을 진다.
- ② 복대리에도 표현대리에 관한 법리가 적용된다.
- ③ 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에도 본인에 책임을 지는 경우가 있다.
- ④ 임의대리인은 본인의 승낙이 있는 경우에 한하여 복대리인을 선임할 수 있다.
- ⑤ 복대리인의 대리권 범위는 대리인의 대리권 범위를 넘지 못한다.

해설

- ④ 임의대리인은 본인의 승낙이 있는 경우뿐만 아니라 부득이한 사유, 본인의 지명에 의해서도 복대리인을 선임할 수 있다(제120조, 제121조 제2항). 정답: ④

09 다음 중 복대리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 법정대리인은 언제나 복대리인을 선임할 수 있으며, 이 경우 원칙적으로 그 선임·감독에 관한 과실의 유무를 묻지 않고 본인이 입은 손해 전부에 대해 책임을 진다.
- ② 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 때에는 그의 부적임 또는 불성실을 알고도 본인에 대하여 통지와 해임을 태만히 한 경우에만 책임을 부담한다.
- ③ 복대리인이 대리인의 대리권의 범위를 초과하는 행위를 한 경우에 본인은 그 행위를 추인할 수 있다.
- ④ 복대리인은 대리인이 자신의 이름으로 선임하기 때문에 복대리인은 대리인의 대리인이다.
- ⑤ 본인이나 복대리인이 한정후견심판을 받았다고 하더라도 그로 인하여 복대리권이 소멸하는 것은 아니다.

해설

- ④ 복대리인은 대리인의 대리인이 아니라 본인의 대리인이다.
- ① 법정대리인은 언제든지 복임권을 갖는다(제122조 본문). 다만 그 선임에 따른 책임이 가중된다. 즉, 복대리인의 선임·감독에 있어서의 과실의 유무를 묻지 않고, 복대리인의 행위에 의하여 본인이 입은 손해 전부에 대하여 책임을 진다(제122조 본문). 다만, 법정대리인이 부득이한 사유로 복대리인을 선임한 경우에는 과실에 대해서만 책임을 진다(제122조 단서).
- ② 제121조 제2항
- ③ 복대리인의 권한초과행위는 제126조의 표현대리가 되며, 본인은 그 행위를 추인할 수 있다(제130조)
- ⑤ 제127조 정답: ④

10 표현대리에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 민법 제125조의 표현대리에 있어서의 상대방에는 특정인 뿐만 아니라 불특정다수인도 이에 해당한다.
- ② 자기의 명의를 사용하는 것을 타인에게 허용한 자는 타인이 자기의 대리인으로 행위한 경우가 아니더라도 그 타인의 행위에 관하여 선의의 제3자에게 대하여 책임이 있다.
- ③ 대리행위의 상대방의 악의·과실 여부의 증명책임은 본인이 진다.
- ④ 본인이 무권대리행위의 추인을 거절한다 하더라도 상대방의 동의를 얻어야 한다.
- ⑤ 강행법규에 위반하여 무효인 법률행위에도 표현대리에 관한 규정이 적용된다.

해설

- ⑤ 계약체결의 요건을 규정하고 있는 강행법규에 위반한 계약은 무효이므로 그 경우에 계약상대방이 선의·무과실이더라도 민법 제107조의 비진의표시의 법리 또는 표현대리 법리가 적용될 여지는 없다(대법원 2016.5.12. 2013다49381). 정답: ⑤

11 표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표현대리가 성립하는 경우에도 선의의 상대방은 본인의 추인이 있을 때까지 무권대리를 이유로 계약을 철회할 수 있다.
- ② 대리권소멸 후의 표현대리는 법정대리에도 적용된다.
- ③ 대리권수여 표시에 의한 표현대리에서 대리권의 수여표시는 대리인이라는 문자를 사용한 경우에만 한정되지 않는다.
- ④ 권한을 넘은 표현대리에 있어서 기본대리권에는 복대리권도 포함한다.
- ⑤ 표현대리가 성립하여 본인이 이행책임을 지는 경우 상대방에게 과실이 있다면 과실상계의 법리가 적용된다.

해설

- ⑤ 표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추 적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다 (대법원 1996.7.12., 95다49554). 정답: ⑤

12 무권대리인 甲은 乙의 대리인이라 칭하고 乙 소유 X 부동산을 丙에게 처분하는 매매계약을 체결하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙은 乙에게 상당한 기간을 정하여 추인여부의 확답을 최고할 수 있고, 乙이 그 기간 내에 확답을 발하지 않으면 추인한 것으로 본다.
- ② 乙은 甲에게 무권대리행위를 추인할 수는 없다.
- ③ 乙이 丙에게 甲의 무권대리행위를 추인하면 매매계약은 추인한 때로부터 유효하게 된다.
- ④ 계약체결시 甲이 무권대리인이라는 사실을 알았던 丙은 乙에게 최고권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 丙이 甲에게 무권대리인의 책임을 물어 X 부동산의 소유권이전을 청구할 경우, 甲이 제한능력자라면 이를 이유로 丙에게 대항할 수 있다.

해설

- ⑤ 무권대리인 甲이 제한능력자라면 책임을 지지 않으므로 상대방 丙이 무권대리인 甲에게 무권대리의 책임을 물어 X 부동산의 소유권이전을 청구할 경우에도 제한능력을 이유로 상대방 丙에게 대항할 수 있다(제135조).
- ① 상대방 丙은 본인 乙에게 상당한 기간을 정하여 추인여부의 확답을 최고할 수 있고, 본인 乙이 그 기간 내에 확답을 발하지 않으면 추인을 거절한 것으로 본다(제131조).
- ② 추인은 무권대리인 뿐만 아니라 상대방, 상대방의과 거래한 승계인에게 할 수 있으므로 본인 乙은 무권대리인 甲에게 무권대리행위를 추인할 수는 있다.
- ③ 본인 乙이 상대방 丙에게 무권대리인 甲의 무권대리행위를 추인하면 무권대리가 있는 때로 소급하여 즉, 매매계약시부터 유효하게 된다.
- ④ 계약체결시 甲이 무권대리인이라는 사실을 알았던 악의의 상대방 丙은 본인 乙에게 최고권을 행사할 수 있다. 정답: ⑤

13 표현대리에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 권한을 넘은 표현대리 규정은 임의대리에만 적용된다.
- ② 대리행위가 허위표시로서 무효인 경우에는 표현대리가 성립할 수 없다.
- ③ 기본대리권이 권한을 넘은 대리행위와 동종이어야 권한을 넘은 표현대리가 성립한다.
- ④ 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 않은 경우에도 권한을 넘은 표현대리 규정이 직접 적용된다.
- ⑤ 대리권이 소멸된 후 선임된 복대리인이 선의·무과실인 상대방과 대리행위를 한 경우에는 표현대리가 성립할 수 없다.

해설

- ② 대리행위 자체가 허위표시로서 무효인 경우에는 표현대리가 성립할 수 없다.
- ① 제126조의 표현대리는 임의대리, 법정대리 모두에 적용된다.
- ③ 제126조의 표현대리에서 기본대리권과 월권대리행위는 동종·유사할 필요가 없다. 기본대리권이 등기신청행위라 할지라도 표현대리인이 그 권한을 유월하여 대물변제라는 사법행위를 한 경우에는 표현대리의 법리가 적용된다(대법원 1978.3.28, 78다282·78다283).
- ④ 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 않고 의사표시를 한 경우에는 그 의사표시는 대리인 자신을 위한 것으로 본다(제115조 본문).
- ⑤ 대리인이 대리권 소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 상대방과 사이에 대리행위를 하도록 한 경우에도, 상대방이 대리권 소멸 사실을 알지 못하여 복대리인에게 적법한 대리권이 있는 것으로 믿었고 그와 같이 믿은 데 과실이 없다면 「민법」 제129조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다(대법원 1998.5.29., 97다55317). 정답: ②

14 A의 성년의 자 甲은 A명의 위임장을 위조하고 A의 대리인임을 사칭하여 A소유의 부동산을 B에게 매각하였다. 다음의 설명 중 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① A가 B에 대해서 매매대금의 지불을 청구한 이후에는 A는 더 이상 매매계약의 효력을 부인할 수 없다.
- ② 甲이 상속에 의해 A의 지위를 승계한 경우라 하더라도 甲은 B에 대해서 추인을 거절할 수 없다.
- ③ A가 甲의 무권대리행위의 추인을 거절한 때에는 B는 甲에 대해서 계약의 이행을 청구하거나 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ A가 부동산을 제3자인 C에게 양도하였다면, A는 B에 대해서 더 이상 甲의 무권대리행위를 추인할 수 없다.
- ⑤ B가 부동산을 선의의 제3자인 C에게 매각한 때에도 A는 C에게 부동산의 반환을 청구할 수 있다.

해설

- ④ 무권대리의 추인은 시기의 제한이 없다. 다만 상대방의 철회 후에는 행사하지 못한다.
- ① 추인을 전제로 하는 효과를 본인이 주장하거나 이행하는 경우에는 추인한 것으로 본다. 예컨대, 본인이 매매대금의 전부 또는 일부를 받은 경우나 본인이 변제기한의 유예를 요청한 경우 등에 있어서는 추인을 의제하고 있다.
- ② 무권대리인이 본인을 상속한 경우에 무권대리인이 본인의 지위에서 추인거절권을 행사하는 것은

신의칙에 반한다는 것이 판례의 태도이다.
 ③ 제135조 제1항
 ⑤ 무권대리행위는 유동적 무효이므로 乙은 처분권한이 없고, 아울러 부동산등기에는 공신력이 인정되지 않는다. 정답: ④

15 제한능력자의 상대방의 최고와 무권대리인의 상대방의 최고에 관한 기술 중 옳은 것은?

- ① 최고기간은 모두 1월 이상이다.
- ② 전자에서는 발신주의를 취하나, 후자에서는 도달주의를 취한다.
- ③ 최고의 상대방은 전자에서는 법정대리인임에 반하여, 후자는 본인이다.
- ④ 최고의 성질은 전자는 의사의 통지이나, 후자는 관념의 통지이다.
- ⑤ 확답하지 않는 경우에는 전자에서는 추인 또는 취소의 효과가 생기나, 후자에서는 거절한 것으로 본다.

제5장
기본문제

해설

◎ 제한능력자와 무권대리인의 상대방의 최고의 비교

구분 내용	제한능력자의 상대방의 최고	무권대리인의 상대방의 최고
최고기간	1월 이상의 유예기간	상당한 기간
확답자	법정대리인 또는 제한능력자이었던 본인	본인
효력발생	도달주의(법정대리인의 확답은 발신주의)	도달주의(본인의 확답은 발신주의)
최고의 성질	의사의 통지	의사의 통지
효과	추인 또는 취소	추인의 거절

정답: ⑤

16 표현대리에 대한 판례의 태도와 다른 것은?

- ① 유권대리에 관한 주장 속에는 표현대리의 주장이 포함되어 있다고 볼 수 없다.
- ② 표현대리가 성립하여 본인이 이행책임을 부담하는 경우에 상대방에게 과실이 있으면 과실상계의 법리를 적용하여 본인의 책임을 경감할 수 있다.
- ③ 표현대리의 법리가 적용될 권한을 넘은 행위는 그 대리인이 가지고 있는 진실한 대리권과 동종임을 필요로 하지 않는다.
- ④ 민법 제129조에 의한 대리권소멸후의 표현대리로 인정되는 경우에, 그 표현대리의 권한을 넘는 대리행위가 있을 때에는 민법 제126조의 표현대리가 성립될 수 있다.
- ⑤ 표현대리에 관한 민법 제126조의 규정에서 제3자라 함은 당해 표현대리행위의 직접 상대방이 된 자만을 의미한다.

해설

- ② 과실상계는 불법행위책임이나 채무불이행책임에서 인정되는 제도이며, 표현대리가 성립하는 경우에는 본인은 계약상의 책임을 전적으로 진다. 즉 상대방의 또 다른 과실을 이유로 본인의 표현대리책임을 경감할 수는 없다.
- ① 유권대리의 주장 속에 무권대리에 속하는 표현대리의 주장이 포함되어 있다고 볼 수 없으며, 따로 표현대리에 관한 주장이 없는 한 법원은 표현대리의 성립여부를 심리 판단할 필요가 없다.
- ③ 대리행위의 내용은 기본대리권의 내용과 동종 유사할 것을 요하지 않는다. 정답: ②

01

대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 대리행위의 효과는 일단 대리인에게 귀속하였다가 본인과 대리인 간의 내부적 법률관계에 따라 본인에게 이전한다.
- ② 물건을 매도하는 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 매매계약에 따른 중도금이나 잔금을 수령할 수 있다.
- ③ 본인은 원인된 법률관계가 존속하고 있더라도 수권행위를 철회하여 임의대리권을 소멸시킬 수 있다.
- ④ 지명채권 양도의 통지도 대리인을 통하여 할 수 있다.
- ⑤ 수인의 대리인에게 대리권을 수여한 경우, 원칙적으로 각자가 본인을 대리한다.

해설

- ① 대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다(제114조 제1항). 즉, 대리행위의 효과는 직접 본인에게 귀속하는 것이지, 대리인에게 귀속 후 본인에게 이전하는 것이 아니다. 정답: ①

02

대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 임의대리인은 행위능력자여야 한다.
- ② 대리인의 법률행위의 효과는 본인에게 귀속되므로 의사표시의 하자의 유무는 본인을 기준으로 판단한다.
- ③ 복대리인은 대리인이 선임한 자로서 본인의 대리인이 아니다.
- ④ 대리인은 본인의 허락을 얻어 본인을 위하여 자기와 법률행위를 할 수 있다.
- ⑤ 권한을 넘은 표현대리의 규정은 법정대리에는 적용되지 않는다.

해설

- ④ 타당한 기술이다. 즉 민법은 자기계약과 쌍방대리를 원칙적으로 금하나(제124조), 예외적으로 본인의 승낙 또는 채무의 이행의 경우에는 허용된다.
- ① 대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다(제117조).
- ② 의사표시의 효력이 의사에 흠결, 사기, 강박 또는 어떤 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준으로 하여 결정한다(제116조 제1항).
- ③ 복대리인이란 대리인이 자기의 이름과 책임으로 선임한 본인의 대리인이다(제123조).
- ⑤ 권한을 넘은 표현대리의 규정은 법정대리에도 적용되며, 대리권수여의 표시에 의한 표현대리는 임의대리에 한하여 적용된다. 정답: ④

03 대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산 입찰절차에서 동일한 물건에 관하여 이해관계가 다른 2인 이상의 대리인이 된 경우, 그 대리인이 한 입찰은 유효하다.
- ② 본인을 위하여 금전소비대차계약을 체결할 권한을 수여받은 대리인에게는, 특별한 사정이 없는 한, 본래의 계약을 해제할 대리권도 있다.
- ③ 대리인이 수인인 경우에 다른 정함이 없으면 대리인은 공동으로 대리권을 행사하여야 한다.
- ④ 파성년후견인이 아닌 자가 임의대리인이 된 후에 그에게 성년후견이 개시되면 그 대리권은 소멸한다.
- ⑤ 대리권의 범위가 정해지지 않은 대리인은 보존행위만을 할 수 있다.

해설

- ④ 대리인의 성년후견개시는 대리권 공통의 소멸사유에 해당한다.
- ① 이러한 쌍방대리는 당연히 무효이다.
- ② 어떠한 계약의 체결에 관한 대리권을 수여받은 대리인이 수권된 법률행위를 하게 되면 그것으로 대리권의 원인된 법률관계는 원칙적으로 목적을 달성하여 종료하는 것이고, 법률행위에 의하여 수여된 대리권은 그 원인된 법률관계의 종료에 의하여 소멸하는 것이므로(민법 제128조), 그 계약을 대리하여 체결하였던 대리인은 체결된 계약의 해제권 등 일체의 처분권과 상대방의 의사를 수령할 권한까지는 없다(대법원 2008.06.12. 2008다11276).
- ③ 대리인이 수인인 경우에 다른 정함이 없으면 각자가 본인을 대리한다.
- ⑤ 제118조(대리권의 범위)
권한을 정하지 아니한 대리인은 다음 각 호의 행위만을 할 수 있다.
1. 보존행위
2. 대리의 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위에서 그 이용 또는 개량하는 행위
정답: ④

04 A는 자신의 중고자동차 X를 좋은 가격에 팔기 위해 중고차 딜러인 B에게 매매에 대한 대리권을 수여하는 위임계약을 체결하였다. 이에 의해 B는 그 물건을 C에게 파는 매매계약을 체결하였다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 행위능력이자 아닌 자도 임의대리인이 될 수 있으므로 B가 미성년자라도 A는 B가 제한능력자임을 이유로 B와 C 사이에 체결된 계약을 취소할 수 없다.
- ② B가 미성년자인 경우 B는 자신의 제한능력을 이유로 A와 체결된 위임계약을 취소할 수 있다.
- ③ C의 B에 대한 기망행위를 통하여 자동차의 매매계약이 체결되었다면 본인인 A는 계약을 취소할 수 없다.
- ④ 대리인 B는 대리인임을 표시하지 않고 마치 자기가 A인양 본인명의로 계약을 체결하여도 대리행위로서의 유효를 인정함이 판례의 입장이다.
- ⑤ B가 A를 위한 것임을 현명하지 않아도 B는 A의 대리인으로 의사표시한 것임을 C가 알 수 있었다면 그 법률효과는 A에게 생기게 된다.

해설

- ③ 대리인이 상대방으로부터 사기나 강박을 당하여 대리행위가 이루어졌다면 그 효과는 본인에게 귀속한다. 따라서 본인(A)은 상대방(C)에 대하여 취소할 수 있다. 대리인(B)이 직접 취소권을 행사하기 위해서는 본인으로부터 특별수권이 있어야 한다. 정답: ③

05 민법상 임의대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대리인은 행위능력자임을 요하지 않는다.
- ② 대리권은 다른 특약이 없으면 법률관계의 종료 전에 수권행위를 철회한 경우에도 소멸한다.
- ③ 대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에 대하여 효력이 생긴다.
- ④ 특정한 법률행위를 위임한 경우에 대리인이 본인의 지시에 좇아 그 행위를 한 때에는 본인은 자기가 안 사정 또는 과실로 인하여 알지 못한 사정에 관하여 대리인의 부지를 주장하지 못한다.
- ⑤ 대리인이 수인(數人)인 경우에 대리인은 원칙적으로 공동으로 대리하고 수권행위 또는 법률로 달리 정하는 경우에만 각자 본인을 대리한다.

해설

⑤ 대리인이 수인이더라도 각자대리가 원칙이며, 예외적으로 공동대리를 인정한다. 정답: ⑤

06 복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임의대리인은 본인의 승낙이나 부득이한 사유가 없으면, 복대리인을 선임하지 못한다.
- ② 복대리인은 제3자에 대하여도 대리인과 동일한 권리의무가 있다.
- ③ 임의대리인은 본인의 지명에 의해서도 복대리인을 선임할 수 있다.
- ④ 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 대리권도 소멸한다.
- ⑤ 복대리인은 대리인이 본인의 명의로 선임한 본인의 대리인이다.

해설

⑤ 복대리인은 대리인이 자기의 이름과 책임으로 선임한 본인의 대리인이다. 정답: ⑤

07 복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법정대리인은 자신의 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.
- ② 복대리인은 임의대리인이다.
- ③ 복대리인의 대리행위가 대리인의 대리권의 범위를 넘은 경우 본인이 이를 추인할 수 있다.
- ④ 복대리인은 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다.
- ⑤ 복대리인은 본인에게 직접 비용상환을 청구할 수 없다.

해설

⑤ 복대리인도 본인에게 직접 비용상환을 청구할 수 있다. 정답: ⑤

08 甲은 그 소유의 X건물을 매도하기 위하여 乙에게 대리권을 수여하였다. 이에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 공인중개사]

- ① 乙이 사망하면 특별한 사정이 없는 한 乙의 상속인에게 그 대리권이 승계된다.
- ② 乙은 특별한 사정이 없는 한 X건물의 매매계약에서 약정한 중도금이나 잔금을 수령 할 수 있다.
- ③ 甲의 수권행위는 묵시적인 의사표시에 의하여도 할 수 있다.
- ④ 乙이 대리행위를 하기 전에 甲이 그 수권행위를 철회한 경우, 특별한 사정이 없는 한 乙의 대리권은 소멸한다.
- ⑤ 乙은 甲의 허락이 있으면 甲을 대리하여 자신을 X건물의 매수인으로 하는 계약을 체결할 수 있다.

해설

- ① 대리인이 사망하면 대리권은 소멸하고, 상속인에게 승계되지 않는다. 정답: ①

09 복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 감정평가사]

- ① 대리권이 소멸하면 특별한 사정이 없는 한 복대리권도 소멸한다.
- ② 복대리인의 대리권은 대리인의 대리권의 범위보다 넓을 수 없다.
- ③ 복대리인의 대리행위에 대해서는 표현대리가 성립할 수 없다.
- ④ 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.
- ⑤ 임의대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다.

해설

- ③ 복대리인의 대리행위에 대해서도 당연히 표현대리가 성립할 수 있다. 정답: ③

10 甲은 乙의 대리인이다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 임의대리인 甲은 자기책임으로 자유롭게 복대리인을 선임할 수 있다.
- ② 甲이 복대리인을 선임하는 경우 甲은 乙의 이름으로 복대리인을 선임하여야 한다.
- ③ 甲이 선임한 복대리인 丙은 甲의 이름으로 법률행위를 하여야 한다.
- ④ 甲이 선임한 복대리인 丙의 복대리권은 甲의 대리권이 소멸하여도 소멸하지 않는다.
- ⑤ 법정대리인 甲이 부득이한 사유로 복대리인 丙을 선임한 경우, 甲은 乙에 대하여 丙의 선임감독에 관한 책임이 있다.

해설

- ⑤ 법정대리인 甲이 부득이한 사유로 복대리인 丙을 선임한 때에는 甲은 乙에 대하여 丙의 선임감독에 관하여 과실책임을 진다(제122조).
- ① 임의대리인 甲은 자기책임으로 원칙적으로 복대리인을 선임할 수 없다(제120조).
 - ② 甲이 복대리인을 선임하는 경우 甲은 대리인 자신의 이름인 甲의 이름으로 복대리인을 선임하여야 한다.
 - ③ 甲이 선임한 복대리인 丙은 본인 乙의 이름으로 법률행위를 하여야 한다.
 - ④ 甲이 선임한 복대리인 丙의 복대리권은 甲의 대리권이 소멸하면 소멸한다. 정답: ⑤

11 복대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 복대리권은 대리인에 의한 수권행위의 철회에 의하여도 소멸한다.
- ② 법정대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다.
- ③ 임의대리인이 본인의 지명 없이 복대리인을 선임한 경우에는, 그 부적임을 알고 본인에게 통지나 그 해임을 태만한 때가 아니면 본인에게 대하여 책임이 없다.
- ④ 복대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 때에는, 원칙적으로 대리인을 위한 것으로 본다.
- ⑤ 복대리인이 선임되면 대리인의 대리권은 소멸하고 복대리인만 본인을 대리하게 된다.

해설

- ① 타당한 기술이다.
- ② 법정대리인은 언제든지 복임권이 있다.
- ③ 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 책임이 경감된다. 즉, 본인이 지명한 자가 부적임 또는 불성실함을 알고도 본인에게 그 통지를 하지 않았거나 해임을 태만히 한 때가 아니면 책임지지 아니한다(제121조 제2항).
- ④ 복대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니한 때에는, 원칙적으로 복대리인 자신을 위한 것으로 본다.
- ⑤ 복대리인의 선임은 대리권의 양도가 아니기 때문에 대리인도 본인의 대리인의 지위를 가진다. 즉 복대리인을 선임하더라도 대리인의 대리권을 소멸하지 않는다. 정답: ①

12 임의대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 임의대리권의 발생원인인 수권행위의 하자 유무는 대리인을 기준으로 판단한다.
- ② 통상의 임의대리권은 상대방의 의사표시를 수령하는 대리권을 포함하지 않는다.
- ③ 피한정후견인이 대리인이 된 후 성년후견심판을 받은 때에는 대리권은 당연히 소멸한다.
- ④ 매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 대리인은 중도금 등을 수령할 권한이 없는 것이 일 반적이다.
- ⑤ 대리권의 범위가 불분명한 경우에 대리인은 제한 없이 개량행위를 할 수 있다.

해설

- ③ 대리인은 행위능력자임을 요하지 않으므로 피한정후견인도 대리인이 될 수 있으나(제117조), 대리인(임의, 법정대리 불문)이 성년후견심판을 받으면 대리권은 소멸한다(제127조).
- ① 임의대리권의 발생원인인 수권행위의 하자 유무는 본인을 기준으로 판단한다.
- ② 통상의 임의대리권은 상대방의 의사표시를 수령하는 대리권을 포함한다.
- ④ 매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 대리인은 중도금 등을 수령할 권한이 있다는 것이 판례의 입장이다.
- ⑤ 대리권의 범위가 불분명한 경우에 임의대리인은 대리 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위에서 개량행위를 할 수 있다(제118조). 정답: ③

13 甲은 자기소유의 건물을 매각하도록 대리권을 乙에게 주고 백지위임장을 써 주었다. 乙은 그 건물에 대하여 자기 스스로 매수인이 되어 매매계약을 체결하고 자기명으로 등기를 하였다. 이 경우 타당한 설명은?

- ① 乙의 행위는 자기 계약이므로 甲·乙 간의 계약은 무효이고 甲의 추인에 의하여도 효력이 생기지 않는다.
- ② 乙의 행위는 쌍방대리이므로 甲·乙 간의 계약은 무효이고 추인에 의하여도 효력이 생기지 않는다.
- ③ 乙의 행위는 무권대리가 되며, 甲이 추인하면 乙의 행위도 유효한 대리행위가 된다.
- ④ 乙의 행위는 쌍방대리에 해당하며 효력이 없다.
- ⑤ 甲이 미리 乙에게 甲·乙 간의 매매계약을 허락한 경우에도, 乙의 행위가 유효하게 성립할 여지가 없다.

해설

- ③ 자기계약 또는 쌍방대리의 제한규정(제124조)에 위반하여 대리행위를 한 경우에는 당연히 무효가 아니라 제126조의 표현대리가 성립한다. 따라서 본인의 추인이 있을 경우에는 처음부터 유권대리였던 것으로 된다. 정답: ③

14 복대리에 관한 다음 기술 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표현대리의 규정은 복임권 없는 대리인에 의하여 선임된 복대리인의 대리행위에 관하여도 적용된다.
- ② 임의대리인의 선임에 있어 부득이한 사유란 본인의 소재불명으로 승낙을 얻을 수 없거나 사임할 수 없는 경우, 대리인이 질병으로 인하여 대리행위를 할 수 없는 경우를 말한다.
- ③ 복대리인은 본인의 대리인이므로 본인을 위한다는 표시를 하면 되고 대리인의 이름은 표시할 필요가 없다.
- ④ 복대리인의 대리권은 대리인이 파산선고를 받더라도 소멸하지 않는다.
- ⑤ 복대리인이 수인인 때에는 법률 또는 수권행위에 다른 규정이 없는 한 각자가 본인을 대리한다.

해설

- ④ 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리권도 따라서 소멸한다. 정답: ④

18 甲은 乙의 A자동차의 보관을 의뢰받은 대리인이며 동시에 乙의 채권자이다. 종래 乙에게 1,000만 원을 빌려 주었던 바, 그 담보로서 자동차의 보관을 겸하여 왔는데, 그 변제기가 경과되어도 乙의 변제가 없기 때문에 甲은 그 자동차를 변제로서 자기소유로 취득한 경우 다음 중 가장 타당한 설명은?

- ① 甲은 대리인이므로 乙을 대리하여 A를 유효하게 취득할 수 있다.
- ② 민법 제124조 단서의 '채무의 이행'에 해당되기 때문에 甲의 A의 취득은 유효한 변제가 된다.
- ③ 甲의 행위는 절대무효이며 A를 乙에게 반환하여야 한다.
- ④ 乙의 이익과 상반되므로 甲의 취득은 추인의 여지없이 무효가 된다.
- ⑤ 甲의 행위는 무권대리행위로서 乙의 추인에 의하여 담보적 의미의 유효한 취득이 가능하다.

해설

⑤의 경우 甲(대리인)의 A자동차의 취득은 자기계약에 해당한다. 다만, 채무의 이행으로서의 자기계약은 허용되지만 대물변제에 해당하므로 인정될 수 없다. 따라서 甲의 행위는 제126조의 표현대리에 해당하며 당연히 무효가 아니라 본인(乙)의 추인에 의하여 유효한 취득이 인정될 수 있다(제124조).

정답: ⑤

19 다음 증명책임에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 착오로 인한 의사표시에서 중대한 과실이 있다는 증명책임은 표의자의 상대방이 부담한다.
- ② 사기나 강박에 의한 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항할 수 없는데, 이때의 선의는 추정되고 취소권자 쪽에서 악의를 증명해야 한다.
- ③ 좁은 의미의 무권대리인의 상대방에 대한 책임에서의 상대방이 대리권 없음을 몰랐고, 모르는 데 과실이 없을 것의 증명책임은 무권대리인에게 있다.
- ④ 대리권수여의 표시에 의한 표현대리의 경우, 본인이 상대방의 악의·과실을 증명해야 한다.
- ⑤ 대리권소멸 후의 표현대리의 경우에는 상대방이 자기의 선의·무과실을 증명해야 한다.

해설

⑤ 협의의 무권대리의 경우에는 상대방의 악의 또는 과실에 대한 증명책임이 무권대리인에게 있으며, 표현대리의 경우에는 상대방의 악의 또는 과실에 대한 증명책임은 본인(단, 126조의 표현대리는 상대방에게 증명책임이 있다는 것이 판례의 태도)에게 있다. 정답: ⑤

20

乙은 甲의 임의대리인으로서 A와 거래를 하고 있던 중 甲은 乙의 평소 행실에 문제가 있음을 알고 곧 乙의 대리권을 박탈하였다. 그럼에도 乙은 그 이후 丙을 복대리인으로 선임하여 丙으로 하여금 A와 거래를 계속하도록 하였다. 그 과정에서 丙은 A의 물건을 시가의 3배를 더 주고 매수하기로 계약을 하였고, 이에 A는 그 대금의 지급을 甲에게 청구하였다. 甲, 乙, 丙, A의 법률관계에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙의 복대리인 선임행위는 자신의 대리권소멸 후의 행위이므로 甲과의 관계에서는 아무런 법적 효과가 발생할 여지가 없다.
- ② 따라서 A가 乙의 대리권상실에 대해 선의이며 이에 대하여 과실이 없는 경우에도 甲에게 丙과의 계약에 따른 대금지급을 청구할 수는 없다.
- ③ 丙은 비록 乙의 대리권이 소멸한 후에 선임된 복대리인이나 이러한 복대리인의 법률행위에 대하여도 표현대리의 규정이 적용될 수 있다.
- ④ 甲이 乙의 대리권을 소멸시키기 전이라면 乙은 甲의 승낙 없이도 언제든지 복대리인을 선임할 수 있다.
- ⑤ 乙의 대리권이 소멸하기 전에 乙이 甲의 승낙 하에 丙을 복대리인으로 선임한 경우라면 이후 乙의 대리권이 소멸되었어도 丙은 여전히 甲의 대리인으로서의 지위에는 변함이 없다.

해설

- ① ② ③ 제129조의 표현대리가 적용될 수 있다. 따라서 상대방 A가 선의·무과실인 경우에는 본인 甲에 대하여 매매계약의 효력을 주장할 수 있다.
- ④ 乙은 임의대리인으로서 본인의 승낙 또는 부득이한 사유가 아닌 한 복임권을 행사하지 못한다.
- ⑤ 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 당연히 소멸한다. 정답: ③

21

甲 소유의 X토지를 매도하는 계약을 체결할 대리권을 甲으로부터 수여받은 乙은 甲의 대리인임을 현명하고 丙과 매매계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 乙은 특별한 사정이 없는 한 매매계약을 해제할 권한이 없다.
- ② 乙이 미성년자인 경우, 甲은 乙의 제한능력을 이유로 X토지에 대한 매매계약을 취소할 수 없다.
- ③ 丙과의 매매계약이 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부가 문제된 경우, 매도인의 무경험은 甲을 기준으로 판단한다.
- ④ 乙이 丙으로부터 매매대금을 수령한 경우, 甲에게 이를 아직 전달하지 않았더라도 특별한 사정이 없는 한 丙의 매매대금채무는 소멸한다.
- ⑤ 甲이 乙에게 매매계약의 체결과 이행에 관한 포괄적 대리권을 수여한 경우, 특별한 사정이 없는 한 乙은 약정된 매매대금 지급기일을 연기하여 줄 권한을 가진다.

해설

- ③ 대리인에 의하여 법률행위가 이루어진 경우 그 법률행위가 민법 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경솔과 무경험은 대리인을 기준으로 하여 판단하고, 궁박은 본인의 입장에서 판단하여야 한다(대법원 2002.10.22. 2002다38927). 정답: ③

22 본인 甲, 그 대리인 乙 및 복대리인 丙과의 법률관계에 관한 다음 기술 중 옳은 것은?

- ① 乙이 甲의 허락을 얻어 丙을 복대리인으로 선임한 후에 대리권을 상실하는 경우에 丙도 대리권을 상실한다.
- ② 丙이 복대리인의 권한을 초월하여 행위를 했지만 그것이 乙의 대리권의 범위를 초과하지 않은 경우는 丙의 행위는 무권대리가 되지 않는다.
- ③ 乙이 甲의 허락을 얻어 丙을 선임한 경우 乙이 사망해도 丙의 대리권은 소멸하지 않는다.
- ④ 乙이 甲의 지명에 따라 丙을 선임한 경우에는 乙은 甲의 동의가 없으면 丙을 해임할 수 없다.
- ⑤ 乙이 甲의 허락을 얻어 丙을 선임한 경우에는 乙은 丙의 선임에 대해 책임을 지지 않는다.

해설

- ① 대리인이 복대리인을 선임한 후에 사망하거나 대리권을 상실하는 경우에 복대리인도 대리권을 상실한다.
- ② 복대리인은 그 권한 내에서 본인을 대리한다(제123조 제1항). 따라서 무권대리가 된다.
- ③ 대리인의 대리권 소멸은 복대리권도 소멸시킨다.
- ④ 본인의 지명에 의하여 대리인이 복대리인을 선임한 경우 복대리인의 부적임 또는 불성실함을 알고도 대리인이 본인에 대한 통지나 그 해임을 해대한 때에는 본인에 대하여 책임을 진다(제121조 제2항). 따라서 乙이 甲의 지명에 따라 丙을 선임한 경우에도 乙은 甲의 동의 없이도 丙을 해임할 수 있다.
- ⑤ 선임 및 감독상의 책임을 부담한다(제121조 제1항). 정답: ①

23 표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 일상가사대리권은 권한을 넘은 표현대리에 있어서 기본대리권이 될 수 없다.
- ② 유권대리의 주장 속에 표현대리의 주장이 포함되어 있다고 볼 수는 없다.
- ③ 강행법규에 반하여 무효인 법률행위에 대하여는 표현대리의 법리가 준용될 수 없다.
- ④ 표현대리가 성립하는 경우, 상대방의 과실이 있더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 감경할 수 없다.
- ⑤ 법정대리의 경우에도 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.

해설

- ① 부부는 일상가사에 관하여 서로 대리권이 있는데, 이러한 일상가사대리권은 권한을 넘은 표현대리에 있어서 기본대리권이 될 수 있기 때문에 부부 중 일방이 일상가사대리권의 범위 이외의 행위를 한 경우에도 본조에 의한 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다(통설·판례).
- ② 표현대리가 성립한다 하여 무권대리의 성질이 유권대리로 전환되는 것은 아니므로 유권대리에 관한 주장 속에 무권대리에 속하는 표현대리의 주장이 포함되어 있다고 볼 수 없다(대법원 1983.12.13, 83다카1489).
- ③ 증권거래법을 위반한 투자수익보장약정은(강행규정 위반으로) 무효이며, 무효인 이상 표현대리의 법리도 준용될 여지가 없다(대법원 2002.12.26, 2000다56952).
- ④ 표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추 적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다(대법원 1996.7.12, 95다49554).
- ⑤ 권한을 넘은 표현대리는 임의대리 및 법정대리 모두에 적용된다(대법원 1987.11.10., 87다카1325). 정답: ①

24

甲으로부터 대리권을 수여받지 않은 甲의 처(妻) 乙은, 자신의 오빠 A가 丙에게 부담하는 고가의 외제자동차 할부대금채무에 대하여 甲의 대리인이라고 하면서 甲을 연대보증인으로 하는 계약을 丙과 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 甲이 乙의 무권대리행위를 추인하기 위해서는 乙의 동의를 얻어야 한다.
- ② 甲이 자동차할부대금 보증채무액 중 절반만 보증하겠다고 한 경우, 丙의 동의가 없으면 원칙적으로 무권대리행위의 추인으로서 효력이 없다.
- ③ 乙의 대리행위는 일상가사대리권을 기본대리권으로 하는 권한을 넘은 표현대리가 성립한다.
- ④ 계약 당시 乙이 무권대리인임을 알지 못하였던 丙이 할부대금보증계약을 철회한 후에도 甲은 乙의 무권대리행위를 추인할 수 있다.
- ⑤ 계약 당시 乙이 무권대리인임을 알았던 丙은 甲에게 乙의 무권대리행위의 추인 여부의 확답을 최고할 수 없다.

해설

- ② 타당한 기술이다. 본인이 무권대리인이 한 계약의 내용을 변경하여 추인하거나 일부 추인한 경우에는 상대방의 동의가 있어야 추인의 효력이 발생한다.
- ① 추인은 단독행위이며 형성권으로서, 무권대리인이나 상대방의 동의를 요하지 않는다.
- ③ 남편이 처에게 타인의 채무를 보증함에 필요한 대리권을 수여한다는 것은 사회통념상 이례에 속하므로, 처가 특별한 수권 없이 남편을 대리하여 위와 같은 행위를 하였을 경우에 그것이 민법 제126조 표현대리가 되려면 처에게 일상가사대리권이 있었다는 것만이 아니라 상대방이 처에게 남편이 그 행위에 관한 대리권을 주었다고 믿었음을 정당화할 만한 객관적인 사정이 있어야 한다(대법원 2016.6.9. 2014다58139). 따라서 설문의 경우에는 권한을 넘은 표현대리가 성립하지 않는다.
- ④ 철회권이 행사되면 처음부터 그 무권대리행위는 무효로 확정되고 그 후 본인은 추인하지 못한다.
- ⑤ 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에 대하여 추인여부의 확답을 구하는 최고를 할 수 있다. 만약 그 기간 내에 본인이 확답을 발하지 않는 경우에는 추인을 거절한 것으로 본다. 약의 상대방에게도 최고권을 인정한다. 정답: ②

25

표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 대리권 소멸 후의 표현대리가 인정되는 경우, 그 표현대리의 권한을 넘은 대리행위가 있을 때 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.
- ② 대리인이 대리권 소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 대리행위를 하도록 한 경우, 대리권 소멸 후의 표현대리가 성립할 수 없다.
- ③ 권한을 넘은 표현대리에 있어 '정당한 이유'의 존부는 대리행위 당시의 제반 사정을 객관적으로 관찰하여 판단하여야 한다.
- ④ 본인이 대리권 수여표시에 의한 표현대리 또는 대리권 소멸 후의 표현대리로 인하여 책임을 지기 위해서는 상대방이 선의·무과실이여야 한다.
- ⑤ 교회의 대표자가 교인총회의 결의를 거치지 아니하고 교회 재산을 처분한 행위에 대하여 권한을 넘은 표현대리에 관한 규정을 준용할 수 없다.

해설

- ② 대리인이 대리권소멸 후 직접 상대방과 사이에 대리행위를 하는 경우는 물론 대리인이 대리권 소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 상대방과 사이에 대리행위를 하도록 한 경우에도, 상대방이 대리권소멸 사실을 알지 못하여 복대리인에게 적법한 대리권이 있는 것으로 믿었고 그와 같이 믿은 데 과실이 없다면 제129조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다(대법원 1998.05.29. 97다55317). 정답: ②

26

표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 권한을 넘은 표현대리인지를 판단할 때 정당한 이유의 유무는 대리행위를 기준으로 한다.
- ② 권한을 넘은 표현대리에서는 기본대리권의 내용이 되는 행위와 표현대리행위가 반드시 같은 종류의 것이어야 한다.
- ③ 부부간의 일상가사대리권을 기본대리권으로 하여 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.
- ④ 복대리인의 대리권은 권한을 넘은 표현대리의 기본대리권이 될 수 있다.
- ⑤ 표현대리가 성립하여도 무권대리의 성질이 유권대리로 전환되는 것은 아니다.

해설

- ② 제126조의 표현대리에서 기본행위와 월권된 행위는 동종, 유사할 것을 요하지 않는다는 것이 다수설과 판례의 태도이다. 정답: ②

27

표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 표현대리가 성립하는 경우에는 상대방에게 설령 과실이 있더라도 과실상계의 법리를 유추 적용할 수 없다.
- ② 등기신청을 위한 대리권을 가진 대리인이 그 권한을 넘어 대물변제를 한 경우 표현대리의 법리는 적용되지 않는다.
- ③ 표현대리가 성립한다고 하여 무권대리의 성질이 유권대리로 전환되는 것은 아니다.
- ④ 호텔 등의 시설이용 우대회원 모집계약을 체결하면서 자신의 판매점이나 총대리점 등의 명칭을 사용하여 회원모집 안내를 하는 것을 승낙 또는 묵인하였다면 대리권 수여의 표시가 있는 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 대리권 소멸후의 표현대리가 인정되는 경우 그 권한을 넘은 대리행위가 있을 때에는 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.

해설

- ② 기본대리권이 등기신청행위(공법행위)라 할지라도 표현대리인이 그 권한을 초과하여 대물변제(또는 매매)라는 사법행위를 한 경우에는 표현대리의 법리가 적용된다(대법원 1978.03.28. 78다 282,283). 정답: ②

- ① 복대리인은 대리인의 대리인이다.
- ② 복대리인은 본인에 대해 어떠한 권리 · 의무도 부담하지 않는다.
- ③ 복대리인이 선임되면 복대리인의 대리권 범위 내에서 대리인의 대리권은 잠정적으로 소멸한다.
- ④ 대리인이 복대리인을 선임한 후 사망하더라도 특별한 사정이 없는 한 그 복대리권은 소멸하지 않는다.
- ⑤ 복임권 없는 대리인에 의해 선임된 복대리인의 대리행위에 대해서도 권한을 넘은 표현대리에 관한 규정이 적용될 수 있다.

해설

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 복대리인은 본인의 대리인이며, 복대리인은 언제나 임의대리인이다.
 - ② 본인에 대하여는 복대리인도 대리인과 동일한 지위를 가진다.
 - ③ 복대리인 선임 후에도 대리인의 대리권은 존속한다.
 - ④ 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 소멸한다. 정답: ⑤

乙은 아무런 권한이 없음에도 불구하고 甲의 대리인이라고 사칭하여 甲소유의 부동산에 대하여 대리권 없음을 몰랐던 丙과 매매계약을 체결하였다. 다음 설명 중 옳은 것은?

(표현대리는 논외로 하며 다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙이 상당한 기간을 정하여 甲에게 추인 여부의 확답을 최고한 경우에 甲이 그 기간 내에 확답을 발하지 아니한 때에는 추인한 것으로 본다.
- ② 甲이 乙에 대하여 추인을 한 후에는, 상대방 丙이 아직 그 추인 있었음을 알지 못한 때에도 丙은 乙과 맺은 계약을 철회할 수 없다.
- ③ 乙이 그 대리권을 증명하지 못하고, 또 甲의 추인을 얻지 못한 때에는 乙은 자신의 선택에 좇아 계약의 이행 또는 손해배상의 책임을 진다.
- ④ 추인은 명시적으로 이루어져야 하므로 甲이 丙으로부터 매매대금의 전부 또는 일부를 받았을 경우에는, 甲이 乙의 매매계약을 추인하였다고 볼 수는 없다.
- ⑤ 甲의 丙에 대한 추인거절권의 행사가 있으면 甲은 다시 추인할 수 없으며, 丙도 최고권이나 철회권을 행사하지 못한다.

해설

- ⑤ 본인이 추인을 거절하면 무권대리행위는 확정적으로 무효가 된다. 따라서 본인은 더 이상 추인할 수 없으며, 상대방도 최고권이나 철회권을 행사할 수 없게 된다.
- ① 상당기간 내에 확답을 발송하지 않으면 추인거절로 본다.
- ② 추인은 무권대리인 또는 상대방에 대하여 할 수 있으나, 추인의 의사표시를 무권대리인에 대하여 한 경우에는 그 사실을 모르는 상대방에게 대항할 수 없으므로(제132조), 선의의 상대방(丙)은 철회권을 행사할 수 있다(제134조).
- ③ 선택권은 상대방(丙)에게 있다.
- ④ 추인은 묵시적으로도 할 수 있다. 무권대리인이 체결한 매매계약의 대금을 본인이 전부 또는 일부를 수령하였다면 이는 추인한 것으로 본다. 정답: ⑤

30

협의를 무권대리에 관하여 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 원칙적으로 본인에 대하여 효력이 없지만, 이 무효는 추인에 의하여 유효로 될 수 있는, 이른바 유동적 무효이다.
- ② 무권대리행위의 추인은 무권대리인, 무권대리행위의 직접의 상대방 및 그 무권대리행위로 인한 권리 또는 법률관계의 승계인에 대하여도 할 수 있다.
- ③ 판례는 무권대리행위에 대하여 이의를 제기함이 없이 방치하였다는 사실만으로는 추인한 것으로 볼 수 없다는 입장이다.
- ④ 무권대리인의 상대방에게 인정되는 최고권과 철회권은 모두 상대방이 선의일 것을 전제로 한다.
- ⑤ 무권대리인의 상대방에 대한 책임이 인정되기 위한 요건으로서 민법 제135조 제1항에 규정된 '본인의 추인을 얻지 못한 때'란 본인이 명시적으로 추인을 거절하지 않았더라도, 사실상 추인의 가능성이 없어진 때를 의미한다는 것이 판례의 입장이다.

해설

④ 철회권은 선의의 상대방에게만 인정되며, 최고권의 경우는 상대방의 선의, 악의를 묻지 않는다.

① 제130조

② 대법원 1981.4.14. 80다2314

③ 대법원 1998.2.10. 97다31113 정답: ④

31

협의를 무권대리에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무권대리인이 한 계약은 본인이 추인하지 아니하면 본인에 대하여 효력이 없다.
- ② 본인이 추인이나 거절의 의사표시를 상대방에 대하여 하지 아니하였더라도 상대방이 그 사실을 안 때에는 이 의사표시로 상대방에게 대항할 수 있다.
- ③ 무권대리인이 대리권을 증명하지 못하고 또 본인의 추인을 얻지 못한 때에는 무권대리인이 계약의 이행이나 손해배상 중 하나를 선택하여 책임을 져야 한다.
- ④ 무권대리인이 한 계약에 대하여 상대방이 상당한 기간을 정하여 본인에게 추인 여부의 확답을 최고하였으나 본인이 그 기간 내에 확답을 발송하지 않은 경우에는 추인을 거절한 것으로 본다.
- ⑤ 본인이 무권대리행위를 추인하면서 상대방과 합의하여 그 행위의 효력이 추인한 때로부터 발생하는 것으로 정할 수 있다.

해설

③ 제135조【무권대리인의 상대방에 대한 책임】

① 타인의 대리인으로 계약을 한 자가 그 대리권을 증명하지 못하고 또 본인의 추인을 얻지 못한 때에는 상대방의 선택에 좇아 계약의 이행 또는 손해배상의 책임이 있다.

① 제130조 ② 제132조 ④ 제131조

⑤ 무권대리행위는 본인의 추인을 받으면 소급하여 유효하게 되는 유동적 무효의 성질을 갖는다. 그러나 다른 의사표시가 있는 때에는 추인의 소급효는 배제된다. 또한 추인의 소급효는 제3자의 권리를 해하지 못한다(제133조). 정답: ③

32 무권대리인 乙은 甲의 대리인이라 칭하면서 甲소유의 부동산을 丙에게 매도하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 甲이 丙에게 乙의 무권대리행위를 추인하면, 위 매매계약은 추인한 때로부터 효력이 있다.
- ② 甲이 乙에게 무권대리행위를 추인하였지만 丙이 이를 알지 못하였다면 甲은 추인으로써 丙에게 대항할 수 없다.
- ③ 丙은 甲에게 상당한 기간을 정하여 추인여부의 확답을 최고할 수 있다.
- ④ 丙이 乙의 대리권 없음을 알지 못하였다면, 丙은 甲의 추인이 있기 전에 계약을 철회할 수 있다.
- ⑤ 乙이 행위능력이 없는 때에는, 乙은 丙에게 대하여 계약의 이행 또는 손해배상책임을 지지 않는다.

해설

① 甲이 丙에게 乙의 무권대리행위를 추인하면, 위 매매계약은 추인한 때가 아니라 무권대리행위로 소급하여 효력이 있다(제133조). 정답: ①

33 협의의 무권대리에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 무권대리인에게 대리권한이 없다는 것을 알지 못한 상대방은 본인에 대하여 최고는 할 수 있지만 철회는 할 수 없다.
- ② 무권대리의 경우에 본인은 이를 추인하는 것이 가능하지만 추인은 반드시 상대방에 대해서 할 것을 필요로 한다.
- ③ 무권대리인은 본인의 추인을 얻거나 또는 진실한 대리권을 가지고 있었다는 것을 증명하지 못하는 한, 상대방의 선택에 따라서 계약을 이행하든가 또는 손해를 배상하여야 한다.
- ④ 무권대리의 경우에 본인이 그에 따른 법률효과를 받는 일은 있을 수 없다.
- ⑤ 상대방 없는 단독행위의 무권대리에 대하여 본인은 추인할 수 있다.

해설

③ 타당하다(제135조).
 ① 철회권은 선의의 상대방에게만 인정하나, 최고권행사는 상대방이 악의이어도 무방하다(제131조·제134조).
 ② 본인의 추인권 행사는 상대방에게 직접하지 않아도 되고 무권대리인에게 행사하여도 무방하다(제132조 단서).
 ④ 본인이 추인함으로써 그 법률효과가 본인에 대하여 발생한다(제133조).
 ⑤ 상대방 없는 단독행위의 무권대리는 절대적으로 무효이다(통설). 정답: ③

34

행위능력자 甲은 대리권 없이 乙을 대리하여 乙 소유 토지를 丙에게 매도하는 계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙이 매매계약을 추인한 경우 다른 의사표시가 없으면 그 계약은 추인한 때부터 장래를 향하여 효력이 있다.
- ② 丙이 계약 당시 甲의 대리권 없음을 알았더라도 乙의 추인이 있을 때까지 丙은 그 계약을 철회할 수 있다.
- ③ 상대방에 대한 무권대리인의 책임에 관한 규정에 의하여 甲은 丙에게 무과실책임을 진다.
- ④ 丙이 계약 당시 甲의 대리권 없음을 알았다면 丙은 상당한 기간을 정하여 乙에게 추인 여부의 확답을 최고할 수 없다.
- ⑤ 甲의 대리권 없음을 알지 못한 丙은, 乙이 甲에 대하여 매매계약을 추인한 사실을 몰랐더라도 계약을 철회할 수 없다.

해설

③ 타당한 기술이다.

① 무권대리행위의 추인은 소급효가 있다.

② 상대방 丙이 악의인 경우에는 철회권이 인정되지 아니한다.

④ 丙이 계약 당시 甲의 대리권 없음을 알았더라도 丙은 상당기간을 정하여 乙에게 추인 여부의 확답을 최고할 수 있다. 즉 악의의 상대방에게도 최고권은 인정된다.

⑤ 본인이 무권대리인에게 추인한 경우, 그 사실을 상대방이 알고 있지 못한 경우에는 상대방은 철회할 수 있다. 정답: ③

35

甲의 친구인 乙은 권한 없이 甲의 기명날인을 대행하는 방식에 의하여 약속어음을 위조하고, 丙 벤처기업에 투자하는 계약을 체결하였다. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 丙이 상당기간을 정하여 甲에게 추인 여부를 최고하였는데도 불구하고 이에 대한 확답이 없는 경우 추인을 거절한 것으로 본다.
- ② 甲이 乙의 범죄사실을 알고도 장기간 형사고소를 하지 않은 경우 묵시적인 추인에 해당한다.
- ③ 甲이 乙의 무권대리의 추인을 거절한 경우, 이에 기해 손해를 입은 丙은 乙에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 丙이 乙에 대해 계약을 철회한 후에는 甲은 그 계약을 추인할 수 없다.
- ⑤ 丙이 乙에게 대리권한이 없음을 계약 당시 알았다면 계약을 철회할 수 없다.

해설

② 협의의 무권대리에 관한 문제로서 甲의 丙에 대한 추인은 명시적일 것을 요하지 않으며, 묵시적으로도 가능하다. 그리고 구두 또는 서면·재판상 재판 외의 행사가 모두 허용된다고 본다. 그러나 예문의 경우처럼 본인 甲이 무권대리인 乙의 범죄사실에 대하여 형사고소를 하지 않았다고 해서 상대방 丙에 대한 묵시적 추인이라고는 볼 수 없다. 정답: ②

36 무권대리에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 추인은 의사표시의 전부에 대하여 하여야 하고 그 일부에 대하여 추인하거나 내용을 변경하여 추인한 경우에는 상대방의 동의를 얻지 못하는 한 무효이다.
- ② 무권대리인은 본인의 추인을 얻지 못하거나 대리권을 증명하지 못하면 상대방의 선택에 따라 이행 또는 손해배상을 하여야 한다.
- ③ 무권대리행위를 안 후 그 직후에 그것이 자기에게 효력이 없다고 이의를 제기하지 아니하고 이를 장기간에 걸쳐 방치하였다고 하더라도 묵시적 추인이 있다고 볼 수 없다
- ④ 상대방 없는 단독행위의 무권대리는 항상 무효이며 본인이 추인하더라도 아무런 효력이 없다.
- ⑤ 판례에 의하면 무권대리인이 본인을 상속한 경우 본인의 입장에서 대리의 효과를 거절할 수 있다.

해설

⑤ 무권대리인은 본인으로부터 추인권과 추인거절권을 승계하지만, 손해배상책임과 이행책임도 병존하게 되어 본인의 자격에서 추인을 거절하는 것은 신의칙에 반하여 인정되지 않는다고 한다(대법원 1994.9.27. 94다20617).

① 대법원 1982.1.16. 81다카549

② 제135조 제1항

③ 대법원 2001.3.23. 2001다4880

④ 이 경우는 본인의 추인 여부와 관계없이 언제나 절대적으로 무효이다. 본인의 추인권을 인정한다면 본인의 자의에 따라 무권대리행위의 효과가 좌우된다는 문제가 있기 때문이다. 정답: ⑤

37 乙은 대리권 없이 행위능력자인 甲의 임의대리인으로 행세하여 甲 소유의 부동산을 丙에게 매매하는 계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (표현대리는 고려하지 않으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙이 위 계약에 따라 丙에게 소유권이전등기를 해준 경우, 甲은 丙 명의등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ② 乙이 위 계약 당시 제한능력자인 경우, 乙은 丙에게 계약의 이행 또는 손해배상책임을 지지 않는다.
- ③ 甲이 乙의 무권대리행위를 알면서도 丙에게 매매대금을 청구하여 전부를 수령하였다면, 특별한 사정이 없는 한, 위 계약을 추인한 것으로 볼 수 있다.
- ④ 甲이 乙에 대하여 추인을 하였다면 丙이 그 추인 사실을 몰랐더라도 위 계약을 철회할 수 없다.
- ⑤ 甲의 유효한 추인이 있으면, 특별한 사정이 없는 한, 乙의 행위는 계약 시에 소급하여 甲에게 효력이 있다.

해설

④ 추인의 의사표시는 상대방이나 무권대리인뿐만 아니라 무권대리행위로 인한 권리의 승계인에 대하여도 할 수 있으나, 무권대리인에 대해 추인한 경우에는 상대방이 추인이 있었던 사실을 알지 못한 때에는 그에 대해 추인의 효과를 주장하지 못한다(제132조). 따라서 본인의 추인 사실을 모른 상대방은 철회할 수 있다. 정답: ④

38 무권대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무권대리행위에 대한 본인의 추인은 재판상·재판외에서 묵시적으로도 할 수 있다.
- ② 무권대리행위는 추인이나 거절 전에는 유동적 무효이다.
- ③ 본인이 무권대리행위의 추인을 거절한 후에는 다시 추인할 수 없다.
- ④ 매매계약을 체결한 무권대리인으로부터 매매대금의 일부를 본인이 수령한 경우 특별한 사정이 없는 한 본인이 무권대리행위를 묵시적으로 추인한 것으로 본다.
- ⑤ 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 과실책임이다.

해설

⑤ 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 무과실책임이다. 정답: ⑤

39 乙이 대리권 없이 甲의 대리인으로 甲소유의 토지를 丙에게 임대한 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲이 계약을 추인한 경우 다른 의사표시가 없으면 그 계약은 처음부터 유효하나, 제3자의 권리를 해치지 못한다.
- ② 乙이 이행책임 또는 손해배상책임을 져야 하는 경우 어느 책임을 부담할 것인지는 원칙적으로 丙이 선택한다.
- ③ 甲이 사망하고 乙이 유일한 상속인인 경우 乙은 이 계약의 추인을 거절하지 못한다.
- ④ 丙이 상당한 기간을 정해 추인 여부를 최고한 경우 甲이 그 기간 내에 응답을 발송하지 않으면 추인을 거절한 것으로 본다.
- ⑤ 丙이 선의인 경우 그는 甲이 계약을 추인한 후에도 그 계약을 철회할 수 있다.

해설

⑤ 상대방은 계약 당시에 무권대리인임을 알지 못한 경우에(선의) 한하여, 본인이 아직 추인하지 않고 있는 동안 본인이나 무권대리인에게 그 계약을 철회할 수 있다. 정답: ⑤

40

대리권 없는 甲은 乙 소유의 X부동산에 관하여 乙을 대리하여 丙과 매매계약을 체결하였고, 丙은 甲이 무권대리인이라는 사실에 대하여 선의·무과실이였다. 이에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 공인중개사]

- ① 丙이 乙에 대하여 상당한 기간을 정하여 추인여부를 최고하였으나 그 기간 내에 乙이 응답을 발하지 않은 때에는 乙이 추인한 것으로 본다.
- ② 乙이 甲에 대해서만 추인의 의사표시를 하였더라도 丙 은 乙의 甲에 대한 추인이 있었음을 주장할 수 있다.
- ③ 乙이 甲에게 매매계약을 추인하더라도 그 사실을 알지 못하고 있는 丙은 매매계약을 철회할 수 있다.
- ④ 乙이 丙에 대하여 추인하면 특별한 사정이 없는 한, 추인은 매매계약 체결 시에 소급하여 그 효력이 생긴다.
- ⑤ 乙이 丙에게 추인을 거절한 경우, 甲이 제한능력자가 아니라면 甲은 丙의 선택에 따라 계약을 이행할 책임 또는 손해를 배상할 책임이 있다.

해설

- ① 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에 대하여 추인여부의 응답을 구하는 최고를 할 수 있다. 만약 그 기간 내에 본인이 응답을 발하지 않는 경우에는 추인을 거절한 것으로 본다(제131조).

정답: ①

41

대리권의 범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정대리권의 범위는 법정대리인에 관한 규정에 의하여 결정된다.
- ② 임의대리권은 통상 그 권한에 부수하여 필요한 한도에서 상대방의 의사표시를 수령하는 대리권을 포함한다.
- ③ 계약체결의 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 체결된 계약을 해제할 수 있는 권한을 갖지 않는다.
- ④ 대리권의 범위를 정하지 않은 임의대리인은 대리의 목적인 물건의 성질이 변하지 않는 범위에서 그 이용행위를 할 수 있다.
- ⑤ 예금계약의 체결을 위임받은 자의 대리권에는 특별한 사정이 없는 한 그 예금을 담보로 대출을 받을 수 있는 권한이 포함되어 있다.

해설

- ⑤ 예금계약의 체결을 위임받은 자의 대리권에는 특별한 사정이 없는 한 그 예금을 담보로 대출을 받을 수 있는 권한까지는 포함되지 아니한다. 정답: ⑤

42 복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정대리인은 자신의 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.
- ② 임의대리인은 부득이한 사유가 있는 경우, 복대리인을 선임할 수 있다.
- ③ 법정대리인이 부득이한 사유로 복대리인을 선임한 경우, 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 있다.
- ④ 임의대리인이 본인의 승낙을 얻어 복대리인을 선임한 경우, 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 없다.
- ⑤ 대리인이 대리권 소멸 후 복대리인을 선임하여 그로 하여금 대리행위를 하도록 한 경우, 복대리인의 대리행위에 대하여 표현대리에 관한 규정이 적용될 수 있다.

해설

- ④ 임의대리인은 원칙적으로 복임권이 없으나 예외적으로 본인의 승낙 또는 부득이한 사유가 있는 때에 한하여 복임권을 갖는다(과실책임). 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 책임이 경감된다. 즉, 본인이 지명한 자가 부적임 또는 불성실함을 알고도 본인에게 그 통지를 하지 않았거나 해임을 태만히 한 때가 아니면 책임지지 아니한다(제121조 제2항).

정답: ④

43 복대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 복대리인은 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다.
- ② 본인의 묵시적 승낙에 기초한 임의대리인의 복임권행사는 허용되지 않는다.
- ③ 임의대리인이 본인의 명시적 승낙을 얻어 복대리인을 선임한 때에는 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 없다.
- ④ 법정대리인이 그 자신의 이름으로 선임한 복대리인은 법정대리인의 대리인이다.
- ⑤ 복대리인의 대리행위에 대해서는 표현대리가 성립할 수 없다.

해설

- ① 본인에 대하여는 복대리인도 대리인과 동일한 지위를 가진다.
 ② 본인의 승낙은 사안에 따라 명시적일 것을 요하는 경우도 있으나 원칙적으로 묵시적 승낙도 무방하다.
 ③ 임의대리인이 본인의 명시적 승낙을 얻어 복대리인을 선임한 때에도 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 있다(과실책임).
 ④ 복대리인은 본인의 대리인이며, 복대리인은 언제나 임의대리인이다.
 ⑤ 복대리인의 대리행위에 대해서도 표현대리가 성립할 수 있다. 정답: ①

44

무권대리와 표현대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 강행법규에 위반한 무효의 대리행위에 대해서도 표현대리의 법리가 적용될 수 있다.
- ② 무권대리행위의 주인은 본인이 무권대리행위의 상대방뿐만 아니라 무권대리인에 대해서도 할 수 있다.
- ③ 상대방의 유권대리 주장에는 표현대리의 성립 역시 포함되므로 법원은 표현대리의 성립 여부까지 판단해야 한다.
- ④ 무권대리인이 무권대리행위 후 본인을 단독상속한 경우, 그 무권대리행위가 무효임을 주장하는 것은 신의칙에 반하지 않는다.
- ⑤ 표현대리가 성립하는 경우, 상대방에게 과실이 있으면 과실상계의 법리가 적용된다.

해설

- ② 타당한 기술이다.
- ① 강행법규에 위반하여 무효인 대리행위에는 표현대리의 법리가 적용될 수 없다.
- ③ 유권대리의 주장에 표현대리의 성립이 포함되는 것은 아니다.
- ④ 무권대리인이 무권대리행위 후 본인을 단독상속한 경우, 그 무권대리행위가 무효임을 주장하는 것은 신의칙에 반한다.
- ⑤ 표현대리가 성립하는 경우, 상대방에게 과실이 있다 하더라도 과실상계의 법리를 적용하여 본인의 책임이 경감되지 아니한다. 정답: ②

45

법률행위의 대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2023' 감정평가사]

- ① 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 대리권의 흠결에 관하여 대리인에게 귀책사유가 있는 경우에만 인정된다.
- ② 민법 제124조에서 금지하는 자기계약이 행해졌다면 그 계약은 유동적 무효이다.
- ③ 행위능력자인 임의대리인이 성년후견개시 심판을 받아 제한능력이자 되면 그의 대리권은 소멸한다.
- ④ 대리인이 수인인 경우, 법률 또는 수권행위에서 다른 정함이 없으면 각자가 본인을 대리한다.
- ⑤ 상대방 없는 단독행위의 무권대리는 특별한 사정이 없는 한 확정적 무효이다.

해설

- ① 무권대리인에게 고의 또는 과실 있음을 요하지 않는다(무과실책임). 정답: ①

46 18세의 甲은 乙의 대리인을 사칭하여 그가 보관하던 乙의 노트북을 그 사정을 모르는 丙에게 팔았다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 乙이 丙에게 매매계약을 추인한 때에는 매매계약은 확정적으로 효력이 생긴다.
- ② 乙이 甲에게 추인한 때에도 그 사실을 모르는 丙은 매매계약을 철회할 수 있다.
- ③ 乙이 추인하지 않으면, 甲은 자신의 선택으로 丙에게 매매계약을 이행하거나 손해를 배상하여야 한다.
- ④ 丙이 甲에게 대리권이 없음을 알았더라도 丙은 乙에게 추인 여부의 확인을 최고할 수 있다.
- ⑤ 乙이 추인한 때에는 甲은 자신이 미성년자임을 이유로 매매계약을 취소하지 못한다.

해설

- ③ 무권대리인이 제한능력자인 경우에는 계약의 이행 또는 손해배상책임을 지지 아니한다(제135조 제2항). 정답: ③

47 표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ㉠ 대리권 소멸 후의 표현대리에 관한 규정은 임의대리에만 적용된다.
- ㉡ 표현대리를 주장할 때에는 무권대리인과 표현대리에 해당하는 무권대리행위를 특정하여 주장하여야 한다.
- ㉢ 강행법규를 위반하여 무효인 법률행위라 하더라도 표현대리의 법리는 준용될 수 있다.
- ㉣ 표현대리가 성립하는 경우에도 상대방에게 과실이 있다면 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 있다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉠, ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉣, ㉣

해설

- ㉠ 임의대리에만 적용되며 법정대리에는 적용되지 않는 것은 제125조(대리권수여의 표시에 의한 표현대리)에 한하며, 제126조와 제129조의 표현대리는 임의대리와 법정대리 모두에 적용된다.
 ㉢ 강행법규를 위반하여 무효인 법률행위는 추인의 여지가 없어 표현대리의 법리는 적용될 수 없다.
 ㉣ 표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다. 정답: ④

제4절 무효와 취소

1 기본문제

01 다음은 그 효력의 법적 성질이 같은 것을 묶은 것이다. 틀린 것은?

- ① 사회질서 위반의 법률행위 — 토지거래허가를 받지 않은 매매계약의 효력
- ② 무권대리인이 한 법률행위의 효력 — 무권리자의 처분행위
- ③ 사기·강박에 의한 의사표시 — 중요부분에 관한 착오에 의한 의사표시
- ④ 통정허위표시 — 상대방이 표의자의 진의 아님을 안 비진의 의사표시
- ⑤ 중요부분에 해당하지 않는 동기의 착오 — 법정대리인이 동의한 미성년자의 법률행위

해설

- ① 사회질서위반의 법률행위는 확정적 무효이나 토지거래허가를 받지 않은 매매계약의 효력은 유동적 무효이다. 정답: ①

02 무효가 아닌 것은?

- ① 통정한 허위의 의사표시
- ② 반사회질서의 법률행위
- ③ 불공정한 법률행위
- ④ 제한능력자의 법률행위
- ⑤ 원시적 불능인 법률행위

해설

㉔ 민법상 무효인 법률행위와 취소할 수 있는 법률행위

무효인 법률행위	취소할 수 있는 법률행위
㉑ 의사무능력자의 법률행위 ㉒ 불능인 법률행위 ㉓ 강행법규(효력규정)에 위반한 법률행위 ㉔ 반사회질서의 법률행위 ㉕ 불공정한 법률행위 ㉖ 비진의표시(상대방의 약의 또는 과실) ㉗ 통정허위표시	㉑ 제한능력자의 법률행위 ㉒ 착오에 의한 의사표시 ㉓ 사기·강박에 의한 의사표시
㉑㉒㉓㉔㉕ : 절대적 무효 ㉖㉗ : 상대적 무효	㉑ : 절대적 취소 ㉒㉓ : 상대적 취소

정답: ④

03 무효와 취소에 대한 설명으로 옳은 것은 몇 개인가?

- ㉠ 강박을 당하여 물건을 매수한 자가 공포심에서 벗어난 후 그 물건을 제3자에게 매도한 경우에는 법정추인으로 볼 수 있다.
- ㉡ 무권대리행위는 본인의 추인을 받으면 소급해서 유효하게 되는 유동적 무효이다.
- ㉢ 유동적 무효는 허가를 받으면 법률행위시에 소급하여 유효하다.
- ㉣ 취소할 수 있는 법률행위를 한 자의 채권자라도 그 취소권을 대위행사할 수 없다.
- ㉤ 판례는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 허가구역 내의 토지를 관할관청의 허가를 받지 않고 이를 배제할 목적으로 매매계약을 체결한 경우는 유동적 무효로 판단한다.
- ㉥ 법률행위의 취소권자가 항상 추인권을 갖는 것은 아니다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

해설

틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉡ 행사상의 일신전속권이 아닌 한 대위행사가 가능하다.
- ㉤ 허가를 받기 전의 거래계약이 처음부터 허가를 배제하거나 잠탈하는 내용의 계약일 경우에는 확정적으로 무효로서 유효화될 여지가 없다(대법원 1991.12.24. 90다12243). 정답: ④

04 무효를 절대적 무효와 상대적 무효로 구별할 때 상대적 무효에 해당하는 행위는?

- ① 불공정한 법률행위 ② 의사무능력자의 법률행위
- ③ 통정허위표시 ④ 반사회질서의 법률행위
- ⑤ 목적이 불능인 법률행위

해설

㉠ 절대적 무효와 상대적 무효

구 분	내 용
상대적 무효	㉠ 특정인에 대하여서는 주장할 수 없는 무효 ㉡ 허위표시·비진의표시의 예외의 경우
절대적 무효	㉢ 누구에게나 그 효과를 주장할 수 있는 무효 ㉣ 상대적 무효 이외의 전부 예: ▪ 의사무능력자의 법률행위 ▪ 불능인 법률행위 ▪ 강행법규(효력규정)에 위반한 법률행위 ▪ 반사회질서의 법률행위 ▪ 불공정한 법률행위 등

정답: ③

05 다음 중 소급효가 인정되는 것은?

- ① 법인설립허가의 취소
- ② 부재자재산관리명령의 취소
- ③ 혼인의 취소
- ④ 미성년자의 법률행위에 대한 법정대리인의 동의의 취소
- ⑤ 무권대리에 있어서 본인의 추인

해설

㉠ 소급효 있는 행위와 소급효 없는 행위

소급효 있는 행위	소급효 없는 행위
㉠ 실종선고의 취소(제29조) ㉡ 제한능력자의 법률행위의 취소(제5조 제2항·제10조·제13조) ㉢ 착오에 의한 의사표시의 취소(제109조) ㉣ 사기·강박에 의한 의사표시의 취소(제110조) ㉤ 무권대리행위의 추인(제133조) ㉥ 소멸시효의 완성(제167조) ㉦ 선택채권에 있어서의 선택(제386조) ㉧ 상계(제493조) ㉨ 계약의 해제(제548조) ㉩ 이혼의 취소(제838조) ㉪ 인지(제860조) ㉫ 상속재산의 분할(제1015조) ㉬ 상속의 포기(제1042조)	㉭ 미성년자의 영업허락의 취소(제8조) ㉮ 성년후견종료의 심판(제11조) ㉯ 한정후견종료의 심판(제14조) ㉰ 부재자재산관리명령의 취소(제22조) ㉱ 법인설립허가의 취소(제38조) ㉲ 무효행위의 추인(제139조) ㉳ 기한부 법률행위의 효력(제152조) ㉴ 혼인의 취소(제824조) ㉵ 인지의 취소(제861조) ㉶ 입양의 취소(제897조) ㉷ 조건의 성취(제147조) ㉸ 계약의 해지(제269조) ㉹ 공유물의 분할(제550조)

정답: ⑤

06 다음 중 민법상 소급효가 없는 법률행위는 어느 것인가?

- ① 기한부 법률행위의 기한도래
- ② 제한능력자의 법률행위의 취소
- ③ 실종선고의 취소
- ④ 착오·사기·강박에 의한 의사표시의 취소
- ⑤ 무권대리행위의 추인

해설

① 기한도래의 효력은 절대적으로 소급효가 인정되지 않는다. 정답: ①

07 무효행위의 추인에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 무효인 법률행위는 추인하여도 그 효력이 생기지 않는다.
- ② 당사자가 무효임을 알고 추인한 때에는 새로운 법률행위로 본다.
- ③ 반사회질서의 법률행위처럼 무효의 원인이 없어지지 않는 경우에 있어서는 추인의 여지도 없다.
- ④ 무효행위의 추인에는 소급효가 없지만, 당사자간에 한해서는 소급효를 인정할 수 있다는 것이 통설적 견해이다.
- ⑤ 가족법상의 신분행위에도 무효행위의 추인에 관한 규정이 적용된다.

해설

㉔ 무효행위의 추인

- ㉔ 당사자가 법률행위가 무효임을 알고서 추인한 경우에는 그때부터 새로운 법률행위를 한 것으로 본다. 따라서 무효행위의 추인은 소급효가 없다(비소급적 추인).
- ㉕ 절대적 무효에 해당하는 법률행위는 추인하여도 유효로 될 여지가 없다.
- ㉖ 무효행위의 추인은 소급효가 없는 것이 원칙이나(제139조), 예외적으로 당사자 사이에서만 소급효를 인정하는 것은 무방하다(통설).
- ㉗ 가족법상의 행위에는 무효행위의 추인에 관한 규정이 적용되지 않는다. 정답: ⑤

제5장 기본문제

08 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 허가구역내에 속하는 토지에 대하여 거래계약을 맺을 때에는 관할시장 등의 허가를 얻어야 하는데, 판례는 그 허가를 받지 아니하고 체결한 거래계약은 유동적 무효라고 한다. 유동적 무효에 관한 판례이론의 내용이 아닌 것은?

- ① 허가를 얻기까지는 법률상 미완성의 법률행위로서 물권적 효력은 물론 채권적 효력도 발생하지 않는다.
- ② 유동적 무효인 상태에 있어서 계약내용에 따른 채무불이행을 이유로 계약을 해제할 수는 없다.
- ③ 허가를 얻기까지 당사자는 계약에 기한 이행청구를 할 수 없다.
- ④ 허가를 얻기까지는 확정적 무효와 다를 바 없기 때문에, 이미 지급한 계약금 등이 있으면 부당이득을 이유로 그 반환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 당사자 사이에 있어서는 그 계약이 효력있는 것으로 완성될 수 있도록 공동으로 관할관청의 허가를 신청할 의무를 진다.

해설

- ㉔ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상의 허가구역 내의 '토지 등의 거래계약'은 관할관청의 허가를 받아야만 그 효력이 발생하고 허가를 받기 전에는 물권적 효력은 물론 채권적 효력도 발생하지 아니하여 무효라고 보아야 할 것이나, 허가받을 것을 전제로 한 거래계약일 경우에는 일단 허가를 받으면 그 계약은 소급하여 유효한 계약이 되고 이와 달리 불허가가 된 때에는 무효로 확정되는 것으로서 허가를 받기까지는 유동적 무효의 상태에 있다고 보아야 하고, 당사자 사이에 있어서는 그 계약이 효력 있는 것으로 완성될 수 있도록 서로 협력할 의무가 있음이 당연하므로 계약의 쌍방 당사자는 공동으로 관할 관청의 허가를 신청할 의무가 있으므로 허가 받기 전의 매매계약이 유동적 무효라고 하여 매매계약에 관한 계약금을 교부한 상태에 있는 계약당사자 일방이 언제든지 계약의 무효를 주장하여 부당이득으로 계약금의 반환을 구할 수는 없다(대법원 1993.6.22. 91다21435). 정답: ④

09 무효에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 무효인 법률행위는 행위시부터 당연히 효력이 없다.
- ② 모든 자는 무효인 법률행위를 처음부터 효력이 없는 것으로 다루지 않으면 안된다.
- ③ 무효는 방치해 두어도 효력이 없는 것은 변함이 없다.
- ④ 무효인 행위는 이를 추인할 수 없다.
- ⑤ 무효는 누구에 의해서든지 누구에 대해서든지 또한 언제나 이를 주장할 수 있다.

해설

㉠ 무효와 취소의 구별

분 류	무 효	취 소
특정인의 주장	특정인의 주장을 필요로 하지 않고 당연 무효이다.	특정인(취소권자)의 주장이 있어야 비로소 효력이 없게 된다(일단은 유효).
성립시의 효력	처음부터 효력이 없다.	취소를 하기 전에는 일단은 효력이 있는 것으로 다루어진다.
추인의 차이	새로운 법률행위로 본다. (비소급적 추인)	취소권의 포기과 같다.
시간의 경과와 보정	시간의 경과에 의하여 효력에 변동이 생기지 않고 언제나 무효이다.	㉠ 일정한 시간이 경과하면 취소권이 소멸한다. ㉡ 취소권을 행사하면 무효, 방치하면 유효(취소권상실)이다.

정답: ④

10 토지거래계약허가구역 내에서의 허가과 관련하여 확정적으로 무효가 되는 것들이다. 틀린 것은 어느 것인가?

- ① 허가를 배제하거나 허가를 잠탈하는 내용의 계약을 체결한 경우
- ② 관할 관청으로부터 허가가 불허된 경우
- ③ 당사자 일방이 허가신청협력의무의 이행거절의 의사를 명백히 표시한 경우
- ④ 당사자 쌍방이 허가신청을 아니하기로 의사표시를 명백히 한 경우
- ⑤ 허가를 받지 않고 있는 동안에 토지거래계약허가구역의 지정이 해제된 경우

해설

- ⑤ 토지거래허가구역으로 지정된 토지에 관하여 국토교통부장관이 허가구역의 지정을 해제한 경우에는 허가구역의 지정이 해제되기 전에 다른 사유로 확정적으로 무효로 된 경우를 제외하고는 더 이상 관할 행정청으로부터 토지거래허가를 받을 필요가 없이 확정적으로 유효로 된다고 보아야 할 것이지만 여전히 그 계약이 유효적 무효 상태에 있다고 볼 것은 아니다(대법원 1999.7.9. 97누11607).
- ① 토지거래허가구역 내의 토지에 관하여 소유권 등 권리를 이전 또는 설정하는 내용의 거래계약을 체결한 경우에 그 거래계약이 처음부터 허가를 배제하거나 잠탈하는 내용의 계약인 경우에는 확정적으로 무효이다(대법원 1997.12.26. 97다41318).
- ②③ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 토지거래허가를 받지 않아 거래계약이 유효적 무효의 상태에

있는 경우 그와 같은 유동적 무효 상태의 계약은 관할관청의 불허가처분이 있을 때 뿐만 아니라 당사자 쌍방이 허가신청협력의무의 이행거절의 의사를 명백히 표시한 경우에는 그 계약관계는 확정적으로 무효가 된다(대법원 1998.3.27. 97다36996).

- ④ 토지거래허가구역 내의 토지에 관한 매매계약은 당사자 일방의 매매계약의 철회로 확정적으로 무효가 되는 것이 아니라, 당사자 쌍방이 허가신청을 하지 아니하기로 의사표시를 명백히 한 때에 비로소 확정적으로 무효가 된다(대법원 1995.12.26. 93다59526). 정답: ⑤

11 법률행위의 취소에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 제한능력자도 취소권을 행사할 수 있다.
- ② 임의대리인은 자신의 대리행위에 취소원인이 있는 경우 당연히 취소할 수 있다.
- ③ 취소권만의 승계는 인정되지 않는다.
- ④ 취소는 시간의 경과에 의해 취소권이 제한되는 수가 있다.
- ⑤ 취소할 수 있는 행위를 추인할 수 있는 자는 취소권을 가진 자이다.

해설

② 임의대리에 있어서 대리인이 행한 행위에 취소원인이 있으면 그 취소권은 직접 본인에게 귀속한다. 따라서 임의대리인이 취소하려면 본인으로부터 그에 관한 대리권을 수여 받아야 하고, 취소에 관한 대리권 없이 당연히 취소할 수 있는 것은 아니다.

①⑤ 제140조, 제143조

③ 취소권만의 승계는 인정되지 않으며, 취소할 수 있는 행위에 의하여 취득한 권리의 승계가 있는 경우에만 특정승계인은 취소권자가 된다.

④ 제146조 정답: ②

12 다음 중 취소권을 가질 수 없는 사람은?

- ① 취소권자의 특정승계인
- ② 착오로 인한 의사표시를 한 사람의 임의대리인
- ③ 진의 아닌 의사표시를 한 사람의 상속인
- ④ 강박에 의한 의사표시를 한 사람의 법정대리인
- ⑤ 피한정후견인의 법정대리인

해설

③ 비진의의사표시는 원칙적으로 유효이며, 상대방의 악의 또는 과실인 경우에는 무효가 된다. 따라서 취소사유가 아니다. 정답: ③

13 법률행위의 취소에 관한 다음 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 취소의 효과는 선의의 제3자에게 대항할 수 없는 것이 원칙이다.
- ② 취소할 수 있는 법률행위는 취소의 원인이 종료되기 전에 추인할 수 있는 것이 원칙이다.
- ③ 취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 보는 것이 원칙이다.
- ④ 취소권의 행사기간은 법률에 의하여 정하여 있다.
- ⑤ 취소할 수 있는 의사표시를 한 자의 대리인도 그 행위를 취소할 수 있다.

해설

㉠ 취소할 수 있는 행위의 추인

의 의	㉠ 취소할 수 있는 법률행위를 취소하지 않겠다는 의사표시이다. ㉡ 형성권이자 상대방 있는 단독행위이다. ㉢ 취소권의 포기과 같다.
요 건	㉠ 추인권자(취소권자)가 행사하여야 한다. ㉡ 취소의 원인이 종료한 후에 행사(법정대리인은 제한 없음)하여야 한다. ㉢ 취소할 수 있는 것임을 알고서 행사하여야 한다.
효 과	추인한 후에는 취소할 수 없으며 법률행위는 유효한 것으로 확정된다.

정답: ②

14 甲은 乙로부터 속아서 그의 토지를 乙에게 싸게 팔고 등기도 이전해 주었고, 乙은 그 토지를 丙에게 비싸게 팔고 등기를 넘겨주었다. 그 뒤에 곧 甲은 자신이 속은 것을 알고 그 토지를 되찾으려고 한다. 甲은 누구에게 어떠한 주장을 하여야 하는가?

- ① 乙에게 취소의 의사표시를 하여야 한다.
- ② 丙에게 취소의 의사표시를 하여야 한다.
- ③ 乙에게 계약의 무효 주장을 하여야 한다.
- ④ 丙에게 계약의 무효 주장을 하여야 한다.
- ⑤ 乙과 丙 모두에게 계약의 무효 주장을 하여야 한다.

해설

- ① 취소의 상대방이 확정되어 있는 경우에 취소는 취소할 수 있는 법률행위의 상대방(본래의 상대방)에 대하여 하여야 한다(제142조). 정답: ①

15 취소할 수 있는 행위의 추인에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 취소할 수 있는 법률행위가 취소된 이상 그 후에는 취소할 수 있는 법률행위의 추인에 의하여 확정적으로 유효로 할 수는 없다.
- ② 취소할 수 있는 행위에 의하여 성립한 채무를 승인하더라도 그 승인이 당연히 추인으로 되지는 않는다.
- ③ 추인은 누가 하든 취소의 원인이 종료한 후에 하지 않으면 효력이 없다.
- ④ 추인권자는 취소권자와 같다.
- ⑤ 추인할 수 있는 날이란 취소의 원인이 종료되어 취소권행사에 대한 장애가 없어져서 취소권자가 취소의 대상인 법률행위를 추인할 수도 있고 취소할 수도 있는 상태가 된 때를 가리킨다.

해설

- ③ 추인은 취소원인이 종료한 후에 하여야 하나(제144조 제1항), 이 규정은 법정대리인의 추인에는 적용되지 않는다(제144조 제2항).
- ① 대법원 1997.12.12. 95다38240
- ② 추인은 그 행위가 취소할 수 있는 것임을 알고 하여야 하기 때문에 채무의 승인이 있다고 하여 당연히 추인으로 되지 않는다.
- ④ 추인은 취소권의 포기이므로, 법률행위의 취소권자가 추인할 수 있다(제143조 제1항).
- ⑤ 대법원 1998.11.27. 98다7421 정답: ③

16

다음에서 취소할 수 있는 법률행위의 추인이라고 할 수 없는 것은?

- ① 취소할 수 있는 행위에서 생긴 채무가 인수된 경우
- ② 취소할 수 있는 행위에서 생긴 채무의 일부를 이행한 경우
- ③ 채권자가 취소할 수 있는 행위에서 생긴 채권에 관해 보증을 받은 경우
- ④ 취소권이 있는 채무자가 취소할 수 있는 행위에서 생긴 채무에 관하여 이의 없이 강제집행을 받은 경우
- ⑤ 취소권을 가진 채권자가 취소할 수 있는 행위에서 생긴 채무의 이행을 청구한 경우

해설

◎ 법정추인

- ① 채무인수는 법정추인사유에 해당하지 않는다.

의 의	추인이라고 인정할 수 있는 일정한 사실이 있을 때 법률상 당연히 추인이 있었던 것으로 간주하는 제도이다.	
요건	사 유	내 용
	전부나 일부의 이행	㉠ 취소권자가 이행한 경우 ㉡ 상대방의 이행을 수령한 경우
	이행의 청구	취소권자가 청구한 경우에 한한다.
	경 개	취소권자가 채권자 또는 채무자로서 구채권·채무를 소멸시키고 신채권·채무를 성립시키는 계약을 체결한 경우
	담보의 제공	취소권자가 채무자로서 담보를 제공하거나 채권자로서 담보의 제공을 받는 경우
	권리의 양도	㉠ 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도 ㉡ 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리 위에 제한물권을 설정하는 것을 포함 ㉢ 취소함으로써 발생하게 될 장래의 채권(장래 취소한다면 취득하게 될 손해배상청구권)의 양도는 포함되지 않음
	강제집행	취소권자가 채권자로서 집행하는 경우와 취소권자가 채무자로서 집행을 받는 경우도 포함한다.
㉠ 이상의 사실 중 하나일 것 ㉡ 취소의 원인이 종료 후의 행사일 것 ㉢ 이의를 유보하지 않았을 것		
효과	법정추인 역시 추인으로 간주(다시는 취소를 행하지 못함)한다.	

정답: ①

17 법률행위에 대한 취소권은 일정한 기간 안에 행사하지 않으면 소멸하게 된다. 다음 중 민법이 규정하는 것은?

- ① 추인할 수 있는 때로부터 1년 이내, 법률행위를 한 때로부터 5년 이내에 행사하여야 한다.
- ② 추인할 수 있는 때로부터 2년 이내, 법률행위를 한 때로부터 10년 이내에 행사하여야 한다.
- ③ 추인할 수 있는 때로부터 1년 이내, 법률행위를 한 때로부터 10년 이내에 행사하여야 한다.
- ④ 추인할 수 있는 때로부터 3년 이내, 법률행위를 한 때로부터 10년 이내에 행사하여야 한다.
- ⑤ 추인할 수 있는 때로부터 5년 이내, 법률행위를 한 때로부터 10년 이내에 행사하여야 한다.

해설

◎ 취소권의 단기소멸

☐ 추인할 수 있는 날로부터 3년 내
☐ 법률행위를 한 날로부터 10년 내

불행사 → 취소권소멸

㉠ 취소권자의 상대방보호제도이다.

㉡ 두 기간 중 어느 것이든 먼저 경과하면 취소권이 소멸한다. 정답: ④

18 A는 B의 사기에 의하여 자기의 토지에 C를 위한 지상권을 설정하였다. 그 후 A는 토지를 D에게 양도하고 C는 E에게 지상권을 양도한 경우 취소권자와 그 상대방에 대한 설명으로 가장 타당한 것은? (단, C가 B의 사기를 알았던 것으로 가정한다)

- ① D는 E에게 취소할 수 있다.
- ② D 또는 B는 C에게 취소할 수 있다.
- ③ A는 D에게 취소할 수 있다.
- ④ A 또는 D는 E에게 취소할 수 있다.
- ⑤ A 또는 D는 C에게 취소할 수 있다.

해설

⑤ D는 취소권자의 특정승계인으로서 취소권을 행사할 수 있으며, 취소권의 행사는 본래의 법률행위의 상대방(C)에게 행사하여야 한다. 정답: ⑤

01

다음 중 무효인 법률행위에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 사람의 생체장기 일부에 대한 매매계약
- ㉡ 의사무능력자가 체결한 주택의 매매계약
- ㉢ 사기에 의한 토지매매계약
- ㉣ 상대방과 통정하여 허위로 체결한 도급계약
- ㉤ 피성년후견인의 자기 소유 건물에 대한 매매계약

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉡, ㉢, ㉣
- ③ ㉠, ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉢, ㉤
- ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

해설

- ㉠ 사기에 의한 토지매매계약은 취소사유이다(제109조).
- ㉡ 피성년후견인의 자기 소유 건물에 대한 매매계약은 취소사유이다(제10조). 정답: ③

02

다음 법률행위 중 그 효력이 상대적 무효인 것은?

- ① 의사능력의 흠결로 인한 법률행위
- ② 반사회질서인 법률행위
- ③ 효력규정에 위반한 법률행위
- ④ 통정허위표시인 법률행위
- ⑤ 불공정한 법률행위

해설

- ①②③⑤는 누구에게든, 즉 선의의 제3자에게도 무효로써 대항(주장)할 수 있는 절대적 무효이다.
- ④ 통정허위표시인 법률행위는 법률행위의 당사자 간에는 무효이나 선의의 제3자에 대하여는 그 무효로써 대항(주장)할 수 없는 상대적 무효이다. 정답: ④

03

취소원인이 있는 법률행위는?

[2020' 공인중개사]

- ① 불공정한 법률행위
- ② 불법조건이 붙은 증여계약
- ③ 강행법규에 위반한 매매계약
- ④ 상대방의 사기로 체결한 교환계약
- ⑤ 원시적·객관적 전부불능인 임대차계약

해설

- ①②③⑤는 절대적 무효이고, ④의 사기에 의한 교환계약은 취소할 수 있는 법률행위이다. 정답: ④

할 의무가 있음이 당연하므로, 계약의 상대방사자는 공동으로 관할 관청의 허가를 신청할 의무가 있고, 이러한 의무에 위반하여 허가신청절차에 협력하지 않는 당사자에 대하여 상대방은 협력의 무의 이행을 소송으로써 구할 이익이 있다(대법원 1991.12.24. 90다12243).

- ㉔ 유동적 무효와 부당이득의 법리: 유동적 무효상태와 매매계약을 체결하고 매수인이 이에 기하여 임의로 지급한 계약금은 그 계약이 유동적 무효상태로 있는 한 이를 부당이득으로 반환을 구할 수 없고 유동적 무효상태는 확정적으로 무효가 되었을 때 비로소 부당이득으로 그 반환을 구할 수 있다(대법원 1993.7.27. 91다33766).

민법상 유동적 무효의 법리가 적용될 수 있는 것으로 정지조건부 법률행위·시기부법률행위·무권대리행위의 추인(제130조)이 있다. 여기서 무권대리의 추인의 예를 들면 무권대리인의 행위는 행위 당시 확정적 무효가 아니라 본인의 추인이 있게 되면 처음부터 유권대리이었던 것으로 그 효력이 발생하게 된다. 정답: ㉔

06 토지거래허가를 받지 않아 토지매매계약이 유동적 무효의 상태에 있는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉑ 위 매매계약이 확정적으로 무효로 됨에 있어서 귀책사유가 있는 자는 그 계약의 무효를 주장할 수 없다.
- ㉒ 허가구역 지정이 해제되면 위 매매계약은 확정적 유효로 된다.
- ㉓ 허가구역 지정기간이 만료되었음에도 허가구역 재지정을 하지 아니한 경우, 위 매매계약은 확정적 유효로 된다.
- ㉔ 허가를 받으면 위 매매계약은 소급해서 유효로 되므로 허가 후에 새로 매매계약을 체결할 필요는 없다.
- ㉕ 사기에 의하여 위 매매계약이 체결된 경우, 취소권자는 토지거래허가를 신청하기 전에 사기에 의한 계약의 취소를 주장하여 거래허가신청협력에 거절의사를 일방적으로 명백히 함으로써, 그 계약을 확정적으로 무효화 시킬 수 있다.

해설

- ㉑ 토지거래허가(土地去來許可)를 받지 아니하여 유동적 무효상태에 있는 계약이라고 하더라도 일단 거래허가신청을 하여 불허되었다면 특별한 사정이 없는 한, 불허된 때로부터 그 거래계약은 확정적으로 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 거래허가신청을 하지 아니하여 유동적 무효상태에 있던 계약이 확정적으로 무효로 됨에 있어서 귀책사유가 있는 자라고 하더라도 그 계약의 무효를 주장하는 것이 신의칙에 반한다고 할 수 없다(대법원 1995.02.28. 94다51789). 정답: ㉑

07 법률행위의 무효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉑ 법률행위의 일부분이 무효인 경우, 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 않는다.
- ㉒ 매매계약이 매매대금의 과다로 인하여 불공정한 법률행위로서 무효인 경우, 무효행위의 반환에 관한 규정이 적용될 수 없다.

- ③ 무효행위의 추인은 명시적으로뿐만 아니라 묵시적으로도 할 수 있다.
- ④ 부동산 이중매매에서 매도인의 배임행위에 제2매수인이 적극 가담한 경우, 제2매수인의 매매계약은 무효이고 추인에 의하여 유효로 되지 않는다.
- ⑤ 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용하기로 한 약정은 그 때부터 유효하고, 이로써 그 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다.

해설

- ② 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 ‘불공정한 법률행위’에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용되어 당사자 쌍방이 위와 같은 무효를 알았더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립할 수 있다(대법원 2011.04.28. 2010다106702). 정답: ②

08 법률행위의 무효에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법률행위의 당사자가 그의 행위가 무효임을 알고서 이를 추인하는 때에는 새로운 법률행위를 한 것으로 본다.
- ② 강행법규 위반의 행위는 추인하여도 유효로 될 수 없다.
- ③ 무효행위는 당사자가 추인을 하여도 원칙적으로 처음에 소급하여 효력을 발생하지 않는다.
- ④ A의 소유물을 B가 자기의 이름으로 처분한 경우에, A가 이를 추인하면, B의 처분행위는 그 행위를 한 때로부터 유효하게 된다.
- ⑤ 타인의子を 자기의子로 출생신고한 경우 입양의 효력을 인정하지 않는다.

해설

- ⑤ 판례는 타인의 자를 자기의 출생자로 출생신고한 경우에 입양의 효력을 인정하고(대법원 1977.7.26. 76다792), 혼인 외의 출생자를 혼인 중의 출생자로 출생신고한 경우에 친생자 출생신고로는 무효이지만 인지신고로는 효력을 인정한다(대법원 1989.9.12. 88누9305).
- ① 제139조 단서
- ② 무효행위의 추인은 무효의 원인이 없어진 것을 전제로 하여 그 추인한 때로부터 새로운 법률행위를 한 것으로 보기 때문에 반사회질서의 법률행위나 강행법규 위반의 행위의 경우와 같이 무효의 원인이 없어지지 않는 경우에는 그 추인의 여지가 없다. 판례도 “불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 추인에 의하여 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다”(대법원 1994.6.24. 94다1090)고 한다.
- ③ 무효행위의 추인은 원칙적으로 소급효가 없는 것이 원칙이다. 다만 당사자 사이에서는 소급적 추인을 하는 것은 인정된다.
- ④ 무권리자의 처분행위에 대하여 원래의 권리자가 이를 추인하여 그 처분의 효력이 자기에게 미치게 할 수 있는가에 관해 민법은 아무런 규정도 두고 있지 않으나, 판례는 타인의 권리를 자기의 이름으로 또는 자기의 권리로 처분한 후에 본인이 그 처분을 인정하였다면 특별한 사정이 없는 한 무권대리에 있어서 본인의 추인의 경우와 같이 그 처분은 본인에 대하여 효력을 발생한다(대법원 1981.1.5. 79다2151)고 하여 무권대리의 추인을 유추하여 소급적 추인을 인정하고 있다.

정답: ⑤

09

법률행위의 무효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 인하여 불공정한 법률행위에 해당하는 경우, 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용될 수 있다.
- ② 취소할 수 있는 법률행위를 취소한 후에도 무효인 법률행위의 주인의 요건과 효력으로서 주인할 수 있다.
- ③ 법률행위의 일부무효에 관한 민법 제137조는 임의규정이다.
- ④ 집합채권의 양도가 양도금지특약을 위반하여 무효인 경우, 채무자는 집합채권의 일부 개별채권을 특정하여 추인할 수 없다.
- ⑤ 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용하기로 한 약정은 특별한 사정이 없는 한 그 때부터 유효하고 이로써 그 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다.

해설

- ④ 집합채권의 양도가 양도금지특약에 위반해서 무효인 경우 채무자는 일부 개별채권을 특정하여 추인하는 것이 가능하다(대법원 2009. 10. 29. 2009다47685). 정답: ④

10

甲은 乙소유의 토지 X를 1억 원에 매수하기로 하고 매매계약을 체결하였다. 그런데 토지 X는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상의 토지거래허가대상이었다. 이때 甲과 乙의 법률관계에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 따름)

- ① 이후 X토지에 대한 허가를 받으면 그 때부터 甲과 乙의 매매계약은 유효한 것으로 되고 그 계약성립시에 소급하여 유효한 계약이 되는 것은 아니다.
- ② 허가를 받기 전의 상태라도 乙은 계약금의 배액을 상환하고 적법하게 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 허가가 있기 전에는 이른바 유동적 무효의 상태로서 甲과 乙은 아무런 의무도 부담하지 않으므로 甲은 X 토지거래에 대한 허가신청에 乙이 협력할 것을 訴로써 구할 수는 없다.
- ④ X토지거래에 대하여 허가 여부가 불확정한 상태라도 甲이 이미 계약금과 중도금을 乙에게 지급한 이상 이에 대한 甲의 부당이득반환청구는 가능하다.
- ⑤ 매매계약이 있는 이후에 X 토지에 대한 토지거래허가구역지정이 해제되었더라도 당연히 甲과 乙의 매매계약이 확정적으로 유효로 되는 것은 아니다.

해설

- ② 매매 당사자 일방이 계약 당시 상대방에게 계약금을 교부한 경우 당사자 사이에 다른 약정이 없는 한 당사자 일방이 계약이행에 착수할 때까지 계약금 교부자는 이를 포기하고 계약을 해제할 수 있고, 그 상대방은 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제할 수 있음이 계약일반의 법리인 이상, 특별한 사정이 없는 한 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상의 토지거래허가를 받지 않아 유동적 무효상태인 매매계약에 있어서도 당사자 사이의 매매계약은 매도인이 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제함으로써 적법하게 해제된다(대법원 1997.6.27. 97다9369). 정답: ②

11 토지거래허가구역 내의 토지매매계약이 확정적 무효로 되는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 관할 관청의 불허가처분이 있는 경우
- ㉡ 처음부터 토지거래허가를 배제하는 내용의 계약인 경우
- ㉢ 당사자 쌍방이 허가신청협력의무의 이행거절 의사를 명백히 표시한 경우
- ㉣ 상대방의 허가신청협력의무 불이행을 이유로 일방적으로 해제의 의사표시를 한 경우
- ㉤ 허가받기 전의 상태에서 계약상 채무불이행을 이유로 손해배상을 청구한 경우

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣ ③ ㉠, ㉡, ㉢
 ④ ㉢, ㉣, ㉤ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

해설

유동적 무효(토지거래허가제)에 대한 판례의 입장을 묻는 문제이다. 판례에 의하여 유동적 무효가 확정적 무효가 되는 경우는 다음과 같다.

1. 처음부터 토지거래허가를 배제하거나 잠탈하는 내용의 계약인 경우
2. 토지거래허가 신청에 대하여 불허가처분이 있을 때
3. 거래계약에 제107조 내지 제110조의 사유가 있어 무효 또는 취소한 경우
4. 당사자 쌍방이 허가신청협력의무의 이행거절 의사를 명백히 표시한 경우

따라서 ㉠㉡㉢은 확정적 무효에 해당하는 경우이다.

유동적 무효인 상태에서 계약을 일방적으로 해제할 수 없으며(㉣), 이 경우에는 일방은 타방에게 허가절차의 협력이행을 청구(재판상 청구 포함)할 수 있을 뿐이다(여전히 유동적 무효인 상태). 그리고 허가받기 전의 상태에서 계약상 채무불이행을 이유로 손해배상을 청구할 수도 없으며(㉤), 여전히 유동적 무효인 상태에 해당한다. 정답: ③

12 법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사기를 이유로 취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다.
- ② 제한능력자가 취소권을 가지는 경우 법정대리인의 동의 없이 행사할 수 있다.
- ③ 피성년후견인은 법정대리인의 동의가 있더라도 재산상 법률행위를 스스로 유효하게 추인할 수 없다.
- ④ 법정대리인이 미성년자의 법률행위를 추인하는 경우, 취소 원인이 소멸된 후에 하여야만 효력이 있다.
- ⑤ 법률행위를 취소한 후라도 무효행위의 추인의 요건과 효력으로서 추인할 수 있다.

해설

- ④ 법정대리인이 추인하는 경우에는 취소원인의 소멸, 즉 미성년자가 성년자로 될 것을 요하지 아니한다. 정답: ④

13 무효와 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무효인 법률행위는 취소할 수 없다.
- ② 취소할 수 있는 법률행위의 추인은 취소의 원인이 소멸된 후에 하여야 효력이 있다.
- ③ 「민법」상 법률행위의 일부가 무효인 때에는 전부를 무효로 함이 원칙이다.
- ④ 취소할 수 있는 법률행위는 취소권자가 추인할 수 있고, 추인 후에는 취소할 수 없다.
- ⑤ 취소권은 법률행위를 추인할 수 있는 날로부터 3년내에 행사하여야 한다.

해설

- ① 미성년자가 만취상태에서 법률행위를 행한 경우에는 무효와 취소의 경합이라는 해석상의 문제가 발생한다. 즉 제한능력자에게 의사능력이 없다면, 제한능력을 이유로 하는 취소 외에 의사무능력을 입증하여 법률행위의 무효를 주장할 수도 있다는 '이중효설' 이 통설이다. 정답: ①

14 취소권자가 추인을 할 수 있는 후부터 일정한 사실이 있을 때에는 추인한 것으로 되는데, 이에 해당하지 않는 것은?

- ① 상대방이 강제집행을 해왔기 때문에 변제하였다.
- ② 상대방의 채무의 이행을 수령하였다.
- ③ 상대방이 취소할 수 있는 행위에 의하여 취득한 권리를 제3자에게 양도하였다.
- ④ 보증인을 세웠다.
- ⑤ 건물을 인도하는 채무를 1억 원의 채무로 경개하였다.

해설

- ③ 이행의 청구나 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도는 취소권자가 하는 경우에 한한다.
④ 담보의 제공에서 담보는 인적·물적 담보를 포함하며 취소권자가 담보를 제공하든 제공받든 불문한다. 정답: ③

15 미성년자 甲의 행위에 관한 다음 기술 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲이 乙로부터 乙 소유의 토지의 매각을 위임받아 乙의 대리인으로서 丙과 매매계약을 체결했으나 그 후 乙과의 사이에 위임계약을 취소한 경우라도 乙·丙간의 계약은 효력이 상실되지 않는다.
- ② 甲이 자신의 부동산에 관해 매매계약을 체결한 후 성년에 달해 그 대금을 수령하면 甲은 이 계약을 추인한 것으로 보게 된다.
- ③ 甲이 그 소유의 동산을 법정대리인의 동의 없이 선의·무과실인 乙에게 매각하고 인도했는데 甲의 법정대리인이 그 계약을 취소한 경우 乙은 그 동산의 소유권을 취득할 수 없다.
- ④ 甲의 법정대리인이 甲이 매매계약을 체결한 것을 알면서도 4년간 취소권을 행사하지 않는 경우 甲은 고유의 취소권을 행사할 수 없다.

- ⑤ ㉠이 대학생활을 시작하면서 법정대리인의 동의를 얻지 않고 원룸의 전기·수도 공급계약을 체결한 경우 ㉠은 이 계약을 취소할 수 있다.

해설

- ⑤ 사실적 계약관계(전기·수도·전화 등의 계약관계)에서는 의사능력이나 행위능력이 없음을 이유로 무효를 주장하거나 취소할 수 없다.
- ① 수권행위는 기초적 내부관계(고용·위임·도급·조합 등)와는 구별하여야 한다. 따라서 乙과 丙의 계약의 효력은 본인 甲에게 그 효과가 발생한다.
- ② 취소권자가 상대방에 대하여 전부나 일부의 이행을 하거나 상대방으로부터 수령을 한 경우에는 법정추인이 된다(제145조).
- ③ 제한능력자와 거래한 상대방은 선의·무과실 등의 사유와 관계없이 취소권을 행사당할 수 있다.
- ④ 법정대리인이 甲의 매매계약 체결사실을 안 날(추인할 수 있는 날)로부터 3년 내에 취소권을 행사하지 않음으로써 취소권의 단기소멸에 해당되어 취소권은 소멸한다(제146조). 정답: ⑤

16 법률행위의 무효와 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 당사자가 무효임을 알고 추인한 때에는 새로운 법률행위를 한 것으로 본다.
- ② 취소할 수 있는 법률행위의 취소원인이 소멸한 후에 취소권자의 상대방이 이행을 청구한 경우에는 다른 사정이 없는 한, 법률상 당연히 추인이 있었던 것으로 본다.
- ③ 취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 확정된 경우에는, 그 취소는 그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다.
- ④ 제한능력자가 제한능력을 이유로 법률행위를 취소한 경우에는, 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환책임이 있다.
- ⑤ 취소할 수 있는 법률행위가 적법하게 취소되어 무효가 되었더라도 그 무효행위가 추인의 요건을 갖춘 경우에는 이를 다시 추인할 수 있다.

해설

- ② 법정추인사유로서의 '이행의 청구'는 취소권자가 상대방에게 한 경우에 한한다. 정답: ②

17 법률행위의 취소에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 공인중개사]

- ① 제한능력자가 제한능력을 이유로 자신의 법률행위를 취소하기 위해서는 법정대리인의 동의를 받아야 한다.
- ② 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다.
- ③ 취소된 법률행위는 특별한 사정이 없는 한 처음부터 무효인 것으로 본다.
- ④ 제한능력을 이유로 법률행위가 취소된 경우, 제한능력자는 그 법률행위에 의해 받은 급부를 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.
- ⑤ 취소할 수 있는 법률행위에 대해 취소권자가 적법하게 추인하면 그의 취소권은 소멸한다.

해설

- ① 제한능력자의 취소권 행사는 법정대리인의 동의를 요하지 않고 단독으로 할 수 있다. 정답: ①

18 법률행위의 무효와 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 토지거래허가를 배제하거나 잠탈하는 내용의 토지매매계약은 확정적으로 무효이다.
- ② 무효인 법률행위에 의한 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 위법행위가 있더라도 그 법률 효과의 침해에 따른 손해가 인정되지 않는다.
- ③ 무효인 재산상 법률행위를 당사자가 무효임을 알고 추인한 경우 제3자에 대한 관계에서도 처음부터 유효한 법률행위가 된다.
- ④ 무능력을 이유로 법률행위가 취소된 경우 악의의 무능력자도 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 책임이 있다.
- ⑤ 강박에 의한 의사표시가 적법하게 취소된 후에 그 의사표시를 추인하는 경우 그 취소원인이 소멸한 후에 하여야만 추인의 효력이 있다.

해설

- ③ 당사자가 법률행위의 무효임을 알고서 추인한 경우에는 그 때부터 새로운 법률행위를 한 것으로 본다. 따라서 무효행위의 추인은 소급효가 없는 것이 원칙이다(제139조).
- ② 무효인 법률행위는 그 법률행위가 성립한 당초부터 당연히 효력이 발생하지 않는 것이므로, 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 위법행위나 채무불이행이 있다고 하여도 법률효과의 침해에 따른 손해는 없는 것이므로 그 손해배상을 청구할 수는 없다(대법원 2003.3.28. 2002다72125). 정답: ③

19 법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 제한능력자의 법률행위에 대한 법정대리인의 추인은 취소의 원인이 소멸된 후에 하여야 그 효력이 있다.
- ② 취소할 수 있는 법률행위로 취득한 권리를 취소권자의 상대방이 제3자에게 양도한 경우, 법정추인이 되지 않는다.
- ③ 법률행위의 취소를 전제로 한 소송상의 이행청구나 이를 전제로 한 이행거절에는 취소의 의사표시가 포함되어 있다고 볼 수 있다.
- ④ 취소할 수 있는 법률행위는 취소권자가 추인할 수 있는 후에 이익을 보류하지 않고 이행 청구를 하면 추인한 것으로 본다.
- ⑤ 취소권자가 취소할 수 있는 법률행위를 적법하게 추인한 경우, 그 법률행위를 다시 취소할 수 없다.

해설

- ① 제한능력자의 추인은 취소의 원인이 종료한 후에 행사하여야 한다. 다만, 법정대리인은 이러한 제한을 받지 않는다. 정답: ①

20 법률행위의 무효와 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 취소권은 형성권으로서 취소권자가 단독으로 행사할 수 있다.
- ② 법률행위의 무효로 인하여 쌍방이 부당이득반환의무를 부담하는 경우, 쌍방의 의무는 동시 이행관계이다.
- ③ 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 나머지 부분은 원칙적으로 유효하다.
- ④ 법률행위가 취소되어 무효가 되었더라도 무효행위의 추인요건을 갖춘 경우, 이를 추인할 수 있다.
- ⑤ 법률행위가 무효이더라도 선의의 제3자에게 무효를 주장할 수 없는 경우가 있다.

해설

- ③ 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다. 그러나 그 무효부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다(제137조). 즉, 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 원칙적으로 법률행위 전부가 무효이다.
- ⑤ 법률행위가 무효이더라도 선의의 제3자에게 무효를 주장할 수 없는 경우로는 상대적 무효가 이에 해당한다. 정답: ③

21 추인할 수 있는 법률행위가 아닌 것은?(다툼이 있으면 판례에 따름) [2020· 공인중개사]

- ① 통정허위표시에 의한 부동산매매계약
- ② 상대방의 강박으로 체결한 교환계약
- ③ 무권대리인이 본인을 대리하여 상대방과 체결한 임대차계약
- ④ 미성년자가 법정대리인의 동의나 허락 없이 자신의 부동산을 매도하는 계약
- ⑤ 처음부터 허가를 잠탈할 목적으로 체결된 토지거래허가 구역 내의 토지거래계약

해설

- ⑤ 처음부터 허가를 잠탈할 목적으로 체결된 토지거래허가 구역 내의 토지거래계약은 확정적 무효이며 절대적 무효로써 추인할 수 없다. 정답: ⑤

22 취소에 관한 다음 기술 중 타당하지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 취소할 수 있는 법률행위는 취소되면 처음부터 무효인 것으로 간주된다.
- ② 의사표시의 효과가 발생하기 전에 그 발생을 방지하는 것은 설사 취소라고 하여도 철회이다.
- ③ 취소권자의 특정승계인은 취소권을 승계하나, 취소권만을 승계하는 것은 허용되지 않는다.
- ④ 매매계약을 한 후 매도인이 소유권이전등기의 말소등기절차이행을 청구하거나 매수인이 대금반환을 청구하는 것은 그 전에 매매계약을 취소하는 의사표시가 포함된 것으로 해석할 수 있다.
- ⑤ 취소할 수 있는 법률행위를 추인한 후에도 다시 그 법률행위를 취소할 수 있다.

해설

- ⑤ 취소할 수 있는 법률행위를 추인한 후에는 다시 취소할 수 없다. 정답: ⑤

23

A는 B에게 속아서 쓸모없는 토지를 1억 원에 매수하기로 하고 계약금 1000만 원을 지급하고 중도금을 2000만 원, 잔금을 7000만 원 지급하기로 약정하였다. 그 후 A는 B의 사기행위를 알고 난 후에 다음의 행위를 하였다. 법정추인으로 볼 수 없는 경우는?

- ① A는 중도금 2000만 원을 지급하였다.
- ② A는 계약금을 포기하고 매매계약을 해제하였다.
- ③ A는 중도금 2000만 원과 잔금 7000만 원을 전부 지급하였다.
- ④ A는 대금이 부족하여 중도금과 잔금 대신에 시가 1억 원 상당의 아파트의 소유권을 이전하기로 약정하였다.
- ⑤ A는 경영자금이 부족하여 자금조달의 목적으로 위 부동산의 소유권이전청구권을 C에게 양도하였다.

해설

② 법정추인사유로는 전부나 일부의 이행, 이행의 청구, 경개, 담보의 제공, 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도, 강제집행이 있다(제145조). 그러므로 계약금을 포기하고 매매계약을 해제한 것은 법정추인사유에 해당하지 않는다.

- ① 일부의 이행
- ③ 전부의 이행
- ④ 경개
- ⑤ 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 양도 정답: ②

24

취소할 수 있는 법률행위의 추인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 상대방이 취소권자에 대하여 이행의 청구를 한 경우에는 법정추인이 된다.
- ② 추인은 그 행위가 취소할 수 있는 것임을 알고 하여야 한다.
- ③ 취소권자가 취소할 수 있는 법률행위를 적법하게 추인하면 더 이상 취소할 수 없다.
- ④ 법정대리인은 취소원인이 종료하기 전이라도 추인할 수 있다.
- ⑤ 취소권자가 추인할 수 있는 후에 이익을 유보하지 않고 담보를 제공한 경우에는 추인한 것으로 간주된다.

해설

상대방이 취소권자에 대하여 이행의 청구를 한 경우에는 법정추인사유가 아니다(제145조). 취소권자가 상대방에 대하여 이행의 청구를 한 경우에만 법정추인이 된다. 정답: ①

25

무효와 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 의사무능력으로 인한 무효행위의 추인은 그 무효원인이 소멸한 후에 하여야 효력이 있다.
- ② 취소권 행사기간은 제척기간이므로 당사자의 주장에 관계없이 법원이 당연히 조사하여 고려하여야 한다.
- ③ 미성년자는 성년자가 된 후에야 단독으로 추인할 수 있다.
- ④ 하나의 계약이라 할지라도 가분성을 가지거나 그 목적물의 일부가 특정될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하다.
- ⑤ 무효인 법률행위는 추인에 의해 소급하여 유효한 법률행위로 전환된다.

해설

- ⑤ 당사자가 법률행위의 무효임을 알고서 추진한 경우에는 그 때부터 새로운 법률행위를 한 것으로 본다. 따라서 무효행위의 추진은 소급효가 없는 것이 원칙이다(제139조). 정답: ⑤

26

다음 사례에 대한 교수의 질문에 대한 학생의 대답 중 맞는 것은?

계약 당시 18세인 甲이 법정대리인 乙 모르게 자신이 소유하는 카메라를 丙에게 20만 원에 팔기로 하고 즉시 매매대금을 지급받았는데 위 매매계약이 체결된 후 3년이 경과한 현재의 시점에서 乙이 이러한 사정을 발견한 경우, 미성년자 측에서는 위 매매계약을 취소할 수 있습니까?

학생 A : 법정대리인 B의 동의가 없었으므로, B는 현재 위 매매계약을 취소할 수 있습니다.

학생 B : 甲이 취소할 수 있는 날로부터 3년이 경과하였으므로, 甲은 현재 위 매매계약을 취소할 수 없습니다.

학생 C : 甲이 성년이 된 후 3년이 경과하지 않았으므로, 甲은 현재 위 매매계약을 취소할 수 있습니다.

- ① 학생 A ② 학생 B ③ 학생 C
④ 학생 A, 학생 C ⑤ 없음

해설

- ③ 취소권은 추진할 수 있는 날로부터 3년 내에 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다(제146조). 위 사례의 경우 甲은 성인이 된 후에 단독으로 추진할 수 있다. 현재 甲이 성인이 된 후 3년이 경과되지 않았으므로 여전히 취소권을 행사할 수 있다. 따라서 위 사례에 대한 가장 정확한 대답은 학생 C의 대답이다. 정답: ③

법률행위의 무효와 취소에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 무효인 법률행위는 당사자가 무효임을 알고 추인할 경우 새로운 법률행위를 한 것으로 간주할 뿐이고 소급효가 없는 것이므로 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용키로 한 약정은 그때부터 유효하고 이로써 위 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다.
- ② 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다.
- ③ 추인은 취소권을 가지는 자가 취소원인이 종료한 후에 취소할 수 있는 행위임을 알고서 추인의 의사표시를 하거나 법정 추인사유에 해당하는 행위를 행할 때에만 법률행위의 효력을 유효로 확정시키는 효력이 발생한다.
- ④ 취소할 수 있는 법률행위가 일단 취소된 이상 그 후에는 취소할 수 있는 법률행위의 추인에 의하여 이미 취소되어 무효인 것으로 간주된 당초의 의사표시를 다시 확정적으로 유효하게 할 수 없고, 다만 무효인 법률행위의 추인의 요건과 효력으로서 추인할 수 있을 뿐이다.
- ⑤ 법률행위의 취소에 있어 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다고 규정한 민법 제141조 단서는 의사능력의 흠결을 이유로 법률행위가 무효가 되는 경우에게까지 유추 적용될 수 없다.

해설

⑤ 민법 제141조는 “취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다. 다만, 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.”고 규정하고 있는데, 제한능력자의 책임을 제한하는 민법 제141조 단서는 부당이득에 있어 수익자의 반환범위를 정한 민법 제748조의 특칙으로서 제한능력자의 보호를 위해 그 선의·악의를 묻지 않고 반환범위를 현존 이익에 한정시키려는 데 그 취지가 있으므로, 의사능력의 흠결을 이유로 법률행위가 무효가 되는 경우에도 유추 적용되어야 한다.

- ① 무효인 법률행위는 당사자가 무효임을 알고 추인할 경우 새로운 법률행위를 한 것으로 간주할 뿐이고 소급효가 없는 것이므로, 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용키로 한 약정은 그때부터 유효하고 이로써 위 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다.
- ② 제146조.
- ③ 추인은 취소권을 가지는 자가 취소원인이 종료한 후에 취소할 수 있는 행위임을 알고서 추인의 의사표시를 하거나, 법정추인사유에 해당하는 행위를 행할 때에만 법률행위의 효력을 유효로 확정시키는 효력이 발생한다.
- ④ 취소한 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 간주되므로 취소할 수 있는 법률행위가 일단 취소된 이상 그 후에는 취소할 수 있는 법률행위의 추인에 의하여 이미 취소되어 무효인 것으로 간주된 당초의 의사표시를 다시 확정적으로 유효하게 할 수는 없고, 다만 무효인 법률행위의 추인의 요건과 효력으로서 추인할 수는 있다. 정답: ⑤

28 법률행위의 무효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무효인 재산상 법률행위에 대하여 당사자가 무효임을 알고 추인하면 그 추인에는 원칙적으로 소급효가 인정된다.
- ② 위증하기로 하는 계약은 당사자가 무효임을 알고 추인하여도 유효로 될 수 없다.
- ③ 불공정한 법률행위에 대하여도 무효행위의 전환에 관한 민법 규정이 적용될 수 있다.
- ④ 무효행위의 추인은 명시적으로뿐만 아니라 묵시적으로도 할 수 있다.
- ⑤ 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 채무불이행이 있다고 하여도 그 법률효과와 침해에 따른 손해배상을 청구할 수는 없다.

해설

- ① 당사자가 법률행위의 무효임을 알고서 추인한 경우에는 그 때부터 새로운 법률행위를 한 것으로 본다. 따라서 무효행위의 추인은 소급효가 없는 것이 원칙이다(제139조). 정답: ①

29 법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법률행위를 취소한 후라도 무효행위 추인의 요건을 충족할 경우, 무효행위의 추인은 가능하다.
- ② 제한능력이자 맺은 계약은 추인이 있을 때까지 상대방이 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ③ 제한능력을 이유로 법률행위가 취소된 경우, 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.
- ④ 법률행위의 취소를 전제로 한 소송상의 이행청구에는 취소의 의사표시가 포함되어 있다고 볼 수 있다.
- ⑤ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다.

해설

- ② 선의의 상대방은 제한능력자와 체결한 계약에 대하여 제한능력자 측의 추인이 있기 전까지는 그 의사표시를 철회할 수 있다(제16조 제1항). 그러나 상대방에게 취소권은 인정되지 않는다.

정답: ②

- ① 무권대리행위에 대한 본인의 추인은 다른 의사표시가 없는 한 소급효를 가진다.
- ② 법률행위의 일부가 무효일 때, 그 나머지 부분의 유효성을 판단함에 있어 나머지 부분을 유효로 하려는 당사자의 가정적 의사를 고려하여야 한다.
- ③ 토지거래허가구역 내의 토지를 매매한 당사자가 계약체결시부터 허가를 잠탈할 의도였더라도, 그 후 해당 토지에 대한 허가구역 지정이 해제되었다면 위 매매계약은 유효가 된다.
- ④ 무효인 법률행위를 추인에 의하여 새로운 법률행위로 보기 위해서는 당사자가 그 무효를 알고서 추인하여야 한다.
- ⑤ 처분권자는 명문의 규정이 없더라도 처분권 없는 자의 처분행위를 추인하여 이를 유효하게 할 수 있다.

해설

- ③ 처음부터 허가를 배제하거나 잠탈(潛脫)하는 내용의 계약을 체결한 경우에는 확정적 무효이다.

정답: ③

- ① 취소권의 단기제척기간은 취소할 수 있는 날로부터 3년이다.
- ② 취소권의 행사시 반드시 취소원인의 진술이 함께 행해져야 하는 것은 아니다.
- ③ 취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 그 행위로 취득한 특정의 권리를 양도한 경우 양수인이 아닌 원래의 상대방에게 취소의 의사표시를 하여야 한다.
- ④ 노무자의 노무가 일정기간 제공된 후 행해진 고용계약의 취소에는 소급효가 인정되지 않는다.
- ⑤ 매도인이 매매계약을 적법하게 해제한 후에도 매수인은 그 매매계약을 착오를 이유로 취소할 수 있다.

해설

- ① 추인할 수 있는 날로부터 3년 내, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 취소권을 행사하지 아니하면 취소권은 소멸한다(제146조). 정답: ①

32 소급효가 원칙적으로 인정되지 않는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 무권대리인이 체결한 계약에 대한 추인의 효과
- ② 기한부 법률행위에서의 기한도래의 효과
- ③ 토지거래 허가구역 내의 토지거래계약에 대한 허가의 효과
- ④ 소멸시효 완성의 효과
- ⑤ 법률행위 취소의 효과

해설

- ② 기한부 법률행위는 절대적으로 소급효를 인정하지 않는다. 정답: ②

제5장
실전문제

33 법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 취소할 수 있는 미성년자의 법률행위를 친권자가 추인하는 경우, 그 취소의 원인이 소멸한 후에 하여야만 효력이 있다.
- ② 제한능력자가 그 의사표시를 취소한 경우, 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환(償還) 할 책임이 있다.
- ③ 강박에 의하여 의사표시를 한 자의 포괄승계인은 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ④ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다.
- ⑤ 의사표시의 취소는 취소기간 내에 소를 제기하는 방법으로만 행사하여야 하는 것은 아니다.

해설

- ① 추인은 취소의 원인이 종료한 후에 행사하여야 한다. 즉 미성년자가 직접 추인하려면 법정대리인의 동의를 얻거나, 성년자가 된 경우에 할 수 있다. 그러나 법정대리인은 그러하지 아니하다.

정답: ①

1

기본문제

01

조건부 법률행위에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 판례에 의하면 어음보증에 조건을 붙이는 것은 어음거래의 안정성을 해치므로 허용되지 않는다.
- ② 상계, 취소, 철회, 선택채권의 선택 등에 대하여는 조건을 붙일 수 없다.
- ③ 채무의 면제에는 조건을 붙일 수 있다.
- ④ 유증에는 조건을 붙일 수 있다.
- ⑤ 계약당사자 일방이 이행지체에 빠진 상대방에 대하여 일정한 기간을 정하여 채무이행을 최고함과 동시에 그 기간 내에 이행이 없을 시에는 계약을 해제하겠다는 정지조건부 계약 해제의 의사표시는 유효하다.

해설

- ① 어음 및 수표행위에는 원칙적으로 조건을 붙일 수 없다. 그러나 그 거래의 안정성을 해하지 않는 어음보증에 조건을 붙이는 행위는 허용된다(대법원 1986.9.9. 84다카2310). 정답: ①

02

조건과 기한을 대비한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 양자는 모두 법률행위의 부관이다.
- ② 어음행위는 조건에는 친하나, 기한에는 친하지 않다.
- ③ 양자는 모두 장래의 사실과 결부되어 있다.
- ④ 조건의 성취는 불확실하나, 기한의 도래는 확실하다.
- ⑤ 조건부 권리나 기한부 권리는 모두 침해금지의 적용이 있다.

해설

- ㉠ 조건을 붙일 수 없는 법률행위(조건과 친하지 않은 법률행위)

공익상 불허가	㉠ 가족법상 신분행위(혼인, 입양, 인지, 상속의 승인 및 포기) 단, 유증에는 조건을 붙일 수 있음 ㉡ 어음행위, 수표행위(기한과는 친함 단, 어음보증은 가능)
사익상 불허가	㉢ 단독행위에는 원칙적 불가 ㉣ 채무면제, 유증, 정지조건부 계약해제와 같은 단독행위는 예외적으로 허용

- ② 어음행위는 조건은 붙이지 못하나, 기한은 붙일 수 있다. 정답: ②

03 조건에 관한 다음 기술 중 옳은 것은?

- ① 불능조건이 해제조건으로 되어 있는 법률행위는 무효이다.
- ② 기성조건이 정지조건으로 되어 있는 법률행위는 조건 없는 법률행위이다.
- ③ 선량한 풍속 그 밖의 사회질서에 위반한 조건이 붙은 법률행위라고 해서 반드시 무효로 되는 것은 아니다.
- ④ “甲이 乙과 결혼하면, 이 반지를 주겠다.”고 하는 경우는 단순수의조건이다.
- ⑤ 상계에도 조건이나 기한을 붙일 수 있다.

해설

◎ 조건의 종류

불능조건+정지조건 : 무효

불능조건+해제조건 : 유효(=조건 없는 법률행위)

기성조건+정지조건 : 유효(=조건 없는 법률행위)

기성조건+해제조건 : 무효

정지조건	법률행위의 효력의 발생을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존하게 하는 조건 예) 시험에 합격하면, 학비를 주겠다.	
해제조건	법률행위의 효력의 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존하게 하는 조건	
수의조건	순수수의조건	일방의 의사에만 지나치게 의존하는 조건 : 무효 예) 내마음이 내키면, 변제하겠다.
	단순수의조건	일방의 의사에 다른 사실상태의 성립을 요하는 조건 : 유효 예) 내가 제주에 가면, 선물을 사주겠다.
비수의 조건	우 성 조 건	자연의 사실 또는 제3자의 의사나 행위에 의존하는 조건 예) 내일 비가 오면, 우산을 주겠다.
	혼 성 조 건	일방의 의사에다 제3자의 의사까지를 요하는 조건 예) 내가 甲과 혼인하면, 반지를 주겠다.

정답: ②

04 조건에 관한 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 불능조건이 해제조건으로 되어 있는 법률행위는 무효이다.
- ② 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 신의성실에 반하는 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.
- ③ 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 조건이 붙은 법률행위라고 해서 반드시 무효로 되는 것은 아니다.
- ④ 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 본다.
- ⑤ 취소 등의 단독행위에도 조건이나 기한을 붙일 수 있다.

해설

- ② 판례의 태도로서 타당하다.
- ① 무효가 아니라 조건 없는 법률행위로 유효하다.
- ③ 절대적 무효이다.
- ④ 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
- ⑤ 단독행위에는 원칙적으로 조건이나 기한을 붙일 수 없다. 정답: ②

05 다음은 조건과 기한에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 기한은 기한 도래 후의 효력에 대하여 당사자의 특약으로 소급효를 인정할 수 없다.
- ② 불법조건이 붙은 법률행위는 그 법률행위 자체가 무효로 된다.
- ③ 어음, 수표행위에는 시기를 붙일 수는 있다.
- ④ 이미 성취된 조건을 해제조건으로 하는 법률행위는 무효이다.
- ⑤ 조건의 성취가 미정인 상태의 권리는 담보로 제공할 수 없다.

해설

- ⑤ 조건의 성취가 미정인 권리의무도 일반규정에 의하여 처분, 상속, 보존 또는 담보로 할 수 있다 (제149조).
- ① 조건의 경우에는 제3자의 권리를 침해하지 않는 한 당사자의 특약으로 소급효를 인정할 수 있으나, 기한은 그 본질상 소급효가 없고, 당사자의 특약에 의해서도 인정할 수 없다.
- ② 제151조 제1항
- ③ 어음행위에는 조건은 붙이지 못하나, 시기는 허용된다.
- ④ 제151조 제2항 정답: ⑤

06 조건에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 불능조건을 해제조건으로 하면 조건 없는 법률행위로 된다.
- ② 조건부 권리자는 그 권리를 침해한 상대방에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 조건의 성취가 미정인 권리는 상속될 수 없다.
- ④ 법정조건은 민법상 조건으로 보기 어렵다.
- ⑤ 채권자가 채무자의 감정평가사시험 합격을 조건으로 채무를 면제해 주는 것은 금지되지 않는다.

해설

㉠ 조건부 권리보호

소극적 보호	조건부 권리의 의무자는 조건의 성부가 미정인 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다(제148조).
적극적 보호	조건부 권리의무는 일반규정에 따라 이를 처분·상속·보존·담보로 할 수 있다 (제149조).

정답: ③

07 조건부 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법률행위 당시에 정지조건이 이미 성취된 것이면 그 법률행위는 무효이다.
- ② 법률행위의 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것인 때에도 그 법률행위는 유효하다.
- ③ 조건을 붙일 수 없는 법률행위에 조건을 붙인 경우도 그 법률행위는 원칙적으로 전부 무효가 된다.
- ④ 건축허가를 받지 못할 때에는 토지매매계약을 무효로 하기로 한 약정은 정지조건부 법률행위에 해당한다.
- ⑤ 조건이 법률행위의 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우에 그 조건이 해제조건이면 그 법률행위는 무효이다.

해설

- ③ 불법조건이 붙은 법률행위는 조건만이 아니라 그 법률행위 전체가 무효로 된다(제151조 제1항).
- ① 조건이 법률행위의 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위로 하고 해제조건이면 그 법률행위는 무효로 한다(제151조 제2항).
- ④ 법률행위의 효력의 발생을 장래의 불확실한 사실에 의존하게 하는 조건이 정지조건이다. 이미 발생한 법률행위의 효력의 소멸을 장래의 불확실한 사실에 의존하게 하는 조건을 해제조건이라고 한다. 지문의 경우는 매매계약은 유효하게 발생하나 만약 건축허가를 받지 못한 경우에는 매매계약의 효력이 소멸하는 해제조건부 법률행위로 볼 수 있다.
- ⑤ 조건이 법률행위의 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위로 하고 정지조건이면 그 법률행위는 무효로 한다(제151조 제3항). 정답: ③

08 기한과 조건에 대한 다음 설명 중 타당하지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 판례에 의하면 매도인에게 부과될 공과금을 매수인이 책임진다는 취지의 특약을 하였다 하더라도 그 자체가 불법조건이라고 할 수 없고, 이것만 가지고 사회질서에 반한다고 할 수는 없다고 한다.
- ② 조건이 등기되어 있는 경우일지라도 조건성취의 효력을 소급시키려는 당사자의 채권적 약정에 의하여 제3자의 권리를 해할 수는 없다.
- ③ 혼인, 입양, 이혼 등의 가족법상의 행위에는 조건과 기한을 붙일 수 없다.
- ④ 이자부 소비대차처럼 기한의 이익이 채권자에게도 있는 경우에 채무자는 상대방의 손해, 즉 본래의 이행기까지의 이자를 지급하여 기한전에 변제할 수 있다.
- ⑤ 조건부 권리를 침해당한 자는 상대방에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

해설

- ② 해제조건부 증여로 인한 부동산소유권이전등기를 마쳤다 하더라도 그 해제조건이 성취되면 그 소유권은 증여자에게 복귀한다고 할 것이고, 이 경우 당사자 간에 특별한 의사표시가 없는 한 그 조건성취의 효과는 소급하지 아니하나, 조건성취 전에 수증자가 한 처분행위는 조건성취의 효과를 제한하는 한도 내에서는 무효라고 할 것이고, 다만 그 조건이 등기되어 있지 않는 한 그 처분행위로 인하여 권리를 취득한 제3자에게 위 무효를 가지고 대항할 수 없다(대법원 1992.5.22. 92

다5584). 따라서 등기된 경우에는 제3자에게 대항할 수 있다.

- ① 매매계약에서 매도인에게 부과될 공과금을 매수인이 책임진다는 취지의 특약을 하였다 하더라도 이는 공과금이 부과되는 경우 그 부담을 누가 할 것인가에 관한 약정으로서 그 자체가 불법조건이라고 할 수 없고, 이것만 가지고 사회질서에 반한다고 단정하기도 어렵다(대법원 1993.5.25. 93다296).
- ③ 조건부 법률행위는 그 효력의 발생이나 존속이 불안정하기 때문에 그러한 불안정이 타당한 것으로 볼 수 없는 법률행위에 대하여는 조건이나 기한을 붙일 수 없는데 혼인, 입양, 이혼 등의 가족법상의 행위가 이에 해당한다. 정답: ②

09 다음 중 기한의 이익을 가지지 아니하는 자는?

- ① 이자 있는 정기예금의 채권자
- ② 이자 있는 정기예금의 채무자
- ③ 이자 없는 소비대차의 채무자
- ④ 이자 없는 소비대차의 채권자
- ⑤ 무상임치에 있어서의 임치인

해설

◎ 기한의 이익

구 분	채권자	채무자
이자부 정기예금	있 음	있 음
이자부 소비대차	있 음	있 음
무이자소비대차	없 음	있 음
유상임치	있 음	있 음
무상임치	있 음	없 음

정답: ④

01 조건을 붙일 수 있는 법률행위로만 묶여진 것은?

- | | | | |
|----------|----------|-------|-------|
| ㉠ 인 지 | ㉡ 유 증 | ㉢ 입 양 | ㉣ 혼 인 |
| ㉤ 상속의 포기 | ㉥ 채무의 면제 | ㉦ 상 계 | |

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣ ③ ㉡, ㉤
 ④ ㉢, ㉤ ⑤ ㉤, ㉦

해설

㉠ ㉢ ㉤은 가족법상 신분행위로서 조건을 붙일 수 없다. ㉦은 단독행위로서 조건을 붙이는 것은 허용되지 않는다. 다만 상대방만을 유리하게 하는 단독행위인 ㉡과 ㉣은 예외적으로 허용된다. 아울러 단독행위라 하더라도 상대방의 동의가 있는 경우에도 조건을 붙일 수 있다. 정답: ③

02 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① “건축허가 신청이 불허되면 계약은 효력을 상실한다.”는 특약은 해제조건에 관한 약정이다.
 ② 조건이 법률행위 당시에 이미 성취된 것인 때에는 그 조건이 해제조건이면 그 법률행위는 무효로 한다.
 ③ 약혼예물의 수수는 혼인의 불성립을 해제조건으로 하는 증여와 유사한 성질을 갖는다.
 ④ 조건부 법률행위는 조건을 붙이고자 하는 의사와 그 표시가 요구된다.
 ⑤ 부채관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 조건 없는 법률행위가 된다.

해설

⑤ 부채관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 불법조건이므로 불법조건이 붙어 있는 증여계약이라는 법률행위는 조건만이 아니라 증여계약 즉, 법률행위 전부가 무효이다(제151조 제1항). 정답: ⑤

03 법률행위의 조건에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조건의 성취가 미정한 권리라도 일반규정에 의하여 처분하거나 상속할 수 있다.
 ② 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해하였어도 상대방은 그 조건이 성취한 것으로 주장할 수 없다.
 ③ 모든 법률행위에는 조건을 붙일 수 있다.
 ④ 조건이 법률행위 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 정지조건이면 그 법률행위는 무효로 한다.
 ⑤ 조건이 법률행위 당시 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는 그 조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위로 한다.

해설

- ① 조건부 권리·의무는 일반규정에 따라 이를 처분·상속·보존·담보로 할 수 있다(제149조).
- ② 조건의 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취된 것으로 주장할 수 있다(제150조 제1항).
- ③ 가족법상 신분행위, 어음행위, 수표행위(기한과는 친함), 불법행위, 단독행위 등에는 원칙적으로 조건을 붙이지 못한다.
- ④ 조건이 법률행위 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 정지조건이면 그 법률행위는 조건 없는 법률행위(유효)와 같다.
- ⑤ 조건이 법률행위 당시 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는 그 조건이 정지조건이면 무효이다.

정답: ①

04

법률행위의 조건에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ① 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것인 때에는 조건 없는 법률행위로 한다.
- ② 조건의 성취가 미정한 권리의무는 이를 처분할 수 없다.
- ③ 조건을 붙이는 것이 허용되지 아니하는 법률행위에 조건을 붙인 경우 조건 없는 법률행위로 한다.
- ④ 정지조건부 채권양도에 있어서 조건이 성취되었다는 사실은 채권양도의 효력을 주장하는 자에게 그 증명책임이 있다.
- ⑤ 주택건설을 위한 토지매매계약의 당사자가 건축허가 신청이 불허되었을 때에는 이를 무효로 한다는 약정을 한 경우 이는 정지조건부계약이다.

해설

- ④ 타당한 기술이다. 정지조건부 법률행위에 있어서 조건이 성취되었다는 사실은 이에 의하여 권리를 취득하고자 하는 측에서 그 증명책임이 있다(대법원 1993.04.12. 81다카692).
- ① 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것인 때에는 무효이다.
- ② 조건부 권리·의무는 일반규정에 따라 이를 처분·상속·보존·담보로 할 수 있다(제149조).
- ③ 조건을 붙이는 것이 허용되지 아니하는 법률행위에 조건을 붙인 경우에는 무효이다.
- ⑤ 주택건설을 위한 토지매매계약의 당사자가 건축허가 신청이 불허되었을 때에는 이를 무효로 한다는 약정을 한 경우 이는 해제조건부계약이다. 정답: ④

05

법률행위의 조건과 기한에 관한 설명으로 틀린 것은?

[2021' 공인중개사]

- ① 법정조건은 법률행위의 부관으로서의 조건이 아니다.
- ② 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것이면 그 법률행위는 무효이다.
- ③ 조건부 법률행위는 조건이 성취되었을 때에 비로소 그 법률행위가 성립한다.
- ④ 조건부 법률행위에서 불능조건이 정지조건이면 그 법률행위는 무효이다.
- ⑤ 과거의 사실은 법률행위의 부관으로서의 조건으로 되지 못한다.

해설

- ③ 조건부 법률행위는 성립요건이 아니라 효력요건으로서 조건이 성취되었을 때에 비로소 그 효력이 발생 또는 소멸한다. 정답: ③

06 법률행위의 부관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 임대인이 생존하는 동안 임대하기로 하는 계약은 기한부 법률행위이다.
- ② 해제조건부 법률행위에서 그 조건이 이미 성취할 수 없는 것인 경우 그 법률행위는 무효로 한다.
- ③ 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 이러한 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.
- ④ 어느 법률행위에 어떤 조건이 붙어 있었는지 여부는 그 조건의 존재를 주장하는 자가 입증하여야 한다.
- ⑤ 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 조건이 붙은 법률행위는 무효로 한다.

해설

- ② 해제조건부 법률행위에서 그 조건이 이미 성취할 수 없는 것인 경우 그 법률행위는 조건 없는 법률행위(유효)와 같다. 정답: ②

07 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 조건이 불능인 법률행위는 그 조건이 정지조건이면 무효이고, 해제조건이면 조건 없는 법률행위로 된다.
- ② 해제조건이 법률행위 당시 기성조건이면 그 법률행위는 무효이다.
- ③ 조건을 붙일 수 없는 법률행위에 조건을 붙인 경우 그 법률행위는 전부무효임이 원칙이다.
- ④ 불법조건이 붙은 법률행위는 정지조건이면 무효이고, 해제조건이면 조건 없는 행위로서 유효하다.
- ⑤ 소유권유보부 매매의 경우 대금이 모두 지급되면 별도의 의사표시가 없더라도 목적물의 소유권이 매수인에게 이전된다.

해설

- ④ 불법조건이란 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 조건으로서 조건만이 무효가 아니라 법률행위 전부를 무효로 한다. 정답: ④

08 조건에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 공인중개사]

- ① 조건성취의 효력은 특별한 사정이 없는 한 소급하지 않는다.
- ② 해제조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것인 때에는 특별한 사정이 없는 한 조건 없는 법률행위로 된다.
- ③ 정지조건과 이행기로서의 불확정기한은 표시된 사실이 발생하지 않는 것으로 확정된 때에 채무를 이행하여야 하는지 여부로 구별될 수 있다.
- ④ 이행지체의 경우 채권자는 상당한 기간을 정한 최고와 함께 그 기간 내에 이행이 없을 것을 정지조건으로 하여 계약을 해제할 수 있다.
- ⑤ 신의성실에 반하는 방해로 말미암아 조건이 성취된 것으로 의제되는 경우, 성취의 의제시점은 그 방해가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.

해설

- ② 불법조건이란 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 조건으로서 그 조건이 정지조건이든 해제조건이든 당연히 무효이다. 정답: ②

09 다음은 조건과 기한에 대한 설명이다. 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 조건의 성취가 미정인 권리의무는 일반규정에 의해 처분, 상속, 보존 또는 담보로 할 수 없다.
- ② 소급효가 인정되는 행위에는 기한을 붙이는 것이 허용되지 않는다.
- ③ 기한의 이익은 당사자의 특약이나 법률행위의 성질에 비추어 반대의 취지가 없는 한 채무자를 위한 것으로 추정한다.
- ④ 기한의 이익이 상대방을 위하여서도 존재하는 경우에는, 상대방의 손해를 배상하고 포기할 수 있다.
- ⑤ 기한의 이익의 상실사유의 발생으로 기한의 도래가 의제되는 것은 아니고 채권자가 기한이익의 상실청구(즉시변제청구권)를 하여야 기한도래의 효과가 발생한다.

해설

- ① 제149조【조건부권리의 처분 등】
조건의 성취가 미정인 권리의무는 일반규정에 의하여 처분, 상속, 보존 또는 담보로 할 수 있다.
정답: ①

10 조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법률행위에 정지조건이 붙어 있다는 사실의 증명책임은 그 법률효과의 발생을 다투는 자에게 있다.
- ② 조건은 사적 자치에 의한 것으로 당사자가 그 의사에 의하여 임의로 정한 것이어야 한다.
- ③ 조건성취로 불이익을 받을 당사자가 과실로 신의성실에 반하여 조건성취를 방해한 경우에도 상대방은 그 조건의 성취를 주장할 수 있다.
- ④ 기한의 이익은, 당사자의 특약이나 법률행위의 성질에 의하여 분명하지 아니한 경우, 채권자의 이익을 위한 것으로 추정된다.
- ⑤ 당사자가 조건성취의 효력을 그 성취 전에 소급하게 할 의사를 표시한 경우에는 그 의사에 의한다.

해설

- ④ 기한의 이익은, 당사자의 특약이나 법률행위의 성질에 의하여 분명하지 아니한 경우, 채무자의 이익을 위한 것으로 추정된다. 정답: ④

11 조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 기성조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위가 되고, 해제조건이면 그 법률행위는 무효이다.
- ② 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 방해행위 시점이다.
- ③ 기한이익의 상실약정이 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 채권자가 통지나 청구 등을 하여야만 채무자의 기한이익이 상실된다.
- ④ 부첩관계 종료를 해제조건으로 하여 부동산을 증여한 경우, 증여계약은 무효이다.
- ⑤ 조건성취의 효력은 조건이 성취한 때로부터 생기고 소급하지 않는 것이 원칙이다.

해설

- ② 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 이러한 신의성실에 반하는 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다(대법원 1998.12.22. 98다42356). 정답: ②

12 기한부 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 토지임대차계약을 체결함에 있어 임대기간을 '그 토지를 임차인에게 매도할 때까지'로 정한 것은 별다른 사정이 없는 한 기간의 약정이 없는 계약이라 볼 수 있다.
- ② 채무자가 과실로 담보제공의 의무를 이행하지 않았다면, 채권자는 즉시 채무의 이행을 청구할 수 있다.
- ③ 무이자 금전소비대차의 차주는 빌린 금전을 언제든지 반환할 수 있다.
- ④ 상계의 의사표시에는 상대방의 동의 없이도 조건이나 기한을 붙일 수 있다.
- ⑤ 신축 중인 건물의 분양계약에 따른 중도금지급기일을 '1층 골조공사 완료시'로 정한 경우, 그 중도금지급의무는 불확정기한을 이행기로 정한 것이다.

해설

- ④ 단독행위(해제, 해지, 취소, 추인, 상계 등)에 원칙적으로 조건을 붙일 수 없고 조건을 붙이면 법률 행위 전체가 무효가 된다. 이는 단독행위의 상대방이 지나치게 불안정한 지위에 서게 되는 것을 막기 위함이다. 민법은 상계에 관하여 이를 규정하고 있다(제493조 제1항 후단).
- ① 임대차계약을 체결함에 있어서 임대기간은 '본건 토지를 임차인에게 매도할 때까지'로 정하였다면 별다른 사정이 없는 한 그것은 도래할지의 여부가 불확실한 것이므로 기한을 정한 것이라고 볼 수 없으니 위 임대차계약은 기간의 약정이 없는 것이라고 해석함이 상당하다(대법원 1974.5.14. 73다631).
- ② 채무자가 과실로 담보제공의 의무를 이행하지 않았다면 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 아니한 때에 해당하여 기한의 이익의 상실되므로 채권자는 즉시 채무의 이행을 청구할 수 있다(제388조 제2호).
- ③ 무이자 금전소비대차의 경우 차주가 기한의 이익을 가지므로 빌린 금전을 언제든지 반환할 수 있다. 정답: ④

13 甲은 乙이 甲소유의 A건물을 1년 내에 10억 원에 팔아 주면 甲소유의 B건물을 증여한다는 계약을 체결했다. 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 10억 원에 팔 수 있는지의 여부가 결정되기 전에 甲의 과실로 B건물이 소실된 경우, 乙이 1년 내에 A건물을 10억 원에 팔면, 甲은 乙에 대하여 손해배상의 의무를 진다.
- ② 계약할 때 이미 A건물이 소실된 경우 계약은 무효이다.
- ③ 乙은 A건물을 10억 원에 팔 수 있는지의 여부가 결정되기 전에도 B건물에 대하여 자기의 권리를登記할 수 있다.
- ④ 乙이 1년 내에 A건물을 10억 원에 매수할 상대방을 찾았는데도 甲은 타인에게 A건물을 9억 원에 팔았다. 이 경우 乙은 甲에 대하여 B건물의 소유권을 주장할 수 있다.
- ⑤ 乙이 1년 내에 A건물을 10억 원에 판 경우 증여는 그때부터 효력이 생기며, 당사자 사이의 특약에 의해서도 그 효력을 소급해서 발생시킬 수 없다.

해설

- ⑤ 조건부 법률행위의 효력은 원칙적으로 소급효가 없다(제147조 제1항). 단, 당사자의 특약으로 소급효를 부여하는 것은 무방하다(제147조 제3항).
- ① 제148조의 소극적 보호에 해당하는 예문이다. 따라서 乙은 甲에 대하여 손해배상청구권을 행사할 수 있다.
- ② 불능조건이 정지조건이면 무효이다.
- ③ 장래 확정될 청구권이나 정지조건부 권리·시기부 권리는 가등기를 할 수 있으며 가등기를 한 경우에는 후에 성립하는 물건에 대항할 수 있다.
- ④ 제150조 제1항의 조건성취의 의제규정이 적용된다. 정답: ⑤

14 다음 중 기한의 이익 상실사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 채무자가 담보를 손상하거나 감소하게 한 때
- ② 채무자가 담보를 멸실하게 한 때
- ③ 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 아니한 때
- ④ 채무자의 파산선고
- ⑤ 채권자의 파산선고

해설

기한의 이익의 상실사유에는 ㉠ 채무자가 담보를 손상하거나 감소 또는 멸실하게 한 때(제388조 제1호), ㉡ 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 아니한 때(제388조 제2호), ㉢ 채무자의 파산선고(채무자회생 및 파산에 관한 법률 제425호) 등이 있다. 그러나 채권자와 관련된 것은 기한의 이익 상실사유가 아니다. 정답: ⑤

15 기한에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 기한에는 소급효가 없으나 당사자 간의 특약으로 소급효를 인정할 수 있다.
- ② 이자부 소비대차의 경우에는 채권자만이 기한의 이익을 가진다.
- ③ 당사자 간의 약정으로 기한의 이익이 채권자를 위한 것이며 채권자만이 포기할 수 있다는 약정은 무효이다.
- ④ 수표행위에 시기를 붙이는 것은 허용되지 않는다.
- ⑤ 기한의 이익을 포기하면 그때에 기한이 도래한 것이 된다.

해설

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 당사자 간의 특약으로도 기한의 소급효를 인정할 수 없다.
- ② 이자부 소비대차는 채권자·채무자 모두에게 기한의 이익이 있다.
- ③ 기한의 이익에 대한 규정은 임의규정이다.
- ④ 어음·수표행위에 시기를 붙이는 것은 허용된다. 정답: ⑤

16 조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① “내가 프랑스에 가면 고급 포도주를 사 주겠다.”고 한 경우 이 법률행위는 유효하다
- ② “나의 처를 대신해서 아이를 낳아주면 1억 원을 주겠다.”고 한 경우 이 법률행위는 조건만을 무효로 하는 것이 아니라 법률행위 전부를 무효로 한다.
- ③ 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
- ④ 이미 대학에 합격한 동생에게 “대학시험에 합격하면 차를 한 대 사주겠다.”고 한 경우 이 법률행위는 무효이다.
- ⑤ 기한이익상실의 특약은 명백히 정지조건부 기한이익 상실의 특약이라고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 형성권적 기한이익상실의 특약으로 추정된다.

해설

- ④ 정지조건부 법률행위에 기성조건이 붙어 있는 경우 유효하다.
- ① 단순수익조건부 법률행위로서 유효하다.
- ② 불법조건부 법률행위로 무효이다.
- ③ 제153조 제1항
- ⑤ 대법원 2010.8.26. 2008다42416,42423 정답: ④

17 기한의 이익에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 기한의 이익이 채권자 및 채무자 쌍방에게 있는 경우, 채무자는 기한의 이익을 포기할 수 없다.
- ② 채무자인 甲이 저당권자 乙 이외의 다른 채권자 丙에게 동일한 부동산 위에 후순위저당권을 설정해 준 경우 원칙적으로 甲은 乙에게 기한의 이익을 주장하지 못한다.
- ③ 기한이익 상실의 특약은 특별한 사정이 없는 한 형성권적 기한이익 상실의 특약으로 추정된다.
- ④ 형성권적 기한이익 상실의 특약이 있는 할부채무의 경우, 특별한 사정이 없는 한 1회의 불이행이 있으면 채무전액에 대하여 소멸시효가 진행된다.
- ⑤ 정지조건부 기한이익 상실의 특약이 있는 경우, 그 특약에 정한 기한이익 상실사유가 발생 하더라도 기한이익을 상실케 하는 채권자의 의사표시가 없다면 특별한 사정이 없는 한 이행기 도래의 효과가 발생하지 않는다.

해설

- ③ 기한이익 상실의 특약은 그 내용에 의하여 일정한 사유가 발생하면 채권자의 청구 등을 요함이 없이 당연히 기한의 이익이 상실되어 이행기가 도래하는 것으로 하는 정지조건부 기한이익 상실의 특약과 일정한 사유가 발생한 후 채권자의 통지나 청구 등 채권자의 행위를 기다려 비로소 이행기가 도래하는 것으로 하는 형성권적 기한이익 상실의 특약의 두 가지로 대별할 수 있고, 기한이익 상실의 특약이 위의 양자 중 어느 것에 해당하느냐는 당사자의 의사해석의 문제이지만 일반적으로 기한이익 상실의 특약이 채권자를 위하여 둔 것인 점에 비추어 명백히 정지조건부 기한이익 상실의 특약이라고 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 형성권적 기한이익 상실의 특약으로 추정된다(대법원 2010.8.26. 2008다42416,42423). 정답: ③

18 법률행위의 조건과 기한에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 공인중개사]

- ① 조건부 법률행위에서 불능조건이 정지조건이면 그 법률행위는 무효이다.
- ② 조건부 법률행위에서 기성조건이 해제조건이면 그 법률행위는 무효이다.
- ③ 법률행위에 조건이 붙어 있다는 사실은 그 조건의 존재를 주장하는 자가 증명해야 한다.
- ④ 기한이익 상실특약은 특별한 사정이 없으면 정지조건부 기한이익 상실특약으로 추정된다.
- ⑤ 종기(終期) 있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력을 잃는다.

해설

- ④ 기한이익 상실의 특약은 그 내용에 의하여 일정한 사유가 발생하면 채권자의 청구 등을 요함이 없이 당연히 기한의 이익이 상실되어 이행기가 도래하는 것으로 하는 정지조건부 기한이익 상실의 특약과 일정한 사유가 발생한 후 채권자의 통지나 청구 등 채권자의 행위를 기다려 비로소 이행기가 도래하는 것으로 하는 형성권적 기한이익 상실의 특약의 두 가지로 대별할 수 있고, 기한이익 상실의 특약이 위의 양자 중 어느 것에 해당하느냐는 당사자의 의사해석의 문제이지만 일반적으로 기한이익 상실의 특약이 채권자를 위하여 둔 것인 점에 비추어 명백히 정지조건부 기한이익 상실의 특약이라고 볼 만한 특별한 사정이 없는 이상 형성권적 기한이익 상실의 특약으로 추정된다(대법원 2010.8.26. 2008다42416,42423). 정답: ④

19 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 조건은 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존하게 하는 법률행위의 부관이다.
- ② 불능조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위가 된다.
- ③ 조건의사가 있더라도 법률행위의 내용으로 외부에 표시되지 않은 경우, 그것만으로는 법률행위의 조건이 되지 않는다.
- ④ 부관이 붙은 법률행위에 있어서 부관에 표시된 사실의 발생 유무에 상관없이 그 채무를 이행해야 하는 경우에는 조건으로 보아야 한다.
- ⑤ 정지조건부 법률행위의 경우에는 조건성취로 권리를 취득하는 자가 조건성취 사실에 대한 증명책임을 진다.

해설

- ④ 조건은 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존케 하는 부관이다. 따라서 부관에 표시된 사실의 발생 유무에 상관없이 그 채무를 이행해야 하는 경우에는 조건으로 볼 수 없다.
- ⑤ 정지조건부 법률행위에 있어서 조건이 성취되었다는 사실은 이에 의하여 권리를 취득하고자 하는 측에서 그 증명책임을 있다(대법원 1993.04.12. 81다카692). 정답: ④

20 법률행위의 부관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 조건을 붙이고자 하는 의사가 있더라도 그것이 표시되지 않으면 법률행위의 부관으로서의 조건이 되는 것은 아니다.
- ② 어떤 조건이 붙어 있었는지 아닌지는 그 조건의 존재를 주장하는 자가 이를 증명하여야 한다.
- ③ 당사자는 조건의 성부가 미정인 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다.
- ④ 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우, 그 법률행위 전부가 무효로 된다.
- ⑤ 부관에 표시된 사실이 발생하지 아니하는 것이 확정된 때에도 그 채무를 이행하여야 한다고 보는 것이 상당한 경우, 조건부 법률행위로 보아야 한다.

해설

- ⑤ 법률행위에 부관이 붙은 경우, 부관에 표시된 사실이 발생하지 아니하면 채무를 이행하지 아니하여도 된다고 보아야 하는 때에는 정지조건으로 정한 것으로 보아야 하고, 표시된 사실이 발생하면 물론이고 반대로 발생하지 아니하는 것이 확정된 때에도 그 채무를 이행하여야 한다고 보는 것이 타당한 경우에는 표시된 사실의 발생 여부가 확정되는 것을 불확정기한으로 정한 것으로 보아야 한다(대법원 2011.4.28. 2010다89036). 정답: ⑤

21

조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 갑정평가사]

- ① 법률행위의 조건은 그 조건의 존재를 주장하는 사람이 증명하여야 한다.
- ② 정지조건부 법률행위에서 조건이 성취된 사실은 조건의 성취로 권리를 취득하는 사람이 증명하여야 한다.
- ③ 불능조건이 정지조건인 경우 그 법률행위는 무효이다.
- ④ 조건의 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 처음부터 조건 없는 법률행위로 본다.
- ⑤ 기한이익 상실의 약정은 특별한 사정이 없으면 형성권적 기한이익 상실의 약정으로 추정한다.

해설

- ④ 조건의 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취된 것으로 주장할 수 있다(제150조 제1항). 정답: ④

22

법률행위의 조건에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 조건의 성취가 미정인 권리는 일반규정에 의하여 처분, 상속할 수 있으나 담보로 제공할 수는 없다.
- ② 조건이 법률행위의 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위로 한다.
- ③ 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에도 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 없다.
- ④ 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우 그 조건만을 분리하여 무효로 할 수 있다.
- ⑤ 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 신의성실에 반하는 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.

해설

- ⑤ 대법원 1998.12.22. 98다42356
- ① 조건의 성취가 미정인 권리도 일반규정에 의하여 처분, 상속, 보존, 담보로 할 수 있다.
 - ② 조건이 법률행위의 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 무효이다.
 - ③ 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 있다.
 - ④ 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우 그 조건만을 분리하여 무효로 할 수 없다. 정답: ⑤

23

법률행위의 조건과 기한에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 법정조건도 법률행위의 부관으로서 조건에 해당한다.
- ② 채무면제와 같은 단독행위에는 조건을 붙일 수 없다.
- ③ 기한은 특별한 사정이 없는 한 채권자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
- ④ 조건에 친하지 않은 법률행위에 불법조건을 붙이면 조건 없는 법률행위로 전환된다.
- ⑤ 불확정한 사실의 발생을 기한으로 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 사실의 발생이 불가능한 것으로 확정된 때에도 기한이 도래한 것으로 본다.

해설

⑤ 대법원 2018.4.24. 2017다205127

- ① 법률의 규정에 의해 부가된 조건을 말하며 조건으로서의 의미가 없다.
- ② 단독행위는 조건을 붙일 수 없으나 채무면제나 유증은 상대방만을 유리하게 하는 것으로 허용되며 상대방의 동의가 있는 경우에는 조건을 붙이는 것이 허용된다.
- ③ 기한은 특별한 사정이 없는 한 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다(제153조 제1항).
- ④ 불법조건은 무효이다. 정답: ⑤

제5장
실전문제

24

법률행위의 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2022' 감정평가사]

- ① 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 있다.
- ② 법률행위 당시 이미 성취된 조건을 해제조건으로 하는 법률행위는 조건 없는 법률행위이다.
- ③ 정지조건이 있는 법률행위는 특별한 사정이 없는 한 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 생긴다.
- ④ 조건 있는 법률행위의 당사자는 조건의 성부가 미정한 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다.
- ⑤ 조건의 성취가 미정인 권리도 일반규정에 의하여 담보로 할 수 있다.

해설

- ② 기성조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위(유효)가 되고, 기성조건이 해제조건이면 무효이다(제151조 제2항). 정답: ②

- ① 물건행위에는 조건을 붙일 수 없다.
- ② 조건이 되기 위해서는 법률이 요구하는 것이 아니라 당사자가 임의로 부가한 것이어야 한다.
- ③ 조건의 성취를 의제하는 효과를 발생시키는 조건성취 방해행위에는 과실에 의한 행위도 포함된다.
- ④ 부첩(夫妾) 관계의 종료를 해제조건으로 하는 부동산 증여계약은 해제조건뿐만 아니라 증여계약도 무효이다.
- ⑤ 당사자의 특별한 의사표시가 없는 한 정지조건이든 해제조건이든 그 성취의 효력은 소급하지 않는다.

해설

- ① 채권행위나 물건행위는 모두 법률행위이며 원칙적으로 조건을 붙일 수 있다. 정답: ①

기간과 소멸시효

1

기본문제

01

사단법인 총회소집을 1주일 전에 회원에게 통지하여야 하는 경우에 총회를 2023년 12월 15일 오후 2시에 개최하고자 한다면, 소집권자는 총회소집을 늦어도 2023년 언제까지 통지해야 하는가?

- ① 12월 6일 24시까지 통지도달 ② 12월 7일 24시까지 통지발송
- ③ 12월 7일 24시까지 통지도달 ④ 12월 8일 24시까지 통지발송
- ⑤ 12월 8일 24시까지 통지도달

해설

② 총회의 소집은 1주간 전에 그 회의의 목적사항을 기재한 통지를 발하고 기타 정관에 정한 방법에 의하여야 한다(제71조). 따라서 12월 15일에 개최를 하고자 하는 경우에는 초일을 산입하지 않고 14일부터 기산하여 1주간 전인 12월 7일 24시까지는 통지를 발송하여야 한다. 정답: ②

02

기간에 관한 다음 설명 중 옳지 아니한 것은?

- ① 연령계산에 있어서는 출생일을 산입한다.
- ② 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.
- ③ 기간에 관한 민법의 규정은 공법관계에도 적용된다.
- ④ 시·분·초를 단위로 하는 기간의 계산은 자연적 계산방법에 의한다.
- ⑤ 민법은 단기간에 관하여는 역법적 계산방법을 채용하고 있다.

해설

◎ 기간의 계산방법

㉠ 자연적 계산방법

- ㉠ 시·분·초의 단기계산에 적용한다.
- ㉡ 정확하나 번잡하다.
- ㉢ 기산점 : 즉시로부터 기산한다.
- ㉣ 만료점 : 정하여진 시·분·초가 종료한 때이다.

㉡ 역법적 계산방법

- ㉠ 일·주·월·년의 장기계산에 적용한다.
- ㉡ 간편하나 부정확하다.
- ㉢ 기산점 : 초일불산입의 원칙을 적용한다.
- ㉣ 만료점 : 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간은 만료한다.

정답: ⑤

03

민법의 기간규정에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 기간의 계산에 대해서는 법률행위로 달리 정할 수 없다.
- ② 연령계산에는 출생일을 산입한다.
- ③ 기간은 법률사실로서 사건에 속한다.
- ④ 정년이 60세라 함은 만 60세에 달하는 날을 의미하지 만 60세가 만료하는 날을 의미하지 않는다.
- ⑤ 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 다음 날로 만료하지만, 기간의 초일이 공휴일인 경우에는 그 적용이 없다.

해설

- ① 기간의 계산에 대한 민법의 규정은 임의규정이다. 따라서 특약이나 관습, 영업시간의 규칙 또는 다른 법률에 규정이 있으면 그에 의한다. 정답: ①

04

기간의 계산에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 정년이 60세라 함은 만 60세가 되는 날을 의미하는 것이지 60세가 만료되는 날을 의미하는 것이 아니다.
- ② 사단법인의 사원총회를 1주일 전에 통지한다고 할 때에 총회일이 10월 19일이라면 늦어도 10월 11일 자정까지는 사원에게 총회소집통지가 발신되어야 한다.
- ③ 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.
- ④ 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 경우 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에도 초일은 산입하지 않는다.
- ⑤ 기간을 시, 분, 초로 정한 때에는 즉시로부터 기산한다.

해설

- ④ 기간을 일·주·월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 않는다. 그러나 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다(제157조). 정답: ④

05

소멸시효기간에 관한 다음 기술 중 타당하지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 단기의 소멸시효에 걸리는 것이라도 확정판결을 받은 권리의 소멸시효는 10년으로 된다.
- ② 주채무에 관한 판결이 확정되어 10년으로 된 경우에도 보증채무의 시효기간은 여전히 종전의 소멸시효기간에 따른다.
- ③ 지상권은 20년간 행사하지 않음으로써 소멸시효에 걸린다.
- ④ 일반 민사채권의 소멸시효기간은 10년이다
- ⑤ 채무불이행으로 인한 손해배상청구권은 계약시부터 소멸시효가 진행된다.

해설

- ⑤ 채무불이행으로 인한 손해배상청구권은 채무불이행 시부터 소멸시효가 진행된다. 정답: ⑤

06

소멸시효의 대상이 될 수 있는 권리는?

- ① 할부금채권 ② 유치권 ③ 상린권
- ④ 저당권 ⑤ 인격권

해설

- ① 할부채권의 경우에는 1회의 불이행이 있더라도 각 할부금에 대해 그 각 변제기의 도래시마다 그 때부터 순차로 소멸시효가 진행하고, 채권자가 특히 잔존 채무전액의 변제를 구하는 취지의 의사를 표시한 경우에 한하여 잔액에 대하여 그 때부터 소멸시효가 진행된다(대법원 1997.8.29, 97다12990).
- ②④ 유치권·질권·저당권과 같은 담보물권은 피담보채권의 소멸로 부종성에 기하여 소멸할 뿐, 피담보채권이 존속하는 한 담보물권만이 피담보채권에 독립하여 소멸시효의 대상이 되지 않는다.
- ③ 상린관계상의 권리 및 공유물분할청구권(제268조)은 기초가 되는 법률관계가 존재하는 한 독립하여 소멸시효의 대상이 되지 않는다(대법원 1981.3.24, 80다1888).
- ⑤ 인격권, 가족권 등 비재산권은 소멸시효의 대상이 아니다. 정답: ①

제6장
기본문제

07

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ① 부동산의 매수인이 목적 부동산을 인도받아 계속 점유하는 경우, 그 매매로 인한 매수인의 소유권이전등기청구권의 소멸시효는 진행하지 않는다.
- ② 신축 중인 건물에 관한 소유권이전등기청구권의 소멸시효는 그 건물이 완공되지 아니한 동안에는 진행하지 않는다.
- ③ 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다.
- ④ 단기의 소멸시효에 해당하는 주채무의 소멸시효기간이 확정판결에 의하여 10년으로 연장되면 보증채무의 소멸시효기간도 10년으로 연장된다.
- ⑤ 소멸시효의 중단을 위한 승인은 묵시적인 방법으로도 할 수 있다.

해설

- ④ 주채무에 관한 판결이 확정되어 10년으로 된 경우에도 보증채무의 시효기간은 여전히 종전의 소멸시효기간에 따른다. 정답: ④

08

소멸시효에 관한 설명이다. 다음 기술 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다.
- ② 시효의 이익은 미리 포기하지는 못한다.
- ③ 소멸시효기간은 당사자의 합의로 이를 단축 또는 경감할 수 없다.
- ④ 주채무자가 시효이익을 포기하더라도 보증인에게 영향을 미치지 않는다.
- ⑤ 주된 권리의 소멸시효가 완성한 때에는 종속된 권리에 그 효력이 미친다.

해설

- ③ 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제, 연장 또는 가중할 수 없으나 이를 단축 또는 경감할 수 있다(제184조 제2항).
- ① 제166조
- ② 제184조 제1항
- ④ 소멸시효이익의 포기는 상대적이며 다른 사람에게는 영향을 미치지 않는다. 따라서 주채무자의 시효이익의 포기는 보증인에 대해서는 그 영향을 미치지 않는다.
- ⑤ 제183조 정답: ③

09

소멸시효에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압류 등의 집행행위를 시효의 이익을 받을 자에 대하여 하지 않은 때에는 이를 그 자에게 통지한 후가 아니면 소멸시효의 중단의 효력이 없다.
- ② 판례는 채권의 소멸시효가 완성된 후에 채무자가 그 기한의 유예를 요청하였다면 소멸시효의 이익을 포기한 것으로 본다.
- ③ 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당한 것이더라도 그 소멸시효는 10년으로 연장된다.
- ④ 판례에 의하면 최고를 거듭하다가 재판상 청구를 한 경우 최초의 최고시에 시효의 중단의 효력이 발생한다.
- ⑤ 판례에 따르면 행정소송도 시효중단사유가 될 수 있는 경우가 있다.

해설

- ④ 최고를 여러 번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 있어서의 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생하는 것이 아니라 재판상 청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고시에 발생한다(대법원 1987.12.22. 87다카437).
- ① 제176조, 이는 제169조의 예외가 되며, 채권자와 채무자 간의 이익을 조화시키기 위함이다.
- ② 대법원 1965.12.28. 65다2133
- ③ 제165조 제1항
- ⑤ 오납한 조세에 대한 부당이득반환청구권을 실현하기 위한 수단이 되는 과세처분의 취소 또는 무효 확인을 구하는 소송은 비록 행정소송일지라도 그것은 부당이득반환청구권에 관한 재판상 청구에 해당한다(전합 1992.3.31. 91다32053). 정답: ④

10 다음 권리 중 원칙적으로 시효로 인하여 소멸되는 것은?

- ① 공유물분할청구권
- ② 부양료청구권
- ③ 취소권
- ④ 상속회복청구권
- ⑤ 소유권 이전등기청구권

해설

◎ 소멸시효에 걸리지 않는 권리

소 유 권	소유권은 존속기간의 제한이 없는 항구성을 가진다.
물권적 청구권	㉠ 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다는 데에 이설이 없다. ㉡ 제한물권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸린다는 견해(판례)와 소멸시효에 걸리지 않는다는 견해의 대립(다수설)이 있다.
신 분 권	신분권은 진실관계를 보다 존중하므로 소멸시효에 걸리지 않는다.
점 유 권	점유권은 일정한 사실상태가 있으면 언제나 존재하고, 그 사실상태가 소멸하면 당연히 소멸하는 권리이므로 소멸시효의 문제가 생길 여지가 없다.
등기청구권	채권적 청구권은 당연히 소멸시효에 걸리나, 채권적 청구권 중에서 특히 등기 청구권에 대하여 판례는 “만일에 매수인이 목적물을 인도받고 있으면, 그 등기 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다”(대법원 76다148 전합)고 판시하고 있다.
담 보 물 권	담보물권(저당권·질권·유치권)은 피담보채권이 존속하는 한 독립하여 소멸시효에 걸리지 않는다.
일정한 법률관계에 의존하는 권리	상린권, 공유물분할청구권 등은 그 기초가 되는 권리관계가 존속하는 동안은 독립하여 소멸시효에 걸리지 않는다.

정답: ⑤

제6장
기본문제

11 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 소멸시효에 관한 규정은 강행규정이지만, 법률행위에 의하여 경감할 수 있다.
- ② 공유물분할청구권은 공유관계가 존속하는 한 별도로 소멸시효가 진행되지 않는다.
- ③ 부당이득반환청구권의 소멸시효는 청구권이 성립한 때로부터 진행하고, 원칙적으로 권리의 존재나 발생을 알지 못하였다고 하더라도 소멸시효의 진행에 장애가 되지 않는다.
- ④ 부동산매수인이 소유권이전등기 없이 부동산을 인도받아 사용·수익하다가 제3자에게 그 부동산을 처분하고 점유를 승계하여 준 경우, 소유권이전등기청구권의 소멸시효가 진행되지 않는다.
- ⑤ 원인채권의 지급을 확보하기 위하여 어음이 수수된 당사자 사이에 채권자가 어음채권에 관한 집행권원에 기하여 한 배당요구는 그 원인채권의 소멸시효를 중단시키는 효력이 없다.

- ⑤ 원인채권의 지급을 확보하기 위한 방법으로 어음이 수수된 경우에 원인채권과 어음채권은 별개로서 채권자는 그 선택에 따라 권리를 행사할 수 있고, 원인채권에 기하여 청구를 한 것만으로는 어음채권 그 자체를 행사한 것으로 볼 수 없어 어음채권의 소멸시효를 중단시키지 못한다. 그러나 반대로 어음채권의 행사는 원인채권의 소멸시효를 중단시키는 효력이 있다(대법원 1999.6.11. 99다16378). 정답: ⑤

12 소멸시효의 기산점에 대한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 기한을 정하지 아니한 권리는 권리가 발생한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ② 정지조건부 권리는 조건이 성취되지 않은 것으로 확정된 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ③ 부작위를 목적으로 하는 채권은 위반행위를 하였음을 채권자가 안 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ④ 병원에 장기간 입원하여 치료받은 환자의 치료비채권은 환자가 퇴원한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ⑤ 공동불법행위자 중 1인의 다른 공동불법행위자에 대한 구상금채권은 불법행위시부터 소멸시효가 진행된다.

해설

- ① 기한의 정함이 없는 권리는 원칙적으로 그 권리가 성립한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ② 정지조건부 권리는 조건이 성취된 때로부터 소멸시효가 진행된다(제147조 제1항 참조).
- ③ 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행된다(제166조 제1항).
- ④ 치료비채권은 각 치료행위마다 별개로 진행된다.
- ⑤ 구상권자가 면책행위를 한 때부터 기산한다(대법원 1996.3.26., 96다3791). 정답: ①

13 소멸시효기간에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 1개월 단위로 지급되는 집합건물의 관리비채권은 10년의 소멸시효에 걸린다.
- ㉡ 상인이 판매한 상품의 대금채권은 3년의 소멸시효에 걸린다.
- ㉢ 상인이 아닌 물상보증인이 상인인 채무자에게 구상권을 행사하는 경우 그 구상권은 5년의 소멸시효에 걸린다.
- ㉣ 도급으로 인한 공사대금채권은 3년의 소멸시효에 걸린다.

- ① ㊲, ㊳ ② ㊲, ㊴ ③ ㊳, ㊴
- ④ ㊳, ㊵ ⑤ ㊴, ㊵

- ㉠ 1개월 단위로 지급되는 집합건물의 관리비채권은 1년 이내의 기간으로 정한 채권이므로 3년의 소멸시효에 걸린다.
- ㉡ 상인이 아닌 물상보증인이 상인인 채무자에게 구상권을 행사하는 경우 그 구상권은 일반 민사채권으로서 10년의 소멸시효에 걸린다.

◎ 소멸시효기간

기 간	권 리
20년	용익물권
10년	- 보통의 민사채권 - 판결 등으로 확정된 단기소멸시효에 해당되는 권리
5년	- 상행위로 인한 채권 - 공법상의 채권
3년	- 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권 - 의사, 조산사, 간호사 및 약사의 치료, 근로 및 조제에 관한 채권 - 도급받은 자, 기사 기타 공사의 설계 또는 감독에 종사하는 자의 공사에 관한 채권 - 변호사, 변리사, 공증인, 공인회계사 및 법무사에 대한 직무상 보관한 서류의 반환을 청구하는 채권 - 변호사, 변리사, 공증인, 공인회계사 및 법무사의 직무에 관한 채권 - 생산자 및 상인이 판매한 생산물 및 상품의 대가 - 수공업자 및 제조업자의 업무에 관한 채권
1년	- 여관, 음식점, 대석, 오락장의 숙박료, 음식료, 대석료, 입장료, 소비물의 대가 및 체당금의 채권 - 의복, 침구, 장구 기타 동산의 사용료의 채권 - 노역인·연예인의 임금 및 그에 공급한 물건의 대금채권 - 학생 및 수업자의 교육, 의식, 유숙에 관한 교생, 숙주, 교사의 채권

정답: ②

14 소멸시효기간에 관한 다음 기술 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 확정판결을 받은 권리의 소멸시효를 10년으로 한다는 민법 제165조의 규정은 단기의 소멸시효에 걸리는 것이라도 확정판결을 받은 권리의 소멸시효는 10년으로 한다는 뜻일 뿐, 10년보다 장기의 소멸시효를 10년으로 한다는 의미도 아니고 본래 소멸시효의 대상이 아닌 권리가 확정판결을 받음으로써 10년의 소멸시효에 걸린다는 뜻도 아니다.
- ② 주채무에 관한 판결이 확정되어 10년으로 된 경우에도 보증채무의 시효기간은 여전히 종전의 소멸시효기간에 따른다.
- ③ 지상권은 20년간 행사하지 않음으로써 소멸시효에 걸린다.
- ④ 일반민사채권의 소멸시효기간은 10년이다
- ⑤ 민법 제163조 제1항에서 '1년 이내의 기간으로 정한 채권'이라 함은 1년 이내의 정기로 지급되는 채권이라는 뜻이 아니라, 변제기가 1년 이내의 채권이라는 뜻이다.

해설

- ⑤ 변제기가 1년 이내의 채권이라는 뜻이 아니라, 1년 이내의 정기로 지급되는 채권(정기금부채권)이라는 뜻이다.
- ① 대법원 1981.3.24, 80다1888 · 1889
- ② 대법원 1986.11.25, 86다카1569
- ③ 제162조 제2항
- ④ 제162조 제1항 정답: ⑤

15 시효중단사유로서의 '재판상 청구'에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 시효완성을 주장하는 자가 원고가 되어 소를 제기한 데 대하여 권리자가 '응소'를 한 경우도 재판상 청구에 해당함이 원칙이다.
- ② 형사소송은 시효중단사유로서의 재판상 청구에 해당하지 않는다.
- ③ 행정소송이나 행정심판의 경우에도 소멸시효의 중단사유가 될 수 있다.
- ④ 재판상 청구에 의한 시효중단의 효과는 소를 제기한 때에 발생한다.
- ⑤ 재판상 청구로 인하여 중단된 시효는 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행된다.

해설

- ③ 재판상 청구는 민사소송이어야 하고 행정소송이나 행정심판 그리고 형사재판의 경우에는 중단사유가 되지 않는다는 것이 통설과 판례의 태도이다. 정답: ③

16甲은 乙에 대하여 채권을 가지고 있다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲이 소멸시효 기간 만료 전 최고를 한 후 6개월 이내에 소를 제기한 경우 그 소제기시에 시효중단의 효력이 생긴다.
- ② 甲의 乙에 대한 시효중단의 효력은 乙의 보증인에게는 미치지 않는다.
- ③ 乙이 명시적으로 채무를 승인한 경우뿐만 아니라 묵시적으로 승인한 경우도 소멸시효는 중단될 수 있다.
- ④ 甲이 乙을 사기죄로 고소하여 형사재판이 개시된 경우 특별한 사정이 없는 한 소멸시효의 중단사유인 재판상의 청구로 볼 수 있다.
- ⑤ 甲이 이미 사망한 乙을 피신청인으로 하여 가압류신청을 한 경우 법원의 가압류결정이 내려지면 소멸시효가 중단된다.

해설

- ③ 타당한 기술이다.
- ① 재판상 청구를 한 시점을 기준으로 소급하여 6월 이내에 한 최고시에 중단의 효력이 발생한다.
- ② 주채무자에 대한 시효중단은 보증인에 대하여 그 효력이 있다(제440조).
- ④ 재판상 청구는 민사재판이어야 하며 과세처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 행정소송을 제외한 형사재판은 시효중단 사유인 재판상 청구가 될 수 없다(대법원 1992.3.31, 91다32053).

- ⑤ 압류, 가압류 및 가처분은 시효의 이익을 받은 자에 대하여 하지 아니한 때에는 이를 그에게 통지한 후가 아니면 시효중단의 효력이 없다(제176조). 즉, 甲이 이미 사망한 乙을 피신청인으로 하여 가압류신청을 한 경우 乙은 이미 사망하여 시효의 이익을 받을 수 없으므로 법원의 가압류 결정이 있더라도 소멸시효가 중단되지 않는다. 정답: ③

17 시효정지의 사유에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 천재 그 밖의 사변으로 말미암아 소멸시효를 중단할 수 없는 때에는 그 사유가 종료한 때로부터 6월 안에는 시효가 완성하지 않는다.
- ② 상속재산에 대한 권리는 상속인의 확정, 관리인의 선임 또는 파산선고가 있을 때로부터 6월 안에는 소멸시효가 완성하지 않는다.
- ③ 부부의 일방의 타방에 대한 권리는 혼인관계의 종료한 때로부터 6월 안에는 소멸시효가 완성하지 않는다.
- ④ 재산을 관리하는 부모 또는 후견인에 대한 제한능력자의 권리는 그가 능력자가 되거나 또는 후임의 법정대리인이 취임한 때로부터 6월 안에는 소멸시효가 완성하지 않는다.
- ⑤ 소멸시효의 기간만료 전 6월 안에 제한능력자의 법정대리인이 없게 된 때에는 후임의 법정대리인이 취임한 때로부터 6월 안에는 시효가 완성하지 않는다.

해설

- ① 천재 그 밖의 사변으로 인하여 소멸시효를 중단할 수 없을 때에는 그 사유가 종료한 때로부터 1월 안에는 시효가 완성하지 않는다. 정답: ①

18 시효에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 소멸시효는 강행규정이므로 이를 배제·연장·가중·단축·감경할 수 없다.
- ② 시효의 이익은 미리 포기하지 못한다.
- ③ 소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다.
- ④ 임의출석도 소멸시효중단의 사유가 된다.
- ⑤ 시효이익을 포기할 수 있는 자가 다수인 경우 1인의 포기는 다른 사람에게 영향을 미치지 않는다.

해설

- ① 소멸시효는 이를 배제·연장·가중할 수 없으나 단축 또는 감경할 수 있다. 정답: ①

19 제척기간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 제척기간에 의한 권리소멸의 효과는 그 기간이 경과한 때로부터 장래에 향하여 생긴다.
- ② 제척기간에 의한 권리소멸의 여부는 당사자의 주장에 관계없이 법원이 직권으로 조사하여 한다.
- ③ 불법행위를 한 날로부터 10년이 경과하면 손해배상청구를 할 수 없도록 한 민법의 규정은 제척기간이 아니라 소멸시효에 관한 규정이다.
- ④ 형성권의 행사기간은 소멸시효기간에 해당한다.
- ⑤ 제척기간에는 기간의 중단이 있을 수 없다.

해설

- ④ 형성권의 행사기간은 소멸시효가 아니라 제척기간에 해당한다. 정답: ④

20 소멸시효와 제척기간에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 소멸시효와 제척기간에 의한 권리의 소멸은 모두 소급하여 효력이 생긴다.
- ② 소멸시효기간의 완성 후에는 이익의 포기라는 제도가 있으나, 제척기간에는 그러한 제도가 없다.
- ③ 권리소멸에 대한 원용의 필요성에 관하여 소멸시효에 있어서는 당사자의 원용을 요하나, 제척기간에 있어서는 원용이 없어도 법원이 직권으로 고려한다.
- ④ 제척기간에는 소멸시효기간에 있어서와는 달리 중단이라는 제도는 인정되지 않는다.
- ⑤ 소멸시효에는 시효정지에 관한 규정이 있으나, 제척기간에는 정지에 관한 규정이 없으며, 다만 제182조의 정지제도가 제척기간에 준용될 것인가에 학설의 대립이 있다.

해설

- ① 소멸시효의 완성의 효과는 소급효가 있으나, 제척기간은 소급효가 없다. 정답: ①

01 기간의 계산에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 어느 법률이 2023년 1월 30일에 공포되고 부칙에서 공포 후 6월이 경과한 날부터 시행하도록 되어 있다면, 그 법률은 2023년 7월 31일 0시부터 시행된다.
- ② 기간계산에 관한 「민법」 규정은 강행규정이므로 당사자가 법률행위로 달리 정할 수 없다.
- ③ 2004년 8월 5일 오전 8시에 태어난 자는 2023년 8월 6일 0시부터 성인자이다.
- ④ 2023년 5월 22일 오후 1시에 오토바이를 빌리면서 3월 내에 반환하기로 한 경우 8월 21일 24시가 만료점이 된다.
- ⑤ 2023년 9월 8일 오후 2시에 사단법인의 사원총회를 소집하려면, 별도의 정함이 없는 한, 2023년 9월 2일 24시까지 사원들에게 소집통지가 발송되어야 한다.

제6장
실전문제

해설

- ① 타당한 기술이다.
- ② 기간계산에 관한 「민법」 규정은 임의규정이므로 당사자가 법률행위로 달리 정할 수 있다.
- ③ 2004년 8월 5일 오전 8시에 태어난 자는 연령계산에 있어서 초일을 산입하므로 2023년 8월 5일 오전 0시(8월 4일 24시)부터 성인자이다.
- ④ 2023년 5월 22일 오후 1시에 오토바이를 빌리면서 3월 내에 반환하기로 한 경우 8월 22일 24시가 만료점이 된다.
- ⑤ 2023년 9월 8일 오후 2시에 사단법인의 사원총회를 소집하려면, 별도의 정함이 없는 한, 총회소집 1주일 전까지 소집통지해야 하므로(제71조) 2023년 8월 31일 24시(9월 1일 0시)까지 사원들에게 소집통지가 발송되어야 한다. 정답: ①

02 기간계산에 관한 다음 설명 중 잘못된 내용은 어느 것인가?

- ① 기간계산에 관한 민법 규정은 사법관계 뿐만 아니라 공법관계에도 적용된다.
- ② 민법의 기간에 관한 규정은 강행규정으로 당사자의 특약으로 달리 정할 수 없다.
- ③ 상행위에 의한 채무의 이행과 관련해서는 기간의 말일이 영업시간의 종료로써 만료한다.
- ④ 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료하며, 이때의 공휴일에는 임시공휴일도 포함된다.
- ⑤ 기간의 초일이 공휴일이라도 기간의 기산점이 되는 데는 상관없다.

해설

- ② 기간에 관한 규정은 보충적 규정이며, 법령이나 관습 또는 법률행위(특약)에 의하여 달리 정함이 있으면 그에 의한다(제155조).
- ① 대법원 1993.11.23. 93도662
- ③ 상법 제63조
- ④ 제161조, 정부가 임시공휴일을 지정한 경우 그 공휴일은 휴일에 해당한다(대법원 1964.5.26. 63다958).

- ⑤ 기간의 말일이 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다는 규정의 취지는 기간의 말일이 공휴일인 경우를 정하는 것이고, 이는 기간의 만료일이 공휴일에 해당함으로써 발생할 수 있는 불이익을 막자고 함에 그 뜻이 있는 것이므로 기간 기산의 초일은 이의 적용이 없다(대법원 1982.2.23. 81누204).

정답: ②

03 甲(2001년 3월 14일 17시 출생)은 자기 소유의 부동산을 법정대리인인 부모의 동의 없이 2019년 2월 19일 오전 10시경 乙에게 매도하였다. 甲이 직접 계약을 취소하려는 경우, 취소권은 언제까지 행사할 수 있는가? (기간 말일의 공휴일 등 기타 사유는 고려하지 않음)

- ① 2023년 3월 13일 24시 ② 2023년 3월 14일 24시
③ 2024년 3월 13일 24시 ④ 2024년 3월 14일 24시
⑤ 2029년 2월 19일 24시

해설

- ① 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다. 미성년자인 甲이 직접 취소권을 행사하는 경우, 제척기간으로서의 '추인할 수 있는 날로부터 3년'이란 성년이 된 때로부터 3년이다. 甲이 성년이 되는 때는 2020년 3월 13일 24시가 되고, 그로부터 3년은 2023년 3월 13일 24시가 된다. 정답: ①

04 기간의 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (기간 말일의 공휴일 등 기타 사유는 고려하지 않음)

- ① 기간을 연으로 정한 경우 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 익월의 초일로 기간이 만료한다.
② 기간을 일(日)로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.
③ 기간을 시, 분, 초로 정한 때에는 즉시로부터 기산한다.
④ 기간을 월로 정한 경우 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 기간의 초일을 산입한다.
⑤ 연령계산에는 출생일을 산입한다.

해설

- ① 월·년으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다 (제160조 제3항). 정답: ①

07 다음 중 설명이 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 생산자 및 상인이 판매한 생산물 및 상품의 대가채권의 소멸시효는 3년이다.
- ② 판결에 의하여 확정된 채권의 소멸시효기간을 10년으로 한다고 함은 단기의 소멸시효에 걸리는 것이라도 확정판결을 받은 권리의 소멸시효는 10년으로 한다는 뜻일 뿐이지, 10년보다 장기의 소멸시효를 10년으로 단축한다는 의미도 아니고, 본래 소멸시효의 대상이 아닌 권리가 확정판결을 받음으로써 10년의 소멸시효에 걸린다는 뜻도 아니라는 것이 판례의 입장이다.
- ③ 甲은 乙로부터 경운기 1대를 2년간 빌리기로 하고 그 사용료로 1년 이내에 금 50만 원을 지급하기로 약속하였다. 이때에 乙이 갖는 경운기 사용료 금 50만 원 채권의 소멸시효기간은 10년이다.
- ④ 계속적 거래관계로 인하여 발생한 채권의 경우 변제기에 관한 특약이 없는 한 소멸시효의 기산점은 각 외상대금채권이 발생한 때로부터 개별적으로 진행한다.
- ⑤ 채권자 甲과 주 채무자 乙사이의 판결에 의해 판매대금채권이 확정되어 그 소멸시효가 10년으로 되었다면 채권자 甲과 연대보증인 丙사이의 연대보증채권의 소멸시효기간도 10년이다.

해설

- ⑤ 甲과 乙 사이의 채권에 대한 확정판결은 채권자 甲과 연대보증인 丙 사이의 연대보증채권의 시효기간에 대해서 아무런 영향을 미치지 않기 때문에 채권자와 연대보증인의 연대보증채권의 소멸시효기간은 여전히 종전의 소멸시효기간에 따른다(대법원 1986.11.25. 86다카1569).
- ② 대법원 1981.3.24. 80다1888
- ④ 대법원 1978.12.22. 92다40211 정답: ⑤

08 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소멸시효의 기간은 법률행위로 단축할 수 있다.
- ② 매달 지급해야 하는 집합건물의 관리비채권의 소멸시효기간은 10년이다.
- ③ 환매권의 행사로 발생한 소유권이전등기청구권의 소멸시효기간은 10년이다.
- ④ 공유물분할청구권은 그 기초가 되는 법률관계가 존속하는 동안 시효로 소멸하지 않는다.
- ⑤ 근저당설정약정에 의한 근저당권설정등기청구권은 피담보채권과 별도로 소멸시효가 진행된다.

해설

- ② 민법 제163조 제1호에서 3년의 단기소멸시효에 걸리는 것으로 규정한 '1년 이내의 기간으로 정한 채권'이란 1년 이내의 정기로 지급되는 채권을 말하는 것으로서 1개월 단위로 지급되는 집합건물의 관리비채권은 이에 해당한다(대법원 2007.02.22. 2005다65821). 정답: ②

09 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소멸시효는 그 기산일에 소급하여 효력이 생긴다.
- ② 소멸시효이익은 시효가 완성되기 전에 미리 포기하지 못한다.
- ③ 주된 권리가 시효로 소멸하면 종된 권리에 그 효력이 미친다.
- ④ 20년의 시효에 걸리는 권리에 확정판결이 있으면, 그 시효기간은 10년으로 단축된다.
- ⑤ 시효는 법률행위에 의하여 이를 가중할 수 없으나 경감할 수는 있다.

해설

- ④ 단기의 소멸시효에 걸리는 것이라도 확정판결을 받은 권리의 소멸시효는 10년으로 한다는 뜻일 뿐, 10년보다 장기의 소멸시효를 10년으로 단축한다는 의미도 아니고 본래 소멸시효의 대상이 아닌 권리가 확정판결을 받음으로써 10년의 소멸시효에 걸린다는 뜻도 아니다(대법원 1981.03.24. 80다1888). 정답: ④

10 민법상 소멸시효의 중단사유로서 최고에 대한 설명이다. 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 최고라 함은 채무자에 대하여 이행을 청구하는 채권자의 의사 통지이다.
- ② 최고 후 6개월 이내에 다시 최고를 한 경우 최고를 할 때마다 시효중단의 효력이 생기는 것은 아니다.
- ③ 최고를 여러 번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 있어서의 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생한다.
- ④ 최고는 6월내에 재판상의 청구, 파산절차참가, 화해를 위한 소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분을 하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다.
- ⑤ 최고는 그 형식이나 방법의 여하를 묻지 않으므로 서면·구두를 불문한다.

해설

- ③ 최고를 여러 번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 있어서의 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생하는 것이 아니라 재판상 청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고시에 발생한다(대법원 1987.12.22., 87다카2337). 정답: ③

11 소멸시효에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 판례에 의하면 시효를 주장하는 자가 원고가 되어 소(訴)를 제기한 데 대하여 피고로서 응소행위를 한 경우에는 피고가 시효중단 취지의 주장을 하지 않더라도 응소행위가 있었다는 사실만으로 당연히 시효중단의 효력이 발생한다.
- ② 채무의 일부변제가 있으면 채권의 시효는 중단된다.
- ③ 파산절차 참가신청이 있으면 시효중단의 효력이 생긴다.
- ④ 재판 외에서 채무이행을 청구하고 1년이 지난 뒤에 소(訴)를 제기하면 채무이행을 청구한 때에 시효가 중단되지 않는다.
- ⑤ 본소(本訴)가 제기된 법원에 반소(反訴)를 제기하여도 소멸시효는 중단된다.

해설

- ① 시효중단사유의 하나로 규정하고 있는 재판상의 청구라 함은, 통상적으로는 권리자가 원고로서 시효를 주장하는 자를 피고로 하여 소송물인 권리를 訴의 형식으로 주장하는 경우를 가리키지만, 시효의 이익을 받는 자가 원고가 되어 訴를 제기한 데 대하여 피고로서 응소하여 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우도 마찬가지로 이에 포함되는 것으로 해석함이 타당하다(대법원 1997.11.11. 96다28196).
- ② 시효완성 전에 채무의 일부를 변제한 경우에는, 그 수액에 관하여 다툼이 없는 한 채무승인으로서의 효력이 있어 시효중단의 효과가 발생한다(대법원 1996.1.23. 95다39854).
- ③ 다만 채권자가 이를 취소하거나 또는 그 청구가 각하된 때에는 시효중단의 효력이 없다(제171조)
- ④ 제174조
- ⑤ 재판상 청구란 민사소송이지만 하면 되고 그것이 본소이든, 반소이든, 이행·확인·형성의 소송이든 불문한다. 정답: ①

12 소멸시효에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 매매대금채무의 이행지체로 인한 지연손해금채권의 소멸시효기간은 10년이다.
- ② 소유권이전등기 말소등기 의무의 이행불능으로 인한 전보배상청구권의 소멸시효는 말소등기 의무가 이행불능상태에 돌아간 때로부터 진행된다.
- ③ 공유관계가 존속하는 한, 그 공유물분할청구권만이 독립하여 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ④ 기한을 정하고 있지 않은 채권의 경우, 소멸시효의 기산점은 특별한 규정이 없는 한 채권이 발생한 때이지만, 지체책임은 이행청구를 받은 때로부터 부담한다.
- ⑤ 소멸시효는 특별한 사정이 없는 한 권리를 행사하는 데 사실상의 장애사유가 없는 때로부터 진행된다.

해설

- ⑤ 소멸시효의 기산점인 권리를 행사할 수 있는 때란 권리를 행사함에 있어서 법률상의 장애(예) 이행 기미도래, 정지조건 미성취)가 없는 경우를 말하며, 권리자가 개인적 사정이나 법률지식의 부족, 권리존재의 부지 또는 채무자의 부재 등 사실상 장애로 권리를 행사하지 못하였다 하여 시효가 진행하지 아니하는 것이 아니며, 이행기가 정해진 채권은 그 기한이 도래한 때부터 소멸시효가 진행된다(대법원 1982.1.19. 80다26260).

- ① 매매대금채무의 이행지체로 인한 지연손해금채권은 손해배상채권이므로 소멸시효기간은 10년이다(대법원 1989.2.28, 88다카214).
- ② 매매로 인한 부동산소유권이전채무가 이행불능 됨으로써 매수인이 매도인에 대하여 갖게 되는 손해배상채권은 그 부동산소유권의 이전채무가 이행불능된 때에 발생하는 것이고 그 계약체결일에 생기는 것은 아니므로 위 손해배상채권의 소멸시효는 계약체결일이 아닌 소유권이전채무가 이행불능된 때부터 진행한다(대법원 1990.11.9, 90다카22513).
- ③ 일정한 법률관계에 의존하는 권리인 상린관계상의 권리 및 공유물분할청구권(제268조)은 기초가 되는 법률관계가 존재하는 한 독립하여 소멸시효의 대상이 되지 않는다(대법원 1981.3.24, 80다1888). 또한 공유물분할청구권은 형성권으로서 제척기간의 대상이 될 뿐이다.
- ④ 기한을 정하고 있지 않은 채권의 경우, 소멸시효의 기산점은 채권이 발생한 때이지만, 이행지체책임은 이와 달리 채무자가 이행청구를 받은 때로부터 지체책임이 있다(제387조 제2항). 정답: ⑤

13 소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제하거나 연장할 수 없다.
- ② 시효의 중단은 원칙적으로 당사자 및 그 승계인 사이에서만 효력이 있다.
- ③ 소멸시효 중단사유로서의 채무승인은 채무가 있음을 알고 있다는 뜻의 의사표시이므로 효과의사가 필요하다.
- ④ 소멸시효의 이익은 시효가 완성되기 전에 미리 포기하지 못한다.
- ⑤ 소멸시효 완성 후 채무자는 시효완성의 사실을 알고 그 채무를 묵시적으로 승인함으로써 시효의 이익을 포기할 수 있다.

해설

- ③ 소멸시효 중단사유로서의 승인은 시효의 이익을 받을 당사자가 시효로 인해 권리를 잃을 자에 대하여 상대방의 권리를 인정한다는 일방적인 관념의 통지에 해당한다. 따라서 의사표시에서 요구되는 효과의사를 요하지 않는다. 정답: ③

14 소멸시효의 기산점에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 채무자가 소멸시효 완성 후에 채무를 승인함으로써 시효이익을 포기한 경우에는 그 채무는 소멸시효가 완성된 때로부터 시효가 다시 진행된다.
- ② 부작위 채권의 소멸시효는 그 위반행위를 한 때로부터 진행된다.
- ③ 무효인 과세처분에 기해 오납한 세금의 반환청구권의 소멸시효는 납세자가 그 과세처분의 무효를 안 날로부터 진행된다.
- ④ 이행불능으로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 본래의 채권을 행사할 수 있는 때부터 진행된다.
- ⑤ 동시이행의 항변권이 붙은 채권의 소멸시효는 채권자가 변제의 제공을 하여 채무자의 동시이행의 항변권이 소멸된 때부터 진행된다.

해설

- ② 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다(제166조 제2항).
- ① 채무자가 소멸시효 완성 후에 채무를 승인함으로써 시효이익을 포기한 경우에는 그 채무는 시효 이익을 포기한 때로부터 시효가 다시 진행된다.
- ④ 이행불능으로 인한 손해배상청구권은 이행불능시로부터 소멸시효가 진행한다(대법원 1990.11.9. 90다카22513).
- ⑤ 동시이행의 항변권이 붙어 있는 채권의 경우 항변권의 유무는 당해 권리의 행사가능성과 무관하므로 일반원칙에 따라 시기부 권리는 이행기가 도래한 때부터, 기한 없는 권리는 발생시부터 소멸시효가 진행된다. 정답: ②

15 소멸시효의 기산점에 관한 것으로 틀린 것은? (견해의 대립시 판례에 의한다)

- ① 물권은 일반적으로 권리가 발생한 때부터 시효가 진행된다.
- ② 재판상의 청구로 인하여 중단된 시효는 재판이 확정된 때부터 다시 진행된다.
- ③ 동시이행의 항변권이 붙어 있는 채권은 이행기가 도래한 때부터 소멸시효가 진행된다.
- ④ 불법행위에 의한 손해배상청구권은 기한의 약정이 없는 채권이고, 따라서 불법행위시부터 소멸시효가 진행된다.
- ⑤ 채무불이행으로 인한 손해배상청구권은 본래의 채권을 행사할 수 있는 때로부터 소멸시효가 진행된다.

해설

◎ 소멸시효의 기산점

확정기한부 채권	기한이 도래한 때, 기한이 연기된 경우에는 그 연기된 기한이 새로운 기산점이 된다.
불확정기한부 채권	① 객관적으로 그 기한이 도래한 때부터 소멸시효가 진행된다. ② 채무자의 기한도래사실에 대한 알고 모름은 불문한다.
기한의 정함이 없는 채권	채권이 성립한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
청구 또는 해지통고 후 상당기간이나 일정기간이 지나야 청구할 수 있는 권리	그 기간(유예기간)이 경과한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
기한이익의 상실특약이 있는 채권	할부금채무에서 채무자가 1회라도 변제를 지체하면 채권자가 전 채무의 이행을 청구할 수 있는 특약을 한 경우에는 그 1회의 불이행시부터 잔액 전부에 대한 소멸시효가 진행된다는 것이 통설이나, 판례는 견해를 달리한다(판례참조).
정지조건부 권리	조건성취시부터 소멸시효가 진행된다.
부작위채권	위반행위시부터 소멸시효가 진행된다.
채무불이행으로 인한 손해배상청구권	학설은 대립이 있으며, 판례는 채무불이행시로부터 소멸시효가 진행된다고 한다.
동시이행의 항변권	이행기 도래시부터 소멸시효가 진행된다.
구 상 권	보증인의 구상권은 그 권리가 발생되어 행사할 수 있는 때로부터 소멸시효가 진행된다.

정답: ⑤

16 소멸시효의 기산점에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의한다)

- ① 이전등기의무 이행불능으로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 매매계약이 체결된 때로부터 진행된다.
- ② 공동불법행위자 중 1인의 다른 공동불법행위자에 대한 구상채권은 구상권자가 현실로 피해자에게 손해금을 지급한 때로부터 기산한다.
- ③ 물품계약에 기하여 발생한 외상대금채권은 특별한 사정이 없는 한 채권이 발생한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ④ 무권대리인에 대한 상대방의 계약이행 또는 손해배상청구권의 소멸시효의 기산점은 그 어느 권리를 행사할 것인가를 선택할 수 있었을 때로부터 진행된다.
- ⑤ 기한이익 상실의 특약이 있는 할부채무에 있어서는 1회의 불이행이 있더라도 각 할부금에 대해 그 각 변제기의 도래시마다 그 때부터 순차로 소멸시효가 진행하고 채권자가 특히 잔존채무 전액의 변제를 구하는 취지의 의사를 표시한 경우에 한하여 전액에 대하여 그 때부터 소멸시효가 진행된다.

해설

- ① 판례에 의하면 이행불능으로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 채무이행이 불능으로 된 때부터 진행된다(대법원 1990.11.9. 90다카22513).
- ② 교통사고의 피해자들에게 손해배상을 한 공동불법행위자의 1인의 다른 공동불법행위자에 대한 구상금채권은 일반채권과 같이 구상권자가 현실로 피해자에게 손해금을 지급한 때로부터 10년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다(대법원 1979.5.15. 78다528).
- ③ 기한을 정하지 않은 채권의 소멸시효의 기산점은 채권이 발생한 때로부터 진행되므로 각 외상채권이 발생한 때로부터 기산한다(대법원 1978.3.29. 77다2463).
- ④ 선택채권은 채권을 행사할 수 있는 때로부터 소멸시효가 진행된다(대법원 1965.8.24. 64다1156).
- ⑤ 판례의 태도(대법원 1997.8.29. 97다12990), 단, 통설은 1회의 불이행시로부터 잔액 전부에 대하여 소멸시효가 진행된다고 한다. 정답: ①

17 소멸시효 기간의 기산점에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 동시이행의 항변권이 붙어 있는 채권은 이행기가 도래한 때부터 소멸시효가 진행된다.
- ② 부작위를 목적으로 하는 채권은 위반행위를 한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ③ 불확정기한부 채권은 채무자가 그 기한의 도래를 안 때부터 소멸시효가 진행된다.
- ④ 기한을 정하고 있지 않은 채권은 그 채권이 발생한 때부터 소멸시효가 진행된다.
- ⑤ 이행불능으로 인한 전보배상청구권의 소멸시효는 이행불능시부터 진행된다.

해설

- ③ 불확정기한부 채권은 객관적으로 그 기한이 도래한 때로부터 소멸시효가 진행된다. 정답: ③

18 소멸시효의 기산점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 채무의 이행기가 도래한 후에 채무자의 요청에 의하여 채권자가 채무자에게 기한을 유예한 경우, 유예한 이행기일로부터 다시 소멸시효가 진행된다.
- ② 불확정기한부 채권은 객관적으로 기한이 도래하면 그 때부터 소멸시효가 진행된다.
- ③ 동시이행의 항변권이 붙어있는 채권은 그 항변권이 소멸된 이후부터 소멸시효가 진행된다.
- ④ 매수인이 매매 목적물인 부동산을 인도 받아 점유하고 있는 이상 그 소유권이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다.
- ⑤ 매매로 인한 소유권이전채무의 이행불능으로 인한 손해배상채권의 소멸시효는 그 소유권이전채무가 이행불능으로 된 때부터 진행된다.

해설

- ③ 동시이행의 항변권이 붙어있는 채권은 그 이행기가 도래한 때로부터 소멸시효가 진행된다.
- ① 채권의 소멸시효는 이행기가 도래한 때로부터 진행되지만 이행기일이 도래한 후에 채권자가 채무자에 대하여 기한을 유예한 경우에는 유예시까지 진행된 시효는 포기한 것으로서 유예한 이행기일부터 다시 시효가 진행된다(대법원 1992.12.22. 92다40211).
- ② 권리가 '확정기한부'인 경우에는 그 기한이 도래한 때부터 시효가 진행하고, '불확정기한부'인 경우에는 그 기한이 객관적으로 도래한 때부터 시효가 진행된다. 정답: ③

19 소멸시효의 기산점이 옳게 연결되지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 부작위를 목적으로 하는 채권 - 위반행위시
- ② 동시이행의 항변권이 붙어 있는 채권 - 이행기 도래시
- ③ 이행불능으로 인한 손해배상청구권 - 이행불능시
- ④ 甲이 자기 소유의 건물 매도시 그 이익을 乙과 분배하기로 약정한 경우 乙의 이익금 분배청구권 - 분배약정시
- ⑤ 기한이 있는 채권의 이행기가 도래한 후 채권자와 채무자가 기한을 유예하기로 합의한 경우 그 채권 - 변경된 이행기 도래시

해설

- ④ 소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하며 여기서 권리를 행사할 수 있는 때라 함은 권리행사에 법률상의 장애가 없는 때를 말하므로 정지조건부 권리의 경우에는 조건 미성취의 동안은 권리를 행사할 수 없는 것이어서 소멸시효가 진행되지 않는 것이다(대법원 1992. 12. 22. 92다28822). 甲이 자기 소유의 건물매도시 그 이익을 乙과 분배하기로 약정한 경우 乙의 이익금 분배청구권은 정지조건부 권리에 해당하고 분배약정단계는 조건 미성취 상태라 할 수 있다.
- 정답: ④

20

소멸시효의 중단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소멸시효가 중단된 때에는 중단까지 경과한 시효기간은 산입되지 아니하고, 중단사유가 종료한 때로부터 시효가 새로이 진행된다.
- ② 재판상 청구 후에 그 소를 취하하더라도 시효중단의 효력이 유지된다.
- ③ 원고가 제기한 소에서 피고로서 응소하여 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우, 시효중단사유인 재판상의 청구에 해당한다.
- ④ 주채무자에 대한 시효의 중단은 보증인에 대하여 그 효력이 있다.
- ⑤ 한 개의 채권 중 일부에 관하여만 판결을 구한다는 취지를 명백히 하여 소송을 제기한 경우, 소멸시효중단의 효력은 나머지 부분에는 발생하지 않는 것이 원칙이다.

해설

- ② 재판상의 청구는 소송의 각하, 기각 또는 취하의 경우에는 시효중단의 효력이 없다(제170조 제1항).
- ③ 취득시효를 주장하는 자가 원고가 되어 소를 제기한 데 대하여 권리자가 피고로서 응소하고 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하여 그것이 받아들여진 경우에는 시효중단사유의 하나로 규정하고 있는 재판상 청구에 포함한다(대법원 1993.12.21, 92다47861 전합).
- ④ 주채무자에 대한 시효중단은 보증인에 대하여 그 효력이 있다(제440조).
- ⑤ 청구부분이 일부임이 특정될 수 있거나 명시된 경우에는 일부에 관하여만 시효중단의 효력이 발생하지만, 일부만을 청구한 경우에도 청구취지로 보아 채권 전부에 관하여 판결을 구하는 것으로 해석되는 경우에는 채권의 동일성의 범위 내에서 채권전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생한다(대법원 1992.4.10., 91다43695). 정답: ②

21

시효중단의 효력에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 손해배상청구권을 공동상속한 자 중 1인이 자기의 상속분을 행사하여 승소판결을 얻었다면, 다른 공동상속인의 상속분에도 시효중단의 효력이 미친다.
- ② 물상보증인의 재산에 대하여 압류를 한 경우에, 이를 채무자에게 통지하면 채무자에 대해서도 시효가 중단된다.
- ③ 요역지가 수인의 공유인 경우에, 어느 1인에 의한 지역권 소멸시효의 중단은 다른 공유자에 대해서도 효력이 있다.
- ④ 연대채무자 중 1인에 대한 이행청구는 다른 연대채무자에게도 시효중단의 효력이 미친다.
- ⑤ 주채무자에 대한 시효중단은 보증인에게도 효력이 있다.

해설

- ① 시효의 중단은 당사자 및 그 승계인 간에만 효력이 있다. 여기서 당사자란 시효중단행위에 관여한 당사자를 말하고 시효의 대상인 권리의 당사자를 의미하지 않는다. 따라서 손해배상의 공동상속인 중 1인이 자기의 상속분에 대하여 승소판결을 얻은 경우, 다른 상속인의 상속분까지는 시효중단의 효력이 미치지 않는다.
- ② 제176조, ③ 제296조, ④ 제416조, ⑤ 제440조 등은 예외적으로 시효중단의 효력이 미치는 사례들이다. 정답: ①

24 소멸시효의 중단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 시효기간만료 전에 응소함으로써 시효가 중단되는 경우 소멸시효기간이 만료된 후라도 사실심 변론종결 전에는 언제든지 시효중단을 주장할 수 있다.
- ② 시효중단의 효력은 당사자 및 그 승계인 사이에서만 효력이 있다.
- ③ 시효중단의 효력 있는 승인에는 상대방의 권리에 관한 처분의 능력이나 권한 있음을 요한다.
- ④ 사망한 사람을 피신청인으로 한 가압류결정은 상속인에 대하여 시효중단의 효력이 없다.
- ⑤ 가처분은 시효의 이익을 받은 자에 대하여 하지 아니한 때에는 이를 그에게 통지한 후가 아니면 시효중단의 효력이 없다.

해설

- ③ 시효중단의 효력 있는 승인에는 상대방의 권리에 관한 처분의 능력이나 권한 있음을 요하지 아니한다(제177조). 정답: ③

25 소멸시효의 중단과 정지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 승인은 시효의 진행이 개시된 후에만 할 수 있고, 그 전에 승인하더라도 시효가 중단되지 않는다.
- ② 여러 차례의 최고가 있을 후, 재판상 청구가 있더라도 그 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고를 한 때에 발생한다.
- ③ 가압류에 의한 시효중단의 효력은 가압류의 집행보전의 효력이 존속하는 동안 계속된다.
- ④ 재판상의 청구로 중단된 시효는 재판이 확정된 때로부터 새로이 진행한다.
- ⑤ 천재 기타 사변으로 인하여 시효를 중단할 수 없을 때에는, 그 사유가 종료한 때로부터 1개월 내에는 시효가 완성하지 않는다.

해설

- ② 최고를 여러 번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생하는 것이 아니라 재판상 청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고시에 발생한다(대법원 1987.12.22. 87다카2337). 정답: ②

26

소멸시효이익의 포기에 관한 판례의 입장과 다른 것은?

- ① 소멸시효이익 포기의 의사표시를 할 수 있는 자는 시효완성의 이익을 받을 당사자 또는 대리인에 한정된다.
- ② 주채무자가 시효이익을 포기하더라도 보증인이나 물상보증인에게서는 포기의 효과가 미치지 않는다.
- ③ 소멸시효완성 이후에 있는 과세부과처분에 대하여 세액을 납부하였다면 소멸시효의 이익을 포기한 것으로 보아야 한다.
- ④ 채권의 소멸시효가 완성된 후에 채무자가 그 기한의 유예를 요청하였다면 그때에 소멸시효의 이익을 포기한 것으로 보아야 한다.
- ⑤ 채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정된다.

해설

- ③ 소멸시효완성 이후에 있는 과세처분에 기하여 세액을 납부하였다 하더라도 이를 들어 바로 소멸시효의 이익을 포기한 것으로 볼 수 없다는 것이 판례의 입장이다(대법원 1988.1.19., 87다카70).
정답: ③

27

제척기간에 관하여 다음 중 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 당사자 사이의 약정에 의하여 제척기간은 연장할 수 없다.
- ② 제척기간에 의한 권리의 소멸은 당사자가 이를 주장하지 않더라도 법원이 당연히 고려하여야 하는 직권조사사항이다.
- ③ 형성권을 행사한 결과 발생하는 채권도 그 형성권의 제척기간까지 존속한다.
- ④ 제204조 제3항과 제205조 제2항 소정의 점유보호청구권은 그 기간 내에 재판상 행사하여야 한다. 즉, 반드시 그 기간 내에 소(訴)를 제기하여야 하는 출소기간으로 해석한다.
- ⑤ 제척기간을 정하지 않은 형성권의 제척기간은 10년이다.

해설

- ③ 판례는 형성권행사의 결과 발생하는 채권적 권리는 형성권을 행사한 때로부터 따로 소멸시효가 진행된다고 본다(대법원 1991.2.22. 90다13420).
② 대법원 2000.10.13. 99다18725
④ 대법원 2002.4.26. 2001다8097
⑤ 대법원 1992.7.28. 91다44766, 44773 정답: ③

28 소멸시효에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 재판상 청구는 민사소송이지만 하면 족하고, 소의 종류는 묻지 아니하므로 이행의 소, 확인의 소, 형성의 소, 반소이든 소송계속 중에 청구의 변경이든 모두 시효중단의 효력이 있다.
- ② 채권자와 주채무자 사이의 판결 등에 의해 채권이 확정되어 그 소멸시효가 10년으로 되었다 할지라도 위 당사자 이외의 채권자와 연대보증인 사이에 있어서는 위 확정판결은 그 시효기간에 대하여는 아무런 영향이 없고, 연대보증인의 연대보증채무의 소멸시효기간은 여전히 종전의 소멸시효기간에 따른다고 보아야 한다.
- ③ 주된 권리의 소멸시효가 완성되더라도 종된 권리의 소멸시효는 그와 별개로 독립적으로 진행한다.
- ④ 소멸시효 중단사유인 재판상의 청구라 함은 통상적으로는 권리자가 원고로서 시효를 주장하는 자를 피고로 하여 소송물인 권리를 소의 형식으로 주장하는 경우를 가리키지만, 이와 반대로 시효를 주장하는 자가 원고가 되어 소를 제기한 데 대하여 피고로서 응소하여 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우도 마찬가지로 이에 포함되는 것으로 해석함이 타당하다.
- ⑤ 채권자대위권의 행사에서 제3채무자는 채무자가 채권자에 가지는 항변으로 대항할 수 없고, 채권의 소멸시효가 완성된 경우 이를 원용할 수 있는 자는 원칙적으로는 시효이익을 직접 받는 자뿐이므로 제3채무자는 이를 행사할 수 없다.

해설

③ 제183조(종속된 권리에 대한 소멸시효의 효력)

주된 권리의 소멸시효가 완성한 때에는 종속된 권리에 그 효력이 미친다. 정답: ③

29 소멸시효 완성 후에 한 시효이익의 포기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 시효이익을 포기하면 그 때부터 시효가 새로 진행된다.
- ② 시효완성의 이익을 받을 당사자 또는 그 대리인은 시효이익 포기의 의사표시를 할 수 있다.
- ③ 주채무자가 시효이익을 포기하더라도 보증인에게는 그 효력이 없다.
- ④ 시효이익을 이미 포기한 사람과의 법률관계를 통해 시효이익을 원용할 이해관계를 형성한 사람은 소멸시효를 주장할 수 있다.
- ⑤ 채권의 시효완성 후에 채무자가 그 기한의 유예를 요청한 때에는 시효이익을 포기한 것으로 보아야 한다.

해설

- ④ 시효완성의 이익포기의 의사표시를 할 수 있는 자는 시효완성의 이익을 받을 당사자 또는 대리인에 한정된다고 할 것이고, 그 밖의 제3자가 시효완성의 이익포기의 의사표시를 하였다 하더라도 이는 시효완성의 이익을 받을 자에 대한 관계에서 아무 효력이 없다(대법원 1988.02.27. 97다 53366). 정답: ④

30

소멸시효와 관련된 판례의 내용 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산 매수인이 목적물을 인도 받고 있으면 그 등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ② 과세처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 소는 비록 행정소송일지라도 그것은 부당이득 반환청구권에 관한 재판상 청구에 해당한다.
- ③ 채권의 소멸시효가 완성된 후에 채무자가 그 변제기한의 유예를 요청하였더라도 소멸시효의 이익을 포기한 것으로 볼 수는 없다.
- ④ 소멸시효완성 이후의 과세처분에 기하여 세액을 납부한 경우 바로 소멸시효의 이익을 포기한 것이라고 할 수 없다.
- ⑤ 소멸시효로 채무를 면한 자는 시효기간 중의 이자·지연손해금을 지급할 필요가 없다.

해설

- ③ 채권의 소멸시효가 완성된 후에 채무자가 그 변제기한의 유예를 요청한 것은 소멸시효의 이익을 포기한 것으로 볼 수 있다. 정답: ③

31

소멸시효의 중단과 정지에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소송계속 중 청구의 변경도 시효중단의 사유가 된다.
- ② 현존하지 아니한 장래의 채권을 미리 승인하면 소멸시효의 진행이 중단된다.
- ③ 가압류에 의한 시효중단의 효력은 가압류의 집행보전의 효력이 존속하는 동안은 계속된다.
- ④ 부부일방의 타방에 대한 권리는 혼인관계가 종료한 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성되지 않는다.
- ⑤ 공유자의 한 사람이 공유물의 보존행위로서 그 공유물의 일부 지분에 관하여서만 재판상 청구를 하였으면 다른 공유자에 대해서는 시효중단의 효력이 없다.

해설

- ② 소멸시효의 진행이 개시되기 전에 소멸시효의 중단사유로서의 승인을 할 수 없다. 소멸시효의 중단사유로서의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 그 권리의 존재를 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립하는 것이므로 이는 소멸시효의 진행이 개시된 이후에만 가능하고 그 이전에 승인을 하더라도 시효가 중단되지는 않는다고 할 것이고, 또한 현존하지 아니하는 장래의 채권을 미리 승인하는 것은 채무자가 그 권리의 존재를 인식하고서 한 것이라고 볼 수 없어 허용되지 않는다고 할 것이다(대법원 2001.11.9, 2001다52568).
- ① 소멸시효의 중단사유로서 재판상 청구는 보통 소를 제기하는 것을 지칭하지만, 재심청구, 공시최고의 신청은 물론 반소, 소송계속 중의 청구의 변경이나 확장도 시효중단사유로 된다. 더 나아가 피고로서 응소하여 승소한 경우에도 중단된다(대법원 1993.12.21, 92다47861 전합).
- ③ 대법원 2000.4.25, 2000다11102
- ④ 제180조 제2항
- ⑤ 공유자의 한 사람이 공유물의 보존행위로서 그 공유물의 일부 지분에 관하여서만 재판상 청구를 하였으면 그로 인한 시효중단의 효력은 그 공유자와 그 청구한 소송물에 한하여 발생한다(대법원 1999.8.20., 99다15146). 정답: ②

32 甲의 乙에 대한 채권을 담보하기 위해 丙이 자신의 부동산에 저당권을 설정해 준 경우, 甲의 乙에 대한 채권의 소멸시효 중단사유가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 丙의 저당권말소등기청구의 소에 대한 甲의 응소
- ② 甲의 乙에 대한 채권에 기한 지급명령 신청
- ③ 乙의 재산에 대한 甲의 가압류 신청
- ④ 乙이 변제기 도래 후에 한 채무의 승인
- ⑤ 乙의 파산절차에 대한 甲의 참가

해설

- ① 시효중단사유의 하나로 규정하고 있는 재판상의 청구라 함은, 통상적으로는 권리자가 원고로서 시효를 주장하는 자를 피고로 하여 주장하는 경우를 가리키지만, 시효의 이익을 받는 자가 원고가 되어 소를 제기한 데 대하여 피고로서 응소하여 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우도 마찬가지로 이에 포함된다(대법원 2005.12.23. 2005다59383,59390). 물상보증인 丙의 저당권말소등기청구의 소에 대한 甲의 응소는 이에 해당하지 아니한다. 정답: ①

33 소멸시효와 제척기간에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소멸시효와 제척기간 모두 중단과 정지가 인정된다.
- ② 소멸시효의 중단에 관한 규정은 취득시효에 준용한다.
- ③ 소멸시효는 법률행위로 단축할 수 없다.
- ④ 당사자가 본래의 소멸시효 기산일보다 뒤의 날짜를 기산일로 주장하는 경우 법원은 본래의 소멸시효 기산일을 기준으로 소멸시효를 계산하여야 한다.
- ⑤ 제척기간은 소송상 당사자가 제척기간의 도과를 주장한 경우에 한하여 고려된다.

해설

◎ 소멸시효와 제척기간의 비교

구 분	소 멸 시 효	제 척 기 간
소급효	소멸시효로 인한 권리소멸은 소급	권리소멸의 효과는 소급하지 않고 장래에 향하여 발생
중단제도	인 정	부 정
정지제도	인 정	부 정(다수설)
법원의 직권고려 여부	재판의 기초로 하기 위하여는 당사자의 원용이 있어야 한다. 이는 상대적 소멸설에 의하면 논리적 필연이고, 절대적 소멸설에 의하면 민사소송법상의 변론주의 때문이다.	원용이 없어도 당연히 권리가 소멸한다. 따라서 법원은 당사자의 원용이 없어도 이를 직권으로 고려하여야 한다.
이익의 포기	시효기간 완성 후의 소멸시효이익의 포기 제도가 있다.	이익의 포기가 인정되지 않는다.
기간의 단축	법률행위에 의하여 이를 단축 또는 경감할 수 있다.	단축 또는 경감할 수 없다.

정답: ②

34

소멸시효와 제척기간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 명의신탁 해지를 원인으로 하는 소유권에 기한 이전등기청구권은 소멸시효의 대상이 되지 않는다.
- ② 점유자가 점유를 계속하는 동안에는 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기청구권은 소멸시효가 진행되지 않는다.
- ③ 공유물분할청구권은 공유관계가 존속하는 한 그 분할청구권만이 독립하여 시효로 소멸될 수 없다.
- ④ 제척기간을 정한 형성권의 경우, 그 행사로 인하여 발생하는 채권도 형성권의 제척기간 내에 행사하여야 한다.
- ⑤ 소멸시효의 중단에 관한 규정은 취득시효에 의한 소유권취득기간에 준용한다.

해설

- ④ 취소권의 행사에 대하여는 제척기간이 적용되나, 그 취소권의 행사로 인하여 발생하는 부당이득반환청구권은 소멸시효가 적용된다. 정답: ④

35

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 변제기가 도래한 단기소멸시효채권이 판결에 의해 확정된 경우 그 소멸시효는 5년으로 한다.
- ② 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다.
- ③ 최고는 6월내에 재판상의 청구, 파산절차참가, 화해를 위한 소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분을 하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다.
- ④ 1년의 단기소멸시효에 걸리는 채권의 상대방이 그 채권의 발생원인이 된 계약에 기하여 가지는 반대채권은 특별한 사정이 없는 한 10년의 소멸시효에 걸린다.
- ⑤ 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제, 연장 또는 가중할 수 없으나 이를 단축 또는 경감할 수 있다.

해설

- ① 판결에 의해서 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년이다(제 165조 제1항). 정답: ①

36

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 손해배상청구권에 대해 법률이 제척기간을 규정하고 있더라도 그 청구권은 소멸시효에 걸린다.
- ② 동시이행의 항변권이 붙어 있는 채권은 그 항변권이 소멸한 때로부터 소멸시효가 기산한다.
- ③ 채권양도 후 대항요건을 갖추지 못한 상태에서 양수인이 채무자를 상대로 소를 제기하면 양도된 채권의 소멸시효는 중단된다.
- ④ 비법인사단이 채무를 승인하여 소멸시효를 중단시키는 것은 사원총회의 결의를 요하는 총유물의 관리·처분행위가 아니다.
- ⑤ 채권의 소멸시효 완성 후 채무자가 채권자에게 그 담보를 위해 저당권을 설정해 줌으로써 소멸시효의 이익을 포기했다면 그 효력은 그 후 저당부동산을 취득한 제3자에게도 미친다.

해설

- ② 부동산에 대한 매매대금채권이 소유권이전등기청구권과 동시이행의 관계에 있다고 할지라도 매도인은 매매대금의 지급기일 이후 언제라도 그 대금의 지급을 청구할 수 있는 것이며, 다만 매수인은 매도인으로부터 그 이전등기에 관한 이행의 제공을 받기까지 그 지급을 거절할 수 있는데 지나지 아니하므로 매매대금청구권은 그 지급기일 이후 시효의 진행에 걸린다(대법원 1991.03.22. 90다 9797). 즉 이행기 도래시부터 소멸시효가 진행된다. 정답: ②

37

소멸시효의 중단과 정지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2022' 감정평가사]

- ① 시효의 중단은 원칙적으로 당사자 및 그 승계인 간에만 효력이 있다.
- ② 파산절차참가는 채권자가 이를 취소하거나 그 청구가 각하된 때에는 시효중단의 효력이 없다.
- ③ 부재자재산관리인은 법원의 허가 없이 부재자를 대리하여 상대방의 채권의 소멸시효를 중단시키는 채무의 승인을 할 수 없다.
- ④ 천재 기타 사변으로 인하여 소멸시효를 중단할 수 없을 때에는 그 사유가 종료한 때로부터 1월내에는 시효가 완성하지 아니한다.
- ⑤ 부부 중 한쪽이 다른 쪽에 대하여 가지는 권리는 혼인관계가 종료된 때부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성되지 아니한다.

해설

- ③ 승인을 함에 있어서는 상대방의 권리에 관하여 처분의 능력이나 권한이 있음을 요하지 아니한다(제177조). 정답: ③

02

CONTENT

물권법

서론

1

기본문제

01

다음 중 부동산을 그 객체로 할 수 없는 물건은?

- ① 소유권 ② 지상권 ③ 유치권
④ 질 권 ⑤ 저당권

해설

- ④ 민법은 동산질권과 권리질권을 규정하고 있다. 따라서 부동산은 질권의 객체로 될 수 없다.
나머지는 모두 부동산을 객체로 할 수 있다. 정답: ④

02

다음 중 물건과 채권의 차이에 관한 설명으로서 틀린 것은?

- ① 물건은 지배권이고 채권은 청구권이다.
② 물건은 법정된 것에 한하는 것이 원칙이나 채권은 그러하지 아니하다.
③ 모든 물건은 등기하여야 효력이 있으나 채권은 그러하지 아니하다.
④ 물건은 성립순위에 따라 우선적 효력이 있으나 채권 사이에는 우선적 효력이 없다.
⑤ 물건의 목적물은 현존한 특정물건 또는 독립된 물건임을 요하나 채권의 목적물은 그러하지 않다.

해설

㉠ 물건의 객체

물 건	예외적으로 권리가 물건의 객체가 되는 경우 ┌ 채권의 준점유 └ 재산권을 목적으로 하는 권리질권 └ 지상권과 전세권을 목적으로 하는 저당권
독 립	예외적으로 용익물권은 토지나 건물의 일부 위에 설정이 가능하다.
현 존	채권의 객체는 현존하지 않는 물건의 급부를 목적으로 할 수 있다.
특 정	채권의 객체는 불특정물을 목적으로 할 수 있다.

- ③ 물건 중 유치권, 점유권 등은 등기가 될 수 없는 권리이다.

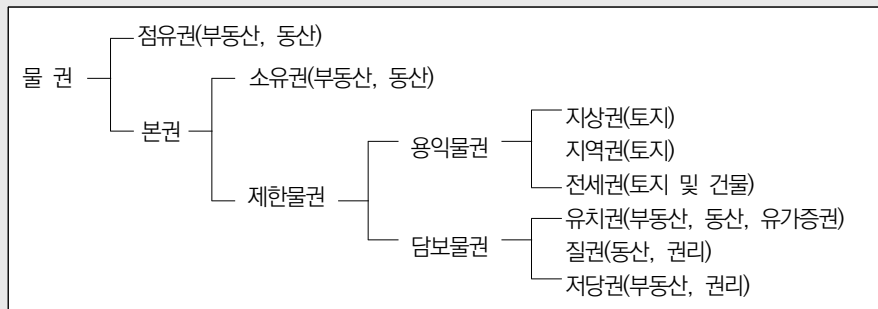
정답: ③

03 권리의 객체는 원칙적으로 특정된 독립의 물건이어야 한다. 다음의 기술 중 잘못된 것은?

- ① 관리할 수 있는 자연력은 물건이므로 그 위에 물권의 성립이 가능하다.
- ② 수목은 그것이 자라고 있는 토지의 정착물이며 독립성이 없으나 그 집단은 관습법상의 공시방법을 갖추면 물권의 객체가 될 수도 있다.
- ③ 물권의 객체는 특정한 것만으로는 부족하며 동시에 현존하는 것이어야 하므로 장래의 물건에 대하여서는 성립할 수 없다.
- ④ 물건의 일부나 집단위에 하나의 물권을 인정하여야 할 사회적 필요나 실익이 있고 공시가 가능한 때에는 물건의 일부나 집합물위에 물권을 설정할 수 있다.
- ⑤ 물건이 아닌 권리 위에는 물권이 성립할 수 없다.

해설

◎ 민법이 인정하는 물건



- ⑤ 권리질권이 인정되며, 지상권이나 전세권도 저당권의 목적이 될 수 있다. 정답: ⑤

04 제한물권이 아닌 것은?

- [illegible]

해설

- ① 점유권은 본권이 아니므로 제한물권에 해당하지 않는다. 정답: ①

05 부동산만을 객체로 하는 물건으로 묶인 것은?

- ① 소유권-점유권-저당권
- ② 소유권-지상권-저당권
- ③ 지상권-지역권-전세권
- ④ 유치권-질권-저당권
- ⑤ 지상권-유치권-저당권

해설

- ③ 용익물권은 모두 부동산물권이다. 정답: ③

06 물건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토지의 일부에 대하여 구분소유권이 인정된다.
- ② 지역권은 구역지와 분리하여 양도할 수 없다.
- ③ 질권과 저당권은 권리 위에도 설정될 수 있다.
- ④ 등기된 수목의 집단(입목)은 토지와는 독립한 물권의 객체가 된다.
- ⑤ 지상공간의 일부나 지하의 일부분만을 대상으로 하는 구분지상권이 인정된다.

해설

- ① 건물의 일부분이 경제적으로 독립한 효용을 가지며 또한 사회관념상 독립한 소유권을 인정할 필요가 있는 경우에, 한 채의 건물을 구분하여 그 일부분에 각각의 소유권을 인정하는 것을 구분소유라고 한다(제215조 제1항). 토지에 대한 구분소유는 인정되지 않는다(다만, 공동소유는 허용된다).
- ② 지역권은 구역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다(제292조 제2항. 지역권의 부종성).
- ③ 질권은 재산권을 그 목적으로 할 수 있다. 그러나 부동산의 사용, 수익을 목적으로 하는 권리는 그러하지 아니하다(제345조, 권리질권). 저당권도 지상권 또는 전세권을 목적으로 할 수 있다(제371조 제1항).
- ④ 「입목에 관한 법률」에 의하여 '수목의 집단'은 독립한 부동산으로 된다(동법 제3조 제1항). 입목은 소유권보존등기에 의하여 독립된 물건으로서 양도할 수 있고 저당권의 목적으로 할 수도 있다(동법 제3조).
- ⑤ 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다(제289조의2, 구분지상권). 정답: ①

07 물건적 청구권에 관한 설명으로서 틀린 것은?

- ① 소유권에 기인하는 물건적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ② 물건적 청구권은 침해자의 귀책사유를 그 요건으로 한다.
- ③ 토지의 진정한 소유자는 현재의 등기명의자에게 고의나 과실이 없는 경우에도 진정한 권리 관계에 반하는 소유권이전등기의 말소를 요구할 수 있다.
- ④ 물건적 청구권은 물권의 내용이 실현을 방해받고 있거나 방해당할 염려가 있는 경우에 그 방해의 제거 또는 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있는 권리이다.
- ⑤ 물건적 청구권은 불법행위로 인한 손해배상청구권과 양립할 수 있다.

해설

물건적 청구권

의 의

- 물권의 내용의 실현이 어떤 사정으로 인하여 방해당하고 있거나 방해당할 염려가 있는 경우에 그 방해의 제거 또는 예방에 필요한 일정한 행위를 청구할 수 있는 권리이다.
- 점유권과 소유권에 관하여 명문의 규정을 두고 있으며 소유권에 기인한 물건적 청구권을 다른 물건에도 준용한다.

법 률 적 성 질	▪ 물건적 청구권은 채권적 청구권에 우선한다. ▪ 물건과 운명을 같이하므로 물건이 이전, 소멸되면 물건적 청구권도 따라서 이전, 소멸한다.
종 류	▪ 물건적 반환청구권 └ 물건자가 물건의 현실적 지배를 전면적으로 빼앗긴 경우 침탈자에게 반환을 청구 할 수 있는 권리 └ 침탈자의 고의, 과실은 요건이 아님 └ 청구의 상대방은 현재의 점유자 └ 지역권자, 저당권자에게는 인정되지 않음 ▪ 물건적 방해제거청구권 └ 점유침탈 이외의 방법으로 현실적 지배를 방해당하고 있는 경우에 방해자에게 그 제거를 청구할 수 있는 권리 └ 방해자의 고의, 과실은 요건이 아님 └ 청구의 상대방은 방해의 사실을 현재 자기의 지배 내에 두고 있는 자 ▪ 물건적 방해예방청구권 └ 물건이 현재 방해당하고 있지는 않지만 방해가 생길 객관적 염려가 있는 경우에는 그 원인을 제거하여 방해가 생기지 않도록 조치를 청구할 수 있는 권리 └ 방해자의 고의, 과실은 요건이 아님 └ 청구의 상대방은 방해의 염려사실을 현재 자기의 지배 내에 두고 있는 자
손해배상 청구권과의 관계	물건의 침해가 방해자(침해자)의 고의 또는 과실로 이루어져 불법행위가 성립할 때에는 손해배상청구권을 행사할 수 있다. → 양자의 청구권이 양립

정답: ②

08 물건적 청구권에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지역권 및 저당권에서는 목적물반환청구권이 인정되지 않는다.
- ② 지상권 및 전세권에서는 목적물반환청구권이 인정된다.
- ③ 사기에 의해 물건을 인도한 자는 점유물반환청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 매매를 원인으로 소유권이전등기를 경료해 준 자는 불법점유자에 대하여 소유권에 기한 물건적 청구권을 행사하지 못한다.
- ⑤ 물건적 청구권과 함께 손해배상청구권이 인정되기 위해서는 침해자의 고의 또는 과실을 요한다.

해설

- ③ 점유권에 기한 반환청구권이 인정되려면 점유가 침탈되어야 한다. 그런데 사기에 의해 물건을 인도한 것은 점유자의 의사에 의한 것이지 의사에 반한 점유의 이탈, 즉 침탈이라고 볼 수 없으므로 점유권에 기한 반환청구권은 인정되지 않는다는 것이 판례이다.
- ④ 소유권을 상실한 매도인은 더 이상 물건자가 아니므로 물건적 청구권을 행사하지 못한다.
- ⑤ 물건적 청구권은 상대방의 귀책사유를 요건으로 하지 않는다. 그러나 손해배상청구권은 상대방의 귀책사유(고의 또는 과실)를 요건으로 한다. 그러므로 침해자에게 고의 또는 과실이 있다면 둘 다 인정된다. 정답: ③

01 법률에서 정하는 요건이 충족되면 당연히 성립하는 법정담보물권에 해당하는 것은?

[2023' 감정평가사]

- ① 유치권
- ② 채권질권
- ③ 법정지상권
- ④ 전세권저당권
- ⑤ 동산·채권 등의 담보에 관한 법률에 따른 동산담보권

해설

① 유치권은 일정한 사유가 발생하면 당연히 성립되는 법정담보물권이고, 질권이나 저당권처럼 당사자의 합의에 의하여 성립하는 약정담보물권이 아니다. 정답: ①

02 1필의 토지의 일부를 객체로 할 수 없는 권리는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 공인중개사]

㉠ 저당권 ㉡ 전세권 ㉢ 지상권 ㉣ 임차권 ㉤ 점유권

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢
- ④ ㉡, ㉤ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤

해설

① 저당권은 1필의 토지 일부위에는 설정할 수 없다. 정답: ①

03 명인방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 관습법상의 공시방법이다.
- ② 수확되지 아니한 농작물에 대해서도 인정된다.
- ③ 토지의 지상물이 독립된 물건이며 현재의 소유자가 누구라는 것을 명시하여야 한다.
- ④ 명인방법으로 양도담보를 공시할 수 없다.
- ⑤ 건물 이외의 지상물을 토지 또는 원물과 분리하지 않은 채 독립된 거래객체로 하는 데 이용된다.

해설

④ 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 소유권과 양도담보의 객체가 될 수 있다. 정답: ④

04

물권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 특별한 사정이 없으면, 물건의 일부는 물권의 객체가 될 수 없다.
- ② 권원 없이 타인의 토지에 심은 수목은 독립한 물권의 객체가 될 수 없다.
- ③ 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법으로 특정할 수 있으면 수량이 변동하는 동산의 집합도 하나의 물권의 객체가 될 수 있다.
- ④ 소유권을 비롯한 물권은 소멸시효의 적용을 받지 않는다.
- ⑤ 소유권을 상실한 전(前)소유자는 물권적 청구권을 행사할 수 없다.

해설

- ④ 용익물권은 20년의 소멸시효에 걸린다. 정답: ④

05

물권의 객체에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 지상권은 물건이 아니므로 저당권의 객체가 될 수 없다.
- ② 법률상 공시방법이 인정되지 않는 유동집합물이라도 특정성이 있으면 이를 양도담보의 목적으로 할 수 있다.
- ③ 저당권과 질권은 서로 다른 물건이므로 하나의 물건에 관하여 동시에 성립할 수 있다.
- ④ 토지소유권은 토지의 상하에 미치므로 지상공간의 일부만을 대상으로 하는 구분지상권은 원칙적으로 허용되지 않는다.
- ⑤ 기술적인 착오 없이 작성된 지적도에서의 경계가 현실의 경계와 다르다면, 토지소유권의 범위는 원칙적으로 현실의 경계를 기준으로 확정하여야 한다.

해설

- ② 일반적으로 일단의 증감 변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼으려는 이른바 집합물에 대한 양도담보설정계약체결도 가능하며 이 경우 그 목적 동산이 담보설정의 다른 물건과 구별될 수 있도록 그 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법에 의하여 특정되어 있으면 그 전부를 하나의 재산권으로 보아 이에 유효한 담보권의 설정이 된 것으로 볼 수 있다 (대법원 2013.1.16. 2012다78726).
- ① 지상권이나 전세권은 저당권의 객체가 될 수 있다.
- ④ 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다(구분지상권, 제289조의 2).
- ⑤ 지적도상의 경계와 실제의 경계에 차이가 있는 경우에는 도상경계를 경계로 보나, 지적공부상의 경계등록에 명백한 오류가 있음이 입증될 때에는 실제의 경계를 경계로 볼 수 있다. 정답: ②

㉠ 전세권 ㉡ 지상권 ㉢ 저당권 ㉣ 임차권

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉣
 ④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ② 용익물권은 모두 토지를 그 객체로 점유할 수 있다. 임차권도 토지를 객체로 점유할 수 있으나 물권이 아니고 채권이다. 정답: ②

- ① 우리 민법은 명문으로 소유권, 점유권, 유치권, 질권에 기한 물권적 청구권을 규정하고 있다.
 ② 소유권에 기한 반환청구권과 점유권에 기한 반환청구권은 선의의 특별승계인에게 대항할 수 없다.
 ③ A가 타인 토지에 건축을 한 뒤 그 건물을 B에게 양도하고 점유를 이전해 준 경우에는 물권적 청구권의 상대방은 B이다.
 ④ 물권적 청구권은 물건과 분리하여 양도할 수 있다.
 ⑤ 물권적청구권은 모두 소멸시효에 걸린다.

해설

- ③ 물권적 청구권의 상대방은 물권의 원만한 지배를 방해하는 원인을 현재 자기의 지배 내에 가지고 있는 자이며 그 판단 시기는 청구권의 존부를 확정해야 하는 때, 즉 사실심 변론 종결 시를 기준으로 한다.
 사안에서는 현재 토지를 점유하여 토지소유자의 점유를 방해하고 있는 자인 B가 청구권의 상대방이다.
 ① 우리 민법은 물권적 청구권에 관한 일반규정을 두지 않고 점유권에 기한 물권적 청구권과 소유권에 기한 물권적 청구권을 규정하고 소유권에 기한 물권적 청구권에 관한 규정을 지상권, 지역권, 전세권, 저당권에 준용하고 있으나, 질권, 유치권에 대해서는 규정하고 있지 않다.
 ② 소유권에 기한 반환청구권은 선의의 특정승계인에 대하여도 주장할 수 있으나, 점유권에 기한 반환청구권은 선의의 특정승계인에게 대항할 수 없다.
 ④ 물권적 청구권은 물권의 실효성을 확보하기 위한 것으로 물건에서 파생되므로 물건에 종속하며 따로 분리, 양도할 수 없다.
 ⑤ 판례에 의하면 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다. 정답: ③

08 물권적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효 대상이 아니다.
- ② 간접점유자는 제3자의 점유침해에 대하여 물권적 청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 토지의 저당권자는 무단점유자에 대해 저당권에 기한 저당물반환청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 점유물반환청구권은 점유를 침탈당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.
- ⑤ 점유보조자에게는 점유보호청구권이 인정되지 않는다.

해설

③ 지역권자와 저당권자에게는 목적물반환청구권이 인정되지 아니한다. 정답: ③

09 물권적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲의 물건을 乙이 불법 점유하는 경우 甲은 丙에게 그 소유권을 양도하면서 乙에 대한 소유물반환청구권을 자신에게 유보할 수 없다.
- ② 소유자는 현재 점유하고 있지 않은 자를 상대로 소유물의 반환을 청구할 수 없다.
- ③ 물권적 청구권은 점유권과 소유권 이외의 물권에 대하여도 인정된다.
- ④ 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ⑤ 간접점유자는 직접점유자가 점유의 침탈을 당한 때에는 그 물건의 반환을 청구할 수 없다.

해설

⑤ 간접점유자에게 점유보호청구권은 있으나(제207조), 다만 침탈자에 대하여 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있다. 정답: ⑤

- ① 점유물반환청구권은 점유를 침탈당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다.
- ② 양자 간 등기명의신탁에서 명의수탁자가 신탁부동산을 처분하여 제3취득자가 유효하게 소유권을 취득하였는데, 그 후 명의수탁자가 우연히 신탁부동산의 소유권을 다시 취득하였다면 명의신탁자의 소유권에 기한 물권적 청구권이 인정된다.
- ③ 제3자가 저당권설정자인 소유자의 의사에 반하여 저당권이 설정된 건물의 점유를 침탈한 경우 저당권자는 자신에게 건물의 반환을 청구할 수 있다.
- ④ 토지소유자는 그의 토지 위에 무단으로 건축된 건물을 임차하여 점유하고 있는 자를 상대로 건물철거를 청구할 수 있다.
- ⑤ 유효하게 부동산을 명의신탁한 자는 자신이 직접 제3자에게 물권적 청구권을 행사하여 신탁재산에 대한 침해배제를 구할 수 있다.

해설

- ① 점유물반환청구권은 침탈당한 날로부터 1년내에 행사하여야 한다(제204조 제3항).
- ② 소유자가 자신의 소유권에 기하여 실제관계에 부합하지 아니하는 등기의 명의인을 상대로 그 등기말소나 진정명의회복 등을 청구하는 경우에, 그 권리는 물권적 청구권으로서의 방해배제청구권(민법 제214조)의 성질을 가지는데, 이와 같은 등기말소청구권 등의 물권적 청구권은 그 권리자인 소유자가 소유권을 상실하면 이제 그 발생의 기반이 없게 되어 더 이상 그 존재 자체가 인정되지 아니하는 것이다. 따라서 양자간 등기명의신탁에서 명의수탁자가 신탁부동산을 처분하여 제3취득자가 유효하게 소유권을 취득하고 이로써 명의신탁자가 신탁부동산에 대한 소유권을 상실하였다면, 명의신탁자의 소유권에 기한 물권적 청구권, 즉 말소등기청구권이나 진정명의회복을 원인으로 한 이전등기청구권도 더 이상 그 존재 자체가 인정되지 않는다. 따라서 그 후 명의수탁자가 우연히 신탁부동산의 소유권을 다시 취득하였다고 하더라도 명의신탁자가 신탁부동산의 소유권을 상실한 사실에는 변함이 없으므로, 여전히 물권적 청구권은 그 존재 자체가 인정되지 않는다고 할 것이다(대법원 2013.2.28. 2010다89814).
- ③ 저당권자에게는 물권적 반환청구권이 인정되지 않는다.
- ④ 토지소유자는 그의 토지 위에 무단으로 건축된 건물을 임차하여 점유하고 있는 자를 상대로 건물철거를 청구할 수는 없고, 침탈자인 건물의 임대인을 상대로 물권적 청구권을 행사하여야 한다.
- ⑤ 종중 및 배우자간의 명의신탁과 같이 유효하게 재산을 타인에게 신탁한 경우 대외적인 관계에 있어서는 수탁자만이 소유권자로서 그 재산에 대한 제3자의 침해에 대하여 배제를 구할 수 있으며, 신탁자는 수탁자를 대위하여 수탁자의 권리를 행사할 수 있을 뿐 직접 제3자에게 신탁재산에 대한 침해의 배제를 구할 수 없다. 따라서 명의신탁자는 불법점유자 내지는 불법등기명의자에게 대해 직접 그 명도 또는 등기말소를 청구할 수는 없고, 수탁자를 대위하여 그 권리를 행사할 수 있을 뿐이다(대법원 1979.9.25. 77다1079 전원합의체). 정답: ①

11 물권적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ② 소유권을 상실한 전(前)소유자는 제3자의 불법점유에 대하여 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 없다.
- ③ 임차인이 임차권에 기하여 토지를 점유하고 있는 경우, 임대인인 토지소유자는 임차인에게 물권적 청구권을 행사할 수 없다.
- ④ 부동산에 대한 점유취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권은 물권적 청구권이다.
- ⑤ 토지의 매수인이 소유권이전등기를 경료받기 전에 매매계약의 이행으로 그 토지를 인도받은 경우, 매도인은 매수인에게 토지 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사할 수 없다.

해설

- ④ 부동산에 대한 점유취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이다.

정답: ④

12 물권적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 지역권자는 지역권을 방해하는 자에 대하여 방해의 제거를 청구할 수 있다.
- ② 간접점유자는 제3자의 점유침해에 대하여 물권적 청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 직접점유자가 임의로 점유를 타인에게 양도한 경우에는 그 점유이전이 간접점유자의 의사에 반하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다.
- ④ 부동산 양도담보의 피담보채무가 전부 변제되었음을 이유로 양도담보권설정자가 행사하는 소유권이전등기말소청구권은 소멸시효에 걸린다 .
- ⑤ 민법 제205조 제2항이 정한 점유물방해제거청구권의 행사를 위한 다년의 제척기간'은 출소 기간이다.

해설

- ④ 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다. 정답: ④

13 물건적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 물건적 청구권은 물건과 분리하여 양도하지 못한다.
- ② 물건적 청구권을 보전하기 위하여 가등기를 할 수 있다.
- ③ 미등기건물을 매수한 사람은 소유권이전등기를 갯출 때까지 그 건물의 불법점유자에게 직접 자신의 소유권에 기하여 인도를 청구하지 못한다.
- ④ 토지소유자는 권원 없이 그의 토지에 건물을 신축·소유한 사람으로부터 건물을 매수하여 그 권리의 범위에서 점유하는 사람에게 건물의 철거를 청구할 수 있다.
- ⑤ 소유권에 기한 말소등기청구권은 소멸시효의 적용을 받지 않는다.

해설

- ② 부동산등기법상의 가등기는 주로 채권적 청구권을 보전하기 위해서만 가능하고 이 같은 청구권이 아닌 물건적 청구권을 보전하기 위해서는 할 수 없다(대법원 1982.11.23. 81다카1110).

정답: ②

14 물건적 청구권에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소유자는 소유권을 방해할 염려가 있는 자에 대하여 그 예방과 함께 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.
- ② 점유보조자가 그 물건의 사실적 지배를 가지는 이상 물건적 청구권의 상대방이 된다.
- ③ 乙이 소유자 甲으로부터 토지를 매수하고 인도받았으나 등기를 갯추지 않고 다시 丙에게 전매하고 인도한 경우, 甲은 丙에게 소유물반환청구를 할 수 있다.
- ④ 甲의 토지 위에 乙이 건물을 무단 신축하고 이를 丙에게 임대한 경우, 甲은 직접점유자 丙을 상대로 건물철거를 청구할 수 있다.
- ⑤ 甲의 토지 위에 乙이 건물을 무단 신축하고 이를 丙에게 양도하였으나 건물이 아직 미등기인 경우, 甲은 丙을 상대로 건물철거를 청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 등기를 갯추지 않은 부동산취득자에게 법률상·사실상 처분권이 인정되므로 甲은 丙에게 건물철거를 청구할 수 있다.
- ① 선택적으로만 행사할 수 있다(제214조).
- ② 간접점유자는 물건적 청구권의 상대방이 되나, 점유보조자는 상대방이 되지 않는다.
- ③ 丙은 정당한 점유권원을 가지고 있으므로 甲은 丙에게 소유물반환청구를 할 수 없다(대법원 1988.4.25. 87다카1682).
- ④ 임차인 丙에게는 건물의 철거권한이 없다. 정답: ⑤

물권변동

1

기본문제

01

공시의 원칙과 공신의 원칙에 관한 다음의 기술 중 타당하지 않은 것은?

- ① 우리 민법은 이 두 원칙을 동산·부동산에 구별하지 않고 인정한다.
- ② 민법상 공시방법을 갖추지 않으면 당사자는 물론 모든 사람에 대한 관계에 있어 물권변동의 효력이 생기지 않는다.
- ③ 부동산물권의 등기, 채권양도에 대한 통지, 혼인신고 등은 공시의 원칙이 적용되는 예이다.
- ④ 물권변동에 있어 공신력을 인정하는 경우, 진정한 권리자에게 불법행위로 인한 손해배상 청구권이 인정될 수 있다.
- ⑤ 공신의 원칙을 채택하면 거래의 안전은 꺾일 수 있으나, 진정한 권리자가 희생되는 경우가 있게 된다.

제2장
기본문제

해설

◎ 공신의 원칙

의 의	공시방법을 신뢰하고 거래한 자가 보호된다는 원칙이다.
장단점	상대방과 거래의 안전을 도모할 수 있으나 진정한 권리자는 희생된다(동적 안전은 보호되나 정적 안전을 희생).
적 용	㉠ 「 부동산등기 : 부정 └ 동산의 점유 : 인정 예 갑 소유의 동산을 임대차에 의하여 점유하고 있는 을이 그 동산을 병에게 매각한 경우에 병은 무권리자인 을로부터 양수하였음에도 불구하고 소유권을 취득한다. ㉡ 적용례 ㉢ 채권의 준점유자에 대한 변제자의 보호 ㉣ 표현대리 ㉤ 증권적 채권의 소지인에 대한 변제자의 보호 등

정답: ①

02 부동산물권의 변동에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.
- ② 상속·공용징수·판결·경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니하나, 이를 처분하려면 등기하여야 한다.
- ③ 부동산에 관한 점유권·유치권은 등기를 요하지 아니하나, 법정지상권은 등기를 요한다.
- ④ 부동산 점유취득시효에 의한 소유권의 취득은 「민법」 제187조의 예외로서 등기를 요한다.
- ⑤ 건물의 신축에 의한 소유권의 취득은 「민법」 제187조에 의거 등기를 요하지 않는다.

해설

법정지상권도 법률의 규정에 의한 물권변동이므로 등기를 요하지 않는다. 정답: ③

03 다음 중 등기를 하여야 물권이 변동하는 것은?

- ① 토지수용에 의한 소유권이전 ② 취득시효에 의한 소유권취득
- ③ 주물취득에 따른 종물취득 ④ 부동산의 경매에 의한 소유권취득
- ⑤ 상속에 의한 부동산소유권이전

해설

상속(제997조), 공용징수(대법원 2000.7.4. 98다62961), 판결(대법원 1970.6.30. 70다568), 경매(민사집행법) 기타 법률의 규정에 의한 물권의 취득은 등기를 요하지 않는다. 그러나 등기하지 않으면 제3자에게 처분하지 못한다.

※ 법률의 규정에 의한 물권변동

- 신축건물의 소유권취득(대법원 1997.5.9. 96다54867)
- 법정지상권의 취득(제305조)
- 관습법상의 법정지상권의 취득(제366조)
- 법정저당권의 취득(제649조)
- 존속기간만료로 인한 용익물권의 소멸
- 혼동에 의한 물권의 소멸(제191조)
- 피담보채권의 소멸로 인한 저당권의 소멸
- 법률행위의 무효, 취소로 인한 물권의 복귀(유인성설)
- 법정대위로 인한 저당권의 이전(제368조)
- 분배농지의 상환완료에 의한 소유권의 취득
- 재단법인으로의 출연재산의 귀속(다수설)
- 포괄적 승계(포괄유증, 회사의 합병)

② 취득시효로 인한 물권변동은 법률의 규정에 의한 물권변동이지만, 반드시 등기를 요한다(제245조).

정답: ②

04 다음 중 법률행위로 인한 권리변동이 아닌 것은?

- ① 상속으로 인한 소유권의 취득 ② 지역권 설정
- ③ 지상권 설정 ④ 매매를 원인으로 한 소유권의 이전
- ⑤ 교환을 원인으로 한 소유권의 이전

해설

① 상속으로 인한 소유권의 취득은 법률의 규정에 의한 물권의 변동이다.
 ②③④⑤ 법률행위로 인한 물권의 변동이다. 정답: ①

05 다음 중 등기를 하여야만 부동산에 관한 물건취득의 효력이 생기는 것은?

- ① 피상속인의 사망으로 재산을 상속한 경우
- ② 법률행위를 원인으로 하여 소유권이전등기절차를 명하는 판결이 확정된 경우
- ③ 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따라 토지를 수용한 경우
- ④ 국세징수법에 의한 공매절차에서 매각대금을 완납한 경우
- ⑤ 건축주가 직접 신축건물을 건축한 경우

해설

② 민법 제187조의 판결은 형성판결만을 의미하며 이전등기절차를 명하는 이행판결은 등기를 하여야만 물권을 취득한다. 정답: ②

제2장
기본문제

06 다음 중 등기하여야 부동산에 관한 물건변동의 효력이 발생하는 경우로 짝지어진 것은? (단, 다툼이 있으면 판례에 의함)

- ㉠ 매매계약의 취소에 의한 소유권의 복귀
- ㉡ 경매로 인한 소유권의 취득
- ㉢ 교환계약에 의한 부동산물권의 이전
- ㉣ 피상속인의 사망으로 인한 상속인의 상속재산의 취득
- ㉤ 법원의 이행판결에 의한 소유권의 이전
- ㉥ 포괄유증으로 인한 소유권 이전

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣ ③ ㉢, ㉤
- ④ ㉤, ㉥ ⑤ ㉣, ㉥

해설

① 법률행위가 무효 또는 취소되면 말소등기 없이도 당연히 물권이 복구된다는 것이 판례이다.
 ② 경매는 매각대금 완납시에 물권이 변동한다.
 ③④ 교환계약에 의한 물건변동은 법률행위이므로 등기를 요하고 등기 없이 물건변동을 가져오는 판결은 형성판결만을 의미하므로 이행판결에 의해서 물건변동이 발생하려면 등기를 요한다.
 ⑤ 상속은 법 제187조에 의해서 등기를 요하지 않고 피상속인 사망시에 즉시 물권이 변동한다.
 ⑥ 상속, 포괄유증, 회사의 합병과 같이 포괄적으로 권리, 의무가 승계되는 경우에는 법 제187조가 적용되므로 등기 없이 물권이 변동한다. 정답: ③

07 甲 소유의 건물에 대하여 甲과 乙 사이에 매매의 예약이 2023년 4월 1일에 행하여지고, 乙은 같은 날 이 예약에 기하여 소유권이전청구권보전의 가등기를 하였다. 그런데 甲이 그 부동산을 丙에게 매각, 丙 앞의 소유권이전의 본등기가 2023년 6월 1일 행하여졌다. 따라서 乙이 예약완결의 의사표시를 하고, 2023년 8월 1일 가등기에 기하여 소유권이전의 본등기를 하였다. 이 경우 乙이 소유권자가 되는 시기는?

- ① 2023년 4월 1일
- ② 2023년 4월 1일에서 1996년 6월 1일 사이
- ③ 2023년 6월 1일
- ④ 2023년 8월 1일
- ⑤ 병의 본등기가 먼저 있었으므로 을은 소유권자가 될 수 없다.

해설

④ 가등기에 의거하여 본등기가 행하여지면 본등기의 순위는 가등기의 순위에 의하지만, 물건변동의 시기가 가등기를 한 때까지 소급한다는 것을 의미하지는 않는다(대법원 1992.9.25. 92다 21258). 즉, 乙이 소유권자가 되는 것은 소유권이전의 본등기를 경료한 2023년 8월 1일이다.

정답: ④

08 법률행위에 의하지 않은 부동산물권의 변동에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 공인중개사]

- ① 관습상 법정지상권은 설정등기 없이 취득한다.
- ② 이행판결에 기한 부동산물권의 변동시기는 확정판결시이다.
- ③ 상속인은 등기 없이 상속받은 부동산의 소유권을 취득한다.
- ④ 경매로 인한 부동산소유권의 취득시기는 매각대금을 완납한 때이다.
- ⑤ 건물의 신축에 의한 소유권취득은 소유권보존등기를 필요로 하지 않는다.

해설

② 등기 없이 물건변동을 가져오는 판결은 형성판결만을 의미하므로 이행판결에 의해서 물건변동이 발생하려면 등기를 요한다. 정답: ②

09 부동산 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 청구권보전을 위한 가등기에 기하여 본등기가 되더라도 본등기에 의한 물건변동의 효력이 가등기한 때로 소급하지 않는다.
- ② 소유권이전청구권이 정지조건부인 경우에도 가등기는 가능하다.
- ③ 먼저 된 유효한 소유권보존등기로 인해 뒤에 된 이중보존등기가 무효인 경우, 뒤에 된 등기를 근거로 등기부취득시효를 주장할 수 있다.
- ④ 등기되어 있는 3층 건물이 멸실되자 5층 건물을 신축하였으나 종전 등기를 그대로 사용하는 경우 이 등기는 무효이다.
- ⑤ 등기명의인 표시변경등기는 권리변동을 가져오는 것은 아니다.

해설

- ③ 어느 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 소유권보존등기가 이중으로 경료된 경우 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 아니어서 뒤에 된 소유권보존등기가 무효로 되는 때에는, 뒤에 된 소유권보존등기나 이에 터 잡은 소유권이전등기를 근거로 하여서는 등기부취득시효의 완성을 주장할 수 없다(대법원 1996.10.17. 96다12511). 정답: ③

10 다음 중 이해관계인이 없는 경우에도 무효인 등기는? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 피담보채무가 변제된 후에 남아있는 저당권등기를 동일한 내용의 저당권등기로 유용한 때
② 갑, 을 그리고 을, 병간에 순차적으로 매매되었으나 등기는 갑으로부터 병으로 직접 이전된 경우
③ 갑, 을간의 가장매매를 원인으로 소유권이전등기를 한 후, 다시 갑, 을간에 적법한 매매가 있을 때
④ 등기되어 있는 건물이 소멸되어 종전 건물과 동일하게 신축한 신건물의 등기로 유용한 때
⑤ 증여받은 부동산을 매매를 원인으로 소유권이전등기를 한 경우

제2장
기본문제

해설

- ④ 판례는 표제부등기에 대하여는 무효등기의 유용을 인정하지 않으므로, 멸실된 구 건물에 대한 등기의 유용은 허용될 수 없다고 한다.
① 저당권등기의 유용은 이해관계인이 없을 때 가능하다.
② 중간생략등기가 이미 경료된 경우, 등기가 실제관계에 부합한다고 보아 유효성이 인정된다(대법원 1980.2.1. 79다2104).
③ 등기가 선행되고 이에 부합하는 물권적 합의가 있는 것은 유효한 등기가 된다.
⑤ 대법원 1980.10.14. 79다232 정답: ④

11 중복등기에 관한 판례의 태도에 관한 설명 중 타당한 것은?

- ① 하나의 부동산에 관하여 중복된 소유권보존등기에 터잡아 등기명의인을 달리하는 각 소유권이전등기가 경료된 경우에 등기의 효력은 소유권이전등기의 선후에 의한다.
② 판례는 토지에 한하여 중복등기의 문제가 발생한다고 한다.
③ 동일인 명의의 경우 후등기가 무효이나 등기명의인을 달리하는 경우에는 선등기에 원인무효사유가 없는 한 후등기가 무효이다.
④ 원칙적으로 ③의 입장이나 등기부취득시효의 경우에는 후등기를 기준으로 등기부취득시효가 가능하다는 입장이다.
⑤ 1부동산 1용지주의를 채택하고 있는 우리 법제에서 이중의 보존등기는 선등기, 후등기 모두 무효이다.

해설

- ③ 동일 부동산에 관하여 동일인 명의로 중복하여 보존등기가 이루어진 경우에는, 판례는 일관되게 실체관계를 묻지 않고 등기의 선후에 따라 후등기를 무효로 처리한다(대법원 1981.11.18. 81다 1340). 동일부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경료된 경우에는 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 되지 아니하는 한 뒤에 된 소유권보존등기는 비록 그 부동산의 매수인에 의하여 이루어진 경우에도 1부동산 1용지주의를 채택하고 있는 부동산등기법 아래에서는 무효라고 해석함이 상당하다(대법원 2011.7.14. 2010다107064).
- ① 소유권보존등기의 선후에 의한다(대법원 2001.2.15. 99다66915).
- ② 판례는 토지와 건물 모두에 중복등기의 정리 문제가 발생한다고 한다.
- ④ 민법 제245조 제2항의 등기는 부동산등기법 제15조가 규정한 1부동산 1용지주의에 위배되지 아니한 등기를 말하므로, 어느 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 소유권보존등기가 이중으로 경료된 경우 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 아니어서 뒤에 된 소유권보존등기가 무효로 되는 때에는, 뒤에 된 소유권보존등기나 이에 더 잡은 소유권이전등기를 근거로 하여서는 등기부취득시효의 완성을 주장할 수 없다(대법원[전합] 1996.10.17. 96다12511). 정답: ③

12 등기청구권에 관한 다음 기술 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 등기청구권이란 등기권리자가 등기의무자에게 등기신청에 협력할 것을 요구하는 권리이다.
- ② 물건행위의 형식주의를 취하는 법제하에서는 등기청구권은 바로 물건적인 청구권이라 할 수 있다.
- ③ 건물의 신축 등의 경우는 등기의무자가 없으므로 등기청구권은 문제되지 않는다.
- ④ 판례는 등기인수청구권을 인정하는데 이는 과세 등의 불이익을 받는 등기의무자가 등기의무의 이행을 수취할 것을 청구할 수 있는 권리이다.
- ⑤ 甲소유의 부동산을 乙이 서류를 위조하여 乙명의로 소유권이전등기를 한 경우 그 등기청구권의 법적 성격은 물건적 청구권이다.

해설

◎ 등기청구권의 법적 성질

채권적 청구권	물권적 청구권
① 매수인의 이전등기청구권 ② 설정계약에 기한 저장권설정등기청구권 ③ 점유취득시효완성에 기한 소유권이전등기청구권 ④ 부동산임차인의 임차권등기청구권 ⑤ 환매권행사에 기한 소유권이전등기청구권 ⑥ 저장부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에 전(前)소유자의 저장권말소등기청구권 ⑦ 청구권 보전을 위한 가등기에 기한 본등기청구권	① 등기와 실체관계가 불일치한 경우에 발생하는 말소등기청구권 ② 법정지상권자의 지상권설정등기청구권 ③ 법률행위의 무효·취소·해제에 기한 말소등기청구권 ④ 진정명의회복을 원인으로 하는 이전등기청구권 ⑤ 저장부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에 제3취득자의 저장권말소등기청구권 ⑥ 합의해제에 기한 말소등기청구권

정답: ②

13 등기의 추정력에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 등기가 있는 이상 일응 그 절차 및 원인은 정당한 것으로 추정을 받게 된다.
- ② 등기명의자가 건물을 신축한 것이 아니라도 등기명의자로 건물의 보존등기가 되어 있으면 등기명의자는 적법하게 소유권을 취득한 것으로 추정된다.
- ③ 근저당권설정등기가 있으면 근저당권의 존재뿐만 아니라 피담보채권의 존재도 추정된다.
- ④ 소유권이전등기가 제3자에 의해서 이루어진 경우 제3자는 前등기명의인의 적법한 대리인이었던 것으로 추정된다.
- ⑤ 소유권이전등기가 경료된 경우에는 그 前소유자에 대하여도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다.

해설

- ② 보존등기명의자가 건물을 신축한 것이 아니라면(원시취득자가 아니라면) 등기명의자는 적법하게 소유권을 취득한 것으로 추정되지는 않는다. 정답: ②

14 신축건물의 물건변동에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물의 신축자는 보존등기를 하지 않으면 건물의 소유권을 취득할 수 없다.
- ② 신축건물의 보존등기를 건물 완성 전에 하더라도 그 후 건물이 완성된 이상 그 등기를 무효라고 볼 수 없다.
- ③ 신축건물의 보존등기 명의자는 적법한 소유자로 추정될 수 없다.
- ④ 기존 건물 멸실 후 건물이 신축된 경우에 기존 건물에 대한 등기는 신축건물에 대한 등기로서의 효력을 가진다.
- ⑤ 미등기건물의 원시취득자와 그 승계취득자의 합의에 의해 직접 승계취득자 명의로 한 보존등기는 효력이 없다.

해설

- ② 타당한 기술이다.
- ① 신축건물의 소유권취득은 보존등기를 요하지 아니한다.
 - ③ 신축건물의 보존등기 명의자는 적법한 소유자로 추정된다.
 - ④ 기존 건물이 멸실되고 새로이 건물이 세워진 경우 신축된 건물과 멸실된 건물이 그 재료, 위치, 구조 기타 면에 있어서 상호 유사한 면이 있다고 하더라도 그로써 신축된 건물이 멸실된 건물과 동일한 건물이라고는 할 수 없으므로, 그 등기는 신축건물에 대한 등기로서 유효하다고 할 수 없다(대법원 2012.10.29. 자2012마1235). 무효등기의 유용은 권리관계에 관한 등기에 한하여 인정된다. 따라서 부동산의 표시, 즉 표제부의 무효등기의 유용은 인정되지 아니한다.
 - ⑤ 미등기건물을 등기할 때에는 소유권을 원시취득한 자 앞으로 소유권보존등기를 한 다음 이를 양수한 자 앞으로 이전등기를 함이 원칙이라 할 것이나, 원시취득자와 승계취득자 사이의 합치된 의사에 따라 그 건물에 관하여 승계취득자 앞으로 직접 소유권보존등기를 경료하게 되었다면, 그 소유권보존등기는 실제적 권리관계에 부합되어 적법한 등기로서의 효력을 가진다(대법원 1995.12.26. 94다44675). 정답: ②

- 15 甲은 乙 소유 토지 위에 식재된 입목등기가 되어 있지 않은 소나무 50그루에 대하여 매매 계약 체결과 동시에 소유권을 이전받기로 약정하였다. 甲은 계약체결 후 잔금을 지급하지 않은 채 乙의 동의하에 소나무 50그루에 각각 '소유자 甲'이라는 표기를 써서 붙였다. 이후 乙은 이 소나무를 丙에게 이중으로 매도하였다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙은 여전히 소나무에 대하여 소유권을 가진다.
- ② 甲은 소나무에 대하여 입목등기 없이 소유권을 취득한다.
- ③ 丙이 乙과의 계약에 의해 명인방법을 갖추면 丙이 소유권을 취득한다.
- ④ 甲은 명인방법을 통해 소나무에 대하여 저당권을 설정할 수 있다.
- ⑤ 甲은 소나무에 대하여 입목등기 없이 丙에게 대항할 수 없다.

해설

- ② 관습법상의 명인방법을 갖춘 미분리의 과실이나 수목의 집단은 소유권의 객체가 될 수 있다.

정답: ②

- 16 甲은 자기 소유 주택을 乙에게, 乙은 이를 丙에게 순차로 매도하고 등기는 甲으로부터 직접 丙에게 경료 되었다. 다음 설명 중 타당하지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산등기특별조치법상 중간생략등기 금지규정은 효력규정이므로 중간생략등기에 관한 사법상의 효력은 무효이다.
- ② 중간생략등기의 합의가 없는 경우 부동산의 최종매수인은 중간자를 대위하여서도 최초 양도인에 대하여 직접 자기 앞으로의 소유권이전등기를 구할 수 없다.
- ③ 매매로 인하여 甲 소유의 부동산이 乙과 丙에게 각각 전전 양도된 경우에, 乙이 甲에게 가지는 소유권이전등기청구권을 丙에게 양도하고 채권양도의 대항요건인 통지를 갖추었다 라도 丙은 甲에게 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기절차의 이행을 청구할 수 없다.
- ④ 이미 경료된 중간생략등기는 중간취득자의 합의가 없다는 이유로 무효로 볼 수는 없다.
- ⑤ 탈세, 탈법의 목적이 있는 중간생략등기에 대하여는 형사처벌의 대상이 된다.

해설

- ① 부동산등기특별조치법상 조세포탈과 부동산투기 등을 방지하기 위하여 위 법률 제2조 제2항 및 제8조 제1호에서 등기하지 아니하고 제3자에게 전매하는 행위를 일정 목적범위 내에서 형사처벌 하도록 되어 있으나 이로써 순차매도한 당사자 사이의 중간생략등기합의에 관한 사법상 효력까지 무효로 한다는 취지는 아니다(대법원 1993.1.26. 92다39112).

- ② 대법원 1995.8.22. 95다15575

- ④ 중간생략등기절차에 있어서 이미 중간생략등기가 이루어져 버린 경우에는 그 계약 당사자 사이에 적법한 원인행위가 성립되어 이행된 이상 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 사유로써 이를 무효라고 할 수는 없다(대법원 1979.7.10. 79다847). 정답: ①

17 다음 중 등기청구권의 법적 성질이 물건적 청구권인 경우는? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲이 乙에게 부동산을 매도하고 소유권이전등기를 하였다가 매매계약이 해제된 후 甲이 乙에게 소유권이전등기의 말소를 청구하는 경우
- ② 부동산을 매수하고 인도받은 자가 매도인에 대해 소유권이전등기를 청구하는 경우
- ③ 부동산의 점유취득시효가 완성된 후 점유자가 등기명의자에 대해 소유권이전등기를 청구하는 경우
- ④ 근저당권이 설정 후에 소유권이 제3자에게 이전된 경우, 종전소유자가 피담보채무의 소멸을 이유로 근저당권설정등기의 말소를 청구하는 경우
- ⑤ 甲 소유의 부동산에 乙 명의로 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가등기가 경료된 후, 乙이 甲에 대하여 소유권이전의 본등기를 청구하는 경우

해설

① 우리 판례는 계약해제로 인하여 등기없이도 당연히 물건이 복귀한다는 물건적 효과설의 입장에서 해제로 인한 소유권이전등기 말소청구권은 소유권에 기한 물건적 청구권이므로 소멸시효에 걸리지 않는다고 본다(대법원 1982.7.27, 80다2968).

②③④⑤는 채권적 청구권이다. 정답: ①

18 다음 사실 중 민법상 동산의 인도라고 인정되는 것은?

- ① 점유개정
- ② 상속
- ③ 공용징수
- ④ 판결에 의한 동산물권변동
- ⑤ 유실물 습득

해설

◎ 인도

현실의 인도 (제188조 제1항)	양도인이 양수인에게 점유를 현실로 이전하는 것을 말한다.
간이인도 (제188조 제2항)	양수인이 이미 점유하고 있는 경우에는 물건적 합의만으로 점유를 이전하는 것으로서 당사자의 의사표시만으로 효력이 발생한다. 예) 을이 갑 소유의 노트북을 빌려 쓰던 중, 이를 매수하였다.
점유개정 (제189조)	양도인이 동산을 양도한 후에 계속하여 점유하고자 하는 경우 당사자의 합의(계약)로 이미 인도받은 것으로 보는 경우를 말한다. 예) 갑이 자신의 노트북을 을에게 매도하였으나 1개월 동안 갑이 계속 사용하기로 하였다.
목적물반환청구권의 양도 (제190조)	제3자가 점유하고 있는 동산을 양도하는 경우 반환청구권만을 양수인에게 양도함으로써 인도에 갈음하는 경우를 말한다. 예) 갑이 자기 소유의 택시 1대를 병에게 위임하여 운행하던 중, 이를 친구 을에게 매도하고 갑은 을에게 부탁하여 병이 계속하여 운행하고 있다.

정답: ①

19 선의취득에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 선의취득에 의하여 취득되는 권리는 소유권과 질권에 한한다.
- ② 거래에 의하여 점유를 승계하는 것은 선의취득의 요건이다.
- ③ 판례에 의하면 양수인이 점유개정을 하였을 때에는 선의취득이 되지 않는다.
- ④ 양도인의 점유는 직접·간접·자주·타주점유를 불문한다.
- ⑤ 동산을 상속에 의하여 취득한 경우에는 선의취득의 적용이 있다.

해설

- ⑤ 선의취득은 거래의 안전을 보호하는 제도이므로, 거래행위에 의하여 양도인의 점유를 승계하여야 하므로, 상속에 의한 취득은 이에 해당되지 않는다.

선의취득의 요건과 효과

(1) 의 의

무권리자의 동산의 점유를 믿고 매수한 경우에 매수자가 그 물건의 소유권을 취득하는 것과 같이 동산거래의 안전을 확보하기 위하여 동산점유에 공신력을 인정하는 제도를 말한다.

(2) 요 건

- ① 목적물은 동산에 한한다.
- ② 등기·등록으로 공시되는 동산은 제외한다.
- ㉠ 화물상환증 등 증권에 의하여 표상되는 동산은 원칙적으로 적용되지 않는다.
- ㉡ 증권적 채권(지시채권 등)도 원칙적으로 적용되지 않는다.
- ㉢ 금전도 선의취득의 적용이 되지 않는 것이 원칙이나 단순한 물건으로서 거래되는 금전의 경우에는 선의취득의 적용을 받는다.
- ③ 양도인이 목적물의 점유자일 것
 - ㉠ 양도인의 점유는 직접점유·간접점유임을 불문한다.
 - ㉡ 양도인의 점유는 자주점유·타주점유임을 불문한다.
- ③ 거래행위에 의하여 점유를 승계하였을 것
 - ㉠ 유효한 거래행위에 의하여 취득하였어야 한다.
 - ㉡ 상속 등 포괄승계에 의한 취득에는 인정되지 않는다.
 - ㉢ 점유의 취득방법은 현실의 인도에 한하지 않으며, 간이인도 및 반환청구권의 양도에 의한 방법도 가능하나 점유개정에 의한 선의취득은 다수설과 판례는 부정한다.
- ④ 양도인이 무권리자일 것
 - ㉠ 양도인이 임차인이나 수차인, 점유보조자 등인 경우를 말한다.
 - ㉡ 양도인이 무권대리인인 경우에는 선의취득이 적용되지 않는다. 단, 대리권은 있지만 본인이 무권리자인 경우에는 선의취득의 적용이 될 수 있다.
- ⑤ 평온·공연·선의·무과실로 취득할 것
 - ㉠ 취득자에게는 평온·공연·선의가 추정되므로 스스로 증명책임을 부담하지 않는다.
 - ㉡ 무과실은 추정되지 않으므로 이에 대한 증명책임에 대하여 판례는 무과실에 대하여는 추정규정이 없으므로 선의취득자가 증명책임을 부담해야 한다는 입장이다.

(3) 효 과

- ① 취득자는 동산 위에 외형상 존재하는 소유권 또는 질권을 취득한다.
- ② 선의취득에 의한 물건의 취득은 원시취득이라는 것이 통설과 판례의 견해이다.
- ③ 선의취득자는 원권리자에 대하여 부당이득반환의무를 부담하지 않는다. 정답: ⑤

20

다음은 선의취득에 대한 설명이다. 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 동산이라도 점유가 아닌 등기·등록으로써 공시되는 것은 선의취득의 대상이 아니다.
- ② 양도가 금지되는 문화재 등도 선의취득의 대상이 된다.
- ③ 양도인은 무권리자이어야 한다.
- ④ 양수인은 거래행위에 의하여 권리를 승계취득한 자이어야 한다.
- ⑤ 선의취득의 경우에 그 동산이 도품이나 유실물인 때에는 피해자 또는 유실자는 도난 또는 유실한 날로부터 2년 내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다.

해설

- ② 양도가 금지되는 문화재 등은 선의취득의 대상이 될 수 없다.
- ① 동산이라도 그 공시방법이 인도나 점유의 방법이 아닌 등기나 등록으로 공시되는 것(예) 자동차, 선박, 항공기 등)은 선의취득의 대상이 될 수 없다.
- ③④ 제249조(선의취득)
평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실 없이 그 동산을 점유한 경우에는 양도인이 정당한 소유자가 아닌 때에도 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다.
- ⑤ 제250조 정답: ②

제2장
기본문제

21

선의취득에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 평온·공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실 없이 그 동산을 점유한 경우에는 양도인이 정당한 권리자가 아닌 때에도 그 동산에 대한 권리를 취득한다.
- ② 선의취득에 의하여 취득되는 권리는 소유권과 질권에 한한다.
- ③ 등기나 등록에 의해 공시되는 동산도 선의취득의 객체가 된다.
- ④ 선의취득에 의한 권리의 취득은 원시취득이다.
- ⑤ 점유개정에 의하여 점유를 취득한 경우에는 선의취득이 인정되지 않는다.

해설

- ③ 등기나 등록에 의해 공시되는 동산은 선의취득의 객체가 될 수 없다. 정답: ③

24 혼동에 관한 기술 중에서 가장 타당한 것은?

- ① 채무자 갑 소유의 토지위에 을이 1번 저당권, 병이 2번 저당권을 가지고 있는 경우에 을이 갑 소유의 토지를 양도받으면 을의 저당권은 소멸한다.
- ② 갑 토지에 병이 저당권을 취득한 후, 그 갑 토지에 을이 지상권을 취득하였을 때 을이 그 토지의 소유권을 취득하면 을의 지상권은 소멸한다.
- ③ 소유자가 광업권을 취득한 경우에 광업권은 혼동으로 소멸한다.
- ④ 점유권도 예외적인 경우에는 혼동으로 소멸한다.
- ⑤ 혼동은 소유권과 제한물권이 혼동한 경우에 한하여 소멸한다.

해설

◎ 혼동의 모습

소유권과 제한물권의 혼동	(원칙) 소멸 예) 건물의 전세권자가 그 건물의 소유권을 취득할 경우 전세권은 소멸한다. (예외) 존속 ▪ 제한물권이 제3자의 권리의 목적으로 된 경우 예) 전세권이 저당권의 목적이 된 경우, 전세권자가 소유권을 취득하여도 전세권은 존속한다. ▪ 제3자에게 부당한 이익이나 손해를 주게 되는 경우 예) 하나의 토지에 둘 이상의 저당권이 설정된 경우에 선순위저당권자가 토지의 소유권을 취득하여도 순위승진을 막기 위하여 그 선순위저당권은 존속한다. ▪ 점유권은 성질상 혼동에 걸리지 않는다. ▪ 광업권은 토지소유권과는 독립되는 물권으로서 혼동에 걸리지 않는다.
제한물권과 제한물권의 혼동	(원칙) 소멸 예) 지상권 위에 저당권을 가지는 자가 그 지상권을 취득한 경우에는 저당권은 소멸한다. (예외) 혼동으로 소멸할 수 있는 제한물권이 권리의 목적으로 되어 있을 때에는 소멸하지 아니하고 존속한다.

정답: ②

25 물권의 소멸에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소유권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ② 지역권은 20년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성한다.
- ③ 피담보채권이 존속하는 한 저당권은 단독으로 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ④ 유치권과 점유권은 소멸시효대상이 될 수 없다.
- ⑤ 토지소유권과 광업권이 동일인에게 귀속하게 되면 광업권은 혼동으로 소멸한다.

해설

- ⑤ 광업권에 대해서는 혼동의 법리가 적용되지 않는다.
- ① 소유권은 항구성이 있으므로 소멸시효대상이 아니다.
- ③ 저당권은 채권에 부종하므로 채권과 독립하여 단독으로 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ④ 유치권과 점유권은 점유를 상실하면 즉시 소멸하는 것이므로 소멸시효대상이 아니다. 정답: ⑤

26 법률행위에 의하지 않은 물건변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정저당권은 저당권설정등기 없이 성립한다.
- ② 부동산소유권을 확인하는 판결에 의해서도 등기 없이 그 부동산의 소유권을 취득한다.
- ③ 공경매에 있어서 부동산 물건변동의 시기는 매각허가결정이 확정된 후 매수인이 매각대금을 완납한 때이다.
- ④ 자기의 비용과 노력으로 건물을 신축한 건축주는 건물의 소유권을 등기 없이 취득한다.
- ⑤ 상속에 의한 물건변동은 피상속인의 사망 시에 발생한다.

해설

- ② 등기를 요하지 아니하는 물건변동으로서의 판결이란, 형성판결만을 의미하며 이행판결이나 확인판결은 이에 해당하지 아니한다. 형성판결에는 공유물분할판결, 사해행위취소판결, 상속재산분할판결 등이 있다. 정답: ②

27 부동산등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 멸실된 건물의 보존등기를 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 것은 허용되지 않는다.
- ② 소유자로부터 토지를 적법하게 매수한 매수인의 소유권이전등기가 위조된 서류에 의하여 경료되었더라도 그 등기는 유효하다.
- ③ 가등기된 권리의 이전등기는 가등기에 대한 부기등기의 형식으로는 경료할 수 없다.
- ④ 명의자를 달리하는 중복보존등기가 부동산을 표상함에 부족함이 없는 경우, 선행등기가 원 인무효가 아닌 한 후행등기는 실제적 권리관계에 부합하더라도 무효이다.
- ⑤ 지분이전등기가 경료된 경우 그 등기는 적법하게 된 것으로서 진실한 권리상태를 공시하는 것이라고 추정된다.

해설

- ③ 가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물건변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로, 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다(대법원 1998.11.19. 98다24105 전원합의체). 정답: ③

01 부동산 물권변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲이 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기소송에서 승소의 확정판결을 얻었더라도 이전등기 전에는 소유권을 취득하지 못한다.
- ② 재단법인의 설립을 위해 부동산을 출연한 경우, 출연자와 재단법인 사이에서도 그 부동산은 소유권 이전등기 없이도 재단법인의 소유가 되지 않는다.
- ③ 甲이 건물을 신축한 후 乙에게 양도하고 乙 명의로 보존등기를 한 경우 乙은 건물의 소유권을 취득한다.
- ④ 공용징수에 의한 부동산 소유권의 취득에는 등기를 요하지 않는다.
- ⑤ 甲이 乙에게 부동산을 매도하고 소유권이전등기를 한 후 계약을 해제하였으나 그 말소등기 전에 乙이 선의의 丙에게 매도하고 이전등기한 경우, 甲은 丙에게 등기의 말소를 청구할 수 없다.

해설

- ② 출연자와 재단법인 사이에 있어서는 법인의 성립 외에 출연재산의 소유권이전등기를 필요로 하는 것이 아니나, 제3자에 대한 관계에 있어서는 출연행위가 법률행위이므로 출연재산의 법인에 귀속에는 부동산의 권리에 관해서는 법인성립 외에 등기를 필요로 한다(대법원 1993.09.14. 93다 8054). 정답: ②

02 등기에 대한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 계약이 해제되면 그 계약의 이행으로 변동이 생겼던 물권은 말소등기 없이도 당연히 그 계약이 없었던 원상태로 복귀한다.
- ② 등기는 물권의 효력존속요건이고 효력발생요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에는 물권은 소멸한다.
- ③ 이중으로 경료된 사항란의 소유권보존등기의 경우 등기명의인이 동일인인 경우 먼저 한 등기가 유효하고, 뒤에 한 등기는 효력이 없다.
- ④ 원시취득자와 승계취득자 사이의 합치된 의사에 따라 승계취득자 앞으로 직접 소유권보존등기를 경료하게 되었다면, 그 소유권보존등기는 실제적 권리관계에 부합되어 적절한 등기로서의 효력을 가진다.
- ⑤ 피상속인의 사망으로 부동산물권을 상속한 자가 자기 앞으로 상속에 의한 이전등기를 하지 아니한 채 매수인에게 매도하고, 등기는 피상속인으로부터 직접 매수인에게 이전등기가 된 경우에도 그 등기는 유효하다.

해설

- ② 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에도 그 물권이 곧 소멸하는 것은 아니며, 말소된 등기의 명의인은 여전히 적절한 권리자로 추정된다(대법원 1982.9.14., 81다카923). 정답: ②

03 물건변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 수공업자가 타인의 동산에 가공을 한 경우 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 경우, 가공물은 그 수공업자의 소유로 한다.
- ② 부동산등기법상 무효인 이중등기를 근거로 해서도 등기부취득시효가 완성될 수 있다.
- ③ 인도는 법률행위로 인한 부동산 소유권취득을 위한 요건이 아니다.
- ④ 타인의 임야에 권원 없이 심은 임목의 소유권은 임야소유자에게 속한다.
- ⑤ 경매 대상 토지에 채무자 아닌 자의 소유인 동산이 설치되어 있는 경우, 경매의 매수인은 그 동산을 선의취득할 수 있다.

해설

- ② 어느 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 소유권보존등기가 2중으로 경료된 경우 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 아니어서 뒤에 된 소유권보존등기가 무효로 되는 때에는, 뒤에 된 소유권보존등기나 소유권이전등기를 근거로 등기부취득시효의 완성을 주장할 수는 없다(대법원 1996.10.17. 96다12511 전원합의체). 정답: ②

04 원칙적으로 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 하는 것은?

- ① 저당권말소등기
- ② 판결에 의한 등기
- ③ 부동산표시의 변경등기
- ④ 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기
- ⑤ 대법원규칙으로 정하는 포괄승계에 따른 등기

해설

- ②③④⑤ 등기의 진정성이 보장되거나 등기의무자의 부존재의 이유로 등기권리자의 단독신청이 가능한 경우이다.
① 저당권말소등기는 당사자 공동신청에 의한다. 정답: ①

05 甲이 등기를 하여야 비로소 소유권을 취득하는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲이 수용재결을 통해 토지를 취득한 경우
- ② 甲 소유의 건물에 임차인이 창고를 지어 부합된 경우
- ③ 저당권 실행을 위한 경매에서 매수인 甲이 매각대금을 완납한 경우
- ④ 乙이 건물을 신축한 후 사망하여 甲이 상속한 경우
- ⑤ 甲이 부동산을 20년간 평온·공연하게 소유의 의사로 점유하여 점유취득시효를 완성한 경우

해설

- ⑤ 취득시효로 인한 물건변동은 법률의 규정에 의한 물건변동이지만 반드시 등기를 요한다(제245조). 정답: ⑤

06

등기를 마치지 않더라도 물건변동의 효력이 발생하는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 지상권설정계약에 따른 지상권의 취득
- ② 피담보채권의 시효소멸에 따른 저당권의 소멸
- ③ 공익사업에 필요한 토지에 관하여 토지소유자와 관계인 사이의 협의에 의한 토지소유권의 취득
- ④ 공유토지의 현물분할에 관한 조정조서의 작성에 따른 공유관계의 소멸
- ⑤ 당사자 사이의 법률행위를 원인으로 한 소유권이전등기절차 이행의 소에서의 승소판결에 따른 소유권의 취득

해설

- ② 피담보채권의 소멸에 따른 저당권의 소멸은 말소등기를 요하지 아니한다. 정답: ②

07

등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 경정등기는 원시적으로 진실한 권리관계와 등기가 일부 어긋나는 경우 이를 바로잡는 등기이다.
- ② 소유자만이 진정명의회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구의 상대방은 현재의 등기명의인이다.
- ④ 증여로 부동산을 취득하였으나 등기원인을 매매로 기재하였다면 그 등기는 무효등기이다.
- ⑤ 그 이유가 무엇이든 당사자가 자발적으로 말소등기한 경우 말소회복등기를 할 수 없다.

해설

- ④ 증여를 하면서 증여세를 탈세하기 위하여 매매로 가장하여 소유권이전등기를 하는 것과 같이 허위표시(가장행위) 뒤에 감추어진 행위를 은닉행위라 한다. 은닉행위라는 것만으로 당연히 무효라고 할 수 없다. 정답: ④

08

가등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 할 수 있다.
- ② 저당권설정등기청구권을 보전하기 위한 가등기는 인정되지 않는다.
- ③ 가등기에 기한 본등기가 경료되더라도 본등기에 의한 물건변동의 효력이 가등기 한 때로 소급하여 발생하는 것은 아니다.
- ④ 가등기가 부적법하게 말소된 후 소유권이전등기를 마친 제3자는 가등기의 회복등기절차에서 승낙의무가 있다.
- ⑤ 가등기에 기한 본등기청구권과 소유권이전등기청구권은 그 등기원인이 동일하더라도 서로 다른 청구권으로 보아야 한다.

해설

- ② 가등기는 권리에 관한 등기로써 소유권에 관한 가등기 외에도 소유권이외의 권리에 관한 가등기도 인정된다.
- ① 가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물건변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로, 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다(대법원 1998.11.19. 98다24105 전원합의체).
- ③ 가등기는 그 성질상 본등기의 순위보전의 효력만이 있어 후일 본등기가 경료된 때에는 본등기의 순위가 가등기할 때로 소급하는 것 뿐이지 본등기에 의한 물건변동의 효력이 가등기할 때로 소급하여 발생하는 것은 아니다(대법원 1992.09.25. 92다21258).
- ④ 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인없이 말소된 경우에 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다(대법원 2001.01.16. 98다20110). 따라서 가등기가 부적법하게 말소된 후 소유권이전등기를 마친 제3자는 가등기의 회복등기절차에서 승낙 의무가 있다. 정답: ②

09 미등기 부동산에 관한 법률관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소유자 甲으로부터 미등기 건물을 매수한 乙이 소유권이전등기를 마치지 않은 상태에서 이를 다시 丙에게 전매하여 인도한 경우 甲은 丙에게 소유물 반환을 청구할 수 없다.
- ② 미등기 무허가건물을 매수하였으나 소유권이전등기를 마치지 않은 매수인은 그 건물의 불법점유자에 대하여 소유물반환을 청구할 수 없다.
- ③ 미등기 건물에 대한 양도담보계약상의 채권자의 지위를 승계하여 건물을 관리하고 있는 자는 건물에 대한 철거처분권을 갖지 못한다.
- ④ 미등기건물을 그 대지와 함께 매수한 사람이 그 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받아 저당권을 설정한 후 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우 그 건물을 위한 법정지상권이 성립한다.
- ⑤ 미등기 부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 경우 매도인의 상속인이 행사하는 반환 청구에 대하여 반환을 거절할 수 있다.

해설

- ④ 민법 제366조의 법정지상권은 저당권설정 당시에 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물이 저당권의 실행에 의한 경매로 인하여 각기 다른 사람의 소유에 속하게 된 경우에 건물의 소유를 위하여 인정되는 것이므로, 미등기건물을 그 대지와 함께 매수한 사람이 그 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 건물에 대하여는 그 등기를 이전받지 못하고 있다가, 대지에 대하여 저당권을 설정하고 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우에는, 그 저당권의 설정 당시에 이미 대지와 건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하고 있었으므로 법정지상권이 성립될 여지가 없다(대법원 2002.06.20. 2002다9660 전원합의체). 정답: ④

10 청구권 보전의 가등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 본등기의 순위는 가등기의 순위에 따라나 물건변동의 시기가 가등기를 경료한 때로 소급하지 않는다.
- ② 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가등기가 있다 하여 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률 관계가 있다고 추정되지 않는다.
- ③ 소유권이전등기청구권의 보전을 위한 가등기에 기한 본등기가 경료되면 그 사이에 행해진 중간처분의 등기는 가등기에 의하여 순위가 보전된 권리와 양립할 수 없는 범위 내에서 무효로 된다.
- ④ 매수인 명의의 가등기가 이루어진 후에 매도인이 제3자 앞으로 소유권이전등기를 경료해 준 경우 매수인은 매도인을 상대로 본등기를 청구하여야 한다.
- ⑤ 부동산 강제경매절차에서 부동산이 매각된 경우 특단의 사정이 없으면 소유권이전등기청구 권의 보전을 위한 가등기는 말소된다.

해설

- ⑤ 부동산 강제경매절차에서 부동산이 매각된 경우라도 소유권이전등기청구권의 보전을 위한 가등기는 말소되지 않는다. 정답: ⑤

제2장
실전문제

11부동산등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 가등기된 권리의 이전등기는 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 할 수 있다.
- ② 근저당권등기가 원인 없이 말소된 경우, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 등기의 등기명의인은 적법한 권리자로 추정된다.
- ③ 청구권보전을 위한 가등기에 기하여 본등기가 경료되면 본등기에 의한 물건변동의 효력은 가등기한 때로 소급하여 발생한다.
- ④ 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명되었다면 그 등기의 적법추정은 복멸된다.
- ⑤ 동일 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경료된 경우, 선행 보존등기가 원인무효가 아닌 한 후행보존등기는 실체관계에 부합하더라도 무효이다.

해설

- ③ 가등기는 본등기의 순위보전의 효력만이 있고 후일 본등기가 경료된 때에는 본등기의 순위가 가 등기한 때로 소급하고, 본등기에 의한 물건변동의 효력이 가등기한 때로 소급하여 발생하는 것은 아니다(대법원 1992.9.25. 92다21258). 정답: ③

해설

- ① 신축된 건물의 소유권은 이를 건축한 사람이 원시취득하는 것이므로, 건물 소유권보존등기의 명의자가 이를 신축한 것이 아니라면 그 등기의 권리 추정력은 깨어지고, 등기 명의자가 스스로 적법하게 그 소유권을 취득한 사실을 입증하여야 한다(대법원 1996.7.30. 95다30734). 정답: ①

14 등기의 유효요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 중복된 소유권보존등기의 등기명의인이 동일인이 아닌 경우, 선등기가 원인무효가 아닌 한 후등기는 무효이다.
② 무효등기의 유용에 관한 추인은 언제나 명시적으로 이루어져야 한다.
③ 무효인 중복등기에 더 잡은 등기부시효취득은 인정되지 않는다.
④ 중간생략등기의 사법상 효력이 모든 경우에 부정되는 것은 아니다.
⑤ 소유권에 관한 등기가 적법한 원인 없이 말소되더라도 원칙적으로 그 소유권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

해설

- ② 무효등기의 유용에 관한 합의 내지 추인은 묵시적으로도 이루어질 수 있으나, 위와 같은 묵시적 합의 내지 추인을 인정하려면 무효등기 사실을 알면서 장기간 이의를 제기하지 아니하고 방치한 것만으로는 부족하고 그 등기가 무효임을 알면서도 유효함을 전제로 기대되는 행위를 하거나 용태를 보이는 등 무효등기를 유용할 의사에서 비롯되어 장기간 방치된 것이라고 볼 수 있는 특별한 사정이 있어야 한다(대법원 2007.01.11. 2006다50055). 정답: ②

15 이중보존등기에 관한 설명으로 판례의 태도와 다른 것은?

- ① 소유권보존등기 명의인이 동일인인 경우에는 그 실체관계의 부합여부를 가릴 것 없이 먼저 행하여진 등기가 유효하다.
② 소유권보존등기 명의인이 동일인이 아닌 경우에는 비록 나중에 이루어진 보존등기라 할지라도 그것이 실체관계에 부합하면 유효하다.
③ 두 개의 이중보존등기가 그 부동산의 표시에 있어서 차이가 나는 경우에는 실제상황에 합치하는 보존등기가 효력을 가진다.
④ 후등기가 무효로 되면 이에 기초하여 경료된 다른 등기, 예컨대 근저당권설정등기도 무효이므로 이에 기인하여 경락을 받았다 하더라도 소유권을 취득하지 못한다.
⑤ 표시란의 이중등기에 있어서, 먼저 된 등기가 실제와의 현격한 차이가 있는 경우에는 그 후 실체관계와 부합하도록 경정등기를 하였다 하더라도 그 경정등기는 무효이다.

해설

- ② 종래에는 등기의 선후만을 따져서 결정할 것이 아니라 실체관계를 살펴서 진정한 소유자에 바탕을 둔 보존등기가 유효하다는 태도를 취하였으나(대법원[전합] 1978.12.26. 77다2427), 최근에 그 태도를 변경하였다. 즉, 동일 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경료된 경우에는 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 되지 아니하는 한, 뒤에 된 소유권보

존등기는 비록 그 부동산의 매수인에 의하여 이루어진 경우에도 1부동산 1용지주의를 채택하고 있는 부동산등기법 아래에서는 무효라고 해석함이 상당하다고 한다(대법원[전합] 1990.11.27. 87다카 2961 등).

- ① 대법원 1981.10.24. 80다1473
- ③ 대법원 1968.11.19. 66다1473
- ④ 후등기가 무효이므로 물권변동이 생기지 않는다. 따라서 이에 기초한 근저당권의 설정은 무효이므로 이에 터 잡아 임의경매경락허가결정을 원인으로 경료된 소유권이전등기도 무효이다(대법원 1974.11.26. 74다1230).
- ⑤ 표시란의 이중등기에 있어서는 등기의 선후에 관계없이 부동산의 실제상황과 일치하는 보존등기만이 유효하다(대법원 1989. 1.31. 87다카2358). 정답: ②

16 물권적 청구권이 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산매수인의 소유권이전등기청구권
- ② 진정한 등기명의의 회복을 위한 소유권이전등기청구권
- ③ 지상권에 기한 방해예방청구권
- ④ 피담보채무 변제 후의 소유권에 기한 저장권 말소등기청구권
- ⑤ 저장권에 기한 방해배제청구권

해설

◎ 등기청구권의 법적 성질

채권적 청구권	물권적 청구권
① 매수인의 이전등기청구권 ② 설정계약에 기한 저장권설정등기청구권 ③ 점유취득시효완성에 기한 소유권이전등기청구권 ④ 부동산임차인의 임차권등기청구권 ⑤ 환매권행사에 기한 소유권이전등기청구권 ⑥ 저장부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에 전(前)소유자의 저장권 말소등기청구권 ⑦ 청구권 보전을 위한 가등기에 기한 본등기청구권	① 등기와 실체관계가 불일치한 경우에 발생하는 말소등기청구권 ② 법정지상권자의 지상권설정등기청구권 ③ 법률행위의 무효·취소·해제에 기한 말소등기청구권 ④ 진정한명의회복을 원인으로 하는 이전등기청구권 ⑤ 저장부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에 제3취득자의 저장권말소등기청구권 ⑥ 합의해제에 기한 말소등기청구권

- ① 부동산매수인의 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이다. 정답: ①

17 등기의 효력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있어도 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다.
- ② 허무인(虛無人)으로부터 이어받은 소유권이전등기의 경우에도 그 등기명의자의 소유권은 추정된다.
- ③ 신축된 건물의 소유권보존등기 명의자는 실제로 그 건물을 신축한 자가 아니더라도 적법한 권리자로 추정된다.
- ④ 등기가 원인 없이 말소된 경우, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라면 말소된 등기의 등기명의인은 적법한 권리자로 추정되지 않는다.
- ⑤ 소유권이전등기 명의자는 그 전(前) 소유자에 대하여 적법한 등기원인에 의해 소유권을 취득한 것으로 추정되지 않는다.

해설

- ① 가등기에는 추정력도 인정되지 않는다. 예컨대 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있다고 하여 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다(대법원 1979.5.22. 79다239).
- ② 허무인(虛無人)으로부터 등기를 이어받은 소유권이전등기는 원인무효라 할 것이어서 그 등기명의자에 대한 소유권추정은 인정되지 않는다(대법원 1985.11.12. 84다카2494).
- ③ 소유권 보존등기의 본질에 비추어 보존등기 명의인이 원시취득자가 아니라는 점이 증명되면 그 보존등기의 추정력은 깨어진다(대법원 1996.6.28. 96다16247).
- ④ 등기는 물권의 효력 발생 요건이고 존속 요건은 아니어서 등기가 원인 없이 말소된 경우에는 그 물권의 효력에 아무런 영향이 없고, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 등기의 등기명의인은 적법한 권리자로 추정되므로 원인 없이 말소된 등기의 효력을 다투는 쪽에서 그 무효 사유를 주장·입증하여야 한다(대법원 1997.9.30. 95다39526).
- ⑤ 부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐만 아니라, 그 전 소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다(대법원 2000.3.10. 99다65462). 정답: ①

18 부동산 소유권 이전등기의 추정력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 등기명의자는 그 전 소유자에 대하여는 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것이라는 등기의 추정력을 주장할 수 없다.
- ② 등기명의자가 등기부와 다른 등기원인을 주장하였으나 그 주장 사실이 인정되지 않은 것만으로는 등기의 추정력이 깨어지는 것은 아니다.
- ③ 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명된 경우, 그 등기의 적법 추정은 깨어진다.
- ④ 등기원인 사실에 대한 입증이 부족하다는 이유로 그 등기를 무효라고 단정할 수 없다.
- ⑤ 증여를 원인으로 미성년자에게서 친권자 앞으로 소유권이전등기가 경료된 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 이전등기에 관하여 필요한 절차를 적법하게 거친 것으로 추정된다.

해설

- ① 부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐만 아니라, 그 전 소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다(대법원 2000.3.10. 99다65462). 정답: ①

19 등기의 추정력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소유권에 관한 등기에는 권리의 추정력이 있으므로 이를 다투는 측에서 그 무효사유를 주장·증명하여야 한다.
- ② 등기절차가 적법하게 진행되지 아니한 것으로 볼 만한 의심스러운 사정이 증명된 경우에는 등기의 추정력이 깨어진다.
- ③ 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기가 경료된 경우 등기 기재와 같이 매매에 의하여 등기명의인이 소유권을 취득한 것으로 추정된다.
- ④ 권리취득의 원인을 등기부에 기재된 취득원인과 달리 주장하는 경우 그 주장만으로는 등기의 추정력이 깨어지지 않는다.
- ⑤ 부동산의 등기명의자는 자신의 소유권이전등기가 유래한 전 소유자에 대하여 등기의 추정력을 주장할 수 없다.

해설

- ⑤ 부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐만 아니라, 그 전 소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다(대법원 2000.3.10. 99다65462). 정답: ⑤

20 부동산등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 전부 멸실한 건물의 보존등기를 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 것은 허용된다.
- ② 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소되었더라도 특별한 사정이 없는 한 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
- ③ 소유권이전청구권 보전의 가등기가 있더라도 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다.
- ④ 가등기권리자가 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 한 경우에는 등기공무원은 그 가등기 후에 한 제3자 명의의 소유권이전등기를 직권으로 말소하여야 한다.
- ⑤ 소유권이전등기가 마쳐지면 그 등기명의자는 제3자는 물론이고 전소유자에 대해서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다.

해설

- ① 기존 건물이 멸실되고 새로이 건물이 세워진 경우 신축된 건물과 멸실된 건물이 그 재료, 위치, 구조 기타 면에 있어서 상호 유사한 면이 있다고 하더라도 그로써 신축된 건물이 멸실된 건물과 동일한 건물이라고는 할 수 없으므로, 그 등기는 신축건물에 대한 등기로서 유효하다고 할 수 없다(대법원 2012.10.29. 자2012마1235). 정답: ①

甲은 乙 소유의 부동산을 취득하고자 하나 세금문제 등을 이유로 그 부동산 소유권등기를 丙의 명의로 해 두고자 한다. 이에 따른 아래의 <법률관계 Ⅰ> <법률관계 Ⅱ>에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (현재시점을 기준으로 판단하며, 다툼이 있는 경우 판례에 의함)

<법률관계 Ⅰ>

甲이 乙과 매매계약을 체결한 후 乙의 양해를 얻어 그 명의만을 丙으로 해두고 있는 경우

<법률관계 Ⅱ>

甲이 丙에게 매수자금을 지급하여 丙이 乙과 직접 매매계약을 체결하도록 하여 이전등기 역시 丙 명의로 경료해 둔 경우

- ① 乙은 여전히 부동산에 대한 소유권을 갖고 있다.
- ② 甲은 乙에 대해 소유권이전등기청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 丙이 甲 명의로 이전등기를 경료해준 경우 甲 명의의 등기는 유효하다.
- ④ 乙이 악의인 경우 丙은 소유권을 취득할 수 없지만 만약 丙이 명의신탁사실을 알고 있는 제3자 丁에게 부동산을 처분하여 이전등기를 경료해 주었다면 乙은 丁에게 그 등기의 말소를 청구할 수는 없다.
- ⑤ 乙이 선의인 경우 甲은 丙에 대해 취득한 소유권을 부당이득으로 반환청구할 수 있다.

해설

<법률관계 Ⅰ>은 3자간 명의신탁(중간생략등기형 명의신탁)이다.

- ①③ 명의신탁약정과 명의수탁자의 등기는 부동산실명법상 무효이므로 매도인 乙은 여전히 부동산에 대한 소유권을 가지고 있다.
- ② 甲과 乙의 매매계약은 유효이기 때문에 甲은 乙에 대해 소유권이전등기청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 실제관계와 부합하는 매수인의 등기로 유효하다.

<법률관계 Ⅱ>는 계약명의신탁을 제시한 것이다.

- ④ 제3자 丁은 선의·악의 불문하고 소유권을 취득한다.
- ⑤ 매도인 乙이 선의인 경우 乙과 丙간의 매매계약은 유효하며, 그 결과 명의수탁자 丙명의로 등기도 유효하다. 다만 명의신탁자 甲은 수탁자 丙에 대해 매수자금을 부당이득으로 반환청구할 수 있다(대법원 2005.1.28. 2002다66922). 정답: ⑤

22

중간생략등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲이 신축한 건물을 乙이 매수한 후, 당사자들의 합의에 따라 경료된 乙명의로의 보존등기는 유효하다.
- ② 토지거래허가구역 내 토지가 甲에서 乙, 乙에서 丙으로 매도되고 중간생략등기의 합의가 있더라도, 丙이 자신과 甲을 매매 당사자로 하는 토지거래허가를 받아 丙 앞으로 경료된 소유권이전등기는 무효이다.
- ③ 매도인 甲, 중간매수인 乙, 최후매수인 丙 사이에 중간생략등기에 대한 전원의 합의가 없는 경우, 丙은 甲에 대하여 직접 자기에게 이전등기를 청구할 수 없다.
- ④ 매도인 甲, 중간매수인 乙, 최후매수인 丙이 甲으로부터 丙으로 이전등기를 해주기로 전원 합의한 경우, 乙이 대금을 지급하지 않더라도 甲은 丙에게 소유권이전등기를 해주어야 한다.
- ⑤ 매도인 甲, 중간매수인 乙, 최후매수인 丙이 甲으로부터 丙으로 이전등기를 해주기로 전원 합의한 경우에도 乙은 甲에 대한 등기청구권을 잃지 않는다.

해설

- ④ 중간생략등기의 합의란 부동산이 전전 매도된 경우 각 매매계약이 유효하게 성립함을 전제로 그 이행의 편의상 최초의 매도인으로부터 최종의 매수인 앞으로 소유권이전등기를 경료하기로 한다는 당사자 사이의 합의에 불과할 뿐이므로, 이러한 합의가 있다고 하여 최초의 매도인이 매매계약상의 매수인인 중간자에 대하여 갖고 있는 매매대금청구권의 행사가 제한되는 것은 아니다(대법원 2005.04.29. 2003다66431). 따라서 중간생략등기의 합의가 있는 후 최초매도인과 중간자 사이에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 최초매도인은 최종매수인에 대한 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 있다. 정답: ④

23

X 부동산을 甲으로부터 매수한 乙은 이전등기를 경료하지 않은 채 丙에게 그 부동산을 매도하였고 현재 丙은 이를 점유하여 사용·수익하고 있다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 3자간 중간생략등기의 합의가 있더라도 甲과 丙 사이에 토지거래허가를 받아 甲에서 丙 앞으로 직접 경료된 소유권이전등기는 무효이다.
- ② 甲과 丙 사이에 물권적 합의가 없더라도 중간생략등기에 관한 3자 합의가 있다면, 丙은 甲에 대하여 직접 자신의 명의로 이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 중간생략등기의 합의가 있는 후 甲과 乙 사이에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 甲은 丙에 대한 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 없다.
- ④ 이미 甲에서 丙으로 소유권이전등기가 경료된 경우, 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 이유만으로는 중간생략등기가 무효라고 할 수 없다.
- ⑤ 乙의 甲에 대한 이전등기청구권은 중간생략등기의 합의가 있는 경우에도 소멸되지 않는다.

해설

- ③ 중간생략등기의 합의가 있는 후 최초매도인과 중간자 사이에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 최초매도인은 최종매수인에 대한 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 있다(대법원 2005.04.29. 2003다66431). 정답: ③

24

중간생략등기에 관한 다음 설명 가운데 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 중간생략등기의 합의가 있다 하더라도 중간매수인의 첫 매도인에 대한 소유권이전등기청구권은 소멸되지 않는다.
- ② 최종매수인은 최초매도인에 대해 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기절차의 이행을 청구할 수 있다.
- ③ 부동산등기특별조치법에 의해 중간생략등기의 사법상 효력까지 부정되지는 않는다.
- ④ 미등기부동산의 양수인에 의한 보존등기는 일종의 중간생략등기이지만 유효하다.
- ⑤ 토지거래허가구역 내의 토지에 대한 중간생략등기는 최초 매도인과 최종매수인을 당사자로 하는 토지거래허가를 받아 이루어지더라도 무효이다.

해설

- ② 부동산이 전전 양도된 경우에 중간생략등기의 합의가 없는 한 그 최종 양수인은 최초 양도인에 대하여 직접 자기명의로의 소유권이전등기를 청구할 수 없고, 부동산의 양도계약이 순차 이루어져 최종 양수인이 중간생략등기의 합의를 이유로 최초 양도인에게 직접 그 소유권이전등기 청구권을 행사하기 위해서는 관계 당사자 전원의 의사합치, 즉 중간생략등기에 대한 최초 양도인과 중간자의 동의가 있는 외에 최초 양도인과 최종 양수인 사이에도 그 중간등기 생략의 합의가 있었음이 요구되므로, 비록 최종 양수인이 중간자로부터 소유권이전등기 청구권을 양도받았다고 하더라도 최초 양도인이 그 양도에 대하여 동의하지 않고 있다면 최종 양수인은 최초 양도인에 대하여 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기 절차 이행을 청구할 수 없다(대법원 1995.8.22. 95다15575).

- ① 대법원 1991.12.13. 91다18316
- ③ 대법원 1993.1.26. 92다39112
- ④ 대법원 1995.12.26. 94다44675
- ⑤ 대법원 1997.11.11. 97다33218 정답: ②

25

X토지는 甲→乙→丙으로 순차 매도되고, 3자간에 중간생략등기의 합의를 하였다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 공인중개사]

- ① 丙은 甲에게 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ② 乙의 甲에 대한 소유권이전등기청구권은 소멸하지 않는다.
- ③ 甲의 乙에 대한 매매대금채권의 행사는 제한받지 않는다.
- ④ 만약 X토지가 토지거래허가구역에 소재한다면, 丙은 직접 甲에게 허가신청절차의 협력을 구할 수 없다.
- ⑤ 만약 중간생략등기의 합의가 없다면, 丙은 甲의 동의나 승낙 없이 乙의 소유권이전등기 청구권을 양도받아 甲에게 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 최종 양수인이 중간자로부터 소유권이전등기 청구권을 양도받았다고 하더라도 최초 양도인이 그 양도에 대하여 동의하지 않고 있다면 최종 양수인은 최초 양도인에 대하여 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기 절차 이행을 청구할 수 없다(대법원 1995.8.22. 95다15575). 정답: ⑤

26

甲은 토지거래허가구역 내에 있는 그 소유의 X토지에 대하여 토지거래허가를 받을 것을 전제로 乙과 매매계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 甲이 허가신청절차에 협력하지 않으면 乙은 甲에 대하여 협력의무의 이행을 소구할 수 있다.
- ② 甲이 허가신청절차에 협력할 의무를 이행하지 않더라도 특별한 사정이 없는 한 乙은 이를 이유로 계약을 해제할 수 없다.
- ③ 甲과 乙이 허가신청절차 협력의무의 이행거절의사를 명백히 표시한 경우, 매매계약은 확정적으로 무효가 된다.
- ④ 매매계약이 乙의 사기에 의해 체결된 경우, 甲은 토지거래허가를 신청하기 전에 사기를 이유로 계약을 취소함으로써 허가신청절차의 협력의무를 면할 수 있다.
- ⑤ X토지가 중간생략등기의 합의에 따라 乙로부터 丙에게 허가 없이 전매된 경우, 丙은 甲에 대하여 직접 허가신청절차의 협력의무 이행청구권을 가진다.

해설

- ⑤ 토지거래허가구역 내에서 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였더라도 그러한 최종 매수인 명의의 소유권이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다(대법원 1997.11.11. 97다33218). 따라서 丙은 甲에 대하여 직접 허가신청절차의 협력의무 이행청구권을 행사하지 못한다. 정답: ⑤

27

등기의 유효요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 물건에 관한 등기가 원인 없이 말소되더라도 특별한 사정이 없는 한 그 물권의 효력에는 영향을 미치지 않는다.
- ② 미등기건물의 승계취득자가 원시취득자와의 합의에 따라 직접 소유권보존등기를 마친 경우, 그 등기는 실체관계에 부합하는 등기로서 유효하다.
- ③ 멸실된 건물의 보존등기를 멸실 후에 신축된 건물의 보존등기로 유용할 수 없다.
- ④ 중복된 소유권보존등기의 등기명의인이 동일인이 아닌 경우, 선등기가 원인무효가 아닌 한 후등기는 무효이다.
- ⑤ 토지거래허가구역 내의 토지에 대한 최초매도인과 최후매수인 사이의 중간생략등기에 관한 합의만 있더라도, 그에 따라 이루어진 중간생략등기는 실체관계에 부합하는 등기로서 유효하다.

해설

- ⑤ 토지거래허가구역 내에서 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였더라도 그러한 최종 매수인 명의의 소유권이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다(대법원 1997.11.11. 97다33218). 정답: ⑤

- ① 본등기에 의한 물건변동의 효력은 가등기를 한 때에 소급하여 발생한다.
- ② 등기가 원인 없이 말소된 경우, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 등기의 등기명의인은 적법한 권리자로 추정된다.
- ③ 합유자가 그 지분을 포기하면 지분권 이전등기를 하지 않더라도, 포기된 합유지분은 나머지 잔존 합유지분권자들에게 물건적으로 귀속하게 된다.
- ④ 매매로 인한 소유권이전등기에서 등기명의자가 등기원인을 증여로 주장하였다면 등기의 추정력은 깨어진다.
- ⑤ 사망자 명의로 신청하여 이루어진 이전등기도 특별한 사정이 없는 한 등기의 추정력이 인정되므로, 등기의 무효를 주장하는 자가 현재의 실체관계에 부합하지 않음을 증명하여야 한다.

해설

② 대법원 1989.10.27. 87다카425

- ① 가등기에 의한 본등기시 물건변동의 효력은 가등기시로 소급하지 않는다.
- ③ 합유지분 포기가 적법하다면 그 포기된 합유지분은 나머지 잔존 합유지분권자들에게 균분으로 귀속하게 되지만 그와 같은 물건변동은 합유지분권의 포기라고 하는 법률행위에 의한 것이므로 등기하여야 효력이 있다(대법원 1996.12.10. 96다23238).
- ④ 부동산 등기는 현재의 진실한 권리상태를 공시하면 그에 이른 과정이나 태양을 그대로 반영하지 아니하였어도 유효한 것으로서, 등기명의자가 전 소유자로부터 부동산을 취득함에 있어 등기부상 기재된 등기원인에 의하지 아니하고 다른 원인으로 적법하게 취득하였다고 하면서 등기원인 행위의 태양이나 과정을 다소 다르게 주장한다고 하여 이러한 주장만 가지고 그 등기의 추정력이 깨어진다고 할 수는 없다(대법원 2005.09.29. 2003다40651).
- ⑤ 사망자 명의로 신청하여 이루어진 이전등기는 일단 원인무효의 등기라고 볼 것이어서 등기의 추정력을 인정할 여지가 없으므로, 등기의 유효를 주장하는 자가 현재의 실체관계와 부합함을 증명할 책임이 있다(대법원 2018.11.29.) 정답: ②

- ① 양수인의 선의·무과실은 물건적 합의가 선행된 경우 물건적 합의시에 선의·무과실일 것을 요한다.
- ② 거래당사자에게 제한능력, 착오, 사기, 강박 등의 사유가 있어 거래행위가 무효 또는 취소 등으로 실효된 경우에는 선의취득은 인정되지 않는다.
- ③ 선의취득은 거래에 의한 동산취득의 경우에 한해 인정되고, 경매에 의한 경우에는 적용되지 않는다.
- ④ 선의취득자는 임의로 선의취득의 효과를 거부하고 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구할 수 있다.
- ⑤ 명인방법에 의하여 공시되는 지상물도 선의취득의 객체가 된다.

해설

- ② 양수인은 유효한 거래행위에 의하여 그 동산을 승계취득 하여야 한다.
- ① 민법 제249조가 규정하는 선의·무과실의 기준시점은 물권행위가 완성되는 때이므로 물권적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물권적 합의보다 먼저 행하여지면 물권적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다(대법원 1991.03.22. 91다70).
- ③ 경매는 선의취득의 거래행위에 해당한다고 한다(대법원 1998.6.12. 98다6800).
- ④ 제249조의 동산의 선의취득제도는 동산을 점유하는 자의 권리 외관을 중시하여 이를 신뢰한 자의 소유권취득을 인정하고 진정한 소유자의 추급을 방지함으로써 거래의 안전을 확보하기 위하여 법이 마련한 제도이므로, 동산을 선의취득한 자는 권리를 취득하는 반면 종전 소유자는 소유권을 상실하게 되는 효과가 법률의 규정에 의하여 생기므로 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구할 수 없다(대법원 1998.6.12. 98다6800).
- ⑤ 미분리과실은 명인방법이라는 특별한 공시방법이 있으므로 선의취득의 객체가 되지 않는다.

정답: ②

30 중간생략등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 중간생략등기의 합의는 순차적 또는 묵시적으로 할 수 있다.
- ② 중간생략등기의 합의가 있더라도 최초매도인과 최종매수인 사이에 매매계약이 체결되었다고 볼 수는 없다.
- ③ 중간생략등기의 합의가 있다고 하여 최초매도인이 매매계약상 상대방에 대하여 가지는 대금청구권의 행사가 제한되는 것은 아니다.
- ④ 관계당사자 전원의 의사합치가 없어도 중간자의 동의가 있다면 최종매수인은 최초매도인을 상대로 직접 중간생략등기를 청구할 수 있다.
- ⑤ 중간생략등기가 당사자 사이에 적법한 등기원인에 기하여 이미 경료되었다면, 중간생략등기의 합의가 없었음을 들어 그 등기의 말소를 구할 수는 없다.

해설

- ④ 최종 양수인이 중간생략등기의 합의를 이유로 최초 양도인에게 직접 중간생략등기를 청구하기 위하여는 관계 당사자 전원의 의사합치가 필요하지만, 당사자 사이에 적법한 원인행위가 성립되어 일단 중간생략등기가 이루어진 이상 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 이유만으로는 중간생략등기가 무효라고 할 수는 없다(대법원 2005.09.29. 2003다40651). 정답: ④

해설

- ③ 채무자 이외의 자의 소유에 속하는 동산을 경매한 경우에도 경매절차에서 그 동산을 경락받아 경락대금을 납부하고 이를 인도받은 경락인은 특별한 사정이 없는 한 소유권을 선의취득한다(대법원 1998.3.27, 97다32680).
- ① 현실인도, 간이인도, 목적물반환청구권의 양도에 인도를 통한 선의취득은 인정되지만 점유개정을 통한 선의취득은 부정된다.
- ② 양수인의 평온, 공언, 선의까지만 추정되고 무과실은 추정되지 않으므로 양수인 스스로 과실 없음을 입증해야 한다. 정답: ③

33 동산의 선의취득에 관한 다음 설명 중 타당한 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 선의취득은 점유의 취득이 평온·공언하고 선의·무과실인 것을 요한다. 이것은 물권적 합의가 인도보다 선행된 경우 점유개시시 뿐만 아니라 그 이후에도 계속되어야 한다. 따라서 취득 이후 악의로 된 경우는 선의취득이 될 수 없다.
- ② 상속에 의한 동산취득의 경우에도 선의취득은 인정된다.
- ③ 선박은 등기가 대항요건으로 되어 있지만, 어디까지나 동산이므로 역시 선의취득의 대상이 된다.
- ④ 선의취득은 처분권한이 없는 자로부터 동산을 취득한 경우에 인정되며, 물권행위가 제한 능력을 이유로 취소되어도 선의취득은 인정된다.
- ⑤ 무권대리인도 처분권한이 없는 자이지만, 무권대리인이 처분한 경우에는 선의취득은 적용되지 않는다.

해설

- ⑤ 선의취득은 양도인이 권리가 없는 경우로 동산의 소유권 또는 처분권한이 없을 때를 말한다. 그리고 대리인이 본인소유 아닌 동산을 처분한 때에도 이에 포함된다. 그러나 무권대리인인 경우에는 대리권한이 있다고 오신하여도 선의취득의 보호를 받지 못한다.
- ① 선의취득에서 양수인의 선의·평온·공언은 추정된다(제197조). 이것은 있으면 되고, 그 이후에도 계속되어야 할 필요는 없다.
- ② 선의취득에서의 거래행위는 동산의 소유권과 질권에 관한 개별적인 처분행위를 말한다. 따라서 선의취득은 특정승계에 한하며, 법률상 당연히 취득의 효과가 발생하는 포괄승계, 예컨대 상속·회사의 합병의 경우 또는 사실행위에 의하여 원시적으로 취득하는 경우에는 인정되지 않는다.
- ③ 등기·등록으로 공시되는 동산, 즉 선박, 자동차, 항공기, 건설기계 등과 같이 법정의 등기·등록을 공시방법으로 하는 물건은 그것이 동산이더라도 선의취득의 대상이 되지 않는다.
- ④ 거래행위의 유효, 즉 선의취득의 인정이유는 거래의 안전보호에 있으므로 유효한 거래 행위만이 선의취득에 의하여 보호된다. 따라서 거래당사자의 제한능력·대리권의 흠결·착오·사기·강박 반사회질서 등과 같은 원인에 의하여 거래행위가 취소되거나 당연 무효가 되는 경우에는 선의취득이 인정되지 않는다.

정답: ⑤

34 선의취득의 목적물이 도품, 유실물인 경우에 다음 설명 중 타당하지 않은 내용을 모두 찾아 묶은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ㉠ 점유이탈의 의사에 유무는 본인이 간접점유를 하고 있는 경우에 직접 점유자에 관하여 결정하여야 하고, 본인이 점유보조자를 통해서 점유하는 경우에도 직접점유자에 있어서와 마찬가지로 점유보조자에 관하여 결정하여야 한다.
- ㉡ 도난·유실일로부터 2년 이내에는 반환을 청구할 수 있고, 도품, 유실물의 양수인이 그 물건을 경매나 공개시장에서 선의로 매수한 때에는 피해자 또는 유실자에 대하여 대가 변상의 청구권을 갖는다.
- ㉢ 피해자나 유실자는 선의취득자에 대하여는 반환을 청구할 수 있으나, 선의취득자의 특정 승계인에 대하여는 반환을 청구할 수 없다.
- ㉣ 도품, 유실물이란 원권리자로부터 점유를 수탁한 사람이 적극적으로 제3자에게 부정처분한 경우와 같은 위탁물횡령의 경우는 포함되지 않는다.
- ㉤ 점유보조자 내지 소지기관의 횡령처럼 형사법상 절도죄가 되는 경우에는 민법 제250조의 도품, 유실물에 해당된다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉣

④ ㉢, ㉤

⑤ ㉣, ㉤

해설

- ④ ㉢ 도품 및 유실물의 반환청구의 상대방은 도인(盜人)이나 습득자로부터 직접 취득한 자뿐 아니라 취득자로부터 승계한 자도 포함한다,
- ㉤ 점유보조자 내지 소지기관의 횡령의 경우 어디까지나 그의 의사에 의하여 점유가 이전된 것이므로 도품 및 유실물에 해당하지 않는다(대법원 1991.3.2. 91다70). 정답: ④

35 선의취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 경매에 의한 동산의 취득에는 선의취득이 인정되지 않는다.
- ② 점유개정은 선의취득에서의 인도의 방법으로 인정되지 않는다.
- ③ 간이인도는 선의취득에서의 인도의 방법으로 인정된다.
- ④ 저당권은 선의취득의 대상이 아니지만 동산질권은 선의취득의 대상이 된다.
- ⑤ 물건적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 양수인의 선의·무과실은 인도된 때를 기준으로 판단한다.

해설

- ① 채무자 이외의 자의 소유에 속하는 동산을 경매한 경우에도 경매절차에서 그 동산을 경락받아 경락대금을 납부하고 이를 인도받은 경락인은 특별한 사정이 없는 한 소유권을 선의취득 한다(대법원 2003.07.25. 2002다39616). 정답: ①

36

선취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 등기·등록으로 공시되는 자동차, 선박의 선취득은 인정되지 않는다.
- ② 점유개정에 의한 선취득은 부정되지만 목적물반환청구권의 양도에 의한 선취득은 가능하다.
- ③ 점유보조자가 횡령한 물건은 민법상 도품에 해당하지 않는다.
- ④ 선취득을 위해서는 양수인의 점유취득이 선의·무과실로 이루어져야 하는데, 선의·무과실의 기준시점은 물건적 합의와 인도 중에서 어느 것이라도 먼저 갖추어진 때이다.
- ⑤ 선취득의 요건을 갖춘 경우 양수인은 선취득의 효과를 부정하고 임의로 종전소유자에게 동산을 받아갈 것을 요구할 수 없다.

해설

- ④ 민법 제249조가 규정하는 선의·무과실의 기준시점은 물건행위가 완성되는 때이므로 물건적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물건적 합의보다 먼저 행하여지면 물건적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다(대법원 1991. 03.22. 91다70). 정답: ④

37

동산의 선취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 등기나 등록에 의하여 공시되는 동산은 원칙적으로 선취득의 대상이 될 수 없다.
- ② 선취득이 성립하기 위해서는 양도인이 무권리자라고 하는 점을 제외하고는 아무런 흠이 없는 거래행위이어야 한다.
- ③ 양도인이 제3자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도하고 지명채권 양도의 대항요건을 갖춘 경우, 선취득에 필요한 점유의 취득 요건을 충족한다.
- ④ 동산질권의 선취득을 저지하기 위해서는 취득자의 점유취득이 과실에 의한 것임을 동산의 소유자가 증명하여야 한다.
- ⑤ 양수인이 도품을 공개시장에서 선의·무과실로 매수한 경우, 피해자는 양수인이 지급한 대가를 변상하고 그 물건의 반환을 청구할 수 있다.

해설

- ④ 동산의 선취득에서 무과실의 증명책임은 선취득자에게 있다(대법원 1962. 03.22. 4294민상 1174). 정답: ④

38

선의취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 경매에 의하여 소유권을 취득한 매수인에게도 선의취득이 인정될 수 있다.
- ② 동산의 선의취득은 양도인이 무권리자라고 하는 점을 제외하고는 아무런 흠이 없는 거래 행위이어야 성립한다.
- ③ 연립주택의 입주권은 선의취득의 대상이 될 수 없다.
- ④ 저당권은 선의취득할 수 없다.
- ⑤ 현실의 인도를 받지 않아도 점유개정의 방법만으로 선의취득이 인정된다.

해설

⑤ 점유개정에 의한 인도에 대하여는 선의취득이 인정되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

정답: ⑤

39

선의취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 경매에 의해서는 동산을 선의취득할 수 없다.
- ② 점유개정에 의한 인도로는 선의취득이 인정되지 않는다.
- ③ 동산질권도 선의취득할 수 있다.
- ④ 선의취득자는 임의로 선의취득의 효과를 거부하고 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구할 수 없다.
- ⑤ 점유보조자가 횡령한 물건은 민법 제250조의 도품 · 유실물에 해당하지 않는다.

해설

① 경매에 의하여 소유권을 취득한 매수인에게도 선의취득이 인정될 수 있다. 정답: ①

제2장
실전문제

40

선의취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 등록된 자동차는 선의취득의 대상이 아니다.
- ② 양수인의 선의 · 무과실의 기준시점은 물건행위가 완성된 때이다.
- ③ 점유개정에 의한 인도에 대하여는 선의취득이 인정되지 않는다.
- ④ 점유보조자가 본인의 의사에 반하여 본인의 물건을 처분하여 상대방이 선의취득한 경우에는 본인은 2년 내에 물건의 반환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 선의취득이 유효하게 성립한 경우에는 취득자는 임의로 선의취득의 효과를 거부하고 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구할 수 없다.

해설

④ 점유보조자의 횡령의 경우에도 제250조(도품, 유실물에 대한 특례)의 적용이 없다고 보는 것이 다수설·판례의 입장이다. 따라서 제249조의 선의취득이 인정되므로 취득자에 대하여 반환청구를 할 수 없다. 정답: ④

41

선익취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지는 선익취득의 대상이 되지 못한다.
- ② 점유개정에 의해 간접점유를 취득하였다라도 선익취득을 할 수 없다.
- ③ 선익취득자는 임의로 선익취득의 효과를 거부하고 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구할 수 없다.
- ④ 점유보조자가 횡령한 동산은 민법 제250조의 도품·유실물에 해당하지 않는다.
- ⑤ 양수인이 물건적 합의 시점에 선의·무과실이면, 이후 인도받을 때에 악의이거나 과실이 있더라도 선익취득이 인정된다.

해설

- ⑤ 민법 제249조가 규정하는 선의·무과실의 기준시점은 물건행위가 완성되는 때이므로 물건적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물건적 합의보다 먼저 행하여지면 물건적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다(대법원 1991. 03.22. 91다70). 정답: ⑤

42

다음 중 혼동에 의하여 물권이 소멸하는 경우는?

- ① 갑이 을의 소유지 위에 지상권을 가지고 있고 병이 같은 토지 위에 갑의 지상권보다 먼저 저당권을 취득한 경우에 갑이 을의 토지소유권을 취득한 때
- ② 갑이 을에 대한 채권자로서 을의 소유지위에 저당권을 가지고 있고 병은 그 토지에 후순위 저당권을 가지고 있는 경우에 갑이 을을 상속한 때
- ③ 갑이 을이 가지는 지상권 위에 저당권을 가지고 있고 병이 같은 지상권위에 후순위저당권을 가지고 있는 경우에 갑이 지상권을 취득한 때
- ④ 을의 지상권 위에 갑이 저당권을 가지고 있고 또 그 저당권 위에 병이 질권을 가지고 있는 경우에, 갑이 을의 지상권을 취득한 때
- ⑤ 부동산에 대한 소유권과 임차권이 동일인에게 귀속하는 경우 임차권은 혼동에 의하여 소멸하는 것이 원칙이지만 그 임차권이 대항요건을 갖추고 있고 또한 그 대항요건을 구비한 후에 저당권이 설정된 때에는 혼동으로 인한 물권소멸원칙의 예외규정인 제191조 제1항 단서를 준용하여 임차권은 소멸하지 않는다.

해설

- ① 동일한 물건에 대한 소유권과 제한물권이 동일인에게 귀속한 경우에 그 제한물권은 소멸하는 것이 원칙이지만(제191조 제1항 본문), 그 제한물권이 제3자의 권리의 목적인 때에는 소멸하지 않는다(제191조 제1항 단서). 이때 통설과 판례는 ‘제3자의 권리의 목적’을 넓게 해석하여 “본인 또는 제3자”의 이익을 위하여 필요한 경우에는 혼동으로 제한물권은 소멸하지 않는다고 한다. 그러나 제191조 단서가 적용되는 것은 제3자의 권리가 본인의 권리에 비하여 열위인 경우에 한하며, 그 것이 처음부터 우선하는 경우에는 혼동으로 부당하게 제3자가 우위에 선다는 일은 있을 수 없으므로 본 단서는 적용되지 않고 혼동으로 본인의 권리는 소멸한다. 지문에서 갑의 지상권이 병의 저당권보다 후순위이므로 제191조 제1항 본문에 따라 갑의 지상권은 혼동으로 소멸한다.
- ② 갑이 상속으로 인해 을의 토지를 취득함으로써 갑의 피담보채권이 혼동으로 소멸하는 경우 갑의 저당권도 따라서 소멸하게 된다. 이러한 경우 갑의 저당권이 소멸하는 것은 혼동으로 인하여서가 아니라 피담보채권의 소멸에 따른 부종성의 결과이다.

- ③ 갑이 지상권을 취득하더라도 갑의 저당권은 소멸하지 않는다. 만일 혼동으로 갑의 저당권이 소멸한다면 병의 열위의 권리가 혼동의 결과 부당하게 유리한 지위를 차지하여 갑의 이익을 해하는 것이 되기 때문이다.
- ④ 제한물권과 그 제한물권을 목적으로 하는 다른 제한 물권과의 혼동의 경우, 혼동한 권리가 제3자의 권리의 목적인 때에 해당되므로 갑의 저당권은 소멸하지 않는다.
- ⑤ 대법원 2001.5.15. 2000다12693 정답: ①

43 혼동으로 물권이 소멸하는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲의 토지에 乙이 1번 저당권, 丙이 2번 저당권을 취득한 후 乙이 토지 소유권을 취득하는 경우
- ② 甲의 건물에 乙이 저당권을 취득한 다음 그 건물을 매수하여 소유권이전등기를 마쳤는데, 그 매매계약이 원인무효임이 밝혀진 경우
- ③ 甲의 건물에 乙이 1번 저당권, 丙이 2번 저당권을 취득한 후 丙이 건물 소유권을 취득하는 경우
- ④ 甲의 토지에 乙이 지상권을 취득하고, 그 지상권 위에 丙이 저당권을 취득한 후 乙이 토지 소유권을 취득하는 경우
- ⑤ 甲의 토지에 대한 乙의 지상권 위에 丙이 1번 저당권, 丁이 2번 저당권을 취득한 뒤 丙이 乙의 지상권을 취득하는 경우

해설

- ③ 후순위 저당권자가 목적부동산의 소유권을 취득한 경우에는 그 저당권은 혼동으로 소멸한다.

정답: ③

44 혼동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙 소유의 토지에 지상권을 취득한 甲이 그 지상권을 목적으로 하는 저당권을 丙에게 설정한 후 甲이 토지의 소유권을 취득하였다면, 甲의 지상권은 소멸하지 않는다.
- ② 乙 소유의 토지에 지상권을 취득한 甲이 그 지상권을 목적으로 하는 저당권을 丙에게 설정한 후에 甲이 그 저당권을 취득한다면, 그 저당권은 소멸한다.
- ③ 甲 소유의 건물에 乙의 대항력 있는 임차권이 성립한 후 丙이 그 건물에 저당권을 취득하였다면, 후일 乙이 甲으로부터 그 건물을 매수하여도 임차권은 소멸하지 않는다.
- ④ 丙 소유의 토지에 甲의 1순위저당권과 乙의 2순위 저당권이 설정되어 있을 때, 甲이 그 토지를 매수하여 소유권을 취득하였고 甲의 피담보채권이 존속할 경우에는 乙의 저당권이 1순위가 된다.
- ⑤ 근저당권자 甲이 근저당목적물인 건물을 매수한 후 그 소유권취득이 무효로 밝혀지면, 혼동으로 소멸하였던 근저당권은 부활한다.

해설

- ④ 하나의 토지에 둘 이상의 저당권이 설정된 경우에 선순위 저당권자가 소유권을 취득하여도 순위승진을 막기 위하여 그 선순위 저당권은 존속한다. 정답: ④

점유권

1

기본문제

01

점유의 모습에 관하여 옳은 설명은?

- ① 점유보조자에 의한 점유는 간접점유이다.
- ② 직접점유자와는 달리 간접점유자에게는 점유권이 인정되지 않는다.
- ③ 자주점유인지 타주점유인지를 구분하는 기준인 소유의 의사는 점유자의 주관적인 의사에 의하여 결정된다.
- ④ 민법은 점유자는 소유의 의사로 선의, 평온, 공연, 무과실로 점유한 것으로 추정하고 있다.
- ⑤ 점유에 관하여 본권이 있음을 확신한 경우에만 선의점유이고 본권의 유무에 관하여 의심을 품으면서 하는 점유는 악의점유이다.

해설

- ⑤ 과실수취권이 있는 선의점유자로 인정되기 위해서는 본권이 없는데도 있다고 오신할만한 정당한 근거가 있어야 한다. 즉 본권이 있음을 확신한 경우라야 한다. 따라서 본권의 유무에 관하여 의심을 품으면서 하는 점유는 악의점유이다.
- ① 점유보조자는 점유자가 아니다.
- ② 직접점유자와 간접점유자는 모두 점유자이다.
- ③ 소유의 의사유무는 점유취득의 원인이 된 사실, 즉 권원의 성질에 의하여 객관적으로 판정한다(통설·판례).
- ④ 무과실은 추정되지 않는다(제197조). 정답: ⑤

02

자주점유에 대한 설명 중 틀린 것은? (견해의 대립시 판례에 의함)

- ① 소유의 의사는 점유취득의 원인이 되는 점유권원의 성질에 의하여 객관적으로 결정된다.
- ② 타인의 물건을 빌려 쓰고 있는 자의 점유는 타주점유이다.
- ③ 점유자가 취득시효기간 경과 후 매수를 제의하더라도 타주점유로 보지 않는다.
- ④ 공유자 1인이 공유토지 전부를 점유하는 것은 권원의 성질상 다른 공유자의 지분비율의 범위 내에서는 타주점유이다.
- ⑤ 명의수탁자의 점유는 자주점유이다.

해설

- ⑤ 명의수탁자의 점유는 타주점유이다. 정답: ⑤

03

다음 중 자주점유에 해당하는 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 매수인이 지상건물과 그 대지를 매수하여 점유를 개시함에 있어 인접 토지와와 경계를 확인해 보지 않고 착오로 인접 토지의 일부를 그가 매수한 토지의 일부로 알고 점유를 하여 온 경우
- ② 타인의 토지에 분묘를 설치한 자가 점유하는 그 타인의 토지
- ③ 어떤 부동산이 제3자에게 경락되고 대금이 납부된 후에도 종전 소유자가 그 부동산을 점유하고 있는 경우
- ④ 타인의 토지임을 알면서 무단으로 이를 점유하는 경우
- ⑤ 명의신탁의 약정에 의하여 목적물을 점유하고 있는 명의수탁자

해설

- ① 지상 건물과 함께 그 대지를 매수, 취득하여 점유를 개시함에 있어서 매수인이 인접토지와의 경계선을 정확하게 확인하여 보지 아니하여 착오로 인접 토지의 일부를 그가 매수, 취득한 대지에 속하는 것으로 믿고 점유를 하여 왔다고 하더라도 인접 토지의 일부를 현실적으로 인도받아 점유하고 있는 이상 인접토지에 대한 점유 역시 소유의 의사에 기한 것이라고 보아야 한다(대법원 1998.11.10. 98다32878).
- ② 타인의 토지 위에 분묘를 설치·소유하는 자는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 분묘의 보존, 관리에 필요한 범위 내에서만 타인의 토지를 점유하는 것이므로 점유의 성질상 소유의 의사가 추정되지 않는다(대법원 1997.3.28. 97다3651).
- ③ 대법원 1999.4.13. 98다40848
- ④ 점유자가 점유개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 것이 증명된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 점유자는 타인의 소유권을 배척하고 점유할 의사를 갖고 있지 않다고 보아야 할 것이므로 이로써 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어졌다고 할 것이다(대법원 1999.3.12. 98다29834).
- ⑤ 명의신탁의 약정에 의하여 목적물을 점유하고 있는 명의수탁자는 타주점유자이다. 정답: ①

제3장
기본문제

04

다음 중 자주점유에 관한 설명으로 잘못된 설명은? (견해의 대립시 판례에 의함)

- ① 증여·매매·교환 등과 같이 소유권 취득의 원인이 되는 계약이 자주점유임이 명백한 권원에 해당한다.
- ② 등기부상의 명의자로부터 부동산을 양수한 자의 점유는 특별한 사정이 없는 한 무과실의 점유에 해당한다.
- ③ 공유 토지는 공유자 1인이 그 전부를 점유하고 있다고 하여도 다른 공유자의 지분비율의 범위 내에서는 타주점유라고 볼 수 밖에 없다.
- ④ 부동산을 소유의 의사로 점유하던 자가 사망하고 그 점유를 상속인 중 일부만이 승계한 때에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 점유를 승계한 상속인들은 다른 상속인의 지분비율 내에서는 타주점유라고 볼 수 밖에 없다.
- ⑤ 상속인은 피상속인과 동일한 법률상의 지위에 서기 때문에 새로운 권원에 의하여 점유를 개시하지 아니하는 이상 피상속인의 점유의 성질과 하자를 떠나 상속인 고유의 점유를 주장할 수 없다.

해설

- ④ 부동산을 소유의 의사로 점유하던 자가 사망하고 그 점유를 상속인 중 일부만이 승계하여 점유를 승계한 때에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 점유를 승계한 상속인들이 부동산 전체를 소유의 의사로 점유하는 것이고, 그 점유가 계속되어 민법 제245조 제1항의 기간이 만료되면 등기를 함으로써 부동산의 소유권을 취득하게 된다(대법원 1989.4.11. 88다카17389).
- ① 권원이라 함은 점유취득의 원인이 된 사실을 의미하는데 이러한 권원의 성질에 의하여 소유의 의사 유무가 객관적으로 정하여진다(대법원 1969.3.4. 69다5).
- ② 양도인이 등기부상의 명의인과 동일인인 경우에는 등기부상 양도인 명의를 의심할 만한 특별한 사정이 없는 한 그 부동산을 양도받은 자는 과실 없는 점유자에 해당한다(대법원 1998.8.24. 96다8888).
- ③ 대법원 1968.4.30. 67다2862
- ⑤ 대법원 1971.2.23. 70다2755 정답: ④

05 점유권에 관한 설명 중 타당한 것은?

- ① 간접점유자는 점유침탈자에 대하여 자신의 선택에 따라 자기 또는 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있다.
- ② 직접점유자가 간접점유자의 의사에 반하여 점유를 양도하였다면 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당한다.
- ③ 통설은 점유보조자와 간접점유자도 자력구제를 할 수 있다고 한다.
- ④ 통설은 점유가 성립하기 위해서는 물건에 대한 사실상의 지배와 점유설정의사가 요구된다고 한다.
- ⑤ 점유자는 점유침탈자의 포괄승계인이 선의인 경우 그에 대하여 물건의 반환을 청구하지 못한다.

해설

- ④ 판례도 점유설정의사, 즉 사실적 지배관계를 가지려는 의사는 있어야 한다고 한다(대법원 1973.2.13. 72다2505·2451).
- ① 먼저 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있다.
- ② 직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다(대법원 1993.3.9. 92다5300).
- ③ 간접점유자에게는 점유보호청구권이 인정되나(제207조 제1항), 자력구제권은 인정되지 않는다.
- ⑤ 점유물반환청구권은 침탈자의 선의의 '특별승계인'에 대해서는 행사하지 못하나, 포괄승계인에 대하여는 선의·악의를 불문하고 행사할 수 있다. 정답: ④

06 과실수취권에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 유치권자는 유치물의 과실로부터 우선변제에 충당할 수 있다.
- ② 천연과실의 수취권자는 원물의 소유자이나 예외적으로 선의의 점유자, 지상권자, 사용차주, 임차인 등도 취득할 수 있다.
- ③ 저당권의 효력은 목적물의 과실에는 미치지 않으나, 저당부동산의 압류가 있는 후에는 저당권의 효력이 미친다.
- ④ 매매 목적물로부터의 과실은 매매대금을 모두 지급한 경우에도 매도인에게 속한다.
- ⑤ 선의의 점유자에게는 과실취득권이 인정되고, 과실수취로 인해 타인에게 손실을 입혔다 하더라도 이를 반환할 의무가 없다.

해설

- ④ 매매계약이 있는 후에도 원칙적으로 인도하지 아니한 목적물로부터 생긴 과실은 매도인에게 속하나, 매매대금을 완납한 경우에는 그 이후의 과실수취권은 매수인에게 귀속한다(대법원 1993.11.9. 93다28928).
- ① 제323조 제1항
 - ② 천연과실이 원물로부터 분리될 때에 누구에게 귀속되는가에 관하여 우리 민법은 로마법상의 원물주의를 취하고 있다.
 - ③ 제359조
 - ⑤ 본권이 있는 것으로 믿은 선의의 점유자는 과실을 수취하여 소비하는 것이 보통이므로, 이를 반환케 하는 것은 가혹하기 때문이다(제201조 제1항, 대법원 1995.5.12. 95다573). 정답: ④

제3장
기본문제

07 점유물방해제거청구권에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① '점유보호청구권' 이라고도 하며 물건 자체에 대한 사실상의 지배상태를 점유침탈 이외의 방법으로 침해하는 방해행위가 있을 때 성립한다.
- ② 점유에 대한 방해는 사회통념상 정당시되거나 인용할 정도의 것이 아니어야 한다.
- ③ 점유자는 방해제거청구권 이외에 손해배상청구권도 가진다.
- ④ 점유자가 가지는 손해배상청구권은 점유와 관련하여 인정되는 것이기 때문에 방해자의 고의·과실을 필요로 하지 않는다.
- ⑤ 방해제거청구권에 대한 1년의 제척기간은 출소기간으로 이해하며, 성질상 손해배상청구권에 관하여서만 적용될 뿐이다.

해설

㉠ 점유보호청구권

구 분	요 건	내 용	제척기간
점유물반환 청구권	- 점유를 침탈당하였을 것 - 침탈자의 고의·과실이 불문 - 선의의 특정승계인에게는 행사하지 못함	목적물반환 및 손해배상청구	침탈당한 날로부터 1년
점유물방해제거 청구권	- 점유의 방해를 받았을 것 - 방해자의 고의·과실이 불문 - 정당한 방해, 수인한도 내의 것이 아닐 것	방해의 제거 및 손해배상청구	방해가 종료한 날로부터 1년
점유물방해예방 청구권	- 점유를 방해받을 염려가 있을 것 - 염려존부는 사회통념으로 판단	방해예방 또는 손해배상담보 청구	방해염려 존속 중은 언제나 행사

- ④ 손해배상청구권은 방해자의 고의·과실을 요한다.
 ① 대법원 1987.6.9. 86다카2942
 ⑤ 대법원 2002.4.26. 2001다8097 정답: ④

08 점유의 訴와 본권의 訴와의 관계에서 옳지 않은 것은?

- ① 점유의 訴와 본권의 訴는 서로 양립하는 관계에 있고 본권의 訴는 점유할 수 있는 권리에 기인한 訴이다.
- ② 점유의 訴는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다.
- ③ 원고가 점유물반환청구의 訴를 제기한 경우에 피고가 소유권 등의 본권을 가지고 있더라도 이를 이유로 원고의 점유물반환청구의 訴를 기각하지 못한다는 의미이다.
- ④ 위 ③의 경우 본권자는 반소(反訴)를 제기하지는 못한다.
- ⑤ 점유의 訴는 점유보호청구권에 기인한 訴이다.

해설

◎ 점유의 訴와 본권의 訴와의 관계

의 의	점유권에서 생기는 물권적 청구권에 기인하는 소를 '점유의 소'라고 하고, 소유권 등의 본권에 기인하는 소를 '본권의 소'라고 한다.
양자의 관계	▪ 점유의 소와 본권의 소는 서로 영향을 미치지 않는다(제208조 제1항). → 소유자가 점유하고 있던 물건을 빼앗긴 경우에 소유자는 소유물반환청구권과 점유물반환청구권에 기인한 소를 동시에 또는 다른 시기에 제기할 수 있다. → 어느 하나에 패소하더라도 다른 소를 제기할 수 있다. ▪ 점유의 소는 본권에 관한 것을 이유로 재판하지 못한다(제208조 제2항). → 임대인이 기간만료 후에 목적물을 명도하지 않는 임차인으로부터 목적물을 탈환한 경우에 임차인이 점유물반환청구의 소를 제기하였다면 임대인이 임차인은 그 물건을 반환할 의무가 있다고 주장하여도 이를 이유로 점유물반환청구권의 소를 기각하지 못한다.

정답: ④

09 다음 사항 중 민법의 규정상 선의점유와 악의점유를 구별할 실익이 없는 것은?

- ① 소유권의 시효취득 ② 점유물의 멸실·훼손에 대한 점유자의 책임
- ③ 점유자의 과실취득권 ④ 동산의 선의취득
- ⑤ 점유자의 필요비 및 유익비상환청구권

해설

- ⑤ 점유자의 비용상환청구권은 선의·악의를 묻지 않는다. 정답: ⑤

10 점유권에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 점유권은 상속인에게 이전하므로 상속인의 사실상의 지배가 없어도 점유권을 인정한다.
- ② 점유자는 평온·공연 및 선의로 점유하는 것으로 추정된다.
- ③ 점유자는 자주점유를 하는 것으로 추정된다.
- ④ 점유자가 점유물 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.
- ⑤ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 판결이 확정된 때로부터 악의의 점유자로 본다.

해설

⑤ 판결이 확정된 때로부터가 아니라 소가 제기된 때부터이다(제197조 제2항).

① 제193조, ②③ 제197조, ④ 제200조 정답: ⑤

01 점유에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 과실수취권을 포함하지 않는 본권을 가지고 있다고 소극적으로 오신한 경우에는 선의점유에 포함되지 않는다.
- ② 선의점유자가 본권에 관한 訴에서 패소하면, 그 訴가 제기된 때에 소급하여 악의이었던 것으로 본다.
- ③ 점유의 사실상 지배란 타인의 간섭을 배제할 가능성이 있을 것을 요한다.
- ④ 점유자는 선의이며 과실 없이 평온·공연하게 점유하는 것으로 추정된다.
- ⑤ 전후 양 시점에 점유한 사실이 있는 때에는 그 점유는 계속된 것으로 추정된다.

해설

- ④ 점유자의 자주점유, 선의, 평온, 공연은 추정되지만(제197조 제1항), 무과실에 관하여는 명문의 규정이 없기 때문에 추정되지 않는다.
- ① 과실을 취득할 수 있는 선의의 점유자는 과실을 수취할 수 있는 권리(소유권, 지상권, 임차권 등)를 가지고 있다고 오신하고, 그와 같이 오신한데 관하여 오신할 만한 근거가 있는 점유자를 말한다(대법원 1992.12.24. 92다22114).
- ② 제197조 제2항
- ③ 사실상 지배란 타인의 인식이 가능하고 타인의 간섭을 배제할 수 있으며 어느 정도 사실상 지배가 계속될 것을 요한다.
- ⑤ 제198조 정답: ④

02 다음 사항 중 민법의 규정상 선의점유와 악의점유를 구별할 실익이 없는 것은?

- ① 소유권의 시효취득
- ② 점유물의 멸실·훼손에 대한 점유자의 책임
- ③ 점유자의 과실취득권
- ④ 동산의 선의취득
- ⑤ 점유자의 필요비 및 유익비상환청구권

해설

㉠ 선의점유와 악의점유

선의점유	본권이 없음에도 불구하고 있다고 오신하여 하는 점유를 말한다.
악의점유	▪ 본권이 없음을 알면서 하는 점유를 말한다. ▪ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에서 패소한 때에는 訴제기시로부터 악의의 점유자로 간주한다.
구별실익	▪ 취득시효 ▪ 과실수취권 ▪ 점유자의 회복자에 대한 책임 ▪ 선의취득

- ⑤ 따라서 점유자의 비용상환청구권은 선의·악의를 묻지 않는다. 정답: ⑤

03

점유에 관한 다음 설명 중 옳지 못한 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 대지의 소유자로 등기한 자는 보통의 경우 그 대지의 인도를 받아 점유를 얻는 것으로 보아야 할 것이므로 등기사실을 인정하면서 점유사실을 부인할 수 없다.
- ② 점유자가 점유방해의 염려가 있어 손해배상의 담보를 청구할 때에는 방해자의 고의·과실이 필요 없다.
- ③ 정당한 권원이 없는 도둑도 소유의 의사를 갖는 자주점유자가 될 수 있다.
- ④ 점유보조자가 되기 위해 필요한 점유보조관계는 반드시 유효한 법률관계에 의하지 않아도 된다.
- ⑤ 점유자의 과실수취권, 점유자의 필요비 및 유익비 상환청구를 하는데 점유자의 선의·악의를 구별하지 않는다.

해설

⑤ 제201조(점유자와 과실)

④ 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.

⑤ 악의의 점유자는 수취한 과실(果實)을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실(過失)로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실(果實)의 대가를 보상하여야 한다고 규정하여 선악의 구별을 명백히 하고 있다. 그러나 점유자의 비용상환청구권에서 점유자는 선의·악의나 소유의 의사를 불문하고 필요비의 상환을 청구할 수 있으며, 유익비에 대해서는 그 가액의 증가가 현존하는 경우에 한하여 상환을 청구할 수 있다.

① 대법원 2001.1.16. 98다20110

② 방해자의 고의·과실은 불필요하다. 다만, 손해배상청구권에 있어서는 방해자의 고의·과실이 필요하다.

③ 자주점유란 소유의 의사를 가지고 하는 점유를 말한다. 여기에서 소유의 의사란 소유자와 같은 배타적 지배를 사실상 행사하고자 하는 의사를 말한다(대법원 1994.11. 9. 94다36438·36445). 따라서 자주점유란 소유권을 가지고 있거나 또는 소유권이 있다고 믿고 하는 점유를 말하는 것이 아니다(대법원 1987.4.14. 85다카2230). 그러므로 타인의 물건을 절취하여 가지고 있는 자도 자주점유가 된다.

④ 명령복종의 종속관계는 유효한 것이어야 할 필요는 없다. 또한 점유보조자가 점유할 권리를 가지고 있어야 하는 것은 아니다. 정답: ⑤

제3장
실전문제

04

점유에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 무권리자로부터 토지를 매수한 자의 점유는 다른 특별한 사정이 없는 한 자주점유이다.
- ② 점유가 성립하기 위해서는 반드시 물건에 대한 물리적, 현실적 지배가 수반되어야 한다.
- ③ 건물의 소유자가 아닌 자가 실제로 건물을 점유하고 있다면 특별한 사정이 없는 한, 당연히 건물의 부지를 점유한다고 보아야 한다.
- ④ 토지에 대한 소유권보존등기가 이루어졌다면, 그 등기명의자는 그 무렵 다른 사람으로부터 당해 토지에 대한 점유를 이전받았다고 본다.
- ⑤ 부동산을 매도하고 등기를 이전하였으나, 아직 그 부동산을 인도하지 않은 매도인의 점유는 특별한 사정이 없는 한 자주점유로 본다.

해설

- ① 자주점유는 소유자와 동일한 지배를 하려는 의사를 가지고 하는 점유를 의미하는 것이지 소유권을 가지고 있거나 또는 소유권이 있다고 믿고서 하는 점유를 의미하는 것은 아니다(대법원 1987.04.14. 85다카2230).
- ② 점유자의 점유가 소유의 의사 있는 자주점유인지 아니면 소유의 의사 없는 타주점유인지는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유 취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 결정되어야 한다(대법원 2015.04.23. 2013다89358). 정답: ①

05

점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지매도인의 매도 후의 점유는 특별한 사정이 없는 한 타주점유로 된다.
- ② 타인소유의 토지를 자기소유 토지의 일부로 알고 이를 점유하게 된 자가 나중에 그러한 사정을 알게 되었다면 그 점유는 그 사정만으로 타주점유로 전환된다.
- ③ 제3자가 토지를 경락받아 대금을 납부한 후에는 종래소유자의 그 토지에 대한 점유는 특별한 사정이 없는 한 타주점유가 된다.
- ④ 토지점유자가 등기명의자를 상대로 매매를 원인으로 소유권이전등기를 청구하였다가 패소 확정된 경우, 그 사정만으로 타주점유로 전환되는 것은 아니다.
- ⑤ 소유자가 점유자를 상대로 적극적으로 소유권을 주장하여 승소한 경우, 점유자의 토지에 대한 점유는 패소판결 확정 후부터는 타주점유로 전환된다.

해설

- ② 토지를 매수·취득하여 점유를 개시함에 있어서 매수인이 인접 토지와와 경계선을 정확하게 확인하여 보지 아니하여 착오로 인접 토지의 일부를 그가 매수·취득한 토지에 속하는 것으로 믿고서 인접 토지의 일부를 현실적으로 인도받아 점유하고 있다면 인접 토지의 일부에 대한 점유는 소유의 의사(자주점유)에 기한 것이다(대법원 2000. 09. 29. 99다58570, 58587). 정답: ②

06

甲 소유의 물건을 점유할 권리 없이 점유하여 온 점유자 乙에 대해 甲이 소유권에 기한 반환을 청구한 경우 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙이 선의인 경우에는 과실을 반환할 필요가 없다.
- ② 乙이 책임 있는 사유로 그 물건을 훼손한 경우, 乙이 타주점유자라면 전 손해를 배상할 책임이 있다.
- ③ 乙이 악의의 점유자인 경우에도 甲에게 지출한 특별필요비의 상환을 청구할 수 있다.
- ④ 乙이 유익비를 지출한 경우, 가액의 증가가 현존한 때에 한하여 乙의 선택에 따라 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 만약 乙의 점유가 불법행위로 인하여 개시되었다면, 乙이 지출한 유익비의 상환청구권을 기초로 하는 乙의 유치권의 주장은 배척된다.

해설

- ④ 유익비상환청구권은 지출한 금액 또는 증가액의 상환을 선택해서 청구할 수 있는데 점유자의 선택이 아니라 회복자의 선택에 의한다(제203조 제2항). 정답: ④

07

자주점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 점유매개자의 점유는 타주점유에 해당한다.
- ② 부동산의 매매 당시에는 그 무효를 알지 못하였으나 이후 매매가 무효임이 밝혀지더라도 특별한 사정이 없는 한, 매수인의 점유는 여전히 자주점유이다.
- ③ 양자간 등기명의신탁에 있어서 부동산 명의수탁자의 상속인에 의한 점유는 특별한 사정이 없는 한, 자주점유에 해당하지 않는다.
- ④ 공유토지 전부를 공유자 1인이 점유하고 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 다른 공유자의 지분비율 범위에 대해서는 타주점유에 해당한다.
- ⑤ 자주점유의 판단기준인 소유의 의사 유무는 점유취득의 원인이 된 권원의 성질이 아니라 점유자의 내심의 의사에 따라 결정된다.

해설

- ⑤ 점유에 있어 소유의 의사 유무는 점유취득의 원인인 권원에 의하여 외형적·객관적으로 정해져야 하는 것이므로 매매계약에 기하여 목적토지의 점유를 취득한 경우에는 매수인의 점유는 소유의 의사로써 하는 것이다(대법원 1990.11.27. 90다카27280). 정답: ⑤

08

점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

제3장
실전문제

- ① 점유매개자의 점유를 통한 간접점유에 의해서도 점유에 의한 시효취득이 가능하다.
- ② 사기의 의사표시에 의해 건물을 명도해 준 자는 점유회수의 소권을 행사할 수 없다.
- ③ 미등기건물을 양수하여 건물에 관한 사실상의 처분권을 보유한 양수인은 그 건물부지의 점유자이다.
- ④ 간접점유의 요건이 되는 점유매개관계는 법률행위가 아닌 법령의 규정에 의해서는 설정될 수 없다.
- ⑤ 상속에 의하여 점유권을 취득한 상속인은 새로운 권원에 의하여 자기 고유의 점유를 개시하지 않는 한 피상속인의 점유를 떠나 자기만의 점유를 주장할 수 없다.

해설

- ④ 취득시효의 요건인 점유는 직접점유뿐만 아니라 간접점유도 포함하는 것이고, 점유매개 관계는 법률의 규정, 국가행위 등에 의해서도 발생할 수 있다(대법원 1998. 2. 24. 96다8888). 정답: ④

09

점유자와 회복자와의 관계에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 선의점유자가 과실을 취득할 수 있는 범위에서 부당이득은 성립하지 않는다.
- ② 타주점유자가 선의인 경우에는 회복자에 대하여 점유물의 멸실·훼손으로 생긴 이익이 현존하는 한도에서 배상책임을 진다.
- ③ 점유자는 점유물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ④ 폭력 또는 은비에 의한 점유자는 과실을 소비하였거나 과실로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.
- ⑤ 통상의 필요비는 점유자가 과실을 취득한 경우에는 상환을 청구하지 못한다.

해설

- ② 자주점유자가 선의인 경우에 한하여 점유물의 멸실 또는 훼손으로 인한 손해에 대해 '이익이 현존하는 한도 내에서' 회복자에게 배상하여야 한다(제202조).
- ① 토지를 사용함으로써 얻는 이득은 그 토지로 인한 과실과 동일시할 것이므로, 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 토지를 점유·사용하고 이로 말미암아 타인에게 손해를 입혔다 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이득은 그 타인에게 반환할 의무는 없다고 한다(대법원 1987. 9.22. 86다카1996·1997).
- ③ 제203조 제2항
- ④ 제201조 제3항
- ⑤ 제203조 제1항 단서 정답: ②

10

점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 피상속인의 사망을 알지 못한 상속인은 피상속인의 점유를 승계하지 못한다.
- ② 점유자는 과실 없이 점유하는 것으로 추정되지 않는다.
- ③ 점유물반환청구에 대하여 점유침탈자는 점유물에 대한 본권이 있다는 이유로 반환을 거부할 수 없다.
- ④ 점유자가 상대방의 사기로 물건을 인도한 경우에는 점유물반환청구를 할 수 없다.
- ⑤ 직접점유가 침탈된 경우 직접점유자가 반환받을 수 없는 때에는 간접점유자는 자기에게 반환할 것을 청구할 수 있다.

해설

- ① 점유권은 상속인에게 이전한다(제193조). 이전되는 점유권은 피상속인이 가졌던 점유이다. 즉, 피상속인의 직접점유·간접점유·타주점유·자주점유·하자 있는 점유 등의 성질을 상속인은 그대로 승계한다. 상속인이 그 물건을 현실적으로 소지하거나 상속의 개시를 알고 있어야 하는 것은 아니며, 피상속인의 사망으로 점유권은 당연히 상속인에게 이전한다. 정답: ①

11

점유자와 회복자의 법률관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 타인의 건물을 선의로 점유한 자는 비록 법률상 원인 없이 사용하였더라도 이로 인한 이득을 반환할 의무가 없다.
- ② 악의의 점유자가 과실을 소비한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.
- ③ 점유물이 점유자의 책임 있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손된 경우, 선의의 자주점유자는 그 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다.
- ④ 선의의 점유자가 본권에 관한 소에서 패소한 경우, 제소 후 판결확정 전에 취득한 과실은 반환할 의무가 없다.
- ⑤ 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비의 상환을 청구하지 못한다.

해설

- ④ 선의의 점유자라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 그 訴가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 간주된다(제197조 제2항).
- ①② 선의의 점유자는 점유물에서 생기는 과실(果實)을 취득할 수 있다(제201조 제1항). 그러나 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 할 뿐만 아니라, 이미 소비하였거나 과실(過失)로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 과실의 대가를 보상하여야 한다(제201조 제2항).
- ④ 점유자가 점유물을 멸실·훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며, 선의의 자주점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하면 된다(제202조).
- ⑤ 점유자가 과실을 취득한 때에는 통상의 필요비는 청구할 수 없다(제203조 제1항). 정답: ④

제3장
실전문제

12

점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 타주점유자가 그의 책임있는 사유로 점유물을 멸실 또는 훼손한 때에는 그가 선의로 점유 했더라도 손해의 전부를 배상하여야 한다.
- ② 자신에게 과실수취권을 포함하는 권원이 있다고 오신한 데 정당한 근거가 있는 점유자는 과실수취권이 있다.
- ③ 선의의 점유자가 법률상 원인 없이 회복자의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 회복자에게 손해를 입혔다면 그 점유·사용으로 인한 이득을 반환할 의무가 있다.
- ④ 타인 소유물을 권원 없이 점유함으로써 얻은 사용이익을 반환하는 경우, 악의의 점유자는 사용이익 뿐만 아니라 그 이자도 반환해야 한다.
- ⑤ 점유자가 과실을 취득하였다면 통상의 필요비는 청구할 수 없다.

해설

- ③ 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 그에게 손해를 입혔다고 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이득을 반환할 의무는 없다(대법원 1996.01.26. 95다 44290).
- ① 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다(제202조).
- ② 선의의 점유자라 함은 과실수취권을 포함하는 권원이 있다고 오신한 점유자를 말하고, 다만 그와 같은 오신을 함에는 오신할 만한 정당한 근거가 있어야 한다(대법원 2000.03.10. 99다63350).
- ④ 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 할 뿐만 아니라, 이미 소비하였거나 과실(過失)로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 과실의 대가를 보상하여야 한다(제201조 제2항).
- ⑤ 점유자가 과실을 취득한 때에는 통상의 필요비는 청구할 수 없다(제203조 제1항). 정답: ③

13 점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 과실을 수취한 자가 선의의 점유자로 보호되기 위해서는 권원이 있다고 오신할만한 정당한 근거가 있어야 한다.
- ② 선의의 점유자가 직접 물건을 사용함으로써 얻은 이득은 과실이 아니므로 회복자에게 반환하여야 한다.
- ③ 악의의 점유자는 수취한 과실의 반환뿐만 아니라 자신의 책임있는 사유로 수취하지 못한 과실의 대가도 보상하여야 한다.
- ④ 선의의 타주점유자가 자신의 책임 있는 사유로 점유물을 멸실, 훼손하였다면 그로 인한 손해의 전부를 배상하여야 한다.
- ⑤ 점유자가 과실을 취득한 경우, 통상의 필요비는 반환을 청구할 수 없다.

해설

- ② 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 그에게 손해를 입혔다고 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이득을 반환할 의무는 없다(대법원 1996.01.26. 95다44290). 정답: ②

14 점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 선의의 점유자가 취득하는 과실에 점유물의 사용이익은 포함되지 않는다.
- ② 유치권자에게는 원칙적으로 수익목적의 과실수취권이 인정된다.
- ③ 점유물이 점유자의 귀책사유로 훼손된 경우, 선의의 점유자는 소유의 의사가 없더라도 이익이 현존하는 한도에서 배상책임이 있다.
- ④ 회복자로부터 점유물의 반환을 청구 받은 점유자는 유익비의 상환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 점유물의 소유자가 변경된 경우, 점유자는 유익비 지출 당시의 전 소유자에게 비용의 상환을 청구해야 한다.

해설

- ④ 점유물의 개량을 위하여 지출한 유익비는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ① 과실에는 법정과실도 포함되므로 사용이익도 당연히 포함된다.
- ② 유치권자에게는 원칙적으로 과실수취권이 인정되지 않는다.
- ③ 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다(제202조). 따라서 손해전부를 배상하여야 한다.
- ⑤ 점유자의 필요비 또는 유익비상환청구권은 점유자가 회복자로부터 점유물의 반환을 청구받거나 회복자에게 점유물을 반환한 때에 비로소 회복자에 대하여 행사할 수 있다(대법원 1994.09.09. 94다4592). 정답: ④

15 점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 선의의 점유자라도 점유물의 사용으로 인한 이익은 회복자에게 반환하여야 한다.
- ② 임차인이 지출한 유익비는 임대인이 아닌 점유회복자에 대해서도 민법 제203조 제2항에 근거하여 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 과실수취권 있는 선의의 점유자란 과실수취권을 포함하는 본권을 가진다고 오신할 만한 정당한 근거가 있는 점유자를 가리킨다.
- ④ 선의점유자에 대해서는 점유에 있어서의 과실(過失) 유무를 불문하고 불법행위를 이유로 한 손해배상책임이 배제된다.
- ⑤ 점유물이 타주점유자의 책임 있는 사유로 멸실된 경우, 그가 선의의 점유자라면 현존이익의 범위에서 손해배상책임을 진다.

해설

③ 타당한 기술이다.

- ① 선의의 점유자는 점유물에서 생기는 과실(果實)을 취득할 수 있다(제201조 제1항).
- ② 임차인의 비용상환청구권은 임대인에게 행사할 수 있는 권리이다.
- ④ 불법행위를 이유로 한 손해배상청구권을 행사하기 위해서는 가해자의 귀책사유(고의 또는 과실)를 요한다.
- ⑤ 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다(제202조). 따라서 손해전부를 배상하여야 한다.
- ② 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 그에게 손해를 입혔다고 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이익을 반환할 의무는 없다(대법원 1996.01.26. 95다44290). 정답: ③

제3장
실전문제

16 자주점유에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 점유자가 취득시효를 주장하는 경우에는, 그가 스스로 소유의 의사를 증명할 책임은 없고, 오히려 그 점유자의 취득시효의 성립을 부정하는 자에게 그 증명책임이 있다.
- ② 토지의 자주점유자가 토지소유자를 상대로 그 토지에 관하여 매매를 원인으로 한 소유권이전등기 청구소송을 제기하였다가 패소하고 그 판결이 확정된 경우에는 자주점유로 전환되었다고 볼 수 없다.
- ③ 소유권유보부매매의 경우 대금 완납시까지 매수인의 점유는 자주점유이다.
- ④ 점유자가 점유개시 당시에 소유권취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없이 그와 같은 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단 점유한 것이 증명된 경우에는 소유의 의사가 있는 점유라는 추정은 깨어진다.
- ⑤ 주택의 대지로 점유하는 부분이 도로를 침범하여 그 주택담장이 이웃의 담장 또는 건물에 비추어 돌출되어 있는 경우, 주택소유자들의 위 침범부분에 대한 점유는 적어도 담장이 상대적으로 돌출되었을 때부터 자주점유로 보아야 한다.

해설

- ⑤ 타주점유로 보아야 한다(대법원 2000.4.25. 2000다348).
- ① 대법원 1968.6.18. 68다729
- ② 토지의 점유자가 이전에 소유자를 상대로 그 토지에 관하여 소유권이전등기 말소절차의 이행을 구하는 訴를 제기하였다가 패소하고 그 판결이 확정되었다 하더라도 그 소송은 점유자가 소유자를 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 것이므로 그 패소판결의 확정으로 점유자의 소유자에 대한 말소등기청구권이 부정될 뿐, 그로써 점유자가 소유자에 대하여 어떠한 의무를 부담하게 되었다든가 그러한 의무가 확인되었다고 볼 수는 없고, 따라서 점유자가 그 소송에서 패소하고 그 판결이 확정되었다는 사실만으로는 토지 점유자의 자주점유의 추정이 반복되어 타주점유로 전환된다고 할 수 없다(대법원 1999.9.17. 98다63018).
- ③ 대법원 1995.12.22. 95다30062
- ④ 대법원[전합] 1997.8.21. 95다28625 정답: ⑤

17 점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 선의의 점유자가 과실을 취득한 범위에서는 그 이득을 반환할 의무가 없다.
- ② 유효한 도급계약에 기하여 수급인이 도급인으로부터 제3자 소유 물건을 이전받아 수리를 마친 경우, 원칙적으로 수급인은 소유자에 대하여 비용상환청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 악의의 점유자도 원칙적으로 필요비 전부의 상환을 청구할 수 있다.
- ④ 점유물이 점유자의 책임 있는 사유로 멸실 또는 훼손된 경우, 악의의 점유자는 자주점유라도 손해 전부를 배상할 책임이 있다.
- ⑤ 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다.

해설

- ② 도급계약에 기하여 수급인이 도급인으로부터 제3자 소유의 물건에 대하여 수리를 마친 경우, 원칙적으로 수급인은 도급인에 대하여 비용상환청구권을 행사할 수 있다. 정답: ②

18 점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2020' 감정평가사]

- ① 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.
- ② 과실의 수취에 관하여 점유자의 선·악의는 과실이 원물에서 분리되는 때를 기준으로 판단한다.
- ③ 악의의 점유자는 그가 소비한 과실의 대가를 보상하여야 한다.
- ④ 그의 책임 있는 사유로 점유물을 멸실·훼손한 선의의 타주점유자는 손해 전부를 배상하여야 한다.
- ⑤ 과실을 취득한 점유자는 그가 지출한 비용 전부를 청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다. 정답: ⑤

19 다음 중에서 가장 타당하지 못한 설명은?

- ① 간접점유자는 직접점유자에 대하여 점유보호청구권이나 자력구제권을 행사할 수 없고, 다만 점유매개관계나 본권에 기한 청구권만을 행사할 수 있을 뿐이다.
- ② 판례에 의하면 과실 없이 유치권, 질권을 가지는 것으로 오신하는 자는 선의의 점유자의 과실취득권을 가진다.
- ③ 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득하는데 여기서의 과실은 천연과실, 법정과실, 물건의 사용이익을 포함하므로 당사자 상호간의 소유 토지를 착오로 서로 자기 소유로 알고 경작한 경우 선의점유이므로 점유물로부터 생긴 과실을 취득할 권리가 있다.
- ④ 판례에 의하면 시효취득자는 전주명의로 등기기간까지 포함해서 10년이면 등기부취득시효가 완성된다고 하면서 등기의 승계를 인정하고 있다.
- ⑤ 수탁자가 수인인 경우에는 비록 신탁재산이 신탁자들의 합유재산 일지라도 그 수탁자들 사이의 공동소유관계는 언제나 공유관계에 속한다는 것이 판례의 입장이다.

해설

- ② 민법 제201조의 과실취득권이 인정되는 선의의 점유자란 과실취득권을 포함하는 권원(소유권, 지상권, 임차권 등)이 있다고 오신한 점유자를 말하며, 그와 같은 오신을 함에는 오신할 만한 근거가 있어야 한다(대법원 1969.9.30. 69다1234).

- ① 제208조 제1항
- ③ 대법원 1977.11.22. 77다981
- ④ 대법원[전합] 1985.1.29. 83다카217
- ⑤ 대법원 1982.11.23. 81다39 정답: ②

20 乙은 甲의 X토지를 임차하여 점유하고 있는데, 丙이 무단으로 X토지 위에 건축폐자재를 적치(積置)하여 乙의 토지사용을 방해하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 甲은 丙에 대하여 소유권에 기한 방해배제청구권을 행사할 수 있다.
- ② 乙은 丙에 대하여 소유권에 기한 방해배제청구권을 행사할 수 없지만, 甲의 소유권에 기한 방해배제청구권을 대위 행사할 수 있다.
- ③ 丙이 X토지를 자신의 것으로 오신하여 건축폐자재를 적치한 경우라 하더라도, 乙은 丙에 대하여 점유권에 기한 방해배제청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 甲은 丙에 대하여 점유권에 기한 방해배제청구권을 행사할 수 없지만, 乙의 점유권에 기한 방해배제청구권을 대위 행사할 수 있다.
- ⑤ X토지에 대한 임대차 계약이 종료되면 甲은 乙에 대하여 임대차 계약상 반환청구권을 행사할 수 있는데, 이는 채권적 청구권으로 물권적 청구권과 별개로 행사할 수 있다.

해설

- ④ 간접점유자(甲)도 점유권을 가지며(제194조), 점유보호청구권도 있으나(제207조), 다만 침탈자에 대하여 직접점유자(乙)에게 반환할 것을 청구할 수 있을 뿐이다. 정답: ④

21

점유보호청구권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 직접점유자가 제3자로부터 그 점유를 침탈당하더라도 간접점유자는 점유보호청구권을 행사할 수 없다.
- ② 유실물을 우연히 습득한 자에 대해서는 점유물반환청구권을 행사할 수 없다.
- ③ 점유물반환청구의 상대방은 현재 점유를 침해하고 있는 자이므로, 점유침탈자의 선의의 특별승계인도 그 상대방이 된다.
- ④ 영업상 타인의 지시를 받아 물건을 사실상 지배하는 자에게도 점유보호청구권이 인정된다.
- ⑤ 점유물반환청구권의 행사기간은 출소기간이 아니다.

해설

- ② 점유물반환청구권은 점유물을 침탈당한 경우에 행사할 수 있는 권리로서 유실물습득은 점유물의 침탈이라 할 수 없어 그 요건이 되지 않는다.
- ① 간접점유자에게 점유보호청구권은 있으나(제207조), 다만 침탈자에 대하여 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있다.
- ③ 점유물반환청구권은 선의의 특별승계인에게는 행사하지 못한다.
- ④ 점유보조자는 점유자가 아니며, 점유주만이 점유자이므로 점유보조자에게는 점유권의 효력이 인정되지 않는다. 따라서 과실수취권이나 점유보호청구권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 점유물반환청구권의 행사기간은 제척기간이며, 출소기간이다. 정답: ②

22

점유자의 점유보호청구권과 관련한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 부동산의 점유침탈의 경우 점유자가 침탈사실을 알고 모르고는 상관없이 침탈을 당한 후 상당기간이 흘렀다면 자력탈환권을 행사할 수 없다.
- ② 사기의 의사표시에 의해 건물을 명도해 준 것이라면 건물의 점유를 침탈당한 것이 아니므로 피해자는 점유물반환청구권을 가지지 않는다.
- ③ 직접점유자가 임의로 점유를 타인에게 양도한 경우에 그 점유이전이 간접점유의 의사에 어긋나면 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당된다.
- ④ 점유권에 의한 방해배제청구권은 물건 자체에 대한 사실상의 지배 상태를 점유침탈 이외의 방법으로 침해하는 방해행위가 있을 때 성립한다.
- ⑤ 위법한 강제집행에 의해 목적물의 인도를 받은 채권자는 공권력을 빌려서 채무자의 점유를 침탈하였다고 새길 수 있다.

해설

- ③ 직접점유의 침탈이란 직접점유자의 의사에 어긋나서 점유를 박탈당한 것을 의미하므로, 직접점유자가 임의로 물건을 인도한 경우에는 비록 간접점유자의 의사에 어긋난다 하더라도 점유침탈은 아니다(대법원 1993.3.9. 92다5300).
- ① '즉시'란 객관적으로 가능한 한 신속히 또는 사회관념상 가해자를 배제하여 점유를 회복하는데 필요한 범위 안에서 되도록 속히 하라는 뜻으로 점유자가 침탈사실을 알고 여부와는 무관하며 침탈 사실이 있는 후 상당한 기간이 흘렀다면 자력탈환권을 행사할 수 없다(대법원 1993.3.26. 91다14116).
- ② 대법원 1992.2.25. 91다17443
- ④ 대법원 1987.6.9. 86다카2942
- ⑤ 대법원 1987.6.9. 86다카2942 정답: ③

23 점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정된다.
- ② 승계취득자가 전점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 점유의 하자도 승계한다.
- ③ 임치관계로 타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자는 간접으로 점유권이 있다.
- ④ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 판결이 확정된 때로부터 악의의 점유자로 본다.
- ⑤ 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하더라도 그로 인한 이득을 반환할 의무가 없다.

해설

- ④ 선의의 점유자라 하더라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 소(訴) 제기시로부터 악의의 점유자로 간주된다. 정답: ④

24 점유권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 공인중개사]

- ① 특별한 사정이 없는 한, 건물의 부지가 된 토지는 그 건물의 소유자가 점유하는 것으로 보아야 한다.
- ② 전후 양 시점의 점유자가 다른 경우 점유승계가 증명되면 점유계속은 추정된다.
- ③ 적법하게 과실을 취득한 선의의 점유자는 회복자에게 통상의 필요비의 상환을 청구하지 못한다.
- ④ 점유자가 상대방의 사기에 의해 물건을 인도한 경우 점유침탈을 이유로 한 점유물반환청구권은 발생하지 않는다.
- ⑤ 선의의 점유자가 본권의 소에서 패소하면 패소확정시 부터 악의의 점유자로 본다.

해설

- ⑤ 선의의 점유자라 하더라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 소(訴) 제기시로부터 악의의 점유자로 간주된다. 정답: ⑤

25

점유에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 미등기건물의 양수인은 그 건물에 관한 사실상의 처분권을 보유하더라도 건물부지를 점유하고 있다고 볼 수 없다.
- ② 건물 공유자 중 일부만이 당해 건물을 점유하고 있는 경우, 그 건물의 부지는 건물공유자 전원이 공동으로 점유하는 것으로 볼 수 있다.
- ③ 점유자의 권리적법추정 규정(민법 제200조)은 특별한 사정이 없는 한 등기된 부동산에도 적용된다.
- ④ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 패소판결이 확정된 때로부터 악의의 점유자로 본다.
- ⑤ 진정한 소유자가 점유자를 상대로 소유권이전등기의 말소청구소송을 제기하여 점유자의 패소로 확정된 경우, 그 소가 제기된 때부터 점유자의 점유는 타주점유로 전환된다.

해설

② 타당한 기술이다.

- ① 미등기건물의 양수인이 그 건물에 관한 사실상의 처분권을 보유한 경우라면 건물부지를 점유하고 있다고 볼 수 있다.
- ③ 권리의 적법추정은 동산의 점유에 한하고, 부동산물권에는 등기에 권리의 적법추정력이 인정된다.
- ④⑤ 선의의 점유자라 하더라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 소(訴) 제기시로부터 악의의 점유자로 간주된다. 그러나 타주점유로 전환되는 시기는 패소판결 확정 후부터이다. 정답: ②

26

점유보호청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유물방해제거청구권의 행사기간은 출소기간이다.
- ② 점유보조자에게는 점유물방해제거청구권이 인정되지 않는다.
- ③ 직접점유자가 임의로 점유를 타인에게 이전한 경우, 그 점유이전이 간접점유자의 의사에 반하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다.
- ④ 점유자가 점유의 침탈을 당한 경우, 침탈자의 특별승계인이 악의인 때에도 그 특별승계인에게 점유물반환청구권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우, 공사 착수 후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성된 때에는 방해의 제거를 청구하지 못한다.

해설

- ④ 침탈자의 특정승계인에 대하여서는 그 자가 침탈의 사실을 알고 있는 경우에만 청구할 수 있다. 즉 선의의 특정승계인에 대하여는 행사하지 못한다. 정답: ④

소유권

1

기본문제

01

다음 설명 중 정당한 것은?

- ① 토지의 소유권은 법률의 범위 내에서 토지의 상하에 미친다.
- ② 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물 중 공유하는 부분은 그의 공유로 본다.
- ③ 토지의 소유자는 이웃 토지로부터 자연히 흘러오는 물을 막을 수 있다.
- ④ 소유자는 법령의 범위 내에서 그 소유물을 사용·수익·처분할 권리가 있다.
- ⑤ 토지의 소유자는 매연·액체·열기체·음향·진동 기타 유사한 것으로 이웃 토지의 사용을 방해하거나, 이웃 거주자의 생활에 고통을 주지 아니하도록 적당한 조치를 취할 의무가 있다.

해설

⑤ 제217조 제1항

- ① 토지의 소유권은 정당한 이익이 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다(제212조).
- ② 공유로 추정한다(제215조 제1항).
- ③ 토지소유자는 이웃 토지로부터 자연히 흘러오는 물을 막지 못한다(제221조 제1항).
- ④ 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용·수익·처분할 권리가 있다(제211조). 정답: ⑤

제4장
기본문제

02

건물의 구분소유자 사이의 법률관계에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 구분소유자는 규약에 달리 정함이 없는 한 그 지분의 비율에 따라 공용부분의 관리비용 기타의 의무를 부담하고 공용부분에서 생기는 이익을 취득한다.
- ② 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여는 행사할 수 없다.
- ③ 각 공유자는 공용부분을 그 용도에 따라서 사용할 수 있다.
- ④ 구분소유권의 목적이 될 수 있는 전유부분도 규약에 의하여 공용부분으로 할 수 있다.
- ⑤ 공용부분에 대한 지분은 전유부분과 분리하여 처분할 수 없다.

해설

- ② 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여도 행사할 수 있다(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제18조).

집합건물의 공용부분은 전체 공유자의 이익에 공여하는 것이어서 공동으로 유지·관리해야 하고 그에 대한 적절한 유지·관리를 도모하기 위하여는 소요되는 경비에 대한 공유자 간의 채권은 이를 특히 보장할 필요가 있어 공유자의 특별승계인에게 그 승계여사의 유무에 관계없이 청구할 수 있도록 집합건물법 제18조에서 특별규정을 두고 있는바, 위 관리규약 중 공용부분 관리비에 관한 부분은 위 규정에 터잡은 것으로서 유효하다고 할 것이므로, 아파트의 특별승계인은 전 입주자의 채납관리비 중 공용부분에 관하여는 이를 승계하여야 한다고 봄이 타당하다(대법원 2001. 9. 20. 2001다8677 전원합의체).

- ③ 공용부분의 사용에 관하여는 각 구분소유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있다(동법 제11조).
- ④ 전유부분이지만 규약에 의해 공용부분으로 될 수 있는 바, 규약상 공용부분이 그것이다.
- ⑤ 공용부분의 공유지분권은 전유부분의 처분에 수반하며, 그 지분권만을 분리해서 처분하지 못한다(동법 제13조). 정답: ②

03 상린관계에 관한 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 토지 소유자와 이웃하는 건물 임차인과의 사이에는 상린관계의 규정이 적용되지 않는다.
- ② 지하시설을 하는 경우 경계로부터 두어야할 거리에 관한 사항 등을 정한 민법 제244조는 강행규정으로서 이와 다른 내용의 당사자 간의 특약은 무효이다.
- ③ 토지의 사용이나 주거자의 생활이 방해되는 경우 그 피해 소유자는 방해자에 대하여 방해 예방을 위한 시설의 설치와 함께 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.
- ④ 토지의 일부양도로 인해 공로에 통하지 못하는 토지가 생긴 경우 그 양수인에게는 무상의 주위토지통행권이 인정되지만, 판례에 따르면 이로 인한 무상통행권의 부담은 해당 토지가 특정승계인에게 양도됨으로써 원칙적으로 소멸한다.
- ⑤ 인접하여 토지를 소유한 자가 통상의 경계표나 담을 설치하는 경우 별다른 관습이나 특약이 없는 한 그 설치비용이나 측량비용은 쌍방이 절반하여 부담하며, 설치된 경계표등은 상린자의 공유로 추정된다.

해설

- ④ 분할 또는 토지의 일부 양도로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 생긴 경우에, 그 포위된 토지를 위한 통행권은 분할 또는 일부 양도 전의 종전토지에만 있고, 그 경우 통행에 대한 보상의 의무가 없다고 하는 「민법」 제220조의 규정은 직접 분할자, 일부 양도의 당사자 사이에만 적용되고, 포위된 토지 또는 피 통행지의 특정승계인의 경우에는 주위토지통행권에 관한 「민법」 제219조의 일반원칙으로 돌아가 통행권의 유무를 가려야 한다.
- ① 상린관계라 함은 서로 인접하는 부동산소유권의 상호이용을 조절하는 것을 목적으로 하는 법률관계를 말한다.
- ② 지하시설을 하는 경우에 있어서 경계로부터 두어야할 거리에 관한 사항 등을 규정한 민법 제244조는 강행규정이라고 볼 수 없으므로 이와 다른 내용의 당사자간의 특약을 무효라고 할 수 없다(대법원 1982.10.26. 80다1634).
- ③ 방해예방을 위한 시설의 설치나(또는) 손해배상의 담보를 청구할 수 있다(제214조).
- ⑤ 측량비용은 절반하여 부담하는 것이 아니라 토지 면적의 비례하여 부담한다(제237조 제2항).

정답: ④

04 다음의 지역권과 상린관계를 설명한 것 중에서 옳은 것은?

- ① 상린관계는 소유권과는 다른 독립된 권리인데 반하여, 지역권은 소유권의 내용이 되는 권리이다.
- ② 양자는 다 같이 인접한 토지와 토지와의 사이에 상호적 이용조절을 목적으로 하는 제도이다.
- ③ 지역권도 상린관계에서도 권리 불행사의 상태가 계속될 때에는 소멸시효에 의하여 소멸한다.
- ④ 지역권은 독립한 물건이기는 하지만 요역지소유권의 종된 권리이므로 요역지로부터 분리하여 지역권만을 양도할 수는 없으나 담보로 제공할 수는 있다.
- ⑤ 지역권은 개인 간의 계약에 의하여 설정되는 것이나, 상린관계는 법률의 규정에 의하여 당연히 발생한다.

해설

◎ 상린관계와 지역권의 비교

구 분	상린관계	지역권
성 질	소유권의 내재적 제한	독립한 용익물권
성 립	법률의 규정	법률행위
등 기	불필요	필요
관 계	부동산이용자와 이용자사이의 관계	두 개의 토지사이의 관계
소멸시효	걸리지 않음	걸림
인접관계	반드시 인접을 요함	인접을 요하지 않음

정답: ⑤

제4장
기본문제

05 다음은 주위토지통행권에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 주위토지통행권은 타인의 토지에 둘러싸여 공로로 통할 수 없는 경우뿐만 아니라 이미 기존의 통로가 있더라도 그것이 당해 토지의 이용에 부적합하여 실제로 통로로서 충분한 기능을 하고 있지 못한 경우에도 인정된다.
- ② 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 경우 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있으며 이때에도 보상의 의무가 있다.
- ③ 주위토지통행권은 통행지소유자의 점유를 배제할 권능까지 가지고 있지 않으며, 따라서 통행지 소유자는 통행지를 전적으로 점유하고 있는 통행권자에 대하여 토지의 인도를 청구할 수 있다.
- ④ 주위토지통행권은 공유토지의 직접분할자 또는 일부양도의 당사자 사이에만 적용되고 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인에게는 적용되지 않는다.
- ⑤ 이미 그 소유 토지의 용도에 필요한 통로가 있는 경우에는 그 통로를 이용하는 것보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 장소를 통행할 권리를 인정할 수 없다.

해설

- ② 보상 의무는 없다(제220조).
 ① 대법원 1998.3.10. 97다47118
 ③ 대법원 1993.8.24. 93다25479
 ④ 대법원 1990.8.28. 90다카10091
 ⑤ 대법원 1995.6.13. 95다1088 정답: ②

06 상린관계와 지역권에 관한 다음 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 상린관계는 법률의 규정에 의해서 형성되는 데 반하여, 지역권은 계약에 의해서 발생된다.
 ② 상린관계는 등기 없이도 성립하지만, 지역권의 성립을 위해서는 등기를 요한다.
 ③ 상린관계나 지역권은 인접한 부동산의 합리적인 이용을 목적으로 하는 것이므로 양자 모두 소멸시효에 걸리지 않는다.
 ④ 상린관계는 부동산뿐만 아니라 물의 이용을 그 대상으로 하는데 반하여, 지역권은 토지의 이용을 그 대상으로 한다.
 ⑤ 상린관계의 한 모습인 주위토지통행권의 목적은 지역권을 통해서도 실현될 수 있다.

해설

- ③ 지역권은 20년의 소멸시효에 걸린다. 정답: ③

07 부동산 시효취득에 관한 다음 기술 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 시효취득을 주장하는 점유자는 원칙적으로 시효기산점을 임의로 선택할 수 있다.
 ② 등기부취득시효에서 점유자의 무과실은 추정되지 않는다.
 ③ 점유취득시효에서 점유자는 시효완성 후에 등기명의를 취득한 자에게 시효취득을 주장할 수 있다.
 ④ 소유권취득의 효과는 점유를 개시한 때에 소급한다.
 ⑤ 국유재산 중 일반재산은 시효취득의 대상이 될 수 있다.

해설

소유권의 취득시효

부 동 산	점유취득시효	20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하고 등기함으로써 소유권을 취득한다. - 등기하면 점유개시시로 소급하여 소유권을 취득한다(원시취득). - 부동산의 일부에 대한 취득시효도 인정된다. - 등기명의인을 상대로 등기청구권을 행사한다. - 취득시효가 완성된 이후 제3자의 명의로 이전등기가 된 경우에는 그 자가 악의자라 하더라도 취득시효의 완성으로 대항하지 못한다. - 취득시효기간의 만료 전에 제3자의 명의로 이전등기가 된 경우라 하더라도 취득시효의 완성에는 영향을 미치지 않는다.
	등기부 취득시효	- 무권리자가 권리자로 등기되고 10년간 소유의 의사로 평온·공연·선의·무과실로 점유한 때에는 소유권을 취득한다. - 무과실은 추정되지 않으므로 취득시효를 주장하는 자가 증명하여야 한다. - 선의·무과실은 점유개시시에만 있으면 족하다(통설·판례).

정답: ③

08 부동산의 취득시효에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 자기 물건에 대한 시효취득은 불가능하다.
- ② 부동산을 소유의 의사를 가지고 점유한 경우에만 시효취득이 인정된다.
- ③ 등기부취득시효에 있어서 점유의 사실이 있으면 소유의 의사로 평온·공연하게 선의로 점유한 것으로 추정되나, 무과실은 추정되지 않으므로 취득시효를 주장하는 자가 입증책임을 진다.
- ④ 점유취득시효에서 점유자는 시효완성 후에 적법하게 소유권을 취득한 자에 대해서는 시효취득을 주장할 수 없다.
- ⑤ 시효취득기간의 완성 전에 부동산의 소유자가 변경된 경우에, 그 후 취득시효기간이 완성된 시효취득자는 새로운 소유자에게 취득시효를 주장할 수 있다.

해설

- ① 자기소유 부동산에 대한 시효취득도 인정된다. 정답: ①

09甲의 토지를 乙이 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하여 취득시효가 완성되었다. 그런데 乙이 甲에게 등기를 요구하자 甲은 그 부동산을 丙에게 처분하고 이전등기가 경료되었다. 이 경우 법률관계로 옳지 않는 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 乙은 부동산취득시효의 요건 중 일부는 구비하였으나 그의 앞으로 이전등기를 하여야 그 부동산에 대한 소유권을 취득한다.
- ② 만약 乙의 취득시효가 완성되기 전에 丙이 甲으로부터 등기명의를 넘겨받은 경우에, 그 후 취득시효가 완성되면 시효취득자 을은 丙에게 시효취득을 주장할 수 없다는 것이 판례의 태도이다.
- ③ 甲이 乙의 취득시효완성 사실을 알고 그 임야를 丙에게 처분한 경우, 乙은 甲에게 불법행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 판례의 태도에 따르면 만약 乙의 취득시효가 완성된 부동산이 수용되어 시효완성을 원인으로 하는 소유권이전등기의무가 이행불능이 된 경우에, 乙이 그 이행불능 전에 甲에게 취득시효를 주장하여 등기를 요구한 사정이 있으면 甲이 수령한 수용보상금에 대하여 乙은 대상청구권을 행사할 수 있다고 한다.
- ⑤ 丙이 乙의 취득시효완성 사실을 알고도 甲을 적극 권유하여 자기에 처분하게 한 경우에는 甲과 丙의 매매계약은 이중매매의 법리와 마찬가지로 민법 제103조에 의하여 무효가 될 것이다.

해설

- ② 취득시효기간 만료 전에 소유자가 제3자에게 목적물을 처분한 경우 이때는 제3자로서의 소유권등기 자체가 곧 취득시효의 종단을 가져오는 것으로 평가되지는 않으므로, 이 경우에도 취득시효기간 완성 후에 제3자를 상대로 취득시효를 원인으로 하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다(대법원 1976.3.9. 75다2220).
- ① 이전등기가 없는 한 시효완성자는 등기청구권이라는 채권적 청구권을 갖는 지위에 불과하다.

③⑤ 취득시효완성 후 소유자의 처분이 모두 불법이라고는 할 수 없으나, 이를 알고(이전등기청구를 받고)도 처분한 경우는 특별한 위법성 조각사유가 없는 한 불법이 된다(대법원 1994.4.12. 93다 60779).

④ 대법원 1994.12.9. 94다25025 정답: ②

10

甲이 乙 명의의 X토지에 대하여 점유취득시효기간을 완성한 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ㉠ 甲이 乙에게 X토지의 소유권이전등기를 청구한 후 乙이 그 토지를 丙에게 처분한 경우, 이는 乙이 자신의 소유권을 행사한 것이므로 乙은 甲에게 불법행위책임을 지지 않는다.
- ㉡ 甲이 아직 소유권이전등기를 하지 않고 있던 중, 丙이 취득시효가 완성하기 전에 마친 丙 명의의 가등기에 기하여 소유권이전의 본등기를 한 경우에도 甲은 丙에 대하여 시효취득을 주장할 수 있다.
- ㉢ 甲으로부터 X토지의 점유를 승계한 丁은 甲의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 丁에게 소유권이전등기를 청구하지 못한다.

① ㉠

② ㉢

③ ㉠, ㉡

④ ㉠, ㉢

⑤ ㉡, ㉢

해설

- ㉠ 甲이 乙에게 X토지의 소유권이전등기를 청구한 후 乙이 그 토지를 丙에게 처분한 경우, 이는 乙이 甲의 취득시효 완성사실을 알고서 처분한 것이므로 乙은 甲에게 불법행위책임을 진다.
- ㉡ 가등기에 기한 본등기시 물권변동의 효력은 본등기시 발생하므로, 丙의 소유권취득은 甲의 시효완성 이후에 해당하므로 甲은 丙에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다.
- ㉢ 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 丁에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다(대법원 1995.03.28. 93다47745 전원합의체).

정답: ③

11

부동산 점유취득시효에 기한 소유권취득 요건이 아닌 것은?

- ① 일정 기간 이상의 점유
- ② 무과실의 점유
- ③ 자주점유
- ④ 등기
- ⑤ 평온한 점유

해설

- ② 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 부동산을 점유한 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다(제245조 제1항). 부동산의 점유취득시효에서는 등기부취득시효와 달리 선의·무과실은 그 요건이 아니다. 정답: ②

12 부동산 취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 무과실은 점유취득시효의 요건이 아니다.
- ② 성명불상자의 소유물도 시효취득의 대상이 된다.
- ③ 점유취득시효가 완성된 후에는 취득시효 완성의 이익을 포기할 수 있다.
- ④ 행정재산은 시효취득의 대상이 아니다.
- ⑤ 압류는 점유취득시효의 중단사유이다.

해설

⑤ 압류는 점유취득시효의 중단사유에 해당하지 않는다. 정답: ⑤

13 점유취득시효에 관한 설명이다. 틀린 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 갑이 자기소유의 부동산을 을의 취득시효기간 만료 전에 병에게 양도한 경우 을은 취득시효완성 후 병에 대하여 소유권 이전등기를 청구할 수 있다.
- ② 갑이 자기소유의 부동산을 을의 취득시효 만료 후에 양도한 경우 을은 병에 대하여 소유권 이전등기를 청구할 수 없다.
- ③ 위 ②의 경우 을은 시효기간의 기산점을 자기 임의로 선택할 수 없다
- ④ 위 ②의 경우 병이 등기한 후 을이 다시 시효취득에 필요한 점유를 계속하면 병에 대하여 시효취득을 주장할 수 있다
- ⑤ 점유자가 취득시효 기간만으로 일단 소유권이전등기청구권을 취득하여도 그 후 점유를 상실하면 시효이익의 포기로 볼 수 없다 할지라도 그러한 등기청구권은 소멸한다.

해설

⑤ 점유자가 취득시효기간이 완성된 후에 점유를 상실하였다 하더라도 점유의 상실이 시효이익을 포기한 것이라고 인정되지 아니하는 한, 취득시효기간의 완성으로 인하여 이미 취득한 소유권이전등기 청구권은 소멸되지 아니한다(대법원 1992.11.13. 92다14083).

- ① 대법원 1977.8.23. 77다785
- ② 대법원 1986.8.19. 85다카2306
- ④ 대법원[전합] 1994.3.22. 93다46360 정답: ⑤

14 취득시효에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 우리 민법은 부동산에 대해서 등기부취득시효와 점유취득시효를 모두 인정하고 있다.
- ② 부동산의 등기부취득시효를 주장하려면 당해 부동산의 소유자로 등기된 기간과 당해 부동산의 점유기간이 모두 10년 이상이어야 한다는 것이 판례이다.
- ③ 국유재산도 일정한 경우에는 시효취득이 가능하다.
- ④ 자기물건에 대한 시효취득도 가능하다.
- ⑤ 판례는 소유자의 변동이 없는 경우에는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있다고 본다.

해설

- ② 지문은 종래 판례(대법원[전합] 1985. 1.29. 83다카1730)의 태도이다. 현재의 판례의 태도에 따르면, 반드시 시효취득자의 명의로 10년간 등기되어 있어야 하는 것이 아니며 전소유자 명의의 등기기간을 합쳐 10년이면 족하다고 한다(대법원[전합] 1989.12.26. 87다카2176). 즉 등기의 승계를 인정한다.
- ① 제245조
- ③ 국유재산법 제5조 제2항에 따르면 국유재산에 대해서는 시효취득을 배제하고 있다. 그러나 국유재산 가운데 행정재산이나 보존재산이 아닌 사적 거래를 할 수 있는 잡종재산(現 일반재산)에 대해서는 취득시효가 인정된다(헌재결 1991.5.13. 89헌가97 참조).
- ④ 통설과 판례의 태도이다.
- ⑤ 시효기간만료 후에 이해관계가 대립되는 제3자가 존재하지 않을 경우에는 시효이익을 주장하는 자가 취득시효의 기산점을 임의로 주장하여도 무방하다(대법원 1992.9.8. 92다20941·20958).

정답: ②

15 다음 중 부동산 점유취득시효에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 부동산에 대한 점유취득시효가 완성된 후 이를 등기하지 않고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 경료되어 점유자가 그 제3자에게 시효취득으로 대항할 수 없게 된 경우, 점유자가 취득시효완성 당시의 소유자에 대한 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권을 상실하게 된다.
- ② 부동산에 대한 점유취득시효가 완성된 후 이를 등기하지 않고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 경료된 후 어떠한 사유로 취득시효완성 당시의 소유자에게로 소유권이 회복되면 그 소유자에게 시효취득의 효과를 주장할 수 있다.
- ③ 취득시효완성 후에 원소유자가 일시 상실하였던 소유권을 회복한 것이 아니라 그 상속인이 소유권 이전등기를 마쳤을 뿐인 경우에는 특별한 사정이 없는 한, 그 상속인은 점유자에 대한 관계에서 종전 소유자와 같은 지위에 있는 자로 볼 수 없어 그에 대하여는 취득시효의 완성으로 대항할 수 없다.
- ④ 부동산의 취득시효에 있어 시효기간의 경과를 계산하기 위한 기산점은 그 부동산에 대한 소유명의자가 동일하고 그 변동이 없는 경우가 아니라면 원칙적으로 시효취득의 기초가 되는 점유가 개시된 시점이 기산점이 된다.
- ⑤ 취득시효 완성 후 토지소유자에 변동이 있어도 소유자가 변동된 시점을 새로운 기산점으로 삼아 다시 취득시효의 점유기간이 완성되는 경우에도 소유권 변동시를 새로운 취득시효의 기산점으로 삼을 수 있다.

해설

- ①② 부동산에 대한 점유로 인한 소유권취득시효가 완성되었다 하더라도 이를 등기하지 않고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자에게로 소유권이전등기가 경료되면 점유자가 그 제3자에게는 그 시효취득으로 대항할 수 없으나, 그로 인하여 점유자가 취득시효완성 당시의 소유자에 대한 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권을 상실하게 되는 것은 아니고 위 소유자의 점유자에 대한 소유권이전등기무가 이행불능으로 된 것이라고 할 것인데, 그 후 어떠한 사유로 취득시효완성 당시의 소유자에게로 소유권이 회복되면 그 소유자에게 시효취득의 효과를 주장할 수 있다(대법원 1991.6.25. 90다14225).

- ## 제4장 기본문제

17 부동산의 점유취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다.
- ② 시효완성을 이유로 한 소유권취득의 효력은 점유를 개시한 때로 소급하지 않으며 등기를 함으로써 장래를 향하여 발생한다.
- ③ 점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위가 없다는 사실을 알면서 타인 소유의 토지를 무단점유한 것이 증명된 경우, 그 토지 소유권의 시효취득은 인정되지 않는다.
- ④ 시효완성자는 취득시효의 기산점과 관련하여 점유기간을 통틀어 등기명의인이 동일한 경우에는 임의의 시점을 기산점으로 할 수 있다.
- ⑤ 시효이익의 포기는 특별한 사정이 없는 한, 시효취득자가 취득시효완성 당시의 진정한 소유자에 대하여 하여야 한다.

해설

- ② 등기를 하면 점유를 개시한 때에 소급하여 그 부동산의 소유권을 원시적으로 취득한다(제247조 제1항). 정답: ②

18 다음 첨부에 관한 기술 중 타당하지 못한 것은?

- ① 민법상 첨부로 인한 소유권의 소멸과 그에 따른 제3자의 권리보호조항은 임의규정이다.
- ② 첨부로 인한 소유권의 귀속결정에 관한 민법은 임의규정이다.
- ③ 첨부로 인하여 어떤 동산의 소유권이 소멸된 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리도 소멸되지만 보상은 청구할 수 있다.
- ④ 부동산에 권원에 의해 동산을 부합시킨 경우에 그 동산이 부동산과 일체를 이루는 구성부분이 된 경우라면 그 동산의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다.
- ⑤ 동산과 동산이 혼합하여 식별할 수 없는 경우에는 동산간의 부합에 관한 규정을 준용한다.

해설

- ① 첨부로 인한 소유권 귀속관계를 정한 민법의 규정은 임의규정이나, 분리금지규정과 제3자 보호규정은 강행규정이다.
④ 제256조
⑤ 제257조 정답: ①

19

甲소유의 X토지를 乙이 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하여 취득시효기간이 만료되었으나, 乙은 그 등기를 하지 않았다. 그 후 甲은 丙과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙의 소유권이전등기 완료 후에도 乙의 평온·공연한 자주점유가 20년 이상 계속되었다면 乙은 丙에 대하여 취득시효의 완성을 주장할 수 있다.
- ② 甲·丙 간의 토지매매계약은 원칙적으로 유효하므로 丙이 X토지에 대한 소유권이전등기를 완료하였다면 그 토지의 소유권을 취득할 수 있다.
- ③ 乙이 甲에게 소유권이전등기를 청구한 후 甲이 X토지를 丙에게 매도하여 이전등기까지 경료해 준 경우, 乙은 甲에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 만약 丙이 甲의 배임행위에 적극 가담하여 乙에 대한 소유권이전등기 의무를 불가능하게 하였다면 丙은 소유권을 취득하지 못한다.
- ⑤ X토지가 미등기부동산인 경우에는 소유권이전등기가 불가능하므로 乙은 취득시효의 완성만으로 등기 없이도 소유권을 취득할 수 있다.

해설

- ⑤ X토지가 미등기부동산인 경우에도 점유자 乙은 점유취득시효를 원인으로 소유권을 취득하려면 등기를 하여야 X토지에 대한 소유권을 취득할 수 있다(제245조 제1항). 정답: ⑤

20

다음 첨부에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산 간의 부합도 인정하는 것이 판례이다.
- ② 부동산과 동산의 부합의 경우 부합하는 동산의 가액이 부동산의 가액을 초과하는 때에는 동산의 소유자에게 부동산의 소유권이 귀속한다.
- ③ 동산의 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.
- ④ 부동산에 권원에 의해 동산을 부합시킨 경우에 그 동산이 부동산과 일체를 이루는 구성부분이 된 경우라면 그 동산의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다.
- ⑤ 타인의 토지상에 권원 없이 식재한 수목의 소유권은 토지의 소유자에게 귀속한다.

해설

- ② 부동산소유자가 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득하는 것이므로 부합하는 물건의 가격이 부동산의 가격을 초과하더라도 부동산소유자가 부합한 물건의 소유권을 취득한다는 것이 판례이다.
③ 제259조 제1항 단서 정답: ②

21 공유에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 공유물의 분할청구는 법원에 할 수도 있다.
- ② 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있는 것이 원칙이다.
- ③ 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다.
- ④ 공유자는 그 지분을 처분하자면 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다.
- ⑤ 공유물을 처분하자면 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다.

해설

㉠ 공유, 합유, 총유의 비교

구분 \ 형태	공 유	합 유	총 유
소유형태	수인의 소유	조합재산	권리능력 없는 사단재산
색 채	개인주의	개인주의+단체주의	단체주의
지 분 권	있음	있음	없음
지분처분	자유	전원의 동의	지분의 부존재로 처분불가
보존행위	각자 단독	각자 단독	사원총회의 결의
사용·수익	지분의 비율	합유물 전부에 미침	정관 기타 규약에 따름
변경·처분	전원의 동의	전원의 동의	사원총회의 결의
관리행위	지분의 과반수	조합계약 또는 규약	사원총회의 결의
분할청구	자유이나 5년 내의 범위에서 불분할특약을 맞을 수 있다.	불가	불가
종료사유	▪ 공유물의 양도 ▪ 분할	▪ 조합체의 해산 ▪ 합유물의 양도	총유물의 양도

정답: ④

22 공유에 관한 다음의 설명 중에서 틀린 것은?

- ① 공유물의 관리비용 기타의 의무는 공유지분의 비율로 부담한다.
- ② 공유물의 이용개량에 관해서는 공유자의 지분의 과반수로서 정한다.
- ③ 각 공유자는 그의 지분을 양도하고 담보로 제공하고 또는 포기하는 등의 자유를 가진다.
- ④ 분할의 효과는 공동상속재산분할의 경우를 제외하고 소급하지 않는다.
- ⑤ 부동산공유의 경우에는 지분상에 저당권이나 지상권도 설정할 수 있다.

해설

⑤의 경우 저당권은 점유를 수반하지 않으므로 가능하나 지상권은 허용되지 않는다.

- ① 제266조
- ② 제265조
- ③ 제263조
- ④ 제1015조 정답: ⑤

23 공유물에 관한 다음 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 공유물의 관리비용은 각 공유자가 그 지분의 비율로 부담한다.
- ② 공유물을 처분하는 데는 공유자 전원의 동의가 있어야 한다.
- ③ 공유자가 약정으로 일정기간 분할을 금지할 수 있다.
- ④ 공유자가 그 지분을 양도하는 데는 다른 공유자의 동의가 있어야 한다.
- ⑤ 각 공유자는 단독으로 보존행위를 할 수 있다.

해설

- ④ 공유자에게는 지분처분의 자유가 있으므로 공유자가 그 지분을 양도하는 데는 다른 공유자의 동의를 요하지 않는다.
- ① 제266조 제1항 ⑤ 제265조
- ② 공유물의 처분 또는 변경은 공유자 전원의 동의가 있어야 한다(제264조).
- ③ 공유자는 자유롭게 분할을 청구할 수 있는 것이 원칙이다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할 금지 약정을 할 수 있다(제268조 제1항). 정답: ④

24 공유에 관하여 옳은 것은?

- ① 공유자의 1인이 상속인 없이 사망하였을 때에는 그 지분은 무주재산이 되어 국고에 귀속한다.
- ② 제3자가 공유물의 점유를 박탈하였을 때에는 공유자의 1인은 지분을 가지고 단독으로 전부의 반환을 청구할 수 있다.
- ③ 공유물에 대하여 제3자의 침해가 있을 때에는 각 공유자는 단독으로 공유물전부에 대하여 방해의 배제를 청구할 수 없다.
- ④ 공유물의 관리 및 변경에 관하여는 각 공유자의 지분의 가격에 따라 과반수로서 결정한다.
- ⑤ 각 공유자는 5년 내에 한하여 공유물의 분할을 청구할 수 있다.

해설

1. 지분의 비율과 탄력성

지분의 비율	▪ 의사표시 또는 법률의 규정에 따라 결정된다. ▪ 불명(不明)시에는 균등한 것으로 추정한다.
지분의 탄력성	공유자 중 1인이 상속인 없이 사망하거나, 자기 지분을 포기한 경우에는 그 자의 지분은 다른 공유자의 지분 비율로 귀속한다.

2. 공유의 외부관계

지분의 대외적 주장	▪ 단독으로 지분확인 소 및 지분등기청구권을 행사할 수 있다. ▪ 제3자의 점유 침탈시에는 지분에 기인하여 단독으로 반환청구를 행사할 수 있다. ▪ 제3자의 방해 시에는 단독으로 공유물전부에 대한 방해제거를 청구할 수 있다.
------------	---

3. 공유물의 분할

분할의 자유	- 원칙 : 분할청구는 자유 - 예외 : 불분할특약 가능(5년 범위 내)
분할의 방법	- 공유물분할청구권은 일종의 형성권 - 원칙 : 협의분할 - 예외 : 재판상 분할(형성의 소) - 원칙 : 현물분할 - 예외 : 대금분할, 가격배상에 따른 분할(협의분할)
분할의 효과	- 분할로 각 공유자는 단독소유자가 된다. - 분할로 어떤 공유자가 취득한 부분에 하자가 있을 때에는 다른 공유자는 매매에 있어서의 매도인의 담보책임을 진다.

정답: ②

25 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 공유자의 동의 없이 공유지분을 임의로 처분하지 못한다.
- ② 제3자가 공유물에 대하여 침해를 한 때에는 각 공유자는 단독으로 공유물 전부에 대한 방해의 제거를 청구할 수 있다.
- ③ 공유자는 그 지분의 비율로 조세를 부담한다.
- ④ 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 특별한 사유가 없는 한 각 공유자가 지분에 대응하는 비율의 한도 내에서만 이를 행사할 수 있다.
- ⑤ 공유자 중 한 사람이 그의 지분을 포기한 경우, 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다.

해설

- ① 제263조
- ② 각 공유자는 그의 지분에 기해 단독으로 공유물 전부에 대한 방해의 제거를 청구할 수 있다.
- ③ 제266조
- ④ 대법원 1970.4.14, 70다171
- ⑤ 제267조 정답: ①

26

甲, 乙, 丙은 각각 4/7, 2/7, 1/7의 비율로 1필의 토지를 공유하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 丙은 甲이나 乙의 동의 없이도 자신의 지분을 타인에게 양도할 수 있다.
- ② 甲은 위 토지의 임대를 결정함에 있어 다른 공유자의 동의없이도 단독으로 결정할 수 있다.
- ③ 乙이나 丙은 甲으로부터 토지의 사용·수익을 허락받은 점유자에 대하여 그 점유의 배제나 부당이득반환을 청구할 수 없다.
- ④ 위 토지에 대하여 丁 명의의 원인무효의 소유권이전등기가 경료된 경우, 乙은 丁에 대하여 그 등기 전부의 말소를 청구할 수 있다.
- ⑤ 甲의 지분 위에 설정되어 있던 저당권은 토지가 분할되면 甲이 분할 받은 토지 위로 그 효력이 집중된다.

해설

- ⑤ 甲, 乙의 공유인 부동산 중 甲의 지분 위에 설정된 근저당권 등 담보물권은 특단의 합의가 없는 한 공유물분할이 된 뒤에도 종전의 지분비율대로 공유물 전부의 위에 그대로 존속하고, 근저당권 설정자인 甲 앞으로 분할된 부분에 당연히 집중되는 것은 아니다(대법원 1989.8.8, 88다카24868).
- ①②③ 과반수 지분의 공유자는 다른 공유자와 사이에 미리 공유물의 관리방법에 관한 합의가 없었 다 하더라도 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있으므로, 과반수 지분의 공유자로부터 사용·수익을 허락받은 점유자에 대하여 소수 지분의 공유자는 그 점유자가 사용·수익하는 건물의 철거나 퇴거 등 점유배제를 구할 수 없다(대법원 2002.5.14, 2002다9738).
- ④ 부동산의 공유자의 1인은 당해 부동산에 관하여 제3자 명의로 원인무효의 소유권이전등기가 경료 되어 있는 경우 공유물에 관한 보존행위로서 제3자에 대하여 그 등기 전부의 말소를 구할 수 있다 (대법원 1993.5.11., 92다52870). 정답: ⑤

제4장
기본문제

27

합유에 관한 다음 기술 중 옳은 것은?

- ① 합유물의 처분에는 합유자 전원의 동의를 요하나, 그 변경에는 그것을 요하지 않는다.
- ② 합유자의 지분은 합유물 전부에 미친다.
- ③ 합유물에 대한 지분의 처분에는 합유자 전원의 동의가 필요 없다.
- ④ 합유자는 합유물의 분할청구를 자유로 할 수 있다.
- ⑤ 합유물의 보존행위에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다.

해설

- ① 합유물의 변경 역시 합유자 전원의 동의를 요한다.
- ③ 전원의 동의를 요한다.
- ④ 분할청구권이 인정되지 않는다.
- ⑤ 보존행위는 각자가 단독으로 행할 수 있다. 정답: ②

28

다음 보기는 합유에 대한 설명이다. 틀린 것을 모두 고르시오.

- ㉠ 합유는 수인이 조합체를 이루어 물건을 소유하는 공동소유의 한 형태이다.
- ㉡ 합유자의 권리는 합유물의 지분에만 미친다.
- ㉢ 합유물을 처분 또는 변경하는 것은 합유자 전원의 동의가 있어야 한다.
- ㉣ 합유지분의 처분은 합유자가 단독으로 할 수 있다.
- ㉤ 조합이 존속하고 있는 동안에도 각 합유자는 합유물의 분할을 청구할 수 있다.
- ㉥ 합유관계가 종료하는 것은, 합유물의 양도로 조합재산이 없게 되는 때와 조합자체의 해산이 있게 되는 때이다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉢, ㉣, ㉥
- ④ ㉡, ㉣, ㉥
- ⑤ ㉣, ㉥

해설

- ④ ㉠ 제271조 제1항
- ㉡ 합유자의 권리는 합유물 전부에 미친다(제271조 제1항 후단).
- ㉢ 제272조 본문
- ㉣ 합유자는 전원의 동의 없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다(제273조 제1항). 합유자는 합유물의 분할을 청구하지 못한다(제273조 제2항).
- ㉥ 제274조 제1항 정답: ④

29

총유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 비법인사단이 총유물에 관한 매매계약을 체결하는 행위는 총유물의 처분행위가 아니다.
- ② 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물의 관리, 처분행위가 아니다.
- ③ 총유물의 보존행위는 특별한 사정이 없는 한 구성원이 단독으로 결정할 수 없다.
- ④ 비법인사단의 대표자는 총유재산에 관한 소송에서 단독으로 당사자가 될 수 없다.
- ⑤ 비법인사단인 주택조합이 주체가 되어 신축 완공한 건물로서 일반에게 분양되는 부분은 조합원 전원의 총유에 속한다.

해설

- ① 총유물에 관한 매매계약을 체결하는 행위는 총유물의 처분행위에 해당한다. 정답: ①

30

토지소유권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지의 소유권은 정당한 이익있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다.
- ② 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 토지의 구성부분이 아니다.
- ③ 토지가 해면 아래에 잠김으로써 포락될 당시를 기준으로 원상복구가 불가능한 상태에 이르면 종전의 소유권은 영구히 소멸된다.
- ④ 토지등기부의 표제부에 토지의 면적이 실제와 다르게 등재되어 있으면, 이러한 등기는 해당 토지를 표상하는 등기로서 효력이 없다.
- ⑤ 토지 1필지의 공간적 범위를 특정하는 것은 지적도나 임야도의 경계이지 등기부의 표제부나 임야대장·토지대장에 등재된 면적이 아니다.

해설

- ④ 토지등기부의 표제부에 토지의 면적이 실제와 다르게 등재되어 있더라도 이러한 등기는 해당 토지를 표상하는 등기로서 효력이 인정된다. 정답: ④

31

소유권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 공인중개사]

- ① 기술적 착오로 지적도상의 경계선이 진실한 경계선과 다르게 작성된 경우, 그 토지의 경계는 실제의 경계에 따른다.
- ② 토지가 포락되어 원상복구가 불가능한 경우, 그 토지에 대한 종전 소유권은 소멸한다.
- ③ 타인의 토지를 통과하지 않으면 필요한 수도를 설치할 수 없는 토지의 소유자는 그 타인의 승낙 없이도 수도를 시설할 수 있다.
- ④ 포워된 토지가 공로에 접하게 되어 주위토지통행권을 인정할 필요성이 없어진 경우에도 그 통행권은 존속한다.
- ⑤ 증축된 부분이 기존의 건물과 구조상·이용상 독립성이 없는 경우, 그 부분은 기존의 건물에 부합한다.

해설

- ④ 포워된 토지가 공로에 접하게 되어 주위토지통행권을 인정할 필요성이 없어진 경우에는 그 통행권은 소멸한다. 정답: ④

제4장
기본문제

32

부동산 점유취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 취득시효가 완성되었으나 아직 소유권이전등기를 경료하지 않은 시효완성자에 대하여 소유자는 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다.
- ② 시효기간 중 목적부동산이 제3자에게 양도되어 등기가 이전된 경우, 시효기간 만료시 그 양수인을 상대로 시효취득을 주장할 수 있다.
- ③ 소유자가 시효완성 사실을 알고 목적부동산을 제3자에게 처분하고 소유권이전등기를 넘겨준 경우, 소유자는 시효완성자에게 불법행위로 인한 손해배상책임을 진다.
- ④ 시효완성자는 취득시효의 기산점과 관련하여 점유기간을 통틀어 등기명의인이 동일한 경우에는 임의의 시점을 기산점으로 할 수 있다.
- ⑤ 소유자가 시효완성 사실을 알고 목적부동산을 제3자에게 처분한 경우, 소유자는 시효완성자에게 채무불이행으로 인한 손해배상책임을 진다.

해설

- ⑤ 부동산 점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산 소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권·채무관계가 성립하는 것은 아니므로, 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행 책임을 물을 수 없다(대법원 1995.07.11. 94다4509). 정답: ⑤

33

부동산 소유권의 점유취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 시효완성자는 취득시효완성에 따른 등기를 하지 않더라도 시효완성 당시의 등기명의인에 대하여 취득시효를 주장할 수 있다.
- ② 취득시효가 완성되기 전에 등기명의인이 바뀐 경우에는 시효완성자는 취득시효완성 당시의 등기명의인에게 취득시효를 주장할 수 있다.
- ③ 취득시효완성 후 등기명의인이 변경되면 설사 등기원인이 취득시효 완성 전에 존재하였더라도, 시효완성자는 변경된 등기명의인에게 취득시효를 주장할 수 없다.
- ④ 취득시효기간이 진행되는 중에 등기명의인이 변동된 경우, 취득시효기간의 기산점을 임의로 선택하거나 소급하여 20년 이상 점유한 사실만을 내세워 시효완성을 주장할 수 없다.
- ⑤ 취득시효완성 후 등기명의인이 바뀐 경우, 등기명의가 바뀐 시점으로부터 다시 취득 시효기간이 경과하더라도 취득시효완성을 주장할 수 없다.

해설

- ⑤ 부동산에 대한 점유취득시효가 완성된 후 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기를 하지 않고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 경료된 경우라 하더라도 당초의 점유자가 계속 점유하고 있고 소유자가 변동된 시점을 기산점으로 삼아도 다시 취득시효의 점유기간이 경과한 경우에는 점유자로서는 제3자 앞으로의 소유권 변동시를 새로운 점유취득시효의 기산점으로 삼아 2차의 취득시효의 완성을 주장할 수 있다(대법원 2009.07.16. 2007다15172 전원 합의체). 정답: ⑤

34

공동소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물의 관리·처분행위이므로 사원 총회의 결의를 요한다.
- ② 토지 공유자의 공유지분 포기에 따른 등기는 해당 지분에 관하여 다른 공유자 앞으로 소유권 이전등기를 하는 형태가 되어야 한다.
- ③ 합유물에 관하여 경료된 무효의 소유권이전등기 말소청구는 특별한 사정이 없는 한, 합유자 각자가 할 수 있다.
- ④ 공유물분할의 소는 공유자 전원이 소송당사자로 참여해야 하므로, 공동소송인 중 1인에 소송 요건의 흠결이 있는 경우 전 소송이 부적법하게 된다.
- ⑤ 과반수지분권자로부터 공유토지의 특정부분의 점유를 허락받은 제3자는 소수지분권자에 대해서 그 점유로 인한 이득을 부당이득으로 반환할 필요가 없다.

해설

- ① 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물 그 자체의 관리·처분이 따르지 아니 하는 단순한 채무부담행위에 불과하여 이를 총유물의 관리·처분행위라고 볼 수는 없다. 따라서 비 법인사단인 재건축조합의 조합장이 채무보증계약을 체결하면서 조합규약에서 정한 조합 임원회의 결의를 거치지 않았거나 조합원총회 결의를 거치지 않았다 하더라도 그것만으로 바로 그 보증 계약이 무효라고 할 수는 없다(대법원 2007.04.19. 2004다60072 전원합의체). 정답: ①

제4장
기본문제

35

부동산 등기부취득시효의 요건이 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유자의 등기취득에 대한 선의·무과실
- ② 10년간의 점유
- ③ 자주점유
- ④ 평온·공연한 점유
- ⑤ 10년간의 등기

해설

- ① 등기부취득시효에서 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유 취득에 관한 것이다(대법원 2004.06.25. 2004다13052). 정답: ①

01 토지소유권의 범위와 효력에 관한 설명 중 틀린 내용의 것은?

- ① 토지의 소유권은 토지의 상하에 미치나 한계가 있다.
- ② 토지의 소유권의 범위는 지적공부상의 경계에 의하여 확정하여야 할 것이나, 기술적 착오로 말미암아 지적도상의 경계선이 진실의 경계선과 다르게 작성된 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 그 토지의 경계는 실제의 경계에 의하여야 한다.
- ③ 지표면의 수직하에 있는 지하수, 광물 등은 원칙적으로 정당한 이익의 범위 내에 속하므로 토지소유권의 효력이 미친다.
- ④ 토지소유자는 그 소유권의 범위 내에서 사용, 수익, 처분의 권능을 가지며 타인의 침해나 방해를 배제할 수 있다.
- ⑤ 토지소유자는 타인으로 하여금 지상 또는 지하의 공간을 상하의 범위로 정하여 건물 기타 공작물을 소유할 것을 허락할 수 있다.

해설

- ③ 동굴, 지하수에는 깊이 여하를 묻지 않고 토지소유권의 효력이 미치지만 광업권의 객체인 광물(광업법 제2조·제3조), 매장물(제254조)에 대하여는 미치지 않는다.
- ① 제212조
- ② 지적공부에 등록된 각 필지에 있어 그 토지의 소재, 지번, 지목, 지적, 경계는 등록으로 특정되므로 인접한 토지 사이의 경계의 확정을 구하는 소송에서의 경계를 확정함에 있어서도 지적도가 기술적 착오로 잘못 작성되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 지적도상의 경계에 의하여야 한다(대법원 1993.10.8. 92다44503).
- ④ 제211조, 제213조, 제214조
- ⑤ 제289의 2 정답: ③

02 소유권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 소유자는 법률의 범위 내에서 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다.
- ② 지적공부에 등록된 토지의 소유권 범위는 특별한 사정이 없는 한, 지적공부상 경계에 의하여 확정된다.
- ③ 구분소유는 구분행위가 행해지고 건물이 완성되었더라도 집합건축물대장의 등록이나 구분건물의 표시에 관한 등기가 완료된 때에 성립한다.
- ④ 구분소유권의 객체로서 적합한 물리적 요건을 갖추지 못한 건물의 일부가 구분소유권의 목적으로 등기되었더라도 구분소유권은 인정되지 않는다.
- ⑤ 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 다른 사정이 없는 한, 습득자가 그 소유권을 취득한다.

해설

- ③ 1동의 건물에 대하여 구분소유가 성립하기 위해서는 객관적·물리적인 측면에서 1동의 건물이 존재하고, 구분된 건물부분이 구조상·이용상 독립성을 갖추어야 할 뿐 아니라, 1동의 건물 중 물리적으로 구획된 건물부분을 각각 구분소유권의 객체로 하려는 구분행위가 있어야 한다. 여기서 구분행위는 건물의 물리적 형질에 변경을 가함이 없이 법률관념상 건물의 특정 부분을 구분하여 별개의 소유권의 객체로 하려는 일종의 법률행위로서, 그 시기나 방식에 특별한 제한이 있는 것은 아니고 처분권자의 구분의사가 객관적으로 외부에 표시되면 인정된다. 따라서 구분건물이 물리적으로 완성되기 전에도 건축허가신청이나 분양계약 등을 통하여 장래 신축되는 건물을 구분건물로 하겠다는 구분의사가 객관적으로 표시되면 구분행위의 존재를 인정할 수 있고, 이후 1동의 건물 및 그 구분행위에 상응하는 구분건물이 객관적·물리적으로 완성되면 아직 그 건물이 집합건축물 대장에 등록되거나 구분건물로서 등기부에 등기되지 않았더라도 그 시점에서 구분소유가 성립한다(대법원 2013.01.17. 2010다71578 전원합의체). 정답: ③

03 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 점유보조자에게는 점유보호청구권이 인정되지 않는다.
- ② 무주의 부동산은 무주물선점의 대상이 되지 않는다.
- ③ 타인의 토지에서 발견한 매장물은 토지 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다.
- ④ 설립등기된 법인은 총유의 형태로 부동산을 소유한다.
- ⑤ 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.

해설

- ④ 설립등기가 된 법인은 당연히 법인격이 있으므로 그 법인의 단독소유로 본다. 정답: ④

제4장
실전문제

04 주위토지통행권에 관한 판례의 태도로서 틀린 것은?

- ① 민법상 주위토지통행권은 이미 기존의 통로가 있더라도 그것이 당해 토지이용에 부적합하여 실제 통로로서 충분한 기능을 하지 못하고 있는 경우에도 인정된다.
- ② 토지소유자의 적법한 건축행위가 인접 민간 지상파 방송사업자의 방송을 위한 전파송신에 영향을 미친 경우, 민간 지상파 방송사업자로서는 그 비용 부담하에 그 인접의 토지소유자 등의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여 인접 토지상에 건축된 건축물에 방송 송신에 필요한 시설을 설치할 수 있고, 인접 토지소유자등은 이를 용인할 의무가 있다.
- ③ 토지의 이용방법에 따라서는 자동차 등이 통과할 수 있는 통로의 개설도 허용될 수 있다.
- ④ 주위토지통행권에 관련하여 동시분할로 인한 때에도 수분양자간에 무상의 주위토지통행권이 인정된다. 따라서 토지의 직접분할자 또는 일부양도의 당사자뿐만 아니라 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인에게도 적용된다.
- ⑤ 어느 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우, 그 토지소유자가 주위의 토지를 통행 또는 통로로 하지 않으면 공로에 전혀 출입할 수 없는 경우뿐만 아니라 과도한 비용을 요하는 때에도 인정될 수 있다.

해설

- ④ 민법 제220조의 규정은 직접 분할자, 일부 양도의 당사자 사이에만 적용되고, 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인의 경우에는 주위토지통행권에 관한 민법 제219조의 일반원칙으로 돌아가 통행권의 유무를 가려야 한다(대법원 1996.11.29. 96다3440).
- ① 대법원 1998.3.10. 97다47118
② 대법원 2003.11.28. 2003다43322
③ 대법원 1994.10.21. 94다16076
⑤ 제219조 정답: ④

05 주위토지통행권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 주위토지통행권이 발생한 후 그 토지에 접하는 공로가 개설됨으로써 이를 인정할 필요성이 없어진 때에는 주위토지통행권이 소멸한다.
② 토지의 용도에 필요한 통로가 있는 경우에는 그 통로를 사용하는 것보다 더 편리하다는 이유만으로 주위토지통행권을 인정할 수는 없다.
③ 주위토지통행권의 본래적 기능 발휘를 위해서 그 통행에 방해가 되는 축조물은 적법하게 설치되었던 것이라 하더라도 철거되어야 한다.
④ 특별한 사정이 없는 한 주위토지통행권이 성립한 경우, 통행권자는 통행지소유자의 손해를 보상하여야 한다.
⑤ 토지사용권이 없는 명의신탁자에게도 주위토지통행권이 인정된다.

해설

- ⑤ 민법 제219조에 정한 주위토지통행권은 인접한 토지의 상호이용의 조절에 기한 권리로서 토지의 소유자 또는 지상권자, 전세권자 등 토지사용권을 가진 자에게 인정되는 권리이다. 따라서 명의 신탁자에게는 주위토지통행권이 인정되지 아니한다(대법원 2008.05.08. 2007다22767). 정답: ⑤

06 주위토지통행권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지의 분할 및 일부양도의 경우, 무상주위통행권에 관한「민법」의 규정은 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인에게 적용되지 않는다.
② 주위토지통행권은 이를 인정할 필요성이 없어지면 당연히 소멸한다.
③ 기존의 통로가 있더라도 당해 토지의 이용에 부적합하여 실제로 통로로서 충분한 기능을 하지 못하고 있는 경우에도 주위토지통행권이 인정된다.
④ 통행지소유자는 주위토지통행권자의 허락을 얻어 사실상 통행하고 있는 자에게는 그 손해의 보상을 청구할 수 없다.
⑤ 주위토지통행권이 인정되는 도로의 폭과 면적을 정함에 있어서, 「건축법」에 건축과 관련하여 도로에 관한 폭 등의 제한규정이 있으면 이에 따라 결정하여야 한다.

해설

- ⑤ 주위토지통행권은 공로와의 사이에 그 용도에 필요한 통로가 없는 토지의 이용이라는 공익목적을 위하여 피통행지 소유자의 손해를 무릅쓰고 특별히 인정되는 것이므로, 그 통행로의 폭이나 위치 등을 정함에 있어서는 피통행지의 소유자에게 가장 손해가 적게 되는 방법이 고려되어야 하고, 어느 정도를 필요한 범위로 볼 것인가는 구체적인 사안에서 사회통념에 따라 쌍방 토지의 지형적·위치적 형상과 이용관계, 부근의 지리상황, 상린지 이용자의 이해득실 기타 제반 사정을 기초로 판단하여야 한다(대법원 2009.06.11. 2008다75300). 정답: ⑤

07

주위토지통행권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 통행권자가 통행지 소유자에게 손해보상의 지급을 게을리 하면 통행권이 소멸한다.
② 주위토지통행권의 범위는 현재의 토지의 용법은 물론 장래의 이용 상황도 미리 대비하여 정해야 한다.
③ 통행권자가 통행지를 배타적으로 점유하는 경우 통행지 소유자는 통행지의 인도를 청구할 수 있다.
④ 주위토지통행권이 인정되는 경우 통행지 소유자는 원칙적으로 통로개설 등 적극적인 작위의무를 부담한다.
⑤ 동일인 소유의 토지의 일부가 양도되어 공로에 통하지 못하는 토지가 생긴 경우, 포위된 토지를 위한 통행권은 일부 양도 전의 양도인 소유의 종전 토지뿐만 아니라 다른 사람 소유의 토지에 대하여도 인정된다.

제4장
실전문제

해설

- ③ 다른 사람의 토지에 대하여 상린관계로 인한 통행권을 가지는 사람은 그 통행권의 범위 내에서(가장 손해가 적은 장소와 방법을 가려) 그 토지를 사용할 수 있고, 토지소유자는 이를 수인할 의무가 있으나, 이 경우 통행지에 대한 소유자의 점유까지 배제되는 것은 아니므로, 통행권자가 통행지를 통행함에 그치지 아니하고 이를 배타적으로 점유하고 있다면, 통행지 소유자는 통행권자에 대하여 그 인도를 청구할 수 있다(대법원 1993.08.24. 93다25479).
- ① 통행 또는 통로개설로 인하여 통행지 소유자에게 손해를 주었을 경우에는 통행권자는 그 손해를 보상하여야 하고, 통행권자가 손해를 보상하지 않는 경우 통행권 자체가 소멸하는 것은 아니며, 채무불이행의 책임만이 발생한다는 것이 통설이다.
- ②④ 주위토지통행권은 주위토지 소유자의 토지에 대한 독점적 사용권을 제한하는 권리로서 인접한 토지 소유자간의 이해를 조정하는 데 목적이 있으므로 사람이 출입하고 다소의 물건을 공로로 운반할 정도의 폭만 확보할 수 있다면 주위 토지 소유자의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 하고, 또 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이지 더 나아가 장치의 이용상황까지를 미리 대비하여 통행로를 정할 것은 아니다(대법원 1992.12.22. 92다30528). 즉 통행지 소유자는 통행권자의 통행을 수인할 소극적 의무를 부담할 뿐 통로개설 등 적극적인 작위의무까지 부담하는 것은 아니다.
- ⑤ 본래는 공로로 통하고 있었던 토지가 분할 또는 일부의 양도로 공로로 통하지 못하게 된 경우에는, 그 토지소유자는 다른 분할자의 토지 또는 양도인의 토지를 통행할 수 있고, 다른 사람 소유의 토지에 대하여는 통행권이 없다. 정답: ③

08

주위토지통행권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 토지의 분할로 주위토지통행권이 인정되는 경우, 통행권자는 분할당사자인 통행지 소유자의 손해를 보상하여야 한다.
- ② 통행지 소유자는 통행지를 배타적으로 점유하고 있는 주위토지통행권자에 대해 통행지의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 주위토지통행권은 법정의 요건을 충족하면 당연히 성립하고 요건이 없어지면 당연히 소멸한다.
- ④ 주위토지통행권에 기한 통행에 방해가 되는 축조물을 설치한 통행지 소유자는 그 철거의무를 부담한다.
- ⑤ 주위토지통행권의 범위는 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정된다.

해설

- ① 본래는 공로로 통하고 있었던 토지가 분할 또는 일부의 양도로 공로로 통하지 못하게 된 경우에는, 그 토지소유자는 다른 분할자의 토지 또는 양도인의 토지를 통행할 수 있고, 이 경우에는 보상 의무가 없다. 정답: ①

09

주위토지통행권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 이미 그 소유토지의 용도에 필요한 통로가 있는 경우에는 그 통로를 사용하는 것보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 장소로 통행할 권리를 인정할 수는 없다.
- ② 당초에 적법하게 설치된 담장은 주위토지통행권에 기한 통행에 방해가 되더라도 철거할 수 없다.
- ③ 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 생긴 경우 그 포위된 토지의 특정승계인에게는 무상의 주위토지통행권이 인정되지 않는다.
- ④ 토지소유자 자신이 그 토지와 공로사이의 통로를 막는 건물을 축조한 경우 타인소유의 주위토지를 통행할 권리가 없다.
- ⑤ 통행권자의 허락을 얻어 사실상 통행하고 있는 자에 대하여 주위토지의 소유자는 통행에 따른 손해의 보상을 청구할 수 없다.

해설

- ② 주위토지통행권의 본래적 기능발휘를 위하여는 그 통행에 방해가 되는 담장과 같은 축조물도 위 통행권의 행사에 의하여 철거되어야 하는 것이고, 그 담장이 비록 당초에는 적법하게 설치되었던 것이라 하더라도 마찬가지이다(대법원 1990.11.13. 90다5238). 정답: ②

10

상린관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 인접하는 토지를 소유한 자들이 공동비용으로 통상의 경계표를 설치하는 경우, 다른 관습이 없으면 측량비용은 토지의 면적에 비례하여 부담한다.
- ② 지상권자 상호간에도 상린관계에 관한 규정이 준용된다.
- ③ 주위토지통행권은 장래의 이용을 위하여 인정될 수 있으므로, 그 범위와 관련하여 장래의 이용상황까지 미리 대비하여 통행로를 정할 수 있다.
- ④ 건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면 경계로부터 반미터 이상의 거리를 두어야 한다.
- ⑤ 경계에 설치된 경계표나 담은 특별한 사정이 없는 한, 상린자의 공유로 추정한다.

해설

- ③ 주위토지통행권은 주위토지 소유자의 토지에 대한 독점적 사용권을 제한하는 권리로서 인접한 토지 소유자간의 이해를 조정하는 데 목적이 있으므로 사람이 출입하고 다소의 물건을 공로로 운반할 정도의 폭만 확보할 수 있다면 주위 토지 소유자의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 하고, 또 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이지 더 나아가 장차의 이용상황까지를 미리 대비하여 통행로를 정할 것은 아니다(대법원 1992.12.22. 92다30528).

정답: ③

11

상린관계(相隣關係)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

제4장
실전문제

- ① 건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면, 경계로부터 반 미터 이상의 거리를 두어야 한다.
- ② 토지소유자는 이웃 토지로부터 자연히 흘러오는 물을 막지 못한다.
- ③ 인접하여 토지를 소유한 자는 다른 관습이 없으면, 쌍방이 공동비용으로 통상의 경계표를 설치하기 위한 측량비용을 절반하여 부담한다.
- ④ 고지(高地)의 소유자는 이웃 저지(低地)에 자연히 흘러내리는 이웃 저지에서 필요한 물을 자기의 정당한 사용범위를 넘어서 이를 막지 못한다.
- ⑤ 흐르는 물이 저지에서 폐색(閉塞)된 때에는 특별한 관습이 없으면, 고지소유자는 자비로 소통에 필요한 공사를 할 수 있다.

해설

- ③ 경계표 또는 담의 설치비용은 쌍방이 절반하여 부담하나, 측량비용은 토지의 면적에 비례하여 부담한다. 그러나 이와 다른 관습이 있으면 그 관습에 따른다(제237조 제2항). 정답: ③

12 집합건물의 공용부분에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1동의 건물 중 구분소유권의 객체로 되어 있는 전유부분 이외의 건물의 부분은 공용부분이다.
- ② 집합건물의 구분소유자는 공용부분에 대한 보존행위를 단독으로 할 수 있고 그 보존행위에는 지분권에 기한 방해배제청구권과 공유물반환청구권도 포함한다.
- ③ 관리단 집회에서 적법하게 결의된 사항은 그 결의에 반대한 구분소유자에 대하여서도 효력이 미친다.
- ④ 일부의 구분소유자만의 공용에 제공되는 공용부분이라도 구분소유자 전원의 공유에 속한다.
- ⑤ 매수인이 대지를 점유·사용할 권리는 본권으로서 대지사용권에 해당하여 대지지분에 대한 별도의 처분행위는 무효이다.

해설

- ④ 일부의 구분소유자만의 공용에 제공되는 것이 명백한 공용부분은 그들 구분소유자의 공유에 속한다(집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제10조 제1항).
- ② 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제16조 제1항
- ③ 대법원 1995.3.10. 94다49689-49694
- ⑤ 대법원[전합] 2000.11.16. 98다45652-45669 정답: ④

13 집합건물에 관한 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 대지부분의 소유권이전등기를 받지 못한 구분건물의 소유자는 매매계약의 효력으로써 전유부분의 소유를 위하여 건물의 대지를 점유·사용할 권리가 있고, 매수인의 지위에서 가지는 이러한 점유·사용권은 대지사용권에 해당한다.
- ② 공용부분은 구분소유자들의 합유이며, 언제나 전유부분의 면적에 비례한다.
- ③ 대지권등기는 건물등기부가 아닌 토지등기부에 등재된다.
- ④ 집합건물의 등기에 있어서 표제부에는 1동의 건물의 표시와 대지권의 목적인 토지의 표시만이 이루어지고, 전유부분에 관하여는 별도의 표제부를 두지 않는다.
- ⑤ 집합건물의 특별승계인은 규약에 따라 전 소유자의 모든 체납관리비를 승계한다.

해설

- ① 대법원[전합] 2000.11.16. 98다45652-45669
- ② 공용부분은 구분소유자들의 공유에 해당한다.
- ③ 대지권등기는 구분건물등기부의 표제부에 등기된다.
- ④ 전유부분에 대해서도 표제부를 두며 전유부분의 표시란과 대지권의 표시란으로 구성되어 있다.
- ⑤ 집합건물의 특별승계인은 전 입주자의 체납관리비 중 공용부분에 한하여 이를 승계한다는 것이 판례의 태도이다(대법원[전합] 2001.9.20. 2001다8677). 정답: ①

14 집합건물의 구분소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 구분소유자는 전유부분의 보존, 개량을 위하여 다른 구분소유자의 전유부분의 사용을 청구할 수 있다.
- ② 구조상 · 이용상의 독립성을 갖춘 건물부분은 구분소유권의 목적이 될 수 있다.
- ③ 구분소유자의 대지사용권은 규약으로 달리 정함이 없는 한, 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다.
- ④ 아파트의 지하실은 특별한 사정이 없는 한, 구분소유권의 목적이 될 수 없다.
- ⑤ 각 구분소유자의 공용부분에 대한 지분은 규약으로 달리 정함이 없는 한, 그가 가지는 전유부분의 가액 비율에 따른다.

해설

- ⑤ 각 공유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있다. 각 공유자의 공용부분에 대한 지분은 전유부분의 면적의 비율에 따른다(집합건물법 제12조). 정답: ⑤

15 건물의 구분소유 및 집합건물 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 공용부분을 전유부분으로 변경하기 위하여는 구조상이나 이용상으로 다른 전유부분과 독립되어 있어야 한다.
- ② 구분소유자 중 일부가 복도, 계단과 같은 공용부분의 일부를 아무런 권원 없이 점유 · 사용하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 다른 구분소유자들에게 임료 상당의 손해가 발생한 것으로 볼 수 없다.
- ③ 대지에 대한 지상권도 대지사용권이 될 수 있다.
- ④ 집합건물의 관리단은 구분소유자 전원을 구성원으로 하며, 별도의 설립행위가 필요하지 않다.
- ⑤ 구분건물이 물리적으로 완성되기 전이라도 건축허가신청 등을 통하여 구분의사가 객관적으로 표시되면 구분행위의 존재를 인정할 수 있다.

해설

- ② 공용부분이 구조상 이를 별개 용도로 사용하거나 다른 목적으로 임대할 수 있는 대상이 아니더라도, 무단점유로 인하여 다른 구분소유자들이 해당 공용부분을 사용·수익할 권리가 침해된 경우에는 임료 상당의 손해가 발생한 것으로 볼 수 있다(대법원 2020.5.21. 2017다220744 전원합의체).

정답: ②

16 소유권 취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무주의 부동산도 선점의 대상이 된다.
- ② 부동산 매수인이 매도인의 부동산 처분권한을 조사했다라면 그 처분권한이 없음을 알 수 있었음에도 이를 조사하지 않은 경우, 매수인의 등기부취득시효는 완성되지 않는다.
- ③ 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합 당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.
- ④ 타인의 토지 기타 물건으로부터 발견된, 문화재가 아닌 매장물은 법률이 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 그 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하여 취득한다.
- ⑤ 타인의 권원에 의하여 부동산에 부합된 물건이 독립한 권리의 객체성을 상실하고 부동산의 구성부분이 된 경우, 그 부합물의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다.

해설

- ① 무주의 동산을 소유의 의사로 점유한 자가 그 소유권을 가지는 것을(제252조 제1항) 무주물선점이라 하며, 무주의 부동산은 국유로 하므로(제252조 제2항) 이는 선점의 대상이 될 수 없다.

정답: ①

17 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률상 공용부분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 되지 않는다.
- ② 구조상의 공용부분에 관한 물건의 득실변경은 별도로 등기를 하여야 한다.
- ③ 공용부분 관리비에 대한 연체료는 특별한 사정이 없는 한 특별승계인에게 승계되는 공용부분 관리비에 포함되지 않는다.
- ④ 관리인 선임 여부와 관계없이 공유자인 구분소유자가 단독으로 공용부분에 대한 보존행위를 할 수 있다.
- ⑤ 어느 부분이 공용부분인지 전유부분인지는 구분소유자들 사이에 다른 합의가 없는 한 그 건물의 구조에 따른 객관적인 용도에 의하여 결정된다.

해설

- ② 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따른다. 따라서 공용부분에 관한 물건의 득실변경은 등기를 요하지 아니한다. 정답: ②

18

첨부(添附)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 부동산에 부합된 물건이 타인의 권원에 의하여 부합되었더라도 사실상 분리가 불가능하여 부동산의 구성부분이 되었다면, 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다.
- ② 동산이 부동산에 부합되면 그 동산의 소유권자는 부합물 위에 지분권을 취득한다.
- ③ 동산이 부동산에 부합되었더라도 그 동산을 목적으로 하는 다른 권리는 소멸하지 않는다.
- ④ 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 가공자에게 속한다.
- ⑤ 동산간의 부합에 있어서 합성물의 소유권은 원칙적으로 주종의 구별 없이 가액에 비례하여 공유로 한다.

해설

- ① 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립된 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인의 권원에 의하여 이를 부합시킨 경우에도 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다(대법원 2009.08.20. 2008두8727).
- ② 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건(동산)의 소유권을 취득한다. 부합으로 소유권을 취득한 자는 부당이득의 법리에 따라 소유권을 잃은 자에게 보상을 하여야 한다. 그러므로 공유가 성립되지 않는다.
- ③ 동산이 부동산에 부합된 경우에는 그 동산을 목적으로 하는 다른 권리는 원칙적으로 소멸한다.
- ④ 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 귀속하나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유가 된다(제259조).
- ⑤ 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 원칙적으로 주종의 소유자에게 귀속한다(제257조 제1항). 단, 주종을 구별할 수 없는 경우에는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다(제257조 제2항). 정답: ①

제4장
실전문제

19

첨부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 주종을 구별할 수 있는 동산들이 부합하여 분리에 과다한 비용을 요할 경우, 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다.
- ② 타인이 권원에 의하여 부동산에 부속시킨 동산이 그 부동산과 분리되면 경제적 가치가 없는 경우, 그 동산의 소유권은 부동산 소유자에게 속한다.
- ③ 양도담보권의 목적인 주된 동산에 甲소유의 동산이 부합되어 甲이 그 소유권을 상실하는 손해를 입은 경우, 특별한 사정이 없는 한 甲은 양도담보권자를 상대로 보상을 청구할 수 있다.
- ④ 타인의 동산에 가공한 경우, 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.
- ⑤ 건물의 증축 부분이 기존 건물에 부합하여 기존 건물과 분리해서는 별개의 독립물로서의 효용을 갖지 못하는 경우, 기존 건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 않았더라도 매수인은 부합된 증축 부분의 소유권을 취득한다.

해설

- ③ 양도담보권의 목적인 주된 동산에 다른 동산이 부합되어 부합된 동산에 관한 권리자가 권리를 상실하는 손해를 입은 경우, 민법 제261조에 따라 보상을 청구할 수 있는 상대방은 양도담보권자가 아니라 양도담보설정자이다(대법원 2016. 4. 28. 2012다19659). 정답: ③

20

부합에 관한 다음 설명 가운데 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 부동산에 동산이 부합된 경우에는 원칙적으로 부동산 소유자에게 소유권이 귀속한다. 다만, 당사자의 특약이 있거나 타인의 권원에 의하여 부합된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 타인의 토지 위에서 권원 없이 1년생 농작물을 경작한 경우 그 농작물은 토지에 부합하지 않고 경작자의 소유에 속한다.
- ③ 임차인이 임차건물 위에 증축한 부분이 임차건물의 구성부분이 된 경우 그 증축이 임차인의 권원에 의해 이루어진 것이고 구조상·이용상 독립성을 갖추었다 하더라도 증축된 부분은 독립소유권의 객체가 될 수 없다.
- ④ 주유소 지하에 매설된 유류저장탱크의 경우 그것을 토지로부터 분리하는데 과다한 비용이 들고, 분리하면 그 경제적 가치가 현저히 감소할 것으로 판단되면 그 유류저장탱크는 토지에 부합한 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 동산 간의 부합에 관한 규정은 혼화의 경우에 준용된다.

해설

- ③ 임차인이 임차한 건물에 그 권원에 의하여 증축한 경우에 증축한 부분이 구성부분을 이루고 있다면 독립소유권이 성립할 수 없으나, 증축부분이 구조상·이용상 독립성을 구비하고 있다면 독립소유권의 객체가 된다(대법원 1999.7.27. 99다14518).
- ② 대법원 1969.2.18. 68도906
- ④ 대법원 1995.6.29. 94다6345
- ⑤ 제258조 정답: ③

21

부합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부동산에 동산이 부합한 경우, 동산의 가격이 부동산의 가격을 초과하더라도 부동산의 소유자가 부합한 동산의 소유권을 취득한다.
- ② 동산끼리 부합된 경우, 주종을 구별할 수 없는 때에는 각 동산의 소유자가 부합 당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.
- ③ 토지 위에 건물이 신축 완공된 경우에 건물은 토지에 부합하지 않는다.
- ④ 권원이 없는 자가 토지소유자의 승낙 없이 그 토지 위에 나무를 심은 경우, 특별한 사정이 없는 한, 토지소유자에 대하여 그 나무의 소유권을 주장할 수 있다.
- ⑤ 건물의 임차인이 권원에 기하여 증축한 부분이 독립성을 가지면 증축된 부분은 부합되지 않는다.

해설

- ④ 민법 제256조 단서 소정의 “권원”이라 함은 지상권, 전세권, 임차권 등과 같이 타인의 부동산에 자기의 동산을 부속시켜서 그 부동산을 이용할 수 있는 권리를 뜻하므로 그와 같은 권원이 없는 자가 토지소유자의 승낙을 받음이 없이 그 임차인의 승낙만을 받아 그 부동산 위에 나무를 심었다면 특별한 사정이 없는 한 토지소유자에 대하여 그 나무의 소유권을 주장할 수 없다(대법원 1989.07.11. 88다카9067). 정답: ④

22

첨부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 타인이 그의 권원에 의하여 부동산에 부속한 물건은 이를 분리하여도 경제적 가치가 없으면 부동산소유자의 소유로 한다.
- ② 저당권의 효력은 다른 사정이 없으면 저당부동산에 부합된 물건에 미친다.
- ③ 동일인 소유의 여러 동산들이 결합하는 것은 부합이 아니다.
- ④ 부합의 원인은 인위적이든 자연적이든 불문한다.
- ⑤ 타인의 동산에 가공한 때에는 가공물의 소유권은 가공자의 소유로 한다.

해설

- ⑤ 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 귀속하나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액(多額)인 때에는 가공자의 소유가 된다(제259조). 정답: ⑤

23

부합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동산이 부동산에 부합하여 동산의 소유권이 소멸한 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리도 소멸한다.
- ② 부합으로 인하여 권리를 상실하는 등 손해를 입은 자는 부당이득 규정에 의하여 보상을 청구할 수 있다.
- ③ 건물로서의 독립성이 없어서 기존 건물의 구성부분이 된 경우에는 타인이 권원에 의해 부속시킨 것이라도 기존 건물에 부합한다.
- ④ 저당권설정 후 저당목적물에 부합된 물건에는 저당권의 효력이 미치지 않는다.
- ⑤ 건물 증축에 있어서 부합 여부는 증축 부분의 객관적 상태 외에 소유자의 의사를 고려하여 결정한다.

해설

- ④ 저당권의 효력은 저당부동산에 부합(저당권의 설정전후를 불문)된 부합물과 종물에도 미친다. 예외적으로 설정계약에서 반대의 특약을 한 경우와 지상권자·전세권자 등이 부합한 물건에는 미치지 아니한다. 정답: ④

24

부합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 부동산에의 부합 이외에 동산 상호간의 부합도 인정된다.
- ② 동산 이외에 부동산은 부합물이 될 수 없다.
- ③ 동일인 소유의 부동산과 동산 상호간에는 원칙적으로 부합이 인정되지 않는다.
- ④ 분리가 가능하지만 분리할 경우 상호 부착되거나 결합된 물건의 경제적 가치가 심하게 손상되는 경우에도 부합이 인정된다.
- ⑤ 부동산의 소유자는 원칙적으로 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다.

해설

- ② 건물의 증축부분이 기존건물에 부합하여 기존건물과 분리하여서는 별개의 독립물로서의 효용을 갖지 못하는 이상 기존건물에 대한 근저당권은 민법 제358조에 의하여 부합된 증축부분에도 효력이 미치는 것이므로 기존건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 아니하였다고 할지라도 경락인은 부합된 증축부분의 소유권을 취득한다(대법원 1992. 12. 8. 92다26772, 26789)

정답: ②

25

첨부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 주종의 구별이 있는 동산과 동산이 부합된 합성물은 주된 동산의 소유자에게 속한다.
- ② 완성된 건물은 토지에 부합하지 않는다.
- ③ 가공물은 원칙적으로 원재료 소유자에게 속한다.
- ④ 부동산에 부합되어 동산의 소유권이 소멸하는 경우, 그 동산을 목적으로 한 질권은 소멸하지 않는다.
- ⑤ 첨부에 의해 손해를 받은 자는 부당이득에 관한 규정에 의하여 보상을 청구할 수 있다.

해설

- ④ 동산이 부동산에 부합된 경우에는 그 동산을 목적으로 하는 다른 권리는 원칙적으로 소멸한다.

정답: ④

- ① 취득시효완성 전에 이전등기 원인이 발생하였으나 취득시효완성 후에 이전등기를 경료한 자에 대하여도 시효취득을 주장할 수 있다.
- ② 취득시효완성 후에 그 사실을 모르고 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 하였다 하더라도 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다.
- ③ 등기부취득시효의 요건으로서의 소유자로 등기한 자라 함은 적법·유효한 등기를 마친 자일 필요는 없고 무효의 등기를 마친 자라도 상관없으며, 등기부취득시효에서의 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유 취득에 관한 것이다.
- ④ 점유자가 취득시효기간의 만료로 소유권이전등기청구권을 취득한 후 점유를 상실한 경우, 이를 시효이익의 포기로 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 이미 취득한 소유권 이전등기청구권은 바로 소멸되는 것은 아니다.
- ⑤ 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 점유를 승계한 현 점유자가 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원이 없다.

해설

- ① 부동산에 대한 점유취득시효가 완성되었다고 하더라도 이를 등기하지 아니하고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자에게 소유권이전등기가 마쳐지면 점유자는 그 제3자에게 대항할 수 없는 것이고, 이 경우 제3자의 이전등기 원인이 점유자의 취득시효 완성 전의 것이라 하더라도 마찬가지이다(대법원 1998.7.10. 97다45402).
- ② 취득시효완성 후에 그 사실을 모르고 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 하였다 하더라도 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다(대법원 1998.5.22. 96다24101).
- ③ 등기부취득시효의 요건으로서의 소유자로 등기한 자라 함은 적법·유효한 등기를 마친 자일 필요는 없고 1부동산 1등기용지주의원칙에 어긋나지 않는 한 무효의 등기를 마친 자라도 상관없으며, 등기부취득시효에서의 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유취득에 관한 것이다(대법원 1998.1.20. 96다48527).
- ④ '점유자가 취득시효기간의 만료로 일단 소유권이전등기청구권을 취득한 이상, 그 후 점유를 상실하였다고 하더라도 이를 시효이익의 포기로 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 이미 취득한 소유권이전등기청구권은 소멸되지 아니한다'고 하였다(대법원[전합] 1995.3.28. 93다47745).
- ⑤ 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률 효과까지 승계하는 것은 아니므로 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다(대법원[전합] 1995.3.28. 93다47745). 정답: ①

27 부동산 점유취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유취득시효가 완성된 경우 점유자가 시효기간 중에 수취한 과실은 소유자에게 반환할 필요가 없다.
- ② 점유자의 점유가 불법이라고 주장하는 소유자로부터 이익을 받은 사실이 있다 하더라도 그러한 사실만으로 곧 평온·공연한 점유가 부정되지 않는다.
- ③ 취득시효 진행 중에 소유자가 소유권을 제3자에게 양도하고 등기를 이전한 후 시효가 완성된 경우, 점유자는 양수인에게 시효 완성을 이유로 소유권 이전등기를 청구할 수 있다.
- ④ 종종 부동산이 종종 대표자에게 적법하게 명의신탁되었는데 그 부동산에 대해 제3자의 점유에 의한 취득시효가 완성된 후 제3자 명의의 등기 전에 명의신탁이 해지되어 등기 명의가 종중에게 이전된 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 종중에 대해 시효 완성을 주장할 수 있다.
- ⑤ 점유취득시효가 완성된 경우, 점유자는 등기 없이는 그 부동산의 소유권을 주장할 수 없다.

해설

- ④ 명의신탁된 부동산에 대하여 점유취득시효가 완성된 후 시효취득자가 그 소유권이전등기를 경료하기 전에 명의신탁이 해지되어 그 등기명의가 명의수탁자로부터 명의신탁자에게로 이전된 경우에는 명의신탁의 취지에 따라 대외적 관계에서는 등기명의자만이 소유권자로 취급되고 시효완성 당시 시효취득자에게 져야 할 등기의무도 명의수탁자에게만 있을 뿐이므로, 명의신탁자의 등기 취득이 등기의무자의 배임행위에 적극 가담한 반사회적 행위에 근거한 등기라든가 또는 기타 다른 이유로 원인무효의 등기인 경우는 별론으로 하고, 그 명의신탁자는 취득시효 완성 후에 소유권을 취득한 자에 해당하여 그에 대하여 취득시효를 주장할 수 없다(대법원 2001.10.26. 2000다8861).

정답: ④

28 부동산의 점유취득시효에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 자기소유의 부동산은 취득시효의 대상이 될 수 없다.
- ② 시효기간이 진행되던 중에 등기부상의 소유자가 변경된 경우, 시효완성자는 시효완성 당시의 소유자에 대하여 시효완성의 효과를 주장할 수 있다.
- ③ 취득시효를 주장하는 자는 시효기간의 만료로 즉시 소유권을 취득한다.
- ④ 취득시효를 주장하는 자는 반드시 실제로 점유를 개시한 때를 시효의 기산점으로 삼아야 한다.
- ⑤ 취득시효가 완성되었더라도 등기를 하지 않고 있는 사이에 제3자가 그 부동산에 관한 소유권 이전등기를 마친 경우, 시효완성자는 원칙적으로 그 제3자에 대하여 시효완성의 효과를 주장할 수 있다.

해설

- ② 취득시효기간 완성 후 아직 그것을 원인으로 소유권이전등기를 경료하지 아니한 자는 종전 소유자로부터 그 부동산에 대한 등기부상 소유명의를 넘겨받은 제3자에 대하여 시효취득을 주장할 수 없으나 취득시효기간 만료 전에 등기명의를 넘겨 받은 시효완성당시의 등기명의자에 대하여는 그 소유권취득을 주장할 수 있다(대법원 1989.04.11. 88다카5843).

- ① 취득시효는 당해 부동산을 오랫동안 계속하여 점유한다는 사실상태를 일정한 경우에 권리관계로 높이려고 하는 데에 그 존재이유가 있는 점에 비추어 보면, 시효취득의 목적물은 타인의 부동산임을 요하지 않고 자기 소유의 부동산이라도 시효취득의 목적물이 될 수 있다(대법원 2001.07.13. 2001다17572).
- ③ 등기하여야 소유권을 취득한다.
- ④ 취득시효를 주장하는 자는 점유기간 중에 소유자의 변동이 없는 토지에 관하여는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있다(대법원 1994.03.22. 93다46360).
- ⑤ 부동산에 대한 점유취득시효가 완성되었다고 하더라도 이를 등기하지 아니하고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자에게 소유권이전등기가 마쳐지면 점유자는 그 제3자에게 대항할 수 없다(대법원 1998.07.10. 97다45402). 정답: ②

29 갑은 을의 토지(을 명의로 등기되어 있음)를 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 점유한 뒤에 그 토지를 병에게 팔고 점유를 이전하여 주었을 때 옳은 설명은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 병은 을에 대하여 직접 소유권이전등기청구를 할 수 있다.
- ② 병은 을에 대하여 직접 소유권이전등기청구를 할 수도 있고, 갑의 소유권이전등기청구권을 대위행사 할 수도 있다.
- ③ 병은 을에 대하여 갑의 소유권이전등기청구권을 대위행사 할 수 있다.
- ④ 병은 을에 대하여 전혀 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
- ⑤ 병은 자신의 명의로 등기함이 없이 소유권을 취득한다.

해설

- ③ 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률 효과까지 승계하는 것은 아니므로, 부동산을 취득시효 기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사 할 수 있을 뿐, 전점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다(대법원[전합] 1995. 3.28. 93다47745). 정답: ③

30 부동산 취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 중복등기 중 선등기가 원인무효가 아니어서 후등기가 무효로 된 경우, 말소되지 않은 후등기를 근거로 등기부취득시효의 완성을 주장할 수 없다.
- ② 시효기간 만료 전에 제3자가 등기명의를 넘겨받은 경우, 점유자는 시효기간완성 후에 그 제3자를 상대로 취득시효를 원인으로 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 점유자가 취득시효를 주장하는 경우, 자주점유 여부에 관한 증명책임은 취득시효의 성립을 부정하는 자에게 있다.
- ④ 자기 소유의 부동산은 취득시효의 대상이 될 수 없다.
- ⑤ 점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위가 없다는 사실을 알면서 타인 소유의 부동산을 무단점유한 경우, 취득시효는 인정되지 않는다.

해설

- ④ 취득시효는 당해 부동산을 오랫동안 계속하여 점유한다는 사실상태를 일정한 경우에 권리관계로 높이려고 하는 데에 그 존재이유가 있는 점에 비추어 보면, 시효취득의 목적물은 타인의 부동산임을 요하지 않고 자기 소유의 부동산이라도 시효취득의 목적물이 될 수 있다(대법원 2001.07.13. 2001다17572). 정답: ④

31

등기부상 甲 소유의 X 토지를 乙이 소유의 의사로 평온·공연하게 1989. 2. 1.부터 2012. 7. 1.까지 점유하고 있다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 2009. 3. 2. 甲이 丙에게 소유권이전등기 후 다시 20년이 경과하더라도 乙은 등기명의자인 丙에게 취득시효를 주장할 수 없다.
② 2012. 7. 1. 甲이 X 토지의 반환을 청구하는 경우, 乙은 등기 없이도 甲의 반환청구에 대항할 수 있다.
③ 甲은 乙에게 1989. 2. 1.부터 취득시효 완성시까지의 임료 상당액을 반환청구할 수 없다.
④ 2010. 3. 5. 甲이 丁에게 X 토지에 대한 저당권설정등기를 해준 경우, 특별한 사정이 없는 한 저당권설정등기는 유효하다.
⑤ 1995. 5. 15. 甲이 戊에게 소유권이전등기를 해준 경우, 2012. 7. 1. 乙은 戊에 대하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

해설

- ① 부동산에 대한 점유험득시효가 완성된 후 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기를 하지 않고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 경료된 경우라 하더라도 당초의 점유자가 계속 점유하고 있고 소유자가 변동된 시점을 기산점으로 삼아도 다시 취득시효의 점유기간이 경과한 경우에는 점유자로서는 제3자 앞으로의 소유권 변동시를 새로운 점유험득시효의 기산점으로 삼아 2차의 취득시효의 완성을 주장할 수 있다(대법원 2009.07.16. 2007다15172 전원합의체). 정답: ①

32

소유권의 취득사유인 취득시효에 대한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차이행의 訴에서 적극적으로 시효의 이익을 포기하겠다고 표명한 바 없을지라도 소송 계속 중 원고가 그 토지에 대한 피고의 소유를 인정하여 피고와 합의하여 위 소송을 취하한 것이라면, 원고가 그 취득시효의 완성을 알면서 그 시효의 이익을 피고에게 포기하는 의사표시를 한 것으로 볼 수 있다.
② 명의수탁자가 그 부동산 점유자의 취득시효완성 후 명의신탁자로부터 그 부동산을 매수한 경우 시효취득자로서는 수탁자를 상대로 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 청구할 수 없다.
③ 토지에 대한 매매계약이 그 토지의 점유험득시효에 대한 소유권이전등기의무를 면탈하기 위한 목적에서 이루어진 것이라면 통정허위표시에 해당하여 무효이다.
④ 취득시효 완성후 경료된 무효인 제3자 명의의 등기에 대하여 시효완성 당시의 소유자가 무효행위를 추인하여도 그 제3자 명의의 등기는 그 소유자의 불법행위에 제3자가 적극 가담하여 경료된 것으로서 사회질서에 반하여 무효이다.

- ⑤ 부동산에 관하여 피상속인 명의로 소유권이전등기가 10년 이상 경료 되어 있는 이상, 상속인은 부동산등기부 취득시효의 요건인 '부동산의 소유자로 등기된 자'에 해당하므로 피상속인과 상속인의 점유기간을 합산하여 10년을 넘는다면 등기부취득시효를 주장할 수 있다.

해설

- ② 이는 내부적으로 그 소유권을 취득하였다는 것을 의미할 뿐 대외적으로는 그 소유권이나 등기명목에 아무런 변동이 없는 경우이므로 수탁자를 상대로 소유권이전등기 절차의 이행을 청구할 수 있다 (대법원 1989.10.27. 88다카23506).
- ① 대법원 1973.9.29. 73다762
 ③ 대법원 1994.10.11. 94다16090
 ④ 대법원 2002.3.15. 2001다77352·77363
 ⑤ 대법원 1989.12.26. 89다카6140 정답: ②

33

갑의 부동산을 을이 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 점유하여 취득시효가 완성되었다. 이 경우 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 을은 비록 법률의 규정에 의한 소유권취득이나 그에게 이전등기를 하여야 그 부동산에 대한 소유권을 취득한다.
- ② 갑이 을의 시효완성사실을 알았다 하더라도 갑은 그의 처분권한을 잃지 않는다.
- ③ 을이 갑에게 부동산의 매수를 제의하는 경우에도 을의 점유를 타주점유라고 볼 수는 없다.
- ④ 갑이 을의 시효완성 사실을 알고 그 부동산을 병에게 처분하면 을은 갑에게 채무불이행에 기한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 제3자 병이 갑의 배임행위에 적극 가담하면 갑·병의 매매계약은 이중매매의 법리와 마찬가지로 무효이다.

제4장
실전문제

해설

- ④ 부동산 점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산 소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권채무관계가 성립하는 것은 아니므로, 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행 책임을 물을 수 없다(대법원 1995.7.11. 94다4509).
- ① 점유취득시효에 의한 소유권취득은 원시취득이며, 따라서 그 등기는 성질상 보존등기이어야 하지만 형식상은 이전등기가 행하여진다. 부동산등기법상 취득시효에 기한 등기를 어떤 방식에 의하여 하는지는 규정하고 있지 않으나, 통설은 보존등기의 방식에 의할 경우에는 그 동안의 권리 변동과정이 공시되지 않으며 그 부동산에 관하여 등기된 제한물권이 있고 그것이 시효에 의한 소유권취득자에게 대항할 수 있는 것인 때에는 제한물권자의 권리를 해치게 될 염려가 있기 때문에 이전등기에 의하는 것이 바람직하다고 한다.
- ② 점유취득시효는 등기함으로써 그 소유권을 취득하므로 그 전에는 취득시효 완성 당시의 소유자에 대하여 소유권이전등기청구권만을 갖는다. 이는 채권적 청구권이므로 이에 의해 등기가 있기 전까지는 원소유자가 시효완성 사실을 알고 있는 경우에도 채권적인 등기이전 의무를 부담할 뿐 자신의 소유권에 대한 처분권을 상실하는 것은 아니다.
- ③ 취득시효기간이 경과한 후에 부동산의 점유자가 그 등기명의 소유자에게 점유부동산의 매수를 제의한 일이 있다고 하여도 일반적으로 점유자는 취득시효가 완성된 후에도 소유권자와의 분쟁을 간편히 해결하기 위하여 매수를 시도하는 사례가 허다함에 비추어 이와 같은 매수제의를 하였다

는 사실을 가지고 그 점유를 타주점유라고 볼 수 없다(대법원[전합] 1983.7.12. 82다708·709).

- ⑤ 시효취득을 주장하는 권리자가 취득시효를 주장하면서 소유권이전등기청구소송을 제기하여 그에 관한 증명까지 마쳤다면 부동산 소유자로서는 시효취득사실을 알수 있다 할 것이고 이러한 경우에 부동산 소유자가 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 넘겨줌으로써 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기의무가 이행불능에 빠짐으로써 시효취득을 주장하는 자가 손해를 입었다면 불법행위를 구성한다고 할 것이며, 부동산을 취득한 제3자가 부동산 소유자의 이와 같은 불법행위에 적극 가담하였다면 이는 사회질서에 반하는 행위로서 무효라 할 것이다(대법원 1993.2.9. 92다47892). 정답: ④

34

甲 소유 X토지에 대하여 乙이 점유취득시효를 완성하였으나 등기를 경료하지 못하고 있는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲이 丙에게 X토지를 매도하여 이전등기를 마치면, 乙은 甲에 대한 시효취득의 효력을 丙에게 주장할 수 없다.
 ② 위의 ①에서 丙이 甲의 배임행위에 적극 가담한 경우에는 甲과 丙의 매매는 반사회질서의 법률행위로서 무효가 된다.
 ③ 乙이 점유를 상실하면 시효이익의 포기로 간주되어 취득한 소유권이전등기청구권은 소멸한다.
 ④ 乙의 X토지에 대한 취득시효의 주장에도 불구하고 甲이 악의로 丙에게 이를 매도한 경우, 乙은 甲에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
 ⑤ X토지가 수용된 경우, 그 전에 乙이 甲에 대하여 시효취득기간 만료를 원인으로 등기청구권을 행사하였다면 대상청구권을 행사할 수 있다.

해설

- ③ 점유자가 취득시효기간의 만료로 일단 소유권이전등기청구권을 취득한 이상, 그 후 점유를 상실하였다고 하더라도 이를 시효이익의 포기로 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 이미 취득한 소유권이전등기청구권은 소멸되지 아니한다(대법원 1995.03.28. 93다47745 전원합의체). 정답: ③

부동산 점유취득시효에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 취득시효기간이 만료된 당시의 점유자로부터 부동산을 양수한 자가 직접 등기부상의 소유자에게 소유권이전등기를 청구할 수는 없다.
- ② 부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 이상 이를 사용, 수익하다가 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도 이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다.
- ③ 취득시효가 완성된 토지가 수용되어 소유권이전등기의무가 이행불능이 되는 경우 점유취득자는 수용보상금에 대해 대상청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 1필의 토지의 일부에 대하여 분필절차를 밟지 아니한 상태에서는 시효취득에 의하여 소유권을 취득할 수 없다.
- ⑤ 무단점유의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 자주점유의 추정이 깨진다.

해설

④ 1필의 토지의 일부분이 다른 부분과 구분되어 시효취득자의 점유에 속한다는 것을 인식하기에 족한 객관적인 징표가 계속하여 존재한다면 1필의 토지의 일부에 대한 점유취득시효도 인정된다(대법원 1975.6.24. 74다1877). 다만 먼저 점유취득시효가 완성된 토지부분의 분필절차를 밟은 후에 시효취득의 등기를 하여야 한다.

① 대법원[전합] 1995.3.28. 93다47745

② 부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 이상 이를 사용, 수익하다가 그 부동산에 대한 보다 적극적인 권리 행사의 일환으로 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도 그 이전등기청구권의 행사 여부에 관하여 그가 그 부동산을 스스로 계속 사용, 수익만 하고 있는 경우와 특별히 다를 바 없으므로 위 두 어느 경우에도 이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다고 보아야 한다(대법원 1999.3.18. 98다32175).

③ 취득시효가 완성된 토지가 수용됨으로써 취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기의무가 이행불능이 된 경우에는 그 소유권이전등기청구권자는 소위 대상청구권의 행사로서 그 토지의 소유자가 그 토지의 대가로서 지급 받은 수용보상금의 반환을 청구할 수 있다(대법원 1994.12.9. 94다25025).

⑤ 대법원[전합] 1997.8.21. 95다28625 정답: ④

- ① 甲소유의 대지에 대하여 취득시효가 완성된 경우, 甲은 시효완성한 점유자 乙에 대하여 대지에 대한 불법점유를 이유로 그 인도를 청구할 수 없다.
- ② 취득시효완성을 원인으로 乙에게 소유권이전등기의무를 부담하게 된 甲이 그 사실을 알고 당해 부동산을 丙에게 처분하여 乙에 대한 소유권이전등기의무를 이행불능에 빠지게 하고 그로 인해 乙이 손해를 입은 경우, 불법행위가 성립한다.
- ③ 위 ②의 경우 丙이 甲의 처분행위에 적극 가담하였다면 甲과 丙 간의 매매계약은 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효이다.
- ④ 시효완성한 점유자 乙은 시효완성 후 甲으로부터 그 부동산의 소유권을 취득한 丙에 대하여 취득시효를 이유로 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
- ⑤ 甲의 토지를 乙이 점유하다가 乙이 丙에게 임대하여 丙이 임차인으로서 20년간 경작한 경우, 乙은 소유권을 시효취득하지 못하고 丙이 시효취득을 한다.

해설

- ⑤ 乙이 점유하다가 丙에게 임대하여 丙이 임차인으로 직접점유한 경우 시효취득을 하는 자는 간접 점유자 乙만이며 丙은 시효취득을 할 수 없다.
- ①② 시효취득을 주장하는 권리자가 소유자(등기명의인)를 상대로 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기 청구소송 등을 제기하여 소유자가 그 부동산의 취득시효완성 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고, 그 부동산을 제3자에게 처분하여 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기의무가 이행불능에 빠졌다면 소유자는 시효완성자에게 불법행위를 이유로 한 손해를 배상할 책임이 있다. 따라서 甲은 乙에 대하여 대지에 대한 불법점유임을 이유로 그 인도를 청구할 수 없으며, 甲은 乙에게 불법행위책임을 부담한다.
- ③④ 취득시효로 인한 등기청구권은 채권적 청구권에 불과하므로 취득시효완성 후 점유자(시효완성자)가 소유권이전등기를 하기 전에 제3자가 먼저 소유권이전등기를 경료하면, 점유자는 그 제3자에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다. 다만, 소유자의 양도행위가 점유자(시효완성자)에게 불법행위가 되고, 부동산을 취득한 제3자가 이와 같은 불법행위에 적극 가담하였다면 이는 사회질서에 반하는 행위로서 무효이다. 정답: ⑤

甲의 토지를 乙이 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하여 취득시효가 완성되었다. 그런데 乙이 甲에게 등기를 요구하자 甲은 그 부동산을 丙에게 처분하고 이전등기가 경료되었다. 이 경우 법률관계로 옳지 않는 것은?(다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 을은 부동산취득시효의 요건 중 일부는 구비하였으나 그의 앞으로 이전등기를 하여야 그 부동산에 대한 소유권을 취득한다.
- ② 만약 을의 취득시효가 완성되기 전에 병이 갑으로 부터 등기명의를 넘겨받은 경우에, 그 후 취득시효가 완성되면 시효취득자 을은 병에게 시효취득을 주장할 수 없다.
- ③ 갑이 을의 취득시효완성 사실을 알고 그 토지를 병에게 처분한 경우, 을은 갑에게 불법행위에 기한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 을의 취득시효가 완성된 부동산이 수용되어 시효완성을 원인으로 하는 소유권이전등기의무가 이행불능이 된 경우에, 을이 그 이행불능 전에 갑에게 취득시효를 주장하여 등기를 요구한 사정이 있으면 갑이 수령한 수용보상금에 대하여 을은 대상청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 병이 을의 취득시효완성 사실을 알고도 갑을 적극 권유하여 자기에 처분하게 한 경우에는 갑과 병의 매매계약은 이중매매의 법리와 마찬가지로 민법 제103조에 의하여 무효가 된다.

해설

- ② 취득시효기간 만료 전에 소유자가 제3자에게 목적물을 처분한 경우 이때는 제3자로서의 소유권등기 자체가 곧 취득시효의 중단을 가져오는 것으로 평가되지는 않으므로, 이 경우에도 취득시효기간 완성 후에 제3자를 상대로 취득시효를 원인으로 하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다(대법원 1976.3.9. 75다2220).
- ① 이전등기가 없는 한 시효완성자는 등기청구권이라는 채권적 청구권을 갖는 지위에 불과하다.
- ③⑤ 취득시효완성 후 소유자의 처분이 모두 불법이라고는 할 수 없으나, 이를 알고(이전등기청구를 받고)도 처분한 경우는 특별한 위법성 조각사유가 없는 한 불법이 된다(대법원 1994.4.12. 93다 60779).
- ④ 대법원 1994.12.9. 94다25025 정답: ②

38

갑 소유 명의의 부동산이 을, 병, 정에게 순차 전매되면서 각각 17년, 5년, 3년간 평온·공연하게 자주점유하였다. 점유시효취득관계에 관한 설명 중 가장 타당한 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 을이 갑을 상대로 시효취득을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ② 병이 갑을 상대로 시효취득을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있고, 정은 병에게 매매를 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 병 또는 정 누구라도 갑에게 시효취득을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ④ 병이 시효취득기간 완성 후 처분하였으므로, 병의 시효취득은 인정되지 않고, 정은 시효취득기간 완성 후 취득자이므로 갑에게 시효취득을 주장할 수 없다.
- ⑤ 병, 정은 모두 스스로 20년 이상 점유한 것이 아니므로 시효취득이 인정되지 않는다.

해설

- ④ 원래 취득시효제도는 일정한 기간 점유를 계속한 자를 보호하여 그에게 실체법상의 권리를 부여하는 제도이므로, 부동산을 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유한 자는 민법 제245조 제1항에 의하여 점유부동산에 관하여 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 취득하게 되며, 점유자가 취득시효기간의 만료로 일단 소유권이전등기청구권을 취득한 이상, 그 후 점유를 상실하였다고 하더라도 이를 시효이익의 포기로 볼 수 있는 경우가 아닌 한, 이미 취득한 소유권이전등기청구권은 소멸되지 않는다.
- ⑤ 전 점유자의 점유를 승계한 자는 그 점유 자체와 하자만을 승계하는 것이지 그 점유로 인한 법률효과까지 승계하는 것은 아니므로 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위 행사할 수 있을 뿐, 전 점유자의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다. 정답: ②

39

부동산 취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 등기부취득시효의 요건으로서 무과실은 이를 주장하는 자가 증명하여야 한다.
- ② 점유취득시효에 있어서 점유자가 무효인 임대차계약에 따라 점유를 취득한 사실이 증명된 경우, 그 점유자의 소유의 의사는 추정되지 않는다.
- ③ 시효취득자가 시효취득 당시 원인무효인 등기의 등기부상 소유명의자에게 시효이익을 포기한 경우에도 시효이익 포기의 효력이 발생한다.
- ④ 점유취득시효의 완성 후 등기 전에 토지소유자가 파산선고를 받은 때에는 점유자는 파산관재인을 상대로 취득시효를 이유로 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
- ⑤ 토지에 대한 취득시효 완성으로 인한 소유권이전등기청구권은 그 토지에 대한 점유가 계속되는 한 시효로 소멸하지 않는다.

해설

- ③ 시효취득자가 시효취득 당시 시효이익을 포기한 경우라도, 그 포기의 상대방이 원인무효인 등기의 등기부상 소유명의자인 경우에는 포기의 효과가 없다고 보아야 한다. 정답: ③

40 등기부취득시효에 관한 다음 설명 중 판례의 입장과 다른 것은?

- ① 등기부취득시효에 있어서 점유의 사실이 있으면 소유의 의사로 평온·공연하게 선의로 점유한 것으로 추정되나, 무과실은 추정되지 않으므로 취득시효를 주장하는 자가 입증책임을 진다.
- ② 등기부취득시효에 있어서 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유취득에 관한 것이며, 선의·무과실은 점유개시시점만 아니라 시효완성시까지 요구된다.
- ③ 1필지 일부에 대한 등기부취득시효는 성질상 있을 수 없다.
- ④ 등기부취득시효에 있어서 등기는 적법유효한 등기일 필요는 없으나, 2종의 소유권보존등기여서 무효로 되는 후등기나 이에 더 잡은 소유권이전등기는 포함되지 않는다.
- ⑤ 등기부취득시효에 의해 소유권을 취득하는 자는 10년간 반드시 그의 명의로 등기되어 있어야 하는 것은 아니고, 앞사람의 등기기간까지 합하여 10년간 부동산소유자로 등기되어 있으면 된다.

해설

- ② 등기부취득시효에 있어서 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유취득에 관한 것이며, 선의·무과실은 점유개시 시에만 있으면 된다(대법원 1994.11.11., 93다28089). 정답: ②

41 등기부시효취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 무효인 이중보존등기에 기초해서는 등기부취득시효가 완성되지 않는다.
- ② 등기부시효취득에 있어서 무과실은 점유에 관한 것이고 등기에 관한 것이 아니다.
- ③ 등기부시효취득에 있어서 과실 여부의 증명책임은 시효취득을 부인하는 소유자에게 있다.
- ④ 지적공부 소관청의 분필절차를 거치지 않은 채 등기부상 만으로 분할된 토지에 대한 등기부취득시효는 인정되지 않는다.
- ⑤ 점유의 승계는 물론 등기의 승계도 인정한다.

해설

- ③ 등기부취득시효에서 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유 취득에 관한 것으로서 그 무과실에 관한 입증책임은 시효취득을 주장하는 쪽에 있고, 부동산을 취득한 자는 부동산을 양도하는 자가 처분할 권한이 있는지 여부를 조사하여야 할 것이며, 이를 조사하였더라면 양도인에게 처분 권한이 없음을 알 수 있었음에도 불구하고 이러한 조사를 하지 아니하고 양수하였다면 그 부동산의 점유에 대하여 과실이 있다(대법원 2004.06.25. 2004다13052). 정답: ③

44

「민법」상 공동소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (특약은 고려하지 않음)

- ① 공유물의 임대는 공유자의 과반수로 결정한다.
- ② 공유자는 내부적 관계에서 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다.
- ③ 조합재산이 아닌 합유물을 처분하기 위해서는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다.
- ④ 합유물의 지분을 처분하기 위해서는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다.
- ⑤ 총유물의 처분은 물론 관리도 사원총회의 결의에 의해야 한다.

해설

- ① 공유물의 관리에 관한 사항, 즉 목적물의 이용 및 개량을 목적으로 하는 행위(공유물의 임대차 등)는 지분의 과반수로써 결정한다(제265조 본문). 정답: ①

45

공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 다른 공유자의 동의 없이 공유지분을 임의로 처분하지 못한다.
- ② 제3자가 공유물에 대하여 침해할 한 때에는 각 공유자는 단독으로 공유물 전부에 대한 방해의 제거를 청구할 수 있다.
- ③ 공유자는 그 지분의 비율로 조세를 부담한다.
- ④ 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 특별한 사유가 없는 한 각 공유자가 지분에 대응하는 비율의 한도 내에서만 이를 행사할 수 있다.
- ⑤ 공유자 중 한 사람이 그의 지분을 포기한 경우, 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다.

해설

- ① 제263조, 공유자의 지분처분은 자유롭다.
 ② 각 공유자는 그의 지분에 기해 단독으로 공유물 전부에 대한 방해의 제거를 청구할 수 있다.
 ③ 제266조
 ④ 대법원 1970.4.14, 70다171
 ⑤ 제267조 정답: ①

제4장
실전문제

46 공동소유에 관한 다음의 설명 중 가장 타당한 것은?

- ① 공유자는 공유물의 관리비용을 지분의 비율로 부담하지 않고 항상 균등하게 부담함을 원칙으로 한다.
- ② 공유자가 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때는 그 지분은 다른 공유자에게 전유부분의 면적의 비율로 귀속한다.
- ③ 권리능력 없는 사단은 민법상 조합과 유사하므로 재산의 소유권은 사원의 합유에 속한다.
- ④ 갑과 을이 토지를 60:40으로 공유하는 경우에 갑과 을이 공동으로 그 토지를 제3자 병에게 임대하고 있을 때, 병이 그 임대료 지분을 태만히 한 경우에 갑은 단독으로 그 임대계약을 해지할 수 없다.
- ⑤ 각 공유자는 제3자 또는 다투는 공유자만을 상대로 단독으로 지분에 관한 등기를 청구할 수 있거나 지분의 확인을 구할 수 있다.

해설

- ① 지분의 비율은 법률의 규정 또는 공유자의 의사표시에 의하여 정하여지며, 특별한 정함이 없는 경우에는 지분은 균등한 것으로 추정된다(제262조 제2항).
- ② 지분의 비율로 귀속한다(제267조).
- ③ 권리능력 없는 사단의 재산의 소유는 사원의 총유에 속한다(제275조 제1항).
- ④ 공유물의 임대 및 그에 따른 임대계약의 해지는 공유물의 관리행위에 해당하여 공유지분의 과반수로 결정하므로 지분의 과반수를 가지고 있는 갑은 단독으로 임대차 계약을 해지할 수 있다.

정답: ⑤

47 「민법」상 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (특약은 고려하지 않고, 다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 각 공유자는 자기 지분을 자유롭게 처분할 수 있다.
- ② 소수지분권자가 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 배타적으로 점유하는 경우, 다른 소수지분권자는 그 점유자를 상대로 보존행위에 기하여 공유물의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 공유자 1인이 포기한 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다.
- ④ 분할에 관한 협의가 성립한 후에 공유물분할소송을 제기하는 것은 허용되지 않는다.
- ⑤ 공유자는 다른 공유자가 공유물 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.

해설

- ② 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수는 없다(대법원 2020.5.21. 2018다287522 전원합의체) 정답: ②

다음 중 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 공유지분이 과반수에 미달하는 공유자도 공유물의 보존행위로서 다른 공유자와 협의 없이 공유물을 배타적으로 점유, 사용하고 있는 공유자에 대하여 공유물의 인도나 명도를 청구할 수 있다.
- ② 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의없이 그 공유 토지의 특정부분을 매도하여 타인의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다면 그 매도부분 토지에 관한 소유권이전등기는 처분자의 공유지분 내에서는 유효한 등기이다.
- ③ 여러 사람이 공유하는 물건을 현물분할하는 경우에는 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남겨두는 방법도 가능하다.
- ④ 지분권의 대외적 주장에는 지분권확인청구, 지분권의 등기청구, 방해배제청구, 인도청구, 시효의 중단이 있다.
- ⑤ 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 현물로 분할하는 것이 원칙이고, 현물로 분할할 수 없거나 현물로 분할하게 되면 그 가액이 현저히 감소될 염려가 있을 때에 비로소 물건의 경매를 명하여 대금분할을 할 수 있는 것이므로 위와 같은 사유가 없음에도 경매를 명함은 위법이다.

해설

- ① 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수는 없다.(대법원 2020.5.21. 2018다287522 전원합의체).
- ② 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의없이 그 공유 토지의 특정부분을 매도하여 타인 명의로 소유권이전등기가 마쳐지고, 그 매도부분 토지에 관한 소유권이전등기는 처분 공유자의 공유지분 범위 내에서는 실체관계에 부합하는 유효한 등기라고 보아야 한다(대법원 1994.12.12. 93다1596).
- ③ 토지를 현물분할함에 있어 일정한 요건이 갖추어진 경우에는 공유자 상호간에 금전으로 경제적 가치의 과부족을 조정하게 하여 분할을 하는 것도 현물분할의 한 방법으로 허용되고, 여러 사람이 공유하는 물건을 현물분할하는 경우에는 분할을 원하지 않는 나머지 공유자는 공유로 남겨 두는 방법도 허용된다(대법원 1997.9.9. 97다18219).
- ⑤ 대법원 1997.4.22. 95다32662 정답: ①

공유관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 부동산 공유자의 공유지분 포기의 의사표시가 다른 공유자에게 도달하더라도 이로써 곧바로 공유지분 포기에 따른 물권변동의 효력이 발생하는 것은 아니다.
- ② 소수지분권자는 공유물의 전부를 협의 없이 점유하는 다른 소수지분권자에게 공유물의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 과반수 지분권자는 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있다.
- ④ 토지공유자 사이에서는 지분비율로 공유물의 관리비용을 부담한다.
- ⑤ 공유자는 특별한 사정이 없는 한 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다.

해설

- ② 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수는 없다.(대법원 2020.5.21. 2018다287522 전원합의체). 정답: ②

50

甲, 乙, 丙은 X토지를 각각 7분의 1, 7분의 2, 7분의 4의 지분으로 공유하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 감정평가사]

- ① 甲이 乙, 丙과의 협의 없이 X토지 전부를 독점적으로 점유하는 경우, 乙은 甲에 대하여 공유물의 보존행위로서 X토지의 인도를 청구할 수 없다.
- ② 丁이 X토지 전부를 불법으로 점유하는 경우, 甲은 단독으로 X토지 전부의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 丙이 甲, 乙과의 협의 없이 X토지 전부를 戊에게 임대한 경우, 甲은 戊에게 차임 상당액의 7분의 1을 부당이득으로 반환할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 甲, 乙, 丙 사이의 X토지 사용 · 수익에 관한 특약이 공유지분권의 본질적 부분을 침해하지 않는 경우라면 그 특약은 丙의 특정승계인에게 승계될 수 있다.
- ⑤ 甲은 특별한 사정이 없는 한 乙, 丙의 동의 없이 X토지에 관한 자신의 지분을 처분할 수 있다.

해설

- ③ 과반수 지분의 공유자는 공유자와 사이에 미리 공유물의 관리방법에 관하여 협의가 없었다 하더라도 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있으므로 과반수 지분의 공유자는 그 공유물의 관리방법으로서 그 공유토지의 특정된 한 부분을 배타적으로 사용 · 수익할 수 있으나, 그로 말미암아 지분은 있으며 그 특정 부분의 사용 · 수익을 전혀 하지 못하여 손해를 입고 있는 소수지분권자에 대하여 그 지분에 상응하는 임료 상당의 부당이득을 하고 있다 할 것이므로 이를 반환할 의무가 있다 할 것이나, 그 과반수 지분의 공유자로부터 다시 그 특정 부분의 사용 · 수익을 허락받은 제3자의 점유는 다수지분권자의 공유물관리권에 터잡은 적절한 점유이므로 그 제3자는 소수지분권자에 대하여도 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻고 있다고 볼 수 없다(대법원 2002. 5. 14. 2002다9738). 정답: ③

51

공동소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2023' 감정평가사]

- ① 공유자는 다른 공유자의 동의없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다.
- ② 합유는 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태이고, 조합원은 자신의 지분을 조합원 전원의 동의없이 처분할 수 없다.
- ③ 합유물에 대한 보존행위는 합유자 전원의 동의를 요하지 않는다.
- ④ 구조상, 이용상 독립성이 있는 건물부분이라 하더라도 구분소유적 공유관계는 성립할 수 없다.
- ⑤ 공유물분할 금지약정은 갱신할 수 있다.

해설

- ④ 1동의 건물이 구조상 · 이용상으로 구분되어 독립성을 갖추고 있더라도 분양 면적 또는 매도 면적에 해당하는 비율로 공유지분등기를 마쳐 줌으로써 그 건물 각 층의 구분소유자들 사이에 상호명의신탁 관계 내지 구분소유적 공유관계가 성립할 수 있다(대법원 2013. 1. 17. 2010다71578 전원합의체). 정답: ④

54 공유물의 분할에 관한 내용 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 공유자는 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있으나 5년 이내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.
- ② 공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.
- ③ 당사자 간에 공유물분할에 대한 협의가 이루어진 경우에도 재판상 분할을 청구할 수 있다.
- ④ 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에는 법원은 경매를 명할 수 있다.
- ⑤ 공유물분할의 소(訴)는 필수적 공동소송으로서 다른 공유자 전원을 상대로 제기하여야 한다.

해설

- ③ 당사자 간에 분할에 대한 협의가 이루어지지 않은 때에 재판상 분할을 청구할 수 있다(제269조 제1항).
- ① 제268조
 - ② 제270조
 - ④ 제269조 제2항
 - ⑤ 대법원 2003.12.12., 2003다44615 · 2003다44622 정답: ③

55 민법상 부동산의 공동소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 공유자는 자기지분을 원칙적으로 자유롭게 처분할 수 있으나, 합유지분의 처분에는 제한이 있다.
- ② 합유물의 분할청구는 인정되지 않지만, 조합체의 해산 시에는 분할이 인정된다.
- ③ 공유물의 관리에 관한 사항은 특약이 없는 한, 지분의 과반수로 결정한다.
- ④ 비법인사단의 사원은 정관 기타 계약에 정함이 없는 한, 그 지위를 상실하면 총유물에 관한 권리도 소멸한다.
- ⑤ 비법인사단인 교회의 재산에 대하여 각 교인은 그 지분권을 인정받을 수 있다.

해설

- ⑤ 비법인사단인 교회의 재산은 교인들의 총유에 해당하고, 각 교인은 그 지분권이 인정되지 않는다.
정답: ⑤

공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 공유자 사이에 다른 특약이 없는 한 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다.
- ② 공유자의 1인이 상속인 없이 사망한 경우, 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속된다.
- ③ 공유물을 손괴한 자에 대하여 공유자 중 1인은 특별한 사유가 없는 한 공유물에 발생한 손해의 전부를 청구할 수 있다.
- ④ 공유토지 위에 건물을 신축하기 위해서는 공유자 전원의 동의가 있어야 한다.
- ⑤ 공유자가 다른 공유자의 지분권을 대외적으로 주장하는 것은 보존행위가 아니다.

해설

- ③ 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 특별한 사유가 없는 한 각 공유자는 그 지분에 대응하는 비율의 한도내에서만 이를 행사할 수 있다(대법원 1970.04.14. 70다171).
- ① 공유물의 관리비용 기타 의무는 공유자가 그 지분의 비율로 부담한다(제266조 제1항).
- ② 공유자 중 어느 한 사람이 그의 지분을 포기하거나, 상속인 없이 사망한 때에는 그 자의 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다(제267조).
- ④ 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다(제264조). 공유토지위의 건축행위는 공유물의 변경에 해당한다.
- ⑤ 공유자가 다른 공유자의 지분권을 대외적으로 주장하는 것은 보존행위가 아니다. 정답: ③

甲과 乙은 X토지를 공유하고 있는데, 甲의 지분은 2/3, 乙의 지분은 1/3이다. 다음 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲과 乙이 공유한 때로부터 10년 이상 경과하였다면 분할청구권이 소멸시효에 걸리므로, 乙은 甲에게 X토지의 분할을 청구할 수 없다.
- ② 乙이 관리비용 기타 의무이행을 1년 이상 지체한 때에는 甲은 상당한 가액으로 乙의 지분을 매수할 수 있다.
- ③ 丙이 X토지를 불법으로 점유하고 있는 경우, 乙은 丙에 대해 단독으로 X토지 전체에 대해 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 甲이 乙의 동의 없이 X토지 전부를 丙에게 임대하여 丙이 점유하는 경우, 乙은 丙에게 단독으로 점유의 배제를 청구할 수 있다.
- ⑤ 위 ④의 경우, 乙은 丙에게 차임상당의 부당이득반환청구를 할 수 있다.

해설

- ② 제266조 제2항
- ① 분할청구권은 공유관계에 수반되는 형성권으로서 공유관계가 존속하는 한 분할청구권만이 독립하여 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ③ 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 특별한 사유가 없는 한 각 공유자는 그 지분에 대응하는 비율의 한도 내에서만 이를 행사할 수 있다(대법원 1970.4.14. 70다171).
- ④ 과반수 지분권의 공유자로부터 사용·수익을 허락받은 점유자에 대하여 소수 지분의 공유자는 점유 배제를 구할 수 없다.
- ⑤ 제3자(丙)는 소수지분권자(乙)에 대하여도 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻고 있다고 볼 수 없다(대법원 2002.5.14., 2002다9738). 정답: ②

- ① 공유물분할청구권은 공유관계에 수반되는 형성권으로서 채권자대위권의 목적이 될 수 있다.
- ② 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자는 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수 없다.
- ③ 특별한 사정이 없는 한 공유물의 과반수지분권자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익하기로 정하는 것은 공유물의 관리방법으로서 적법하다.
- ④ 특별한 사정이 없는 한 공유물의 과반수지분권자로부터 사용·수익을 허락받은 점유자에 대하여 소수지분권자는 그 점유자가 사용·수익하는 공유물에 대한 점유배제를 구할 수 없다.
- ⑤ 특별한 사정이 없는 한 공유물의 과반수지분권자로부터 공유부동산의 특정 부분에 대한 사용·수익을 허락받은 제3자는 소수지분권자에 대해 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻은 것으로 볼 수 있다.

해설

- ⑤ 공유물의 과반수지분권자로부터 공유부동산의 특정 부분에 대한 사용·수익을 허락받은 제3자는 소수지분권자에 대해 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻은 것으로 볼 수 없다(대법원 2002.5.14., 2002다9738). 정답: ⑤

- ① 구분소유하는 건물과 그 부속물 중 공용하는 부분의 경우
- ② 주종을 구별할 수 없는 동산이 부합된 경우
- ③ 수인이 공동으로 매장물을 발견한 경우
- ④ 수인이 공동으로 유실물을 습득한 경우
- ⑤ 수인이 공동으로 무주물을 선점한 경우

해설

- ① 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다는 규정(제215조)과 경계에 설치된 경계표, 담, 구거 등은 상린자의 공유로 추정한다는 규정(제239조)에는 공유물분할에 관한 규정(제268조)이 적용되지 않는다.

정답: ①

공유물의 분할에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 분할 협의가 성립된 경우에는 일부 공유자가 분할에 따른 이전등기에 협조하지 않더라도 공유물 분할의 소를 제기할 수 없다.
- ② 현물분할의 경우에는 공유자 전원에게 지분의 비율로 분할하고, 일부만을 공유로 남기는 방법은 허용되지 않는다.
- ③ 공유물분할은 재판상 분할을 원칙으로 한다.
- ④ 공유물의 분할시 각 공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율과 관계없이 공유물 전부에 대하여 매도인과 동일한 담보책임이 있다.
- ⑤ 재판상 분할에 의하여 현물분할하는 경우, 분할부분의 경제적 가치의 과부족을 공유자 상호 간에 금전으로 조정하게 하는 것은 허용되지 않는다.

해설

- ①③ 공유물분할은 협의분할을 원칙으로 하고 협의가 성립되지 아니한 때에는 재판상 분할을 청구할 수 있으므로 공유자 사이에 이미 분할에 관한 협의가 성립된 경우에는 일부 공유자가 분할에 따른 이전등기에 협조하지 않거나 분할에 관하여 다툼이 있더라도 그 분할된 부분에 대한 소유권이 전등기를 청구하든가 소유권확인을 구함은 별문제이나 또다시 소로써 그 분할을 청구하는 것은 허용되지 않는다(대법원 1995.01.12. 94다30348,30355).
- ② 현물분할의 경우 공유자 전원에게 지분의 비율로 분할함이 원칙이나, 일부만을 공유로 남기는 방법도 허용된다.
- ④ 분할로 어떤 공유자가 취득한 부분에 하자가 있을 때에는 다른 공유자는 매도인의 담보책임을 진다.
- ⑤ 공유토지를 현물분할하는 경우에도 반드시 공유지분의 비율대로 토지면적을 분할해야 하는 것은 아니고 토지의 형상이나 위치, 이용상황이나 경제적 가치 등 제반 사정을 고려하여 경제적 가치가 지분비율에 상응하도록 분할할 수 있다. 정답: ①

공유물 분할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 공유물분할청구권은 형성권에 해당한다.
- ② 공유관계가 존속하는 한 공유물분할청구권만이 독립하여 시효로 소멸될 수 없다.
- ③ 부동산의 일부 공유지분 위에 저당권이 설정된 후 그 공유부동산이 현물분할된 경우, 저당권은 원칙적으로 저당권설정자에게 분할된 부분에 집중된다.
- ④ 공유물분할청구의 소에서 법원은 원칙적으로 공유물분할을 청구하는 원고가 구하는 방법에 구애받지 않고 재량에 따라 합리적 방법으로 분할을 명할 수 있다.
- ⑤ 공유자는 특별한 사정이 없는 한 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다.

해설

- ③ 부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 부동산이 분할된 경우, 그 저당권은 분할된 각 부동산 위에 종전의 지분비율대로 존속하고, 분할된 각 부동산은 저당권의 공동담보가 된다(대법원 2012.03.29. 2011다74932). 정답: ③

- ① 공유물분할의 효과는 원칙적으로 소급하지 않는다.
- ② 재판에 의한 공유물분할은 현물분할이 원칙이다.
- ③ 공유관계가 존속하는 한, 공유물분할청구권만이 독립하여 시효로 소멸하지는 않는다.
- ④ 공유토지를 현물분할하는 경우에 반드시 공유지분의 비율대로 토지 면적을 분할해야 하는 것은 아니다.
- ⑤ 공유물분할의 조정절차에서 공유자 사이에 현물분할의 협의가 성립하여 조정조서가 작성된 때에는 그 즉시 공유관계가 소멸한다.

해설

- ⑤ 공유물분할의 소송절차 또는 조정절차에서 공유자 사이에 공유토지에 관한 현물분할의 협의가 성립하여 그 합의사항을 조서에 기재함으로써 조정이 성립하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 재판에 의한 공유물분할의 경우와 마찬가지로 그 즉시 공유관계가 소멸하고 각 공유자에게 그 협의에 따른 새로운 법률관계가 창설되는 것은 아니고, 공유자들이 협의한 바에 따라 토지의 분필 절차를 마친 후 각 단독소유로 하기로 한 부분에 관하여 다른 공유자의 공유지분을 이전받아 등기를 마침으로써 비로소 그 부분에 대한 대세적 권리로서의 소유권을 취득하게 된다고 보아야 한다 (대법원 2013. 11. 21. 2011두1917 전원합의제). 정답: ⑤

甲, 乙, 丙은 A토지를 각각 5분의 3, 5분의 1, 5분의 1의 지분으로 공유하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲은 다른 공유자들과의 협의 없이 A토지의 관리방법을 정할 수 있다.
- ② 乙은 A토지에 제3자 명의로 경료된 원인무효인 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ③ 등기부상의 지분과 실제의 지분이 다르고 새로운 이해관계를 가진 제3자가 없다면, 공유물 분할소송에서 甲, 乙, 丙은 특별한 사정이 없는 한 실제의 지분에 따라 A토지를 분할하여야 한다.
- ④ 丙의 지분 위에 근저당권이 설정된 후 A토지가 지분에 따라 분할된 때에는 특별한 합의가 없는 한 그 근저당권은 丙에게 분할된 부분에 집중된다.
- ⑤ 甲, 乙, 丙 사이의 관리방법에 관한 약정에 따라 乙이 A토지의 특정부분만을 사용할 수 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 乙의 지분을 양수한 丁도 그 특정부분만을 사용할 수 있다.

해설

- ④ 공유자 중 1인의 지분위에 설정된 저당권은 공유물분할이 된 뒤에도 종전의 지분비율대로 공유물 전부 위에 그대로 존속한다. 따라서 丙이 분할 받은 부분에 집중되는 것이 아니다. 정답: ④

‘부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률’에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 위 법은 모든 부동산물권을 실체적 권리관계에 부합시키기 위해 실권리자가 등기하는 것을 목적으로 한다.
- ② 위 법이 정한 명의신탁약정과 이를 기초로 행하여진 등기에 의한 부동산물권변동은 무효이다.
- ③ 채무의 변제를 담보하기 위해 채권자가 부동산에 관한 물권을 가등기하는 것은 위 법이 무효로 하는 명의신탁약정에 해당하지 않는다.
- ④ 부동산의 특정된 부분을 2인 이상이 구분소유하면서 공유로 등기하는 소위 상호명의신탁은 위 법이 무효로 하는 명의신탁약정에 해당된다.
- ⑤ 명의수탁자가 일방당사자가 되고, 명의신탁약정에 관해 선의인 타방당사자가 부동산물권의 취득을 목적으로 하는 계약을 기초로 등기하여 성립한 물권변동은 유효하다.

해설

④ 명의신탁약정에 해당하지 않는다(제2조 제1호).

- ① 제1조
- ② 제4조 제1항·제2항
- ③ 제2조 제1호
- ⑤ 제4조 제2항 단서 정당: ④

‘부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률’에 대한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 명의수탁자가 일방당사자가 되고 명의신탁약정에 관해 선의의 타방 당사자가 부동산물권의 취득을 목적으로 하는 계약을 기초로 등기하여 성립한 물권변동은 유효하다.
- ② 종중명의신탁과 배우자명의의 명의신탁의 경우 조세포탈, 강제집행면탈 또는 법령상 제한의 회피 등을 목적으로 하지 않는 한 유효하다.
- ③ 동법에 의해 규제되는 명의신탁은 부동산에 관한 물권에 한정하고 기타 재산권에 관한 명의신탁의 경우에는 동법이 적용되지 않는다.
- ④ 부동산의 양도담보도 명의신탁약정에 포함시킨다.
- ⑤ 동법이 부동산등기제도를 악용한 투기, 탈세, 탈법행위 등 반사회적 행위를 방지하는 것을 목적으로 제정되었다 하더라도 타인명의의 등기가 당연히 불법원인급여에 해당한다고 볼 수 없다.

해설

④ 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률에 있어서 적용대상으로서의 명의신탁이라고 할 수 없는 경우는 다음과 같다(제2조 제1호).

- ㉠ 채무의 변제를 담보하기 위하여 채권자가 부동산에 관한 물권을 이전받거나 가등기하는 경우 (부동산의 양도담보와 가등기담보)
- ㉡ 부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상의 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 구분소유자의 공유로 등기하는 경우(상호명의신탁)
- ㉢ 신탁법 또는 신탁업법에 의한 신탁재산인 사실을 등기한 경우

- ① 제4조 제2항 단서 참조
- ② 제8조
- ③ 제4조 제1항
- ⑤ 부동산실명법을 위반하여 무효인 명의신탁약정에 따라 명의수탁자 명의로 등기를 하였다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 단정할 수는 없다(대법원 2019.6.20. 2013다 218156 전원합의체).
- ⑤ 대법원 2003.11.27. 2003다41722

◎ 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률

(1) 제정이유

이 법은 부동산에 관한 소유권 기타 물권을 실체적 권리관계에 부합하도록 실권리자 명의로 등기하게 함으로써 부동산등기제도를 악용한 투기·탈세·탈법행위 등 반사회적 행위를 방지하고 부동산 거래의 정상화와 부동산가격의 안정을 도모하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지하기 위하여 1995년 7월 1일부터 시행되게 되었다.

(2) 실권리자명의 등기의무와 명의신탁약정의 효력

1995년 7월 1일 이후에는 부동산의 물건변동등기는 실권리자명의로 하도록 하고 타인과 맺은 명의신탁약정은 무효로 한다. 계약명의신탁의 경우를 제외하고는 명의신탁약정에 의한 부동산의 물건변동은 무효로 하되, 등기부에 양도담보사실을 표시한 경우는 예외로 한다(제3조·제4조).

(3) 과징금과 이행강제금

타인명의로 등기를 한 명의신탁자에 대하여는 부동산가액의 30%의 해당하는 금액의 범위안에서 과징금으로 부과한다. 과징금을 부과 받은 자가 실권리자명의로 등기를 하지 아니하는 경우에는 첫째 해에는 부동산가액의 10%, 둘째 해에는 20%의 이행강제금을 부과하며 양도담보사실기재의무를 위반한 채권자에 대하여는 과징금을 부과한다(제5조·제6조).

(4) 벌 칙

명의신탁약정에 의하여 타인명의로 등기를 한 명의신탁자와 양도담보사실기재의무를 위반한 채권자 및 그 교사자 등에 대하여는 5년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금, 명의수탁자 및 그 교사자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금, 방조자에 대하여는 1년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다(제7조).

(5) 종중 및 배우자에 대한 특례

종중이나 배우자간에 타인명의로 등기를 한 경우로서 조세포탈, 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피 등 위법을 목적으로 하지 아니하는 경우에는 그 등기를 유효한 것으로 하고 과징금부과 및 처벌을 하지 아니한다(제8조).

(6) 장기 미등기자에 대한 벌칙

부동산취득일부터 60일 이내에 소유권이전등기를 하지 아니하여 현행 부동산등기특별조치법에 의하여 과태료의 부과대상이 되는 자로서 3년이 지나도록 소유권이전등기를 하지 아니한 자에 대하여는 명의신탁약정이 있는 경우와 같이 과징금을 부과한다(제10조).

(7) 기존 명의신탁약정에 의한 등기의 실명등기와 의무위반의 효력

- ① 1995년 6월 30일 이전의 기존 명의신탁자는 1995년 7월 1일부터 1년 이내에 실명등기를 하거나 당해 부동산에 관한 물권을 매각처분하여야 한다. 실권리자의 귀책사유 없이 다른 법률의 규정에 의하여 실명등기나 매각처분을 할 수 없는 경우에는 그 사유가 소멸한 후 1년 이내에 실명등기 또는 매각처분을 하여야 한다. 이 기간 내에 실명등기 또는 매각처분을 하지 아니한 경우에는 그 명의신탁약정은 무효로 하고 과징금을 부과한다(제11조·제12조 제1항 및 제2항).
- ② 1995년 6월 30일 이전의 명의신탁약정에 의한 등기를 한 사실이 없으면서 실명등기를 가장하여 등기명의를 이전하는 경우에는 5년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에 처한다(제12조 제3항).

정답: ④

2015년 5월경 명의신탁자 甲과 명의수탁자 乙의 약정에 따라, 乙은 매수인으로서 부동산 매도인 丙과 매매계약을 체결하고 대금을 지급한 후, 자신의 명의로 소유권이전등기를 경료받았다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」 제8조(중증, 배우자 및 종교단체에 관한 특례) 등에 해당하는 예외 사유가 없으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉠ 丙이 명의신탁약정을 알지 못한 경우, 甲은 乙에 대하여 소유권이전을 청구할 수 있다.
- ㉡ 丙이 명의신탁약정을 알고 있었던 경우, 乙은 丙에 대하여 매매대금의 반환을 청구할 수 있다.
- ㉢ 丙이 명의신탁약정을 알고 있었던 경우, 甲은 丙에 대하여 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ㉣ 丙이 명의신탁약정을 알고 있었던 경우, 甲은 丙을 대위하여 乙 명의 등기의 말소를 청구함과 동시에 丙에 대하여 매수인의 지위에서 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

① ㄱ

② ㉡

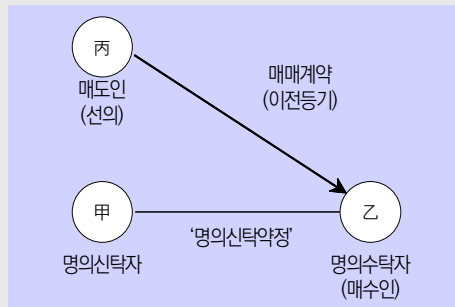
③ ㉡, ㉣

④ ㉢, ㉣

⑤ ㉠, ㉢, ㉣

해설

◎ 계약명의신탁의 법률관계



- ① 매도인 丙이 선의인 경우에는 甲과 乙사이의 명의신탁약정은 무효이지만 丙의 보호를 위해 乙명의로의 이전등기는 유효하다.
- ② 乙은 丙 및 甲에 대한 관계에서도 유효하게 소유권을 취득한다는 것이 판례의 태도이다.
- ③ 다만 甲은 乙에 대해 매매대금상당의 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다.

(1) 甲이 丙의 부동산을 매수하고자 하면서, 乙과의 명의신탁약정 하에 그에게 매매대금을 주어 그를 매수인으로 내세워서 丙과 매매계약을 체결토록 하였고, 그리하여 丙이 乙을 매수인으로 알고 이전등기를 한 경우, 수탁자 乙 명의의 이전등기는 유효하다(동법 제4조 제2항 단서). 이 경우, 만일 수탁자 乙 명의의 등기를 무효로 하면 그 부동산의 소유권이 여전히 매도인 丙에게 있게 되므로 丙이 받은 매매대금은 부당이득이 되어 버린다. 선의의 매도인 丙이 매매대금에 관하여 부당이득반환청구를 당하는 불합리한 결과를 방지하고자 수탁자의 乙의 등기를 유효로 한 것이다. 물론 丙이 악의인 경우에는 수탁자 乙의 등기는 '일반명의신탁'에 의한 등기에 해당하고 이는 무효이다.

(2) 수탁자가 제3자에게 처분한 경우

만일 수탁자 乙이 이를 다시 제3자 丁에게 매도하였다면 丁은 어느 경우에도 선의·악의를 불문하고 소유권을 취득하게 된다. 매도인 丙이 선의인 경우에는 수탁자 乙의 등기는 유효하므로 乙에게 일단 소유권이 있기 때문이며, 丙이 악의인 경우에는 수탁자 乙의 등기가 무효이지만 그 무효로써 제3자에게 대항할 수 없기 때문이다(부동산실명법 제4조 제3항).

(1) 신탁자의 수탁자에 대한 부당이득반환청구

- ① 위 (1)의 사례에서 신탁자 甲은 수탁자 乙에게 '신탁약정해지'에 의한 소유권이전등기를 청구

할 수는 없다. 신탁약정은 무효이기 때문이다.

- ㉔ 다만, 부동산실명법 시행 전에 위와 같은 명의신탁이 이루어진 경우라면 신탁자 甲은 수탁자 乙에게 '부동산 자체'를 부당이득으로 반환청구할 수 있다고 한다. 수탁자 乙의 등기가 유효함으로써 결과적으로 소유권을 취득하였지만 이를 부당이득으로 보는 것이다.
- ㉕ 반면에 계약명의신탁약정이 동법 시행 후에 이루어진 경우에는 '매수자금'에 관해서만 부당이득반환청구를 할 수 있다고 한다. 부동산실명법 시행 이후에는 신탁자는 애초부터 수탁자에게 신탁약정해지를 원인으로 하여 소유권이전등기를 청구할 수 없으므로, 수탁자 乙이 부당이득한 것은 부동산 자체가 아니라 甲으로부터 받은 매수자금으로 보는 것이다(대법원 2005.1.28. 2002다66922 등). 정답: ㉔

67

2022. 8. 16. 甲은 조세포탈의 목적으로 친구인 乙과 명의신탁약정을 맺고 乙은 이에 따라 甲으로부터 매수자금을 받아 丙 소유의 X토지를 자신의 명의로 매수하여 등기를 이전받았다. 이에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2022' 공인중개사]

- ① 甲과 乙의 명의신탁약정은 무효이다.
- ② 甲과 乙의 명의신탁약정이 있었다는 사실을 丙이 몰랐다면, 乙은 丙으로부터 X토지의 소유권을 승계취득한다.
- ③ 乙이 X토지의 소유권을 취득하더라도, 甲은 乙에 대하여 부당이득을 원인으로 X토지의 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
- ④ 甲은 乙에 대해 가지는 매수자금 상당의 부당이득반환 청구권에 기하여 X토지에 유치권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 만일 乙이 丁에게 X토지를 양도한 경우, 丁이 명의신탁약정에 대하여 단순히 알고 있었다면 丁은 X토지의 소유권을 취득하지 못한다.

해설

- ⑤ 수탁자 乙이 이를 다시 제3자 丁에게 매도하였다면 丁은 어느 경우에도 선의·악의를 불문하고 소유권을 취득하게 된다. 매도인 丙이 선의인 경우에는 수탁자 乙의 등기는 유효하므로 乙에게 일단 소유권이 있기 때문이며, 丙이 악의인 경우에는 수탁자 乙의 등기가 무효이지만 그 무효로써 제3자에게 대항할 수 없기 때문이다(부동산실명법 제4조 제3항). 정답: ⑤

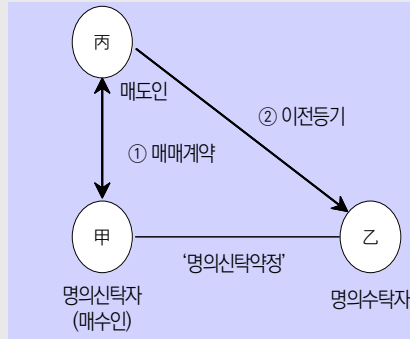
68

甲은 丙 소유의 X토지를 매수하면서 자신과 명의신탁약정을 한 친구 乙 앞으로 소유권이전등기를 해 주기로 丙과 합의하였고, 그에 따라 X토지의 소유권이전등기가 乙 명의로 마쳐졌다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 乙 명의의 소유권이전등기는 무효이다.
- ② 丙은 乙에게 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 甲은 丙을 대위하여 乙에게 소유권이전등기의 말소청구를 할 수 없다.
- ④ 丙은 甲에 대하여 소유권이전등기의무를 부담한다.
- ⑤ 乙로부터 정당하게 X토지를 매수한 丁이 甲과 乙 사이의 명의신탁 약정사실을 알았더라도, 丁은 乙로부터 X토지를 유효하게 취득할 수 있다.

해설

㉔ 3자간 명의신탁(중간생략등기형 명의신탁)의 법률관계



- ① 명의신탁약정과 등기는 모두 무효이므로 명의 신탁된 부동산은 매도인 소유로 복귀된다. 따라서 丙은 乙에 대하여 말소등기를 청구하거나, 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ② 丙과 甲의 매매계약은 유효하므로 甲은 丙에 대하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 甲은 丙을 대위하여 乙에게 등기의 말소를 청구할 수 있다.

- (1) 신탁자 甲이 직접 매도인 丙으로부터 부동산을 매수하는 계약을 체결하되, 丙에게 부탁하여 이전 등기는 수탁자 乙에게 하였다면, 乙명의의 등기는 무효로 된다. 계약명의신탁과는 달리 매도인 丙이 甲과 乙 사이에 명의신탁약정이 있음을 알고 있으므로 보호의 필요성이 없고, 따라서 수탁자 乙의 등기는 '일반명의신탁'에 의한 등기가 되기 때문이다.
- (2) 신탁자 甲은 '신탁약정의 해지'를 원인으로 乙에 대해서 소유권이전등기를 청구할 수 없거나(신탁약정이 무효이므로), 부당이득반환을 원인으로 하여 소유권이전등기를 청구할 수도 없다(대법원 2008.11.27. 2008다55290).
- (3) 수탁자 乙 명의의 등기는 무효이므로 당해 부동산의 소유권은 여전히 매도인 丙에게 있는 것이고, 따라서 매도인 丙은 명의수탁자 乙에게 무효인 등기의 말소를 청구할 수 있는 권리를 갖게 된다. 한편 甲은 丙에 대한 매수인으로서 소유권이전등기청구권을 가지므로, 결국 甲은 丙을 대위하여 명의수탁자 乙에게 이전등기의 말소를 구할 수 있다(대법원 2002.11.22. 2002다11496).
- (4) 만일 명의수탁자 乙이 명의신탁자 甲 앞으로 바로 등기를 해주었다면, 이러한 소유권이전등기는 실체관계에 부합하는 등기로서 유효하다(대법원 1999.9.17. 99다21738).
- (5) 만일 수탁자 乙이 그 부동산을 제3자 丁에게 매도하였다면 丁은 선의·악의를 불문하고 유효하게 소유권을 취득한다. 수탁자 乙의 등기가 무효이지만 이로써 제3자에게 대항할 수 없기 때문이다.

정답: ③

제4장
실전문제

69

甲 소유의 X부동산을 乙이 매수하였으나, 등기과정 중 甲의 양해를 받고 乙, 丙간의 명의 신탁약정에 따라 丙 명의를 빌어 등기하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 갑은 병에게 등기의 말소를 청구할 수 없다.
- ② 을은 갑에게 이전등기를 청구할 수 없다.
- ③ 갑·을 간의 매매계약의 효력은 무효이다.
- ④ 을·병 간 명의신탁약정의 효력은 유효이다.
- ⑤ 을은 갑을 대위하여 병에게 등기말소를 청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 을은 갑을 대위하여 명의수탁자 병에게 무효인 그 등기명의의 말소를 구할 수 있다. 설문의 경우는 3자간 명의신탁으로서 판례(대법원 2002.3.15. 2001다61654)의 태도에 따르면
- ① 갑은 병에 대하여 무효를 이유로 말소등기를 청구할 수 있다.
- ② ③ 갑과 을 사이의 매매계약은 유효이므로 을은 갑에 대하여 이전등기를 청구할 수 있다.
- ④ 을·병 간의 명의신탁 약정의 효력은 무효이다. 정답: ⑤

70

2014년 丙 소유 X토지를 취득하고 싶은 甲은 그 친구 乙과 X토지의 취득에 관한 명의신탁약정을 맺고 乙에게 X토지를 매수하기 위한 자금을 제공하면서 乙 명의로 丙과 계약 하도록 하였다. 이에 乙은 그 사실을 알지 못하는 丙으로부터 X토지를 매수하여 자기 앞으로 이전등기를 마쳤다. 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲과 乙의 명의신탁약정은 무효이다.
- ② 乙은 甲으로부터 받은 X토지 매수대금을 甲에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다.
- ③ 만약 丙이 명의신탁약정의 존재를 알았다면 X토지에 관한 물권변동은 무효이다.
- ④ 만약 乙이 완전한 소유권을 취득했음을 전제로 사후적으로 甲과 매수자금반환의무의 이행에 갈음하여 X토지를 양도하기로 약정하고 甲 앞으로 소유권이전등기를 마쳤다면, 그 등기는 원칙적으로 유효하다.
- ⑤ 만약 甲과 乙의 명의신탁약정 및 乙 명의의 등기가 「부동산 실권리자 명의등기에 관한 법률」의 시행 전에 이루어지고, 같은 법 소정의 유예기간 내에 甲 앞으로 등기가 되지 않았다면, 乙은 甲에게 X토지를 부당이득으로 반환할 의무가 없다.

해설

- ⑤ 부동산실명법 시행 전에 위와 같은 명의신탁이 이루어진 경우라면 신탁자 甲은 수탁자 乙에게 '부동산 자체'를 부당이득으로 반환을 청구할 수 있다. 수탁자 乙의 등기가 유효함으로써 결과적으로 소유권을 취득하였지만 이를 부당이득으로 보는 것이다. 반면에 계약명의신탁약정이 동법 시행 후에 이루어진 경우에는 '매수자금'에 관해서만 부당이득반환청구를 할 수 있다. 실명법 시행 이후에는 신탁자는 애초부터 수탁자에게 신탁약정해지를 원인으로 하여 소유권이전등기를 청구할 수 없으므로, 수탁자 乙이 부당이득한 것은 부동산 자체가 아니라 甲으로부터 받은 매수자금으로 보는 것이다(대법원 2005.1.28. 2002다66922). 정답: ⑤

71

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률상 명의신탁에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무효인 명의신탁등기가 행하여진 후 신탁자와 수탁자가 혼인한 경우, 조세포탈 등의 목적이 없더라도 그 명의신탁등기는 유효로 인정될 수 없다.
- ② 채무변제를 담보하기 위해 채권자 명의로 부동산에 관한 소유권이전등기를 하기로 하는 약정은 명의신탁약정에 해당하지 않는다.
- ③ 무효인 명의신탁약정에 기하여 타인 명의의 등기가 마쳐졌다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 볼 수 없다.
- ④ 조세포탈 등의 목적 없이 종교단체 명의로 그 산하조직이 보유한 부동산의 소유권을 등기한 경우, 그 단체와 조직 간의 명의신탁약정은 유효하다.
- ⑤ 신탁자는 명의신탁약정의 무효로서 수탁자로부터 소유권이전등기를 받은 제3자에게 그의 선의·악의 여부를 불문하고 대항하지 못한다.

해설

- ① '부동산 실권리자 명의등기에 관한 법률' 제8조 제2호에서는 배우자 명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우로서 조세포탈, 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는

경우에는 그 명의신탁약정과 그 약정에 기하여 행하여진 물건변동을 무효로 보는 위 법률 제4조 등을 적용하지 않는다고 규정하고 있는바, 어떠한 명의신탁등기가 위 법률에 따라 무효가 되었다고 할지라도 그 후 신탁자와 수탁자가 혼인하여 그 등기의 명의자가 배우자로 된 경우에는 조세 포탈, 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 한 이 경우에도 위 법률 제8조 제2호의 특례를 적용하여 그 명의신탁등기는 당사자가 혼인한 때로부터 유효하게 된다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 25. 2002다23840). 정답: ①

72 명의신탁에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름) [2020' 감정평가사]

- ① 종중재산이 여러 사람에게 명의신탁된 경우, 그 수탁자들 상호간에는 형식상 공유관계가 성립한다.
- ② 3자간 등기명의신탁관계의 명의신탁자는 수탁자에게 명의신탁된 부동산의 소유권이전등기를 청구하지 못한다.
- ③ 채무자는 채권을 담보하기 위하여 채권자에게 그 소유의 부동산에 관한 소유권이전등기를 할 수 있다.
- ④ 부부 사이에 유효하게 성립한 명의신탁은 배우자 일방의 사망으로 잔존배우자와 사망한 배우자의 상속인에게 효력을 잃는다.
- ⑤ 계약 상대방이 명의수탁자임을 알면서 체결한 매매계약의 효력으로 소유권이전등기를 받은 사람은 소유권을 취득한다.

해설

- ④ 부동산실명법 제8조 제2호에 따라 부부간 명의신탁이 일단 유효한 것으로 인정되었다면 그 후 배우자 일방의 사망으로 부부관계가 해소되었다 하더라도 그 명의신탁약정은 사망한 배우자의 다른 상속인과의 관계에서도 여전히 유효하게 존속한다고 보아야 한다(대법원 2013.1.24. 2011다99498).
- ① 종중재산이 여러 사람에게 명의신탁된 경우 그 수탁인들 상호간에는 형식상 공유관계가 성립한다(대법원 1992.9.8. 92다18184).
- ② 명의신탁자는 매도인을 대위하여 명의수탁자에게 등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ③ 양도담보의 설정을 의미한다.
- ⑤ 명의수탁자로부터 부동산을 전득한 제3자는 선의·악의를 불문하고 명의신탁부동산의 소유권을 취득한다(부동산실명법 제4조 제3항). 정답: ④

73 부동산 실권리자명의등기에 관한 법률에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 명의신탁자에게 법률효과를 직접 귀속시킬 의도의 매매계약을 체결한 사정이 인정되더라도, 부동산매매계약서에 명의수탁자가 매수인으로 기재되어 있다면 계약명의신탁으로 보아야 한다.
- ② 부동산소유권 또는 그 공유지분은 명의신탁 대상이 되지만, 용익물권은 명의신탁의 대상이 될 수 없다.
- ③ 탈법적 목적이 없는 종중재산의 명의신탁에 있어서 종중은 명의신탁재산에 대한 불법점유자 내지 불법등기명의자에 대하여 직접 그 인도 또는 등기말소를 청구할 수 있다.

- ④ 탈법적 목적이 없더라도 사실혼 배우자간의 명의신탁은 무효이다.
- ⑤ 계약당사자인 매수인이 명의수탁자라는 사정을 매도인이 알지 못하였더라도, 매매로 인한 물건변동은 무효이다.

해설

- ④ 타당한 기술이다(1998. 7. 10, 98다18988).
- ① 명의신탁약정이 3자간 등기명의신탁인지 아니면 계약명의신탁인지의 구별은 계약당사자가 누구인가를 확정하는 문제로 귀결되는데, 계약명의자가 명의수탁자로 되어 있다 하더라도 계약당사자를 명의신탁자로 볼 수 있다면 이는 3자간 등기명의신탁이 된다. 따라서 계약명의자인 명의수탁자가 아니라 명의신탁자에게 계약에 따른 법률효과를 직접 귀속시킬 의도로 계약을 체결한 사정이 인정된다면 명의신탁자가 계약당사자이고, 이 경우의 명의신탁관계는 3자간 등기명의신탁으로 보아야 한다(대법원 2022.4.28. 2019다300422).
- ③ 중증은 명의신탁재산에 대한 불법점유자 내지 불법등기명의자에 대하여 직접 그 인도 또는 등기말소를 청구할 수는 없고 명의수탁자를 대위하여 청구할 수 있다.
- ⑤ 매도인이 선의인 경우에는 명의신탁자와 명의수탁자 사이의 명의신탁약정은 무효이지만 매도인 보호를 위해 명의수탁자 명의의 이전등기(물권변동)는 유효하다. 정답: ④

74

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률상 명의신탁에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 투기·탈세 등의 방지라는 법의 목적상 명의신탁은 그 자체로 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반된다.
- ② 명의신탁이 무효인 경우, 신탁자와 수탁자가 혼인하면 명의신탁약정이 체결된 때로부터 위 명의신탁은 유효하게 된다.
- ③ 부동산 명의신탁약정의 무효는 수탁자로부터 그 부동산을 취득한 악의의 제3자에게 대항할 수 있다.
- ④ 농지법에 따른 제한을 피하기 위하여 명의신탁을 한 경우에도 그에 따른 수탁자 명의의 소유권이전등기가 불법원인급여라고 할 수 없다.
- ⑤ 조세포탈 등의 목적 없이 종교단체장의 명의로 그 종교단체 보유 부동산의 소유권을 등기한 경우, 그 단체와 단체장 간의 명의신탁약정은 유효하다.

해설

- ④ 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(이하 '부동산실명법'이라 한다) 규정의 문언, 내용, 체계와 입법 목적 등을 종합하면, 부동산실명법을 위반하여 무효인 명의신탁약정에 따라 명의수탁자 명의로 등기를 하였다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 단정할 수는 없다. 이는 농지법에 따른 제한을 회피하고자 명의신탁을 한 경우에도 마찬가지이다(대법원 2019. 6. 20. 2013다218156 전원합의체). 정답: ④

75

2020년 5월 신탁자 甲과 그의 친구인 수탁자 乙이 X부동산에 대하여 명의신탁약정을 한 후, 乙이 직접 계약당사자가 되어 丙으로부터 X를 매수하고 소유권이전등기를 마쳤다. 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 甲과 乙 사이의 명의신탁약정은 무효이다.
- ② 丙이 甲 · 乙 사이의 명의신탁약정 사실을 몰랐다면 乙은 X의 소유권을 취득한다.
- ③ 丙이 甲 · 乙 사이의 명의신탁약정 사실을 알았는지 여부는 소유권이전등기가 마쳐진 때를 기준으로 판단하여야 한다.
- ④ 乙이 X의 소유자가 된 경우 甲으로부터 제공받은 매수자금 상당액을 甲에게 부당이득으로 반환하여야 한다.
- ⑤ 丙이 甲 · 乙 사이의 명의신탁약정 사실을 안 경우에도 乙이 그 사정을 모르는 丁에게 X를 매도하여 소유권이전등기를 마쳤다면 丁은 X의 소유권을 취득한다.

해설

- ③ 丙이 甲 · 乙 사이의 명의신탁약정 사실을 알았는지 여부는 매매계약 당시를 기준으로 판단한다.

정답: ③

76

구분소유적 공유관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 구분소유적 공유관계의 해소는 상호명의신탁의 해지에 의한다.
- ② 당사자 내부에 있어서는 각자가 특정매수한 부분은 각자의 단독 소유가 된다.
- ③ 구분소유적 공유지분을 매수한 자는 당연히 구분소유적 공유관계를 승계한다.
- ④ 제3자의 방해행위가 있으면 공유자는 자기의 구분소유 부분뿐만 아니라 전체 토지에 대하여 공유물의 보존행위로서 그 배제를 구할 수 있다.
- ⑤ 구분소유적 공유관계는 어떤 토지에 관하여 그 위치와 면적을 특정하여 여러 사람이 구분 소유하기로 하는 약정이 있어야만 적법하게 성립할 수 있다.

해설

- ③ 구분소유적 공유자가 그 권리를 타인에게 처분하는 경우에는 구분소유의 목적인 특정 부분을 처분하면서 등기부상 공유지분을 그 특정 부분에 대한 표상으로서 이전하는 경우와 등기부의 기재대로 1필지 전체에 대한 진정한 공유지분을 처분하는 경우가 있을 수 있다. 전자의 경우에는 구분소유적 공유관계가 승계되나, 후자의 경우에는 그 매수인이 부동산 전체에 대한 공유지분을 취득하고, 구분소유적 공유관계는 소멸된다(대법원 2022. 3. 31. 2021다215589, 215596).

정답: ③

용익물권

1

기본문제

01

지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권자는 권리의 존속기간 내에서 타인에게 그 토지를 임대할 수 있다.
- ② 지상권자는 지상권을 유보한 채 지상물 소유권만을 양도할 수 있으나 지상물 소유권을 유보한 채 지상권만을 양도할 수는 없다.
- ③ 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권의 최단존속기간은 30년이다.
- ④ 지료의 지급은 지상권의 요소가 아니어서 지료에 관한 유상 약정이 없는 이상 지료의 지급을 구할 수 없다.
- ⑤ 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.

해설

- ② 지상권자는 지상권을 유보한 채 지상물 소유권만을 양도할 수도 있고 지상물 소유권을 유보한 채 지상권만을 양도할 수도 있는 것이어서 지상권자와 그 지상물의 소유권자가 반드시 일치하여야 하는 것은 아니며, 또한 지상권설정시에 그 지상권이 미치는 토지의 범위와 그 설정 당시 매매되는 지상물의 범위를 다르게 하는 것도 가능하다(대법원 2006.6.15. 2006다6126). 정답: ②

02

전세권과 부동산임차권을 비교한 다음 설명으로 틀린 것은?

- ① 전세권에 있어서는 전세권자가 양도·임대·전전세를 할 수 있으나, 임차인은 임대인의 동의 없이는 양도·전대를 할 수 없다.
- ② 전세권자와 임차인 모두에게는 부속물매수청구권이 있다.
- ③ 전세권자와 임차인 모두 목적물에 들인 필요비·유익비의 상환청구는 할 수 있다.
- ④ 임차인의 파산은 전세권의 경우와 달리 임대차의 해지통고사유가 된다.
- ⑤ 임대차에서는 묵시의 갱신이 되나, 토지전세권에는 그것이 인정되지 않는다.

◎ 지상권과 전세권, 임차권의 비교

구 분	지 상 권	전 세 권	임 차 권
성 질	- 용익물권 - 절대권, 대세권	- 용익물권+담보물권성 - 절대권, 대세권	- 채권 - 상대권, 대인권
성 립	설정계약+등기	설정계약+등기 +전세금 수수	설정계약
대항력	인 정	인정(경매권, 우선변제력)	등기하면 인정
최장기간	제한 없음	10년	제한 없음
최단기간	- 건고한 건물, 수목 : 30년 - 기타 건물 : 15년 - 공작물 : 5년	- 토지전세권 : 제한 없음 - 건물전세권 : 1년	- 민 법 : 제한 없음 - 주임법 : 2년 - 상임법 : 1년
기간약정 없는 경우	최단기간으로 제한	언제든지 소멸통고 가능	언제든지 해지통고 가능
약정갱신	최단기간 이상으로 약정	10년을 초과할 수 없음	제한 없음
법정갱신	명문규정이 없음	규정 있음	규정 있음
요 소	지료는 요소가 아님	반드시 전세금이 수수	차임이 요소
증감청구	인 정	인 정	인 정
연 체	2년 연체시 소멸청구		2기의 연체로 해지
비용청구	유익비만 가능	유익비만 가능	필요비, 유익비 모두 가능

③ 전세권자는 목적물의 유지·수선의무가 있으므로 필요비상환청구는 할 수 없다. 정답: ③

03 지상권에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지상권은 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 타인의 토지를 사용하는 권리이다.
- ② 토지사용의 대가인 지료의 지급은 지상권의 성립요소이다.
- ③ 지상권자는 타인에게 그 지상권을 양도할 수 있다.
- ④ 지상권자는 지상권의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다.
- ⑤ 지상권의 존속기간은 약정하지 아니한 경우, 건물 이외의 공작물의 소유를 목적으로 하는 지상권의 존속기간은 5년이다.

해설

◎ 지상권의 존속기간

(1) 약정에 의한 존속기간

최 단 기 간	- 다음 연한보다 단축하지 못한다. - 석조, 석회조, 연와조 기타 견고한 건물이나 수목의 소유 : 30년 - 기타의 건물(목조 등) : 15년 - 건물 이외의 공작물의 소유 : 5년 - 이상의 기간보다 짧은 약정기간은 위의 최단기간으로 연장된다.
최 장 기 간	명문규정이 없으며, 영구무한의 지상권설정여부에 대해서는 학설의 대립이 있으나, 판례는 인정한다(대법원 2001.5.29. 99다66410).

(2) 약정이 없는 경우의 존속기간

- ① 지상물의 종류와 구조에 따라 제280조의 최단존속기간을 그 기간으로 한다.
- ② 지상권 설정 당시에 공작물의 종류와 구조를 정하지 않은 경우 : 15년

② 지료의 지급은 지상권의 성립요소가 아니다. 정답: ②

04 법정지상권에 관한 다음 기술 중 틀리는 것은?

- ① 대지와 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우에 건물에 대해서만 전세권을 설정한 후, 그 대지의 소유자가 변경된 때에는 전세권자는 법정지상권을 취득한다.
- ② 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속하게 된 경우에 건물 소유자는 법정지상권을 취득한다.
- ③ 입목의 경매 등으로 인하여 토지와 그 입목이 다른 소유자에게 속하게 된 경우에 입목의 소유자는 법정지상권을 취득한다.
- ④ 토지와 건물이 동일소유자에게 속하였다가 건물이나 토지가 매매 등으로 인하여 그 소유자가 다르게 된 때에는 건물소유자는 관습에 의한 법정지상권을 취득한다.
- ⑤ 이들 법정지상권은 등기 없이도 성립하지만, 이를 처분하려면 등기하여야 한다.

해설

◎ 지상권의 취득

법률행위로 인한 취득	㉠ 설정계약에 의한 취득 ㉡ 유언과 지상권의 양도에 의한 취득
법률의 규정에 의한 취득	㉠ 상속, 판결, 경매, 공용징수, 취득시효 등에 의한 취득 ㉡ 법정지상권에 의한 취득 ㉢ 대지와 건물이 동일소유자에게 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다(제305조). ㉣ 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다(제366조). ㉤ 성립요건 : 저당권설정 당시에 건물이 존재할 것과 저당권설정 당시에 토지와 건물이 동일한 소유자에게 속할 것을 요한다.

	㉔ 경매의 결과로 입목소유자와 토지소유자가 다르게 된 경우, 입목소유자는 법정지상권을 취득한 것으로 본다. ㉕ 법정지상권의 취득은 등기를 요하지 않으나 제3자에게 처분하기 위해서는 등기가 필요하다. ㉖ 법정지상권에 관한 규정은 강행규정이므로 당사자의 특약으로 그 성립을 막지 못한다.
--	--

①의 경우 전세권자가 아니라 전세권설정자가 법정지상권을 취득한다. 정답: ①

05 관습법상의 법정지상권에 관한 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 매매에 의하여 토지소유자와 건물소유자가 다르게 된 경우에도 관습법상의 법정지상권이 성립할 수 있다.
- ② 견고하지 않은 건물의 소유를 목적으로 하는 경우에는 그 존속기간이 5년으로 된다.
- ③ 관습법상의 법정지상권을 취득한 건물소유자는 지상권의 등기 없이도 토지소유권을 취득한 제3자에 대하여 그 권리를 주장할 수 있다.
- ④ 제3자가 관습법상의 법정지상권을 취득하려면 건물소유자가 먼저 그의 법정지상권의 등기를 하고 그 다음에 이 지상권의 이전등기를 하여야 한다.
- ⑤ 토지와 건물 중 건물만을 양수하면서 건물을 위하여 따로 토지의 임대차계약을 체결한 경우에는 관습법상의 법정지상권이 성립하지 않는다.

해설

- ② 관습법상의 법정지상권의 존속기간에 대하여 특별한 규정이 없는 한 원칙적으로 약정을 하지 않은 것으로 처리되므로(제281조), 견고하지 않은 건물의 소유를 목적으로 하는 때에 그 존속기간은 15년이다(제280조 제1항).
- ③④ 제187조 단서 정답: ②

제5장
기본문제

06 다음 중 관습법상의 법정지상권이 성립하는 경우는 어느 것인가?

- ① 동일인의 소유인 토지와 건물 중 하나가 소유자를 달리하게 되고 건물을 철거한다는 특약이 없을 때
- ② 동일인의 소유인 토지와 건물 중 건물에 전세권이 설정된 후 토지소유자가 달라진 때
- ③ 토지에 저당권이 설정된 후 저당권의 실행으로 토지와 건물의 소유자가 달라진 때
- ④ 건물에 저당권이 설정된 후 저당권의 실행으로 토지와 건물의 소유자가 달라진 때
- ⑤ 동일인의 소유인 토지와 입목이 경매 기타의 사유로 소유자가 각각 달라진 때

해설

◎ 관습법상의 법정지상권

의 의	동일인 소유의 토지와 건물 중의 어느 한쪽이 매매 기타의 원인으로 소유자를 각각 달리하게 된 경우, 당사자 사이에 특약이 없는 한 건물소유자는 당연히 지상권을 취득한다.
-----	--

성 립 요 건	▪ 토지와 건물의 소유자가 동일인일 것 ▪ 토지와 건물 중 어느 한쪽이 매매, 증여, 대물변제, 강제경매 등으로(환지처분, 담보권실행으로 인한 경매이외의 사유) 소유자를 달리할 것 ▪ 당사자 사이에 건물을 철거한다는 특약이 없을 것
내 용	민법의 지상권에 관한 규정은 관습법상의 법정지상권에 준용한다.

정답: ①

07 법정지상권의 효력에 관한 다음 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 법정지상권의 존속기간이나 기타의 효력은 일반지상권과 같다.
- ② 법정지상권의 범위는 반드시 그 건물의 대지에 국한되는 것은 아니며 그 건물의 이용에 필요한 상당한 범위이다.
- ③ 법정지상권에 관한 규정은 지상물의 소유자를 보호하기 위한 것이므로 당사자의 약정으로 적용을 배제할 수 있다.
- ④ 자료는 당사자의 협의에 의하여 정할 것이나, 협의가 성립되지 않을 때에는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.
- ⑤ 토지에 저당권이 설정된 후 저당권설정자가 그 위에 건물을 건축하였다가 담보권의 실행을 위한 경매로 인하여 그 토지와 지상 건물이 소유자를 달리하였을 경우에는, 제366조의 법정지상권이 인정되지 아니할 뿐만 아니라 관습상의 법정지상권도 인정되지 않는다.

해설

- ③ 법정지상권에 관한 규정은 강행규정으로서 당사자의 약정으로 그 규정의 적용을 배제할 수 없다 (대법원 1988.10.25. 87다카1564).
- ④ 제366조 단서
- ⑤ 대법원 1995.12.11. 95마1262 정답: ③

08 구분지상권에 관한 기술로 틀린 것은?

- ① 구분지상권은 토지소유자에 대한 권리가 아니라 타인 토지의 공중 또는 지하의 공간의 이용가치를 직접 지배하는 물권이다.
- ② 구분지상권이 당해 토지를 사용·수익할 권리를 가진 제3자의 승낙을 얻어 설정된 경우에는 이 권리를 가진 제3자는 지상권의 정당한 행사를 방해하지 못한다.
- ③ 구분지상권의 성립에 있어서 자료의 지급은 그 요건이 아니다.
- ④ 구분지상권은 토지의 어느 층만을 객체로 한다는 점에서 일반지상권과 양적인 차이가 있으나, 그 성질에 있어서는 지상권과 다를 바 없고 그 범위를 반드시 등기하여야 한다.
- ⑤ 구분지상권에 의해 소유할 수 있는 목적물은 건물 기타의 공작물 및 수목이다.

해설

◎ 구분지상권

성 질	▪ 건물 기타의 공작물의 소유를 목적으로 하며 수목은 그 객체가 될 수 없다. ▪ 토지의 상하의 어느 층만을 객체로 한다. ▪ 물건으로서 지상권의 일종이다.
설 정	▪ 설정계약과 등기로서 설정된다. ▪ 그 토지 위의 용익권자와 그 용익권을 목적으로 하는 권리를 가지는 자의 승낙은 구분지상권의 성립요건이다. ▪ 승낙을 한 용익권자는 구분지상권자의 정당한 행사를 방해하지 못한다.
효 력	지상권에 관한 규정을 준용한다(제290조 제2항).

정답: ⑤

09 지역권에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 요역지는 1필지의 전부이어야 하나, 승역지는 1필 토지의 전부 또는 일부이다.
- ② 요역지와 분리하여 지역권만을 따로 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못하는데 이를 지역권의 부종성이라고 한다.
- ③ 요역지 소유자가 승역지의 소유권을 취득하여도 지역권은 성질상 소멸하지 않는다.
- ④ 지역권은 약정소멸사유의 발생으로도 소멸한다.
- ⑤ 승역지에 대하여 점유자의 취득시효가 진행하고 있는 동안에 지역권자가 그의 권리를 행사 하면 지역권의 제한을 받으므로 승역지가 시효취득 되어도 지역권은 소멸하지 않는다.

제5장
기본문제

해설

◎ 지역권의 소멸사유

물권일반의 소멸사유	▪ 요역지 또는 승역지의 멸실 ▪ 지역권자의 지역권의 포기 ▪ 혼 동 ▪ 존속기간의 만료 ▪ 약정소멸사유의 발생 ▪ 소멸시효
지역권 특유의 소멸원인	▪ 승역지소유자의 위기(제298조·제299조) ▪ 승역지의 시효취득 ▪ 승역지의 수용

- ③ 요역지 소유자가 승역지의 소유권을 취득하면 지역권은 혼동으로 소멸한다.
- ② 제292조 정답: ③

10 지역권의 시효취득에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 점유로 인한 지역권취득시효의 중단은 요역지가 공유인 때에는 그 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유로 그 효력이 있다.
- ② 요역지를 공유하고 있을 때, 공유자의 1인이 그 토지의 지역권의 소멸시효를 중단시키면 소멸시효는 전 공유자를 위하여 완성하지 않는다.
- ③ 요역지의 소유자, 지상권자, 전세권자 등이 시효취득의 주체가 될 수 있다.
- ④ 공유자의 1인이 취득시효로 지역권을 취득할 때에도, 지역권의 불가분성을 이유로 다른 공유자도 그것을 취득한다고 할 수 있다.
- ⑤ 불계속 또는 불표현의 지역권도 시효취득할 수 있다.

해설

⑤ 시효취득이 인정되는 지역권은 계속되고 표현된 지역권에 한한다. 정답: ⑤

11 전세권의 법적 성질에 관하여 잘못 설명한 것은?

- ① 전세금은 목적부동산의 사용의 대가, 보증금, 신용 수수의 수단으로서의 성질을 갖는다.
- ② 전세권은 타인의 부동산을 사용·수익할 수 있는 용익물권이다.
- ③ 농경지는 전세권의 목적이 될 수 있다.
- ④ 전세권에는 목적물을 점유할 수 있는 권리가 포함되기 때문에 상린관계의 규정이 적용된다.
- ⑤ 전세금이 목적부동산에 대한 조세·공과금 기타 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니할 때에는 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다.

해설

㉠ 전세권의 의의와 법률적 성질

의 의	전세금을 지급하고 타인의 부동산을 그 용도에 좇아 사용·수익하는 용익물권임과 동시에 전세금의 우선변제를 받을 수 있는 권리이다.
법 률 적 성 질	▪ 타인의 부동산에 대한 권리 ┌ 토지 또는 건물의 일부분 위에도 설정가능 └ 농경지는 전세권의 목적물이 되지 못함 ▪ 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소 ┌ 증감청구권이 서로에게 인정되며, 증액청구는 연 20분의 1을 초과하지 못한다. └ 보증금과 신용의 수수로서의 성질을 가짐. ▪ 용익물권으로서의 전세권 ┌ 설정계약과 부동산의 용도에 좇아 사용, 수익하는 물건 └ 소유권의 상린관계의 규정이 준용됨 ▪ 담보물권성 ┌ 우선변제권 └ 경매청구권

정답: ③

12 부동산임차권과 전세권을 비교하는 설명으로 틀린 것은?

- ① 전세권자와 임차인은 목적물에 들인 필요비·유익비의 상환청구를 할 수 있다.
- ② 임차인과 전세권자에게 일정한 귀책사유가 있으면 임대인과 전세권설정자는 소멸청구를 할 수 있다.
- ③ 임차인과 전세권자는 임대인이나 전세권설정자의 동의를 얻어 부속시킨 것의 매수를 청구할 수 있다.
- ④ 임차인은 임대인의 동의 없이는 그 임차권을 양도 또는 전대할 수 없는 데 반하여, 전세권은 양도·임대할 수 있다.
- ⑤ 임대차는 반드시 등기가 있는 것이 아니므로 제3자 관계에 있어서는 그 효력을 주장할 수 없는 것이 보통이나, 전세권은 반드시 등기가 있어야 하므로 제3자에 대하여도 효력이 있다.

해설

- ① 전세권자에게는 필요비상환청구권이 인정되지 않는다. 정답: ①

13 다음 중 전세권자가 가지지 못하는 것은?

- ① 물건적 청구권 ② 우선변제권 ③ 유익비상환청구권
- ④ 과실수취권 ⑤ 전세권소멸청구권

해설

- ◎ 전세권자의 권리
- 목적부동산의 사용·수익권, 과실수취권, 우선변제권, 전세금반환청구권, 유익비상환청구권, 전세금 감액청구권, 전세권소멸통고권, 부속물수거권, 부속물매수청구권, 동시이행의 항변권, 경매신청권, 물건적 청구권

- ⑤는 전세권설정자의 권리이다. 정답: ⑤

제5장
기본문제

14 乙은 자기 소유부동산에 관하여 甲에게 전세권을 설정한 후에, 丙에게 그 부동산의 소유권을 이전하였다. 이 경우의 전세금반환의 법률관계에 대한 설명 중 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 전세권설정계약 관계로부터 생기는 상환청구, 소멸청구 등의 법률관계의 당사자는 甲과 丙으로 새겨야 한다.
- ② 전세권은 甲과 丙 사이에서 동일한 내용으로 존속하게 된다고 보아야 한다.
- ③ 丙은 전세권 소멸시 甲에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금반환의무를 부담한다.
- ④ 丙은 전세금반환채무를 병존적으로 인수하였다고 볼 수 있어 甲은 乙과 丙 중 누구에게나 전세금의 반환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙은 전세권설정자의 지위를 상실하여 전세금반환의무를 면하게 된다.

해설

- ④ 전세권이 성립한 후 목적물의 소유권이 이전되는 경우에 있어서 전세권 관계가 전세권자와 전세권설정자인 종전소유자와 사이에 계속 존속되는 것인지 아니면 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신소유자와 사이에 동일한 내용으로 존속되는지에 관하여 민법에 명시적인 규정은 없으나, 소유권이 이전된 경우 민법이 전세권관계로부터 생기는 상환청구, 소멸청구, 갱신청구, 전세금증감청구, 원상회복, 매수청구 등의 법률관계의 당사자는 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신소유자로 새길 수밖에 없다고 할 것이므로, 전세권은 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신소유자 사이에서 계속 동일한 내용으로 존속하게 된다고 보아야 할 것이고, 따라서 목적물의 신소유자는 구소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금반환의무를 부담하게 되고, 구소유자는 전세권설정자의 지위를 상실하여 전세금반환의무를 면하게 된다고 보아야 하고, 전세권이 전세금채권을 담보하는 담보물권적 성질을 가지고 있다고 하여도 전세권은 전세금이 존재하지 않으면 독립하여 존재할 수 없는 용익물권으로서 전세금은 전세권과 분리될 수 없는 요소이므로 전세권관계로 생기는 위와 같은 법률관계가 신 소유자에게 이전되었다고 보는 이상, 전세금채권관계만이 따로 분리되어 전소유자와 사이에 남아있다고 할 수는 없을 것이고, 당연히 신소유자에게 이전되었다고 보는 것이 옳다(대법원 2000.6.9. 99다15122). 정답: ④

15 전전세권에 관하여 틀린 것은?

- ① 전전세권의 설정도 부동산물권변동의 일반원칙에 의한다.
- ② 전전세권이 설정되면 원전세권은 소멸한다.
- ③ 전전세금의 지급은 전전세권성립의 요소이다.
- ④ 전전세권의 존속기간은 원전세권의 존속기간 내이어야 한다.
- ⑤ 원전세권의 소멸은 전전세권의 소멸원인이 된다.

해설

전전세권

의 의	전세권자의 전세권은 그대로 존속하면서 그 전세권을 목적으로 하는 전세권을 다시 설정하는 것을 말한다.
요 건	■ 설정자의 동의를 요하지 않으며 설정계약과 등기로써 성립한다. ■ 전전세금의 지급을 요하며 원전세금의 한도를 초과할 수 없다. ■ 전전세권의 존속기간은 원전세권의 존속기간 내이어야 한다.
효 과	■ 전전세권의 설정은 원전세권의 효력에 영향을 미치지 않는다. ■ 원전세권이 소멸하면 전전세권도 소멸한다. ■ 전세권자는 전전세하지 않았더라면 면할 수 있었을 불가항력에 대한 손해에 대하여 책임을 진다. ■ 전전세권자에게도 제한적이나마 경매권을 인정한다.

정답: ②

16 전세금증감청구권에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 전세금이 목적부동산에 관해 조세·공과금 기타 부담의 증감으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에 행사하는 것이다.
- ② 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있을 뿐이다.
- ③ 이 청구권은 증감의 경우에 약정한 전세금의 연 1/20을 초과하지 못한다.
- ④ 전세금의 증액청구는 전세권설정계약이 있는 날로부터 1년 이내에는 행사할 수 없다.
- ⑤ 전세금증감청구권은 쌍방이 모두 행사할 수 있으며 그 실질은 형성권이다.

해설

③의 경우에 전세금 증액에 한하여 초과금지의 규정이 있을 뿐이다. 정답: ③

17 전세권의 소멸사유에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 전세권의 존속기간을 약정하지 않은 경우에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 통고를 받은 날로부터 즉시 전세권은 소멸한다.
- ② 전전세권의 존속기간은 원전세권의 존속기간을 넘지 못한다.
- ③ 전세권의 포기는 물권적 단독행위이므로 이에 의한 전세권의 소멸은 포기의 의사표시와 등기로써 그 효력을 발생하게 된다.
- ④ 전세권은 그 설정행위로 양도를 금지할 수 있다.
- ⑤ 전세권자가 설정계약 또는 목적부동산의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용, 수익하지 않는 경우에는 전세권설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다.

해설

① 소멸통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다. 정답: ①

제5장
기본문제

18 乙이 甲의 건물을 사용하던 중 보일러가 고장 난 상태이다. 이 경우의 법률관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 을이 임차인인 경우 보일러의 수리 또는 교체의무는 을에게 있다.
- ② 을이 전세권자인 경우 甲에게 보일러의 수리 또는 교체를 요구할 수 있다.
- ③ 을이 임차인인 경우 자기의 비용으로 보일러를 수리하였다면 그 수리비를 상환 받을 때까지 을은 그 건물을 유치할 권리가 있다.
- ④ 을이 전세권자인 경우 자기의 비용으로 보일러를 수리하였다면 전세권 종료시 보일러의 수리 비용을 청구할 수 있다.
- ⑤ 을이 전세권자인 경우 자기의 비용으로 보일러를 수리하였다면 전세권이 종료한 후에도 수리비를 상환 받을 때까지 그 건물을 유치할 권리가 있다.

해설

- ① 임차인이 임차물의 보존에 관한 필요비를 지출한 때에는 임대인에 대하여 그 상환을 청구할 수 있다. 임대인이 이를 지불하지 않는다면 유치권을 행사할 수 있다.
- ② 전세권자는 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 하여야 한다.
- ④ 전세권자는 필요비의 상환을 청구하지 못한다.
- ⑤ 필요비의 상환을 청구하지 못하므로 상환 받지 못한다고 하여 유치권을 행사할 수도 없다.

정답: ③

19 지상권과 임차권에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 지상권은 임의로 담보설정이 가능하나, 임차권은 그렇지 않다.
- ② 지상권과 임차권 모두 등기를 하면 제3자에 대한 대항력이 생긴다.
- ③ 지상권자는 권리소멸 후 잔존물의 수거권과 매수청구권을 가지고 있으나, 임차인은 수거권만 있을 뿐 매수청구권은 없다.
- ④ 지상권은 상속성 및 양도성이 있으나, 임차권은 상속성만 있고 임대인의 동의 없이는 양도하지 못한다.
- ⑤ 기간을 약정하지 않은 경우, 임대차에 있어서는 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있으나, 지상권에 있어서는 토지의 사용목적에 따라 법정의 존속기간으로 그 기간이 정해지게 된다.

해설

- ③ 임대인으로부터 매수하였거나, 임대인의 동의를 얻어 부속시킨 부속물에 대하여 임차인도 부속물 매수청구권이 있다(제646조). 정답: ③

01 지상권에 대한 다음의 설명 중 잘못된 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 지상권자와 인접토지의 소유자 사이에는 상린관계에 관한 규정이 준용된다.
- ② 지상권자의 갱신청구권은 그 법적 성질을 채권적 청구권으로 보아야 하기 때문에 지상권설정자가 그에 응하여 갱신계약을 체결함으로써 갱신의 효과가 발생한다.
- ③ 지상권의 존속기간과 갱신에 관한 규정은 주로 임의규정이기 때문에 지상권설정계약의 갱신에 있어서 존속기간은 당사자의 합의에 의하여 지상권 존속기간의 최단기간보다 단축할 수 있다.
- ④ 관습법상 법정지상권의 존속기간은 그 기간을 정하지 않은 지상권과 마찬가지로 본다.
- ⑤ 법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 지상권까지 양도받기로 한 자에 대하여 대지의 소유자가 건물철거를 청구하는 것은 신의칙에 반하여 허용되지 않는다.

해설

- ③ 지상권의 존속기간과 갱신에 관한 규정은 강행규정(제289조)이므로, 지상권설정계약의 갱신에 있어서 존속기간을 당사자의 합의에 의해 지상권 존속기간의 최단기간(제280조)보다 단축하지 못한다.
- ① 제290조
- ② 지상권자의 갱신청구로 곧 계약 갱신의 효과가 발생하지는 않으며, 갱신청구가 있는 경우 지상권설정자가 그에 응하여 갱신계약을 맺음으로써 갱신의 효과가 생긴다.
- ④ 판례는 관습법상의 법정지상권의 존속기간에 있어서 존속기간을 약정하지 않은 경우로 본다(대법원 1963.5.9. 630411). 따라서 제280조, 제281조에 의하여 그 존속기간이 정해지게 된다.
- ⑤ 대법원[전합] 1985.4.9. 84다카314 정답: ③

02 지상권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 지상권자는 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리가 있다.
- ② 지상권자는 지상권설정자에게 지상물매수청구권을 행사할 수 있고, 이 권리는 청구권에 해당한다.
- ③ 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ④ 지상권자는 소유자의 동의가 없어도 타인에게 그 권리를 양도하거나, 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다.
- ⑤ 타인의 토지에 소유자의 승낙 없이 분묘를 설치하고 20년간 평온, 공연하게 그 분묘를 점유하면 분묘기지권을 취득한다.

해설

- ② 지상권이 존속기간의 만료로 소멸한 경우 지상물이 현존하면 지상권자는 갱신청구권을 가진다. 지상권설정자가 갱신청구권을 거절하면 지상권자가 지상권설정자에 대하여 상당한 가격으로 지상물의 매수를 청구할 수 있다. 이를 지상물매수청구권이라 하며 이는 형성권이다. 정답: ②

03 지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수목의 소유를 목적으로 한 지상권의 최단존속기간은 30년이다.
- ② 토지의 지상권자는 타인에게 그 권리를 양도하거나 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다.
- ③ 지상권이 소멸한 경우에 지상권설정자가 상당한 가액을 제공하여 그 토지에 현존하는 공작물이나 수목의 매수를 청구한 때에는 지상권자는 정당한 이유없이 이를 거절하지 못한다.
- ④ 타인의 토지의 지하 또는 지상의 공간을 상하의 범위를 정하여 사용할 수 있는 권리를 물건으로 취득하는 것도 허용된다.
- ⑤ 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있으나, 당사자의 약정으로 그 기간을 단축할 수 있다.

해설

- ⑤ '정기의 지료를 지급하여야 하는 지상권자가 2년 이상의 지료를 체납한 경우에 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다(제287조).' 이 지상권소멸청구권 규정은 지상권자를 불리하게 약정하면 그 효력이 인정되지 않는 편면적 강행규정이다. 정답: ⑤

04 지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 지료는 지상권의 성립요소가 아니다.
- ② 토지에 저당권을 취득한 자가 그 토지 위에 차후 용익권이 설정되어 담보가치가 떨어지는 것을 막기 위하여 자신의 명의로 지상권을 설정한 경우 저당권의 피담보채권이 변제로 소멸하면 지상권도 소멸한다.
- ③ 지상권자가 건물을 축조한 뒤 지상권을 유보한 채 건물만을 양도할 수도 있고 건물 소유권을 유보한 채 지상권만을 양도할 수도 있다.
- ④ 기존 건물을 소유하기 위해 지상권을 설정 받은 경우 지상권의 최단존속기간에 관한 민법 규정이 적용된다.
- ⑤ 존속기간을 영구(永久)로 약정한 지상권도 유효하다.

해설

- ④ 민법 제280조 제1항 제1호가 석조·석회조·연와조 또는 이와 비슷한 견고한 건물이나 수목의 '소유를 목적으로 하는' 지상권의 경우 그 존속기간은 30년보다 단축할 수 없다고 규정하고 있음에 비추어 볼 때, 최단 존속기간에 관한 규정은 지상권자가 그 소유의 건물 등을 건축하거나 수목을 식재하여 토지를 이용할 목적으로 지상권을 설정한 경우에만 그 적용이 있다. 따라서 기존 건물의 사용을 목적으로 지상권이 설정된 경우, 지상권의 최단 존속기간에 관한 민법 규정은 적용되지 않는다(대법원 1996.03.22. 95다49318). 정답: ④

05

지상권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권의 양도는 토지소유자의 동의를 요한다.
- ② 지료합의가 없는 지상권 설정계약은 무효이다.
- ③ 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권의 최단존속기간은 10년이다.
- ④ 지상권이 설정된 토지의 소유자는 그 지상권자의 승낙 없이 그 토지 위에 구분지상권을 설정할 수 있다.
- ⑤ 「장사 등에 관한 법률」시행 이전에 설치된 분묘에 관한 분묘기지권의 시효취득은 법적 규범으로 유지되고 있다.

해설

- ⑤ 타인 소유의 토지에 분묘를 설치한 경우에 20년간 평온, 공연하게 분묘의 기지를 점유하면 지상권과 유사한 관습상의 물건인 분묘기지권을 시효로 취득한다는 점은 오랜 세월 동안 지속되어 온 관습 또는 관행으로서 법적 규범으로 승인되어 왔고, 이러한 법적 규범이 장사 등에 관한 법률(장사법, 법률 제6158호) 시행일인 2001. 1. 13. 이전에 설치된 분묘에 관하여 현재까지 유지되고 있다고 보아야 한다(대법원 2017.1.19. 2013다17292 전원합의체).
- ① 지상권자는 타인에게 그 권리를 양도하거나 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다(제282조). 이는 지상권설정자의 동의를 요하지 아니한다.
- ② 지료의 지급은 지상권성립의 요소가 아니다. 따라서 무상(無償)의 지상권도 설정이 가능하다.
- ③ 석조, 석회조, 연와조 또는 이와 유사한 견고한 건물이나 수목의 소유를 목적으로 하는 때에는 30년을 최단기간으로 규정하고 있다(제280조).
- ④ 제3자가 사용·수익할 권리를 가진 토지에 토지소유자가 구분지상권을 설정하려면 그 권리자 및 그 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자 전원의 승낙이 있어야 한다(제289조의2 제2항).

정답: ⑤

제5장
실전문제

06

분묘기지권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 분묘기지권을 시효취득하는 경우에는 특약이 없는 한 지료를 지급할 필요가 없다.
- ② 「장사 등에 관한 법률」이 시행된 후 설치된 분묘에 대해서는 더 이상 시효취득이 인정되지 않는다.
- ③ 분묘기지권의 시효취득을 인정하는 종전의 관습법은 법적 규범으로서의 효력을 상실하였다.
- ④ 분묘기지권이 인정되는 분묘를 다른 곳에 이장하면 그 분묘기지권은 소멸한다.
- ⑤ 분묘가 일시적으로 멸실되어도 유골이 존재하여 분묘의 원상회복이 가능하다면 분묘기지권은 존속한다.

해설

- ③ 분묘기지권에 관한 관습에 대하여 사회 구성원들의 법적 구속력에 대한 확신이 소멸하였다거나 그러한 관행이 본질적으로 변경되었다고 볼 수 없다(대법원 2017.1.19. 2013다17292 전원합의체). 즉 장사법 시행 이후 설치된 분묘에 대해서는 더 이상 시효취득이 인정되지 않는다 하더라도 분묘기지권에 대한 관습법적 효력을 부정하는 것은 아니라는 것이 판례의 태도이다.

대법원 전원합의체 판결에 의한 변경으로 ①, ③으로 변경

07 구분지상권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보통의 지상권은 토지의 상하 전부에 미치지만 구분지상권은 구분된 일정한 층에만 그 효력이 미친다.
- ② 구분지상권의 성립에 있어서 지료의 지급은 그 요건이다.
- ③ 구분지상권의 행사를 위하여 토지소유권자의 사용권을 제한하는 특약을 할 수 있다.
- ④ 구분지상권자는 구분지상권의 존속기간 내에 자신의 구분지상권을 양도할 수 있으며, 양도를 금지하는 특약을 하더라도 그 특약은 무효이다.
- ⑤ 제3자에 의하여 구분지상권이 침해된 때에는, 구분지상권자는 물권적 청구권을 행사할 수 있다.

해설

- ② 지료의 지급은 성립요건이 아니다.
- ③ 제289조의 2 제1항
- ④ 구분지상권은 지상권에 관한 규정을 준용하므로(제290조 제2항) 구분지상권의 양도, 임대도 자유로이 할 수 있다.
- ⑤ 구분지상권도 물권인 만큼 그 내용이 침해된 때에는 물권적 청구권이 인정된다. 정답: ②

08 지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 지상권자는 지상권을 유보한 채 지상물의 소유권만을 양도할 수 있다.
- ② 당사자가 지료에 관한 합의를 하였더라도 이를 등기하지 않았다면, 당해 지상권자에 대하여 지료지급을 청구할 수 없다.
- ③ 구분지상권의 존속기간을 영구적인 것으로 약정하는 것도 허용된다.
- ④ 지상권은 저당권의 목적이 될 수 있다.
- ⑤ 지상권자는 지상권설정자의 명시적 반대에도 불구하고 지상권의 존속기간 내에서 그 토지를 타인에게 임대할 수 있다.

해설

- ② 지상권설정등기에서 '지료'는 필수적 등기사항은 아니며, 등기하지 않더라도 당사자사이의 채권적 효력은 있으므로 지상권설정자는 지상권자에게 지료지급을 청구할 수 있다. 정답: ②

09

법정지상권에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 관습법상의 법정지상권이나 제366조의 법정지상권 모두 건물의 사회적 효용을 위해 인정되는 권리라는 점에서 당사자에 의해 포기될 수 없다.
- ② 미등기 건물을 그 대지와 함께 양수한 사람이 그 대지에 관해서만 소유권이전등기를 넘겨 받은 상태에서 대지가 경매되어 소유자가 달라지는 경우에는 관습법상의 법정지상권이나 제366조의 법정지상권이 모두 발생할 수 없다.
- ③ 토지와 건물의 소유자가 토지만을 타인에게 증여한 후, 구 건물을 철거하되 그 자상에 자신의 이름으로 건물을 다시 신축하기로 합의한 경우에는 관습법상의 법정지상권의 발생이 배제되지 않는다.
- ④ 건물이 없는 토지에 저당권을 설정한 후에 저당권설정자가 저당권자로부터 법정지상권의 성립을 인정한다는 양해를 얻어 건물을 신축한 경우에도 제366조의 법정지상권은 인정되지 않는다.
- ⑤ 관습법상의 법정지상권을 취득한 건물의 소유자가 법정지상권 설정등기를 경료하지 않는 채 그 건물을 양도한 경우 건물의 양수인은 대지소유자에 대해 자신의 지상권을 주장할 수는 없으며 단지 대지소유자에 대한 건물 양도인의 권리를 대위행사할 수 있을 뿐이다.

해설

- ① 제366조의 법정지상권은 개인차원의 불이익을 떠나 국가경제적 불이익을 막기 위한 공익상 인정되는 강행규정이나 관습법상의 법정지상권은 포기특약이 가능한 임의규정이다.
- ④ 나대지에 저당권설정 후에 저당권이 실행된 경우에 경락인은 나대지 소유권을 취득한다. 이 경우 건물소유를 위한 법정지상권이 인정된다고 한다면 토지의 경락인을 해하는 결과가 된다. 따라서 지문의 경우에 건물소유를 위한 법정지상권이 인정될 수 없다.
- ⑤ 관습법상의 법정지상권을 취득한 건물의 소유자가 법정지상권 설정등기를 경료하지 않는 채 그 건물을 양도한 경우 건물의 양수인은 (아직은 법정지상권자가 아니기 때문에) 대지소유자에 대해 자신의 지상권을 주장할 수는 없으며 단지 대지소유자에 대한 건물 양도인(법정지상권자)의 권리를 대위행사하여 지상권의 설정등기를 청구할 수 있다. 정답 ①

제5장
실전문제

10

법정지상권의 성립에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 토지에 저당권이 설정된 후에 저당권자의 동의를 얻어 건물이 신축된 경우라도 법정지상권은 성립한다.
- ② 토지의 정착물로 볼 수 없는 가설 건축물의 소유를 위한 법정지상권은 성립하지 않는다.
- ③ 무허가건물이나 미등기건물을 위해서도 관습법상의 법정지상권이 인정될 수 있다.
- ④ 토지공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의를 얻어 그 자상에 건물을 소유하면서 자신의 토지지분에 저당권을 설정한 후 그 실행경매로 인하여 그 공유지분권자와 건물소유자가 달라진 경우에는 법정지상권이 성립하지 않는다.
- ⑤ 동일인 소유의 토지와 건물 중 건물에 전세권이 설정된 후 토지소유자가 바뀐 경우, 건물소유자가 그 토지에 대하여 지상권을 취득한 것으로 본다.

해설

- ① 법정지상권이 성립하기 위해서는 토지에 저당권이 설정될 당시에 건물이 존재하고 있었어야 한다. 정답 ①

11 다음 중 관습상의 법정지상권이 성립하는 경우는 어느 것인가? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 동일인예의 소유권 귀속이 원인무효로 이루어졌다가 그 후에 원인무효를 이유로 등기가 말소되어 건물과 토지의 소유자가 달라지게 된 경우
- ② 대지와 그 지상의 미등기건물을 양도하여 대지에 관해서만 소유권이전등기를 경료하고 건물에 관해서는 소유권이전등기를 경료하지 못하고 있다가 양수인이 대지에 설정한 저당권의 실행에 의하여 대지의 소유자가 달라지게 된 경우
- ③ 공유자 중 1인 또는 수인 소유의 건물이 있는 공유대지를 분할하여 대지의 소유권이 공유에서 단독소유로 바뀐 경우
- ④ 토지공유자 중 1인이 공유토지 위에 건물을 소유하고 있다가 토지지분만을 전매한 경우
- ⑤ 대지상에 담보가등기가 경료되고 나서 대지소유자가 그 지상에 건물을 신축한 후 본등기가 경료되어 대지와 건물의 소유자가 달라진 경우

해설

- ③ 공유지상에 공유자의 1인 또는 수인 소유의 건물이 있을 경우 위 공유지의 분할로 그 대지와 지상건물이 소유자를 달리하게 된 경우에 다른 특별사정이 없는 한 건물소유자는 그 건물 부지상에 그 건물을 위하여 관습상의 지상권을 취득한다(대법원 1974.2.12. 73다353).
- ① 관습상의 법정지상권의 성립요건인 해당 토지와 건물의 소유권의 동일인예의 귀속과 그 후의 각기 다른 사람의 귀속은 법의 보호를 받을 수 있는 권리변동으로 인한 것이어야 하므로, 원래 동일인예의 소유권 귀속이 원인무효로 이루어졌다가 그 뒤 그 원인무효임이 밝혀져 그 등기가 말소됨으로써 그 건물과 토지의 소유자가 달라지게 된 경우에는 관습상의 법정지상권을 허용할 수 없다(대법원 1999.3.26. 98다64189).
- ④ 토지에 관하여 관습법상의 법정지상권이 성립되는 것으로 보게 되면 이는 토지공유자의 1인으로 하여금 자신의 지분을 제외한 다른 공유자의 지분에 대하여서까지 지상권설정의 처분행위를 허용하는 셈이 되어 부당하기 때문이다(대법원 1993.4.13. 92다55756).
- ⑤ 원래 채권을 담보하기 위하여 나대지상에 가등기가 경료되었고, 그 뒤 대지소유자가 그 지상에 건물을 신축하였는데, 그 후 그 가등기에 기한 본등기가 경료 되어 대지와 건물의 소유자가 달라진 경우에 관습상 법정지상권을 인정하면 애초에 대지에 채권담보를 위하여 가등기를 경료한 사람의 이익을 크게 해하게 되기 때문에 특별한 사정이 없는 한 건물을 위한 관습상 법정지상권이 성립한다고 할 수 없다(대법원 1994.11.22. 94다5458). 정답: ③

12

법정지상권 및 관습법상의 법정지상권에 관한 다음 기술 중 잘못된 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 관습법상의 지상권이 성립하기 위해서는 원래 토지와 건물은 동일인의 소유에 귀속하고 있어야 한다.
- ② ①과 관련하여 판례는 토지가 명의신탁된 경우 토지의 수탁자가 수탁토지 위에 신축한 경우, 수탁토지는 대내적으로는 신탁자의 소유이므로 그 후 신탁이 해지되면 건물의 소유자인 명의 수탁자는 토지에 대하여 관습법상의 법정지상권을 취득하지 못한다고 한다.
- ③ 토지를 단독으로 소유하고 있는 자가 그 지상의 건물을 타인과 함께 공유하면서 그 단독 소유의 토지만을 타인에게 매도한 경우에도 관습법상의 법정지상권이 인정된다.
- ④ 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물 양자가 저당권의 목적이 된 공동저당의 경우, 구 건물을 철거하고 새 건물을 신축하였는데 신축건물에 대해서 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등의 특별한 사정이 없는 한, 새 건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다.
- ⑤ 법정지상권을 취득한 건물의 소유자가 지상권이전등기를 함이 없이 건물의 소유권만을 이전한 경우에 토지소유자가 건물의 승계인에 대하여는 철거청구를 할 수 있다.

해설

- ⑤ 법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 법정지상권까지 양도받기로 한 자는 채권자대위의 법리에 따라 전 건물소유자 및 대지소유자에 대하여 차례로 지상권의 설정등기 및 이전 등기절차이행을 구할 수 있다 할 것이므로 이러한 법정지상권을 취득할 지위에 있는 자에 대하여 대지소유자가 소유권에 기하여 건물철거를 구함은 지상권의 부담을 용인하고 그 설정등기절차를 이행할 의무 있는 자가 그 권리자를 상대로 한 청구라 할 것이어서 신의성실의 원칙상 허용될 수 없다(대법원[전합] 1985.4.9. 84다카1131·1132).
- ② 양도담보나 명의신탁의 경우 대내적 관계에서는 담보권자나 수탁자는 토지소유권을 주장할 수 없으므로 지상에 담보권자나 수탁자 소유의 건물이 있더라도 담보권설정자나 신탁자에 대하여 법정지상권을 취득하였다고 주장할 수 없다(대법원 1986.5.27. 86다카62)
- ③ 대법원 1977.7.26. 76다388
- ④ 대법원 2003.12.18. 98다43601 정답: ⑤

13

법정지상권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정지상권의 성립 후 구건물이 철거되고 신건물이 축조된 경우, 그 법정지상권의 존속 기간·범위 등은 신건물을 기준으로 한다.
- ② 관습상의 법정지상권에서 건물은 등기가 되어 있지 않아도 무방하나, 무허가건물이어서는 안 된다.
- ③ 토지와 함께 공동근저당권이 설정된 건물이 그대로 존속함에도 등기가 멸실되고 등기부가 폐쇄되면, 그 후 경매로 토지와 건물의 소유자가 달라지더라도 법정지상권이 성립할 수 없다.
- ④ 구분소유적 공유관계에 있는 자가 자신의 특정 소유가 아닌 부분에 신축한 건물을 제3자에게 양도한 경우에 관습상 법정지상권이 성립한다.
- ⑤ 가압류 후 본압류 및 강제경매가 이루어지는 경우 관습상 법정지상권의 요건으로 '토지와 그 지상 건물이 동일인 소유' 인지 여부는 가압류의 효력 발생시를 기준으로 한다.

해설

- ⑤ 강제경매개시결정 이전에 가압류가 있는 경우에는, 그 가압류가 강제경매개시결정으로 인하여 본 압류로 이행되어 가압류집행이 본집행에 포섭됨으로써 당초부터 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있다. 따라서 경매의 목적이 된 부동산에 대하여 가압류가 있고 그것이 본압류로 이행되어 경매 절차가 진행된 경우에는 애초 가압류가 효력을 발생하는 때를 기준으로 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지 여부를 판단할 것이다(대법원 2012.10.18. 2010다52140 전원합의체).
- ① 민법 제366조 소정의 법정지상권이 성립하려면 저당권의 설정 당시 저당권의 목적이 되는 토지 위에 건물이 존재하여야 하고, 저당권 설정 당시 건물이 존재한 이상 그 이후 건물을 개축, 증축하는 경우는 물론이고 건물이 멸실되거나 철거된 후 재축, 신축하는 경우에도 법정지상권이 성립하며, 이 경우의 법정지상권의 내용인 존속기간, 범위 등은 구 건물을 기준으로 하여 그 이용에 일반적으로 필요한 범위 내로 제한된다(대법원 1991.04.26. 90다19985).
- ② 토지와 그 지상의 건물이 동일한 소유자에게 속하였다가 토지 또는 건물이 매매나 기타 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 된 때에는 그 건물을 철거하기로 하는 합의가 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 건물소유자는 지상소유자에 대하여 그 건물을 위한 관습상의 지상권을 취득하게 되고, 그 건물은 반드시 등기가 되어 있어야만 하는 것이 아니고 무허가건물이라고 하여도 상관없다(대법원 1991.08.13. 91다16631).
- ③ 토지와 함께 공동근저당권이 설정된 건물이 그대로 존속함에도 불구하고 사실과 달리 등기부에 멸실의 기재가 이루어지고 이를 이유로 등기부가 폐쇄된 경우, 저당권자로서는 멸실 등으로 인하여 폐쇄된 등기기록을 부활하는 절차 등을 거쳐 건물에 대한 저당권을 행사하는 것이 불가능한 것이 아닌 이상 저당권자가 건물의 교환가치에 대하여 이를 담보로 취득할 수 없게 되는 불측의 손해가 발생한 것은 아니라고 보아야 하므로, 그 후 토지에 대하여만 경매절차가 진행된 결과 토지와 건물의 소유자가 달라지게 되었다면 그 건물을 위한 법정지상권은 성립한다 할 것이고, 단지 건물에 대한 등기부가 폐쇄되었다는 사정만으로 건물이 멸실된 경우와 동일하게 취급하여 법정지상권이 성립하지 아니한다고 할 수는 없다(대법원 2013.3.14. 2012다108634).
- ④ 공유로 등기된 토지의 소유관계가 구분소유적 공유관계에 있는 경우에는 '공유자 중 1인이 소유하고 있는 건물과 그 대지'는 다른 공유자와의 내부관계에 있어서는 그 공유자의 단독소유로 되었다 할 것이므로, 건물을 소유하고 있는 공유자가 그 건물 또는 토지지분에 대하여 저당권을 설정하였다가 그 후 저당권의 실행으로 소유자가 달라지게 되면 건물 소유자는 그 건물의 소유를 위한 법정지상권을 취득하게 된다(대법원 2004.6.11. 2004다13533). 그러나 구분소유적 공유관계에 있는 자가 자신의 특정 소유가 아닌 부분에 신축한 건물을 제3자에게 양도한 경우에는 관습상 법정지상권이 성립하지 않는다.

정답: ⑤

14 법정지상권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 법정지상권이 성립한 후에 건물을 증축, 개축, 멸실 후 신축하는 경우에도 법정지상권은 성립하나 그 법정지상권의 범위는 구건물을 기준으로 한다.
- ② 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속하게 된 경우에 건물소유자는 법정지상권을 취득한다.
- ③ 법정지상권은 등기 없이도 성립하지만, 이를 처분하기 위해서는 등기하여야 한다.
- ④ 법정지상권도 법률의 규정에 의한 물권취득이므로 등기를 요하지 아니하나, 토지소유자나 토지소유권을 전득한 제3자에 대하여는 등기 없이 지상권을 주장할 수 없다.
- ⑤ 관습법상의 법정지상권이 성립하려면 당사자 간에 건물철거특약이 없어야 한다.

해설

- ④ 제3자에게 대하여도 등기 없이 위 지상권을 주장할 수 있다(대법원 1988.9.27, 87다카279).
① 대법원 2001.3.13, 2000다48517
② 제366조
③ 제187조
⑤ 특약이 있으면 관습법상의 법정지상권은 성립하지 않는다. 정답: ④

15 법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
② 토지공유자 중 1인이 다른 공유자 지분 과반수의 동의를 얻어 건물을 건축한 후 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우, 관습상의 법정지상권이 성립된다.
③ 미등기건물을 그 대지와 함께 매도하여 대금이 완납되었으나 건물이 미등기인 관계로 대지에 관하여만 매수인 앞으로 소유권이전등기가 경료된 경우, 매도인에게 관습상의 법정지상권은 인정되지 않는다.
④ 관습상 법정지상권이 성립하려면 토지와 그 지상 건물이 애초부터 동일인의 소유에 속하였을 필요는 없고, 그 소유권이 유효하게 변동될 당시에 동일인이 토지와 그 지상 건물을 소유 하였던 것으로 족하다.
⑤ 토지와 건물의 소유자 甲으로부터 乙이 건물을 매수하여 취득한 경우 乙이 건물 소유를 위해 甲과 대지의 임대차계약을 체결하였다면, 관습상 법정지상권을 포기한 것으로 본다.

제5장
실전문제

해설

- ② 토지공유자의 한 사람이 다른 공유자의 지분 과반수의 동의를 얻어 건물을 건축한 후 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우 토지에 관하여 관습법상의 법정지상권이 성립되는 것으로 보게 되면 이는 토지공유자의 1인으로 하여금 자신의 지분을 제외한 다른 공유자의 지분에 대하여서까지 지상권설정의 처분행위를 허용하는 셈이 되어 부당하다. 그리고 이러한 법리는 민법 제366조의 법정지상권의 경우에도 마찬가지로 적용되고, 나아가 토지와 건물 모두가 각각 공유에 속한 경우에 토지에 관한 공유자 일부의 지분만을 목적으로 하는 근저당권이 설정되었다가 경매로 인하여 그 지분을 제3자가 취득하게 된 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2014.09.04. 2011다73038).

정답: ②

18 관습상 법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 환지처분으로 인하여 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라진 경우, 법정지상권이 그 지상건물의 토지 위에 성립한다.
- ② 법정지상권이 성립한 후 건물을 증·개축한 경우에도 법정지상권은 존속한다.
- ③ 공유토지 위에 건물을 소유하고 있는 토지공유자 중 1인이 자기의 토지지분만을 매도한 경우, 토지전체에 관해 법정지상권은 성립할 수 없다.
- ④ 법정지상권의 지료를 정하는 때에 법정지상권이 설정된 토지 위에 그 건물이 건립되어 있음으로 인하여 토지소유권이 제한받는 사정은 참작·평가해서는 안 된다.
- ⑤ 시공회사가 자기 소유의 토지위에 수위실을 건축한 후 그 부지를 타인에게 매도한 경우, 특별한 사정이 없는 한, 법정지상권이 성립될 수 있다.

해설

- ① 환지로 인하여 새로운 분할지적선이 그어진 결과 환지 전에는 동일인에게 속하였던 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라졌다 하더라도 환지의 성질상 건물의 부지에 관하여 소유권을 상실한 건물 소유자가 환지된 토지(건물부지)에 대하여 건물을 위한 관습상의 법정지상권을 취득한다거나 그 환지된 토지의 소유자가 그 건물을 위한 관습상의 법정지상권의 부담을 안게 된다고는 할 수 없다(대법원 2001.05.08. 2001다4101). 정답: ①

19 관습상 법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지공유자 중 1인이 다른 공유자의 지분 과반수의 동의를 얻어 공유토지 위에 건물을 건축한 후 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우, 관습상 법정지상권은 성립하지 않는다.
- ② 강제경매에 있어 관습상 법정지상권이 인정되기 위해서는 매각대금 완납 시를 기준으로 해서 토지와 그 지상 건물이 동일인의 소유에 속하여야 한다.
- ③ 관습상 법정지상권자는 토지소유자로부터 토지를 양수한 자에 대하여 등기 없이도 자신의 권리를 주장할 수 있다.
- ④ 대지와 건물의 소유자가 건물만을 양도하면서 양수인과 대지에 관하여 임대차 계약을 체결한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 양수인은 관습상 법정지상권을 포기한 것으로 본다.
- ⑤ 구분소유적 공유관계에 있는 자가 자신의 특정 소유가 아닌 부분에 건물을 신축한 경우, 관습상 법정지상권이 성립하지 않는다.

해설

- ② 강제경매에 있어 관습상 법정지상권이 인정되기 위해서는 매수인이 소유권을 취득하는 매각대금의 완납시가 아니라 그 압류의 효력이 발생하는 때를 기준으로 하여 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지가 판단되어야 한다는 것이 판례의 태도이다.

[대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다52140 전원합의체]

- [1] 동일인의 소유에 속하고 있던 토지와 그 지상 건물이 강제경매 또는 국세징수법에 의한 공매 등으로 인하여 소유자가 다르게 된 경우에는 그 건물을 철거한다는 특약이 없는 한 건물소유자는 토지소유자에 대하여 그 건물의 소유를 위한 관습상 법정지상권을 취득한다. 원래 관습상 법정

지상권이 성립하려면 토지와 그 지상 건물이 애초부터 원시적으로 동일인의 소유에 속하였을 필요는 없고, 그 소유권이 유효하게 변동될 당시에 동일인이 토지와 그 지상 건물을 소유하였던 것으로 족하다.

- [2] 강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상의 매수인에게 이전된 경우에 건물의 소유를 위한 관습상 법정지상권이 성립하는가 하는 문제에 있어서는 그 매수인이 소유권을 취득하는 매각대금의 완납시가 아니라 그 압류의 효력이 발생하는 때를 기준으로 하여 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지가 판단되어야 한다. 정답: ②

20

관습상의 법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매절차로 인하여 매수인에게 이전된 경우, 매수인의 매각대금 완납시를 기준으로 토지와 그 지상 건물이 동일인 소유에 속하였는지 여부를 판단하여야 한다.
- ② 관습상의 법정지상권이 성립하였으나 건물 소유자가 토지 소유자와 건물의 소유를 목적으로 하는 토지 임대차계약을 체결한 경우, 그 관습상의 법정지상권은 포기된 것으로 보아야 한다.
- ③ 관습상의 법정지상권은 이를 취득할 당시의 토지소유자로부터 토지소유권을 취득한 제3자에게 등기없이 주장될 수 있다.
- ④ 관습상의 법정지상권이 성립한 후에 건물이 증축된 경우, 그 법정지상권의 범위는 구 건물을 기준으로 그 유지·사용을 위하여 일반적으로 필요한 범위 내의 대지 부분에 한정된다.
- ⑤ 관습상의 법정지상권 발생을 배제하는 특약의 존재에 관한 주장·증명책임은 그 특약의 존재를 주장하는 측에 있다.

해설

- ② 강제경매에 있어 관습상 법정지상권이 인정되기 위해서는 매수인이 소유권을 취득하는 매각대금의 완납시가 아니라 그 압류의 효력이 발생하는 때를 기준으로 하여 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지가 판단되어야 한다는 것이 판례의 태도이다(대법원 2012. 10. 18. 2010다52140 전원합의체). 정답: ①

21

저당권의 실행으로 인해 발생하는 법정지상권에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 저당권의 설정 당시에는 건물이 존재하지 않아도 무방하다.
- ② 저당권설정 당시 토지와 건물이 동일인의 소유에 속하고 있지 않아도 무방하다.
- ③ 토지와 건물 중 어느 한 쪽에 저당권이 설정된 경우에만 법정지상권이 성립한다.
- ④ 저당권자와 저당권설정자간의 특약으로 법정지상권의 성립을 배제할 수 있다.
- ⑤ 법정지상권은 성립했으나 그 등기가 이루어지지 않은 건물의 양수인에 대해 토지소유자가 건물철거청구를 할 수는 없다는 것이 판례의 태도이다.

해설

- ⑤ 법정지상권이 설정된 건물을 매수한 전득자(양수인)는 원소유자(양도인)를 대위하여 토지소유자에 대하여 지상권설정등기를 청구할 수 있다(대법원 1981.9.8. 80다2873).
- ① ② 법정지상권의 성립요건으로는 ③저당권설정 당시의 건물의 존재 ④저당권설정 당시의 소유자의 동일성 ⑤저당권의 설정 ⑥경매로 소유자가 달라질 것이 요구된다.
- ③ 동일인에게 속하고 있던 토지와 지상건물이 그 중 어느 하나 위에 또는 양자 위에 설정된 저당권의 실행으로 말미암아 그 소유자를 달리하게 되는 경우에 건물의 소유자를 위하여 대지에 대한 지상권의 성립을 인정한다.
- ④ 제366조는 가치권과 이용권의 조절을 위해 지상권의 설정을 강제하는 것으로서 강행규정이다. 따라서 이의 적용을 배제하는 당사자의 특약은 무효이다(대법원 1988.10.25. 87다1564).
- 정답: ⑤

22

甲 소유의 토지 위에 1층 목조건물이 있었고, 토지에 대해 저당권이 설정되었다. 그 후 구 건물이 철거되고 2층 콘크리트 건물이 건축되었다. 저당권의 실행으로 추후 경매가 이루어진다고 가정할 때, 법정지상권은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 신 건물에 대해 10년 법정지상권이 인정된다.
② 신 건물에 대해 15년 법정지상권이 인정된다.
③ 신 건물에 대해 20년 법정지상권이 인정된다.
④ 신 건물에 대해 30년 법정지상권이 인정된다.
⑤ 신 건물에 대해 법정지상권이 인정되지 않는다.

해설

- ② 동일인의 소유에 속하는 토지와 건물 중 토지만이 저당권의 목적이 된 '단독저당'의 경우, 기존 건축물을 철거하고 새 건물을 건축한 때에는 새 건물을 위한 법정지상권이 성립하지만, 그 내용은 구 건물을 기준으로 한다(대법원 1991.4.26. 90다19985). 따라서 구 건물은 목조이며 그 존속기간은 최단기간이 15년에 해당한다. 정답: ②

제5장
실전문제

23

갑은 자신의 토지 위에 건물을 소유하고 있다가 그 토지에 대하여 을에게 저당권을 설정해 주었다. 그 후 갑은 건물을 병에게 양도하고 이전등기를 하여 주었고, 그 후 갑이 채무를 변제하지 않자 을이 토지 위의 저당권을 실행하였고, 그 결과 정이 토지를 경락받았다. 이 경우 판례의 입장과 가장 부합하는 것은?

- ① 병은 정이 경락을 받을 때에 제366조의 법정지상권을 취득한다.
② 병은 건물을 매수할 때 관습상 법정지상권을 취득하였으나 경락에 의하여 그 권리를 잃고 건물을 철거하여야 한다.
③ 병은 건물매수와 함께 언제나 관습상 법정지상권을 취득하고, 그 권리를 가지고 정에게 대항할 수 있다.
④ 병은 건물의 소유권을 취득하였다가 정의 경락에 의하여 소유권을 잃는다.
⑤ 병은 관습상 법정지상권을 취득한 바 없고, 제366조의 법정지상권을 취득하지 못한다.

해설

- ① 토지와 건물의 소유자가 동일인이었고 이후 토지의 저당권자의 실행에 의하여 토지와 건물의 소유자를 달리하게 된 경우이므로 제366조의 법정지상권이 성립한다. 정답: ①

24

법정지상권을 취득한 건물소유자가 법정지상권설정등기를 경료함이 없이 건물을 제3자에게 양도하였다. 이 경우 전개될 수 있는 법률관계로서 틀린 것은?

- ① 법정지상권을 취득한 건물소유자가 건물을 양도하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 건물과 함께 지상권도 양도하는 것이 된다.
- ② 건물양수인은 양도인을 대위하여 대지소유권자에 대해 법정지상권 설정등기를 양도인에게 해줄 것을 청구할 수 있다.
- ③ 대지소유자가 건물의 양수인에 대해 건물철거 및 대지 인도를 청구하는 것은 신의칙상 허용될 수 없다.
- ④ 대지소유자는 건물양수인에 대해 불법점유를 이유로 한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 존속기간은 원칙적으로 그 약정을 하지 않은 것으로 처리된다.

해설

④의 경우는 ③의 경우와 정면으로 배치되는 것으로 타당하지 못하다. 따라서 건물양수인에 대하여 불법점유를 주장하는 것은 신의칙에 반한다.

①②③ 법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 법정지상권까지 양도받기로 한 자는 채권자대위의 법리에 따라 전 건물소유자 및 대지소유자에 대하여 차례로 지상권의 설정등기 및 이전등기절차이행을 구할 수 있다 할 것이므로, 이러한 법정지상권을 취득할 지위에 있는 자에 대하여 대지소유자가 소유권에 기하여 건물철거를 구함은 지상권의 부담을 용인하고 그 설정등기 절차를 이행할 의무 있는 자가 그 권리자를 상대로 한 청구라 할 것이어서 신의성실의 원칙상 허용될 수 없다(대법원[전합] 1985.4.9. 89다카1131 · 1132). 정답: ④

25

관습법상의 법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 토지의 매수인이 소유권이전등기를 하기 전에 토지소유자의 승낙을 받아 건물을 신축했으나 매매계약이 해제된 경우 관습법상의 법정지상권이 성립하지 않는다.
- ② 관습법상 법정지상권을 미리 포기하기로 하는 약정은 효력이 있다.
- ③ 토지공유자의 한 사람이 과반수 지분을 갖는 일부 공유자만의 동의를 얻어 건물을 신축한 후 이를 타인에게 양도한 경우 관습법상의 법정지상권이 성립하지 않는다.
- ④ 토지 소유자가 담보의 목적으로 채권자에게 그 토지위에 가등기를 마친 뒤 건물을 신축하였고 그 후 채권자가 가등기에 기한 본등기를 한 경우 특별한 사정이 없으면 관습법상 법정지상권이 성립한다.
- ⑤ 토지를 제3자에게 매도하고 토지소유권이전등기를 하기 전에 매도인이 건물을 신축하고 그 후에 토지소유권이전등기를 한 경우 특별한 사정이 없으면 관습법상 법정지상권이 성립하지 않는다.

해설

④ 토지와 그 위의 건물이 동일한 소유자에게 속하는 경우 그 토지나 건물에 대하여 제4조 제2항에 따른 소유권을 취득하거나 담보가등기에 따른 본등기가 행하여진 경우에는 그 건물의 소유를 목적으로 그 토지 위에 지상권이 설정된 것으로 본다(가등기담보 등에 관한 법률 제10조; 법정지상권). 따라서 토지에 가등기가 설정될 당시에는 건물이 존재하지 않았으므로 법정지상권은 인정되지 않는다. 정답: ④

26 관습법상 법정지상권이 성립되지 않는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ㉠ 환지처분으로 인하여 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라진 경우
- ㉡ 미등기 건물을 그 대지와 함께 양수한 사람이 그 대지에 관하여서만 소유권이전등기를 넘겨받고 건물에 대하여는 그 등기를 이전받지 못하고 있는 상태에서 그 대지가 강제 경매되어 소유자가 달라진 경우
- ㉢ 공유토지 위에 신축한 건물을 단독 소유하던 토지공유자 1인이 자신의 토지지분만을 양도하여 건물과 토지의 소유자가 달라진 경우
- ㉣ 토지를 매수하여 소유권이전등기를 마친 매수인이 그 지상에 건물을 신축한 후 그 토지의 소유권이전등기가 원인무효로 밝혀져 말소됨으로써 건물과 토지의 소유자가 달라진 경우

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣ ③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

해설

- ⑤ 위 사안은 모두 관습법상 법정지상권이 성립하지 않는다는 것이 판례이다. 정답: ⑤

27 甲은 乙에 대한 채권을 담보하기 위하여 乙 소유의 X토지에 관하여 저당권을 취득하였다. 그 후 X의 담보가치 하락을 막기 위하여 乙의 X에 대한 사용·수익권을 배제하지 않는 지상권을 함께 취득하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 甲의 지상권의 피담보채무는 존재하지 않는다.
- ② 甲의 채권이 시효로 소멸하면 지상권도 소멸한다.
- ③ 甲의 채권이 변제 등으로 만족을 얻어 소멸하면 지상권도 소멸한다.
- ④ 제3자가 甲에게 대항할 수 있는 권원 없이 X 위에 건물을 신축하는 경우, 甲은 그 축조의 중지를 요구할 수 있다.
- ⑤ 제3자가 X를 점유·사용하는 경우, 甲은 지상권의 침해를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 제3자가 X를 점유·사용하는 경우, 甲은 저당권에 기한 방해배제청구권을 행사하여 방해행위의 제거를 청구할 수 있다. 정답: ⑤

28

분묘기지권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 토지 소유자가 그 토지에 봉분(封墳) 형태로 분묘를 설치한 후 그 봉분의 철거 특약 없이 토지를 타인에게 양도한 경우 분묘기지권이 성립한다.
- ② 부부 중 일방이 먼저 사망하여 이미 분묘가 설치된 후 다른 일방을 쌍분(雙墳) 형태로 합장하여 분묘를 설치하는 것은 그 분묘기지권이 미치는 범위 내라 하더라도 허용되지 않는다.
- ③ 분묘기지권의 효력이 미치는 범위 안에서 원래의 분묘를 다른 곳으로 이장하는 것은 허용되지 않는다.
- ④ 토지소유자라도 분묘기지권을 침해하는 공작물을 설치할 수 없다.
- ⑤ 타인의 토지 위에 토지 소유자의 승낙 없이 분묘를 설치한 후 20년간 평온·공연하게 분묘기지를 점유한 경우 그 기지에 대한 등기를 함으로써 분묘기지권을 취득한다.

해설

- ⑤ 타인 소유의 토지에 소유자의 승낙 없이 분묘를 설치한 경우에는 20년간 평온·공연하게 그 분묘의 기지를 점유하면 지상권 유사인 관습상의 물건인 분묘기지권을 시효로 취득하는데, 이러한 분묘기지권은 봉분 등 외부에서 분묘의 존재를 인식할 수 있는 형태를 갖추고 있는 경우에 한하여 인정되고, 평장되어 있거나 암장되어 있어 객관적으로 인식할 수 있는 외형을 갖추고 있지 아니한 경우에는 인정되지 않으므로, 이러한 특성상 분묘기지권은 등기 없이 취득한다
(대법원 1996.06.14. 96다14036). 정답: ⑤

29

분묘기지권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 분묘기지권은 분묘를 소유하기 위하여 타인의 토지를 제한된 범위 내에서 사용할 수 있는 물건이다.
- ② 분묘가 멸실되더라도 유골이 존재하여 일시적인 멸실에 불과하다면 분묘기지권은 소멸하지 않는다.
- ③ 암장(暗葬)되어 있어 객관적으로 인식할 수 있는 외형을 갖추고 있지 아니한 경우에는 분묘기지권이 인정되지 않는다.
- ④ 분묘기지권을 시효로 취득한 경우, 분묘기지권자는 토지소유자가 지료를 청구하면 그 청구한 날부터의 지료를 지급할 의무가 있다.
- ⑤ 분묘기지권의 효력이 미치는 지역의 범위에는 기존의 분묘 외에 새로운 분묘를 신설할 권능도 포함된다.

해설

- ⑤ 분묘기지권은, 당사자 사이에 그 존속기간에 관한 약정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한, 권리자가 분묘의 수호와 봉사를 계속하며 그 분묘가 존속하고 있는 동안 존속하는 것이고, 그 분묘를 다른 곳에 이장하면 그 분묘기지권은 소멸된다. 그리고 분묘기지권에는 그 효력이 미치는 지역의 범위 내라고 할지라도 기존의 분묘 외에 새로운 분묘를 신설할 권능은 포함되지 아니한다(대법원 2013.01.16. 2011다38592).
- ④ 타인의 토지에 분묘를 설치하여 20년간 평온·공연하게 분묘의 기지를 점유함으로써 분묘기지권을 시효로 취득한 경우, 분묘기지권자는 토지소유자가 지료를 청구하면 그 청구한 날부터의 지료를 지급할 의무가 있다(대법원 2021.4.29. 2017다228007 전원합의체). 정답: ⑤

- ㉠ 시효로 분묘기지권을 취득한 사람은 토지소유자가 분묘기지에 관한 지료를 청구하면 그 청구한 날로부터의 지료를 지급할 의무가 있다.
- ㉡ 자기 소유 토지에 분묘를 설치한 사람이 그 토지를 양도하면서 분묘를 이장하겠다는 특약을 하지 않음으로써 분묘기지권을 취득한 경우, 특별한 사정이 없는 한 분묘기지권자는 분묘기지권이 성립한 때로부터 토지소유자에게 지료를 지급할 의무가 있다.
- ㉢ 자기 소유의 토지 위에 분묘를 설치한 후 토지의 소유권이 경매 등으로 타인에게 이전되면서 분묘기지권을 취득한 자가, 판결에 따라 분묘기지권에 관한 지료의 액수가 정해졌음에도 판결확정 후 책임 있는 사유로 상당한 기간 동안 지료의 지급을 지체하여 지체된 지료가 판결확정 전후에 걸쳐 2년분 이상이 되는 경우에는 새로운 토지소유자는 분묘기지권자에 대하여 분묘기지권의 소멸을 청구할 수 있다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉠ 타인의 토지에 분묘를 설치하여 20년간 평온·공연하게 분묘의 기지를 점유함으로써 분묘기지권을 시효로 취득한 경우, 분묘기지권자는 토지소유자가 지료를 청구하면 그 청구한 날부터의 지료를 지급할 의무가 있다(대법원 2021.4.29. 2017다228007 전원합의체).
- ㉡ 자기 소유의 토지에 분묘를 설치한 자가 후에 그 분묘기지에 대한 소유권을 유보하거나 그 분묘를 이장한다는 특약 없이 토지를 매매 등으로 처분한 때에는 그 분묘를 소유하기 위한 분묘기지권을 취득한다. 이 경우 지료는 유상이다.
- ㉢ 자기 소유의 토지 위에 분묘를 설치한 후 토지의 소유권이 경매 등으로 타인에게 이전되면서 분묘기지권을 취득한 자가, 판결에 따라 분묘기지권에 관한 지료의 액수가 정해졌음에도 책임 있는 사유로 판결확정 전후에 걸쳐 2년분 이상의 지료지급을 지체한 경우, 새로운 토지소유자는 분묘기지권의 소멸을 청구할 수 있다(대법원 2015.7.23. 2015다206850). 정답: ⑤

- ① 지역권은 별도의 지역권이전등기 없이도 요역지 소유권의 이전에 따라 함께 이전된다.
- ② 요역지는 1필의 토지이어야 하고 토지의 일부에 대하여는 설정할 수 없지만, 승역지는 1필의 토지의 일부라도 무방하다.
- ③ 승역지소유자가 자신의 비용으로 부담하고 있는 공작물의 설치 또는 수선의 의무를 면하기 위하여 지역권의 필요한 부분의 토지소유권을 지역권자에게 이전시킬 수 있다.
- ④ 용수지역권도 시효취득의 대상이 될 수 있다.
- ⑤ 지역권이 설정된 후, 요역지 위에 지상권·전세권을 취득한 자는 지역권을 행사할 수 없다.

해설

- ⑤ 지역권이 설정된 후, 요역지 위에 지상권·전세권을 취득한 자도 지역권을 행사할 수 있다.
- ① 지역권은 별도의 지역권이전등기 없이도 요역지 소유권의 이전에 따라 함께 이전된다. 법률의 규정(제292조 제1항)에 의한 물권변동이기 때문이다.
- ③ 제299조 정답: ⑤

32

지역권에 관한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 요역지의 소유자가 승역지에 통로를 개설하여 그 통로를 사용하는 상태가 민법 제245조에 규정된 기간 계속된 경우에 한하여 통행지역권의 시효취득을 인정할 수 있다.
- ② 지역권을 시효취득한 자는 등기함으로써 그 지역권을 취득하는 것이다.
- ③ 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 취득시효가 인정된다.
- ④ 점유로 인한 지역권취득시효의 중단은 요역지가 공유인 때에는 항상 그 지역권을 행사하는 공유자 중의 1인에 대한 사유로써만 효력이 있다.
- ⑤ 통로의 개설이 없는 일정한 장소를 오랜 시일 통행한 사실이 있거나 또는 토지의 소유자가 통행을 묵인하여 온 사실만으로는 지역권을 취득할 수 없다.

해설

- ④ 지역권 취득시효중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 효력이 없다(제295조 제2항).
- ② 대법원 1990.10.30. 90다카20395
- ③ 제294조 정답: ④

33

지역권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 지역권은 점유를 요건으로 하는 물건이다.
- ② 지역권은 독립하여 양도·처분할 수 있는 물건이다.
- ③ 통행지역권은 지료의 약정을 성립요건으로 한다.
- ④ 통행지역권의 시효취득을 위하여 지역권이 계속되고 표현되면 충분하고 승역지 위에 통로를 개설할 필요는 없다.
- ⑤ 통행지역권을 시효취득한 요역지소유자는, 특별한 사정이 없으면 승역지의 사용으로 그 소유자가 입은 손해를 보상하여야 한다.

해설

- ⑤ 다른 특별한 사정이 없다면 통행지역권을 시효취득한 자는 승역지 소유자가 입은 손해를 보상하여야 한다.
- ① 지역권은 점유를 요건으로 하지 않는다.
- ② 요역지소유권이 이전되거나 또는 다른 권리의 목적으로 된 때에는 지역권도 그와 법률적 운명을 같이 한다. 따라서 지역권만을 독립적으로 양도할 수는 없다.
- ③ 지역권은 유상으로 하거나 무상으로 하거나 무방하다.
- ④ 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 민법 제245조의 규정을 준용하도록 되어 있으므로, 통행 지역권은 요역지의 소유자가 승역지 위에 도로를 설치하여 승역지를 사용하는 객관적 상태가 민법 제245조에 규정된 기간 계속된 경우에 한하여 그 시효취득을 인정할 수 있다(대법원 1995.06.13. 95다1088,1095). 정답: ⑤

34

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 지역권은 요역지의 사용가치를 높이기 위해 승역지를 이용하는 것을 내용으로 하는 물권이다.
- ② 요역지와 승역지는 서로 인접한 토지가 아니어도 된다.
- ③ 요역지 공유자 중 1인에 대한 지역권 소멸시효의 정지는 다른 공유자를 위하여도 효력이 있다.
- ④ 지역권자는 승역지의 점유침탈이 있는 경우, 지역권에 기하여 승역지 반환청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 시효취득할 수 있다.

해설

- ④ 지역권은 일정한 목적에 따라 승역지에서 편익을 받는 권리이므로 편익을 받는 것이 방해되는 경우에는 방해배제청구권 또는 방해예방청구권을 행사할 수 있다. 그러나 지역권은 승역지의 점유를 수반하는 권리가 아니므로 반환청구권은 인정되지 않는다. 정답: ④

35

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 민법상 지역권의 존속기간은 최장 30년이지만 갱신할 수 있고, 이를 등기하여 제3자에 대항할 수 있다.
- ② 요역지와 승역지는 반드시 서로 인접할 필요가 없다.
- ③ 공유자의 1인이 지역권을 취득하는 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ④ 지역권설정등기는 승역지의 등기부 등록에 기재된다.
- ⑤ 지역권자는 지역권을 방해할 염려 있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방을 청구 할 수 있다.

해설

- ① 지역권의 존속기간은 당사자의 약정으로 자유로이 정할 수 있으며, 그것을 등기함으로써 제3자에게 대항할 수 있다. 그리고 지역권의 성질로 보아 영구무한의 지역권도 설정할 수 있다고 하는 것이 통설과 판례이다. 정답: ①

36

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지역권은 소멸시효의 대상이 될 수 없다.
- ② 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ③ 승역지 소유자는 지역권의 행사를 방해하지 않는 범위 내에서 지역권자가 지역권의 행사를 위하여 승역지에 설치한 공작물을 사용할 수 있다.
- ④ 지역권은 요역지 소유권의 상속에 의하여 취득될 수 있다.
- ⑤ 지역권은 다른 약정이 없는 한, 요역지 소유권에 부종하여 이전한다.

해설

- ① 지역권은 20년의 소멸시효에 걸린다. 정답: ①

제5장
실전문제

37

지역권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 공인중개사]

- ① 요역지의 소유권이 양도되면 지역권은 원칙적으로 이전되지 않는다.
- ② 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ③ 점유로 인한 지역권취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다.
- ④ 어느 토지에 대하여 통행지역권을 주장하려면 그 토지의 통행으로 편익을 얻는 요역지가 있음을 주장·증명해야 한다.
- ⑤ 승역지에 관하여 통행지역권을 시효취득한 경우, 특별한 사정이 없는 한 요역지 소유자는 승역지 소유자에게 승역지의 사용으로 입은 손해를 보상해야 한다.

해설

① 지역권은 별도의 지역권이전등기 없이도 요역지 소유권의 이전에 따라 함께 이전된다. 정답: ①

38

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 1필의 토지 일부를 승역지로 하여 지역권을 설정할 수 있다.
- ② 요역지가 공유인 경우 요역지의 공유자 1인이 지역권을 취득하면 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ③ 지역권은 요역지와 분리하여 양도하지 못한다.
- ④ 승역지 소유자는 지역권에 필요한 부분의 토지소유권을 지역권자에게 위기(委棄)함으로써 지역권행사를 위하여 계약상 부담하는 공작물 수선의무를 면할 수 있다.
- ⑤ 다른 특별한 사정이 없다면 통행지역권을 시효취득한 자는 승역지 소유자가 입은 손해를 보상하지 않아도 된다.

해설

⑤ 다른 특별한 사정이 없다면 통행지역권을 시효취득한 자는 승역지 소유자가 입은 손해를 보상하여야 한다. 정답: ⑤

39

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 통행지역권의 점유취득시효는 승역지 위에 도로를 설치하여 늘 사용하는 객관적 상태를 전제로 한다.
- ② 요역지의 공유자 중 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ③ 요역지의 공유자 중 1인에 의한 지역권소멸시효의 중단은 다른 공유자에게는 효력이 없다.
- ④ 점유로 인한 지역권취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다.
- ⑤ 통행지역권을 시효취득한 요역지 소유자는 특별한 사정이 없는 한 승역지에 대한 도로 설치 및 사용에 의하여 승역지 소유자가 입은 손해를 보상해야 한다.

해설

③ 요역지를 공유하고 있는 경우에 공유자의 1인을 위한 소멸시효의 중단 또는 정지가 있는 경우에는 그 중단 또는 정지의 사유는 다른 공유자를 위해서도 효력이 있다(제296조). 정답: ③

40

지역권에 관한 설명으로 틀린 것은?

[2021' 공인중개사]

- ① 지역권은 요역지와 분리하여 따로 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.
- ② 1필의 토지의 일부에는 지역권을 설정할 수 없다.
- ③ 요역지의 공유자 중 1인이 지역권을 취득한 경우, 요역 지의 다른 공유자도 지역권을 취득한다.
- ④ 지역권에 기한 승역지 반환청구권은 인정되지 않는다.
- ⑤ 계속되고 표현된 지역권은 시효취득의 대상이 될 수 있다.

해설

② 지역권은 1필의 토지 전부 또는 일부위에 설정될 수 있다. 정답: ②

41

전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전세권자의 책임 없는 사유로 전세권의 목적물 전부가 멸실된 때에도 전세권자는 손해배상 책임이 있다.
- ② 건물에 대한 전세권이 법정갱신되는 경우, 그 존속기간은 2년으로 본다.
- ③ 전세권의 존속기간이 만료되면 전세권설정등기의 말소 없이도 당연히 소멸한다.
- ④ 전세권설정자는 특약이 없는 한 목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 해야 한다.
- ⑤ 전세권자는 전세권설정자에게 목적물의 현상을 유지하기 위하여 지출한 필요비의 상환을 청구할 수 있다.

제5장
실전문제

해설

③ 존속기간의 만료로 인한 용익물권의 소멸은 말소등기를 요하지 아니한다. 정답: ③

42

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ② 기존 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수 있다.
- ③ 농경지를 전세권의 목적으로 할 수 있다.
- ④ 전세금이 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다.
- ⑤ 전세권의 목적물의 전부 또는 일부가 전세권자에게 책임있는 사유로 인하여 멸실된 경우, 전세권설정자는 전세권이 소멸된 후 전세금으로써 손해의 배상에 총당할 수 있다.

해설

③ 농경지는 전세권의 목적으로 하지 못한다(제303조 제2항). 정답: ③

43 전세권의 효력에 관한 다음 기술 중 부당한 것은?

- ① 대지와 건물이 동일한 소유자에게 속한 경우에 건물에 대하여 전세권을 설정한 때에는, 그 대지소유자의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- ② 전세권자는 설정행위로서 금지하지 아니하는 한 전세권을 타인에게 양도하거나 담보로 제공할 수 있고, 또 존속기간 내에서 목적물을 타인에게 전전세 또는 임대할 수 있다.
- ③ 전세권자가 목적물을 용익하기 위하여 지출한 유익비에 관해서 그 가격의 증가가 현존하는 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아서 그 지출액이나 증가액 상환을 청구할 수 있다.
- ④ 전세권자는 목적물에 대한 방해제거청구권과 방해예방청구권을 가지고 있으나 목적물반환 청구권은 없다.
- ⑤ 타인의 토지상에 있는 건물에 대하여 전세권을 설정한 때에는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권 또는 임차권에 미친다.

해설

- ④ 전세권의 내용의 실현이 방해된 경우에 전세권자는 물권적 청구권으로서 반환청구권, 방해제거청구권, 방해예방청구권을 행사할 수 있다(제319조·제213조 참조)
- ① 제305조
 - ② 제306조
 - ③ 제310조
 - ⑤ 제304조 정답: ④

44 전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 건물 일부의 전세권자는 나머지 건물 부분에 대해서도 경매신청권이 있다.
- ② 전세권 설정계약의 당사자는 전세권의 사용·수익권능을 배제하고 채권담보만을 위한 전세권을 설정할 수 있다.
- ③ 전세권설정시 전세금 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ④ 전세권자는 특별한 사정이 없는 한 전세권의 존속기간 내에서 전세목적물을 타인에게 전전세 할 수 없다.
- ⑤ 전세권이 소멸된 경우, 전세권자의 전세목적물의 인도는 전세금의 반환보다 선이행되어야 한다.

해설

- ③ 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ① 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대하여는 우선변제권은 있지만 경매신청권은 없다(대법원 2001.07.02. 2001마212).
 - ② 전세권은 설정계약과 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하는 물권으로서 채권담보만을 위한 전세권 설정은 인정되지 않는다.
 - ④ 전세권은 설정자의 동의없이도 양도·임대·전전세·담보로 제공할 수 있다.
 - ⑤ 전세권자의 전세목적물 인도 의무 및 전세권설정등기 말소등기의무와 전세권설정자의 전세금반환의 무는 서로 동시이행의 관계에 있다(대법원 1977.04.13. 77마90). 정답: ③

45

전세권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 공인중개사]

- ① 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ② 당사자가 주로 채권담보의 목적을 갖는 전세권을 설정하였다더라도 장차 전세권자의 목적물에 대한 사용수익권을 완전히 배제하는 것이 아니라면 그 효력은 인정된다.
- ③ 건물전세권이 법정갱신된 경우 전세권자는 전세권갱신에 관한 등기 없이도 제3자에게 전세권을 주장할 수 있다.
- ④ 전세권의 존속기간 중 전세목적물의 소유권이 양도되면, 그 양수인이 전세권설정자의 지위를 승계한다.
- ⑤ 건물의 일부에 대한 전세에서 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체하는 경우, 전세권자는 전세권에 기하여 건물 전부에 대해서 경매청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대하여는 우선변제권은 있지만 경매신청권은 없다(대법원 2001.07.02. 2001마212). 정답: ⑤

46

전세권에 대한 다음 설명 중 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 법정갱신의 경우 등기를 하지 않아도 제3자에게 대항할 수 있다.
- ② 전세권 위에 저당권이 설정된 후 전세권의 존속기간이 만료된 경우에 저당권자는 전세금반환채권에 대하여 압류한 후 추심명령이나 전부명령을 받는 방법으로 자신의 권리를 행사할 수 있다.
- ③ 설정행위로서 존속기간을 정하지 않은 경우에 각 당사자는 언제든지 상대방에게 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다.
- ④ 전세권이 소멸한 때에는 전세권설정자는 전세권자로부터 목적물의 인도 및 전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류의 교부를 받은 후에 전세금을 반환하면 된다.
- ⑤ 저당권과 전세권이 경합하는 경우에 전세권이 선순위인 경우에는 전세권자가 경매를 신청하면 양자 모두 소멸하나 저당권자가 경매를 신청해도 전세권은 소멸하지 않는 것이 원칙이다.

해설

- ④ 목적물 인도 및 말소등기서류의 교부와 전세금의 반환은 동시이행의 관계가 있다(제317조 참조, 대법원 2002.2.5. 2001다62091). 단, 임대차는 목적물반환과 임대보증금반환이 동시이행관계에 있다(대법원[전합] 1977.9.28. 77다1241).

- ① 대법원 1989.7.11. 88다카21029
- ② 대법원 1999.9.17. 98다31301
- ③ 제313조

- ⑤ 전세권이 먼저 설정되고 그 후에 저당권이 설정된 경우에 그 저당권자가 경매를 신청하는 경우에는, 그 당시 전세권의 기간이 만료되지 않은 한 전세권은 소멸하지 않는다. 전세권자의 용익권은 보호되어야 하기 때문이다. 다만 전세권자가 배당요구를 하면 경매로 인한 매각으로 전세권은 소멸한다(민사집행법 제91조 제4항). 정답: ④

제5장
실전문제

47 전세권에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전세권의 존속기간은 10년을 넘지 못하며 당사자의 약정기간이 10년을 넘은 때에는 10년으로 단축된다.
- ② 전세권자가 목적물의 현상을 유지하기 위하여 지출한 필요비와 목적물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비는 전세권자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 전세권의 존속기간을 약정하지 않은 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다.
- ④ 전세권이 소멸한 때에는 전세권설정자는 전세권자로부터 그 목적물의 인도 및 전세권설정 등기의 말소에 필요한 서류의 교부를 받는 동시에 전세금을 반환하여야 한다.
- ⑤ 전세권이 존속기간의 만료로 소멸한 때에는 전세권자는 전세권설정자에 대하여 그의 동의를 얻어 부속시킨 부속물의 매수를 청구할 수 있다.

해설

- ② 전세권자는 목적물의 현상유지의무가 있으므로 필요비의 상환은 청구할 수 없다(제309조). 전세권자가 목적물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다(제310조). 정답: ②

48 전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전세권자가 소유자의 승낙 없이 전세권을 제3자에게 양도한 점만으로는 전세권에 대한 소멸청구사유가 되지 않는다.
- ② 타인의 토지에 있는 건물에 설정된 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 토지 임차권에도 미친다.
- ③ 전세권자는 통상의 필요비와 유익비를 지출한 경우, 전세권설정자에게 그 상환을 청구할 수 있다.
- ④ 전세권의 목적물의 일부가 불가항력으로 인하여 멸실된 때에는 그 멸실된 부분의 전세권은 소멸한다.
- ⑤ 건물의 일부에 대하여만 전세권이 설정되어 있는 경우에 그 전세권자는 건물 전부의 경매를 청구할 수 없다.

해설

- ③ 전세권자는 목적물의 현상을 유지하고 통상의 관리에 속한 수선을 해야 할 의무가 있다. 따라서 필요비상환청구권은 전세권자에게는 인정되지 않는다. 정답: ③

49 전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전세권자는 전세권설정계약에 다른 약정이 없는 한 전세권설정자의 동의 없이 전전세를 할 수 있다.
- ② 전세권이 성립한 후 전세목적물의 소유권이 이전된 경우, 전세권은 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신 소유자 사이에서 동일한 내용으로 존속한다.
- ③ 전세권이 갱신없이 존속기간이 만료되면 그 용익물권적 권능은 전세권설정등기의 말소 없이도 소멸한다.
- ④ 전세권자는 전세권설정자에게 목적물의 현상을 유지하기 위하여 지출한 필요비의 상환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우, 그 전세권의 목적이 된 부분이 구조상 또는 이용상 독립성이 없어 그 부분만의 경매신청이 불가능하다고 하더라도, 이를 이유로 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대하여 그 전세권에 기한 경매신청을 할 수 없다.

해설

④ 전세권자에게는 필요비상환청구권은 인정되지 않는다. 정답: ④

50 다음 중 전세권의 성립 및 소멸에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전세권은 타인의 부동산 또는 동산에 인정되는 권리이다.
- ② 전세권의 소멸의 경우에는 설정자의 전세금반환과 전세권자의 전세권말소등기서류의 교부는 동시이행의 관계에 있다.
- ③ 전세권설정자는 목적부동산을 사용·수익에 적합한 상태에 두어야 할 적극적 의무가 있다.
- ④ 전세권자와 설정자는 상호간 그 부속물의 매수를 청구할 수 있다.
- ⑤ 전세권 위에는 저당권을 설정할 수 없다.

제5장
실전문제

해설

◎ 전세권소멸의 효과

동시이행	목적물의 인도 및 전세권말소등기서류교부와 전세금의 반환은 동시이행의 관계에 있다.
경매청구권	설정자가 전세금의 반환을 지체하는 경우 행사할 수 있다.
전세권자의 부속물매수청구권	설정자의 동의를 얻어 부속시킨 경우 또는 설정자로부터 매수한 부속물인 경우에 설정자에 대하여 매수를 청구할 수 있다. 아울러 설정자도 전세권자에 대하여 부속물의 매수를 청구할 수 있다.
유익비상환청구권	가액의 증가가 현존하는 경우에 한하여 지출액 또는 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
원상회복의무와 부속물수거권	전세권자 목적물을 원상에 회복하여야 하고 부속물을 수거할 수 있다.
전세권자의 손해배상책임	목적물의 전부 또는 일부가 전세권자의 귀책사유로 인하여 멸실된 때에는 전세권자는 손해를 배상할 책임이 있다.

정답: ④

51 전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 대지와 건물의 소유자가 동일한 경우, 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- ② 전세권자는 전세목적물의 현상을 유지하고 그 통상의 관리에 속한 수선을 해야 한다.
- ③ 전세권자가 전세목적물에 필요비를 지출한 경우, 전세권설정자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ④ 전세권자가 전세목적물을 타인에게 임대한 경우, 전세권자는 임대하지 아니하였다면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여 책임을 부담한다.
- ⑤ 전세권자는 전세목적물을 점유하여 그 목적물의 용도에 좇아 사용·수익할 수 있다.

해설

- ① 제305조 ④ 제308조 ⑤ 제303조
- ②③ 전세권자는 목적물의 현상유지의무가 있으므로 필요비의 상환은 청구할 수 없다(제309조). 다만, 전세권자가 목적물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 소유자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허용할 수 있다(제310조). 정답: ③

52 전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 전세권자는 목적부동산의 사용·수익의 방법에 어떠한 제한도 받지 않는다.
- ② 전세권설정자는 인도한 목적부동산을 사용·수익에 적합한 상태로 유지할 적극적 의무가 있다.
- ③ 전세권의 존속기간 중 전세금반환청구권을 전세권과 분리하여 확정적으로 양도할 수 있다.
- ④ 甲소유에 속한 대지와 건물 중 그 건물에 乙이 전세권을 취득한 후 그 대지가 丙에게 양도된 경우에 乙은 법정지상권을 취득한다.
- ⑤ 주로 채권담보목적으로 전세권이 설정되었더라도 장차 전세권자가 목적물을 사용·수익하는 것을 완전히 배제하지 않았다면, 그 전세권의 효력은 인정된다.

해설

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 해당 부동산의 용법에 따라 사용·수익하여야 하며, 이를 위반시 전세권 소멸사유가 될 수 있다.
- ② 목적물의 현상을 유지하고 통상의 관리에 속한 수선을 해야 할 의무는 전세권자에게 있다. 따라서 필요비상환청구권은 전세권자에게는 인정되지 않는다.
- ③ 전세금반환청구권과 전세권을 분리하여 양도할 수 있는지에 대하여 학설은 대립하나, 판례는 전세권이 존속하는 동안은 전세금반환채권만을 분리하여 확정적으로 양도하는 것은 허용되지 않는다고 한다(대법원 2002.8.23. 2001다69122).
- ④ 법정지상권을 취득하는 자는 전세권자 乙이 아니라 전세권설정자 甲이다. 정답: ⑤

53

전세권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉠ 전세권은 전세권의 양도나 상속에 의해서도 취득할 수 있다.
- ㉡ 전세권자와 인지소유자 사이에는 상권관계에 관한 민법 규정이 준용된다.
- ㉢ 동일한 건물에 저당권이 전세권보다 먼저 설정된 경우, 전세권자가 경매를 신청하여 매각되면 전세권과 저당권은 모두 소멸한다.
- ㉣ 임대인과 임차인이 임대차계약을 체결하면서 임차보증금을 전세금으로 하는 전세권설정 계약을 체결하고 전세권설정등기를 경료한 경우, 다른 약정이 없는 한 임차보증금 반환 의무와 전세권설정등기 말소의무는 동시이행관계에 있다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣ ③ ㉠, ㉡, ㉢ ④ ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

해설

- ⑤ 모두 타당한 지문이다. 아울러 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다. 정답: ⑤

54

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 때에는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권에 미친다.
- ② 건물전세권설정자가 건물의 존립을 위한 토지사용권을 가지지 못하여 그가 토지소유자의 건물철거 등 청구에 대항할 수 없는 경우, 전세권자는 토지소유자의 권리행사에 대항할 수 없다.
- ③ 지상권을 가지는 건물소유자가 그 건물에 전세권을 설정하였으나 그가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니하였음을 이유로 지상권설정자가 지상권의 소멸을 청구한 경우, 전세권자의 동의가 없다면 지상권은 소멸되지 않는다.
- ④ 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지 소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- ⑤ 건물에 대한 전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다.

해설

- ③ 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니하여 지상권설정자가 지상권의 소멸을 청구한 경우, 건물의 전세권자의 동의와 관계없이 지상권은 소멸한다. 정답: ③

제5장
실전문제

55

다음 중 전세권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우 그 전세권자는 건물 전부에 대하여 후 순위 권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있다.
- ② 전세목적물의 소유자가 바뀔 경우, 목적물의 경매대금으로 전세금채권의 일부밖에 만족 받지 못한 전세권자는 나머지 부분에 대해서는 전 소유자에 대하여 전세금반환을 청구하여야 한다.
- ③ 전세권을 그 담보하는 전세금반환채권과 분리하여 양도하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.
- ④ 당사자가 주로 채권담보의 목적으로 전세권을 설정하였고, 그 설정과 동시에 목적물을 인도하지 아니한 경우라 하더라도, 장차 전세권자가 목적물을 사용, 수익하는 것을 완전히 배제하는 것이 아니라면, 그 전세권의 효력을 부인할 수는 없다.
- ⑤ 전세권의 법정갱신은 법률의 규정에 의한 물건변동이므로 전세권 갱신에 관한 등기를 요하지 아니하고 전세권자는 등기 없이도 목적물을 취득한 제3자에게 그 권리를 주장할 수 있다.

해설

② 목적물의 신소유자는 구소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어, 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금 반환의무를 부담하게 되고, 구소유자는 전세권설정자의 지위를 상실하여 전세금반환의무를 면하게 된다고 보아야 할 것이다(대법원 2000.6.9. 99다15122).

- ① 대법원 1991.3.25. 91라63·64
- ③ 대법원 1999.2.5. 97다33997
- ④ 대법원 1995.2.10. 94다18508
- ⑤ 대법원 1989.7.11. 88다카21029 정답: ②

56

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 건물 일부의 전세권자는 나머지 건물 부분에 대한 경매신청권이 없다.
- ② 토지전세권의 경우 전세권의 법정갱신이 인정된다.
- ③ 토지전세권의 존속기간이 만료한 경우 전세권의 용익물권적 권능은 전세권설정등기의 말소 없이도 당연히 소멸한다.
- ④ 전세권설정자가 제3자에게 전세 목적 부동산을 양도한 경우 그는 원칙적으로 전세금반환의무를 면한다.
- ⑤ 전세권자가 장차 전세권이 소멸하여 전세금 반환채권이 발생하는 것을 조건으로 그 장래의 조건부 채권을 제3자에게 양도한 경우 그 양도는 유효하다.

해설

② 건물의 전세권설정자가 전세권의 존속기간 만료 전 6월부터 1월까지 사이에 전세권자에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 않으면 갱신하지 않는다는 뜻의 통지를 하지 않은 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전(前)전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다. 이 경우 전세권의 존속기간은 그 정하지 않은 것으로 본다(제312조 제4항). 따라서 토지전세권의 경우에는 법정갱신이 인정되지 않는다. 정답: ②

57 갑의 아파트에 을이 전세권을 가지고 있는 도중에 갑이 그 아파트를 병에게 매도하고 소유권이전등기까지 마쳤다. 그러면서 갑은 병과의 사이에 갑의 전세금반환채무를 병이 인수하기로 합의하여 그것을 공제한 나머지 대금만 병으로부터 받았다. 판례에 의할 때, 이 경우에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 을의 전세권은 매매 당시에 소멸한다.
- ② 전세금반환의무는 갑이 여전히 부담하고 있다.
- ③ 전세금반환의무는 병이 부담한다.
- ④ 전세금반환의무는 갑과 병이 연대하여 부담한다.
- ⑤ 이 경우는 채권양도이론에 의하여 법률관계가 정하여 진다.

해설

- ③ 전세권이 성립한 후 목적물의 소유권이 이전되는 경우에 있어서 전세권 관계가 전세권자와 전세권설정자인 종전 소유자와 사이에 계속 존속되는 것인지 아니면 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신소유자와 사이에 동일한 내용으로 존속되는지에 관하여 민법에 명시적인 규정은 없으나, 전세목적물의 소유권이 이전된 경우 민법이 전세권 관계로부터 생기는 상환청구, 소멸청구, 갱신청구, 전세금증감청구, 원상회복, 매수청구 등의 법률관계의 당사자로 규정하고 있는 전세권설정자 또는 소유자는 모두 목적물의 소유권을 취득한 신소유자로 새길 수밖에 없다고 할 것이므로, 전세권은 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신소유자 사이에서 계속 동일한 내용으로 존속하게 된다고 보아야 할 것이고, 따라서 목적물의 신소유자는 구소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금반환의무를 부담하게 되고, 구소유자는 전세권설정자의 지위를 상실하여 전세금반환의무를 면하게 된다고 보아야 하고, 전세권이 전세금 채권을 담보하는 담보물권적 성질을 가지고 있다고 하여도 전세권은 전세금이 존재하지 않으면 독립하여 존재할 수 없는 용익물권으로서 전세금은 전세권과 분리될 수 없는 요소이므로 전세권 관계로 생기는 위와 같은 법률관계가 신소유자에게 이전되었다고 보는 이상, 전세금 채권 관계만이 따로 분리되어 전 소유자와 사이에 남아 있다고 할 수는 없을 것이고, 당연히 신 소유자에게 이전되었다고 보는 것이 옳다(대법원 2000.6.9. 99다15122). 정답: ③

58 전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 전전세권의 설정에는 원전세권자와 전전세권자 사이의 전전세권 설정의 합의 및 등기와 원전세권설정자의 동의를 요한다.
- ② 구분등기 되지 않은 건물 일부의 전세권자는 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대해서는 전세권에 기하여 경매신청을 할 수 없으나 우선변제권은 가진다.
- ③ 전세권이 법정 갱신된 경우 갱신에 따른 등기를 하지 않으면, 전세권자는 그 목적물을 취득한 제3자에 대하여 갱신된 권리를 주장하지 못한다.
- ④ 전세금을 현실적으로 지급하지 아니하고 기존의 채권으로 갈음하기로 한 경우에는 전세권이 성립될 수 없다.
- ⑤ 전세권 존속기간이 만료된 경우 전세권의 용익물권적 권능은 소멸되고 전세금반환채권은 무담보채권으로 전환된다.

해설

- ② 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우 그 전세권자는 그 건물전부에 대하여 후순위 권리자 기타 채권자보다 전세권의 우선변제를 받을 권리가 있고, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물 부분에 대하여는 우선변제권은 있지만 경매신청권은 없다(대법원 2001.07.02. 2001마212 결정).
- ① 전전세권의 설정에는 전세권설정자의 동의를 요하지 않으며 원전세권자와 전전세권자의 설정계약과 등기(부기등기)로서 성립한다.
- ③ 전세권이 법정갱신된 경우 이는 법률의 규정에 의한 물권의 변동이므로 전세권갱신에 관한 등기를 필요로 하지 아니하고, 전세권자는 등기 없이도 전세권설정자나 그 목적물을 취득한 제3자에 대하여 갱신된 권리를 주장할 수 있다(대법원 2010.03.25. 2009다35743).
- ④ 전세권이 용익물권적 성격과 담보물권적 성격을 겸비하고 있다는 점 및 목적물의 인도는 전세권의 성립요건이 아닌 점 등에 비추어 볼 때, 당사자가 주로 채권담보의 목적으로 전세권을 설정하였고, 그 설정과 동시에 목적물을 인도하지 아니한 경우라 하더라도, 장차 전세권자가 목적물을 사용·수익하는 것을 완전히 배제하는 것이 아니라면, 그 전세권의 효력을 부인할 수는 없다 할 것이고, 한편 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다(대법원 2009.01.30. 2008다67217).
- ⑤ 전세권이 존속기간의 만료나 합의해지 등으로 종료하면 전세권의 용익물권적 권능은 소멸하고 단지 전세금반환채권을 담보하는 담보물권적 권능의 범위 내에서 전세금의 반환시까지 전세권설정등기의 효력이 존속한다(대법원 2015.11.17. 2014다10694). 정답: ②

59

전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 전세권이 성립한 후 목적물의 소유권이 이전되더라도 전세금반환채무가 당연히 신소유자에게 이전되는 것은 아니다.
- ② 전세권의 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 시작되기 전에는 무효이다.
- ③ 전세권을 설정하는 때에는 전세금이 반드시 현실적으로 수수되어야 한다.
- ④ 건물의 일부에 전세권이 설정된 경우 전세권의 목적물이 아닌 나머지 부분에 대해서도 경매를 신청할 수 있다.
- ⑤ 전세권자가 통상의 필요비를 지출한 경우 그 비용의 상환을 청구하지 못한다.

해설

- ⑤ 전세권자에게는 유익비상환청구권은 인정되나 필요비상환청구권은 인정되지 않는다.
- ④ 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우 그 전세권자는 그 건물전부에 대하여 후순위 권리자 기타 채권자보다 전세권의 우선변제를 받을 권리가 있고, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물 부분에 대하여는 우선변제권은 있지만 경매신청권은 없다(대법원 2001.07.02. 2001마212 결정).
- ① 전세권이 성립한 후 목적물의 소유권이 이전되면 전세금반환채무는 신소유자에게 이전된다.
- ② 전세권의 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 시작되기 전에도 효력이 있다.
- ③ 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다(대법원 2009.01.30. 2008다67217). 정답: ⑤

- ㉔ 전세권의 존속기간이 만료하면 전세권의 용익물권적 권능이 소멸하기 때문에 그 전세권에 대한 저당권자는 더 이상 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없게 되고, 이러한 경우에는 민법 제370조, 제342조, 민사집행법 제273조에 의하여 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 추심명령 또는 전부명령을 받거나, 제3자가 전세금 반환채권에 대하여 실시한 강제집행절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사할 수 있다(대법원 2008.03.13. 선고 2006다29372). 정답: ④

62

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 타인의 토지에 있는 건물의 소유자가 그 건물에 설정한 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 임차권에도 미친다.
- ② 대지와 건물이 동일한 소유자에게 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지 소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- ③ 전세권이 법정갱신된 경우, 전세권자는 등기 없이도 그 목적물을 취득한 제3자에 대하여 갱신된 권리를 주장할 수 있다.
- ④ 전세권에 저당권을 설정한 경우, 전세기간이 만료되더라도 전세권의 저당권자는 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행하여 전세금을 배당받을 수 있다.
- ⑤ 토지전세권의 존속기간을 15년으로 약정한 경우에 그 존속기간은 10년으로 단축되지만, 당사자는 존속기간 만료 시에 갱신한 날로부터 10년을 넘지 않는 기간으로 전세권을 갱신할 수 있다.

해설

- ④ 전세권의 존속기간이 만료하면 전세권의 용익물권적 권능이 소멸하기 때문에 그 전세권에 대한 저당권자는 더 이상 전세권 자체에 대하여 저당권을 실행할 수 없게 되고, 이러한 경우에는 저당권의 목적물인 전세권에 갈음하여 존속하는 것으로 볼 수 있는 전세금반환채권에 대하여 추심명령 또는 전부명령을 받거나, 제3자가 전세금반환채권에 대하여 실시한 강제집행절차에서 배당요구를 하는 등의 방법으로 자신의 권리를 행사할 수 있다(대법원 2008.03.13. 선고 2006다29372).

정답: ④

63

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 변리사]

- ① 전세권은 1필의 토지 중 일부에 대해서도 설정할 수 있다.
- ② 전세권 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기는 특별한 사정이 없는 한 무효로 추정된다.
- ③ 전세금이 현실적으로 수수되지 않은 경우에도 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수 있다.
- ④ 전세권 존속기간 만료의 경우, 합의에 의하여 전세권설정계약을 갱신할 수 있으나 그 기간은 갱신한 날로부터 10년을 넘을 수 없다.
- ⑤ 전세권설정계약의 당사자가 전세권의 존속기간을 약정하지 않은 경우, 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있다.

해설

- ② 전세권의 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 시작되기 전에도 효력이 있다. 정답: ②

64

지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권자는 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다.
- ② 지상권이 소멸한 경우 특별한 사정이 없는 한, 지상권자는 건물 기타 공작물이나 수목을 수거하여 토지를 원상에 회복하여야 한다.
- ③ 지상권자의 지료지급이 토지소유권의 양도 전후에 걸쳐 2년 이상 연체된 경우, 토지양수인에 대한 연체기간이 2년이 되지 않더라도 토지양수인은 지상권소멸청구를 할 수 있다.
- ④ 나대지에 저당권을 설정한 당사자들이 그 목적 토지상에 저당권자 앞으로 저당토지의 담보 가치 저감을 막기 위하여 지상권도 설정한 경우, 저당권의 피담보채권이 시효로 소멸하면 지상권도 소멸한다.
- ⑤ 토지와 그 지상건물이 함께 양도되었다가 채권자취소권의 행사로 그 중 건물에 대해서만 양도가 취소되어 수익자 명의의 소유권이전등기가 말소된 경우, 채무자에게 관습상 법정지상권은 인정되지 않는다.

해설

- ③ 지상권자의 지료 지급 연체가 토지소유권의 양도 전후에 걸쳐 이루어진 경우 토지양수인에 대한 연체기간이 2년이 되지 않는다면 양수인은 지상권소멸청구를 할 수 없다(대법원 2001.03.13. 99다17142). 정답: ③

제5장
실전문제

65

법정지상권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 관습상 법정지상권이 성립하려면 토지와 그 지상건물이 원시적으로 동일인의 소유에 속하고 있어야 한다.
- ② 토지에 저당권이 설정될 때에 그 지상건물이 미등기인 경우, 저당권 실행으로 토지와 건물의 소유자가 상이하게 되더라도 법정지상권은 인정될 수 없다.
- ③ 환지처분으로 인하여 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라진 경우에도 관습상 법정지상권은 인정될 수 있다.
- ④ 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라질 때, 토지의 사용에 대하여 당사자 사이에 특약이 있는 경우, 관습상 법정지상권은 인정될 수 없다.
- ⑤ 나대지상에 채권담보를 위한 가등기가 경료된 후에 대지소유자가 그 지상에 건물을 신축하였고, 그 후에 가등기에 기한 본등기가 경료되어 대지와 건물의 소유자가 달라진 경우 관습상 법정지상권이 성립될 수 있다.

해설

- ④ 동일인 소유였던 토지와 그 지상건물의 소유권이 분리되어 건물소유자가 관습상의 법정지상권을 취득한 후 토지소유자와 간에 건물소유를 위한 임대차계약을 체결하고 임차권을 취득한 경우에는 관습법상의 법정지상권을 포기한 것으로 보아야 한다(대법원 1979.06.05. 79다572). 정답: ④

66

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지역권은 요역지와 분리하여 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.
- ② 토지공유자의 1인은 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담한 지역권을 소멸하게 할 수 있다.
- ③ 지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용할 권리가 있다.
- ④ 점유로 인한 지역권취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다.
- ⑤ 계약에 의하여 승역지소유자가 자기의 비용으로 지역권의 행사를 위하여 공작물의 수선 의무를 부담하기로 하고 이를 등기한 경우, 승역지소유자의 특별승계인도 그 의무를 부담한다.

해설

- ② 토지공유자의 1인은 자기의 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담하고 있는 지역권을 소멸하게 하지 못한다(제293조 제1항). 정답: ②

67

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물전세권이 법정갱신된 경우, 전세권자는 등기 없이도 전세권설정자나 그 목적물을 취득한 제3자에 대하여 갱신된 권리를 주장할 수 있다.
- ② 토지전세권의 존속기간을 약정하지 아니한 경우 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있다.
- ③ 토지전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다.
- ④ 전세권자가 그 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용, 수익하지 아니한 경우에는 전세권설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ⑤ 전세권 존속 중에는 장래에 그 전세권이 소멸하는 경우에 전세금반환채권이 발생하는 것을 조건으로 그 장래의 조건부채권을 양도할 수 있다.

해설

- ③ 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다는 최단존속기간의 제한은 건물의 전세권에 한한다.

정답: ③

68

전세권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉠ 전세권자는 전세권이 설정된 부동산 전부에 대하여 후순위 권리자나 그 밖의 일반채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있다.
- ㉡ 전세권은 용익물권적 성격과 담보물권적 성격을 겸비하고 있다.
- ㉢ 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 경우 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권에는 미치지 않는다.

① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉡

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉢ 타인의 토지 위에 있는 건물에 전세권을 설정한 경우에는, 그 건물의 사용·수익을 확보하기 위하여 전세권의 효력은 건물의 소유를 목적으로 한 지상권이나 임차권에도 미친다. 따라서 전세권설정자는 지상권이나 임차권을 전세권자의 동의 없이 소멸시키지 못한다(제304조). 정답 ③

제5장
실전문제

- ① 저당권설정자는 저당권자의 동의 없이 전세권을 소멸하게 하는 행위를 하지 못한다.
- ② 전세권의 존속기간이 만료된 경우 저당권자는 전세권 자체에 대해 저당권을 실행할 수 있다.
- ③ 전세권의 존속기간이 만료되면 저당권자는 전세금반환채권에 대하여 물상대위할 수 있다.
- ④ 전세금반환채권은 저당권의 목적물이 아니다.
- ⑤ 전세권이 기간만료로 소멸한 경우 전세권설정자는 원칙적으로 전세권자에 대하여만 전세금 반환의무를 부담한다.

해설

- ② 전세권이 기간만료로 종료된 경우 전세권은 전세권설정등기의 말소등기 없이도 당연히 소멸하고, 저당권의 목적물인 전세권이 소멸하면 저당권도 당연히 소멸하는 것이므로 전세권을 목적으로 한 저당권자는 전세권의 목적물인 부동산의 소유자에게 더 이상 저당권을 주장할 수 없다(대법원 1999. 9. 17. 98다31301). 정답: ②

담보물권

1

기본문제

01 유치권에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 유치권은 부동산에 대해서도 성립할 수 있다.
- ② 피담보채권이 목적물의 반환청구권과 동일한 법률관계 또는 사실관계로부터 발생한 경우에도 유치권은 성립할 수 있다.
- ③ 피담보채권과 목적물의 '점유' 사이의 견련관계는 요구되지 않는다고 봄이 통설·판례이다.
- ④ 채권의 변제기 도래는 유치권의 성립요건일 뿐 아니라 환가를 위한 경매실행요건이다.
- ⑤ 유치권이 성립하고 있는 물건의 인도청구에 대해서 현재 우리 대법원은 상환금부판결을 선고한다.

해설

- ④ 동시이행의 항변권(제536조)과 마찬가지로 유치권이 성립하기 위해서는 피담보채권의 변제기가 도래하여야 한다(제320조 제1항). 그러나 환가를 위한 경매실행요건은 아니다.
- ① 동산, 부동산, 유가증권에 대하여 성립하며(제320조) 채무자의 소유물임을 요하지 않는다.
- ② 매매가 취소된 경우에 부당이득에 의한 매매대금상환청구권과 목적물의 반환의무 사이에서도 목적물과 채권과의 견련관계를 인정한다(제320조 제1항).
- ③ 채권은 목적물의 점유 중 또는 점유와 더불어 발생할 필요는 없다(대법원 1965.3.30. 64다1977).
- ⑤ 소송경제의 관점에서 채무의 변제와 상환으로 물건을 인도하라는 뜻의 판결을 하는 것이 타당하다고 한다(대법원 1969.11.25. 69다1592). 정답: ④

02 다음 담보물권의 특징 중 불가분성에 해당하는 것은?

- ① 피담보채권이 불성립하면 담보물권도 성립하지 않는다.
- ② 피담보채권이 전부의 변제가 있을 때까지 담보물권은 그 목적물의 전부의 위에 효력이 미친다.
- ③ 피담보채권의 일부가 변제되면 그 목적물의 일부도 담보물권의 구속에서 벗어난다.
- ④ 담보물권의 목적물이 어떤 이유로 교환가치를 현실화한 때에는 담보물권은 그 위에 미치게 된다.
- ⑤ 피담보채권이 이전하면 담보물권도 이전한다.

◎ 담보물권의 통유성

통 유 성	내 용
물상 대위성	- 목적물의 멸실, 훼손, 공용징수에 의하여 채무자가 받게 될 보험금, 손해배상금 보상금 위에 담보물권의 효력이 존속하는 성질이다. - 유치권에는 인정되지 않는다.
불가분성	- 담보물권자는 피담보물권의 전액을 변제받을 때까지 목적물 전부에 담보물권을 행사할 수 있다는 성질이다. - 공동저당은 불가분성의 예외가 된다.
타물권	- 담보물권이 타인의 물건 위에 설정될 수 있다는 성질이다. - 혼동의 예외로서 소유자저당권의 현상을 보이는 경우는 있다.
부종성	- 피담보채권과 담보물권은 법률적 운명을 같이한다는 성질이다. - 근저당은 부종성이 특히 완화된다.
수반성	피담보채권이 이전하면 담보물권도 당연히 이전된다는 성질을 말한다.

정답: ②

03 담보물권의 효력은 크게 유치적 효력과 우선변제적 효력으로 나눌 수 있다. 이 두 가지의 효력을 모두 가지는 담보물권은?

- [illegible]

해설

◎ 담보물권의 비교

내 용 \ 담보물권	유 치 권	질 권	저 당 권
성 립	일정한 요건이 성립하면 당연히 성립하는 법정담보물권	■ 설정계약+인도(양도) ■ 약정담보물권	■ 설정계약+등기 ■ 약정담보물권
목 적 물	동산, 부동산, 유가증권	동산, 권리	부동산, 권리
우선적 효력	없음(실질적 : 인정)	있음	있음
경 매 권	있음	있음	있음
유치적 효력	있음	있음	없음
수익적 효력	없음	없음	없음
간이변제충당권	법원의 허가를 얻어 행할 수 있음	유치권과 동일	없음
물상대위성	없음	있음	있음

정답: ④

04 다음 중 유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 주택건물의 신축공사를 한 수급인이 그 건물을 점유하고 있고, 또 건물에 관하여 생긴 공사금채권이 있다면 수급인은 그 채권을 변제받을 때까지 건물을 유치할 권리가 있다.
- ② 피담보채권과 목적물의 점유 사이의 견련관계는 요구되지 않는다는 것이 통설·판례의 태도이다.
- ③ 임차인은 보증금반환청구권으로서 임대인에게 임차물에 대한 유치권을 주장할 수 있다.
- ④ 타인의 건물을 불법으로 점유한 점유자는 그 건물에 대하여 지출한 유익비의 상환청구권에 기하여 그 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 임차인은 건물을 임차목적대로 사용치 못하여 발생한 손해배상청구권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다.

해설

- ③ 임차인의 임대인에 대한 보증금의 반환청구권으로서 임대인에 대한 유치권을 행사할 수 없다 (대법원 1960.9.29. 4292민상229).
- ① 대법원 1995.9.15. 95다16202
- ② 대법원 1965.3.30. 64다1977
- ④ 건물 점유자가 건물의 원시취득자에게 그 건물에 관한 유치권이 있다고 하더라도 그 건물의 존재와 점유가 토지소유자에게 불법행위가 되고 있다면 그 유치권으로 토지소유자에게 대항할 수 없다 (대법원 1989.2.14. 87다카3073).
- ⑤ 대법원 1976.5.11. 75다1305 정답: ③

05 담보물권이 가지는 특성(통유성) 중에서 유치권에 인정되는 것을 모두 고른 것은?

[2020' 공인중개사]

- | | | | |
|-------|-------|--------|---------|
| ㉠ 부종성 | ㉡ 수반성 | ㉢ 불가분성 | ㉤ 물상대위성 |
|-------|-------|--------|---------|

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉤
- ③ ㉢, ㉤
- ④ ㉠, ㉡, ㉢
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

해설

- ④ 유치권에는 물상대위성이 인정되지 않는다. 정답: ④

06 동시이행의 항변권과 유치권의 이동(異同)에 관한 다음 기술 중 옳은 것은?

- ① 동시이행의 항변권에 의하여 거절할 수 있는 급부에는 제한이 없으나, 유치권에 의하여 거절할 수 있는 것은 물건의 인도이다.
- ② 동시이행의 항변권이나 유치권에 있어서는 두 개의 채무가 대가관계에 있다는 점에서는 동일하다.
- ③ 동시이행의 항변권은 대세권(對世權)이나 유치권은 대인권(對人權)이다.
- ④ 양자는 서로 배척한다.
- ⑤ 양자 모두 채무자가 상당한 담보를 제공하고 그 소멸을 청구할 수 있다.

해설

◎ 유치권과 동시이행의 항변권의 비교

구 분	유 치 권	동시이행의 항변권
성 질	▪ 독립한 물건 ▪ 절대적 대세권	▪ 쌍무계약의 효력(작용) ▪ 상대적 대인권
대항력	있음	없음
목적	채권담보를 목적으로 함	일방당사자만이 선이행을 요구당함을 저지함이 목적
관계	대가적 관계 ×	대가적 관계 ○
대담보	타(他)담보를 제공하고 소멸시킬 수 있음	타(他)담보를 제공하고 소멸시킬 수 없음
경매권	있음	없음

※ 공평의 원리에 입각하여 인정된 것이며 양자는 서로 배척하지 않고 병존할 수 있다. 정답: ①

07 유치권에 관한 기술 중 옳은 것은?

- ① 유치권자가 보존의 필요로 유치물을 사용하더라도 불법행위가 된다.
- ② 유치권자는 유치물의 보전에 필요한 사용은 할 수 있으나 그 사용으로 인하여 얻은 이익은 부당이득으로서 반환하여야 한다.
- ③ 도인(盜人)이라도 도품에 필요한 지출을 하였을 때에는 그 비용상환시까지 도품을 유치할 수 있다.
- ④ 유치권자가 유치물의 보전에 필요한 사용을 하는 것은 적법하므로 소유자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상책임이나 부당이득반환의무가 생기지 않는다.
- ⑤ 채권과 목적물의 점유와의 사이에 견련관계도 요구된다는 것이 통설·판례이다.

해설

- ① ② ④ 유치권자는 유치물의 보전에 필요한 사용은 할 수 있으나 그 사용으로 인하여 얻은 이익은 부당이득으로 반환하여야 한다.
- ③ 채권자의 점유가 불법행위 및 권원없이 이루어진 경우 그 물건에 관하여 필요비·유익비를 지출하더라도 유치권은 성립하지 못한다.
- ⑤ 피담보채권과 목적물의 '점유' 사이의 견련관계는 요구되지 않는다고 봄이 통설·판례이다.

정답: ②

08

유치권에 관한 다음 기술 중 잘못된 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 임차인은 임대인에 대한 보증금반환채권을 피담보채권으로 하여 임차물에 대한 유치권을 행사할 수 없다.
- ② 유치권자가 보관하기 위해 유치물건을 사용하였을 경우에는 임차료에 상당하는 이익을 반환하여야 한다.
- ③ 채권의 발생원인이 불법행위에 기한 경우에도 유치권은 성립하지만 특정물의 점유가 불법행위로 인한 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.
- ④ 유치권자로부터 점유를 승계한 자가 유치권자를 대위하여 유치권을 주장할 수 있다.
- ⑤ 수급인의 재료와 노력으로 지어진 건물에 해당하는 기성부분은 수급인의 소유라 할 것이므로 수급인은 공사대금을 지급받을 때까지 이에 대하여 유치권을 가질 수 없다.

해설

- ④ 유치권자는 점유를 상실하면 곧 유치권을 상실하므로 점유를 승계한 자도 유치권자의 유치권을 대위할 수 없다(대법원 1972.5.30. 72다548).
- ③ 유치권은 채권의 발생원인과 종류에 제한이 없으므로 불법행위에 의해 채권이 발생하는 경우에도 유치권이 성립한다.
단, 불법행위로 인한 점유인 경우 유치권이 성립하지 않는다(제320조 제2항).
- ⑤ 유치권은 타물권인 점에 비추어 볼 때 수급인의 재료와 노력으로 지었고 독립한 건물에 해당하는 기성부분은 수급인의 소유라 할 것이므로 수급인은 이에 대해 유치권을 가질 수 없다(대법원 1993. 3.26. 91다14116).
단, 건물의 신축공사를 한 수급인이 그 건물을 점유하고 있고 또 그 건물에 대하여 생긴 공사금 채권이 있다면 수급인은 그 채권을 변제받을 때까지 건물을 유치할 권리가 있다(대법원 1995.9.15. 95다16219). 정답: ④

제6장
기본문제

09

유치권 성립을 위한 건련관계가 인정되는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 공인중개사]

- ㉠ 임대인과 임차인 사이에 건물명도시 권리금을 반환하기로 약정을 한 때, 권리금반환청구권을 가지고 건물에 대한 유치권을 주장하는 경우
- ㉡ 건물의 임대차에서 임차인의 임차보증금 반환청구권으로서 임차인이 그 건물에 유치권을 주장하는 경우
- ㉢ 가축이 타인의 농작물을 먹어 발생한 손해에 관한 배상청구권에 기해 그 타인이 그 가축에 대한 유치권을 주장하는 경우

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉢
- ④ ㉠, ㉡
- ⑤ ㉡, ㉢

해설

- ③ 임차보증금반환채권이나 권리금반환채권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 유치권의 성립요건인 '채권과 목적물의 건련성'에 해당하지 아니한다. 정답: ③

10 질권과 저당권의 비교 설명이다. 틀린 것은?

- ① 양자 모두 목적물을 경매하여 우선변제를 받는다.
- ② 양자 모두 낙성계약에 의하여 성립한다.
- ③ 질권은 사용가치와 교환가치를 지배하고 저당권은 교환가치만을 지배한다.
- ④ 질권과 저당권의 차이는 목적물의 점유 여부에 중점이 있다.
- ⑤ 저당권보다 질권이 담보설정자의 심리압박이 심하다.

해설

사 항		질 권	저 당 권
본 질		목적물의 점유가 질권자에게 이전	목적물의 점유가 저당권설정자에게 그대로 남음
기 능		서민의 금융수단	투자의 수단
성립	설정계약	설정계약+목적물인도	설정계약+등기
	객 체	동산, 권리(주식, 채권)	부동산, 권리(지상권, 전세권)
	선의취득	성립 가능	성립 불능
효력	유치력	있음	없음
	우선변제권	있음	있음
	사용수익권	보존의 범위 내에서 가능	없음
	유질, 유저당	금지	인정
	과실에 대한 효력	효력이 미침	효력이 미치지 않음

③ 양자 모두 목적물의 교환가치만을 지배한다. 정답: ③

11 다음 중 틀린 것은?

- ① 원질권이 소멸하면 항상 전질권도 소멸한다.
- ② 유치권은 독립하여 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ③ 창고증권의 입질은 권리질권을 성립케 한다.
- ④ 저당물의 소유권을 취득한 제3자도 경매인이 될 수 있다.
- ⑤ 저당권이 국세징수권에 우선하는 경우도 있다.

해설

◎ 책임전질과 승낙전질의 비교

구 분	책 임 전 질	승 낙 전 질
성 질	- 채권, 질권공동입질설(다수설) - 질물재입질설(소수설)	질물재입질설(통설)
요 건	- 원질권자와 전질권자 사이에 합의와 질물의 인도가 있을 것 - 원질권의 범위 내의 계약일 것 → 피담보채권, 변제기 등 - 채권양도의 대항요건(통지, 승낙)을 갖추지 않으면 전질로써 채무자, 보증인, 질권설정자 등에게 대항하지 못함.	- 질물소유자의 승낙이 있을 것 - 원질권의 범위에 의한 제한을 받지 않음. → 피담보채권액을 초과하여도 유효 → 변제기의 제한도 받지 않음. - 채무자에의 통지를 요하지 않음.
효 과	- 전질하지 않았더라면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여도 책임을 면할 수 없음. - 원질권자는 질권을 소멸하게 하는 행위를 행하지 못함. → 질권포기, 채무면제 등의 행위를 할 수 없음. - 전질권자는 자기 채권의 변제를 받을 때까지 질물을 유치할 수 있음. - 원질권, 전질권이 모두 변제기에 있어야 전질권자는 실행할 수 있음. - 원질권이 소멸하면 전질권도 소멸	- 불가항력으로 인한 손해배상책임을 부담하지 않음. - 원질권이 소멸하더라도 전질권은 소멸하지 않음.

- ① 승낙전질은 원질권이 소멸하더라도 전질권은 소멸하지 않는다. 정답: ①

12 유치권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 유치권은 법정담보물권이나 당사자의 특약에 의해 그 발생을 배제할 수 있다.
- ② 피담보채권이 발생한 이후에 물건의 점유를 취득한 경우에도 유치권은 성립할 수 있다.
- ③ 채권자와 채무자가 목적물을 공동으로 점유하는 경우에도 채권자는 목적물에 관한 유치권을 갖는다.
- ④ 임차인이 임대인과의 약정에 따라 계약 종료시에 권리금반환청구권을 갖기로 한 경우 임차인은 변제기가 도래하는 한 임차목적물의 양수인에 대해서도 유치권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 유치권자가 채무자의 승낙없이 목적물을 제3자에게 담보로 제공한 경우 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

해설

- ④ 임차인이 유치권을 행사할 수 있는 경우는 비용상환청구권에 기해서 유치권을 행사할 수 있는 경우이다. 보증금반환청구권이나 권리금반환청구권은 임차물건에 관해서 생긴 채권이 아니기 때문에 유치권에 의해서 담보되는 채권이 아니다.
- ① 유치권은 법정담보물권이므로 당사자의 합의에 의하여 설정하지는 못한다. 다만 당사자 사이에서 유치권 배제의 특약을 할 수는 있다.
- ⑤ 유치권소멸청구권(제327조) 정답: ④

13 저당권에 관한 다음 기술 중 틀린 것은? (견해의 대립시 판례에 의함)

- ① 근저당권 설정계약상의 채무자가 아닌 제3자를 채무자로 하여 경료된 근저당권설정등기는 근저당권의 부종성에 비추어 무효인 등기이다.
- ② 1번 저당권의 피담보채권이 소멸하면 저당권도 역시 소멸하고, 2번 저당권은 1번 저당권으로 그 순위가 올라간다.
- ③ 설정행위 또는 채무의 변제기 전의 계약으로써 목적물의 소유권을 저당권자에게 취득시킬 것을 약정하는 이른바 유저당계약은 일반적으로 허용된다고 본다.
- ④ 저당권에도 물상대위성이 있으므로 저당목적물의 매각으로 인한 매매대금에도 저당권의 효력이 미친다.
- ⑤ 토지를 목적으로 저당권을 설정한 자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있으나, 그 건물의 경매대금로부터는 우선변제를 받을 수 없다.

해설

- ④ 저당권에도 물상대위성이 있으므로 저당목적물의 멸실·훼손·공용징수로 인하여 저당권설정자가 받을 금전 기타의 물건에 저당권의 효력이 미친다. 그러나 매매대금 등에는 저당권의 추급력으로 인해 물상대위성이 인정되지 않는다. 정답: ④

① 이 자 ② 원 본 ③ 저당물의 관리비용
④ 저당권의 실행비용 ⑤ 변제기 이후 1년분의 지연배상

◎ 피담보채권의 범위

- (1) 원 본
- (2) 이 자
 - 변제기 이전의 이자는 무제한으로 담보
- (3) 채무불이행으로 인한 손해배상
 - 지연배상은 원본의 이행기일 경과 후의 1년분에 한함
- (4) 위약금
 - 등기한 경우에 저당권에 의하여 담보
- (5) 저당권실행비용
 - 부동산감정평가비용, 경매신청등록세 등의 비용 정답: ㉓

- ① 저당목적물의 소유자가 채납하고 있는 국세는 그 법정기일 전에 설정된 저당채권에 우선해서 징수하지 못한다.
- ② 저당권설정자의 책임 없는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에도 저당권자는 저당권설정자에 대하여 그 원상회복을 청구할 수 있다.
- ③ 토지임대인이 변제기를 경과한 최후 2년의 차임채권에 의하여 그 지상에 있는 임차인 소유의 건물을 압류한 때에는 저당권과 동일한 효력이 있다.
- ④ 민법은 저당권의 실행이 착수되어 목적부동산에 대한 압류가 있은 후에는 설정자가 그 부동산으로부터 수취하였거나 수취할 수 있는 과실에도 저당권의 효력이 미친다고 규정하고 있다.
- ⑤ 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권 또는 토지임차권을 설정하고 그 건물에 대한 저당권이 실행되면 지상권 또는 토지임차권은 건물소유권과 함께 매수인(경락인)에게 이전된다고 한다.

② 저장권설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저장물의 가액이 현저히 감소한 때에 저장권자에게 담보 물보충청구권이 인정된다(제362조).

① 국세기본법 제35조 제1항 제3호

③ 제649조

④ 제359조

⑤ 대법원 1993.4.13. 92다24950 정답: ②

16 저당권에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 근저당에 있어서 피담보채권이 확정되면 그 이후에 발생하는 채권은 그 근저당에 의하여 담보되지 못한다.
- ② 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 2년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다.
- ③ 이자채권은 저당권에 의하여 무제한으로 담보된다.
- ④ 근저당에 있어서 담보할 채권의 최고액은 이를 반드시 등기하여야 한다.
- ⑤ 제3자가 취득시효로 저당목적물에 대한 소유권을 취득하는 경우에는 저당권은 소멸한다.

해설

- ② 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다 (제360조 단서).
- ③ 저당권의 효력이 미치는 이자의 범위에 대하여는 제한이 없으므로 이자채권은 저당권에 의하여 제한으로 담보된다.
- ⑤ 취득시효로 인한 권리의 취득은 원시취득이다. 따라서 원(原)권리자의 권리위에 존재하였던 모든 제한은 시효취득완성의 효과로 소멸한다. 정답: ②

17 저당권에 관한 다음의 기술 중 옳은 것은?

- ① 저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미치지만 당사자가 저당권설정계약에 의하여 저당권의 효력이 부합물이나 종물에 미치지 않는 것으로 할 수 있다.
- ② 저당권의 효력은 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취할 수 있는 과실 위에도 미친다.
- ③ 저당권의 효력은 저당부동산의 매각대금 위에도 미친다.
- ④ 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도할 수 있다.
- ⑤ 지상권을 목적으로 하여 저당권을 설정할 수 없다.

해설

◎ 저당권의 효력이 미치는 목적물 범위

- (1) 저당권의 효력은 저당부동산에 부합된 부합물과 종물에도 미친다.
- (2) 토지와 건물은 별개의 부동산이므로 저당목적 토지 위의 건물에는 저당권의 효력이 미치지 않는다.
→ 설정자가 그 저당토지 위에 건물을 축조한 경우에는 토지와 함께 건물에 대해서도 경매를 청구할 수 있으나 건물의 경락대금으로부터는 우선변제를 받지 못한다.
최근 판례는 저당지상의 건물에 대한 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정 받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다고 판시하여 예외를 인정하고 있다(대법원 2003.4.11. 2003다3850).
- (3) 과실에는 저당권의 효력이 미치지 않으나 저당권의 실행으로 목적물에 대한 압류가 있는 후에는 설정자가 수취하는 과실 또는 수취할 수 있는 과실에도 저당권의 효력이 미친다.
- (4) 저당권에도 물상대위성이 있으므로 저당목적물의 멸실, 훼손, 공용징수로 인하여 저당권설정자가 받을 금전 기타의 물건에 저당권의 효력이 미친다. 정답: ①

18

乙명의의 저당권이 설정되어 있는 甲소유의 X토지위에 Y건물이 신축된 후, 乙의 저당권이 실행된 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ㉠ 甲이 Y건물을 신축한 경우, 乙은 Y건물에 대한 경매도 함께 신청할 수 있으나 Y건물의 경매대가에서 우선변제를 받을 수는 없다.
- ㉡ Y건물을 甲이 건축하였으나 경매 당시 제3자 소유로 된 경우, 乙은 Y건물에 대한 경매도 함께 신청할 수 있다.
- ㉢ Y건물이 X토지의 지상권자인 丙에 의해 건축되었다가 甲이 Y건물의 소유권을 취득하였다면 乙은 Y건물에 대한 경매도 함께 신청할 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ③ 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다(대법원 2003.04.11. 2003다3850). 정답: ③

19

민법 제365조의 일괄경매청구권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ㉠ 토지에 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조하여 저당권자가 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구하는 경우, 저당권자는 그 건물의 경매대가에 대해서도 우선변제를 받을 권리가 있다.
- ㉡ 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우, 저당권자는 토지와 건물을 일괄하여 경매를 청구할 수 있다.
- ㉢ 토지에 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 축조한 건물의 소유권이 제3자에게 이전된 경우, 저당권자는 토지와 건물을 일괄하여 경매를 청구할 수 없다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

- ㉠ 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다. 그러나 그 건물의 경매대가에 대하여는 우선변제를 받을 권리가 없다(제365조).
- ㉡㉢ 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다(대법원 2003.04.11. 2003다3850). 정답: ④

제6장
기본문제

20

甲은 乙소유의 X토지에 저당권을 취득하였다. X토지에 Y건물이 존재할 때, 甲이 X토지와 Y건물에 대해 일괄경매를 청구할 수 있는 경우를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 공인중개사]

- ㉠ 甲이 저당권을 취득하기 전, 이미 X토지 위에 乙의 Y건물이 존재한 경우
- ㉡ 甲이 저당권을 취득한 후, 乙이 X토지 위에 Y건물을 축조하여 소유하고 있는 경우
- ㉢ 甲이 저당권을 취득한 후, 丙이 X토지에 지상권을 취득하여 Y건물을 축조하고 乙이 그 건물의 소유권을 취득한 경우

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

해설

㉠㉢ 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다(대법원 2003.04.11. 2003다3850). 정답: ④

21

저당권의 효력이 미치는 목적물의 범위에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 토지상의 저당권은 그 토지 위의 농작물에 대하여는 그 효력이 미치지 않는다.
- ② 토지임차권이 있는 건물에 대해 저당권을 실행한 경우에는 그 토지임차권도 경락인에게 이전된다.
- ③ 저당권의 효력은 저당부동산에 대한 압류가 있는 후에는 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 미친다.
- ④ 임야를 저당권의 목적으로 하였는데 그 임야상의 수목이 벌채되어 반출된 경우에는 저당권의 효력은 그에 미치지 못한다.
- ⑤ 토지상의 저당권은 그 설정자가 후에 그 토지에 건물을 축조하더라도 그 건물에는 그 효력이 미치지 않고 따라서 그 건물에 대해 경매를 청구할 수는 없다.

해설

◎ 저당권의 효력이 미치는 범위

피담보채권의 범위	▪ 원본 ▪ 이자(변제기 이전의 이자는 제한 없이 담보된다) ▪ 채무불이행으로 인한 손해배상(지연배상·지연이자) 지연배상은 원본의 이행기일 경과 후의 1년분에 한하여 담보된다(후순위권리자, 제3취득자를 보호하기 위한 규정). ▪ 위약금(등기한 경우에 저당권에 의하여 담보된다) ▪ 저당권실행비용(감정평가비용, 경매신청등록세 등의 비용) 피담보채권에 포함되는지에 대하여 명문은 없으나 인정된다는 것에 이설이 없다.
-----------	---

목적물의 범위	▪ 저당권의 효력은 저당부동산에 부합(저당권의 설정전후를 불문)된 부합물과 종물에도 미친다. 예외적으로 설정계약에서 반대의 특약을 한 경우와 지상권자, 전세권자 등이 부합한 물건에는 미치지 않는다. ▪ 토지와 건물은 별개의 부동산이므로 저당목적 토지 위의 건물에는 저당권의 효력이 미치지 않는다. 단, 설정자가 그 저당토지 위에 건물을 축조한 경우에는 토지와 함께 건물에 대해서도 경매를 청구할 수 있으나 건물의 경락대금으로부터는 우선변제를 받지 못한다. ▪ 과실에는 저당권의 효력이 미치지 않으나 저당권의 실행으로 목적물에 대한 압류가 있는 후에는 설정자가 수취하는 과실 또는 수취할 수 있는 과실에도 저당권의 효력이 미친다. ▪ 저당권에도 물상대위성이 있으므로 저당목적물의 멸실, 훼손, 공용정수로 인하여 저당권설정자가 받을 금전 기타의 물건에 저당권의 효력이 미친다.
---------	---

정답: ⑤

22 저당권의 효력에 관한 다음 기술 중 옳지 않은 것은? (건해의 대립시 판례에 의함)

- ① 저당권의 목적물로 되어 있는 건물이 증축된 때, 증축부분이 구분소유권으로서 독립된 건물로 인정되지 않는 한 저당권의 효력은 증축부분에도 미친다.
- ② 전유부분에 대한 저당권 또는 경매개시결정과 압류의 효력은 당연히 종물 내지 종된 권리인 대지사용권에까지 미친다.
- ③ 저당권의 효력은 저당설정 당시에 이미 부합된 물건에만 미치고, 설정 후에 부합한 것에는 미치지 않는다.
- ④ 피담보채권이 소멸하여 무효인 저당권등기가 말소되지 않고 그대로 남아있는 경우에, 당사자 사이의 계약으로 이 무효로 된 등기를 다른 저당권을 위한 등기로 유용하여도 유효하다.
- ⑤ 구분건물의 전유부분에 설정된 저당권의 효력은 특별한 사정이 없는 한 그 전유부분의 소유자가 나중에 취득한 대지사용권에까지 미친다.

제6장
기본문제

해설

- ③ 저당권설정 당시에 이미 부합되어 있는 것이든 그 후에 부합된 것이든 이를 묻지 않고 저당권의 효력이 미친다. 건물이 증·개축, 대수선이 된 경우 동일성이 인정되는 한 현존건물 전체에 대하여 저당권이 효력이 미친다(대법원 1992.1.8. 92다2672).
- ① 제358조 본문, 토지에 대한 수목이나 건물에 대한 증축부분, 부속건물 등은 부합물의 예이다. 하나의 저당 등기부상의 부속건물은 특단의 사정이 없는 한 주된 건물과 일체를 이루는 하나의 건물로 보아 주된 건물에 관한 저당권은 부속건물에 관하여도 그 효력이 미친다. 건물에 증축된 부분에 관하여도 저당권설정 당시의 저당목적 건물과 동일성이 있는 한 저당권의 효력이 미친다고 할 것이다(대법원 1992.1.8. 92다2672).
- ② 집합건물 구분소유자의 대지사용권은 전유부분과 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 전유부분과 종속적 일체불가분성이 인정되므로, 구분건물의 전유부분에 대한 저당권 또는 경매개시결정과 압류의 효력은 당연히 종물 내지 종된 권리인 대지사용권에까지 미치고, 그에 터잡아 진행된 경매절차에서 전유부분을 경락받은 자는 그 대지사용권도 함께 취득한다(대법원 2008.03.13. 2005다15048).
- ④ 무효등기의 유용이라 함은 등기원인의 부존재, 무효, 취소, 해제로 인하여 말소되어야 할 무효인 등기가 말소되지 않고 있다가 후에 이에 상응하는 등기원인이 발생한 경우 이 무효인 등기를 유효한 등기로 취

급하여 그 등기원인의 적법한 공시방법으로 하는 것을 말한다. 무효인 저당권설정등기의 유효의 합의(순수한 등기법상의 합의이다)에 관해서는 이해관계인의 부존재를 요건으로 한다(대법원 1970.12.24. 70다1630).

⑤ 대법원 2001.2.9. 2000다62179 정답: ③

23 저당목적물에 대한 침해에 관한 다음 설명 가운데 틀린 것은?

- ① 침해가 있더라도 목적물의 잔존가치가 피담보채권을 충분히 만족시킬 수 있는 경우에는 저당권자의 침해자에 대한 손해배상청구권이 성립하지 않는다.
- ② 저당목적물에 대한 침해가 저당권설정자의 책임 있는 사유로 이루어진 경우에만 저당권자는 저당권설정자에 대해 담보물보충청구권을 가진다.
- ③ 저당목적물에 대한 침해가 채무자에 의해 이루어진 경우에는 저당권자는 채무자에 대해 즉시변제를 청구할 수 있다.
- ④ 저당권자가 채무자에 대해 즉시변제를 청구한 경우에는 담보물보충청구권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 저당권자가 채무자에 대해 즉시변제를 청구함과 동시에 손해배상을 청구할 수는 없다.

해설

⑤ 즉시변제청구권과 손해배상청구권은 병존할 수 있다. 정답: ⑤

24 저당권에 관한 다음 설명 중 옳은 것은? (견해의 대립시 판례에 의함)

- ① 저당권의 목적물인 산림상의 수목이 통상의 용법을 넘어 무단으로 벌채된 경우에도 산림의 저당권자는 수목의 반출금지를 청구할 수 없다.
- ② 저당권의 효력은 저당목적물에 대한 압류가 있기 전이라도 저당권설정 후에 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있었던 과실에 미치는 것이 원칙이다.
- ③ 제3자가 저당목적물을 훼손한 경우, 잔존가격이 피담보채권의 담보로서 충분해도 저당권자는 불법행위로서 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 채무자가 저당목적물인 부동산을 훼손한 경우, 저당권자는 피담보채권의 변제기 전이라도 저당권을 실행할 수 있다.
- ⑤ 토지에 설정된 저당권은 그 토지의 지상권자가 심은 입목에도 미친다.

해설

- ① 저당권은 물권이므로 물권적 청구권으로서의 방해제거 또는 예방을 청구할 수 있다. 따라서 부합물이나 종물이 부당하게 분리된 경우에 이의 반출금지를 청구할 수 있다.
- ② 저당권의 효력은 저당권실행 전에는 원칙적으로 천연과실에 효력이 미치지 않으나, 실행에 착수하여 부동산 압류 후에는 설정자가 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 대하여 저당권의 효력이 미친다(제359조).
- ③ 저당목적물의 침해로 저당권자가 채권의 만족을 얻을 수 없는 경우에는 그 침해자에 대하여 불법행위를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 그 침해가 있더라도 채권의 만족을 얻는 데 지장이 없는 경우에는 불법행위는 성립하지 않는다.
- ⑤ 토지에 설정된 저당권의 효력은 입목에 미치지 않는다. 정답: ④

25 근저당에 관하여 틀린 것은?

- ① 채권의 이자는 최고액 중에 산입하지 않는다.
- ② 최고액을 초과한 부분은 담보되지 않는다.
- ③ 채권최고액, 채무자, 근저당이라는 취지 등을 설정등기에 명시하여야 한다.
- ④ 근저당권에 있어서 확정된 피담보채권액이 최고액을 초과하는 경우 근저당권자는 채무자겸 근저당권설정자에 대하여 그 채권전액의 변제를 받을 때까지 근저당권의 효력을 주장할 수 있다.
- ⑤ 장래의 증감 변동하는 불특정다수의 채권을 담보하는 것을 내용으로 하며, 채권의 확정을 장래에 유보한다.

해설

◎ 근저당

의의와 성질	▪ 계속적인 거래관계로부터 생기는 불특정다수의 채무를 장래의 결산기에 있어서 일정한 한도액(최고액)까지 담보하기 위하여 현재에 설정하는 저당권(제357조) ▪ 장래의 증감 변동하는 불특정다수의 채권을 담보 ▪ 피담보채권이 영이 되거나, 일시적으로 감소하여도 저당권의 효력에는 영향을 미치지 않음(부종성이 특히 완화).
근저당의 설정	▪ 설정계약과 등기로써 성립 → 등기에는 근저당이라는 뜻과 최고액을 반드시 명시
근저당의 처분	▪ 근저당권자와 양수인 및 채무자의 3면계약으로 양도 가능 → 이전등기를 요함.
근저당의 효력	▪ 증감 변동하는 채권의 결산기에 있어서의 총화를 일정한 최고액까지 담보 ▪ 이자는 최고액 중에 산입된 것으로 다름. ▪ '원본+이자 = 총액 > 최고액'인 경우 초과부분은 담보되지 않음.

정답: ①

제6장
기본문제

26 다음은 근저당권에 관한 설명이다. 틀린 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 저당권의 채권최고액에 산입되는 이자에는 지연이자도 포함하는데 이 이자는 이행기 후의 1년분에 한하지 않는다.
- ② 채무의 총액이 근저당권의 채권최고액을 초과한 경우에도, 근저당부동산을 매수한 제3취득자는 그 채권최고액만을 변제하고 근저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ③ 근저당권자나 후순위 근저당권자가 경매를 신청하면 경매 신청시에 근저당권의 피담보채무의 범위가 확정된다.
- ④ 확정된 피담보채무액이 근저당권 최고액을 초과하는 경우, 채무자가 근저당권설정자인 때는 최고액을 넘는 실제의 피담보채무 전액을 변제하여야 근저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ⑤ 근저당권의 성립 당시 근저당권의 피담보채권을 성립시키는 법률행위가 있었는지 여부에 대한 증명책임은 그 존재를 주장하는 측에 있다.

해설

- ③ 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우에는 경매 신청시에 근저당권의 피담보채권액이 확정되고, 그 이후부터 근저당권은 부종성을 가지게 되어 보통의 저당권과 같은 취급을 받게 된다(대법원 1998.10.27. 97다26104). 그러나 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우, 선순위 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 경락인이 경락대금을 완납한 때에 확정된다고 보아야 한다(대법원 1999.9.21. 99다26085).

① 제357조 제2항

② 대법원 1974.12.10. 74다998

④ 대법원 1992.5.26. 92다1896

- ⑤ 근저당권은 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고, 채무의 확정을 장래에 보류하여 설정하는 저당권으로서, 계속적인 거래관계로부터 발생하는 다수의 불특정채권을 장래의 결산기에서 일정한 한도까지 담보하기 위한 목적으로 설정되는 담보권이므로, 근저당권설정행위와는 별도로 근저당권의 피담보채권을 성립시키는 법률행위가 있어야 하고, 근저당권의 성립 당시 근저당권의 피담보채권을 성립시키는 법률행위가 있었는지 여부에 대한 증명책임은 그 존재를 주장하는 측에 있다(대법원법원 2011.04.28. 2010다107408). 정답: ③

27 공동저당과 근저당에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 공동저당에 있어서는 목적물의 수만큼의 저당권이 성립한다.
② 근저당권의 존속기간에 관한 등기가 없더라도 등기가 무효인 것은 아니다.
③ 피담보채권액의 확정은 근저당권을 실행하기 위한 필수요건은 아니다.
④ 근저당의 경우에도 공동저당이 가능하다.
⑤ 공동저당에 있어서 채무자 소유 부동산 위의 후순위 저당권자의 대위권이 물상보증인 소유의 부동산까지 미치지 않는다.

해설

- ③ 근저당권을 실행하여 피담보채권의 우선변제를 받기 위해서는 채권액이 확정되어야 한다. 피담보채권액의 확정 없이는 근저당권을 실행할 수 없다.

① 공동저당은 복수의 부동산 위에 1개의 저당권이 있는 것이 아니라, 1물1권주의의 원칙상 각 부동산마다 저당권이 성립하되 다만 이들 저당권이 피담보채권을 공통으로 하는 것이다.

② 근저당권의 존속기간은 임의적 기재사항이다(부동산등기법 제140조).

- ⑤ 공동저당의 목적인 채무자 소유의 부동산과 물상보증인 소유의 부동산 중 채무자 소유의 부동산에 대하여 먼저 경매가 이루어져 1번 공동저당권자가 변제를 받은 경우, 채무자소유의 부동산에 대한 후순위저당권자는 민법 제368조 제2항 후단에 의하여 1번 공동저당권자를 대위하여 물상보증인 소유의 부동산에 대하여 저당권을 행사할 수 없다(대법원 1995.6.13. 95마500). 정답: ③

28 다음 중 공동저당을 바르게 말한 것은?

- ① 동일채권의 담보를 위하여 수 개의 부동산에 설정된 저당권을 말한다.
- ② 공유부동산 위에 설정된 저당권을 말한다.
- ③ 수 개의 채권을 담보하기 위하여 1개의 부동산에 설정된 저당권을 말한다.
- ④ 저당권을 수인이 공유한 것을 말한다.
- ⑤ 물상보증인이 제공하는 부동산에 설정된 저당권을 말한다.

해설

◎ 공동저당

의 의	동일한 채권담보를 위하여 여러 개의 부동산 위에 설정되는 저당권 → 불가분성의 예외가 되며, 일명 총괄저당이라고 한다.
실 행	- 후순위저당권자와의 관계 ㉠ 동시배당 : 공동저당권의 목적물을 전부 경매하여 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매대가에 비례하여 피담보채권을 분담(제368조 제1항) ㉡ 순차(이시)배당 : 공동저당의 목적물 중 일부만이 경매되어 그 대가를 먼저 배당하는 때에는 공동저당권자는 전액변제를 받을 수 있으나, 그 부동산의 후순위저당권자는 선순위저당권자가 동시 배당하였더라면 다른 부동산의 경매대가에서 변제받을 수 있었던 한도에서 선순위를 대위하여 저당권을 행사할 수 있음(제368조 제2항).

정답: ①

29 비전형담보에 관한 다음 설명이다. 다음 중 가장 타당하지 않은 설명은?

- ① 배당참가를 하는 경우에는 가등기담보권자는 가등기인 채로 그 가등기의 순위로서 다른 채권자보다 우선순위를 주장할 수 있다.
- ② 담보가등기가 경료된 부동산에 대하여 경매 등이 행하여진 때에는 담보가등기권리는 그 부동산의 매각에 의하여 소멸한다.
- ③ 양도담보의 목적물을 제3자가 불법점유하거나 기타 불법한 침해를 하고 있는 경우에 양도 담보권자와 설정자 쌍방은 모두 제3자에 대한 반환청구 내지 방해배제청구권을 가진다.
- ④ 양도담보의 실행시 청산금의 평가 결과 청산금이 없는 것으로 인정되는 경우라도 상대방에게 그 뜻을 담은 통지를 하여야 한다.
- ⑤ 판례는 소비대차이외의 사유로 생긴 채권도 가등기담보의 피담보채권이 된다고 한다.

해설

⑤ 대법원 2002.12.24. 2002다50484

- ①② 가등기담보권이 경료된 부동산에 대하여 경매가 개시된 경우에는 가등기담보권자는 다른 채권자보다 자기채권에 대하여 우선변제를 받을 권리가 있다. 이 경우 그 순위에 관하여는 가등기담보권을 저당권으로 보고 그 가등기가 경료된 때에 저당권의 설정등기가 경료된 것으로 본다(가등기담보에 관한 법률 제13조). 그리고 이 때 가등기담보권은 부동산의 매각에 의하여 소멸한다(동법 제15조).

- ③ 담보물권설의 주장이다. 즉, 양도담보권자는 그의 양도담보권에 기하여, 설정자는 그의 소유권에 기하여 물건적 청구권을 행사할 수 있다고 한다. 한편 목적물을 점유하는 자는 점유권에 기한 물건적 청구권도 행사할 수 있다고 한다. 신탁적 소유권이전설에 의하면, 양도담보권자는 소유권에 기한 물건적 청구권을, 설정자는 그 목적물을 점유하는 경우에 한하여 점유권에 기한 점유보호 청구권을 행사할 수 있다.
- ④ 채권자는 담보계약에 의한 담보권을 실행하여 그 담보목적 부동산의 소유권을 취득하기 위해서는 그 채권의 변제기 후에 청산금의 평가액을 채무자 등에게 통지하고(동법 제2조 제2항 제2호) 그 통지가 채무자 등에게 도달한 날로부터 2월(청산기간)이 경과하여야 한다. 이 경우 청산금이 없다고 인정되는 때에는 그 뜻을 통지하여야 한다(동법 제3조 제1항, 제4조 제1항 후단). 정답: ⑤

30 다음은 가등기담보에 관한 기술이다. 옳지 못한 것은?

- ① 매매대금의 지급을 담보하기 위하여 부동산의 소유권을 이전하는 경우 '가등기담보법'이 적용된다.
- ② 가등기담보도 담보권의 일종이므로, 피담보채권이 소멸하면 가등기담보도 당연히 소멸한다.
- ③ 가등기담보에도 그 성질상 물상대위성이 인정된다.
- ④ 장래의 증감 변동하는 일단의 불특정채권을 일정한 한도까지 담보하는 이른바 근가등기 담보의 설정도 가능하다.
- ⑤ 담보가등기가 경료된 부동산에 대하여 경매 등이 행하여진 때에는 담보가등기권리는 그 부동산의 매각에 의하여 소멸한다.

해설

- ②③④ 가등기담보권도 담보물권의 통유성(부종성, 수반성, 불가분성, 물상대위성)을 가진다.
- ⑤ 동법 제15조 정답: ①

31 가등기담보권자가 권리취득에 의한 실행을 하는 경우에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 채권자가 채권의 변제기 후에 청산금의 평가액을 채무자 등에게 통지하여야 한다.
- ② 2개월의 청산기간이 경과하여야 한다.
- ③ 채권자가 청산금을 지급하여야 하나 그가 청산금을 청산기간이 만료되기 전에 지급하더라도 후순위권리자에게 대항할 수 있다.
- ④ 가등기담보권 실행통지에는 통지 당시의 목적부동산의 평가액과 피담보채권액을 명시하여야 한다.
- ⑤ 담보가등기 후에 등기된 저당권자도 청산금 청구권자에 속한다.

해설

◎ 권리취득에 의한 실행

‘실행통지 → 청산 → 소유권취득’의 단계로서 실행된다.

(1) 실행통지

- ① 실행통지사항은 목적부동산의 평가액과 피담보채권액이다.
- ② 통지의 상대방은 채무자 등(채무자, 물상보증인, 제3취득자)이다.
- ③ 통지시기는 피담보채권의 변제기 이후이다.

(2) 청 산

- ① 청산시기(청산시기는 청산기간이 만료한 이후)가 도래하면 채무자 등에게 청산금을 지급하여야 한다.
- ② 청산금 = 실행통지 당시의 목적물가액 - (피담보채권액 + 선순위담보권자의 채권액 + 주택(상가)임대차보호법상의 보험금 중의 일정액)
- ③ 청산기간은 실행통지가 채무자 등에게 도달된 날로부터 2월이다.
- ④ 청산기간 경과 전의 무청산특약(청산금지급면제특약)은 강행규정위반으로서 당연히 무효이다.
- ⑤ 청산은 귀속청산방법(채권자가 본등기를 함과 동시에 청산금을 지급하는 방법 : 동시이행의 관계)에 의한다.
- ⑥ 청산금청구권자는 채무자 등(채무자, 물상보증인, 제3취득자, 후순위담보권자, 가등기 이후의 대항력 있는 임차인)이다.
- ⑦ 후순위당권자는 청산금의 평가액에 불만이 있는 때에는 청산기간 내에 자기 채권의 변제기가 도래하고 있지 않더라도 경매를 청구할 수 있다.
- ⑧ 지급할 청산금이 없는 경우에도 반드시 청산기간이 경과하여야 본등기청구권을 행사할 수 있다.

정답: ③

32 권리질권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 채권을 질권의 목적으로 하는 경우에 채권증서가 있는 때에는 질권의 설정은 그 증서를 질권자에게 배서와 교부함으로써 그 효력이 생긴다.
- ② 저당권으로 담보한 채권을 질권의 목적으로 할 때에는 그 저당권등기에 질권의 부기등기를 하여야 그 효력이 저당권에 미친다.
- ③ 질권설정자는 질권자의 동의없이 질권의 목적이 된 권리를 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다.
- ④ 채권의 목적물이 금전 이외의 물건인 때에는 질권자는 그 변제를 받은 물건에 대하여 질권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 무기명채권을 목적으로 한 질권의 설정은 증서를 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다.

해설

① 채권 중에서도 지시채권(어음·수표)의 입질의 경우에만 배서와 증서의 교부를 공시방법으로 한다.

정답: ①

甲은 乙에 대한 채무의 담보를 위하여 자신 소유의 토지 X위에 저당권을 설정해 주었다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲과 乙 사이에 채무이행을 위한 위약금 약정이 행해진 경우 이 약정은 등기를 하여야만 저당권에 의해 담보될 수 있다.
- ② 甲이 토지 X위에 수목을 식재한 경우 별다른 약정이 없는 한 저당권 설정 이후에 식재된 수목에 대해서도 乙의 저당권의 효력이 미친다.
- ③ 乙이 토지 X에 대해 저당권을 설정 받을 당시 그 지상에 존재하던 甲소유의 건물에 대해서도 공동저당권을 설정해 두었는데 甲이 그 건물을 철거하고 다른 건물을 신축한 경우, 토지 X의 경매로 인해 토지 X와 신축건물이 다른 소유자에게 속하게 되었다면 판례에 의할 때 그 건물을 위한 법정지상권은 인정되지 않는다.
- ④ 丙의 토지 X에 대한 침해행위가 있는 경우 토지 X의 교환가치가 乙의 채권을 여전히 만족시킬 수 있더라도 乙은 丙에 대해 저당권에 기한 방해제거나 예방청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 저당권설정 이후에 甲으로부터 토지 X에 대한 지상권을 설정 받은 丙이 건물을 축조한 경우에는 甲이 그 후 건물의 소유권을 취득하더라도 乙은 토지 X와 함께 그 건물에 대해 경매를 청구할 수 없다.

해설

- ⑤ 저당권의 설정 이후에 축조된 건물에 해당하므로 일괄경매청구권이 인정된다 할 것이다(대법원 2003.4.11. 2003다2350).
- ① 위약금은 등기된 경우에 한하여 피담보채권의 범위에 속한다.
- ② 저당권 설정 이전에 있었던 부합물이든 이후에 있었던 부합물이든 乙의 저당권의 효력이 미친다.
- ④ 토지 X의 교환가치가 乙의 채권을 여전히 만족시킬 수 있다면 손해배상청구권은 발생하지 않으나 물건적 청구권은 행사할 수 있다. 정답: ⑤

01 다음 중 유치권이 성립하지 않는 것은?

- ① 전세권자가 목적물을 개량하기 위하여 지출한 금액에 있어 그 목적물
- ② 임차인이 임차물의 보존에 관한 필요비를 지출한 경우에 있어 그 임차물
- ③ 건물수급인이 건물을 완성한 경우에 있어 그 건물
- ④ 목적물로부터 받은 손해배상청구권에 있어 그 목적물
- ⑤ 건물의 임차보증금에 있어 그 건물

해설

- ⑤ 건물의 임차보증금은 유치권이 발생하지 않는다.
 ①②③④는 목적물에 관하여(유치권의 건련관계) 발생한 채권이다. 정답: ⑤

02 다음 중 담보물권의 소멸에 관한 설명으로 타당하지 않는 것은?

- ① 유치권은 점유의 상실로 소멸한다. 그러나 유치권의 목적물을 그 소유자가 몰래 침탈한 경우에도 유치권자가 점유물반환청구권을 행사하여 점유를 회복하면 유치권은 소멸하지 않는다.
- ② 유치권자는 유치물의 멸실로 유치물의 소유자가 받을 금전에 대하여 유치권을 행사하지 못한다.
- ③ 채무자는 피담보채권의 소멸시효와는 별도로 저당권 자체의 시효에 의한 소멸을 주장할 수 있다.
- ④ 취득시효에 의하여 저당목적물에 대한 소유권을 취득하면 저당권은 소멸한다.
- ⑤ 질권자가 질권설정자에게 목적물을 반환하면 동산질권은 소멸한다.

해설

- ③ 담보물권은 피담보채권에 부종하는 권리이기 때문에 피담보채권이 존속하는 한 존속하며, 이러한 담보물권 자체는 소멸시효에 걸리지 않는다.
 ① 제328조, 제192조 제2항 단서
 ② 유치권은 물상대위성이 없다. 유치권은 목적물을 유치할 수 있는 것을 본질로 하고 목적물의 교환가치를 목적으로 하는 것이 아니기 때문이다. 정답: ③

03

갑은 노트북 수리인 을에게 자기가 소유하고 있는 노트북의 수리를 부탁하고 수리가 끝나는 대로 수리대금으로 10만 원을 지급키로 약속하였다. 그러나 갑은 이를 지급하지 않았으므로 을은 유치권을 행사하여 노트북을 반환하지 않았다. 이 경우의 법률관계상 옳은 것은?

- ① 제3자 병이 갑으로부터 노트북을 양수하고 을에 대하여 노트북을 인도할 것을 청구한 경우, 을은 병에 대하여 인도하지 않으면 안 된다.
- ② 갑이 7만 원을 지급한 경우, 을은 노트북을 반환하지 않으면 안 된다.
- ③ 을은 자기의 물건에 있어서와 같은 주의를 가지고 노트북을 점유하지 않으면 안 된다.
- ④ 을이 노트북을 유치하고 있는 동안은 수리대금채권의 소멸시효는 진행되지 않는다.
- ⑤ 을은 갑의 동의를 얻어 그 노트북을 타인에게 임대하고 그로 인하여 얻은 임대료로부터 변제에 충당할 수 있다.

해설

- ⑤ 제324조, 제323조
- ① 유치권은 물권으로서 대세적 효력이 있다.
- ② 유치권의 불가분성에 반한다.
- ③ 선량한 관리자의 주의의무를 요한다(제324조 제1항).
- ④ 제326조에 반한다. 정답: ⑤

04

甲은 乙은행으로부터 1억 원을 빌리면서 그 채무를 담보하기 위하여 자신 소유의 X토지(나대지)에 1번 저당권을 설정해 주었다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙이 X토지 위에 건물 신축을 방지하기 위하여 지상권을 설정한 경우, 그 지상권은 무효이다.
- ② X토지의 2번 저당권자인 A가 甲의 채무 일부를 변제한 경우, A는 乙의 저당권을 대위 행사할 수 없다.
- ③ 乙의 채권이 일부 무효인 경우, 甲은 유효인 부분의 채권에 대한 변제 없이도 저당권등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ④ 저당권 설정 후에 X토지의 임차인 B가 그 지상에 Y건물을 신축하고 甲이 이를 매수한 경우, 乙은 X토지와 Y건물에 대하여 일괄경매를 청구할 수 있다.
- ⑤ 乙은 원본의 이행기일을 경과한 후 3년분의 지연손해에 한하여 저당권을 행사할 수 있다.

해설

- ④ 민법 제365조가 토지를 목적으로 한 저당권을 설정한 후 그 저당권설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자가 토지와 건물을 일괄하여 경매를 청구할 수 있도록 규정한 취지는, 저당권은 담보물의 교환가치의 취득을 목적으로 할 뿐 담보물의 이용을 제한하지 아니하여 저당권 설정자로서는 저당권설정 후에도 그 지상에 건물을 신축할 수 있는데, 후에 그 저당권의 실행으로 토지가 제3자에게 경락될 경우에 건물을 철거하여야 한다면 사회경제적으로 현저한 불이익이 생기게 되어 이를 방지할 필요가 있으므로 이러한 이해관계를 조절하고, 저당권자에게도 저당토지상의 건물의 존재로 인하여 생기게 되는 경매의 어려움을 해소하여 저당권의 실행을 쉽게 할 수 있도록 한 데에 있다는 점에 비추어 볼 때, 저당지상의 건물에 대한 일괄경매청구권은 저당권 설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정

받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다(대법원 2003.04.11. 2003다3850). 정답: ④

05 유치권에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

- ① 민법은 피담보채권은 유치권의 목적물에 관하여 생긴 것이어야 한다고 하여 목적물과 피담보채권 간의 건련관계를 요구한다.
- ② 임차인의 보증금반환청구권과 임차목적물 사이에도 유치권이 성립한다.
- ③ 목적물의 점유가 불법행위로 인한 것이 아닐 것이 요구된다.
- ④ 임야의 일부를 개간한 경우, 개간 부분과 다른 부분의 분할이 가능·용이하다면 유치권은 개간한 부분에만 성립한다.
- ⑤ 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 목적물을 점유하여야 한다.

해설

- ① 제320조 제1항 ③ 제320조 제2항 ⑤ 제324조 제1항
- ② 보증금반환청구권은 목적물에 관하여 발생한 것이 아니다. 따라서 유치권이 성립할 수 없다.
- ④ 대법원 1968.3.5., 67다2786 정답: ②

06 갑은 컴퓨터수선인인 을에게 고장 난 자기소유 컴퓨터의 수선을 의뢰하면서 수선대금은 수선 후에 지급하기로 합의하였다. 그런데 갑이 수선대금을 지급하지 않으므로 을은 유치권을 행사하여 컴퓨터의 반환을 거절하였다. 이 경우의 법률관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 을이 컴퓨터를 유치하고 있는 동안에도 수선대금채권의 소멸시효는 중단되지 않는다.
- ② 을은 갑의 승낙 없이 이 컴퓨터를 제3자에게 담보로 제공하지 못한다.
- ③ 을은 자기의 물건과 같은 정도의 주의를 가지고 컴퓨터를 점유하여야 한다.
- ④ 갑이 수선비의 3/4을 지급하더라도 을은 컴퓨터를 반환하지 않아도 된다.
- ⑤ 제3자인 병이 갑으로부터 컴퓨터를 양수하고 을에 대하여 컴퓨터를 인도할 것을 청구한 경우에도, 을은 병에게 컴퓨터를 반환하지 않아도 된다.

해설

- ③ 제324조(유치권자의 선관의무) 제1항은 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다고 규정하고 있다.
- ① 피담보채권이 시효 소멸되면 담보물권도 소멸한다. 다만, 담보물권은 피담보채권과 독립해서 소멸 시효에 걸리지 않는다(제326조). 따라서 을이 컴퓨터를 유치하고 있더라도 소멸시효가 중단되지 않는다.
- ② 제324조 제2항에서 유치권자는 채무자의 승낙 없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 않는다고 규정하고 있다.
- ④ 제321조(유치권의 불가분성)에서는 유치권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다고 규정하고 있다. 즉 부종성, 수반성, 불가분성 등이 있다.
- ⑤ 유치권자는 채무자뿐만 아니라 그 밖의 모든 사람에게 대항할 수 있다. 즉, 유치물의 소유권이 채무자 이외의 제3자에게 귀속된 경우에 채무자의 이행은 채무자에게 청구하지만 유치권은 유치물의 소유자에게 행사할 수 있다. 따라서 반환하지 않아도 된다. 정답: ③

07 유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 유치권자는 피담보채권 전부의 변제를 받을 때까지 경매절차의 매수인에 대하여도 목적물의 인도를 거절할 수 있다.
- ② 유치권자의 점유는 직접점유이든 간접점유이든 관계가 없으나, 그 직접점유자가 채무자인 경우에는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당되지 않는다.
- ③ 유치권을 행사하고 있는 동안에는 피담보채권의 소멸시효는 진행하지 않는다.
- ④ 건물의 임차인은 임대차 존속기간 중 지출한 유익비의 상환을 받을 때까지 유치권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 건축업자가 건물을 점유하기 전에 건물공사로 취득한 건축비채권이라도 그 후 그 건물을 점유하였다면 유치권은 성립한다.

해설

- ③ 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효진행에 영향을 미치지 아니한다(제326조). 정답: ③

08 다음 중 유치권이 성립하는 경우는?

- ① 임대인이 건물에 필요한 시설을 아니하기 때문에 임차인에게 건물을 임차목적대로 사용 못한 것을 이유로 하는 손해배상청구권과 그 임차목적물
- ② 신축건물의 소유권을 도급인에게 귀속시키기로 한 수급인의 공사대금채권과 그 완성물
- ③ 임차목적물의 명도시에 반환하기로 한 권리금반환채권과 그 임차목적물
- ④ 임대차계약 종료 후 보증금반환채권과 그 임차목적물
- ⑤ 임차인의 부속물매수청구에 따른 대금채권과 그 임차목적물

해설

- ② 유치권은 타물권이므로 신축건물이 도급인 소유라면 수급인은 공사대금채권으로써 유치권을 주장할 수 있다. 그러나 신축건물이 수급인 소유라면 유치권은 성립하지 않는다.
- ① 임대인이 건물시설을 아니하기 때문에 임차인에게 건물을 임차목적대로 사용 못한 것을 이유로 하는 손해배상청구권과 그 임차목적물은 견련성이 인정되지 않는다는 것이 판례이다.
- ③ ④ ⑤ 모두 다 견련성이 인정되지 않는다는 것이 판례이다. 정답: ②

09

유치권에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 피담보채권이 발생한 이후에 물건의 점유를 취득한 경우에는 유치권이 성립할 수 없다.
- ② 유치권은 법정담보물권이나 당사자의 특약에 의해 그 발생을 배제할 수 있다.
- ③ 유치권은 우선변제적 효력이 있으므로 부동산경매의 경우 경락인에 대하여 그 변제를 청구할 수 있다.
- ④ 채무자를 직접점유자로 하여 채권자가 간접점유하는 경우에도 유치권은 성립한다.
- ⑤ 유치권에도 물상대위성이 인정된다.

해설

② 타당한 기술이다.

- ① 채권은 목적물의 점유 중 또는 점유와 더불어 생긴 것임을 요하지 않고, 점유하기 전에 그 목적물에 관련되는 채권이 발생하고, 그 후 어떤 사정으로 목적물의 점유를 취득한 경우에도 유치권은 성립한다.
- ③ 유치권에는 경매권은 있으나 우선변제적 효력은 없다.
- ④ 유치권의 성립요건이자 존속요건인 유치권자의 점유는 직접점유이든 간접점유이든 관계가 없으나, 다만 유치권은 목적물을 유치함으로써 채무자의 변제를 간접적으로 강제하는 것을 본체적 효력으로 하는 권리인 점 등에 비추어, 그 직접점유자가 채무자인 경우에는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당하지 않는다고 할 것이다(대법원 2008.4.11. 2007다27236).
- ⑤ 유치권은 물상대위성이 인정되지 않는다. 정답: ②

10

유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 임차인의 임차보증금반환청구권은 임차건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없다.
- ② 점유를 침탈당한 유치권자가 점유회수의 소를 제기하면 유치권을 보유하는 것으로 간주된다.
- ③ 유치권의 발생을 배제하는 특약은 유효하다.
- ④ 피담보채권이 변제기에 이르지 아니하면 유치권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 우선하여 그 채권의 변제에 충당할 수 있다.

해설

- ② 점유회수의 소를 제기한 자체만으로는 유치권을 회복한 것으로 볼 수 없으며, 그에 의하여 점유를 회복하여야 유치권은 부활한다.

[참조판례] 갑 주식회사가 건물신축 공사대금 일부를 지급받지 못하자 건물을 점유하면서 유치권을 행사해 왔는데, 그 후 을이 경매절차에서 건물 중 일부 상가를 매수하여 소유권이전등기를 마친 다음 갑 회사의 점유를 침탈하여 병에게 임대한 사안에서, 을의 점유침탈로 갑 회사가 점유를 상실한 이상 유치권은 소멸하고, 갑 회사가 점유회수의 소를 제기하여 승소판결을 받아 점유를 회복하면 점유를 상실하지 않았던 것으로 되어 유치권이 되살아난다(대법원 2012.02.09. 2011다72189). 정답: ②

11

민사유치권자 甲에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2022' 감정평가사]

- ① 甲이 수취한 유치물의 과실은 먼저 피담보채권의 원본에 충당하고 그 잉여가 있으면 이자에 충당한다.
- ② 甲은 피담보채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.
- ③ 甲이 유치권을 행사하더라도 피담보채권의 소멸시효의 진행에는 영향을 미치지 않는다.
- ④ 甲은 채무자의 승낙이 없더라도 유치물의 보존에 필요한 사용은 할 수 있다.
- ⑤ 甲은 피담보채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.

해설

- ① 유치권자에게 과실수취권이 인정된다. 유치물의 과실을 수취하여 1차적으로 이자에 충당하고, 2차적으로는 원본에 충당하여야 한다(제323조). 정답: ①

12

유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 채권자가 불법으로 점유를 취득한 경우에도 유치권이 성립한다.
- ② 채권자가 유치권을 행사하면 채권의 소멸시효는 중단된다.
- ③ 건물임차인은 권리금반환청구권에 기하여 임차건물에 대하여 유치권을 주장할 수 없다.
- ④ 유치권에는 우선변제적 효력이 없으므로, 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 없다.
- ⑤ 공사대금채권에 기하여 유치권을 행사하는 자가 채무자의 승낙 없이 유치물의 보존에 필요한 범위 내에서 유치물인 주택에 거주하며 사용하였다면, 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 없다.

해설

- ③ 임차보증금반환채권이나 권리금반환채권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 유치권의 성립요건인 '채권과 목적물의 견련성'에 해당하지 아니한다.
- ① 대법원 1976.05.25. 76다482
부동산의 점유가 불법행위로 인하여 시작되었을 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.
- ② 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효진행에 영향을 미치지 아니한다(제326조).
- ④ 유치권자에게는 경매권이 인정된다.
- ⑤ 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다(대법원 2009.09.24. 2009다40684). 정답: ③

13 민사유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 유치권 배제 특약이 있더라도 다른 법정요건이 모두 충족되면 유치권이 성립한다.
- ② 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ③ 원칙적으로 유치권은 채권자 자신 소유 물건에 대해서도 성립한다.
- ④ 채권자가 채무자를 직접점유자로 하여 간접점유하는 경우, 채권자의 점유는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당한다.
- ⑤ 채권자의 점유가 불법행위로 인한 경우에도 유치권이 성립한다.

해설

- ② 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다(제327조).
- ① 유치권의 발생을 배제하는 특약이 있으면 성립하지 않는다.
- ③ 담보물권은 타물권(他物權)이다. 따라서 자신 소유의 물건에 대해서는 성립할 수 없다.
- ④ 채무자를 직접점유로 하여서는 유치권은 성립하지 못한다.
- ⑤ 채권자가 불법으로 점유를 취득한 경우에는 유치권이 성립하지 않는다. 정답: ②

14 민사유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 변리사]

- ① 유치권자는 유치물의 과실(果實)이 금전인 경우, 이를 수취하여 다른 채권보다 먼저 유치권으로 담보된 채권의 변제에 충당할 수 있다.
- ② 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한, 차임 상당의 이득을 소유자에게 반환할 의무가 없다.
- ③ 건물공사대금의 채권자가 그 건물에 대하여 유치권을 행사하는 동안에는 그 공사대금채권의 소멸시효가 진행하지 않는다.
- ④ 임대인과 임차인 사이에 임대차 종료에 따른 건물명도시에 권리금을 반환하기로 약정한 경우, 임차인은 권리금반환청구권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 유치권자가 경매개시결정등기 전에 부동산에 관하여 유치권을 취득하였더라도 그 취득에 앞서 저장권설정등기가 먼저 되어 있었다면, 경매절차의 매수인에게 자기의 유치권으로 대항할 수 없다.

해설

- ① 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다. 그러나 과실이 금전이 아닌 때에는 경매하여야 한다(제323조 제1항).
- ② 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다(대법원 2009.09.24. 2009다40684).
- ③ 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효진행에 영향을 미치지 아니한다. 즉 유치권을 행사하는 동안에도 그 공사대금채권은 소멸시효가 진행된다.
- ④ 권리금반환청구권은 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 그와 같은 채권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다(대법원 1994.10.14. 93다62119).
- ⑤ 유치권자가 경매개시결정등기 전에 부동산에 관하여 유치권을 취득하였다면 경매절차의 매수인에게 자기의 유치권으로 대항할 수 있다. 정답: ①

15 민법상 유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 甲이 丙 소유의 자동차를 乙에게 수리시킨 경우, 乙은 그 수리비에 관하여 丙을 상대로 유치권을 주장할 수 있다.
- ② 채무자를 직접점유자로 하여 채권자가 간접점유하는 경우에도 유치권은 성립한다.
- ③ 채권관계 당사자 사이의 그 채권에 관한 유치권 포기특약은 유효하다.
- ④ 건물신축공사의 하수급인이 다른 하수급인을 통하여 신축건물을 간접점유한 경우에도, 유치권의 성립요건을 충족할 수 있다.
- ⑤ 공사대금채권에 기하여 유치권을 행사하는 자가 스스로 유치물인 주택에 거주·사용하는 것은 특별한 사정이 없는 한, 유치물의 보존에 필요한 사용에 해당한다.

해설

- ② 채무자를 직접점유자로 하여 채권자가 간접점유하는 경우에는 유치권은 성립하지 못한다. 정답: ②

16 유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 당사자의 합의로 유치권을 설정할 수 있다.
- ② 점유를 침탈당한 유치권자가 점유회수의 소를 제기하여 승소판결을 받았더라도 점유를 회복하지 않으면 유치권이 부활하지 않는다.
- ③ 건물신축공사 수급인은 사회통념상 독립한 건물이라고 볼 수 없는 정착물에 대하여도 유치권을 취득할 수 있다.
- ④ 부동산 계약명의신탁의 경우 부동산을 점유하는 명의신탁자는 명의수탁자에 대한 매매대금 상당의 부당이득반환청구권에 기해서 유치권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 유치권에는 물상대위가 인정된다.

해설

- ② 타당한 기술이다. 점유회수의 소를 제기하여 승소판결을 받았더라도 유치권을 회복한 것으로 볼 수 없으며, 그에 의하여 점유를 회복하여야 유치권은 부활한다.
- ① 유치권은 일정한 사유가 발생하면 당연히 성립되는 법정담보물권이고, 질권이나 저당권처럼 당사자의 합의에 의하여 성립하는 약정담보물권이 아니다.
- ③ 건물의 신축공사를 한 수급인이 그 건물을 점유하고 있고 또 그 건물에 관하여 생긴 공사금 채권이 있다면, 수급인은 그 채권을 변제받을 때까지 건물을 유치할 권리가 있는 것이지만, 건물의 신축공사를 도급받은 수급인이 사회통념상 독립한 건물이라고 볼 수 없는 정착물을 토지에 설치한 상태에서 공사가 중단된 경우에 위 정착물은 토지의 부합물에 불과하여 이러한 정착물에 대하여 유치권을 행사할 수 없는 것이다(대법원 2008.05.30. 자 2007마98).
- ④ 유치권의 견련성이 인정되지 않는다.
- ⑤ 유치권은 부종성·수반성·불가분성이 인정되나 추급력과 물상대위성은 부정된다. 정답: ②

17

유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 건물의 임차인이 임대인에게 지급한 임차보증금반환채권은 그 건물에 관하여 생긴 채권이 아니다.
- ② 임대인이 건물시설을 하지 않아 임차인이 건물을 임차목적대로 사용하지 못하였음을 이유로 하는 손해배상청구권은 그 건물에 관하여 생긴 채권이다.
- ③ 수급인의 재료와 노력으로 건축되었고 독립한 건물에 해당되는 기성부분에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 수급인은 유치권을 가질 수 없다.
- ④ 채권자가 채무자를 직접점유자로 하여 간접점유하는 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.
- ⑤ 유치권자가 점유침탈로 유치물의 점유를 상실한 경우, 유치권은 원칙적으로 소멸한다.

해설

- ② 건물의 임대차에 있어서 임차인의 임대인에게 지급한 보증금반환청구권이나 임대인이 건물시설을 아니하기 때문에 임차인에게 건물을 임차목적대로 사용 못한 것을 이유로 하는 손해배상청구권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없다(대법원 1976.05.11. 75다1305). 정답: ②

18

유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 목적물에 대한 점유를 취득한 후 그 목적물에 관한 채권이 성립한 경우 유치권은 인정되지 않는다.
- ② 유치물이 분할 가능한 경우, 채무자가 피담보채무의 일부를 변제하면 그 범위에서 유치권은 일부 소멸한다.
- ③ 유치권자가 유치물을 점유함으로써 유치권을 행사하고 있는 동안에는 피담보채권의 소멸 시효는 진행되지 않는다.
- ④ 유치권자는 특별한 사정이 없는 한 법원에 청구하지 않고 유치물로 직접 변제에 충당할 수 있다.
- ⑤ 공사업자 乙에게 건축자재를 납품한 甲은 그 매매대금채권에 기하여 건축주 丙의 건물에 대하여 유치권을 행사할 수 없다.

해설

- ⑤ 건축자재대금채권과 목적물의 견련성이 없으므로 타당한 기술이다.
 ① '채권과 목적물의 점유'와의 견련성은 요구되지 아니한다.
 ② 피담보채무의 전액을 변제할 때까지 목적물 전부위에 담보물권의 효력이 미친다(불가분성).
 ③ 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효 진행에 영향을 미치지 아니한다.
 ④ 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다 (제322조). 정답: ⑤

19

유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 유치물의 소유자가 변동된 후 유치권자가 유치물에 관하여 새로이 유익비를 지급하여 가격 증가가 현존하는 경우, 유치권자는 그 유익비를 피보전채권으로 하여서도 유치권을 행사할 수 있다.
- ② 다세대주택의 창호공사를 완성한 하수급인이 공사대금채권 잔액을 변제받기 위하여 그 중 한 세대를 점유하는 유치권 행사는 인정되지 않는다.
- ③ 수급인의 재료와 노력으로 건물을 신축한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 건물에 대한 수급인의 유치권은 인정되지 않는다.
- ④ 유치권의 목적이 될 수 있는 것은 동산, 부동산 그리고 유가증권이다.
- ⑤ 유치권자가 유치물에 대한 보존행위로서 목적물을 사용하는 것은 적법하다.

해설

② 다세대주택의 창호 등의 공사를 완성한 하수급인이 공사대금채권 잔액을 변제받기 위하여 위 다세대주택 중 한 세대를 점유하여 유치권을 행사하는 경우, 그 유치권은 위 한 세대에 대하여 시행한 공사대금만이 아니라 다세대주택 전체에 대하여 시행한 공사대금채권의 잔액 전부를 피담보채권으로 하여 성립한다. 정답: ②

20

동산질권의 효력에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 질권의 실행은 경매를 통해 우선변제를 받고 나머지가 있으면 질권설정자에게 반환하는 것이 원칙이다.
- ② 질권설정자는 채무변제기 전후의 계약으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 취득하게 하거나 법률이 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분할 것을 약정하지 못한다.
- ③ 승낙전질은 질권자가 질물 소유자의 승낙을 얻어 그가 점유하는 질물을 입질하여 새로운 질권을 설정하는 것으로 법적 성질은 질물의 재입질이다.
- ④ 질권은 목적물 자체가 아니라 그 교환가치를 우선적으로 파악하는 권리이므로 그 목적물이 멸실 등으로 변환하더라도 그 교환가치의 대표물이 존재하는 때에는 질권은 그 위에 존속하게 된다.
- ⑤ 질권자는 질물에 의하여 변제를 받지 못한 채권에 한하여 채무자의 다른 재산으로부터 변제를 받을 수 있다.

해설

② 변제기 후에 유질계약을 체결하는 것은 유효하다(제339조).
⑤ 제340조 정답: ②

21

동산질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 동산질권도 선의취득의 대상이 될 수 있다.
- ② 질권설정자는 채무변제기 후의 계약으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 취득하게 할 것을 약정하지 못한다.
- ③ 수개의 채권을 담보하기 위하여 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 때에는 그 순위는 설정의 선후에 의한다.
- ④ 다른 약정이 없는 한 질권은 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다.
- ⑤ 정당한 이유가 있는 경우 질권자는 간이변제충당을 법원에 청구할 수 있고, 이때 질권자는 미리 채무자 및 질권설정자에게 통지하여야 한다.

해설

- ② 질권설정자는 채무변제기전의 계약으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 취득하게 하거나 법률에 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분할 것을 약정하지 못한다(유질계약의 금지, 제339조). 그러나 변제기 후의 유질계약은 인정된다. 정답: ②

22

질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 점유개정에 의한 동산질권설정은 인정되지 않는다.
- ② 질권자는 채권 전부를 변제받을 때까지 질물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.
- ③ 질물이 공용징수된 경우, 질권자는 질권설정자가 받을 수용보상금에 대하여도 질권을 행사할 수 있다.
- ④ 전질은 질물소유자인 질권설정자의 승낙이 있어도 허용되지 않는다.
- ⑤ 부동산의 사용, 수익을 내용으로 하는 질권은 물건법정주의에 반한다.

해설

- ④ 책임전질과 승낙전질이 있다. 정답: ④

23 권리질권에 대한 다음 설명 중 옳지 못한 것은?

- ① 양도성이 있는 권리라고 할지라도 지상권, 전세권 등 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 권리는 질권의 목적이 될 수 없다.
- ② 지명채권을 질권의 목적으로 하는 경우 질권설정계약의 합의 이외에 채권증서의 교부가 있어야 질권설정의 효력이 생긴다.
- ③ 입질채권이 금전채권인 경우 질권자는 그 질권의 목적인 채권을 직접 청구할 수는 없다.
- ④ 입질채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 때에는 질권자는 제3채무자에 대해 변제금액의 공탁을 청구할 수 있으며 질권은 여전히 그 공탁금에 존재한다.
- ⑤ 입질채권이 지시채권인 경우에는 증서의 배서교부로, 무기명채권인 경우에는 교부에 의해 권리질권이 성립된다.

해설

- ③ 제353조(질권의 목적이 된 채권의 실행방법) 제2항에서 채권의 목적물이 금전인 때에는 질권자는 자기채권의 한도에서 직접 청구할 수 있다고 규정하고 있다.
- ① 부동산의 사용·수익을 내용으로 하는 권리는 권리질권의 목적이 될 수 없다(제345조 단서). 즉 지상권, 전세권, 부동산임차권 등에 대해서는 권리질권을 설정할 수 없다. 또한 광업권, 어업권, 공장재단, 광업재단 등은 질권의 목적이 되지 않고 저당권의 목적이 된다.
- ② 지명채권의 입질은 제347조(설정계약의 요물성)에서 채권을 질권의 목적으로 하는 경우에 채권증서가 있는 때에는 질권의 설정은 그 증서를 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다고 규정하고 있다.
- ④ 제353조 제3항에서는 채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 때에는 질권자는 제3채무자에 대하여 그 변제금액의 공탁을 청구할 수 있다고 규정하고 있으며, 따라서 질권은 여전히 그 공탁금에 존재한다.
- ⑤ 지시채권의 입질은 배서·교부에 의한다. 즉, 제350조(지시채권에 대한 질권의 설정방법)에서는 지시채권을 질권의 목적으로 한 질권의 설정은 증서에 배서하여 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다고 규정하고 있으며, 무기명채권의 입질은 제351조(무기명채권에 대한 질권의 설정방법)에서 무기명채권을 목적으로 한 질권의 설정은 증서를 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다고 규정하고 있다. 정답: ③

24 질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 양도할 수 없는 물건은 질권의 목적이 되지 못한다.
- ② 질권자는 채권의 변제를 받기 위하여 질물을 경매할 수 있다.
- ③ 채권질권의 효력은 질권의 목적이 된 채권 외에 그 채권의 지연손해금에는 미치지 않는다.
- ④ 질권의 목적인 채권의 양도행위는 질권자의 이익을 해하는 변경에 해당되지 않으므로 질권자의 동의를 요하지 않는다.
- ⑤ 수개의 채권을 담보하기 위하여 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 경우, 그 순위는 설정의 선후에 의한다.

해설

- ③ 질권은 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다(제334조). 채무불이행으로 인한 손해배상, 즉 지연배상은 원칙적으로 원본의 이행기일 경과 후 1년분에 한한다. 정답: ③

25 민사동산질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[2022' 감정평가사]

- ① 질권자는 피담보채권의 변제를 받기 위하여 질물을 경매할 수 있고, 그 매각대금으로부터 일반채권자와 동일한 순위로 변제받는다.
- ② 질권은 양도할 수 없는 물건을 목적으로 하지 못한다.
- ③ 질권은 다른 약정이 없는 한 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다.
- ④ 질권자는 피담보채권의 변제를 받을 때까지 질물을 유치할 수 있으나 자기보다 우선권이 있는 채권자에게 대항하지 못한다.
- ⑤ 수개의 채권을 담보하기 위하여 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 때에는 그 순위는 설정의 선후에 의한다.

해설

- ① 질권은 담보물권으로서 일반채권자에 대하여 우선변제적 효력을 갖는다. 정답: ①

26 질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 채권을 질권의 목적으로 하는 경우에 채권증서가 있는 때에는 질권의 설정은 그 증서를 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다.
- ② 질권의 목적인 채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 경우 질권자는 제3채무자에 대하여 자신에게 변제할 것을 청구할 수 있다.
- ③ 저당권으로 담보한 채권을 질권의 목적으로 한 때에는 그 저당권등기에 질권의 부기등기를 하여야 그 효력이 저당권에 미친다.
- ④ 질권자는 질권의 실행방법으로서 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.
- ⑤ 양도할 수 없는 동산은 질권의 목적이 될 수 없다.

해설

- ② 채권의 변제기가 질권자의 채권의 변제기보다 먼저 도래한 때에는 질권자는 제3채무자에 대하여 그 변제금액의 공탁을 청구할 수 있으며, 있으며, 질권은 그 공탁금에 존재한다(제353조 제3항). 정답: ②

제6장
실전문제

27

질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 질권은 질물 전부에 효력이 미친다.
- ② 저당권으로 담보된 채권에 설정된 질권은 그 저당권등기에 질권의 부기등기를 하여야 저당권에 효력이 미친다.
- ③ 금전채권에 질권을 취득한 질권자는 자기채권액의 범위에서 직접 추심하여 변제에 총당할 수 있다.
- ④ 질권설정자는 피담보채무의 변제기 이후의 약정으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 이전할 수 있다.
- ⑤ 금전채무자가 채권자에게 담보물을 제공한 경우, 특별한 사정이 없으면 채무자의 변제업무와 채권자의 담보물반환의무는 동시이행관계에 있다.

해설

⑤ 채무자의 변제업무가 채권자의 담보물반환의무보다 선행행 의무이다. 정답: ⑤

28

저당권에 관하여 다음 중 틀린 것은?

- ① 판례는 저당권이 설정될 당시 존재하던 건물이 그 후 증·개축된 경우에도 민법 제366조 소정의 법정지상권의 성립을 인정하면서, 그 내용은 구 건물을 기준으로 한다고 한다.
- ② 토지저당권자가 지상건물을 일괄 경매하는 경우에, 그가 우선 변제받는 범위는 토지의 매각대금에 한정된다.
- ③ 저당부동산의 제3취득자는 경매인이 될 수 없다.
- ④ 저당부동산의 제3취득자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권만을 변제하고, 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ⑤ 저당권자는 저당권이 침해된 경우에 물건적 반환청구권을 가지지 않는다.

해설

③ 저당부동산의 제3취득자도 경매인이 될 수 있다.

① 대법원 1991.4.26. 90다19985

② 제365조

④ 제364조 정답: ③

29 저당권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 저당권이 실행되면 그 목적물에 설정된 용익물권은 저당권설정 전·후를 불문하고 모두 이에 대항할 수 없다.
- ② 저당권의 피담보채권에는 위약금과 채무불이행의 손해배상이 포함된다.
- ③ 저당권의 목적물에 대한 제3자의 침해에는 손해배상청구권만을 주장할 수 있다.
- ④ 목적부동산의 종물에는 저당권의 효력이 미치지 않는다.
- ⑤ 우리 민법상의 저당권에는 순위확정의 원칙이 적용된다.

해설

- ② 다만, 위약금에 대해서는登記하여야 하며, 지연배상은 이행기일을 경과한 후 1년분에 한한다(제360조).
- ① 저당권이 설정되기 전에登記된 용익물권은 후순위저당권이 실행되더라도 권리의 내용에 따라 목적물을 지배할 수 있다.
- ③ 물건적 청구권을 행사할 수 있다(제370조에 의한 제214조 준용).
- ④ 저당부동산에 부합된 물건 또는 종물에 미친다. 그러나 법률의 규정이나 당사자의 특약에 의하여 이를 배제할 수 있으나 이러한 특약은 등기사항이다(제358조 및 부동산등기법 제140조 제1항).
- ⑤ 근대 저당권제도의 내용이긴 하나, 우리 민법은 순위승진원칙을 채용한다. 정답: ②

30 저당권의 객체가 될 수 없는 것은 모두 몇 개인가?

- ㉠ 전세권
- ㉡ 성숙한 농작물
- ㉢ 타인의 토지 위에 무단으로 건축하여登記된 주택
- ㉣ 명인방법만을 갖춘 수목

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개
- ④ 3개 ⑤ 4개

해설

- ㉠ ㉢ 전세권은 저당권의 객체가 될 수 있고, 건물은 토지와 별개의 부동산이므로 저당권의 객체가 될 수 있다.
- ㉡ ㉣ 성숙한 농작물이나 명인방법을 갖춘 수목의 경우에는 소유권의 객체는 될 수 있으나, 저당권의 객체가 되지는 못한다. 정답: ③

31

저당권의 객체 및 효력에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 저당권은 원본뿐 아니라 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상을 담보하지만 저당권의 실행비용은 등기될 수 없으므로 담보되지 못한다.
- ② 저당권은 부동산에 대해서 뿐만 아니라 전세권과 지상권에 대해서도 설정될 수 있다.
- ③ 근저당권 설정 후 부동산 소유권이 이전된 경우 근저당권설정자인 종전의 소유자도 피담보 채권의 소멸을 이유로 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ④ 저당부동산에 부합된 물건은 저당권설정 이후에 부합한 경우에도 그 부합물에 저당권의 효력이 미치는 것이 원칙이다.
- ⑤ 근저당의 채권 최고액이란 후순위담보권자나 저당목적부동산의 제3취득자에 대하여 근저당권자가 목적물로부터 우선변제를 받을 수 있는 한도액을 의미한다.

해설

- ① 제360조(피담보채권의 범위)에서는 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보한다. 그러나 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한하여 저당권을 행사할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 조문에 의하여 당연히 실행비용이 담보된다.
- ② 저당권의 객체는 민법상 저당권의 객체로서 부동산(제356조)과 지상권, 전세권(제371조 제1항) 등과 특별법상 저당권의 객체로서 입목, 각종 채단, 자동차, 건설기계, 항공기, 선박, 어업권, 광업권 등이 있다.
- ④ 타당한 기술이다.
- ⑤ 대법원 1992.5.26. 92다1896 정답: ①

32

저당권에 관한 설명 중 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 저당권의 부종성 때문에 저당권자는 피담보채권의 채권자에 한한다.
- ② 피담보채권이 소멸하였음에도 저당권설정등기가 말소되지 않고 남아 있는 경우에 등기가 무효로 된 후 당사자가 그 무효등기를 유용하기로 합의할 때까지 사이에 등기부상 이해관계 있는 제3자가 나타나지 않는 한 그 유용의 합의는 유효하다
- ③ 유효하게 경로된 저당권설정등기가 불법 말소되거나 유폐된 경우에도 저당권자는 저당권을 상실하지 않고 그 말소된 등기의 회복등기를 할 수 있지만, 저당목적물이 경락된 경우에는 저당권등기가 회복될 수 없고, 저당권자는 경매절차에서 실제로 배당받은 후순위 권리자에 대하여 부당이득반환청구로서 그 배당금의 한도 내에서 저당권설정등기가 말소되지 않았더라면 배당받았을 금액의 지급을 구할 수 있을 뿐이다.
- ④ 저당권이 설정된 후에 저당권설정자 외의 제3자가 건물을 축조한 경우 또는 저당권설정자가 축조하였으나 경매 당시에 제3자가 소유하고 있는 경우에는 일괄경매권이 인정되지 않는다.
- ⑤ 구분건물의 전유부분에 대하여서만 설정된 저당권의 효력은, 그 전유부분의 소유자가 사후 예라도 대지사용권을 취득함으로써 전유부분과 대지권이 동일 소유자의 소유에 속하게 되었다면, 그 대지사용권에까지 미치고 여기의 대지사용권에는 지상권, 전세권, 임차권 이외에 대지소유권도 포함된다.

해설

- ① 근저당권은 채권담보를 위한 것이므로 원칙적으로 채권자와 근저당권자가 동일인이 되어야 하지만, 제3자를 근저당권의 명의인으로 하는 근저당권을 설정하는 경우 그 점에 대하여 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있고, 채권양도, 제3자를 위한 계약, 불가분적 채권관계의 형성 등 방법으로 채권이 그 제3자에게 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있는 경우에는 제3자 명의의 근저당권설정등기도 유효하다고 보아야 할 것이다(대법원[전합] 2001.3.15. 99다48948).
- ② 대법원 1970.12.24. 70다1630
- ③ 대법원 1998.10.2. 98다27197
- ④ 최근 판례는 설사 저당권설정자로부터 용익물권을 설정받은 자가 건물을 축조하였다 하더라도 경매 신청 시 저당권설정자의 소유에 속하고 있다면 일괄경매청구를 인정하고 있다(대법원 2003.4.11. 2003다3850).
- ⑤ 대법원 1995.8.22. 94다1272 정답: ①

33 저당권의 효력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 토지저당권의 효력은 토지상에 타인이 무단 경작하여 성숙한 농작물에는 미치나, 적법한 토지임차인이 경작한 농작물에는 미치지 않는다.
- ② 건물에 저당권이 설정된 경우 그 건물에 연이어 설치되어 그 일부에 불과한 부속건물에도 저당권의 효력이 미치므로 등기부에 등재되지 않은 그 부속건물을 경매목적에 포함시킨 매각허가 결정은 적법하다.
- ③ 저당권의 효력은 저당부동산에 대한 압류가 있는 후에 저당권설정자가 그 부동산으로부터 수취한 과실 또는 수취할 수 있는 과실에 미친다.
- ④ 구분건물의 전유부분에 대한 저당권의 효력은 특별한 사정이 없으면 대지사용권에도 미친다.
- ⑤ 저당권자가 물상대위권을 행사하기 위한 요건인 '지급 또는 인도 전 압류'는 반드시 저당권자가 할 필요는 없다.

해설

- ① 토지저당권의 효력은 토지상에 타인이 무단 경작하여 성숙한 농작물에는 미치지 않는다. 판례는 아무 권원 없이, 심지어 위법하게 타인의 토지에 농작물을 경작·재배하였더라도, 그 농작물이 성숙하여 독립한 물건으로서의 존재를 갖추었다면 그 농작물의 소유권은 언제나 경작자에게 속하고, 명인방법을 갖추었는지 여부는 문제되지 않는다고 한다(대법원 1979.8.28. 79다784). 정답: ①

34 저당권의 기술로서 타당하지 않은 것은?

- ① 저당물의 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 비용을 지출하였을 때에는 저당물의 경매대가로부터 우선변제를 받을 수 있다.
- ② 저당물의 제3취득자가 변제를 한 경우 제3취득자가 저당권자를 대위하게 되므로 채무자에게 구상권을 행사할 수 없다.
- ③ 저당권의 실행으로 인하여 제3취득자가 권리를 상실한 경우에는 담보책임을 물을 수 있다.
- ④ 저당권설정 이전의 저당물에 관한 제3자의 용익물권은 저당권실행으로 소멸하지 않는다.
- ⑤ 여러 개의 저당권이 설정된 경우에는 그 중 한 개의 저당권이 실행되면 나머지 저당권들도 모두 소멸하게 된다.

해설

◎ 제3취득자의 보호

제3취득자의 변제권	▪ 저당부동산의 제3취득자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다. ▪ 저당권자를 법정대위하며, 채무자에게 구상권을 행사할 수 있다.
비용 상환청구권	저당부동산의 제3취득자가 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 경락대가에서 우선변제를 받을 수 있다(제367조).

정답: ②

35 하나의 부동산에 설정된 저당권과 용익물권의 관계에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 1번 저당권이 설정된 후 지상권이 설정되고, 그 후 2번 저당권이 설정된 경우, 2번 저당권의 실행으로 목적물이 매각되더라도 지상권은 소멸하지 않는다.
- ② 전세권이 저당권보다 먼저 설정된 경우, 전세권자가 배당요구를 하면 전세권은 목적물의 매각으로 소멸한다.
- ③ 대항력을 갖춘 임차권이 저당권보다 먼저 성립한 경우, 저당권의 실행으로 토지가 매각되더라도 임차권은 소멸하지 않는다.
- ④ 지상권이 저당권의 목적이 된 경우에, 저당권자가 그 토지상의 지상권을 취득하면 저당권은 혼동으로 소멸한다.
- ⑤ 지상권이 저당권보다 후에 설정된 경우, 지상권자는 저당권자에게 그 토지로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.

해설

- ① 1번 저당권이 말소기준권리가 되므로 그 이후의 모든 권리는 소멸한다.
- ②③ 말소기준권리 이전의 용익물권은 매수인(경락인)이 인수하지만, 전세권자는 배당신청을 선택할 수도 있다.
- ⑤ 저당부동산에 대하여 소유권, 지상권 또는 전세권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다(제364조). 정답: ①

36

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당권설정자는 현재 저당부동산의 소유자가 아니라면 피담보채무가 소멸하더라도 저당권의 말소를 청구할 수 없다.
- ② 저당권은 경매에서의 매각으로 인하여 소멸한다.
- ③ 저당권은 피담보채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.
- ④ 저당권자가 물상대위를 통하여 우선변제를 받기 위해서는 저당권설정자가 받을 가치 변형물을 그 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.
- ⑤ 저당권자가 물상대위권을 행사하지 아니한 경우, 저당목적물의 변형물로부터 이익을 얻은 다른 채권자에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 없다.

해설

- ① 저당부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에는 전(前)소유자인 저당권설정자도 저당권말소등기청구권을 행사할 수 있고 이때의 등기청구권의 법적 성질은 채권적 청구권이다.

정답: ①

37

저당권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 저당부동산의 소유권이 제3자에게 양도된 후 피담보채권이 변제된 때에는 저당권을 설정한 종전소유자도 저당권설정등기의 말소를 청구할 권리가 있다.
- ② 저당권을 설정한 사람이 채무자가 아닌 경우, 그는 원본채권이 이행기를 경과한 때부터 1년분의 범위에서 지연배상을 변제할 책임이 있다.
- ③ 근저당권의 채무자가 피담보채권의 일부를 변제한 경우, 변제한 만큼 채권최고액이 축소된다.
- ④ 저당권자는 배당기일 전까지 물상대위권을 행사하여 우선변제를 받을 수 있다.
- ⑤ 대체물채권을 담보하기 위하여 저당권을 설정한 경우, 피담보채권액은 채권을 이행할 때의 시가로 산정한 금액으로 한다.

해설

- ① 저당부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에는 전(前)소유자인 저당권설정자도 저당권말소등기청구권을 행사할 수 있고 이때의 등기청구권의 법적 성질은 채권적 청구권이다.

정답: ①

38 저당권의 효력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 저당부동산에 관하여 이해관계인이 없는 경우, 원본의 이행기를 경과한 후의 1년분 이상의 지연손해에 대해서도 저당권의 효력이 미칠 수 있다.
- ② 건물에 저당권이 설정된 경우, 원칙적으로 그 건물에 부속된 창고에도 저당권의 효력이 미친다.
- ③ 저당권의 효력이 미치는 종물은 저당권 설정 전부터 존재하였던 것이어야 한다.
- ④ 건물에 대한 저당권의 효력은 원칙적으로 그 대지이용권인 지상권에도 미친다.
- ⑤ 저당권과 전세권이 경합하는 경우에는 설정등기의 선후에 의하여 우선순위를 정한다.

해설

- ③ 저당권의 효력은 저당부동산에 부합(저당권의 설정전후를 불문)된 부합물과 종물에도 미친다. 예외적으로 설정계약에서 반대의 특약을 한 경우와 지상권자·전세권자 등이 부합한 물건에는 미치지 아니한다. 정답: ③

39 저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2023' 감정평가사]

- ① 채권자와 제3자가 불가분적 채권자의 관계에 있다고 볼 수 있는 경우에는 그 제3자 명의의 저당권등기도 유효하다.
- ② 근저당권설정자가 적법하게 기본계약을 해지하면 피담보채권은 확정된다.
- ③ 무효인 저당권등기의 유용은 그 유용의 합의 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 없어야 한다.
- ④ 저당부동산의 제3취득자는 부동산의 개량을 위해 지출한 유익비를 그 부동산의 경매대가에서 우선 변제받을 수 없다.
- ⑤ 저당권자가 저당부동산을 압류한 이후에는 저당권설정자의 저당부동산에 관한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다.

해설

- ④ 저당부동산의 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 저당물의 매각대금에서 우선상환을 받을 수 있다(제367조). 정답: ④

40

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 장래에 발생할 특정의 조건부 채권을 피담보채권으로 하는 근저당권을 설정하는 것도 가능하다.
- ② 구분건물의 전유부분에 설정된 저당권의 효력은 특별한 사정이 없는 한 전유부분의 소유자가 나중에 취득한 대지사용권에 미친다.
- ③ 저당권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 저당부동산 전부에 관하여 그 저당권을 행사할 수 있다.
- ④ 저당권자는 저당물의 공용징수로 인하여 저당권설정자가 받을 금전의 지급 전에 이를 압류함으로써 저당권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 공유자 중 1인의 지분에 저당권이 설정된 후 공유토지가 분할된 경우, 저당권은 저당권설정자가 분할받은 토지에만 효력이 미친다.

해설

- ⑤ 부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 부동산이 분할된 경우, 그 저당권은 분할된 각 부동산 위에 종전의 지분비율대로 존속하고, 분할된 각 부동산은 저당권의 공동담보가 된다 (대법원 2012.03.29. 2011다74932). 정답: ⑤

41

저당권의 목적물을 제3자가 침해하였을 때에 저당권의 구제방법으로서 옳은 것은?

- ① 기한의 이익이 상실되므로 즉시변제청구권으로 구제된다.
- ② 저당물보충청구권에 의하여 구제된다.
- ③ 저당물보충청구권과 즉시변제청구권으로 구제된다.
- ④ 손해배상청구권만으로 구제된다.
- ⑤ 저당권에 기인한 물권적 청구권과 손해배상청구권으로 구제된다.

제6장
실전문제

해설

저당권 침해에 대한 구제

채무자에 의한 침해	㉠ 물권적 청구권을 인정 → 저당물 반환청구권은 인정되지 않는다. ㉡ 손해배상청구권의 행사 ㉢ 저당물보충청구권 → 저당권설정자의 귀책사유로 저당물의 가액이 현저하게 감소한 때에 저당권자가 청구할 수 있다. ㉣ 기한이익의 상실 → 채무자가 담보물을 손상, 감소, 멸실하게 한 때에는 즉시변제청구권을 행사할 수 있다.
제3자에 의한 침해	위의 ㉠과 ㉡의 사항만을 인정한다.

정답: ⑤

갑은 채무자인 을 소유의 산림에 저당권을 설정하였다. 그 후 을이 산림의 입목을 벌채하기 시작한 경우에 갑이 주장할 수 있는 구제수단으로써 타당하지 않은 것은?

- ① 침해자가 채무자 자신이기 때문에 을은 기한의 이익을 상실한다.
- ② 갑은 을에 대하여 침해로 감소된 담보가치를 보충할 담보를 제공하도록 요구할 수 있다.
- ③ 갑은 이미 벌채되어 반출된 목재에 대하여도 을이 점유하고 있는 한, 자기에게 반환하도록 청구할 수 있다.
- ④ 갑은 을에 대하여 저당권침해에 기한 손해배상을 청구할 수 있는 경우도 있다.
- ⑤ 갑은 을에 대하여 진행 중인 벌채행위의 중지를 요구할 수 있다.

해설

- ③ 저당 산림에 대한 저당권의 침해에 대한 구제의 문제이다. 저당권자는 점유권이 없기 때문에 설정자로부터 일탈한 저당목적물을 저당권자 자신에게 반환할 것을 청구할 수는 없지만, 원래의 설치 장소에 원상회복할 것을 청구할 수 있다(대법원 1996.3.22. 95다55184).
- ①②④ 분리반출은 저당권의 담보력을 약하게 하여 저당권설정자 을은 기한의 이익을 상실하며(제388조), 갑은 을에 대하여 담보물보충청구권을 행사할 수 있을 것이다(제362조). 또 불법행위, 채무불이행의 요건을 충족시킨 때는 손해배상을 청구할 수 있다. 다만, 담보물보충청구권을 행사한 경우에는 손해배상청구권이나 기한의 이익의 상실에 의한 즉시변제청구권은 행사하지 못한다는 것이 통설이다.
- ⑤ 저당산림의 수목을 부당하게 벌채하여 교환가치를 감소케 하는 경우에는 그 벌채행위의 중지를 갑은 을에게 청구할 수 있다. 정답: ③

저당권의 침해에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 이미 소멸한 선순위저당권의 설정등기가 말소되지 않고 있는 경우, 후순위저당권자는 방해배제청구권에 기해 선순위저당권등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ② 부동산에 관하여 저당권설정등기가 경료되었다가 그 등기가 위조 등기서류에 의하여 아무런 원인 없이 말소되었다 하여 저당권이 소멸하는 것은 아니다.
- ③ 저당권 설정자에게 책임 없는 사유로 저당물의 가액이 현저히 감소된 경우에도 저당권자는 담보물의 보충을 요구할 수 있는 권리를 가진다.
- ④ 채무자가 담보를 손상, 감소 또는 멸실하게 한 때 저당채권자는 즉시 변제를 청구할 수 있으며, 변제가 없으면 곧 저당권을 실행할 수 있다.
- ⑤ 저당권자가 담보물보충청구권을 행사하는 경우에는 손해배상청구권이나 즉시변제청구권을 행사할 수 없다.

해설

- ③⑤ 저당권설정자에게 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 경우에, 저당권자는 저당권설정자에 대하여 그 원상의 회복 또는 상당한 담보의 제공을 청구할 수 있다(제362조). 저당권자가 담보물보충청구권을 행사하는 경우에는 손해배상청구권이나 기한의 이익상실로 인한 즉시변제청구권을 행사할 수 없다(통설).
- ① 이미 피담보채무가 변제되었음에도 불구하고 선순위의 저당권등기가 말소되지 않고 있는 경우에 서와 같이 법률상 무효이지만 사실상 저당권의 실행 또는 양도에 장애를 받는 경우에, 저당권자는 방해제거청구로 그 등기의 말소를 청구할 수 있다(제370조, 제214조).
- ② 등기는 물권의 효력발생 요건이고 효력존속 요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다(대법원 1982.9.14. 81다카923).
- ④ 제388조 정답: ③

저당권의 침해에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 저당권이 설정된 임야의 수목이 부당하게 벌채·반출된 경우, 저당권자는 자신에게 수목의 반환을 청구할 수 있다.
- ② 선순위저당권이 소멸된 경우, 후순위저당권자는 선순위저당권의 말소등기를 청구할 수 있다.
- ③ 제3자가 저당권의 목적물을 손상시켜도 나머지 부분의 가액이 피담보채권을 담보하기에 충분한 경우에는 저당권자는 그 제3자에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.
- ④ 저당권설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에는 저당권자는 원상회복 또는 상당한 담보제공을 청구할 수 있다.
- ⑤ 특별한 사정이 없는 한 저당 토지의 지상권자가 통상의 용법에 따라 토지를 사용·수익하는 경우, 저당권 침해에 해당하지 않는다.

해설

- ① 저당산림의 수목을 부당하게 벌채하여 저당물의 가격을 감소시키는 때에는, 그 벌채행위의 중지 및 벌채한 수목(목재)의 반출 금지를 청구할 수 있다. 이 경우 벌채된 수목(목재)이 목적부동산 위에 존속하고 있는 이상 그 위에 저당권의 효력은 계속 미친다. 다만, 이미 반출된 경우에는 저당권의 효력은 미치지 못하고, 또 저당권자는 반환청구권이 없으므로 반출된 재목의 반환청구도 할 수 없다. 정답: ①

저당권의 우선변제와 관련된 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 저당권자는 저당부동산에 대하여 설정자의 일반채권자가 강제집행하는 것을 막지 못한다.
- ② 선순위저당권자의 변제에 총당하고 남는 것(잉여)이 없다면 후순위저당권자의 경매청구는 허용되지 않는다.
- ③ 저당목적물의 소유자가 체납하고 있는 국세는 그 법정기일 전에 설정된 저당채권에 우선하지 못한다.
- ④ 저당목적물에 부과된 국세는 그 법정기일 전에 설정된 저당채권에 언제나 우선한다.
- ⑤ 저당권자는 저당권과 관계없이 채무자의 일반재산에 대해 일반채권자로서 채무명의를 얻어 집행할 수는 없다.

해설

- ⑤ 채무자의 일반재산에 대한 집행, 즉 저당부동산의 경매대금으로부터 우선변제를 받았으나, 피담보채권이 완전히 변제되지 않은 경우 잔액채권은 무담보의 채권으로 남는다. 또한 저당권자는 자신의 저당권을 실행함이 없이 먼저 채무자의 일반재산에 대하여 일반채권자로서 집행할 수 있다. 다만, 일반채권자는 먼저 저당부동산의 경매를 통하여 변제를 받도록 이익을 제기할 수 있다.
- ① 타당한 기술이다.
- ② 訴의 이익이 없기 때문에 후순위저당권자의 경매청구는 허용되지 않는다.
- ③ ④ 저당권과 국세우선권과의 관계에서 저당권설정등기와 조세채권의 법정기일, 예컨대 신고납부방식의 국세에 있어서는 신고일, 납세고지서 등으로 징수되는 국세에 있어서는 그 고지서 등의 발송일 등의 경우는 그 선후에 의하여 정하여진다. 다만, 그 저당물에 부과된 당해 국세, 예컨대 상속세, 증여세 등과 가산금은 그 법정기일 전에 설정된 저당권에 대하여도 항상 우선한다(국세기본법 제35조 제1항 제3호). 정답: ⑤

46

저당부동산의 제3취득자에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 저당부동산의 제3취득자는 저당부동산에 소유권, 지상권, 전세권을 취득한 자를 말하는데 만약 저당권이 실행되어 경락되면 제3취득자는 불안한 지위에 놓이게 되므로 제3취득자는 경매인이 될 수 있고, 또 적극적으로 피담보채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있도록 민법은 규정하고 있다.
- ② 피담보채권의 변제기에 관계없이, 그 부동산으로 담보된 채권만을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ③ 위 부동산을 양수할 때 피담보채무액을 매매대금에서 공제하기로 약정하였다면, 특별한 사정이 없는 한 이행인수가 있었다고 보아야 한다.
- ④ 저당부동산의 제3취득자는 채무자의 의사에 반해서도 채무를 변제할 수 있다.
- ⑤ 물상보증의 목적물인 저당부동산의 제3취득자가 저당권의 실행으로 저당물의 소유권을 잃을 때에는 물상보증인의 구상권에 관한 민법 제370조, 제341조의 규정을 유추적용하여 보증채무에 관한 규정에 의하여 채무자에 대한 구상권이 있다.

해설

② 근저당 부동산의 제3취득자는 민법 제364조에 의하여 결산기에 이르러 확정되는 피담보채무를 변제하고 근저당권 설정등기의 말소를 구할 수 있으나, 근저당권 설정계약 종료전에 이를 해지하고 그 당시까지의 채무만을 변제하는 조건으로 그 말소를 구할 수는 없다(대법원 1979.8.21. 79다783).

① 제363조, 제364조

③ 대법원 2002.5.10. 2000다18578

④ 저당부동산의 제3취득자는 저당채무가 변제되면 저당권이 소멸하여 저당목적물에 대한 자신의 권리를 보전할 수 있는 지위에 있기 때문에 '이해관계 있는 제3자'에 해당한다. 따라서 저당부동산의 제3취득자는 채무자의 의사에 반해서 채무를 변제할 수 있다(제469조 제2항). 정답: ②

47

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 저당부동산에 대한 압류 후에는 저당권설정자의 저당부동산에 관한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다.
- ② 저당목적물의 변형물에 대하여 이미 제3자가 압류하였더라도 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않으면 물상대위권을 행사할 수 없다.
- ③ 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.
- ④ 저당권의 효력은 원칙적으로 저당부동산에 부합된 물건에 미친다.
- ⑤ 저당부동산에 대하여 지상권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.

해설

② 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있다(대법원 2010.10.28. 2010다46756). 정답: ②

저당권의 효력이 미치는 목적물의 범위에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 공인중개사]

- ① 당사자는 설정계약으로 저당권의 효력이 종물에 미치지 않는 것으로 정할 수 있다.
- ② 저당권의 목적 토지가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 협의 취득된 경우, 저당권자는 그 보상금청구권에 대해 물상대위권을 행사할 수 없다.
- ③ 건물 소유를 목적으로 토지를 임차한 자가 그 토지 위에 소유하는 건물에 저당권을 설정한 경우 건물 소유를 목적으로 한 토지 임차권에도 저당권의 효력이 미친다.
- ④ 저당목적물의 변형물인 금전에 대해 이미 제3자가 압류한 경우 저당권자는 물상대위권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 저당부동산에 대한 압류 이후의 저당권설정자의 저당부동산에 관한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다.

해설

- ④ 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있다(대법원 2010.10.28. 2010다46756). 정답: ④

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당물의 소유권을 취득한 제3자는 경매인이 될 수 없다.
- ② 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조하고 소유한 경우, 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다.
- ③ 저당부동산에 대하여 저당권에 기한 압류가 있으면, 압류 이후의 저당권설정자의 저당 부동산에 관한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다.
- ④ 저당부동산에 대하여 지상권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ⑤ 저당권설정자의 책임 있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에는 저당권자는 저당권설정자에 대하여 그 원상회복 또는 상당한 담보제공을 청구할 수 있다.

해설

- ① 저당물의 소유권을 취득한 제3자도 경매인이 될 수 있다. 정답: ①

50

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.
- ② 저당물의 소유권을 취득한 제3자는 그 저당물에 관한 저당권 실행의 경매절차에서 경매인이 될 수 있다.
- ③ 특별한 사정이 없는 한 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다.
- ④ 전세권을 목적으로 한 저당권이 설정된 후 전세권이 존속기간 만료로 소멸된 경우, 저당권자는 전세금반환채권에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 저당목적물의 변형물인 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 물건이 특정된 경우에도 저당권자는 스스로 이를 압류하여야 물상대위권을 행사할 수 있다.

해설

- ⑤ 저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있다(대법원 2010.10.28. 2010다46756). 정답: ⑤

51

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2020' 감정평가사]

- ① 저당권의 효력은 천연과실뿐만 아니라 법정과실에도 미친다.
- ② 저당권으로 담보된 채권을 양수하였으나 아직 대항요건을 갖추지 못한 양수인도 저당권이 전의 부기등기를 마치고 저당권실행의 요건을 갖추면 경매를 신청할 수 있다.
- ③ 후순위담보권자가 경매를 신청한 경우, 선순위근저당권의 피담보채권은 매수인이 경락대금을 완납하여 그 근저당권이 소멸하는 때에 확정된다.
- ④ 저당권의 이전을 위하여 저당권의 양도인과 양수인, 그리고 저당권설정자 사이의 물권적 합의와 등기가 있어야 한다.
- ⑤ 공동저당관계의 등기를 공동저당권의 성립요건이나 대항요건이라고는 할 수 없다.

해설

- ④ 저당권의 이전은 저당권의 양도인과 양수인의 물권적 합의와 등기(부기등기)가 있어야 한다.

정답: ④

52 근저당에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 근저당권은 장래의 증감변동하는 불특정의 채권을 담보한다는 점과 일시적으로 채무전액이 변제되더라도 근저당권이 소멸되지 아니한다는 점에서 부종성을 일반 저당권에 비하여 부종성을 완화하고 있다.
- ② 근저당권은 원래 피담보채권이 불특정이므로 채권 최고액을 증액한다 하더라도 피담보채권 자체의 변경이 있는 것은 아니다.
- ③ 채권의 최고액은 보통의 저당권에 있어서 채권액에 상당하는 것이므로 이를 등기로 공시하지 않더라도 제3자에게 대항할 수 있다.
- ④ 근저당권에 의하여 담보되는 채권이 전부 소멸하고 채무자가 채권자와의 거래를 계속할 의사가 없는 경우에는 근저당권의 기본계약상 결산기가 도래하지 않았다 하더라도 근저당권 설정자는 기본계약을 해지하고 근저당권의 말소를 구할 수 있다.
- ⑤ 피담보채권과 분리하여 근저당권만의 양도는 허용되지 않고 피담보채권이 없는 근저당권의 양도는 무효이다.

해설

- ③ 근저당권의 설정등기를 하기 위해서는 채권 최고액과 채무자를 기재하여야 한다.
- ① 제357조
- ④ 대법원 2001.11.9. 2001다47528 정답: ③

53 근저당권에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 근저당권의 실행비용은 채권최고액에 포함되지 아니한다.
- ② 채권최고액이란 우선변제를 받을 수 있는 한도액을 의미하고, 책임의 한도액을 의미하는 것은 아니다.
- ③ 피담보채권이 확정되기 전에 제3자가 채무의 일부를 대위변제하여도 근저당권이 그 제3자에게 이전하지 않는다.
- ④ 근저당권의 피담보채권이 확정되었을 경우, 확정 이후에 새로운 거래관계에서 발생한 원본 채권은 그 근저당권에 의하여 담보되지 않는다.
- ⑤ 확정된 피담보채권액이 채권최고액을 초과하는 경우에 채무자는 채권최고액만을 변제하고 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.

해설

- ⑤ 원래 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보하는 것이며, 채권최고액의 정함이 있는 근저당권에 있어서 이러한 채권의 총액이 그 채권최고액을 초과하는 경우, 적어도 근저당권자와 채무자 겸 근저당권설정자와의 관계에 있어서는 위 채권 전액의 변제가 있을 때까지 근저당권의 효력은 채권최고액과는 관계없이 잔존채무에 여전히 미친다(대법원 2001.10.12. 2000다59081). 그러나 경매부동산을 매수한 제3취득자나 물상보증인은 채권 최고액과 경매비용만을 변제공탁하고 근저당권의 소멸을 구할 수 있다(대법원 1971.4.6., 71다26). 정답: ⑤

- ① 채무자가 아닌 제3자도 근저당권을 설정할 수 있다.
- ② 채권자가 아닌 제3자 명의의 근저당권설정등기는 특별한 사정이 없는 한 무효이다.
- ③ 근저당권에 의해 담보될 채권최고액에 채무의 이자는 포함되지 않는다.
- ④ 근저당권설정자가 적법하게 기본계약을 해지하면 피담보채권은 확정된다.
- ⑤ 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우에는 경매신청시에 피담보채권액이 확정된다.

해설

- ③ 이자는 최고액 속에 산입된 것으로 보게 되므로 원본과 이자를 합한 것이 최고액을 넘으면 그 초과부분은 담보되지 못한다. 정답: ③

- ① 근저당권의 피담보채무가 확정되기 이전에는 채무자를 변경할 수 없다.
- ② 근저당권의 확정 전에 발생한 원본채권으로부터 그 확정 후에 발생하는 이자는 채권최고액의 범위 내에서 여전히 담보된다.
- ③ 선순위근저당권자가 경매를 신청하는 경우, 후순위근저당권의 피담보채권의 확정시기는 경매개시결정시이다.
- ④ 근저당권의 존속 중에 피담보채권이나 기본계약과 분리하여 근저당권만을 양도할 수도 있다.
- ⑤ 채권의 총액이 채권최고액을 초과하는 경우, 채무자겸 근저당권설정자는 근저당권의 확정 전이라도 채권최고액을 변제하고 근저당권의 말소를 청구할 수 있다.

해설

- ② 근저당권자의 경매신청 등의 사유로 인하여 근저당권의 피담보채권이 확정되었을 경우, 확정 이후에 새로운 거래관계에서 발생한 원본채권은 그 근저당권에 의하여 담보되지 아니하지만, 확정 전에 발생한 원본채권에 관하여 확정 후에 발생하는 이자나 지연손해금 채권은 채권최고액의 범위 내에서 근저당권에 의하여 여전히 담보되는 것이다(대법원 2007.04.26. 2005다38300).
- ① 근저당권은 당사자 사이의 계속적인 거래관계로부터 발생하는 불특정채권을 어느 시기에 계산하여 잔존하는 채무를 일정한 한도액 범위 내에서 담보하는 저당권으로서 보통의 저당권과 달리 발생 및 소멸에 있어 피담보채무에 대한 부종성이 완화되어 있는 관계로 피담보채무가 확정되기 이전 이라면 채무의 범위나 또는 채무자를 변경할 수 있고, 채무의 범위나 채무자가 변경된 경우에는 당연히 변경 후의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권만이 당해 근저당권에 의하여 담보되고, 변경 전의 범위에 속하는 채권이나 채무자에 대한 채권은 그 근저당권에 의하여 담보되는 채무의 범위에서 제외된다(대법원 1999.05.14. 97다15777·15784).
- ③ 선순위근저당권자가 경매를 신청하는 경우, 후순위근저당권의 피담보채권의 확정시기는 경매의 매수인이 매각대금을 모두 지급한 때에 확정된다.
- ④ 근저당권은 피담보채권과 함께 양도될 수 있으며, 피담보채권과 분리하여 양도할 수는 없다.
- ⑤ 근저당권자의 채권액이 채권최고액을 초과하는 경우, 근저당권자와 그 채무자 겸 근저당권설정자 사이에서는 채권최고액 등 그 채권 일부의 변제가 있더라도 채권 전액의 변제가 있을 때까지 근저당권의 효력이 잔존채무에 미친다(대법원 2010.05.13. 2010다3681). 정답: ②

- ① 동일한 채권의 담보를 위해 복수의 부동산에 저당권이 설정된 경우 각 부동산의 수만큼의 저당권이 존재한다.
- ② 공동저당권의 목적물 전부를 경매하여 동시에 배당하는 경우 각 부동산의 경매대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정한다.
- ③ 공동저당권 설정계약시에 포함된 목적물에 대해서만 저당권이 성립하며 저당권설정계약 후 추가로 공동저당에 편입시킬 수 없다.
- ④ 여러 개의 목적물에 성립되는 공동저당권은 각각의 저당 목적물마다 그 소유자가 다르거나 그 저당권의 순위가 다르더라도 무방하다.
- ⑤ 공동저당권의 목적물의 순차(異時)배당시 경매된 부동산의 차순위 저당권자는 선순위 저당권자가 동시에 배당했다면 다른 부동산의 경매대가에서 변제받을 수 있는 금액의 한도에서 선순위자를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다.

해설

- ③ 저당권설정 후에 추가로 공동저당에 포함시키는 것을 추가저당이라고 하며, 저당권설정 후에 추가로 공동저당에 편입시킬 수 있다.
- ① 공동저당이란 동일한 채권의 담보로서 수개의 부동산 위에 설정된 수개의 저당권을 말한다. 공동저당은 수개의 부동산 위에 하나의 저당권이 설정되는 것이 아니라, 각각의 목적물마다 하나의 저당권이 설정된다. 다만, 피담보채권을 공통으로 한다는 점에서 복수의 저당권은 일정한 제약을 받는다는 특색이 있다.
- ② 동시배당에 있어서의 부담의 안분으로 부동산의 일괄경매로 경매 대가를 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매대가에 비례하여 그 채권의 분담을 정한다(제368조 제1항). 즉, 동시배당의 경우에 공동저당권자는 어느 부동산으로부터 변제를 받더라도 상관없기 때문이다.
- ④ 공동저당은 각 저당권이 동시에 설정될 필요가 없으며, 추가담보도 가능하다. 또한 목적물의 전부·일부가 타인소유라도 상관없으며, 순위도 같을 필요가 없다. 그리고 공동저당의 목적물은 보통의 저당권의 목적물과 같다.
- ⑤ 순차(이시)배당에 있어서의 후순위저당권자의 대위로서 저당부동산 중 일부의 경매대가를 먼저 배당하는 경우에는 그 대가에서 그 채권 전부의 변제를 받을 수 있다(제368조 제2항 1문). 이 경우에 그 경매한 부동산의 차순위 저당권자는 동시에 배당하였다면 다른 부동산의 경매대가에서 변제를 받을 수 있는 금액의 한도에서 선순위자를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다(제368조 제2항 2문). 정답: ③

57

근저당권에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㉠ 피담보채무의 확정 전 채무자가 변경된 경우, 변경 후의 채무자에 대한 채권만이 당해 근저당권에 의하여 담보된다.
- ㉡ 근저당권의 존속기간이나 결산기의 정함이 없는 경우, 근저당권설정자는 근저당권자를 상대로 언제든지 해지의 의사표시를 함으로써 피담보채무를 확정시킬 수 있다.
- ㉢ 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우, 경매신청시에 근저당권이 확정된다.
- ㉣ 선순위 근저당권의 확정된 피담보채권액이 채권최고액을 초과하는 경우, 후순위 근저당권자가 선순위 근저당권의 채권최고액을 변제하더라도 선순위 근저당권의 소멸을 청구할 수 없다.

① ㉠, ㉡

② ㉡, ㉢

③ ㉡, ㉣

④ ㉠, ㉢, ㉣

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

해설

⑤ 모두 타당한 기술이다. 정답: ⑤

58

근저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

[2022' 감정평가사]

- ① 근저당권의 존속기간이나 결산기를 정한 경우, 원칙적으로 결산기가 도래하거나 존속기간이 만료한 때에 그 피담보채무가 확정된다.
- ② 근저당권의 존속기간이나 결산기를 정하지 않고 피담보채권의 확정방법에 관한 다른 약정이 없는 경우, 근저당권설정자는 근저당권자를 상대로 언제든지 계약 해지의 의사표시를 하여 피담보채무를 확정시킬 수 있다.
- ③ 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우, 경매신청시에 근저당권의 피담보채권액이 확정된다.
- ④ 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우, 선순위 근저당권의 피담보채권은 매수인이 매각 대금을 완납한 때에 확정된다.
- ⑤ 공동근저당권자가 저당목적 부동산 중 일부 부동산에 대하여 제3자가 신청한 경매절차에 소극적으로 참가하여 우선배당을 받은 경우, 특별한 사정이 없는 한 나머지 저당목적 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권도 확정된다.

해설

⑤ 공동근저당권자가 목적 부동산 중 일부 부동산에 대하여 제3자가 신청한 경매절차에 소극적으로 참가하여 우선배당을 받은 경우, 해당 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 매수인이 매각대금을 지급한 때에 확정되지만, 나머지 목적 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권은 기본거래가 종료하거나 채무자나 물상보증인에 대하여 파산이 선고되는 등의 다른 확정사유가 발생하지 아니하는 한 확정되지 아니한다(대법원 2017. 9. 21. 2015다 50637). 정답: ⑤

- ① 근저당권의 물상보증인은 확정된 채무액이 채권최고액을 초과하더라도 특별한 사정이 없는 한 채권최고액만을 변제하고 근저당권설정등기의 말소청구를 할 수 있다.
- ② 근저당권에 존속기간이나 결산기의 정함이 없는 경우, 근저당권설정자는 근저당권자에 대한 해지의 의사표시로서 피담보채권을 확정시킬 수 없다.
- ③ 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우, 선순위 근저당권의 피담보채권은 후순위 근저당권자의 경매신청시에 확정된다.
- ④ 근저당권의 피담보채권 확정 전에 발생한 원본채권에 관하여 확정 후에 발생하는 이자나 지연손해금 채권은 채권최고액의 범위 내 일지라도 근저당권에 의하여 담보되지 않는다.
- ⑤ 근저당권의 피담보채권이 확정되기 전에 채권의 일부가 대위변제된 경우, 근저당권의 일부 이전의 부기등기 여부와 관계없이 근저당권은 대위변제자에게 법률상 당연히 이전된다.

해설

- ① 근저당권의 물상보증인은 민법 제357조에서 말하는 채권의 최고액만을 변제하면 근저당권설정등기의 말소청구를 할 수 있고 채권최고액을 초과하는 부분의 채권액까지 변제할 의무가 있는 것이 아니다.
- ② 존속기간이나 결산기의 정함이 없는 때에는 근저당권의 피담보채무의 확정방법에 관한 다른 약정이 없는 경우라면 근저당권설정자가 근저당권자를 상대로 언제든지 해지의 의사표시를 함으로써 피담보채무를 확정시킬 수 있다.
- ③ 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우 선순위 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 경락인이 경락대금을 완납한 때에 확정된다(대법원 1999.09.21. 99다2608).
- ④ 근저당권자의 경매신청 등의 사유로 인하여 근저당권의 피담보채권이 확정되었을 경우, 확정 이후에 새로운 거래관계에서 발생한 원본채권은 그 근저당권에 의하여 담보되지 아니하지만, 확정 전에 발생한 원본채권에 관하여 확정 후에 발생하는 이자나 지연손해금 채권은 채권최고액의 범위 내에서 근저당권에 의하여 여전히 담보되는 것이다(대법원 2007.04.26. 2005다38300).
- ⑤ 저당권의 이전은 부기등기가 있어야 한다. 정답: ①

A는 X로부터 6,000만 원을 차용한 후 자신의 甲 토지(시가 6,000만 원)와 乙 토지(시가 4,000만 원)에 공동저당권을 설정하였다. 그 후 甲 토지에는 B가 2,400만 원의 저당권을, 乙 토지에는 C가 1,600만 원의 후순위저당권을 설정하였다. 그 후 A는 X에게 차용금을 변제하지 못하여 甲 토지와 乙 토지 모두가 경매에 붙여져서 전부의 대가를 동시에 배당하는 경우, X는 (㉠)을 배당받게 되며, B는 (㉡), C는 (㉢)을 배당받게 된다. 빈칸에 들어갈 가액은?

- ① ㉠ 甲 토지로부터 3,600만 원, 乙 토지로부터 2,400만 원 ㉡ 甲 토지로부터 2,400만 원 ㉢ 乙 토지로부터 1,600만 원
- ② ㉠ 甲 토지로부터 6,000만 원 ㉡ 0원 ㉢ 乙 토지로부터 1,600만 원
- ③ ㉠ 甲 토지로부터 6,000만 원 ㉡ 乙 토지로부터 2,400만 원 ㉢ 乙 토지로부터 1,600만 원
- ④ ㉠ 甲 토지로부터 3,600만 원 ㉡ 甲 토지로부터 2,400만 원 ㉢ 0원
- ⑤ ㉠ 甲 토지로부터 3,600만 원 乙 토지로부터 2,400만 원 ㉡ 乙 토지로부터 2,400만 원 ㉢ 0원

해설

- ① 공동저당권의 목적물을 전부 경매하여 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매대가에 비례하여 피담보채권액을 안분한다(제368조 제1항).

■ X의 배당액

$$\text{甲토지 } 6,000\text{만 원} \times \frac{6}{6+4} = 3,600\text{만 원}$$

$$\text{乙토지 } 6,000\text{만 원} \times \frac{4}{6+4} = 2,400\text{만 원}$$

■ B와 C의 배당액

B는 甲토지에서 남은 경락대금 2,400만 원 배당

C는 乙토지에서 남은 경락대금 1,600만 원 배당 정답: ①

61

갑은 을에 대한 자신의 채권을 담보하기 위하여 을의 토지 A(시가 3000만 원), 병의 토지 B(시가 2000만 원), 정희의 토지 C(시가 1000만 원)에 대하여 각각 1번 근저당권(채권최고액 3000만 원)을 설정하였다. A토지에 대하여는 2번 근저당권(채권최고액 2000만 원)이 존재한다. 그런데 갑은 A토지만을 경매하여 전액을 선순위자로 배당받아 갔다. 이 경우 A토지의 2번 근저당권자는 얼마의 범위에서 B토지에 대해 갑을 대위하여 저당권을 행사할 수 있는가? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 500만 원 ② 1000만 원 ③ 0원(대위하여 저당권을 행사할 수 없다)
④ 2000만 원 ⑤ 1500만 원

해설

- ③ 채무자소유의 부동산에 대하여 먼저 경매한 경우, 채무자소유 부동산의 후순위저당권자는 물상보증인 소유의 부동산에는 대위권이 미치지 않는다.

위 예에서 A토지에 대한 2번 저당권자는 갑을 대위하여 병, 정희에 대하여 대위를 주장할 수 없다(대법원 1995.6.13. 95마500). 정답: ③

62

甲은 乙에 대한 5,000만 원의 채권을 담보하기 위하여 A부동산(시가 6,000만 원)과 B부동산(시가 4,000만 원)에 공동저당권을 가지고 있다. A부동산에는 2번저당권자 丙(피담보채권액 4,000만 원)이 있고, B부동산에는 2번저당권자 丁(피담보채권액 3,000만 원)이 있다. 이 경우 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① A, B 모두 채무자 乙의 소유인데, 동시배당되는 경우 丁은 2,000만 원의 배당을 받는다.
- ② 위 ①의 경우, A의 저당권이 먼저 실행된 경우 丙은 B로부터 2,000만 원의 배당을 받을 수 있다.
- ③ A는 乙의 소유이고, B는 물상보증인 戊의 소유인데, A의 저당권이 먼저 실행된 경우, 丙은 B로부터 배당을 받을 수 있다.
- ④ 위 ③의 경우, B의 저당권이 먼저 실행된 경우 戊는 변제자대위에 의하여 A에 대한 1번저당권을 취득한다.
- ⑤ 위 ④의 경우, 丁은 A로부터 3,000만 원의 배당을 받을 수 있다.

해설

③④⑤ 채무자소유 부동산(A)의 후순위저당권자(丙)는 물상보증인소유 부동산(B)에 대위할 수 없다. 이에 반하여 물상보증인(戊)은 채무자소유 부동산(A)에 대위할 수 있다. 결과적으로 물상보증인소유 부동산(B)의 후순위저당권자(丁)는 A부동산으로부터 자신의 피담보채권액인 3,000만 원을 배당받을 수 있다.

- ① 동시배당의 경우, 甲은 A로부터 3,000만 원, B로부터 2,000만 원의 배당을 받고, 丁은 B로부터 나머지 2,000만 원의 배당을 받는다.
- ② A가 먼저 배당되는 경우, 甲은 A로부터 5,000만 원은 배당받고, 후순위자 丙은 甲을 대위하여 B로부터 2,000만 원을 배당받을 수 있다. 정답: ③

63

甲은 乙에 대한 2억 원의 채권을 담보하기 위하여 乙 소유 X토지와 Y건물에 대하여 각각 1번 공동저당권을 취득하였다. 그 후 丙은 乙에 대한 1억 6천만 원의 채권을 담보하기 위하여 X에 대하여 2번 저당권을, 丁은 乙에 대한 7천만 원의 채권을 담보하기 위하여 Y에 대하여 2번 저당권을 취득하였다. 그 후 丙이 경매를 신청하여 X가 3억 원에 매각되어 배당이 완료되었고, 다시 丁이 경매를 신청하여 Y가 1억 원에 매각되었다. 丁이 Y의 매각대금에서 배당받을 수 있는 금액은? (단, 경매비용 · 이자 등은 고려하지 않으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

[2021' 감정평가사]

- ① 0원 ② 3,500만원 ③ 4,000만원 ④ 5,000만원 ⑤ 7,000만원

해설

④ 공동저당의 목적물 중 일부만이 경매되어 그 대가를 먼저 배당하는 때에는 공동저당권자는 전액 변제를 받을 수 있으나, 그 부동산의 후순위저당권자는 선순위저당권자가 동시배당을 하였더라면 다른 부동산의 경매대금에서 변제받을 수 있었던 한도에서 선순위를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다(제368조 제2항). 정답: ④

64 가등기담보 등에 관한 법률에 관하여 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 동법은 매매대금채권을 담보하기 위하여 경료된 양도담보에도 적용된다.
- ② 동법은 가등기담보 채권자에게 저당권자와 유사한 지위를 인정하는 한편, 이른바 귀속청산의 방법도 규정한다.
- ③ 귀속청산의 경우에, 변제기가 경과하더라도 채권자가 곧바로 담보를 실행할 수는 없으며, 변제기 후 일정한 기간(청산기간)이 경과하여야 비로소 담보를 실행할 수 있다.
- ④ 채권담보의 목적으로 소유권이전등기가 경료된 경우에도 청산기간이 경과하고 청산금을 지급하지 않는 한, 그에게 대내외적으로 소유권 취득의 효과가 발생하지 않는다.
- ⑤ 귀속청산의 경우에 후순위권리자는 가등기담보권자가 채무자에게 지급하여야 할 청산금에 대하여 권리를 행사할 수 있다.

해설

- ① 가등기담보 등에 관한 법률은 차용물의 반환(금전소비대차나 준소비대차)에 관하여 다른 재산권을 이전할 것을 예약한 경우에 적용되는 것이므로, 공사잔대금의 지급이나 매매대금을 담보하기 위하여 체결된 양도담보계약에 기하여 소유권이전등기를 구하는 경우에는 같은 법이 적용되지 않는다(대법원 1996.11.15. 96다31116, 대법원 2002.12.24. 2002다50484, 대법원 2004.4.27. 2003다29968). 정답: ①

65 다음 중 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 담보가등기가 경료된 경우에 담보물에 대한 사용·수익권은 가등기담보의 설정자인 소유자에게 있으나, 이러한 사용·수익권은 청산절차의 종료와 함께 채권자에게 이전된다.
- ② 담보가등기가 경료된 부동산에 대하여 경매가 행하여진 경우에 담보가등기권리는 그 부동산의 매각에 의하여 소멸된다.
- ③ 동산양도담보의 공시방법으로서의 인도는 점유개정의 방법에 의하더라도 상관없다.
- ④ 돼지를 양도담보의 목적으로 한 경우에 반대의 특약이 없는 한, 천연과실인 새끼돼지에 대해서도 양도담보의 효력이 미친다.
- ⑤ 양도담보의 피담보채권은 장래의 채권일 수 있다.

해설

- ④ 돼지를 양도담보의 목적물로 하여 소유권을 양도하되 점유개정의 방법으로 양도담보설정자가 계속하여 점유·관리하면서 무상으로 사용·수익하기로 약정한 경우, 양도담보목적물로서 원물인 돼지가 출산한 새끼 돼지는 천연과실에 해당하고 그 천연과실의 수취권은 원물인 돼지의 사용·수익권을 가지는 양도담보설정자에게 귀속하므로, 다른 특별한 약정이 없는 한 천연과실인 새끼돼지에 대하여는 양도담보의 효력이 미치지 않는다고 본다(대법원 1996.9.10. 96다25463). 정답: ④

甲 은행은 乙에게 대출을 해주면서 그 담보로 乙이 양식하고 있는 양식장 내의 뱀장어에 대한 양도담보를 설정하였다. 그런데 乙은 어린 뱀장어가 성어가 된 경우에는 수시로 내다 팔고, 또 수시로 어린 뱀장어를 양식장에 넣어 왔다. 이 경우에 관한 설명으로 가장 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 뱀장어에 변동이 있더라도 양도담보권은 현재의 뱀장어 전부에 미친다.
- ② 증감 변동하는 물건에 대해 설정한 양도담보이므로 무효이다.
- ③ 1물1권주의에 위배되어 양도담보는 무효로 된다.
- ④ 양도담보설정 당시의 뱀장어에 대하여는 유효하지만 현재의 뱀장어에 대하여는 양도담보권이 무효로 된다.
- ⑤ 목적물이 특정되지 않았기 때문에 양도담보는 무효로 된다.

해설

- ① ② 일반적으로 일단의 증감·변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼으려는 이른바 집합물에 대한 양도담보설정계약체결도 가능하며 이 경우 그 목적부동산이 담보설정자의 다른 물건과 구별될 수 있도록 그 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법에 의하여 특정되어 있으면 그 전부를 하나의 재산권으로 보아 이에 유효한 담보권의 설정이 된 것으로 볼 수 있다. 특히 양도담보계약서 중 양도물건목록에 소재지, 보관창고명과 목적물이 양식장 내 뱀장어, 수량 약 백만 마리라고 기재되어 있을 뿐이고 특별히 위 양식장 내의 뱀장어 중 백만 마리로 그 수량을 지정하여 담보의 범위를 제한한 사실이 인정되지 않는다면 위 양도담보계약서에 기재된 수량은 단순히 위 계약 당시 위 양식장 내에 보관하고 있던 뱀장어 등의 수를 개략적으로 표시한 것에 불과하고 당사자는 위 양식장 내의 뱀장어 등 어류 전부를 그 목적으로 하였다고 봄이 당사자의 의사에 합치된다고 할 것이다(대법원 1990.12.26. 88다카20224).
- ⑤ 성장을 계속하는 어류일지라도 특정 양식장 내의 뱀장어 등 어류 전부에 대한 양도담보계약은 그 담보목적물이 특정되었으므로 유효하게 성립하였다고 할 것이다.
- ③ ④ 결국 집합물에 대한 양도담보권설정계약이 이루어지면 그 집합물을 구성하는 개개의 물건이 변동되거나 변형되더라도 한 개의 물건으로서 동일성을 잃지 아니하므로 양도담보권의 효력은 항상 현재의 집합물 위에 미치는 것이고, 따라서 양도담보권자가 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물 위에 미치는 것이고, 따라서 양도담보권자가 담보권설정계약 당시 존재하는 집합물을 점유개정의 방법으로 그 점유를 취득하면 그 후 양도담보설정자가 그 집합물을 이루는 개개의 물건을 반입하였다 하더라도 그 때마다 별도의 양도담보설정계약을 맺거나 점유개정의 표시를 하여야 하는 것은 아니다. 정답: ①

비전형담보에 대한 현재의 판례이론과 일치하지 않는 것은?

- ① 가등기담보 등에 관한 법률의 적용범위를 좁게 인정하여 피담보채권이 소비대차, 준소비대차에 의하여 발생한 경우를 규율하며 이때 담보의 목적물 가액이 차용액과 이자의 합산액을 넘지 않는 경우에 한하여 적용한다.
- ② 가등기담보 등에 관한 법률의 규정에 따른 청산절차진행 전에 신청된 강제경매에 의하여 제3자에게 소유권이 이전된 경우 담보가등기권자는 더 이상 위 가등기에 기하여 본등기를 청구할 수 없다.
- ③ 동산의 매매계약을 체결하면서 소유권유보의 계약을 한 경우 목적물이 매수인에게 인도되었다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 매도인은 대금이 모두 지급될 때까지 매수인 뿐만 아니라 제3자에 대하여 유보된 목적물의 소유권을 주장할 수 있다
- ④ 특정 양식장 내의 뱀장어 등 어류 전부에 대한 양도담보계약도 유효하게 성립할 수 있다.
- ⑤ 약한 의미의 양도담보가 이루어진 경우 채무의 변제기가 경과한 후라고 하더라도 채권자가 담보권을 실행하여 청산절차를 마치기 전에는 채무자가 언제든지 채무를 변제하고 채권자에게 가등기 및 가등기에 기하여 이루어진 본등기의 말소를 청구할 수 있다.

해설

- ① 가등기담보 등에 관한 법률은 소비대차에 따른 채권을 담보하기 위해 대물변제의 예약을 하고 나아가 그 담보의 목적으로 가등기 내지는 소유권이전등기를 한 경우만을 규제한다(동법 제1조). 판례도 이 이외에는 동법의 적용범위를 확대하지 않는다. 단순히 매매 잔대금채권을 담보하기 위하여 경료된 가등기에 기하여 본등기를 구하는 경우에는 가등기담보 등에 관한 법률은 적용되지 아니한다(대법원 1991.9.24. 90다13765). 또 가등기담보 등에 관한 법률은 재산권 이전의 예약에 의한 가등기담보에 있어서 그 재산의 예약 당시의 가액이 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 초과하는 경우에 한하여 그 적용이 있다(대법원 1993.10.26. 93다27611).
- ② 대법원 1992.2.11. 91다36932
- ③ 대법원 1999.9.7. 99다30534
- ④ 대법원 1990.12.26. 88다카20224
- ⑤ 대법원 1994.6.28. 94다3087·3094 정답: ①

68 가등기담보 등에 관한 법률에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 채권자가 담보권을 실행하여 담보부동산의 소유권을 취득하기 위해서는 원리금을 초과하는 청산금의 평가액을 채무자 등에게 통지하고 그 통지가 채무자 등에게 도달한 날로부터 2월이 경과하여야 한다.
- ② 채권자가 일단 청산금의 평가액을 통지한 후에는 그가 통지한 평가금의 수액에 관하여 다툴 수 없다.
- ③ 담보부동산에 관하여 이미 소유권이전등기가 경료된 경우에 채권자는 청산기간의 경과 후 청산금을 채무자에게 지급한 때에 목적부동산의 소유권을 취득한다.
- ④ 청산기간이 경과하기 전에는 채무자는 청산금에 관한 권리를 양도하거나 기타 처분할 수 없으며 처분하더라도 이로써 후순위권리자에게 대항하지 못한다.
- ⑤ 채무자 등은 청산금채권을 변제받을 때까지 그 채무액을 채권자에게 지급하고 그 채권담보의 목적으로 경료된 소유권이전등기의 말소를 청구할 수 있으나, 제3자가 소유권을 취득한 경우에는 그 제3자의 선의·악의를 불문하고 말소청구를 할 수 없다.

해설

- ⑤ 제3자가 악의인 경우에만 말소청구를 할 수 있다. 정답: ⑤

69 가등기담보에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 일반적으로 담보목적으로 가등기를 설정한 경우 담보물에 대한 사용수익권은 가등기설정자인 소유자에게 있다.
- ② 가등기담보등에 관한 법률에 따라서 청산절차가 종료되면 담보목적물에 대한 과실수취권은 청산절차의 종료와 함께 채권자에게 귀속된다.
- ③ 가등기담보 등에 관한 법률은 차용물의 반환에 관하여 다른 재산권을 이전할 것을 예약한 경우에 적용되는 것이므로, 공사잔대금의 지급을 담보하기 위하여 체결된 양도담보계약에 기하여 소유권이전등기를 구하는 경우에는 같은 법이 적용되지 않는다.
- ④ 가등기담보 등에 관한 법률 제3조 제4조를 위반하여 담보가등기에 기한 본등기가 이루어진 경우에는 그 본등기는 이른바 약한 의미의 양도담보로서 담보의 목적 내에서는 유효하다고 할 것이다.
- ⑤ 채권자가 가등기담보권을 실행하여 그 담보목적부동산의 소유권을 취득하기 위하여 채무자에게 담보권 실행을 통지하고 2월의 청산기간이 경과한 후에도 채무자는 정당하게 평가된 청산금을 지급받을 때까지 목적부동산의 소유권이전등기 및 인도채무의 이행을 거절하면서 피담보채무 전액과 그 이자 및 손해금을 지급하고 채권담보의 목적으로 경료된 가등기의 말소를 청구할 수 있다.

해설

- ④ 가등기담보 등에 관한 법률 제3조, 제4조의 각 규정에 비추어 볼 때 위 각 규정을 위반하여 담보가등기에 기한 본등기가 이루어진 경우에는 그 본등기는 무효라고 할 것이고, 설령 그와 같은 본등기가 가등기권리자와 채무자 사이에 이루어진 특약에 의하여 이루어졌다고 할지라도 만일 그 특약이 채무자에게 불리한 것으로서 무효라고 한다면 그 본등기는 여전히 무효일 뿐, 이른바 약한 의미의 양도담보로서 담보의 목적 내에서는 유효하다고 할 것이 아니다(대법원 1994.1.25. 92다20132).

①② 대법원 2001.2.27. 2000다20465

③ 대법원 1996.11.15. 96다31116

⑤ 대법원 1994.6.28. 94다3087 정답: ④

70 가등기담보권의 실행과 관련하여 잘못 설명한 것은?

- ① 가등기담보권자가 가등기담보권의 실행으로 소유권을 취득하려면 청산금의 평가액을 통지하여야 한다.
- ② 청산금은 실행통지 당시의 목적부동산의 가액에서 그 시점의 피담보채권액을 공제한 차액이다.
- ③ 가등기담보 등에 관한 법률은 청산방법으로서 처분청산방식과 귀속청산방식을 인정하고 있다.
- ④ 담보가등기 후에 성립한 대항력 있는 임차권을 취득한 자도 청산금의 범위 내에서 보증금의 반환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 청산금채권이 압류 또는 가압류된 경우에는 채권자는 청산기간이 경과한 후에 청산금을 법원에 공탁할 수 있다.

해설

- ① 가등기담보 등에 관한 법률 제4조 제1항 전단
- ② 동법 제3조 제1항 전단
- ③ 가등기담보 등에 관한 법률은 현재 청산방법으로 귀속청산방식을 취한다. 따라서 가등기담보권자는 청산금을 담보권설정자에게 지급하는 것과 상환으로 가등기에 기인한 본등기청구 및 목적물인도 청구를 할 수 있다(제4조 제3항).
- ④ 대항력 있는 임차권을 취득한 자에는 비록 그것이 담보가등기가 설정된 후에 취득되었더라도, 목적물의 인도 의무와 보증금의 반환 의무는 청산금의 범위 내에서 동시이행의 관계에 있다(제5조 제5항). 정답: ③

가등기담보권의 실행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 후순위권리자는 청산기간 내에 한하여 그 피담보채권의 변제기가 되기 전이라도 목적부동산의 경매를 청구할 수 있다.
- ② 채권자가 채무자에게 청산금을 통지하지 아니한 경우에도 청산금을 지급하고 등기를 마쳤다면 소유권을 취득할 수 있다.
- ③ 채권자는 사실실행의 방법으로 청산기간이나 동시이행관계를 인정하지 아니하는 처분정산형의 담보권 실행을 할 수 없다.
- ④ 목적부동산의 평가액이 채권액에 미달하여 청산금이 없다고 인정되는 때에는 채권자는 그 뜻을 채무자 등에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 압류등기 전에 이루어진 담보가등기권리가 매각에 의하여 소멸되면 경매법원에 채권신고를 한 경우에만 그 채권자는 매각대금을 배당받거나 변제금을 받을 수 있다.

해설

- ② 청산금의 통지는 채무자 등, 모두에게 하여야 하는 것으로서 채무자 등의 전부 또는 일부에 대하여 통지를 하지 않으면 청산기간이 진행할 수 없게 되고, 따라서 가등기담보권자는 그 후 적절한 청산금을 지급하였다 하더라도 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 없으며 양도담보의 경우에는 그 소유권을 취득할 수 없다(대법원 1995.4.28., 94다36162). 정답: ②

다음 중 비전형담보에 관한 설명으로서 옳지 않은 것은?

- ① 가등기담보의 피담보채권의 범위는 저당권의 그것(제360조)과 일치한다.
- ② 담보가등기가 저당권등기와 같은 공시적 기능을 함에도 불구하고 변제기, 이자 등에 대하여 제3자(특히 후순위담보권자)에게 대항하기 위하여 이를 등기할 수 있는 길이 없다.
- ③ 가등기담보 등에 관한 법률에 의한 가등기담보권의 실행에서 가등기담보권자가 소유권을 취득하는 시점은 청산을 마치고 담보가등기에 의한 소유권이전등기를 한 때이다.
- ④ 대물변제의 약정 등 담보계약은 있지만 아직 가등기 또는 소유권이전등기가 이루어지지 않은 경우, 판례는 가등기담보 또는 양도담보가 설정되기 전이라고 보고 가등기담보등에 관한 법률 소정의 담보권실행에 관한 규정(제3조)이 적용될 여지가 없고 채권자는 담보계약을 원인으로 가등기 또는 소유권이전등기를 청구할 수 있다고 한다.
- ⑤ 가등기담보 등에 관한 법률은 대물변제의 예약 당시 목적물의 시가가 채무원리금을 넘지 않더라도 적용된다.

해설

- ⑤ 가등기담보 등에 관한 법률은 재산권 이전의 예약에 의한 가등기담보에 있어서 그 재산의 예약 당시의 가액이 차용액 및 이에 붙인 이자의 합산액을 초과하는 경우에 한하여 그 적용이 있다 할 것이므로, 가등기담보부동산에 대한 예약 당시의 시가가 그 피담보채무액에 미치지 못하는 경우에 있어서는 같은 법 제3조, 제4조가 정하는 청산금평가액의 통지 및 청산금지급 등의 절차를 이행할 여지가 없다(대법원 1993.10.26. 93다27611). 정답: ⑤

73

가등기담보 등에 관한 법률이 적용되는 양도담보의 효력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 양도담보권의 피담보채권의 범위는 저당권에 의해 담보되는 채권의 범위에 관한 규정이 적용된다.
- ② 양도담보권자에게는 양도담보권에 기한 물상대위가 인정된다.
- ③ 양도담보권자가 담보목적 부동산을 임의로 처분한 경우, 그 부동산의 양수인이 선의이더라도 소유권을 취득하지 못한다.
- ④ 양도담보권자가 귀속청산의 방법에 의하여 확정적으로 소유권을 취득하려면 적법하게 청산 절차를 거쳐야 한다.
- ⑤ 양도담보권은 우선변제적 효력이 있다.

해설

- ③ 채무자 등은 청산금을 지급받을 때까지는 채무액을 양도담보권자에게 지급하고 이전등기의 말소를 청구할 수 있으나, 거래안전을 위하여 이전등기말소청구권을 제한할 수 있으며 그 제한사유는 '가등기담보 등에 관한 법률'의 규정을 적용한다. 따라서 채무의 변제기가 경과한 때로부터 10년이 경과하거나 또는 선의의 제3자가 소유권을 취득한 때에도 이전등기말소청구권은 소멸한다(가등기담보법 11조 단서 후단). 그러므로 양도담보권자가 담보목적 부동산을 임의로 처분한 경우, 그 부동산의 양수인이 선의인 경우에는 양수인이 그 소유권을 취득한다. 정답: ③

74

甲은 乙로부터 양돈업을 위한 자금을 차용하면서 乙에 대해 그 담보로서 자신의 돈사에서 대량으로 사육하고 있던 돼지를 점유개정의 방법에 따라 양도담보권을 설정해 주었다. 이에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

- ① 양도담보의 목적물인 돼지가 새끼 돼지를 출산한 경우 그 소유권은 양도담보설정자 甲에게 속한다.
- ② 甲이 사업의 악화로 돈사 내에 있던 돼지를 丙에게 처분하였으나 丙이 이를 선의취득 할 수 없는 경우 乙의 양도담보권은 여전히 그 돼지에 대해서는 미치나 丙이 별도의 자금을 투입하여 반입한 돼지에 대해서는 그렇지 않다.
- ③ 甲이 乙에게 양도담보권을 설정해 준 후 또 다시 丙으로부터 사업자금을 차용하면서 丙에 대해 점유개정의 방법에 의한 양도담보권을 설정해 준 경우 丙이 甲의 乙에 대한 담보권 설정사실을 알지 못하였더라도 丙은 양도담보권을 적법하게 취득하지 못한다.
- ④ 甲이 자신의 양돈업 운영을 丙에게 임차해 준 경우, 乙은 甲의 금전반환채무의 불이행을 이유로 양도담보권을 실행하여 丙에게 돼지의 인도를 구할 수 있으며 사용료 상당의 금액도 손해배상으로 청구할 수 있다.
- ⑤ 丙이 담보목적물인 돼지에 대하여 불법한 침해행위를 하는 경우 甲과 乙 모두 丙에 대해 침해행위의 중지를 청구할 수 있다.

해설

- ④ 양도담보 목적물의 사용·수익권은 설정자 甲에게 있고 이로부터 양도업 운영을 적법하게 임차한 임차인 丙에게도 사용·수익권이 있으므로 채권자 乙이 금전반환채무의 불이행을 이유로 돼지의 인도를 청구할 때에 사용료 상당의 금액은 청구할 수 없다.
- ① 대법원 1996.9.10. 96다25463
- ② 별도의 자금을 투입하여 반입한 돼지에는 양도담보권의 효력이 미치는 기존의 물건이 아니다(대법원 2004.11.12. 2004다22858).
- ③ 금전채무자 甲이 그 소유의 동산을 채권자 乙에게 양도하되 점유개정의 방법으로 인도하고 채무자가 이를 계속 점유하기로 약정한 경우, 대외적인 관계에서의 채무자 甲은 동산의 소유권을 이미 채권자 乙에게 양도한 무권리자가 되는 것이어서 다시 다른 채권자 丙과의 사이에 양도담보설정계약을 체결하고 점유개정의 방법으로 인도하더라도 나중에 설정계약을 체결한 채권자 丙은 양도담보권을 취득할 수 없다. 그리고 현실의 인도가 아닌 점유개정의 방법으로는 선의취득이 인정되지 아니하므로 결국 후의 채권자 丙은 적법하게 양도담보권을 취득할 수 없는 것이다(대법원 2005.2.18. 2004다37430).
- ⑤ 양도담보설정자 甲은 물건인 담보물권자로서 물건적 방해제거청구권을 행사할 수 있으며, 양도담보권자는 대외적인 소유자로서 소유권에 기한 방해제거청구권을 행사할 수 있다(신탁적 소유권이 전설에 입각). 정답: ④

75

乙은 자기 소유의 돼지 1천 마리를 甲에게 유동집합물로서 점유개정의 방식으로 양도담보한 후 계속 사육하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲의 양도담보권의 효력은 원칙적으로 위 돼지들이 출산한 새끼돼지들에도 미친다.
- ② 만일 화재로 위 돼지들이 폐사하여 乙이 화재보험금청구권을 취득하면, 이에 대해 甲은 양도담보권에 기한 물상대위권을 행사할 수 있다.
- ③ 만일 乙이 위 돼지들을 丙에게 점유개정의 방식으로 인도한다면, 丙은 선의취득을 할 수 없다.
- ④ 만일 乙이 양도담보 사실을 알고 있는 丁에게 위 돼지들을 양도한 후, 丁이 5백 마리의 돼지를 새로 구입하여 반입한 경우, 별도 자금을 투입해 반입한 사실을 증명하면 甲의 양도담보권의 효력은 그 새로 구입한 돼지들에게 미치지 않는다.
- ⑤ 만일 乙이 위 돼지들을 戊에게 점유개정의 방식으로 인도하여 이중으로 양도담보한다면, 戊는 양도담보권을 선의취득한다.

해설

- ⑤ 점유개정에 의한 선의취득은 인정되지 않는다. 정답: ⑤

가등기담보 등에 관한 법률상 가등기담보에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 후순위권리자는 청산기간 동안에는 담보목적부동산의 경매를 청구할 수 없다.
- ② 채무자는 청산기간이 지나기 전이라도 후순위권리자에 대한 통지 후 청산금에 관한 권리를 제3자에게 양도하면 이로써 후순위권리자에게 대항할 수 있다.
- ③ 담보목적물에 대한 사용·수익권은 채무자에게 지급되어야 할 청산금이 있더라도 그 지급 없이 청산기간이 지나면 채권자에게 귀속된다.
- ④ 담보가등기를 마친 부동산이 강제경매를 통해 매각되어도, 담보가등기권리는 피담보채권액 전부를 변제받지 않으면 소멸하지 않는다.
- ⑤ 담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매가 개시된 경우, 담보가등기를 마친 때를 기준으로 담보가등기권리자의 순위가 결정된다.

해설

- ⑤ 담보가등기가 설정된 부동산에 대하여 경매가 개시된 경우에, 담보가등기권리자는 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리가 있다. 이 경우 그 순위에 관하여는 그 담보가등기권리를 저당권으로 보고, 그 담보가등기가 설정된 때에 그 저당권의 설정등기가 된 것으로 본다.
- ① 후순위권리자는 청산기간에 한정하여 그 피담보채권의 변제기 도래 전이라도 담보목적부동산의 경매를 청구할 수 있다(가등기담보 등에 관한 법률 제12조 제2항).
- ② 채무자가 청산기간이 지나기 전에 한 청산금에 관한 권리의 양도나 그 밖의 처분은 이로써 후순위권리자에게 대항하지 못한다(가등기담보 등에 관한 법률 제7조 제1항).
- ③ 채무자에게 정당한 청산금을 지급하거나 지급할 청산금이 없는 경우에는 채무자가 그 청산의 통지를 받은 날로부터 2월의 청산기간이 경과하여야 하는 청산절차를 거친 후에야 그 가등기에 기한 본등기를 청구할 수 있는데, 위 각 규정을 위반하여 담보가등기에 기한 본등기가 이루어진 경우에는 그 본등기는 무효이다(대법원 2010.11.09. 자2010마1322).
- ④ 담보가등기를 마친 부동산에 대하여 강제경매 등이 행하여진 경우에는 담보가등기권리는 그 부동산의 매각에 의하여 소멸한다. 정답: ⑤